

جامعة الأزهر
قطاع الشريعة والقانون
قسم الفقه

دراسات فقهية على مذهب الشافعية

مقرر الفرقة الثالثة بكليات الشريعة والقانون
وما يناظرها من أقسام الشريعة بكليات الدراسات الإسلامية والعربية
(النص والموضوعي)

١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣/٢٠٢٤ م

أولاً: مقرر الدراسة النصية للفرقة الثالثة
من كتاب: شرح الإمام جلال الدين المحلى
على متن منهاج الطالبين للشيخ محي الدين النووي

تعليق:

- ١- أ.د/ أحمد برج أستاذ الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
- ٢- د/ غنيمي عبد الستار أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور
- ٣- د/ إسماعيل الشنيدى أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا
- ٤- د/ خالد عمارة أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا
- ٥- د/ هشام الجنائني أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا

مراجعة

أ.د/ محمد أبو زيد الأمير

أ.د/ نصر فريد واصل

أستاذ الفقه ومفتي الديار المصرية سابقا أستاذ الفقه ونائب رئيس الجامعة سابقا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب الوصايا

جَمْعُ وَصِيَّةٍ بِمَعْنَى إِيصَاءٍ ^(١) وَتَتَحَقَّقُ ^(٢) بِمُوصٍ، وَمُوصَى لَهُ وَمُوصَى بِهِ، وَصِيَّةٌ كَقَوْلِهِ أَوْصَيْتُ لِلْفُقَرَاءِ ثُلْثَ مَالِي أَيْ تَبَرَّعْتُ لَهُمْ بِهِ بَعْدَ مَوْتِي، وَبَدَأَ الْمُصْتَفِ بِالْمُوصِي ^(٣) فَقَالَ: (تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ مُكَلَّفٍ ^(٤) حُرٍّ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا) ^(٥) هُوَ صَادِقٌ بِالذِّمِّيِّ، وَبِهِ عَبَّرَ فِي الْوَسِيطِ ^(٦) وَبِالْحَرْبِيِّ صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرِدِيُّ ^(٧) (وَكَذَا مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفْهِ) هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الضَّابِطِ فَتَصِحُّ وَصِيَّتُهُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) ^(٨) وَالطَّرِيقُ الثَّانِي قَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا لَا تَصِحُّ لِلْحَجَرِ عَلَيْهِ، فَالْسَّفِيهِ بِلَا حَجَرٍ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ جَزْمًا وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ بِالْفَلَسِ تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ كَمَا ذَكَرَ فِي بَابِهِ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا. (لَا مَجْنُونٌ وَمُعْمَى عَلَيْهِ وَصَبِيٌّ) ^(٩) أَيْ لَا تَصِحُّ وَصِيَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ. (وَفِي قَوْلٍ تَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ مُمَيَّزٍ ^(١٠) لِتَعْلُقِهَا بِالْمَوْتِ ^(١١) بِخِلَافِ الْهَبَةِ

(١) واشتقاقها من: وصى يصي، أي: وصل يصل: لأن الموصي وصل ما كان في حياته بما عبد مماته، أو أنه وصل خير دنياه بخير عقباه، والفعل منها: أوصى يوصي إيصاء، والاسم: وصية ووصاية، وجمع الوصية: وصايا، كهدية وهدايا، وعرية وعرايا.

وهي في الشرع: تبرع بحق - أو تفويض تصرف خاص - مضاف إلى ما بعد الموت. ينظر: نهاية المطلب في دراية المذهب ٤١٢/٨

والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} [النساء: ١٢] وأخبار كخبر الصحيحين «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده» أي ما الحزم أو ما المعروف من الأخلاق إلا هذا فقد يفجؤه الموت وكخبر ابن ماجه «المحروم من حرم الوصية من مات على وصية مات على سبيل وسنة وتقى وشهادة ومات مغفورا له»

حكمها: كانت أول الإسلام واجبة للأقارب بقوله تعالى {كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية} [البقرة: ١٨٠] الآية ثم نسخ وجوبها بآيات الموارث وبقي استحبابها في الثلث فأقل لغير الوارث الغرر

الهيئة ٢/٤

(٢) أركانها أربعة: الركن الأول: مُوصٍ، الركن الثاني: مُوصَى لَهُ، الركن الثالث: مُوصَى بِهِ، الركن الرابع: صيغة

(٣) بدأ بذكر الركن الأول: المُوصي

(٤) يشترط في الموصي التكليف بأن يكون بالغاً عاقلاً مختاراً حراً

(٥) فتصح من الكافر لعوم آية الوصية والأخبار، وبالقياص على الإعتاق والتملك، وهما يصحان من الذمي والحربي، فكذلك الوصية تصح منهما، وتصح وصية الكافر بما تصح به وصية المسلم

(٦) أي الإمام الغزالي في كتابه الوسيط

(٧) في كتابه الحاوي الكبير

(٨) لصحة عبارته، واحتياجه إلى الثواب، وفقدان المعنى الذي لأجله حجر عليه، وبديل وقوع طلاقه وقبول إقراره بالعقوبات

(٩) شرع في بيان محترزات الركن الأول فقال لا تصح الوصية من الصبي والمجنون والمكره والعبد

(١٠) أما غَيْرُ الْمُمَيَّزِ فَلَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ جَزْمًا

(١١) وَلَئِنْهَا لَا تُزِيلُ مِلْكُهُ فِي الْحَالِ، وَتُفِيدُ الثَّوَابَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَأَقْبَلَهُمْ كَلَامُهُ أَنَّ غَيْرَ الْمُمَيَّزِ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ جَزْمًا،

وَالْإِعْتَاقِ، (وَلَا رَقِيقٍ) أَيْ لَا تَصِحُّ وَصِيَّتُهُ، (وَقِيلَ إِنَّ عَتَقَ ثُمَّ مَاتَ صَحَّتْ) لِإِمْكَانِ تَنْفِيزِهَا، وَالْمَكَاتِبُ كَالرَّقِيقِ.

(وَإِذَا أَوْصَى لِجَهَةٍ عَامَّةٍ فَالْشَّرْطُ أَنْ لَا تَكُونَ مَعْصِيَةً كَعِمَارَةِ كَنِيسَةٍ) ^(١) مِنْ كَافِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَلَا تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لَهَا ^(٢)، وَتَصِحُّ لِغَيْرِهَا مِنْ قُرْبَاهِ، وَجَائِزِ كَعِمَارَةِ مَسْجِدٍ، وَفِكَ أَسْرَى الْكُفَّارِ مِنْ أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ (أَوْ) أَوْصَى (لِلشَّخْصِ) ^(٣) أَيْ مُعَيَّنٍ كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ وَغَيْرِهِ (فَالشَّرْطُ أَنْ يُتَصَوَّرَ لَهُ الْمِلْكُ) ^(٤) فَتَصِحُّ لِحَمَلٍ وَتُنْقَذُ بِالْمُعْجَمَةِ (إِنْ انفَصَلَ حَيًّا وَعَلِمَ وُجُودُهُ عِنْدَهَا) أَيْ الْوَصِيَّةِ (بِأَنْ انفَصَلَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنْهَا (فَإِنْ انفَصَلَ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ) مِنْهَا (وَالْمَرْأَةُ فِرَاشُ زَوْجٍ) ^(٥) أَوْ سَيِّدٍ لَمْ يَسْتَحَقِّ (الْمَوْصَى بِهِ لِاحْتِمَالِ خُدُوثِهِ بَعْدَ الْوَصِيَّةِ، وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ عِنْدَهَا وَلَا مَوْلَاةٌ بِنَقْصِ مُدَّةِ الْحَمْلِ فِي ذَلِكَ عَنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ. ^(٦) الْمُبْهَمِينَ الْوُطْءَ وَالْعِلْوَانَ أَخْذًا مِمَّا ذُكِرَ (فَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِرَاشًا وَانْفَصَلَ لِأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ فَكَذَلِكَ) لَمْ يَسْتَحَقِّ لِعَدَمِهِ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ. ^(٧) (أَوْ لِدُونِهِ) أَيْ دُونَ الْأَكْثَرِ (اسْتَحَقَّ فِي الْأَظْهَرِ) ^(٨)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ وَجُودُهُ عِنْدَ الْوَصِيَّةِ، وَالثَّانِي ^(٩) لَا يَسْتَحَقُّ لِاحْتِمَالِ خُدُوثِهِ بَعْدَهَا، وَاعْتِبَارُ هَذَا الْإِحْتِمَالِ فِيمَا تَقَدَّمَ؛ لِمُوَافَقَتِهِ فِيهِ لِلْأَصْلِ وَيَقْبَلُ الْوَصِيَّةَ لِلْحَمْلِ مَنْ يَلِي أَمْرَهُ بَعْدَ خُرُوجِهِ حَيًّا ^(١٠)

(وَإِنْ أَوْصَى لِعَبْدٍ فَاسْتَمَرَ رِقُّهُ فَالْوَصِيَّةُ لِسَيِّدِهِ) أَيْ تُحْمَلُ عَلَى ذَلِكَ لِتَصِحَّ وَيَقْبَلَهَا الْعَبْدُ دُونَ السَّيِّدِ؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ مَعَهُ، وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى إِذْنِ السَّيِّدِ ^(١١) فِي الْأَصَحِّ ^(١٢) (فَإِنْ عَتَقَ قَبْلَ

(١) شَرَعَ فِي بَيَانِ الرُّكْنِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَوْصَى لَهُ فَقَالَ إِذَا أَوْصَى لِجَهَةٍ عَامَّةٍ فَيَشْتَرِطُ فِيهَا أَنْ لَا تَكُونَ فِي مَعْصِيَةِ

(٢) إِنْشَاءً أَوْ تَرْمِيمًا وَلَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ لِلْعِبَادَةِ أَمَا إِذَا كَانَتِ الْكَنِيسَةُ لِلسَّكَنِ بَحِثْ يَسْكُنُهَا أَهْلُ الذِّمَّةِ وَالْمَارَةِ فَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ

(٣) سِوَاءِ أَكَانَ شَخْصًا وَاحِدًا أَمْ أَشْخَاصًا مُتَعَدِّدِينَ

(٤) أَنْ يَكُونَ أَهْلًا لِلتَّمْلِكِ عِنْدَ مَوْتِ الْمَوْصِي وَمَنْ ثَمَّ فَتَصِحُّ لِلْحَمْلِ الْمَوْجُودِ وَقْتَ الْوَصِيَّةِ

(٥) أَيْ أَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ حَقِيقَةً

(٦) لِأَنَّ أَقْلَ مَدَّةِ الْحَمْلِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ

(٧) بِنَاءً عَلَى أَنَّ أَكْثَرَ مَدَّةِ الْحَمْلِ أَرْبَعُ سِنَوَاتٍ

(٨) قَوْلُ لِلْإِمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مُشْعَرُ بَطْنُورٍ مُقَابِلَهُ لِقُوَّةِ مُدْرَكِهِ

(٩) مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ

(١٠) أَيْ الْوَلِيُّ الْمُسْتَوْلُ عَنْهُ

(١١) هَذَا إِذَا كَانَ الْعَبْدُ أَهْلًا لِقَبُولِ الْوَصِيَّةِ وَإِلَّا قَبَلَ السَّيِّدُ

(١٢) أَحَدُ الْوَجْهَيْنِ أَوَّلُ الْأَوْجِهَةِ لِلْأَصْحَابِ يَسْتَخْرِجُونَهَا مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَشْعُرُ بِقُوَّةِ مُقَابِلِهِ

مَوْتِ الْمُوصِي فَلَهُ) الْوَصِيَّةُ؛ لِأَنَّهُ وَقَّتِ الْقَبُولَ حُرًّا. (وَأِنْ عَتَقَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بُنِيَ عَلَى أَنَّ الْوَصِيَّةَ بِمِثْلِكَ) ^(١) إِنْ قُلْنَا بِالْمَوْتِ بِشَرْطِ الْقَبُولِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَلِلْسَيِّدِ أَوْ بِالْقَبُولِ بَعْدَ الْمَوْتِ فَلِلْعَبْدِ وَتَقَدَّمَ أَنَّ الْوَقْفَ عَلَى الْعَبْدِ لِنَفْسِهِ لَا يَصِحُّ فَيَأْتِي مِثْلُهُ فِي الْوَصِيَّةِ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ ^(٢) (وَأِنْ وَصَّى لِذَاتِيَّةٍ وَقَصَدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَقَ فَبَاطِلَةٌ) وَتَقَدَّمَ فِي الْوَقْفِ الْمَطْلُوقُ عَلَيْهَا حِكَايَةً وَجْهٌ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى

مَالِكِهَا قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَيُشَبَّهُ أَنْ يَأْتِيَ فِي الْوَصِيَّةِ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْوَصِيَّةَ تَمْلِيكَ مَحْضٌ فَيَنْبَغِي أَنْ تُضَافَ إِلَى مَنْ يَمْلِكُ، قَالَ فِي الرَّوْضَةِ ^(٣) الْفَرَقُ أَصَحُّ. (وَأِنْ قَالَ لِيُصْرَفَ فِي عَافِيَا فَالْمَنْقُولُ صِحَّتْهَا) ؛ لِأَنَّ عَافِيَا عَلَى مَالِكِهَا، فَهُوَ الْمَقْصُودُ بِالْوَصِيَّةِ فَيُشْتَرَطُ قَبُولُهُ، وَيَتَعَيَّنُ الصَّرْفُ إِلَى جِهَةِ الذَّاتِيَّةِ رِغَايَةً لِعَرَضِ الْمُوصِي، وَقَوْلُهُ فَالْمَنْقُولُ أَشَارَ بِهِ إِلَى مَا فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا ^(٤) أَنَّهُ يُحْتَمَلُ مَجِيءُ وَجْهِهِ بِالْبُطْلَانِ مِنَ الْوَقْفِ عَلَى عَافِيَا

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ) وَمَصَالِحِهِ (وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ) الْوَصِيَّةُ لِلْمَسْجِدِ تَصِحُّ (فِي الْأَصَحِّ وَتُحْمَلُ عَلَى عِمَارَتِهِ وَمَصَالِحِهِ) وَالثَّانِي ^(٥) تَبْطُلُ كَالْوَصِيَّةِ لِلذَّاتِيَّةِ ^(٦) فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ تَمْلِيكَ الْمَسْجِدِ فَقِيلَ: تَبْطُلُ الْوَصِيَّةُ، وَبَحَثَ الرَّافِعِيُّ صِحَّتَهَا بِأَنَّ لِلْمَسْجِدِ مِلْكًا وَعَلَيْهِ وَقَفًا قَالَ ^(٧) فِي الرَّوْضَةِ هَذَا هُوَ الْأَفْقَهُ وَالْأَرْجَحُ

(و) تَصِحُّ (لِذِمِّيٍّ) كَالصَّدَقَةِ عَلَيْهِ (وَكَذَا حَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ فِي الْأَصَحِّ) كَالذِمِّيِّ وَالثَّانِي لَا إِذْ يُقْتَلَانِ ^(٨) (وَقَاتِلٍ فِي الْأَظْهَرِ) ^(٩) كَالْهَبَةِ وَسَوَاءٌ كَانَ بِحَقِّ أَمٍ بِغَيْرِهِ، وَالثَّانِي كَالْإِزْثِ، وَصُورَتُهَا أَنْ يُوصِيَ لِرَجُلٍ فَيُقْتَلُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَتْلُ سَيِّدِ الْمُوصِي لَهُ الْمُوصِي؛ لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ لِلْعَبْدِ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ كَمَا تَقَدَّمَ

(١) اختلفوا في تملك الوصية فقيل: تملك بالموت بشرط القبول وهو الأظهر، وقيل: تملك بالقبول بعد الموت

(٢) قاله إمام الحرمين الجويني في كتابه نهاية المطلب

(٣) قاله الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين

(٤) العزيز شرح الوجيز للإمام الرافعي

(٥) مقابل الأصح

(٦) لأنها لا تملك

(٧) الإمام النووي

(٨) أي يجوز قتلها ولكن ذلك راجع إلى الإمام وليس لأحد الناس

(٩) أي لا تبطل الوصية إذا قام الموصي له بقتل الموصي قياسا على الهبة، ومقابل الأظهر تبطل قياسا على الإرث

(و) تَصِحُّ (لِوَارِثٍ فِي الْأَظْهَرِ إِنْ أَجَازَ بَاقِيَ الْوَرِثَةِ) بِخِلَافِ مَا إِذَا رَدُّوا، وَالثَّانِي لَا تَصِحُّ لَهُ، وَعَلَى الْأَوَّلِ ^(١) الْإِجَازَةُ تَنْفِيزٌ لِلْوَصِيَّةِ. (وَلَا عِبْرَةٌ بِرَدِّهِمْ وَإِجَازَتِهِمْ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي) فَلَمَنْ رَدَّ فِي الْحَيَاةِ الْإِجَازَةُ بَعْدَ الْوَفَاةِ وَالْعَكْسُ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَهَا. (وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهِ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْتِ) أَيَّ بِوَقْتِهِ

(وَالْوَصِيَّةُ لِلْكَلِّ وَارِثٍ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ^(٢) لَعَوُ) ؛ لِأَنَّهُ يُسْتَحَقُّ بِلَا وَصِيَّةٍ (وَبَعَيْنٍ هِيَ قَدْرُ حِصَّتِهِ صَحِيحَةٌ وَتَفْتَقِرُ إِلَى الْإِجَازَةِ فِي الْأَصَحِّ) لِاخْتِلَافِ الْأَعْرَاضِ فِي الْأَعْيَانِ، وَالثَّانِي لَا تَفْتَقِرُ

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِالْحَمْلِ ^(٣)) وَيُشْتَرَطُ انْفِصَالُهُ حَيًّا لَوْقَتِ يُعْلَمُ وَجُودُهُ عِنْدَهَا) وَيَقْبَلُهَا الْمُوصَى لَهُ قَبْلَ الْوَضْعِ، إِنْ قُلْنَا: الْحَمْلُ يُعْلَمُ (وَبِالْمَنَافِعِ) ^(٤) كَالْأَعْيَانِ (وَكَذَا بِثَمَرَةٍ أَوْ حَمْلٍ سَيَخْدُثَانِ فِي الْأَصَحِّ) ^(٥) وَالثَّانِي لَا لِعَدَمِهِمَا الْآنَ (و) تَصِحُّ (بِأَحَدِ عَبْدَيْهِ) ^(٦) وَيُعِينُهُ الْوَارِثُ (وَبِنَجَاسَةٍ يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهَا كَكَلْبٍ مُعْلَمٍ وَزَيْلٍ وَخَمْرٍ مُحْتَرَمَةٍ) لِثُبُوتِ الْإِخْتِصَاصِ فِيهَا بِخِلَافِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ وَالْخَنَزِيرِ. ^(٧)

(وَلَوْ أَوْصَى بِكَلْبٍ مِنْ كِلَابِهِ) أَيُّ الْمُتَنَفِّعِ بِهَا فِي صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ (أَعْطَى) لِلْمُوصَى لَهُ (أَحَدَهَا) بِتَعْيِينٍ فَالْوَارِثُ (إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ كَلْبٌ) مُتَنَفِّعٌ بِهِ (لَعَثَ) وَصِيَّتُهُ (وَلَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ وَكِلَابٌ) مُتَنَفِّعٌ بِهَا (وَوَصَّى بِهَا أَوْ بِبَعْضِهَا فَلَا أَصَحَّ نَفُودُهَا) أَيُّ الْوَصِيَّةِ (وَأِنْ كَثُرَتْ) أَيُّ الْكِلَابِ الْمُوصَى بِهَا. (وَقَلَّ الْمَالُ) ؛ لِأَنَّهُ خَيْرٌ مِنْهَا؛ إِذْ لَا قِيَمَةَ لَهَا، وَالثَّانِي لَا تَنْفُذُ إِلَّا فِي

(١) أي القول الأول: أنه تصح الوصية للوارث إذا أجازها باقي الورثة

(٢) في الميراث

(٣) شرع في الركن الثالث وهو الموصى به، وقال بأنه يشترط كونه مقصوداً بحل الانتفاع به وقبيل النفل فلا تصح بما لا يقصد كدم، ولا بما لا يحل الانتفاع به كميزمار، ولا بما لا يقبل النفل كقصاص، وحق الشفعة - إذا لم يبطل بالتأخير لغدر كتأجيل الثمن - وحيد قذف وإن قبلت الانتفال بالإنز لا لأنها لا تقبل النفل

(٤) أي تصح الوصية بالمنافع المباحة

(٥) لأن الوصية أحتمل فيها وجوه من الغرر وفقاً للناس وتوسعة فتصح بالمعدوم كما تصح بالمجهول؛ ولأن المعدوم يصح تملكه بعقد السلم، والمساقاة والإجارة فكذا بالوصية.

(٦) لأن الوصية تحتمل الجهالة فلا يؤثر فيها الإبهام

(٧) لأنه لا يحل اقتناؤهما ولا الانتفاع بهما

ثُلُثُهَا كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا مَالٌ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ جَنْسِهِ حَتَّى تُضَمَّ إِلَيْهِ، وَالثَّلَاثُ تُقَوَّمُ بِتَقْدِيرِ الْمَالِيَّةِ فِيهَا وَتُضَمُّ إِلَى الْمَالِ، وَتُنْفَذُ الْوَصِيَّةُ فِي ثُلْثِ الْجَمِيعِ أَيَّ فِي قَدْرِهِ مِنْ الْكِلَابِ.

(وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ وَلَهُ طَبْلٌ لَهُوَ وَطَبْلٌ يَحِلُّ الْإِنْتِفَاعُ بِهِ ^(١) كَطَبْلِ حَرْبٍ) يُضْرَبُ بِهِ لِلتَّهْوِيلِ (و) طَبْلٌ (حَجَبِي) يُضْرَبُ بِهِ لِلْإِعْلَامِ بِالنُّزُولِ وَالْإِزْتِحَالِ. (حُمِلَتْ) أَيُّ الْوَصِيَّةِ (عَلَى الثَّانِي) لِتَصِحِّحِ (وَلَوْ أَوْصَى بِطَبْلٍ اللَّهْوِ) وَهُوَ مَا يَضْرَبُ بِهِ الْمُخَنَّثُونَ، وَسَطُهُ ضَيْقٌ وَطَرَفَاهُ وَاسِعَانِ (لَعَثَ إِلَّا إِنْ صَلَحَ لِحَرْبٍ أَوْ حَجَبِي) بِهِيَّتِهِ أَوْ بِأَنْ يُعَيَّرَ فَتَصِحَّ بِهِ. ^(٢)

فَصْلٌ: يَنْبَغِي ^(٣) أَنْ لَا يُوصِي بِأَكْثَرِ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ؛ «لَأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِسَعْدٍ: الثَّلَاثُ، وَالثَّلَاثُ كَثِيرٌ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ ^(٤) وَالزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ قَالَ الْمُتَوَلَّى وَغَيْرُهُ مَكْرُوهَةٌ، وَالْقَاضِي حُسَيْنٌ وَغَيْرُهُ مُحَرَّمَةٌ، وَالْأَحْسَنُ أَنْ يَنْقُصَ مِنَ الثَّلَاثِ شَيْئًا (فَإِنْ زَادَ) الْمُوصِي عَلَى الثَّلَاثِ شَيْئًا. (وَرَدَّ الْوَارِثُ بَطَلَتْ فِي الرَّائِدِ)؛ لِأَنَّهُ حَقُّهُ (وَإِنْ أَجَازَ فَاجَازَتْهُ تَنْفِيزٌ) لِلْوَصِيَّةِ بِالرَّائِدِ. (وَفِي قَوْلٍ عَطِيَّةٌ ^(٥) مُبْتَدَأَةٌ) مِنْهُ (وَالْوَصِيَّةُ بِالزِّيَادَةِ لَعَوٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ خَاصٌّ بَطَلَتْ فِي الرَّائِدِ؛ لِأَنَّ الْحَقَّ ^(٦) لِلْمُسْلِمِينَ فَلَا مُجِيرَ.

(وَيُعْتَبَرُ الْمَالُ) الْمُوصَى بِثُلْثِهِ (يَوْمَ الْمَوْتِ وَقِيلَ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ) ^(٧) وَيَخْتَلِفُ قَدْرُ الثَّلَاثِ بِاخْتِلَافِ قَدْرِ الْمَالِ فِي الْيَوْمَيْنِ (وَيُعْتَبَرُ مِنَ الثَّلَاثِ) الَّذِي يُوصِي بِهِ. (أَيْضًا عَتَقَ غُلَقَ بِالْمَوْتِ) سَوَاءً غُلَقَ فِي الصَّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ (وَتَبَرَّعَ نُجَزَ فِي مَرَضِهِ كَوَفَّ وَهَبَةٍ وَعَتَقَ وَابْرَاءً،

وَإِذَا اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْمَوْتِ ^(٨) وَعَجَزَ الثَّلَاثُ) عَنْهَا (فَإِنْ تَمَحَّضَ الْعَتَقُ) كَأَنَّ قَالَ إِذَا مِتَّ فَأَنْتُمْ أَحْرَارُ (أُقْرِعَ) بَيْنَهُمْ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَتَقَ مِنْهُ مَا بَقِيَ بِالثَّلَاثِ، وَلَا يُعْتَقُ مَنْ

(١) أي جمع في وصيته بين ما تجوز الوصية به وما لا تجوز الوصية به

(٢) أي إن كان فيه منفعة أخرى مباحة صحت الوصية

(٣) أي يندب له

(٤) صحيح البخاري ٣/٤ حديث رقم (٢٧٤٢)، صحيح مسلم ٣/١٢٥٠

(٥) أي هبة جديدة من الوارث فيعتبر فيها شروطها

(٦) في الثلثين

(٧) اختلف فقهاء الشافعية في وقت حساب مقدار الثلث بمعنى: هل المعتبر ثلث المال يوم الوصية أو يوم الممات.

(٨) أي تبرعات متوقفة ومعلقة على الموت

كُلِّ شِقْصٌ (أَوْ غَيْرُهُ) أَي تَمَحَّضَ غَيْرُ الْعَتَقِ (قُسِطَ الثُّلُثُ) عَلَى الْجَمِيعِ فَلَوْ أَوْصَى لِزَيْدٍ بِمِائَةٍ وَلِعَمَرٍو بِخَمْسِينَ وَلِبَكْرٍ بِخَمْسِينَ وَثُلُثُ مَالِهِ مِائَةٌ أُعْطِيَ زَيْدٌ خَمْسِينَ، وَكُلٌّ مِنْ عَمَرٍو وَبَكْرٍ خَمْسَةٌ وَعِشْرِينَ (أَوْ هُوَ) أَي اجْتَمَعَ الْعَتَقُ (وْغَيْرُهُ) كَأَن أَوْصَى بِعَتَقِ سَالِمٍ وَلِزَيْدٍ بِمِائَةٍ (قُسِطَ) الثُّلُثُ عَلَيْهِمَا (بِالْقِيَمَةِ) لِلْمُعْتَقِ فَإِذَا كَانَتْ قِيَمَتُهُ مِائَةً، وَالثُّلُثُ مِائَةً عَتَقَ نِصْفَهُ وَلِزَيْدٍ خَمْسُونَ (وَفِي قَوْلٍ يُقَدِّمُ الْعَتَقُ) فَلَا يَكُونُ لِزَيْدٍ فِي الْمِثَالِ شَيْءٌ (أَوْ) اجْتَمَعَ تَبَرُّعَاتٌ (مُنْجَرَّةٌ) ^(١) كَأَن أُعْتَقَ وَتَصَدَّقَ وَوَقَّفَ (قَدَّمَ الْأَوَّلَ) مِنْهَا (فَالأَوَّلَ حَتَّى يَتِمَّ الثُّلُثُ) وَيَتَوَقَّفَ مَا بَقِيَ عَنْ إِجَارَةِ الْوَارِثِ (فَإِنْ وَجِدَتْ دُفْعَةٌ) بِضَمِّ الدَّالِ (وَاتَّحَدَ الْجِنْسُ كَعَتَقٍ عَبِيدٍ أَوْ إِبْرَاءٍ جَمْعٍ) كَأَن قَالَ أَعْتَقْتُكُمْ أَوْ أَبْرَأْتُكُمْ (أَقْرَعَ فِي الْعَتَقِ) حَذَرًا مِنْ التَّشْقِيقِ ^(٢) فِي الْجَمِيعِ (وَقُسِطَ فِي غَيْرِهِ) بِالْقِيَمَةِ كَمَا تَقَدَّمَ (وَإِنْ اخْتَلَفَ) الْجِنْسُ (وَتَصَرَّفَ وَكَلَاءٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا عَتَقٌ) كَأَن تَصَدَّقَ وَاحِدٌ، وَوَقَّفَ آخَرُ، وَأَبْرَأَ آخَرُ دُفْعَةً. (قُسِطَ) الثُّلُثُ عَلَيْهَا (وَإِنْ كَانَ) فِيهَا عَتَقٌ (قُسِطَ) الثُّلُثُ عَلَيْهَا أَيْضًا (وَفِي قَوْلٍ يُقَدِّمُ الْعَتَقُ) كَمَا تَقَدَّمَ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا مُنْجَرًّا وَبَعْضُهَا مُعْلَقًا بِالْمَوْتِ قَدَّمَ الْمُنْجَرُّ مِنْهُمَا ^(٣) (لَوْ كَانَ لَهُ عَبْدَانِ فَقَطُّ) أَي لَا ثَالِثَ لَهُمَا (سَالِمٌ وَغَانِمٌ فَقَالَ إِنْ أَعْتَقْتُ غَانِمًا فَسَالِمٌ حُرٌّ ثُمَّ أَعْتَقَ غَانِمًا فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ) وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الثُّلُثِ إِلَّا أَحَدُهُمَا فَقَطُّ. (عَتَقَ) غَانِمٌ فَقَطُّ. وَلَا إِقْرَاعَ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَخْرُجَ الْقِرْعَةُ بِالْحُرِّيَةِ لِسَالِمٍ، فَيَلْزَمُ إِزْقَاقُ غَانِمٍ فَيَفُوتُ شَرْطُ عَتَقِ سَالِمٍ، وَلَوْ خَرَجَا مِنَ الثُّلُثِ مِثْلًا.

(وَلَوْ أَوْصَى بِعَيْنٍ حَاضِرَةٍ هِيَ ثُلُثُ مَالِهِ، وَبَاقِيهِ غَائِبٌ لَمْ تُدْفَعْ كُلُّهَا إِلَيْهِ فِي الْحَالِ) لِاحْتِمَالِ تَلَفِ الْغَائِبِ ^(٤). (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الثُّلُثِ مِنْهَا ^(٥) أَيْضًا) ؛ لِأَنَّ الْوَارِثَ لَا يَتَسَلَّطُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ مِنْهَا، لِاحْتِمَالِ سَلَامَةِ الْغَائِبِ، وَالثَّانِي يُقَطِّعُ النَّظَرَ عَنْ الْوَارِثِ.

(١) أي تبرعات منجزة وحالة

(٢) الشَّقْصُ الْجُزْءُ مِنَ الشَّيْءِ وَالنَّصِيبُ وَالشَّقِيقُ مِثْلُهُ وَمِنْهُ التَّشْقِيقُ: التَّجْزِئَةُ

(٣) أي جمع في الوصية بين تبرعات منجزة وأخرى معلقة

(٤) فَلَا يَخْصُلُ لَوَرَثَةٍ مِثْلًا مَا حَصَلَ لِلْمَوْصَى لَهُ

(٥) أي من تلك العين

فَصْلٌ ^(١): إِذَا ظَنَّنَا الْمَرَضَ مَخُوفًا أَيْ يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ ^(٢) (لَمْ يُنْفَذْ تَبَرُّعُ زَادَ عَلَى الثَّلَاثِ؛ لِأَنَّهُ مَخْجُورٌ عَلَيْهِ فِي الزِّيَادَةِ (فَإِنْ بَرَأَ) بِفَتْحِ الرَّاءِ (نُفَذَ) لِتَبَيُّنِ عَدَمِ الْحَجْرِ (وَإِنْ ظَنَّنَاهُ ^(٣) غَيْرَ مَخُوفٍ فَمَاتَ فَإِنْ حُمِلَ عَلَى الْفُجَاءَةِ) بِضَمِّ الْفَاءِ وَالْمَدِّ وَبِفَتْحِهَا وَسُكُونِ الْجِيمِ. (نُفَذَ وَإِلَّا) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَيْهَا ^(٤) (فَمَخُوفٌ)

(الْمَخُوفُ قَوْلُنْجُ) ^(٥) بِفَتْحِ اللَّامِ وَكَسْرِهَا وَهُوَ أَنْ تَنْعَقِدَ أَخْلَاطُ الطَّعَامِ فِي بَعْضِ الْأَمْعَاءِ، فَلَا تَنْزِلَ وَيَصْعَدُ بِسَبَبِهِ الْبُخَارُ إِلَى الدِّمَاغِ فَيُؤَدِّي إِلَى الْهَلَاكِ. (وَدَاثُ جَنْبٍ) وَهِيَ قُرُوحٌ تَحْدُثُ فِي دَاخِلِ الْجَنْبِ بِوَجَعٍ شَدِيدٍ ثُمَّ تَنْفَتِحُ فِي الْجَنْبِ، وَيَسْكُنُ الْوَجَعُ، وَذَلِكَ وَقْتُ الْهَلَاكِ (وَرُعَافٌ) ^(٦) بِتَثْنِيتِ الرَّاءِ (دَائِمٌ)؛ لِأَنَّهُ يُسْقِطُ الْقُوَّةَ بِخِلَافِ غَيْرِ الدَّائِمِ (وَإِسْهَالٌ مُتَوَاتِرٌ)؛ لِأَنَّهُ يُنَشِفُ رُطُوبَاتِ الْبَدَنِ بِخِلَافِ غَيْرِ الْمُتَوَاتِرِ كَأَنْ يَنْقَطِعَ بَعْدَ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ (وَدِيقٌ) بِكَسْرِ الدَّالِ وَهُوَ دَاءٌ يُصِيبُ الْقَلْبَ، وَلَا تَمْتَدُّ مَعَهُ الْحَيَاةُ غَالِبًا (وَإِبْتِدَاءُ فَالِجٍ) ^(٧) بِخِلَافِ اسْتِمْرَارِهِ وَسَبَبُهُ غَلَبَةُ الرُّطُوبَةِ، وَالْبُلْغَمِ فَإِذَا هَاجَ رُبَّمَا أَطْفَأَ الْحَرَارَةَ الْغَرِيزِيَّةَ وَأَهْلَكَ. (وَخُرُوجُ الطَّعَامِ غَيْرُ مُسْتَحِيلٍ) ^(٨) بِأَنْ تَنْخَرِقَ الْبُطْنُ فَلَا يُمْكِنُهُ الْإِمْسَاكُ. (أَوْ كَانَ يَخْرُجُ بِشِدَّةٍ وَوَجَعٍ أَوْ وَمَعَهُ دَمٌ) أَيْ مِنْ غُضُوِّ شَرِيفٍ كَكَبِدٍ بِخِلَافِ دَمِ الْبَوَاسِيرِ وَذَكَرَ كَانَ مَعَ الْمُضَارِعِ ^(٩) لِإِفَادَةِ التَّكَرَّرِ كَمَا فِي قَوْلِهِمْ كَانَ حَاتِمٌ يُكْرِمُ الضَّيْفَ. (وَحُمَى مُطَبَّقَةٌ) بِكَسْرِ الْبَاءِ أَيْ لَازِمَةٌ لَا تَبْرَحُ (أَوْ غَيْرُهَا) كَالْوَرْدِ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي كُلَّ يَوْمٍ، وَالْغَيْبُ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا وَتَقْلَعُ يَوْمًا، وَالثَّلَاثُ وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتَقْلَعُ يَوْمًا وَحُمَى الْأَخْوَيْنِ، وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمَيْنِ وَتَقْلَعُ يَوْمَيْنِ. (إِلَّا الرَّبْعُ) وَهِيَ الَّتِي تَأْتِي يَوْمًا، وَتَقْلَعُ يَوْمَيْنِ، فَلَيْسَتْ مَخُوفَةً؛ لِأَنَّ الْمَحْمُومَ بِهَا يَأْخُذُ قُوَّةً مِنْ يَوْمِي الْإِفْلَاحِ، وَالْحُمَى الْيَسِيرَةُ لَيْسَتْ مَخُوفَةً بِحَالٍ، وَالرَّبْعُ

(١) شرع في بيان المرض المخوف والمُلتحق به

(٢) يُخَافُ مِنْهُ الْمَوْتُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَالِبُ مِنْهُ الْمَوْتُ

(٣) أي المرض

(٤) أي على الفُجَاءَةِ

(٥) شرع في بيان بعض الأمراض المخوفة

(٦) الدم الذي يخرج من الأنف

(٧) وَهُوَ اسْتِزْخَاءُ أَحَدِ شَقِي الْبَدَنِ طَوْلًا، وَيُطْلَقُ أَيْضًا عَلَى اسْتِزْخَاءِ أَيِ غُضُوِّ كَانَ

(٨) أي غير مهضوم بأن يخرج طعاما كما هو

(٩) أي ذكر الفعل المضارع مع استعمال للفعل كان في قوله (كَانَ يَخْرُجُ)

وَالْتُلْتُ وَالْعَبُّ وَالْوَرْدُ بِكُسْرِ أَوَّلِهَا. (وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يَلْحَقُ بِالْمَخُوفِ ^(١) أَسْرُ كُفَّارٍ اعْتَادُوا قَتْلَ الْأَسْرَى، وَالتَّحَامُ قِتَالٌ بَيْنَ مُتَكَافِئَيْنِ وَتَقْدِيمٌ لِقِصَاصٍ أَوْ رَجْمٍ وَاضْطِرَابُ رِيحٍ وَهَيَجَانٌ مُوجٍ فِي زَاكِبٍ سَفِينَةٍ وَطَلْقُ حَامِلٍ، وَبَعْدَ الْوَضْعِ مَا لَمْ تَنْفَصِلِ الْمَشِيمَةُ ^(٢) وَهِيَ الَّتِي تُسَمِّيهَا النِّسَاءُ الْخِلَاصَ؛ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَحْوَالَ تَسْتَعْقِبُ الْهَلَاكَ غَالِبًا، وَوَجْهُ عَدَمِ إلْحَاقِهَا بِالْمَرَضِ أَنَّهُ لَمْ يُصَبِّ بَدَنَ الْإِنْسَانِ فِيهَا شَيْءٌ، وَالْخِلَافُ فِي مَسْأَلَةِ الطَّلْقِ إِلَى آخِرِهَا قَوْلَانِ وَفِيمَا قَبْلَهَا طَرِيقَانِ حَاكِيَةٌ لِقَوْلَيْنِ وَقَاطِعَةٌ فِي التَّقْدِيمِ لِقِصَاصٍ بَعْدَ الْإِلْحَاقِ، وَفِي غَيْرِهِ بِالْإِلْحَاقِ كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِيهِمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ مُسْتَحَقَّ الْقِصَاصِ لَا تَبْعُدُ مِنْهُ الرَّحْمَةُ، وَالْعَفْوُ طَمَعًا فِي الثَّوَابِ أَوْ أَمَالٍ وَلَا خَوْفٍ فِي أَسْرٍ مَنْ لَمْ يَعْتَدِ قَتْلَ الْأَسْرَى كَالرُّومِ، وَلَا فِيمَا إِذَا لَمْ يَلْتَحِمِ الْقِتَالُ، وَإِنْ كَانَ يَتَرَامِيَانِ بِالنَّشَابِ ^(٣)، وَالْحِرَابِ، وَلَا فِي الْفَرِيقِ الْغَالِبِ، وَلَا فِيمَا إِذَا كَانَ الْبَحْرُ سَاكِنًا وَقَوْلُهُ: " مُتَكَافِئَيْنِ " الْمَزِيدُ عَلَى الْمُحَرَّرِ ^(٤) قَالَ فِي الرُّوضَةِ سَوَاءٌ كَانَا مُسْلِمَيْنِ أَوْ كُفَّارًا أَوْ مُسْلِمَيْنِ وَكُفَّارًا

(وَصَيغَتُهَا) ^(٥) أَيِ الْوَصِيَّةِ (أَوْصَيْتَ لَهُ بِكَذَا أَوْ اذْفَعُوا إِلَيْهِ) بَعْدَ مَوْتِي كَذَا (أَوْ أَعْطُوهُ بَعْدَ مَوْتِي) كَذَا (أَوْ جَعَلْتَهُ لَهُ) بَعْدَ مَوْتِي (أَوْ هُوَ لَهُ بَعْدَ مَوْتِي فَلَوْ اقْتَصَرَ عَلَى) قَوْلِهِ (هُوَ لَهُ) فَأَقْرَارٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ هُوَ لَهُ مِنْ مَالِي فَيَكُونُ وَصِيَّةً وَفِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا تُجْعَلُ كِنَايَةً عَنِ الْوَصِيَّةِ ^(٦)

(وَتَتَعَدُّ بِكِنَايَةٍ) بِالنُّونِ مَعَ النِّيَّةِ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ ^(٧)، وَغَيْرِهِ إِشْعَارٌ بِأَنَّهُ لَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ فِي الْبَيْعِ وَقَالَ فِي الرُّوضَةِ ^(٨)، بَلَا خِلَافٍ، وَلِذَلِكَ أَسْقَطَ مِنَ الْمُحَرَّرِ ^(٩)

(١) بعد أن ذكر المرض المخوف شرع في بيان الملحق بالمخوف

(٢) الوعاء الذي يخرج مع الولد

(٣) نوع من الأسهم والنشابة: واحدة النشاب. والنشابة: قوم يرمون بالنشاب، ومتخذ النشاب

(٤) كتاب المحرر للإمام الرافعي

(٥) شرع في بيان الركن الرابع وهو الصيغة فقال أنها تنقسم إلى صريحة وكناية

(٦) ولذلك تتوقف على النية

(٧) إمام الحرمين الجويني

(٨) وقال الإمام النووي في كتابه روضة الطالبين

(٩) الإمام الرافعي في كتابه المحرر

قَوْلُهُ فِيهَا الْأَظْهَرُ. (وَالْكِتَابَةُ) بِالتَّاءِ (كِتَابَةٌ) وَإِذَا كُتِبَ وَقَالَ نَوَيْتِ الْوَصِيَّةَ صَحَّتْ ذِكْرُهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ بَحْثًا وَسَكَتَ عَلَيْهِ فِي الرَّوْضَةِ كَمَا هُنَا

(وَإِنْ وَصَّى لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ لَزِمَتْ بِالْمَوْتِ بِلَا قَبُولٍ) ^(١) أَيِّ مِنْ غَيْرِ اشْتِرَاطِهِ وَيَجُوزُ الْإِقْتِسَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ مِنْهُمْ، وَلَا تَجِبُ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ (أَوْ لِمُعَيَّنٍ) كَزَيْدٍ (أُشْتُرِطَ الْقَبُولُ) وَإِنْ كَانَ الْمُعَيَّنُ مُتَعَدِّدًا كَبَنِي زَيْدٍ أُشْتُرِطَ مَعَ الْقَبُولِ اسْتِيعَابُهُمْ، وَالتَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمْ، وَإِنْ كَانَ الْمُتَعَدِّدُ قَبِيلَةً كَبَنِي هَاشِمٍ فَهُمْ كَالْفُقَرَاءِ فِيمَا تَقَدَّمَ.

(وَلَا يَصِحُّ قَبُولُ وَلَا رَدُّ فِي حَيَاةِ الْمُوصِي) ^(٢) فَلَمَنْ قَبَلَ فِي الْحَيَاةِ الرَّدُّ بَعْدَ الْوَفَاةِ، وَالْعَكْسُ إِذْ لَا حَقَّ لَهُ قَبْلَهَا. (وَلَا يُشْتَرِطُ بَعْدَ مَوْتِهِ) أَيُّ الْمُوصِي (الْفُورُ) فِي الْقَبُولِ (فَإِنْ مَاتَ الْمُوصَى لَهُ قَبْلَهُ) أَيُّ قَبْلَ الْمُوصِي (بَطَلَتْ أَوْ بَعْدَهُ) قَبْلَ الْقَبُولِ (فَيَقْبَلُ وَارِثُهُ) أَوْ يَرُدُّ (وَهَلْ يَمْلِكُ الْمُوصَى لَهُ) الْمُعَيَّنُ الْمُوصَى بِهِ. (بِمَوْتِ الْمُوصِي أَمْ بِقَبُولِهِ أَمْ) هُوَ (مَوْقُوفٌ) ^(٣) فَإِنْ قَبَلَ أَنَّهُ مِلْكٌ بِالْمَوْتِ، وَإِلَّا بَانَ لِلْوَارِثِ أَقْوَالٌ أَظْهَرُهَا الثَّالِثُ ^(٤)، وَعَلَيْهَا تُبْنَى الثَّمَرَةُ وَكَسْبُ عَبْدٍ حَصَلًا بَيْنَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ وَنَفَقَتُهُ وَفِطْرَتُهُ بَيْنَهُمَا فَعَلَى الْأَوَّلِ ^(٥) وَالثَّالِثِ لِلْمُوصَى لَهُ الثَّمَرَةُ، وَالْكَسْبُ وَعَلَيْهِ النَّفَقَةُ وَالْفِطْرَةُ، وَعَلَى الثَّانِي ^(٦) لَا وَلَا، وَلَوْ رَدَّ فَعَلَى الْأَوَّلِ لَهُ وَعَلَيْهِ مَا ذَكَرَ، وَعَلَى الثَّانِي وَالثَّالِثِ لَا وَلَا وَعَلَى النَّفْيِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ يَتَعَلَّقُ مَا ذَكَرَ بِالْوَارِثِ. (وَيُطَالِبُ) بِكَسْرِ اللَّامِ أَيُّ الْعَبْدِ (الْمُوصَى لَهُ) بِهِ (بِالنَّفَقَةِ إِنْ تَوَقَّفَ فِي قَبُولِهِ وَرَدَّهِ) فَإِنْ أَرَادَ الْخُلَاصَ رَدَّ.

فَصْلٌ ^(٧) إِذَا (أَوْصَى بِشَاةٍ تَنَاولَ صَغِيرَةَ الْجَنَّةِ وَكَبِيرَتَهَا سَلِيمَةً وَمَعِيْبَةً ضَانًا وَمَغْرًا) لِيَصْدُقَ الْإِسْمُ بِمَا ذَكَرَ (وَكَذَا ذَكَرًا فِي الْأَصَحِّ) وَالْهَاءُ فِي

(١) الوصية إن كانت لمعين لزم القبول وإن كانت لغير معين لا تفتقر إلى القبول

(٢) شرع في بيان وقت قبول الوصية وردها

(٣) شرع في بيان ما تملك به الوصية

(٤) أنه موقوف

(٥) أنها تملك بالموت

(٦) أنها تملك بالقبول

(٧) فصل في أحكام الوصية الصحيحة وتنقسم إلى ثلاثة أقسام: لفظية، ومعنوية، وحسابية.. وقد شرع في بيان

القسم الأول

الشَّاةِ لِلْوَحْدَةِ وَالثَّانِي لَا يَتَنَاوَلُهُ لِلْعُرْفِ. (لَا سَخْلَةً^(١) وَعِنَاقًا^(٢) فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّ الْإِسْمَ لَا يَصْدُقُ بِهِمَا لِصَغَرِ سِنِّهِمَا وَالثَّانِي قَالَ يَصْدُقُ وَالسَخْلَةُ تَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى مِنَ الضَّانِّ، وَالْمَغْزِ وَالْعِنَاقُ الْأُنْثَى مِنَ الْمَغْزِ، وَمِثْلُهَا الذَّكَرُ أَيُّ الْجَدْيِ

(وَلَوْ قَالَ أَعْطُوهُ شَاةً مِنْ غَنَمِي) أَيُّ بَعْدَ مَوْتِي (وَلَا غَنَمٌ لَهُ لَعَتْ) وَصِيَّتُهُ هَذِهِ^(٣) (وَإِنْ قَالَ مِنْ مَالِي) وَلَا غَنَمٌ لَهُ كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ (أُشْتُرِيَتْ لَهُ) شَاةٌ وَإِنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى أَعْطَى شَاةً مِنْهَا أَوْ فِي الثَّانِيَةِ جَازَ أَنْ يُعْطِيَ شَاةً عَلَى غَيْرِ صِفَةِ غَنَمِهِ. (وَالْجَمَلُ وَالنَّاقَةُ يَتَنَاوَلَانِ الْبَخَاتِيَّ)^(٤) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا (وَالْعِرَابُ لَا أَحَدُهُمَا الْآخَرُ) أَيُّ لَا يَتَنَاوَلُ الْجَمَلُ النَّاقَةَ، وَالْعَكْسُ؛ لِأَنَّ الْجَمَلَ لِلذَّكَرِ، وَالنَّاقَةَ لِلْأُنْثَى. (وَالْأَصَحُّ تَنَاوُلُ بَعِيرِ نَاقَةٍ)^(٥) سَمِعَ حَلَبَ بَعِيرَهُ، وَالثَّانِي الْمُنْعُ كَالْجَمَلِ. (لَا بَقَرَةٌ ثَوْرًا) بِالْمُثَلَّثَةِ وَالثَّانِي يَقُولُ الْهَاءُ لِلْوَحْدَةِ (وَالثَّوْرُ لِلذَّكَرِ) مُبْتَدَأٌ وَخَبَرٌ (وَالْمَذْهَبُ حُمْلُ الدَّابَّةِ) وَهِيَ لُغَةٌ مَا يَدْبُ عَلَى الْأَرْضِ. (عَلَى فَرَسٍ وَبَغْلٍ وَحِمَارٍ) كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيُّ لِاشْتِهَارِهَا فِيهَا غُرْفًا فَقِيلَ هَذَا عَلَى غُرْفِ أَهْلِ مِصْرَ، وَإِذَا كَانَ غُرْفُ أَهْلِ غَيْرِهَا، كَالْعِرَاقِ الْفَرَسُ حُمْلٌ عَلَيْهِ وَالْأَصَحُّ الْعَمَلُ بِالنَّصِّ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ، فَهَذَا اخْتِلَافٌ فِي فَهْمِ الْمُرَادِ بِالنَّصِّ يَصِحُّ التَّعْبِيرُ فِيهِ بِالْمَذْهَبِ^(٦) (وَيَتَنَاوَلُ الرَّقِيقَ صَغِيرًا وَأُنْثَى وَمَعِيْبًا وَكَافِرًا وَعُكُوسَهَا) أَيُّ كَبِيرًا وَذَكَرًا وَسَلِيمًا وَمُسْلِمًا (وَقِيلَ إِنْ أَوْصَى بِإِعْتَاقِ عَبْدٍ وَجَبَ الْمُجْزِئُ كَفَّارَةً) بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَ أَعْطُوهُ عَبْدًا (وَلَوْ وَصَّى بِأَحَدٍ رَقِيقِهِ فَمَاتُوا أَوْ قُتِلُوا قَبْلَ مَوْتِهِ بَطَلَتْ) وَصِيَّتُهُ (وَإِنْ بَقِيَ وَاحِدٌ تَعَيَّنَ) لِلْوَصِيَّةِ فَلَيْسَ لِلْوَارِثِ أَنْ يُنْسِكَ، وَيَذْفَعُ قِيَمَةَ مَقْتُولٍ لَهُ وَإِنْ قُتِلُوا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَبُولِ صَرَفَ الْوَارِثُ قِيَمَةَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَوْ بَيْنَهُمَا فَكَذَلِكَ إِنْ قُلْنَا يُمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْمَوْتِ، أَوْ هُوَ مَوْقُوفٌ، وَإِنْ قُلْنَا بِالْقَبُولِ بَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ. (أَوْ بِإِعْتَاقِ رِقَابِ ثَلَاثٍ) ؛ لِأَنَّهُ أَقْلٌ عَدَدٍ يَقَعُ عَلَيْهِ الْإِسْمُ (فَإِنْ عَجَزَ ثُلُثُهُ عَنْهُمْ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَى شَقْصٌ) مَعَ رَقَبَتَيْنِ (بَلْ)

(١) وَهِيَ وَلَدُ الضَّانِّ وَالْمَغْزُ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى مَا لَمْ يَبْلُغْ سَنَةً

(٢) وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ وَلَدِ الْمَغْزِ

(٣) لِعَدَمِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الْوَصِيَّةُ.

(٤) بِتَشْدِيدِ الْيَاءِ وَتَخْفِيفِهَا، وَاحِدًا بِخَيٍّْ وَبُخَيْتَةٍ. وَهِيَ جِمَالٌ طَوَالُ الْأَعْنَاقِ

(٥) لِأَنَّهُ لُغَةٌ اسْمُ جَنْسٍ كَالْإِنْسَانِ.

(٦) الْمَذْهَبُ هُوَ: مِنَ الطَّرِيقَيْنِ أَوْ الطَّرِيقِ وَهِيَ اخْتِلَافُ الْأَصْحَابِ فِي حِكَايَةِ الْمَذْهَبِ كَأَن يَخِي بَعْضُهُمْ فِي الْمَسْأَلَةِ

قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ لِمَنْ تَقَدَّمَ، وَيَقْطَعُ بَعْضُهُمْ بِأَحَدِهِمَا ثُمَّ الرَّاجِحُ الَّذِي عَرَبَتْهُ بِالْمَذْهَبِ

تُشْتَرَى (نَفِيسَتَانِ بِهِ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَنْفَسِ رَقَبَتَيْنِ شَيْءٌ فَلِلْوَرَثَةِ) وَقِيلَ يُشْتَرَى شِقْصٌ وَعَبْرٌ فِي الرُّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْأَصْحَابِ وَالثَّانِي وَصَفَهُ الْغَزَالِيُّ بِالْأَظْهَرِ، وَلَا تَفْرَادُهُ بِتَرْجِيحِهِ عَبْرَ الْمُصَنَّفِ بِالْمَذْهَبِ. (وَلَوْ قَالَ ثُلَاثِي لِلْعَتَقِ اشْتَرَى شِقْصًا) بِلَا خِلَافٍ أَيْ يَجُوزُ شِرَاؤُهُ.

(وَلَوْ وَصَّى لِحَمْلِهَا) بِكَذَا (فَأَتَتْ بِوَلَدَيْنِ فَلَهُمَا) بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُفْضَلُ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى ^(١) (أَوْ) أَتَتْ (بِحَيٍّ وَمَيِّتٍ فَكُلُّهُ لِحَيٍّ فِي الْأَصَحِّ) ^(٢) وَالثَّانِي ^(٣) لِلْحَيِّ نِصْفُهُ، وَالْبَاقِي لِوَارِثِ الْمُوَصَّى ^(٤) (وَلَوْ قَالَ إِنْ كَانَ حَمْلُكَ ذَكَرًا أَوْ قَالَ) إِنْ كَانَ (أُنْثَى فَلَهُ كَذَا فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى. (لَعَتْ) وَصِيَّتُهُ؛ لِأَنَّ حَمْلَهَا جَمِيعُهُ لَيْسَ بِذَكَرٍ وَلَا أُنْثَى، (وَلَوْ قَالَ إِنْ كَانَ بِبَطْنِهَا ذَكَرٌ) فَلَهُ كَذَا، (فَوَلَدَتْهُمَا) أَيْ وَلَدَتْ ذَكَرًا وَأُنْثَى (اسْتَحَقَّ الذَّكَرُ)؛ لِأَنَّهُ وَجَدَ بِبَطْنِهَا وَزِيَادَةُ الْأُنْثَى لَا تَضُرُّ (أَوْ وَلَدَتْ ذَكَرَيْنِ فَالْأَصَحُّ صِحَّتُهَا) أَيْ الْوَصِيَّةُ (وَيُعْطِيهِ) أَيْ الْمُوَصَّى بِهِ (وَالْوَارِثُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) وَالثَّانِي ^(٥) الْمَنْعُ لِإِقْتِضَاءِ التَّنْكِيرِ التَّوْحِيدِ، وَالثَّلَاثُ يُوزَعُ عَلَيْهِمَا

(وَلَوْ وَصَّى لِجَبْرَانِهِ ^(٦) فَلِأَرْبَعِينَ دَارًا مِنْ كُلِّ جَانِبٍ) مِنْ جَوَانِبِ دَارِهِ الْأَرْبَعَةِ لِحَدِيثٍ فِي ذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ قَالَ فِي الرُّوْضَةِ، وَيُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَى عَدَدِ الدُّورِ لَا عَلَى عَدَدِ سُكَّانِهَا.

(وَالْعُلَمَاءُ) فِي الْوَصِيَّةِ لَهُمْ ^(٧) (أَصْحَابُ عُلُومِ الشَّرْعِ مِنْ تَفْسِيرِ وَحَدِيثِ وَفَقْهِ) وَلَا يَدْخُلُ فِيهِمْ مَنْ يَسْمَعُونَ الْحَدِيثَ، وَلَا عِلْمُ لَهُمْ بِطَرِيقِهِ وَلَا بِأَسْمَاءِ الرُّوَاةِ وَلَا بِالْمُتَوْنِ فَإِنَّ السَّمَاعَ الْمُجَرَّدَ لَيْسَ بِعِلْمٍ (لَا مُقَرَّرٌ وَأَدِيبٌ وَمُعَبَّرٌ وَطَبِيبٌ) بِرَفْعِ الْأَرْبَعَةِ عَطْفًا عَلَى: "أَصْحَابُ" أَيْ لَيْسُوا مِنْ عُلَمَاءِ الشَّرْعِ. (وَكَذَا مُتَكَلِّمٌ ^(٨) عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ) وَقَالَ الْمُتَوَلَّى هُوَ مِنْهُمْ قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ قَرِيبٌ.

(١) لأن الوصية ليست كالميراث

(٢) يَنْ الْمَيِّتِ كَالْمَعْدُومِ

(٣) مقابل الأصح

(٤) قياساً على مَا لَوْ أَوْصَى لِحَيٍّ وَمَيِّتٍ

(٥) مقابل الأصح

(٦) مقدار عدد الجبران الذين تشملهم الوصية للجبران

(٧) تحديد العلماء الذين ينطبق عليهم وصف العلماء ومن ثم يدخلون في الوصية للعلماء

(٨) أي علماء علم الكلام

(وَيَدْخُلُ فِي وَصِيَّةِ الْفُقَرَاءِ الْمَسَاكِينِ وَعَكْسُهُ) ^(١) لَوْ قُوعِ اسْمِ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخِرِ عِنْدَ الْإِنْفِرَادِ. (وَلَوْ جَمَعَهُمَا شَرِكًا) بِضَمِّ أَوَّلِهِ (نِصْفَيْنِ وَأَقَلَّ كُلِّ صِنْفٍ) مِنْهُمَا (ثَلَاثَةٌ وَلَهُ التَّفْضِيلُ) بَيْنَ أَحَادِ الثَّلَاثَةِ فَأَكْثَرُ

(أَوْ) وَصَّى (الرَّيْدَ وَالْفُقَرَاءَ) ^(٢) فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ كَأَحَدِهِمْ فِي جَوَازِ إِعْطَائِهِ أَقَلَّ مُتَمَوِّلٍ لَكِنْ لَا يُحْرَمُ كَمَا يُحْرَمُ أَحَدُهُمْ لِعَدَمِ وُجُوبِ اسْتِيعَابِهِمْ لِلنِّصِّ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا، وَقِيلَ: هُوَ كَأَحَدِهِمْ فِي سِهَامِ الْقِسْمَةِ فَإِنْ ضَمَّ إِلَيْهِ أَرْبَعَةٌ مِنَ الْفُقَرَاءِ. كَانَ لَهُ الْخُمُسُ أَوْ خَمْسَةٌ كَانَ لَهُ السُّدُسُ، وَهَكَذَا، وَقِيلَ: لَهُ الرُّبْعُ؛ لِأَنَّ أَقَلَّ مَنْ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الْفُقَرَاءِ ثَلَاثَةً، وَقِيلَ لَهُ النِّصْفُ؛ لِأَنَّهُ مُقَابِلٌ لِلْفُقَرَاءِ، وَالْأَوَّلَانِ فَسَرَّ بِهِمَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ: إِنَّهُ كَأَحَدِهِمَا كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَأَسْقَطَهُ مِنَ الرُّوْضَةِ وَعَبَّرَ فِيهَا بِأَصَحِّ الْأَوْجُهَةِ

(أَوْ) وَصَّى (الْجَمْعَ مُعَيَّنٍ غَيْرِ مُنْحَصِرٍ) ^(٣) كَالْعَلَوِيَّةِ صَحَّتْ فِي الْأَظْهَرِ وَلَهُ الْإِفْتِصَارُ عَلَى ثَلَاثَةٍ

كَالْفُقَرَاءِ وَالثَّانِي لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَقْتَضِي الْإِسْتِيعَابَ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَلَا عُرْفَ يُخَصِّصُهُ بِخِلَافِ الْفُقَرَاءِ، فَإِنَّ الْعُرْفَ خَصَّصَهُ بِالِاخْتِفَاءِ فِيهِ بِثَلَاثَةِ الْمُتَضَمِّنِ لِلصِّحَّةِ، وَأُجِيبَ بِأَنَّ الصِّحَّةَ فِيهِ لَمَّا صَارَتْ أَصْلًا جَازَ أَنْ يُلْحَقَ بِهِ فِيهَا مَنْ ذَكَرَ، وَنَحْوُهُمْ كَالْهَاشِمِيَّةِ.

(أَوْ) وَصَّى (لِلْأَقَارِبِ زَيْدٍ دَخَلَ كُلُّ قَرَابَةٍ) لَهُ (وَإِنْ بَعْدَ) ^(٤) مُسْلِمًا كَانَ أَوْ كَافِرًا فَقِيرًا أَوْ غَنِيًّا وَارِثًا أَوْ غَيْرَهُ. (إِلَّا أَصْلًا وَفَرَعًا فِي الْأَصَحِّ) أَيُّ الْأَبْوَيْنِ وَالْأَوْلَادِ كَمَا فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا إِذْ لَا يُسَمَّوْنَ أَقَارِبَ فِي الْعُرْفِ، وَيَدْخُلُ الْأَجْدَادُ وَالْأَحْفَادُ، وَقِيلَ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ مِنَ الْأُصُولِ وَالْفُرُوعِ، وَيُؤَافِقُهُ تَغْيِيرُ الْمُحَرَّرِ بِالْأُصُولِ، وَالْفُرُوعِ وَقِيلَ: يَدْخُلُ الْجَمِيعُ، (وَلَا تَدْخُلُ قَرَابَةُ أُمِّ فِي وَصِيَّةِ الْعَرَبِ فِي الْأَصَحِّ) ^(٥)؛ لِأَنَّهُمْ لَا يَفْتَخِرُونَ بِهَا، وَالثَّانِي تَدْخُلُ كَمَا فِي وَصِيَّةِ

(١) حكم الوصية للفقراء أو المساكين

(٢) جمع في الوصية بين خاص (زيد) وعام (الفقراء)

(٣) عمم في وصيته بأن أوصى لعدد غير محصور

(٤) ويسوي بينهم في العطية لأن النسبوية ثابتة بالعرف. وقد قال - تعالى -: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء:

٢١٤] فَدَخَلَ كُلُّ قَرِيبٍ وَبَعْضُهُمْ أَقْرَبُ مِنْ بَعْضٍ، وَلِظَاهِرِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة:

١٨٠]

(٥) هذا إذا كان الموصي عربياً فإنهم لا يفتخرون بها ولا يعدونها قرابة

الْعَجَمَ، قَالَ الرَّافِعِيُّ وَهُوَ الْأَقْوَى^(١) وَعَبَّرَ فِي الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ (وَالْعِبْرَةُ بِأَقْرَبِ جَدٍّ يُنْسَبُ إِلَيْهِ زَيْدٌ وَتَعُدُّ أَوْلَادُهُ قَبِيلَةً) فَلَا يَدْخُلُ أَوْلَادُ جَدٍّ فَوْقَهُ فَلَوْ أَوْصَى لِأَقْرَبِ حَسَنِي لَمْ تَدْخُلِ الْحُسَيْنِيُّونَ (وَيَدْخُلُ فِي أَقْرَبِ أَقَارِبِهِ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ) أَيُّ الْأَبْوَانِ وَالْأَوْلَادِ كَمَا يَدْخُلُ غَيْرُهُمْ عِنْدَ انْتِفَائِهِمْ (وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ ابْنِ عَلَى أَبٍ وَأَخٍ عَلَى جَدٍّ) وَالثَّانِي يُسَوِّي بَيْنَهُمَا لِاسْتَوَاءِ الْأَوَّلَيْنِ فِي الرُّبُوبَةِ وَالْأَخِيرَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَالْأَوَّلِ^(٢) نَظَرَ إِلَى قُوَّةِ إِزْثِ الْإِبْنِ وَعُصُوبِيَّةِ وَالْأَخِ قُوَّةِ النُّبُوَّةِ فِي الْأَخِ وَفِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا فِي الثَّانِيَةِ قَوْلَانِ (وَلَا يَرْجِعُ بِذُكُورَةِ وَرِاثَةِ بَلِّ يَسْتَوِي الْأَبُّ وَالْأُمُّ وَالْإِبْنُ وَالْبِنْتُ) وَالْأَخُ وَالْأُخْتُ. (وَيَقْدَمُ ابْنُ الْبِنْتِ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْإِبْنِ) ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ

(وَلَوْ أَوْصَى لِأَقْرَبِ نَفْسِهِ لَمْ تَدْخُلِ وَرَثَتُهُ فِي الْأَصَحِّ)^(٣) ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُوصَى لَهُمْ فَيُخْتَصَّ بِالْوَصِيَّةِ الْبَاقُونَ، وَالثَّانِي يَدْخُلُونَ لِتَنَاوُلِ اللَّفْظِ لَهُمْ ثُمَّ يَبْطُلُ نَصِيْبُهُمْ، وَيَصِحُّ الْبَاقِي لِغَيْرِ الْوَرِثَةِ قَالَ الرَّافِعِيُّ، هُوَ الْإِمَامُ الْعَالِمُ الْعَلَامَةُ، إِمَامُ الْمِلَّةِ وَالِدِينِ، حُجَّةُ الْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّافِعِيُّ الْقَزْوِينِيُّ مُحَرَّرُ الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ٥٥٧ - ٦٢٣ هـ لَهُ مَوْلُفَاتٌ عَدِيدَةٌ مِنْهَا الْمَحَرَّرُ، الْعَزِيزُ شَرْحُ الْوَجِيزِ: لَكَ أَنْ تَقُولَ يَجِبُ اخْتِصَاصُ الْوَجْهَيْنِ بِقَوْلِنَا: الْوَصِيَّةُ لِلْوَارِثِ بَاطِلَةٌ، فَإِنْ وَقَفْنَا عَلَى الْإِجَارَةِ فَلْيُقْطَعْ بِالْوَجْهِ الثَّانِي قَالَ فِي الرَّوْضَةِ^(٤): الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي جَرَيَانِهِمَا، وَلَئِنْ مَأْخُذُهُمَا، أَنَّ الْإِسْمَ يَقَعُ لِكُنْهِ خِلَافَ الْعَادَةِ.

فَصْلٌ: ^(٥) تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ (بِمَنَافِعِ عَبْدٍ وَدَارٍ وَغَلَّةٍ حَانُوتٍ) مُؤَبَّدَةً وَمُؤَقَّتَةً وَمُطْلَقَةً، وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي التَّأْيِيدَ، وَغَلَّةٌ مَعْطُوفٌ عَلَى مَنَافِعَ. (وَيَمْلِكُ الْمُوصِي لَهُ مَنَفَعَةَ الْعَبْدِ وَأَكْسَابِ الْمُعْتَادَةِ) كَالِاخْتِطَابِ وَالِاحْتِشَاشِ وَالِاصْطِيَادِ وَأُجْرَةِ الْحِرْفَةِ بِخِلَافِ النَّادِرَةِ، كَالْهَبَةِ وَاللَّقْطَةِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُقْصَدُ بِالْوَصِيَّةِ (وَكَذَا) (مَهْرَهَا) أَيُّ الْأُمَةِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهَا إِذَا تَزَوَّجَتْ

(١) لِأَنَّ الرَّجْمَ قَرَابَةٌ وَقَدْ قَالَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْقَبْطِ: «إِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحْمًا» لِأَنَّ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ مِنْهُمْ وَقَدْ افْتَحَرَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِغَالِهِ سَعْدٌ فَقَالَ: سَعْدٌ خَالِي فَلْيُرِنِي أَمْرُؤُ خَالَهُ» حَسَنَةُ التَّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

(٢) أَيُّ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الْقَائِلُ بِتَقْدِيمِ الْإِبْنِ عَلَى الْأَبِ

(٣) اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي دُخُولِ الْوَرِثَةِ فِي الْوَصِيَّةِ لِلْأَقْرَبِ عَلَى قَوْلَيْنِ

(٤) أَيُّ قَالَ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ فِي كِتَابِهِ رَوْضَةُ الطَّالِبِينَ

(٥) شَرَعَ فِي بَيَانِ الْقِسْمِ الثَّانِي وَهُوَ الْأَحْكَامُ الْمُعْتَوِيَّةُ وَبَيَانَ مَا يُفْعَلُ عَنِ الْمَيِّتِ وَمَا يُنْفَعُهُ

أَوْ وَطُنْتُ بِشُبْهَةِ يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ (فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ مِنْ نَمَاءِ الرِّقَبَةِ كَالْكَسْبِ، وَالثَّانِي لَا بَلْ هُوَ لِوَارِثِ الْمُوصَى؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ مَنْفَعَةِ الْبُضْعِ وَهِيَ لَا تَجُوزُ الْوَصِيَّةُ بِهَا، فَلَا يَسْتَحِقُّ بَدَلَهَا بِالْوَصِيَّةِ، وَالْأَوَّلُ يَمْنَعُ هَذَا الْآخِرَ، وَقَالَ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا الثَّانِي الْأَشْبَهُ. (لَا وَلَدَهَا) مِنْ نِكَاحٍ أَوْ زِنَى أَيْ لَا يَمْلِكُهُ الْمُوصَى لَهُ. (فِي الْأَصَحِّ بَلْ هُوَ كَالْأَمِّ مَنْفَعَتُهُ لَهُ وَرَقَبَتُهُ لِلْوَارِثِ) ؛ لِأَنَّهُ جُزْءٌ مِنْهَا وَالثَّانِي يَمْلِكُهَا الْمُوصَى لَهُ كَكَسْبِهَا

(وَلَهُ إِعْتَاقُهُ) أَيْ لِلْوَارِثِ إِعْتَاقُ الْعَبْدِ الْمُوصَى بِمَنْفَعَتِهِ، كَمَا عَبَّرَ بِهِ فِي الْمَحَرَّرِ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِرَقَبَتِهِ لَكِنْ لَا يُجْزِئُ إِعْتَاقُهُ عَنِ الْكَفَّارَةِ لِعَجْزِهِ عَنِ الْكَسْبِ، وَإِذَا أَعْتَقَهُ تَبَقَّى الْوَصِيَّةُ بِحَالِهَا. (وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُ إِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ مُدَّةً، وَكَذَا أَبَدًا فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي عَلَى الْمُوصَى لَهُ، وَالْفِطْرَةُ كَالنَّفَقَةِ (وَبَيْعُهُ إِنْ لَمْ يُؤَبَّدْ) أَيْ الْمُوصَى الْمَنْفَعَةَ (كَالْمُسْتَأْجِرِ) فَيَصِحُّ لِلْمُوصَى لَهُ وَلِغَيْرِهِ عَلَى الرَّاجِحِ (وَإِنْ أَبَدَ) الْمَنْفَعَةَ (فَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يَصِحُّ بَيْعُهُ لِلْمُوصَى لَهُ دُونَ غَيْرِهِ)

إِذْ لَا فَائِدَةَ لِغَيْرِهِ فِيهِ وَالثَّانِي يَصِحُّ مُطْلَقًا لِكَمَالِ الْمَلِكِ، وَالثَّلَاثُ لَا يَصِحُّ مُطْلَقًا لِاسْتِغْرَاقِ الْمَنْفَعَةِ بِحَقِّ الْغَيْرِ (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ تُعْتَبَرُ قِيَمَةُ الْعَبْدِ كُلُّهَا) أَيْ قِيَمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ (مِنْ الثَّلَاثِ إِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَتِهِ أَبَدًا) ؛ لِأَنَّهُ حَالٌ بَيْنَ الْوَارِثِ وَبَيْنَهَا، وَالثَّانِي تُعْتَبَرُ مِنْهُ مَا بَيْنَ قِيَمَتِهِ بِمَنْفَعَتِهِ وَقِيَمَتِهِ بِمَا مَنَفَعَةٍ لِبَقَاءِ الرِّقَبَةِ لِلْوَارِثِ، فَإِذَا كَانَتْ قِيَمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا عَشْرَةٌ أُعْتَبِرَ مِنَ الثَّلَاثِ عَلَى الْأَوَّلِ مِائَةً، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعُونَ (وَإِنْ أَوْصَى بِهَا مُدَّةً قَوْمٌ بِمَنْفَعَتِهِ ثُمَّ مَسْلُوبَهَا تِلْكَ الْمُدَّةُ، وَيُحْسَبُ النَّاقِصُ مِنَ الثَّلَاثِ) فَإِذَا كَانَتْ قِيَمَتُهُ بِمَنْفَعَتِهِ مِائَةً وَبِدُونِهَا تِلْكَ الْمُدَّةُ ثَمَانِينَ، فَالْوَصِيَّةُ بِعَشْرِينَ.

(وَتَصِحُّ) الْوَصِيَّةُ (بِحَجٍّ تَطَوُّعٍ فِي الْأَظْهَرِ) بِنَاءً عَلَى الْأَظْهَرِ مِنْ دُخُولِ النِّيَابَةِ فِيهِ قِيَاسًا عَلَى الْفَرْضِ^(١)، وَمُقَابِلُهُ^(٢) يَقُولُ: الضَّرُورَةُ فِي الْفَرْضِ مُنْتَفِيَةٌ فِي التَّطَوُّعِ، وَظَاهِرٌ عَلَى الصِّحَّةِ أَنَّهَا تُحْسَبُ مِنَ الثَّلَاثِ. (وَيَحُجُّ مِنْ بَلَدِهِ أَوْ الْمِيقَاتِ كَمَا قَيَّدَ وَإِنْ أَطْلَقَ فَمِنْ الْمِيقَاتِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي^(٣) مِنْ بَلَدِهِ؛ لِأَنَّ الْغَالِبَ التَّجْهِيزُ لِلْحَجِّ مِنْهُ وَعُورِضٌ، بِأَنَّهُ

(١) لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ تَدْخُلُ النِّيَابَةَ فِي فَرْضِهَا فَتَدْخُلُ فِي نَفْلِهَا كَأَدَاءِ الزَّكَاةِ

(٢) أَيْ مُقَابِلُ الْأَظْهَرِ

(٣) مُقَابِلُ الْأَصَحِّ

لَيْسَ الْغَالِبُ الْإِحْرَامَ مِنْهُ (وَحَجَّةُ الْإِسْلَامِ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ) كَغَيْرِهَا مِنَ الدُّيُونِ ^(١) (فَإِنْ أَوْصَى بِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ أَوْ الثُّلُثِ عَمِلَ بِهِ وَإِنْ أَطْلَقَ الْوَصِيَّةَ بِهَا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ) عَلَى الْأَصْلِ (وَقِيلَ مِنَ الثُّلُثِ) ؛ لِأَنَّهُ مُصْرَفُ الْوَصَايَا فَيُحْمَلُ ذِكْرُ الْوَصِيَّةِ عَلَيْهِ (وَيُحْجُ مِنَ الْمِيقَاتِ) إِذْ لَا يَجِبُ مِنْ دُونِهِ

(وَلِلْأَجَنْبِيِّ أَنْ يَحْجَّ عَنِ الْمَيِّتِ) حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ^(٢) (بَغَيْرِ إِذْنِهِ) أَيِ الْوَارِثِ (فِي الْأَصَحِّ) كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ إِذْنِهِ لِلِإِفْتِقَارِ إِلَى النِّيَّةِ وَلِلْوَارِثِ أَنْ يَحْجَّ عَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يُوصِ، كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمَحَرَّرِ وَلَيْسَ لِلْأَجَنْبِيِّ أَنْ يَحْجَّ عَنْهُ تَطَوُّعًا إِذَا لَمْ يُوصِ بِهِ (وَيُؤَدِّي الْوَارِثُ عَنْهُ) مِنَ التَّرَكَةِ (الْوَاجِبِ الْمَالِيِّ فِي كَفَّارَةِ صِحَّتِهَا) ^(٣) كَكَفَّارَةِ الْوُقَاعِ مِنْ إِعْتَاقٍ وَإِطْعَامٍ، وَالْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ. (وَيُطْعَمُ وَيَكْسُو فِي الْمُخَيَّرَةِ) كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ (وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ يُعْتَقُ أَيْضًا) ؛ لِأَنَّهُ نَائِبُهُ شَرْعًا فَأِعْتَاقُهُ كِإِعْتَاقِهِ، وَالثَّانِي قَالَ: لَا ضَرُورَةَ هُنَا إِلَى الْإِعْتَاقِ. (و) الْأَصَحُّ (أَنَّ لَهُ) أَيِ فِي الْمَرْتَبَةِ وَالْمُخَيَّرَةِ أَخْذًا مِنَ الْإِطْلَاقِ. (الْأَدَاءُ مِنْ مَالِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ تَرَكَةً) كَقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَالثَّانِي لَا لِبُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ سِيَابَةِ، وَالثَّلَاثُ يَمْتَنِعُ الْإِعْتَاقُ فَقَطْ لِبُعْدِ إِثْبَاتِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ (و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ يَقَعُ) أَيِ الطَّعَامِ أَوْ الْكِسْوَةِ (عَنْهُ لَوْ تَبَرَّعَ أَجَنْبِيٌّ بِطَعَامٍ أَوْ كِسْوَةٍ) كَقَضَاءِ الدَّيْنِ وَالثَّانِي لَا لِبُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ النِّيَابَةِ (لَا إِعْتَاقٍ) أَيِ لَا يَقَعُ عَنْهُ (فِي الْأَصَحِّ) لِاجْتِمَاعِ بُعْدِ الْعِبَادَةِ عَنْ النِّيَابَةِ وَبُعْدِ الْوَلَاءِ لِلْمَيِّتِ، وَالثَّانِي يَقَعُ عَنْهُ كَغَيْرِهِ وَهَذَا التَّصْحِيحُ فِي الْمُخَيَّرَةِ وَالْمَرْتَبَةِ أَخْذًا مِنَ الْإِطْلَاقِ وَلَا يَنَافِي ذَلِكَ مَا فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا فِي كِتَابِ الْأَيْمَانِ مِنْ تَصْحِيحِ الْوُقُوعِ فِي الْمَرْتَبَةِ بِنَاءً عَلَى تَغْلِيلِ الْمَنْعِ فِي الْمُخَيَّرَةِ بِسُهُولَةٍ التَّكْفِيرِ بِغَيْرِ إِعْتَاقٍ فَلْيَتَأَمَّلْ

(وَيَنْفَعُ الْمَيِّتَ صَدَقَةً) عَنْهُ ^(٤) (وَدُعَاءٌ) لَهُ (مِنْ وَارِثٍ وَأَجَنْبِيٍّ) بِالْإِجْمَاعِ ^(١) (كَمَا نَقَلَهُ الْمُصَنِّفُ وَغَيْرُهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَفِي وَسْعِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يُثِيبَ الْمُتَصَدِّقَ أَيْضًا.

(١) بل أَوْلَى، وَكَذَا كُلُّ وَاجِبٍ بِأَصْلِ الشَّرْعِ كَالْعُمْرَةِ، وَالزَّكَاةِ، وَالْكَفَّارَةِ، سَوَاءً أَوْصَى بِهِ فِي الصِّحَّةِ أَمْ فِي الْمَرَضِ

(٢) وَإِنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ وَعُمْرَتُهُ قَبْلَ مَوْتِهِ لِعَدَمِ اسْتِطَاعَتِهِ

(٣) أَيِ يَجُوزُ أَدَاءُ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ الْمَالِيَةِ الَّتِي وَجِبَتْ عَلَى الْمَيِّتِ

(٤) شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا يَنْفَعُ الْمَيِّتَ مِنَ الْقَرِبَاتِ كَالْتَصَدَّقِ لِلْمَيِّتِ وَالدُّعَاءِ لَهُ

فَصْلٌ (٢): لَهُ الرُّجُوعُ عَنِ الوَصِيَّةِ وَعَنْ بَعْضِهَا بِقَوْلِهِ نَقَضْتُ الوَصِيَّةَ أَوْ أَبْطَلْتُهَا أَوْ رَجَعْتُ فِيهَا أَوْ فَسَخْتُهَا أَوْ هَذَا لِوَارِثِي مُشِيرًا إِلَى مَا وَصَّى بِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ لِوَارِثِهِ إِلَّا إِذَا انْقَطَعَ تَعَلُّقُ المَوْصَى لَهُ عَنْهُ (وَبَيَّعَ وَإِغْتَاقَ وَإِصْدَاقَ) لِمَا وَصَّى بِهِ لِخُرُوجِهِ عَنْ مِلْكِهِ. (وَكَذَا هِبَةٌ أَوْ رَهْنٌ) لَهُ (مَعَ قَبْضٍ وَكَذَا دُونُهُ فِي الْأَصَحِّ) لِيُظْهَرَ صَرْفُهُ بِذَلِكَ عَنْ جِهَةِ الوَصِيَّةِ، وَالثَّانِي يَغْتَلُّ بَقَاءَ مِلْكِهِ (وَبِوَصِيَّةٍ بِهَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ) فِيمَا وَصَّى بِهِ (وَكَذَا تَوْكِيلٌ فِي بَيْعِهِ وَعَرْضِهِ عَلَيْهِ فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ تَوَسَّلَ إِلَى مَا يَحْصُلُ بِهِ الرُّجُوعُ، وَالثَّانِي يَقُولُ قَدْ لَا يَحْصُلُ بَيْعُهُ

(وَخَلَطُ حِنْطَةٍ مُعَيَّنَةٍ) وَصَّى بِهَا (رُجُوعٌ) (٣) ؛ لِأَنَّهُ أَخْرَجَهَا عَنْ إِمْكَانِ التَّسْلِيمِ.

(وَلَوْ وَصَّى بِصَاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ، فَخَلَطَهَا بِأَجُودَ مِنْهَا فَرُجُوعٌ) ؛ لِأَنَّهُ أَحْدَثَ زِيَادَةً لَمْ تَتَنَاوَلْهَا الوَصِيَّةُ (أَوْ بِمِثْلِهَا فَلَا وَكَذَا بِأَزْدًا فِي الْأَصَحِّ) ؛ لِأَنَّهُ كَالْتَعْيِيبِ وَالثَّانِي يَقُولُ غَيْرَهَا عَمَّا كَانَتْ كَالْتَعْيِيرِ بِالْأَجُودِ

(وَطَحَنُ حِنْطَةٍ وَصَّى بِهَا وَبَذَرَهَا) بِالْمُعْجَمَةِ (وَعَجْنُ دَقِيقٍ) وَصَّى بِهِ (وَعَزْلُ قُطْنٍ) وَصَّى بِهِ (وَنَسَجُ غَزْلِ) وَصَّى بِهِ (وَقَطْعُ ثَوْبٍ) وَصَّى بِهِ (قَمِيصًا وَبِنَاءً وَغِرَاسٌ فِي عَرِصَةٍ) وَصَّى بِهَا (رُجُوعٌ) لِيُظْهَرَ هَذِهِ الْأَفْعَالِ فِي الصَّرْفِ مِنْ جِهَةِ الوَصِيَّةِ.

تَتِمَّةٌ: لَوْ وَصَّى بِثُلُثِ مَالِهِ ثُمَّ تَصَرَّفَ فِي جَمِيعِهِ بَيَّعَ أَوْ إِغْتَاقَ أَوْ غَيْرَهُمَا لَمْ يَكُنْ رُجُوعًا؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثُلُثُ مَالِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ لَا عِنْدَ الوَصِيَّةِ.

فَصْلٌ: يُسَنُّ الْإِيصَاءُ (٤) بِقَضَاءِ الدَّيْنِ وَرَدِّ الْمَظَالِمِ كَمَا فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (وَتَنْفِيدُ الوَصَايَا، وَالنَّظَرُ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ) فَإِنْ لَمْ يُوصِ بِهَا نَصَّبَ الْقَاضِي مَنْ يَقُومُ بِهَا قَالَهُ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَزَادَ فِيهَا أَنَّ الْإِيصَاءَ فِي رَدِّ الْمَظَالِمِ، وَقَضَاءِ الدَّيْنِ الَّذِي يَعْجُزُ عَنْهُ فِي

(١) لحديث «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» وَخَيْرٌ «سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: سَقَى الْمَاءَ» رَوَاهُمَا مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ.

(٢) شرع في بيان حكم الرُّجُوعِ عَنِ الوَصِيَّةِ

(٣) يحصل الرجوع عن الوصية بالفعل كما يحصل بالقول

(٤) بعد أن انتهى من الكلام عن الوصية شرع في الحديث عن الإيصاء، والفرق بينهما في اصطلاح الفقهاء، هو تَحْصِيصُ الوَصِيَّةِ بِالتَّبَرُّعِ الْمُضَافِ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، بَيْنَمَا الوَصَايَةُ بِالْعَهْدِ إِلَى مَنْ يَقُومُ عَلَى مَنْ بَعْدَهُ.

أَحَالٍ وَاجِبٌ، وَفِيهَا كَأَصْلُهَا فِي أَوَّلِ الْبَابِ مَنْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ، أَوْ فِي ذِمَّتِهِ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى، كَزَكَاةٍ وَحَجٍّ أَوْ دَيْنٍ لَادِمِيٍّ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِهِ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ غَيْرُهُ، زَادَ فِيهَا الْمُرَادُ، إِذَا لَمْ يَعْلَمْ بِهِ مَنْ يَنْتَبِثُ بِقَوْلِهِ: وَعَلِمَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ سَنَ الْإِيصَاءِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ، وَرَدَ الْمُظَالِمُ إِذَا كَانَا مَعْلُومَيْنِ

(وَشَرِطَ لَوْصِيٍّ^(١) تَكْلِيفٍ) أَيُّ بُلُوغٍ وَعَقْلٍ (وَحَرِيَّةٍ وَعَدَالَةٍ إِلَى التَّصَرُّفِ فِي الْمَوْصَى بِهِ وَإِسْلَامَ لَكِنْ الْأَصَحُّ جَوَازُ وَصِيَّةٍ ذِمِّيٍّ إِلَى ذِمِّيٍّ)

أَيُّ عَدْلٍ فِي دَيْنِهِ كَمَا فِي الرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَاسْتَعْنَى عَنْهُ بِقَوْلِهِ السَّابِقِ: وَعَدَالَةٌ وَلَمْ يَحْتَجْ فِي الْجَوَازِ إِلَى قَوْلِ الْوَجِيزِ فِي أَوْلَادِهِ الْكُفَّارِ لظُهُورِ أَنَّهُ الْمُرَادُ إِذْ لَا وَلَايَةَ لِلْكَافِرِ عَلَى أَوْلَادِهِ الْمُسْلِمِينَ، وَلَا يُوصِي عَلَى أَوْلَادِهِ إِلَّا مَنْ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَيْهِمْ، كَمَا سَيَأْتِي فَخَرَجَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ، وَمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَالْفَاسِقُ وَمَنْ لَا يَهْتَدِي إِلَى التَّصَرُّفِ لِسَفِهِ أَوْ هَرَمٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، فَلَا يَصِحُّ الْإِيصَاءُ إِلَيْهِمْ (وَلَا يَصُرُّ الْعَمَى فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي يَصُرُّ؛ لِأَنَّ الْأَعْمَى لَا يَقْدِرُ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ لِنَفْسِهِ، فَلَا يَقْوُضُ إِلَيْهِ أَمْرٌ غَيْرُهُ، وَدُفِعَ بِأَنَّهُ يُوَكَّلُ فِيمَا لَا يَتِمَّكُنُ مِنْ مُبَاشَرَتِهِ. (وَلَا تُشْتَرَطُ الذُّكُورَةُ) فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْوَصِيُّ امْرَأَةً.^(٢) (وَأُمُّ الْأَطْفَالِ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا) إِذَا حَصَلَتْ الشُّرُوطُ فِيهَا، وَهِيَ تُعْتَبَرُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَقِيلَ: وَعِنْدَ الْوَصِيَّةِ أَيْضًا، وَقِيلَ وَمَا بَيْنَهُمَا أَيْضًا

(وَيَنْعَزِلُ الْوَصِيُّ بِالْفِسْقِ)^(٣) بِنَعْدٍ فِي الْمَالِ أَوْ بِسَبَبٍ آخَرَ، وَفِي مَعْنَاهُ قَيِّمُ الْقَاضِي (وَكَذَا الْقَاضِي) أَيُّ يَنْعَزِلُ بِالْفِسْقِ (فِي الْأَصَحِّ لَا الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ) لِتَعَلُّقِ الْمَصَالِحِ الْكُلِّيَّةِ بِوَلَايَتِهِ وَقَاسَ عَلَيْهِ مُقَابِلُ الْأَصَحِّ، وَفِيهِ وَجْهٌ بِالْإِنْعِزَالِ أَيْضًا

(وَيَصِحُّ الْإِيصَاءُ فِي قَضَاءِ الدَّيْنِ وَتَنْفِيزِ الْوَصِيَّةِ مِنْ كُلِّ حَرٍّ مُكَلَّفٍ)^(٤) قَالَ بَعْضُهُمْ: كَذَا فِي أَكْثَرِ النُّسخِ وَتَنْفِيزٍ بِتَحْتَانِيَّةٍ بَيْنَ الْفَاءِ وَالذَّالِ، كَمَا فِي الْمَحَرَّرِ وَالرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَفِي

(١) أَرْكَانُ الْوَصَايَةِ أَرْبَعَةٌ: وَصِيٍّ، وَمَوْصٍ، وَمَوْصَى فِيهِ، وَصِيغَةٌ. وَقَدْ شَرَعَ فِي بَيَانِ شَرْطِ الرُّكْنِ الْأَوَّلِ وَأَنَّهُ يَشْتَرَطُ فِي التَّكْلِيفِ

(٢) وَقَدْ أَوْصَى سَيِّدُنَا عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إِلَى ابْنَتِهِ حَفْصَةَ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا -، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

(٣) الْوَصَايَةُ وَلَايَةٌ وَمَنْ ثُمَّ يَنْعَزِلُ الْوَصِي بِالْفِسْقِ

(٤) شَرَعَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الرُّكْنِ الثَّانِي وَهُوَ الْمَوْصِي

خَطِ الْمُصْتَفِ تَنْفُذُ بِلَا تَحْتَانِيَّةٍ مَضْمُونُ الْفَاءِ وَالذَّالِ بَعْدَ دَائِرَةٍ، أَيْ وَهُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى يَصِحُّ وَيَتَعَلَّقُ بِهِمَا قَوْلُهُ مِنْ إِلَى آخِرِهِ. (وَيُشْتَرَطُ فِي أَمْرِ الْأَطْفَالِ مَعَ هَذَا) الْمَذْكُورِ مِنَ الْحُرِّيَّةِ وَالتَّكْلِيفِ. (أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَايَةٌ عَلَيْهِمْ) قَالَ فِي الرُّوضَةِ كَأَصْلِهَا ابْتِدَاءً مِنَ الشَّرْعِ لَا بِتَفْوِيزٍ أَيْ فَيُوصَى الْأَبُ أَوْ الْجَدُّ دُونَ غَيْرِهِمَا مِنَ الْأَهْلِ.

(وَلَيْسَ لِوَصِيِّ إِيصَاءٍ^(١) فَإِنْ أَدِنَ لَهُ فِيهِ جَازَ فِي الْأَظْهَرِ) وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ، وَالثَّلَاثُ: إِنْ عَيَّنَ الْوَصِيُّ جَازَ وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ قَالَ: أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ إِلَى بُلُوغِ ابْنِي أَوْ قُدُومِ زَيْدٍ فَإِذَا بَلَغَ أَوْ قَدِمَ فَهُوَ الْوَصِيُّ جَازَ) ذَلِكَ وَاعْتَفَرَ التَّائِقِيَةُ فِي الْإِيصَاءِ إِلَى الْأَوَّلِ، وَالتَّغْلِيْقُ فِي الْإِيصَاءِ إِلَى الثَّانِي وَنَحْوُهُ أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ سَنَةً وَبَعْدَهَا وَصِيِّي فَلَانٌ.

(وَلَا يَجُوزُ) لِلْأَبِ (نَصْبُ وَصِيِّ) عَلَى الْأَطْفَالِ. (وَالْجَدُّ حَيٌّ بِصِفَةِ الْوَلَايَةِ) عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّ وَلَايَتَهُ ثَابِتَةٌ شَرْعًا،^(٢) وَيَجُوزُ لَهُ نَصْبُ وَصِيِّ فِي قَضَاءِ الدِّيُونِ وَتَنْفِيزِ الْوَصَايَا، وَهُوَ أَوْلَى مِنْ أَبِيهِ

(وَلَا يَجُوزُ الْإِيصَاءُ بِتَزْوِيجِ طِفْلٍ وَبَنَتٍ)^(٣)؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْأَبِ وَالْجَدِّ لَا يُزَوِّجُ صَغِيرًا وَالصَّغِيرَةَ

(وَلَفْظُهُ)^(٤) أَيْ الْإِيصَاءُ. (أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ أَوْ فَوَّضْتُ) إِلَيْكَ وَنَحْوُهُمَا كَأَقَمْتُكَ مَقَامِي.

(وَيَجُوزُ فِيهِ التَّوْقِيتُ وَالتَّغْلِيْقُ) نَحْوُ مَا سَبَقَ وَنَحْوُ أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ سَنَةً، وَإِذَا جَاءَ فَلَانٌ فَهُوَ وَصِيٌّ

(وَيُشْتَرَطُ بَيَانُ مَا يُوصِي فِيهِ) كَقَضَاءِ الدِّينِ وَتَنْفِيزِ الْوَصَايَا، وَأَمْرِ الْأَطْفَالِ. (فَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى أَوْصَيْتُ إِلَيْكَ لَعَا) هَذَا الْقَوْلُ

(و) يُشْتَرَطُ (الْقَبُولُ)^(١) أَيْ قَبُولُ الْإِيصَاءِ وَفِي قِيَامِ الْعَمَلِ مَقَامَهُ وَجَهَانِ أَخْذًا مِنَ الْوَكَالَةِ. (وَلَا يَصِحُّ) الْقَبُولُ (فِي حَيَاتِهِ) أَيْ الْمُوصِي (فِي الْأَصَحِّ) كَالْمُوصَى لَهُ وَالثَّانِي يَصِحُّ كَمَا

(١) أي لا يملك الوصي أن يوصي غيره إلا إذا أذن له الولي

(٢) ومن ثم فليس له نقل الولاية عنه كولاية التزويج

(٣) شرع في بيان الركن الثالث وهو الموصى فيه

(٤) شرع في بيان الركن الرابع وهو الصيغة

لَوْ وَكَّلَهُ بِعَمَلٍ يَتَأَخَّرُ يَصِحُّ الْقَبُولُ فِي الْحَالِ، وَالرَّدُّ فِي حَيَاةِ الْوَصِيِّ عَلَى هَذَيْنِ التَّوَجُّهَيْنِ
فَعَلَى الْأَوَّلِ لَوْ رَدَّ فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ قَبِلَ بَعْدَ مَوْتِهِ جَارَ وَلَوْ رَدَّ بَعْدَ الْمَوْتِ لَغَا الْإِيصَاءُ
(وَلَوْ وَصَّى اثْنَيْنِ لَمْ يَنْفَرِدْ أَحَدُهُمَا) بِالصَّرْفِ (إِلَّا إِنْ صَرَّحَ بِهِ) أَيُّ بِالْإِنْفِرَادِ فَيَجُوزُ
(وَالْمُوصِي وَالْوَصِي الْعَزْلُ مَتَى شَاءَ) أَيُّ لِلْمُوصِي عَزْلُ الْوَصِي وَلِلْوَصِي عَزْلُ نَفْسِهِ قَالَ
فِي الرُّوْضَةِ إِلَّا أَنْ يَتَعَيَّنَ عَلَيْهِ، أَوْ يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ تَلَفُ الْمَالِ بِاسْتِيلَاءِ ظَالِمٍ، مِنْ قَاضٍ
وغيره، وَعِبَارَةُ الْمُحَرَّرِ وَالرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا وَلِلْمُوصِي الرُّجُوعُ
(وَإِذَا بَلَغَ الطِّفْلُ وَنَازَعَهُ) ^(١) أَيُّ الْوَصِي (فِي الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِ صَدَقَ الْوَصِي) بِبَيْمِنِهِ كَمَا صَرَّحَ
بِهِ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا (أَوْ فِي دَفْعِ إِلَيْهِ بَعْدَ الْبُلُوغِ صَدَقَ الْوَلَدُ) بِبَيْمِنِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ
الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ وَالْفَرْقُ أَنَّهُ لَا يَغْسُرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ الْإِنْفَاقِ، وَفِي
وَجْهِ يُصَدِّقُ الْوَصِي تَقَدَّمَ مِثْلُهُ فِي الْقِيمِ فِي آخِرِ الْوَكَالَةِ.

(١) لِأَنَّهُ عَقْدٌ تَصَرُّفٌ فَأَشْبَهَ الْوَكَالَةَ وَالْقَبُولُ عَلَى التَّرَاخِي عَلَى الْأَصَحِّ

(٢) اخْتِلَافُ الطِّفْلِ مَعَ الْوَصِي

كتاب الخلع (١)

(١) الخلع - بالفتح - لغة: النزاع والإزالة. تقول: خلعت الثوب خلعا: نزعته، والإسم: الخلع- بالضم-، تقول: خلع الرجل امرأته خلعا، أي: أزال عصمتها، وخلعت المرأة زوجها مخالعة: إذا افتدت منه، وطلقها على الفدية، وسمي ذلك الفراق خلعا: لأن الله تعالى جعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن، فقال: ﴿هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لِهِنَّ﴾ {البقرة: ١٨٧} فإذا افتدت المرأة نفسها، فطلقها زوجها على ذلك، فكأن كل واحد منهما خلع لباس صاحبه. ينظر: لسان العرب ٨/٧٦، القاموس المحيط ٢/٩٥٩، المصباح المنير ١٠٩، مادة (خلع).

وشرعا: كما عرفه المصنف (فرقة بعوض مقصود لجهة الزوج بلفظ طلاق أو خلع).
وحكمه: أنه مشروع وجائز.

أدلة مشروعيته: الأصل في مشروعية الخلع: الكتاب، والسنة، والإجماع:
أما الكتاب: فقولته تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩].

وجه الدلالة: أفادت الآية: أنه لا يحل للزوج أن يأخذ من زوجته مالا يملكها به عصمتها إلا في حال الخوف من عدم إقامة حدود الله، وعدم أداء الحقوق الزوجية فيما بينهما: لبغض أو سوء عشرة، فإذا حدث الشقاق وتعذر الإصلاح: جاز للزوج أخذ هذا المال مقابل تملكها نفسها. يراجع هذا المعنى في: أحكام القرآن للجصاص ١/٥٣٣، وأحكام القرآن لابن العربي ١/٢٦٣، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٢/١٢٠، ١٢١.

ومن السنة: ما روي البخاري عن ابن عباس، أَنَّ امْرَأَةً ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ، مَا أَغْتَبَ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتُرِيدِينَ عَلَيْهِ حَديقَتَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَقْبِلِ الْحَديقَةَ وَطَلِّقِيهَا تَطْلِيقَةً» أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الطَّلَاقِ، بَابُ الْخُلْعِ وَكَيْفَ الطَّلَاقِ فِيهِ، حَدِيثٌ رَقْم (٥٢٧٣).

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الخلع، ولم يخالف في ذلك إلا بكر بن عبد الله المزني، حيث قال إنه منسوخ: لكنه قول مردود. قال الجصاص: "وهو قول شاذ يردده الكتاب والسنة واتفاق السلف". أحكام القرآن للجصاص ١/٥٣٤.

وأما حدود هذه المشروعية: فقد ذهب عامة الفقهاء إلى أن الخلع مشروع للمرأة إذا كرهت زوجها لخلقه، أو دينه، أو خلقته، وظنت أن تؤدي بها هذه الكراهة إلى التقصير في حقوقه المشروعة عليها، ومع هذا فقد يكون مكروها، وقد يكون حراما كما لو طلبته المرأة من غير سبب: لقوله - ﷺ - "أي: ما امرأة سألَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا زَانِجَةُ الْجَنَّةِ". أخرجه أحمد في مسنده (٢٢٨١٣) أبو داود في الطلاق (٢٢٢٦)، والترمذي في الطلاق (١١٧٨)، وقال: هذا حديث حسن، وابن ماجه في الطلاق (٢٠٥٥). يراجع مذهب الفقهاء في: (البدأي: للمغنياني ٣/٢٦٣/وبدأي: للمجتهد ٢/١١٧، والبيان للعمراني ٧/١٠، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي ٣/١٠٧).

وأما حكمة مشروعية الخلع: فلأن الشارع الحكيم قد جعل الطلاق بيد الرجل وحقا من حقوقه إذا شعر أنه لا يستطيع العيش مع زوجته في سعادة، ولم يمكنه علاجها بالوسائل التي شرعها له، ولكن قد يحدث أن تبغض المرأة زوجها ولا تتحمل العيش معه، وتتضرر من بقاء الزوجية واستمرارها، فجعل الإسلام لها = مخرجاً، وفتح لها باب الخلاص من هذا الضيق، وذلك بأن تقدم شيئا من المال تفقدي

(هُوَ) (١): فُرْقَةٌ بَعُوضٍ مَقْصُودٌ لِحِجَّةِ الرَّوْجِ، (بِلَفْظِ طَلَّاقٍ أَوْ خُلْعٍ) كَقَوْلِهِ: طَلَّقْتُكَ، أَوْ خَالَعُكَ عَلَى كَذَا، فَتَقْبَلُ، وَسَيَأْتِي صِحَّتُهُ بِكِنَايٍ: اتِّ الطَّلَاقِ.

فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: "بِلَفْظِ طَلَّاقٍ" لَفْظٌ مِنَ الْأَفَاطِهِ، صَرِيحًا كَانَ أَوْ كِنَايً: (٢)، وَلَفْظُ الْخُلْعِ مِنْ ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي، وَصَرَّحَ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ فِي الْبَابِ.

من يصح منه الخلع

(شَرْطُهُ: رَوْجٌ يَصِحُّ طَلَّاقُهُ) يَغْنِي: أَنْ يَكُونَ الرَّوْجُ يَصِحُّ طَلَّاقُهُ، بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، مُخْتَارًا، كَمَا سَيَأْتِي فِي بَابِهِ (فَلَوْ خَالَعَ عَبْدٌ أَوْ مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفْهِ.. صَحٌّ)؛ لِوُجُودِ الشَّرْطِ (٣) وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ وَالْوَلِيُّ، (وَوَجَبَ دَفْعُ الْعَوْضِ) (٤) دَيْنًا كَانَ أَوْ عَيْنًا (إِلَى مَوْلَاهُ وَوَلِيِّهِ)؛ لِيُبْرَأَ الدَّافِعُ مِنْهُ، وَيَمْلِكُهُ السَّيِّدُ كَسَائِرِ أَكْسَابِ الْعَبْدِ، وَلَوْ قَالَ السَّفِيهُ: إِنَّ

به نفسها، وتتخلص من رابطة الزوجية، فالزواج رابطة مقدسة مبنية على الرضا والقبول، فإذا انفصمت عرى هذه الرابطة فخير للزوجين وأكرم لهما أن يركنا إلى حياة أخرى جديدة (وإن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا) [النساء: ١٣٠].: الأحوال الشخصية لأبي زهرة ٣٠١، والزواج والطلاق في الإسلام د. بدران أبو العنين ٣٩١).

أركان الخلع: أركانه خمسة: المخالع، والمختلعة، والمعوض، والعوض، والصيغة. فالمخالع هو: الزوج أو نائبه، وشروطه: أن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا قاصدا. والمختلعة هي: الزوجة أو وليها أو وكيلها، ويشترط كونه مطلق التصرف في المال. والمعوض هو: بضع الزوجة- بضم الباء- وهو فرج المرأة، والمقصود الاستمتاع بها. والمعوض هو: ما تدفعه الزوجة لزوجها؛ لتفتدي به. والصيغة هي: اللفظ الدال على الخلع صريحا كان أو كناية.

(٢) أي: الخلع شرعا.

(٣) الكناية: اللَّفْظُ الْمُخْتَمَلُ شَيْئَيْنِ فَصَاعِدًا. تحرير ألفاظ التنبيه للنووي (٢٤٤/١).

(٤) وهو: كونه بالغًا، عاقلًا، مختارًا.

(٥) العوض: هو ما تدفعه الزوجة لزوجها من مال أو منفعة؛ لتفتدي به نفسها.

دَفَعَتْ إِلَيَّ كَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ لَمْ تُطْلَقْ إِلَّا بِالْإِذْنِ إِلَيْهِ، وَتَبَرَّأَ بِهِ كَمَا قَالَ الْمَاوَرِدِيُّ (١)، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْعَبْدِ، وَأَسْقَطَ الْمُصَنِّفُ مِنَ "الْمُحَرَّرِ" (٢) أَنَّهُ يَصِحُّ خُلْعُ الْمُفْلِسِ؛ لِتَقَدُّمِهِ فِي بَابِهِ.

شرط المختلعة أو وكيلها

(وَشَرَطُ قَابِلِهِ) أَي: الخُلْعُ مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ بِجَوَابٍ أَوْ سُؤَالٍ لِيَصِحَّ خُلْعُهُ.. (إِطْلَاقُ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَالِ) بَأَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا، غَيْرَ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ (فَإِنْ اخْتَلَعَتْ أَمَةٌ بِلَا إِذْنِ سَيِّدٍ بَدِينٍ) فِي ذِمَّتِهَا (أَوْ عَيْنُ مَالِهِ.. بَانَتْ) (٣)؛ لِذِكْرِ الْعَوَضِ (وَلِلزَّوْجِ فِي ذِمَّتِهَا مَهْرٌ مِثْلُ (٤) فِي صُورَةِ الْعَيْنِ، وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهَا)، أَوْ مِثْلُهَا؛ لِفَسَادِ الْعَوَضِ بِإِنْتِفَاءِ الْإِذْنِ فِيهِ، (وَفِي صُورَةِ الدَّيْنِ.. الْمُسَمَّى، وَفِي قَوْلٍ: مَهْرٌ مِثْلُ)، وَرَجَّحَهُ فِي "الْمُحَرَّرِ"، وَ"الشَّرْحَ الصَّغِيرَ" (٥) وَرَجَّحَ فِي "أَصْلِ الرُّوضَةِ" (٦).. الْأَوَّلَ، ثُمَّ مَا ثَبَّتَ فِي ذِمَّتِهَا إِنَّمَا تُطَالِبُ بِهِ بَعْدَ الْعَتَقِ، (وَإِنْ

(١) الحاوي الكبير (١٢/٣٥٠، ٣٥١)، والماوردي هو: الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

البصري، فقيه شافعي، وأقضى قضاة عصره، مولده سنة ٣٦٤هـ، ووفاته سنة ٤٥٠هـ. من أهم مصنفاته: كتاب "الحاوي الكبير" و"أدب الدنيا والدين"، و"الأحكام السلطانية" وتفسيره المسمى بـ"النكت والعيون". طبقات الشافعية لابن السبكي ٢٦٧/٥ وما بعدها، الأعلام للزركلي ٣٢٧/٤.

(٢) كتاب "المحرر" للإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافي القزويني، المتوفى سنة ٦٢٣هـ، اختصره من كتاب "الوجيز" للغزالي المتوفى ٥٠٥هـ..

(٣) هذا: وقوله: "وأسقط المصنف من المحرر"، يقصد بالمصنف: الإمام النووي المتوفى ٦٧٦هـ. حيث اختصر "المحرر" وسماه: "منهاج الطالبين وعمدة المفتين"، وهو المتن الذي بين أي: دينا والذي ندرسه في الدراسة النصية بشرحه المسمى "كنز الراغبين" للإمام جلال الدين المحلي، المتوفى سنة ٨٦٤هـ.

(٤) قوله "بانَتْ" أي: كان طلاقها بانئا بينونة صغرى، يصح لزوجها مراجعتها بعقد ومهر جديدين، والبينونة الصغرى تكون في الطلاق قبل الدخول، والخلع، والمطلقة طلاقا رجعيًا إذا انتهت عدتها قبل مراجعة زوجها لها، أما البينونة الكبرى تكون بعد الطلاق الثلاث، والذي لا تحل فيه الزوجة لزوجها إلا بعد أن تزوج بأخرويدخل بها دخولا حقيقيا وتطلق منه دون اتفاق سابق.

(٥) مهر المثل يقصد به: أن ينظر إلى امرأة مثلها في السن، والبكارة، والتعليم، والنسب، وغير ذلك من الجمال والعفة، فيقرر لها مهرها بمثل قيمة مهر مثلتها في شيء مما سبق.

(٦) كتاب "الشرح الصغير" للإمام أبي القاسم عبد الكريم الرافي القزويني، المتوفى سنة ٦٢٣هـ، وهو شرح على الوجيز" للإمام الغزالي، المتوفى ٥٠٥هـ. وقد شرح الرافي "الوجيز" شرحا كبيرا سماه "العزیز شرح الوجيز" وشرحا صغيرا هو هذا، وليس له اسم غير "الشرح الصغير".

(٧) الإمام النووي- رحمه الله- اختصر كتاب "العزیز شرح الوجيز" للرافعي، وسماه: "روضة الطالبين"، وقد أبقى كثيرا من ألفاظ الرافي في "فتح العزیز" كما هي: لكنه زاد في بعضها، وغير في بعضها الآخر، واستدرك عليه بعض الأشياء، فأحيانا يذكر الشراح: لفظ "الروضة" و"أصل الروضة" و"زيادة

أَذِنَ) السَّيِّدُ، (وَعَيْنَ عَيْنًا لَهُ) أَي: مِنْ مَالِهِ، (أَوْ قَدَّرَ دَيْنًا) فِي ذِمَّتِهَا كَأَلْفِ دِرْهَمٍ (فَامْتَثَلَتْ.. تَعَلَّقَ بِالْعَيْنِ) فِي صُورَةِ الْعَيْنِ، (وَبَكْسِبِهَا فِي الدَّيْنِ)، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَا قَدَّرَهُ.. طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعَتَقِ، (وَإِنْ أَطْلَقَ الْإِذْنَ.. اقْتَضَى مَهْرَ مِثْلِ مَنْ كَسَبَهَا)، فَإِنْ زَادَتْ عَلَيْهِ.. طُولِبَتْ بِالزَّائِدِ بَعْدَ الْعَتَقِ، وَإِنْ قَالَ: اخْتَلَعِي بِمَا شِئْتَ.. اخْتَلَعَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَكْثَرَ مِنْهُ، وَتَعَلَّقَ الْجَمِيعُ بِكَسْبِهَا، ثُمَّ مَا يَتَعَلَّقُ بِكَسْبِهَا يَتَعَلَّقُ بِمَا فِي يَدِهَا مِنْ مَالِ التِّجَارَةِ، إِنْ كَانَتْ مَأْذُونًا لَهَا فِيهَا، وَهَلْ يَكُونُ السَّيِّدُ بِإِذْنِهِ فِي الْخُلْعِ بِالذَّيْنِ ضَامِنًا لَهُ؟ فِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ فِي مَهْرِ زَوْجَةِ الْعَبْدِ، (وَإِنْ خَالَعَ سَفِيهَةً) أَي: مَحْجُورًا عَلَيْهَا بِسَفَاهَةِ بَلْفِظِ الْخُلْعِ، كَقَوْلِهِ: خَالَعْتُكَ عَلَى أَلْفٍ (أَوْ قَالَ) لَهَا: (طَلَّقْتُكَ عَلَى أَلْفٍ، فَقَبِلَتْ: طَلَّقْتُ رَجْعِيًّا)، وَلَعَا ذِكْرُ الْمَالِ، وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ فِيهِ؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَهْلِ التَّرَامِهِ، وَظَاهِرٌ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ طَلَّقَتْ بَائِنًا بِلَا مَالٍ، كَمَا قَالَهُ الْمُصَنِّفُ فِي نَكْتِ التَّنْبِيهِ^(١) (فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ.. لَمْ تُطَلَّقْ)؛ لِأَنَّ الصِّيغَةَ تَقْتَضِي الْقَبُولَ، فَأَشْبَهَ الطَّلَاقَ الْمُعْلَقَ عَلَى صِفَةٍ.

اختلاع المريضة مرض الموت

الروضة"، فمتى قالوا: "أصل الروضة" فالمراد به: عبارة النووي في "روضة الطالبين" التي لخصها واختصرها من "فتح العزيز"، ونقل الشيخ قليوبي في حاشيته عن بعضهم أن المراد بها: مَا تَصَرَّفَ فِيهِ النَّوَوِيُّ مِنْ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ أَوْزَادَهُ بِغَيْرِ تَمْيِيزٍ..

ومتى قالوا: "زوائد الروضة" فالمراد به: زيادتها على ما في "فتح العزيز". وإذا أطلق لفظ: "الروضة" فهو محتمل لتردده بين الأصل والزوائد، ونقل الشيخ قليوبي في حاشيته عن بعضهم أن المراد بها: الزوائد، وربما يستعمل بمعنى -الأصل- كما يقضي به السبر = وإذا قيل: "كذا في الروضة وأصلها" أفاد: أن ما لخصه النووي في "الروضة" من كلام الرافعي في "المحرر" لا تفاوت بينهما في المعنى.

وإذا قيل: "كذا في الروضة كأصلها" أفاد: أن ما لخصه النووي في "الروضة" من كلام الرافعي في "المحرر" متفقان لفظاً؛ لكن بينهما بحسب المعنى تفاوت يسير، ينظر: حاشية الشيخ قليوبي على شرح الجلال المحلي (٤٣/١)، والفتح المبين أ.د. محمد الحفناوي، ص ١٦٢، ١٦٣.

(١) كتاب "نكت التنبيه" ألفه النووي - رحمه الله - لبيان الدقائق الموجودة في كتاب "التنبيه في الفقه

الشافعي" للشيخ أبي إسحاق الشيرازي، المتوفى سنة ٤٧٦هـ، والتنبيه: أحد المتون الخمس المشهورة المتداولة بين الشافعية.. كما ذكر النووي في تهذيبه. أخذه الشيرازي من تعليقه الشيخ أبي حامد المروزي. وقد عمل النووي - رحمه الله - عليه "نكت التنبيه"، ومنه نسختان بهذا العنوان في جامعة بيل (١٠٥ - ١٣٠٥ L) وفي متحف طوبقبوسراي: استانبول (١١٠٠ - ٤٣٧٤ A) وله أيضاً: "تصحیح ألفاظ التنبيه" مطبوع مع التنبيه طبعة الحلبي - مصر، وأيضاً يوجد: نكت التنبيه - لابن النقيب الشافعي المتوفى سنة ٧٦٩هـ، وكذلك النشائي وغيرهما.

(وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ الْمَرِيضَةِ مَرَضَ الْمَوْتِ)؛ إِذْ لَهَا التَّصَرُّفُ فِي مَالِهَا (وَلَا يُحْسَبُ مِنَ التُّلْثِ إِلَّا زَائِدٌ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ)، بِخِلَافِ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَأَقَلُّ مِنْهُ، فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ؛ لِأَنَّ التَّبَرُّعَ إِنَّمَا هُوَ بِالزَّائِدِ، وَلَيْسَ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِخُرُوجِ الزَّوْجِ بِالْخُلْعِ عَنِ الْإِرْثِ، وَيَصِحُّ خُلْعُ الْمَرِيضِ مَرَضَ الْمَوْتِ بِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ، لِأَنَّ الْبُضْعَ (١) لَا يَبْقَى لِلْوَارِثِ لَوْ لَمْ يُخَالَعِ، (وَرَجْعِيَّةٌ فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ، وَالثَّانِي: لَا، لِعَدَمِ الْحَاجَةِ إِلَى الْإِفْتِدَاءِ الَّذِي هُوَ الْقَصْدُ بِالْخُلْعِ، وَعَلَى هَذَا: يَقَعُ بِالطَّلَاقِ رَجْعِيًّا.. إِذَا قَبِلَتْ، كَالسَّفِيهِةِ (لَا بَائِنٍ) بِخُلْعٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَلَا يَصِحُّ خُلْعُهَا إِذْ لَا فَائِدَةٌ فِيهِ.

العوض في الخلع

(وَيَصِحُّ عَوَضُهُ) أَي: الْخُلْعُ (قَلِيلًا، وَكَثِيرًا، دَيْنًا، وَعَيْنًا، وَمَنْفَعَةً) كَالصَّدَاقِ (٢)، (وَلَوْ خَالَعَ بِمَجْهُولٍ) كَكُتُوبٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ غَيْرِ مَوْصُوفٍ، (أَوْ غَيْرِ مَعْلُومَةٍ ..بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ)؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ عِنْدَ فَسَادِ الْعَوَضِ، (وَفِي قَوْلٍ: بِبَدْلِ الْخَمْرِ) وَهُوَ قَدْرُهَا مِنَ الْعَصِيرِ، كَالْقَوْلَيْنِ فِي إِصْدَاقِهَا، وَلَوْ خَالَعَ عَلَى مَا لَا يُقْصَدُ، كَالدَّمِ.. وَقَعَ رَجْعِيًّا، بِخِلَافِ الْمَيْتَةِ؛ لِأَنَّهَا قَدْ تُقْصَدُ لِلْجَوَارِحِ وَاللِّصْرُورَةِ.

التوكيل في الخلع

(وَلَهُمَا (٣) التَّوَكُّلُ فِي الْخُلْعِ، (فَلَوْ قَالَ لَوَكِيلِهِ: خَالَعَهَا بِمِائَةٍ.. لَمْ يَنْقُصْ عَنْهَا)، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهَا مِنْ جَنْسِهَا أَوْ غَيْرِهِ (٤) (وَإِنْ أَطْلَقَ.. لَمْ يَنْقُصْ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ)؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ، وَلَهُ أَنْ يَزِيدَ عَلَيْهِ مِنْ جَنْسِهِ وَغَيْرِهِ، (فَإِنْ نَقَصَ فِيهِمَا) بَأَنْ خَالَعَ بِدُونِ الْمِائَةِ فِي الْأَوَّلَى وَبِدُونِ مَهْرِ الْمِثْلِ فِي الثَّانِيَةِ (..لَمْ تُطْلَقْ)؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِلْمَأْدُونِ فِيهِ وَلِلْمُرَادِ، (وَفِي قَوْلٍ: يَقَعُ

(١) البضع- بضم الباء -: يطلق على الفرج، والجماع، والمهر، وملك الولي للمرأة. مشارق الأنوار ١/٦٩.

(٢) أي: مثل الصداق، وضابطه: "كل ما جاز أن يكون مهرا جاز أن يكون عوضا في الخلع".

(٣) أي: الزوجين.

(٤) لأن الزيادة هنا تعود بالنفع على الزوج، فمخالفة الوكيل هنا للأحسن، حيث تكون سببا للخير الكثير له.

بِمَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِنَقْصِهِ عَنِ الْمَادُونِ فِيهِ وَالْمُرَادُ، وَرَجَّحَهُ فِي "أَصْلِ الرُّوْضَةِ" فِي الثَّانِيَةِ (١) بِخِلَافِ الْأُولَى (٢)؛ لِلْمُخَالَفَةِ فِيهَا لِصَرِيحِ الْإِدْنِ.

(وَلَوْ قَالَتْ لَوَكِيلُهَا: اخْتَلَعَ بِأَلْفٍ، فَأَمْتَلَّ.. نَفَذَ) وَكَذَا لَوْ اخْتَلَعَهَا بِأَقْلٍ مِنْ أَلْفٍ، (وَأِنْ زَادَ فَقَالَ: اخْتَلَعَهَا بِأَلْفَيْنِ مِنْ مَالِهَا بِوَكَايَتِهَا.. بَانَتْ، وَيَلْزَمُهَا مَهْرٌ مِثْلٌ)؛ لِفَسَادِ الْمُسَمَّى بِزِيَادَتِهِ عَلَى الْمَادُونِ فِيهِ، (وَفِي قَوْلٍ: الْأَكْثَرُ مِنْهُ وَمِمَّا سَمَّيْتُهُ)؛ لِرِضَاهَا بِمَا سَمَّيْتُهُ زَائِدًا عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، كَذَا حَكَى هَذَا الْقَوْلُ فِي "الْمَحَرَّرِ" (٣) وَ"الشَّرْحِ" (٤)، وَزَادَ فِي "الشَّرْحِ" فِي بَيَانِهِ: أَنَّهُ إِذَا كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ زَائِدًا عَلَى مَا سَمَّاهُ الْوَكِيلُ لَا يَجِبُ الرَّائِدُ عَلَيْهِ؛ لِرِضَا الزَّوْجِ بِهِ، ثُمَّ قَالَ: "وَالْعِبَارَةُ الْوَافِيَةُ بِمَقْصُودِ الْقَوْلِ أَنْ يُقَالَ: يَجِبُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ مِمَّا سَمَّيْتُهُ هِيَ، وَمِنْ أَقْلِ الْأَمْرَيْنِ مِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ وَمِمَّا سَمَّاهُ الْوَكِيلُ، وَعَلَى هَذَا اقْتَصَرَ فِي الرُّوْضَةِ فِي حِكَايَتِهِ (٥)، (وَأِنْ أَضَافَ الْوَكِيلُ الْخُلْعَ إِلَى نَفْسِهِ (٦).. فَخُلْعٌ أَجْنَبِيٌّ)، وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا سَيَأْتِي، (وَالْمَالُ عَلَيْهِ دُونَهَا (٧) (وَأِنْ أَطْلَقَ) الْخُلْعَ، أَي: لَمْ يُضِفْهُ إِلَيْهَا وَلَا إِلَى نَفْسِهِ، (فَالْأَظْهَرُ: أَنَّ عَلَيْهَا مَا سَمَّيْتُهُ (٨) وَعَلَيْهِ الزِّيَادَةُ (٩)، فَعَلَى كُلِّ مِنْهُمَا فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ أَلْفٌ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْأَمْرَيْنِ، مِمَّا سَمَّيْتُهُ، وَمِنْ مَهْرِ الْمِثْلِ، مَا لَمْ يَزِدْ عَلَى مُسَمَّى الْوَكِيلِ كَمَا تَقَدَّمَ، وَعَلَيْهِ التَّكْمِلَةُ.. إِنْ نَقَصَ عَنْ مُسَمَّاهُ، وَلَوْ أَضَافَ الْوَكِيلُ مَا سَمَّيْتُهُ إِلَيْهَا، وَالزِّيَادَةُ إِلَى نَفْسِهِ.. ثَبَتَ الْمَالُ كَذَلِكَ، وَحَيْثُ يَلْزَمُهَا الْمَالُ.. يُطَالِبُهَا الزَّوْجُ

(٥) وهي النقص عن مهر المثل في حال إطلاق الموكل للوكيل.. وقد ذكر النووي في الروضة أن النص في هذه

الحالة هو: وقوع الطلاق ويجب مهر المثل. روضة الطالبين (٣٩١/٧).

(١) وهي النقص عن مهر المثل إذا حدد الموكل للوكيل المخالعة بمائة، فإن نقص عنها لم يقع الطلاق وقد ذكر

النووي أيضا أنه النص. روضة الطالبين (٣٩١/٧).

(٢) المحرر للرافعي (ص ٣٢٢).

(٣) الشرح الكبير المعروف بالعزیز للرافعي (٤٢٤/٨).

(٤) روضة الطالبين (٣٩٢/٧).

(٥) بأن قال: من مالي.

(٦) لأن إضافته الخلع إلى نفسه إعراض عن التوكيل واستبداد بالخلع مع الزوج.

(٧) لالتزامها بإياه.

(٨) لأنها لم ترض بأكثر مما سمته.

به، وَلَوْ أَطْلَقْتُ التَّوَكِيلَ بِالِاخْتِلَاعِ.. لَمْ يَزِدِ الْوَكِيلُ عَلَى مَهْرِ الْمِثْلِ، فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ.. وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، كَمَا لَوْ زَادَ عَلَى الْمُقَدَّرِ، وَلَا يَجِيءُ قَوْلُ وَجُوبِ أَكْثَرِ الْأَمْرَيْنِ.

(وَيَجُوزُ تَوَكُّلُهُ) أَي: الزَّوْجُ فِي الْخُلْعِ مِنْ مُسْلِمَةٍ (ذِمِّيًّا)؛ لِصِحَّةِ خُلْعِهِ مِمَّنْ أَسْلَمَتْ تَحْتَهُ فِي الْعِدَّةِ ثُمَّ أَسْلَمَ، (وَعَبْدًا، وَمَحْجُورًا عَلَيْهِ بِسَفْهِهِ)، وَلَا يُشْتَرَطُ إِذْنُ السَّيِّدِ وَالْوَلِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِوَكِيلِ الزَّوْجِ فِي الْخُلْعِ عَهْدَةٌ، بِخِلَافِ وَكِيلِ الزَّوْجَةِ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ سَفِيهَا وَإِنْ أَذِنَ الْوَلِيُّ لَهُ، إِلَّا إِذَا أَضَافَ الْمَالَ إِلَيْهَا.. فَتَبَيَّنَ، وَيَلْزَمُهَا؛ إِذْ لَا ضَرَرَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ، فَإِنْ أَطْلَقَ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا كَاخْتِلَاعِ السَّفِيهِةِ. قَالَهُ الْبَغَوِيُّ^(١) وَأَقْرَأَهُ الشَّيْخَانِ^(٢)، وَلَوْ وَكَّلْتُ عَبْدًا فِي الْخُلْعِ.. جَازَ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ السَّيِّدُ، فَإِنْ أَضَافَ الْمَالَ إِلَيْهَا.. فَهِيَ الْمُطَالَبَةُ بِهِ، وَإِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَأْذَنْ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ.. طُوبِلَ بِالْمَالِ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَإِذَا غَرِمَهُ.. رَجَعَ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ إِذَا قَصَدَ الرُّجُوعَ، وَإِنْ أَذِنَ السَّيِّدُ فِي الْوَكَالَةِ.. تَعَلَّقَ الْمَالُ بِكَسْبِ الْعَبْدِ، فَإِذَا أَدَّى مِنْهُ.. رَجَعَ بِهِ عَلَى الزَّوْجَةِ، وَيَجُوزُ تَوَكُّلُهَا فِي الْخُلْعِ ذِمِّيًّا أَيْضًا.

(وَلَا يَجُوزُ تَوَكُّلُ مَحْجُورٍ عَلَيْهِ فِي قَبْضِ الْعَوَضِ) فِي الْخُلْعِ، فَإِنْ وَكَّلَهُ وَقَبِضَ.. فَفِي "التَّيْمَةِ"^(٣): أَنَّ الْمُخْتَلَعَ يَبْرَأُ وَالْمُوكَّلُ مُضَيِّعٌ لِمَالِهِ، وَأَقْرَأَهُ الشَّيْخَانِ (وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ تَوَكُّلِهِ امْرَأَةً بِخُلْعِ زَوْجَتِهِ أَوْ طَلَاقِهَا)؛ لِأَنَّ لِلْمَرْأَةِ تَطْلِيقَ نَفْسِهَا بِقَوْلِهَا لَهَا: "طَلِّقِي نَفْسِي"، وَذَلِكَ إِمَّا تَمْلِيكَ لِلطَّلَاقِ أَوْ تَوَكُّلٍ بِهِ. إِنْ كَانَ تَوَكُّلًا.. فَذَلِكَ، أَوْ تَمْلِيكَ.. فَمَنْ جَازَ تَمْلِيكَهُ الشَّيْءَ جَازَ تَوَكُّلَهُ بِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ، وَلَوْ وَكَّلَتْ الزَّوْجَةَ امْرَأَةً

(١) هو الإمام الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي، فقيه شافعي محدث، يلقب بـ"محيي السنة"، مولده سنة ٤٣٦هـ، ووفاته سنة ٥١٦هـ، من أشهر مؤلفاته: "التهذيب في فقه الإمام الشافعي"، "شرح السنة" و"المصابيح" معالم التنزيل "والبغوي نسبة إلى "بغ" و"بغشور" بلدة من بلاد خراسان بين "هراة" و"مروالروذ". طبقات الشافعية لابن قاضي شعبة ٢٨١/١، الأعلام للزركلي ٢٥٨/٢، ٢٥٩.

(٢) الشيخان: مصطلح عند الشافعية يطلقونه على الإمامين: الرافعي والنووي. (الفتح المبين، ص ١٣٦)

(٣) التئمة: يقصد بها "تئمة الإبانة" للمتولي أبي سعيد عبد الرحمن بن مأمون، المعروف: بالمتولي، النيسابوري، الشافعي. المتوفى: سنة ٤٧٨هـ، كتبها: إلى الحدود، وجمع فيها: نوادر المسائل، وغرائبها، لا تكاد توجد في غيرها وقد تمم بها كتاب: "الإبانة"، في فقه الشافعي "للشيخ، الإمام، أبي القاسم: عبد الرحمن بن محمد الفوراني، المروزي، الشافعي، المتوفى: سنة ٤٦١هـ. وهو: كتاب مشهور بين الشافعية. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لحاجي خليفة ١/١.

بِاخْتِلَاعِهَا.. جَارَ بِلَا خِلَافٍ؛ لِاسْتِقْلَالِ الْمَرْأَةِ بِالِاخْتِلَاعِ، (وَلَوْ وَكَلَا رَجُلًا) فِي الْخُلْعِ (..تَوَلَّى طَرَفًا) مِنْهُ مَعَ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ وَكَيْلِهِ، وَلَا يَتَوَلَّى الطَّرَفَيْنِ كَمَا فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، (وَقِيلَ: (١)) يَتَوَلَّى (الطَّرَفَيْنِ)؛ لِأَنَّ الْخُلْعَ يَكْفِي فِيهِ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ، كَمَا لَوْ قَالَ: إِنَّ أُعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ فَأَعْطَتْهُ ذَلِكَ.. يَقَعُ الطَّلَاقُ خُلْعًا، وَعَلَى هَذَا: فَبِالِاخْتِلَاعِ بِأَحَدِ شِقِّي الْخُلْعِ خِلَافٌ كَمَا فِي بَيْعِ الْأَبِ مَالِ نَفْسِهِ مِنْ وَلَدِهِ.

صيغة الخلع وما يتعلق بها

(فَصْلٌ: الْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ طَلَاقٌ يُنْقِصُ الْعَدَّةَ، فَإِذَا خَالَعَهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.. لَمْ يَنْكِحْهَا إِلَّا بِمُحَلِّلٍ، (وَفِي قَوْلٍ: فَسُخِّ لَا يَنْقُصُ عَدَدًا) وَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ حَضَرٍ، (فَعَلَى الْأَوَّلِ: لَفْظُ الْفُسْخِ) كَأَنَّ قَالَ فَسَخْتُ نِكَاحَكَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ (..كِنَايَةً) فِي الطَّلَاقِ يَحْتَاجُ فِي وَفْوَعِهِ إِلَى نِيَّةٍ، كَمَا أَنَّهُ عَلَى قَوْلِ الْفُسْخِ: صَرِيحٌ فِيهِ. (وَالْمُفَادَةُ) كَأَنَّ قَالَ: فَدَيْتُكَ بِكَذَا، فَقَالَتْ قَبِلْتُ أَوْ افْتَدَيْتُ. (..كَخُلْعٍ) فِي صَرَاحَتِهِ الْآتِيَةِ، (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِيُورِدَ الْقُرْآنُ بِهِ، قَالَ تَعَالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] وَالثَّانِي: أَنَّهُ كِنَايَةٌ جَزْمًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَتَكَرَّرْ فِي الْقُرْآنِ، وَلَا شَاعَ فِي لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ.

(وَلَفْظُ الْخُلْعِ.. صَرِيحٌ فِي الطَّلَاقِ؛ لِشَيْوعِهِ فِي الْعُرْفِ وَالِاسْتِعْمَالِ لِلطَّلَاقِ (وَفِي قَوْلٍ كِنَايَةً) فِيهِ؛ حَطًّا لَهُ عَنْ لَفْظِ الطَّلَاقِ الْمُتَكَرَّرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ. (فَعَلَى الْأَوَّلِ (٢): لَوْ جَرَى بِغَيْرِ ذِكْرِ مَالٍ)، كَأَنَّ قَالَ: خَالَعْتُكَ، فَقَبِلَتْ (..وَجَبَ مَهْرٌ مِثْلُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِإِطْرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ الْخُلْعِ عَلَى الْمَالِ، فَإِذَا لَمْ يُذَكَّرْ.. رَجَعَ إِلَى مَهْرِ الْمِثْلِ؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ.. وَحَصَلَتْ الْبَيِّنُونَةُ، وَالثَّانِي: لَا يَجِبُ شَيْءٌ؛ لِعَدَمِ ذِكْرِ الْعَوَضِ.. وَيَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، وَمَا ذَكَرَهُ عَلَى الْأَوَّلِ يَأْتِي عَلَى الثَّانِي أَيْضًا؛ لَكِنْ مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ.

(وَيَصِحُّ) الْخُلْعُ، (بِكِنَايَاتِ الطَّلَاقِ مَعَ النِّيَّةِ) لَهُ، وَسَيَأْتِي مُعْظَمُهَا فِي بَابِهِ، وَعَلَى قَوْلِ الْفُسْخِ.. يَصِحُّ بِالْكِنَايَةِ أَيْضًا عَلَى الْأَصَحِّ، وَمِنْهَا: "مَسْأَلُهُ بِعُتْكَ نَفْسَكَ" الْآتِيَةُ (و)

(٤) قول الشراح: (قيل) يقال: لما فيه اختلاف، أو لجهل القائل، أو للاختصار. الفتح المبين، ص ١٦٤.

(١) وهو: أن الخلع صريح في الطلاق.

يَصِحُّ (بِالْعَجْمِيَّةِ) نَظَرًا لِمَعْنَى، وَالْمُرَادُ بِهَا: مَا عَدَا الْعَرَبِيَّةَ، وَلَا يَجِيءُ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ فِي النِّكَاحِ النَّاطِرِ لِمَا وَرَدَ فِيهِ. (وَلَوْ قَالَ: بِعَثْكَ نَفْسُكَ بِكَذَا، فَقَالَتْ: اشْتَرَيْتُ) أَوْ قَبِلَتْ (..فَكِنَايَةُ خُلْعٍ) سِوَاءِ جُعِلَ بِلَفْظِهِ طَلَاقًا أَمْ فَسْخًا، (وَإِذَا بَدَأَ الزَّوْجُ (بِصِغَةِ مُعَاوَضَةٍ) كَطَلَّقْتُكَ أَوْ خَالَعْتُكَ بِكَذَا، فَقَبِلَتْ (وَقُلْنَا الْخُلْعُ) فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (طَلَّاقٌ) - وَهُوَ الرَّاجِعُ - (..فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ فِيهَا شَوْبُ تَغْلِيْقٍ)؛ لِتَوْفُّقِ وَقُوعِ الطَّلَاقِ فِيهِ عَلَى الْقَبُولِ، فَإِنْ قُلْنَا: فَسَخٌ.. فَلَيْسَ فِيهِ شَوْبُ تَغْلِيْقٍ، (لَهُ الرُّجُوعُ قَبْلَ قَبُولِهَا) نَظَرًا لِجِهَةِ الْمُعَاوَضَةِ (وَيُشْتَرَطُ قَبُولُهَا بِلَفْظٍ غَيْرِ مُنْفَصِلٍ) كَمَا فِي الْبَيْعِ (فَلَوْ اخْتَلَفَ إِجَابُ وَقَبُولُ، كَطَلَّقْتُكَ بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ وَعَكْسُهُ)، كَطَلَّقْتُكَ بِأَلْفَيْنِ فَقَبِلَتْ بِأَلْفٍ، (أَوْ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثَلَاثِ أَلْفٍ.. فَلَعُوْ)، فِي الْمَسَائِلِ الثَّلَاثِ، وَفِي "الشَّامِلِ" (١): فِي الْأُولَى: أَنَّهُ يَصِحُّ، وَلَا يُلْزَمُهَا الْأَلْفُ (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ.. فَأَلْأَصَحُّ: وَقُوعُ الثَّلَاثِ وَوُجُوبُ أَلْفٍ)؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ يَسْتَقِلُّ بِالطَّلَاقِ، وَالزَّوْجَةُ إِنَّمَا يُعْتَبَرُ قَبُولُهَا بِسَبَبِ الْمَالِ، وَقَدْ وَافَقَتْهُ فِي قَدْرِهِ، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ طَلَّاقٌ؛ لِاخْتِلَافِ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، وَالثَّلَاثُ: يَقَعُ وَاحِدَةً؛ نَظَرًا إِلَى قَبُولِهَا؛ فَإِنَّهَا لَوْ لَمْ تُقْبَلْ شَيْئًا.. لَا يَقَعُ شَيْءٌ، وَعَلَى هَذَا، وَقُوعُ الثَّلَاثِ، قِيلَ: يَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ رَدًّا بِاخْتِلَافِ الْمَذْكُورِ إِلَى التَّأْثِيرِ فِي الْعَوَضِ فَيُفْسِدُهُ (وَإِنْ بَدَأَ بِصِغَةِ تَغْلِيْقٍ، كَمَتَى، أَوْ مَتَى مَا أُعْطِيتَنِي) كَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ (.. فَتَغْلِيْقٌ، فَلَا رُجُوعَ لَهُ) قَبْلَ الْإِعْطَاءِ (وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا وَلَا الْإِعْطَاءُ فِي الْمَجْلِسِ) أَي: عَلَى الْفَوْرِ، فَمَتَى وَجِدَ الْإِعْطَاءُ.. تُطَلَّقُ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مَا ذَكَرَهُ. (وَإِنْ قَالَ: "إِنْ" أَوْ "إِذَا" أُعْطِيتَنِي) كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، (..فَكَذَلِكَ) أَي: تَغْلِيْقٌ لَا رُجُوعَ لِلزَّوْجِ فِيهِ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْقَبُولُ لَفْظًا (لَكِنْ يُشْتَرَطُ فِيهِ (إِعْطَاءٌ عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّهُ قَضِيَّةُ الْعَوَضِ فِي الْمُعَاوَضَةِ، وَإِنَّمَا تُرِكَتْ هَذِهِ

(٢) كتاب "الشامل" في فروع الشافعية" لأبي نصر: عبد السيد بن محمد، المعروف: بابن الصباغ، الشافعي،

المتوفى: سنة ٤٧٧هـ، قال ابن خلكان: وهو من أجود كتب الشافعية، وأصحها نقلًا، قال حاجي

خليفة: وله شروح، وتعليقات، منها: شرح للإمام أبي بكر: محمد بن أحمد البغدادي،

الشافعي، المتوفى: سنة ٥٠٧هـ، في عشرين مجلدا، سماه: (الشافعي) وشرح: لعثمان بن عبد الملك

الكردي، المتوفى: سنة ٧٣٨هـ، وشرح: لابن خطيب الجبريني، فخر الدين، عثمان بن علي الحلبي

المكتوفى سنة ٧٣٩هـ.

كشف الظنون (١/٢٥٠).

الْقَضِيَّةُ فِي "مَتَى"؛ لِأَنَّهَا صَرِيحَةٌ فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ شَامِلَةً لِجَمِيعِ الْأَوْقَاتِ كَأَيِّ وَقْتٍ وَإِنْ لَا تَشْمَلُهَا، وَاخْتَارَ الشَّيْخُ أَبُو إِسْحَقَ الشَّيرَازِي^(١) فِي "المُهَذَّبِ"^(٢) (الْحَاقُّ "إِذَا" بِـ"مَتَى" مُحْتَجًّا، بِأَنَّهُ إِذَا قِيلَ لَكَ: مَتَى أَلْقَاكَ؟ جَازَ أَنْ تَقُولَ: إِذَا شِئْتُ، كَمَا تَقُولُ: مَتَى شِئْتُ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَقُولَ: إِنْ شِئْتُ^(٣))، وَقِيلَ: لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ بَلْ يَكْفِي الْإِعْطَاءُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَإِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ، كَمَا فِي الْقَبْضِ فِي الصَّرْفِ وَالسَّلَمِ.

(وَإِنْ بَدَأَتْ بِطَلَبِ الطَّلَاقِ) كَأَنَّ قَالَتْ: طَلَّقْنِي عَلَى كَذَا، (فَأَجَابَ.. فَمُعَاوَضَةً مَعَ شَوْبِ جَعَالَةٍ)؛ لِأَنَّهَا تَبْذُلُ الْمَالَ فِي تَحْصِيلِ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الزَّوْجُ مِنَ الطَّلَاقِ الْمُحْصَلِ لِلْغَرَضِ، كَمَا أَنَّ الْجَعَالََةَ: بَذْلُ الْجَاعِلِ الْمَالَ فِي تَحْصِيلِ مَا يَسْتَقِلُّ بِهِ الْعَامِلُ مِنَ الْفِعْلِ الْمُحْصَلِ لِلْغَرَضِ، (فَلَهَا الرُّجُوعُ قَبْلَ جَوَابِهِ)؛ لِأَنَّ هَذَا حَقٌّ لَهَا، (وَيُشْتَرَطُ فَوْرٌ لِجَوَابِهِ)؛ لِأَنَّهُ شَأْنُ الْمُعَاوَضَةِ، وَلَا فَرْقَ فِيهَا ذِكْرَ بَيْنَ أَنْ تَطْلُبَ بِصِغَةِ مُعَاوَضَةٍ أَوْ تَغْلِقَ، وَلَا بَيْنَ أَنْ يَكُونَ التَّغْلِيقُ بِـ"إِنْ" أَوْ بِـ"مَتَى" نَحْوُ: إِنْ طَلَّقْتَنِي، أَوْ مَتَى طَلَّقْتَنِي فَكَذَا، وَإِنْ أَجَابَهَا بِأَقْلٍ مِمَّا ذَكَرْتَهُ.. لَمْ يَضُرَّ. (وَلَوْ طَلَبَتْ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ) وَهُوَ يَمْلِكُهَا، (فَطَلَّقَ طَلْقَةً بِثُلَاثِهِ) أَوْ سَكَتَ عَنْ الْعَوَضِ، (..فَوَاحِدَةً بِثُلَاثِهِ) تَغْلِيْبًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ، وَلَوْ قَالَ فِيهَا: رُدَّ عِبْدِي الثَّلَاثَةَ وَلَكَ أَلْفٌ فَرَدَّ وَاحِدًا.. اسْتَحَقَّ ثُلُثَ الْأَلْفِ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ الزَّوْجُ طَلَّقْتُكَ ثَلَاثًا بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِثُلَاثِهِ.. أَنَّهُ لَعَوَّ؛ لِأَنَّهُ صِغَةُ مُعَاوَضَةٍ اخْتَلَفَ فِيهَا الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِيهَا إِذَا كَانَ لَا يَمْلِكُ إِلَّا طَلْقَةً. (وَإِذَا خَالَعَ أَوْ طَلَّقَ بِعَوَضٍ.. فَلَا رَجْعَةَ) سَوَاءً جُعِلَ الْخُلْعُ

(١) هو الإمام القدوة الشيخ إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزي، الشيرازي، من كبار فقهاء الشافعية. قَالَ الدَّهْلِيُّ لِقَبِهِ جَمَالُ الْإِسْلَامِ، مَوْلَدُهُ سَنَةَ ٣٩٣، وَقِيلَ: غَيْرَ ذَلِكَ. وَوَفَاتَهُ سَنَةَ ٤٧٦ هـ. مِنْ أَهَمِّ مُصَنَّفَاتِهِ: "المُهَذَّبُ"، وَ"التَّنْبِيهُ" فِي الْفَقْهِ، وَ"الْمَع"، وَ"التَّبَصُّرَةُ" فِي الْأَصُولِ وَ"طَبَقَاتُ الْفُقَهَاءِ" وَغَيْرَهَا. سِيرَ أَعْلَامُ النُّبَلَاءِ لِلذَّهَبِيِّ ٤٥٢/١٨ وَمَا بَعْدَهَا. طَبَقَاتُ الشَّافِعِيَّةِ لِابْنِ قَاضِي شَهْبَةَ ٢٨٣/١، وَمَا بَعْدَهَا.

(٢) كِتَابُ "المُهَذَّبِ" لِلشَّيْخِ الشَّيرَازِيِّ، هُوَ أَحَدُ الْمَتُونِ الْمَشْهُورَةِ وَالْمُتَدَاوِلَةِ فِي الْمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَدْ شَرَحَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ، أَشْهَرُهُمُ الْإِمَامُ النَّوَوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي شَرْحِهِ الْمُسَمَّى بِـ"الْمَجْمُوعِ"، وَكَذَلِكَ الْإِمَامُ الْعِمْرَانِيُّ فِي كِتَابِهِ الْمُسَمَّى بِـ"الْبَيَانِ"، وَكِلَاهُمَا مَطْبُوعٌ. قَالَ ابْنُ قَاضِي شَهْبَةَ فِي طَبَقَاتِهِ ٢٨٣/١: "وَبَدَأَ فِي الْمُهَذَّبِ سَنَةَ خَمْسٍ وَخَمْسِينَ وَفَرَّغَ مِنْهُ سَنَةَ تِسْعٍ وَسِتِّينَ أَخَذَهُ مِنْ تَعْلِيلِ شَيْخِهِ أَبِي الطَّيِّبِ".

(١) المِهْذَبُ لِلشَّيرَازِيِّ (٩٣/٢).

فَسَخًا أَمْ طَلَقًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْعَوْضُ صَحِيحًا أَمْ فَاسِدًا، (فَإِنْ شَرَطَهَا)، كَأَنَّ قَالَ: خَالَعْتُكَ أَوْ طَلَّقْتُكَ بِدَيْنَارٍ عَلَى أَنَّ لِي عَلَيْكَ الرَّجْعَةَ، (..فَرَجَعِي، وَلَا مَالَ)؛ لِأَنَّ شَرْطَ الْمَالِ، وَشَرْطَ الرَّجْعَةِ يَتَنَافَيَانِ فَيَتَسَاقَطَانِ، وَيَبْقَى مُجَرَّدُ الطَّلَاقِ، وَقَضِيَّتُهُ: ثُبُوتُ الرَّجْعَةِ، (وَفِي قَوْلٍ: بَائِنٌ بِمَهْرٍ مِثْلٍ)؛ لِفَسَادِ الْعَوْضِ بِاشْتِرَاطِ الرَّجْعَةِ، (وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقَنِي بِكَذَا وَازْتَدَتْ) عَقِبَهُ، (فَأَجَابَ: إِنْ كَانَ) الْإِزْتِدَادُ (قَبْلَ دُخُولِ أَوْ بَعْدَهُ وَأَصْرَتْ) عَلَى الرِّدَّةِ، (حَتَّى انْقَضَتْ الْعِدَّةُ..بَانَتْ بِالرِّدَّةِ، وَلَا مَالَ)، وَلَا طَلَاقٍ (وَإِنْ أَسْلَمَتْ فِيهَا.. طَلَّقَتْ بِالْمَالِ)، الْمُسَمَّى حِينَ الْجَوَابِ، وَتَحْسَبُ الْعِدَّةُ مِنْ وَقْتِ الطَّلَاقِ. (وَلَا يَضُرُّ تَخْلُلُ كَلَامٍ يَسِيرُ بَيْنَ إِجَابِ وَقَبُولِ) فِي الْخُلْعِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ الْإِزْتِدَادِ بِالْقَوْلِ، بِخِلَافِ الْكَلَامِ الْكَثِيرِ فَيَضُرُّ؛ لِأَنَّ قَائِلَهُ يُعَدُّ بِهِ مُعْرِضًا.

(فَضْلٌ: قَالَ أَنْتَ طَالِقٌ وَعَلَيْكَ أَوْ وَلِيٍّ عَلَيْكَ كَذَا) كَأَلْفٍ (وَلَمْ يَسْبِقْ طَلَبُهَا بِمَالٍ.. وَقَعَ رَجْعِيًّا قَبْلَتْ أَوْ لَا، وَلَا مَالَ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ عَوْضًا وَشَرْطًا؛ بَلْ جُمْلَةً مَعْطُوفَةً عَلَى الطَّلَاقِ، فَلَا يَتَأَثَّرُ بِهَا الطَّلَاقُ، وَتَلْعُو فِي نَفْسِهَا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا إِذَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي، وَعَلَيَّ أَوْ وَلِيٍّ عَلَيَّ أَلْفٌ.. فَإِنَّهُ يَقَعُ بَائِنًا بِالْأَلْفِ، وَالْفَرْقُ: أَنَّ الزَّوْجَةَ يَتَعَلَّقُ بِهَا التَّزَامُ الْمَالِ، فَيُحْمَلُ اللَّفْظُ مِنْهَا عَلَى الْإِلْتِزَامِ، وَالزَّوْجُ يَنْفَرِدُ بِالطَّلَاقِ، فَإِذَا لَمْ يَأْتِ بِصِيغَةٍ مُعَاوَضَةٍ.. حُمِلَ اللَّفْظُ مِنْهُ عَلَى مَا يَنْفَرِدُ بِهِ. (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ مَا يُرَادُ بِ"طَلَّقْتُكَ بِكَذَا" وَصَدَّقْتَهُ.. فَكُھُو فِي الْأَصَحِّ) أَيُّ: فَتَبِينُ مِنْهُ بِالْمُسَمَّى إِنْ كَانَتْ قَبْلَتْ، وَيَكُونُ الْمَعْنَى: وَعَلَيْكَ كَذَا عَوْضًا، فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ.. لَمْ يَقَعِ شَيْءٌ، وَالثَّانِي(١): لَا أَثَرُ لِلتَّوَافُقِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَصْلُحُ لِلْإِلْتِزَامِ، فَكَأَنَّ لَا إِرَادَةَ، فَإِنْ لَمْ تُصَدِّقْهُ.. حَلَفَتْ عَلَى الْأَوَّلِ(٢) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ أَرَادَ ذَلِكَ إِنْ كَانَتْ قَبْلَتْ، فَإِنْ لَمْ تَقْبَلْ.. فَلَا حَلِفَ، وَعَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي: لَا حَلِفَ؛ لِأَنَّهُ لَا أَثَرُ لِلتَّضَدِيقِ عَلَيْهِ، وَعَلَى كُلٍّ: كَأَنَّ لَا إِرَادَةَ. (وَإِنْ سَبَقَ) طَلَبُهَا لِلطَّلَاقِ بِمَالٍ كَأَلْفٍ، (..بَانَتْ بِالْمَذْكُورِ) لِتَوَافُقِهِمَا عَلَيْهِ، فَإِنْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الْكَلَامِ لَا الْجَوَابِ. وَقَعَ رَجْعِيًّا، كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ(٣) قَالَ: وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ

(١) يعني: مقابل الأصح.

(٢) يعني: على الأصح.

(٣) لفظ (الإمام) عند الشافعية، يقصدون به: إمام الحرمين الجويني: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف،

صاحب كتاب "نهاية المطلب"، و"البرهان"، المتوفى سنة ٤٧٨ هـ. الفتح المبين، ص ١٣٦.

فِي ذَلِكَ بَيِّنَةٍ^(١) (وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لِي عَلَيْكَ كَذًا.. فَأَلْمَذْهَبُ: أَنَّهُ كَذًا طَلَّقْتُكَ بِكَذَا" فَإِذَا قِيلَتْ) عَلَى الْفَوْرِ (..بَانَتْ، وَوَجِبَ الْمَالُ). وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ^(٢): أَنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا وَلَا يَثْبُتُ الْمَالُ^(٣)؛ لِأَنَّ الصَّيْغَةَ صِيغَةُ شَرْطٍ، وَالشَّرْطُ فِي الطَّلَاقِ يُلْغُو إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَضَايَاهُ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ عَلَى أَنْ لَا أَتَزَوَّجَ بَعْدَكَ، أَوْ عَلَى أَنْ لَكَ عَلَيَّ كَذًا، وَحَكَى وَجْهَيْنِ^(٤) فِيمَا إِذَا فَسَّرَ بِالْإِلْزَامِ هَلْ يَقْبَلُ أَوْ لَا؟ أَي: مَعَ انْكَارِ الْمَرْأَةِ إِزَادَةَ ذَلِكَ، بِخِلَافِ انْكَارِهَا فِي قَوْلِهِ: وَلِي عَلَيْكَ كَذًا، حَيْثُ لَا يَقْبَلُ عَلَيْهَا قَطْعًا؛ لِأَنَّ الصَّيْغَةَ هُنَا أَقْرَبُ إِلَى الْإِلْزَامِ إِنْ لَمْ تَكُنْ ظَاهِرَةً فِيهِ مِنْ تِلْكَ، وَالْمُصَنِّفُ حَيْثُ عَبَّرَ بِـ"الْمَذْهَبِ"^(٥) سَاقٍ مَا ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ طَرِيقَةً؛ لِأَنَّهُ ذَكَرَهُ حِكَايَةً لِلْمَذْهَبِ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ ضَمَنْتَ لِي أَلْفًا فَأَنْتَ طَالِقٌ، فَضَمَنْتَ فِي الْفَوْرِ.. بَانَتْ، وَلَزِمَهَا الْأَلْفُ، وَإِنْ قَالَ: مَتَى ضَمَنْتَ)، لِي أَلْفًا فَأَنْتَ طَالِقٌ (فَمَتَى ضَمَنْتَ.. طَلَّقْتَ)، وَالْفَرْقُ: مَا تَقَدَّمَ فِي "إِنْ أَعْطَيْتَنِي" وَ"مَتَى أَعْطَيْتَنِي"، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الرَّجُوعُ قَبْلَ الضَّمَانِ، وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ لَفْظًا كَمَا تَقَدَّمَ هُنَاكَ، (وَإِنْ ضَمَنْتَ دُونَ أَلْفٍ.. لَمْ تُطَلِّقْ)؛ لِانْتِفَاءِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ، (وَلَوْ ضَمَنْتَ

(٤) نهاية المطالب للجويني (٣٣٩/١٣). وفيه: "ويتصل بهذا الطرف: أن الزوج لو قال: طَلَّقَهَا ابتداءً، ولم أقصد جواها، وقد يستفيد بذلك الرجعة، ونفي البينونة، فالوجه تصديقه..... وإن قال: قصدت ابتداءً التطلق، صدق؛ فإن اتهم خلف".

(٥) هو حجة الإسلام، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي، من كبار فقهاء الشافعية وعظمائهم. كان رأساً في العلم والزهد، مولده سنة ٤٥٠ هـ، ووفاته سنة ٥٠٥ هـ. من أهم مصنفاته: "الوسيط"، و"الوجيز" في الفقه، و"المستصفى" في الأصول، و"إحياء علوم الدين" في الزهد والرفائق. طبقات الشافعية لابن السبكي (١٩١/٦)، وما بعدها، طبقات الشافعية لابن قاضي شعبة (٢٩٣/١)، الأعلام للزركلي (٢٢/٧).

(٦) الوجيز للغزالي، ص ٣٧٤.

(٧) أي: الغزالي في الوجيز، ينظر: ص ٣٧٤، حيث قال: "نعم لو فسر بالإلزام ففي قبوله خلاف".

(١) مصطلح "المذهب" مصطلح استخدمه النووي - رحمه الله - في الدلالة على الراجح من الطريقتين أو الطرق عند اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب عن الإمام الشافعي - رحمه الله - حيث يكون هناك طريق لبعض الأصحاب يقولون فيه: أن للإمام الشافعي قولين مثلاً في المسألة، وطريق آخر يقول: له قول واحد، وقد يكون هناك طريق ثالث يقول: له ثلاثة أقوال مثلاً، فيعبر النووي بالمذهب؛ ليؤكد على الراجح والصواب من هذه الطرق، هل الإمام له قولان، أو ثلاثة، أو قول واحد في المسألة؟.

أَلْفَيْنِ.. طَلَّقَتْ)؛ لَوْجُودِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ مَعَ مَزِيدٍ، بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي طَلَّقْتُكَ بِأَلْفٍ، فَقَبِلَتْ بِأَلْفَيْنِ.. أَنَّهُ لَعَوٌ؛ لِأَنَّهَا صِيغَةٌ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَوَافُقُ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ، ثُمَّ الْمَزِيدُ يُلْغَوُ ضِمَانَهُ، وَلَوْ نَقَصَتْ أَوْ زَادَتْ فِي التَّغْلِيْقِ بِالْإِعْطَاءِ.. فَالْحُكْمُ كَمَا ذَكَرَ هُنَا، وَالْمَقْبُوضُ الزَّائِدُ عَلَى مَا عُلِقَ بِهِ أَمَانَةٌ عِنْدَهُ. (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقِي نَفْسَكَ إِنْ ضَمَنْتَ لِي أَلْفًا، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُ وَضَمَنْتُ أَوْ عَكْسَهُ) أَي: ضَمَنْتُ وَطَلَّقْتُ، (..بَانَتْ بِأَلْفٍ، فَإِنْ اقْتَصَرْتَ عَلَى أَحَدِهِمَا (١).. فَلَا بَيِّنُوَّةَ وَلَا مَالٍ؛ لِإِنْتِفَاءِ الْمُوَافَقَةِ، وَفِي الْمُوَافَقَةِ: يُشْتَرَطُ وُجُودُ التَّطْلِيْقِ، وَالضَّمَانِ عَلَى الْقَوْرِ، وَقِيلَ: يَكْفِي وُجُودُهُمَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ، وَلَا يُشْتَرَطُ إِعْطَاءُ الْمَالِ فِي الْمَجْلِسِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالضَّمَانِ هُنَا: الْقَبُولُ وَالْإِلْتِزَامُ، دُونَ الضَّمَانِ الْمُفْتَقِرِ إِلَى الْأَصَالَةِ. (وَإِذَا عُلِقَ بِإِعْطَاءِ مَالٍ فَوَضَعَتْهُ بَيْنَ يَدَيْهِ.. طَلَّقْتُ) وَإِنْ امْتَنَعَ مِنْ قَبْضِهِ؛ لِأَنَّ تَمَكُّنَهَا إِيَّاهُ مِنَ الْقَبْضِ إِعْطَاءٌ مِنْهَا، وَهُوَ بِالْإِمْتِنَاعِ مِنَ الْقَبْضِ مَقْوَتْ لِحَقِّهِ، وَقِيلَ: لَا تُطَلَّقُ؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ إِنَّمَا يَتِمُّ بِالتَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ (وَالْأَصَحُّ: دُخُولُهُ) أَي: الْمُعْطَى (فِي مِلْكِهِ) لِمَلِكِ الْمَرْأَةِ النُّبُوعِ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ، وَالْعَوْضَانِ يَتَقَارَنَانِ فِي الْمَلِكِ، وَالتَّانِي: لَا يَدْخُلُ فِي مِلْكِهِ؛ لِأَنَّ حُصُولَ الْمَلِكِ لَهُ مِنْ غَيْرِ لَفْظِ تَمْلِيكِ مِنْ جِهَتِهَا بَعِيدٌ، فَيُرَدُّ الْمُعْطَى وَيَرْجَعُ إِلَى مَهْرِ الْمَثَلِ.

(وَإِنْ قَالَ: إِنْ أَقْبَضْتَنِي)، كَذَا فَأَنْتَ طَالِقٌ (..فَقِيلَ): هُوَ (كَالْإِعْطَاءِ) فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ فِيهِ، وَمِنْهُ: اشْتِرَاطُ الْقَوْرِ، وَمِلْكُ الْمَقْبُوضِ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ يُقْصَدُ بِهِ مَا يُقْصَدُ بِالْإِعْطَاءِ، (وَالْأَصَحُّ): أَنَّهُ (كَسَائِرِ التَّغْلِيْقِ)؛ لِأَنَّ الْإِقْبَاضَ لَا يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ، بِخِلَافِ الْإِعْطَاءِ؛ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قِيلَ: أَعْطَاهُ عَطِيَّةً.. فَهُمْ مِنْهُ التَّمْلِيكُ، وَإِذَا قِيلَ: أَقْبَضَهُ.. لَمْ يُفْهَمْ مِنْهُ ذَلِكَ؟! (فَلَا يَمْلِكُهُ) أَي: الْمَقْبُوضُ، وَلَا يَرْجَعُ إِلَى مَهْرِ الْمَثَلِ (وَلَا يُشْتَرَطُ لِلْإِقْبَاضِ مَجْلِسٌ) (قُلْتُ (٢): وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيًّا، وَيُشْتَرَطُ لِتَحَقُّقِ الصِّفَةِ) وَهِيَ الْإِقْبَاضُ الْمُتَضَمِّنُ لِلْقَبْضِ.. (أَخْذُهُ بِيَدِهِ مِنْهَا وَلَوْ مُكْرَهَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)، فَلَا يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا يَمْنَعُ الْأَخْذُ كَرَاهًا

(٢) يعني قالت: ضمنت فقط دون طَلَّقْتُ، أو طَلَّقْتُ فقط دون ضمنت.

(١) لفظ (قلت) يستعمله النووي عند استدراكه على الرافعي في تصحيح قول، أو وجه، غير الذي صححه الرافعي في "المحرر"، فالنوي اختصر "منهاج الطالبين" من "المحرر" للرافعي، وفي اختصاره أبقى كثيرا من ألفاظه؛ لكنه استدرك عليه بعض الترجيحات، وزاد عليه مسائل أيضا، وفي كل هذا كان يقول في أوله: (قلت) وفي آخره: (والله أعلم)، وقد نص على ذلك - رحمه الله - في مقدمته للمنهاج.

مِنْ وَقُوعِ الطَّلَاقِ؛ لَوْجُودِ الصِّفَةِ، بِخِلَافِهِ فِي التَّغْلِيْقِ بِالْإِعْطَاءِ الْمُقْتَضِي لِلتَّمْلِيكِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُعْطَ، وَقَالَ الْإِمَامُ: يَكْفِي الْوَضْعُ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَحَكَى (١) فِي الْأَخْذِ كَرَهَا.. قَوْلَيْنِ، أَرْجَحُهُمَا: الْمُنْعُ. (وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِإِعْطَاءِ عَبْدٍ وَوَصَفَهُ بِصِفَةٍ سَلَمٍ فَأَعْطَتْهُ)، عَبْدًا (لَا بِالصِّفَةِ.. لَمْ تُطْلَقْ) أَوْ بِهَا (سَلِيمًا).. طَلَّقْتَ، وَمَلَكَهُ الزَّوْجُ، أَوْ (مَعِيًّا.. فَلَهُ) مَعَ وَقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ (رَدُّهُ) لِلْعَيْبِ (وَمَهْرٌ مِثْلُ، وَفِي قَوْلٍ: قِيمَتُهُ سَلِيمًا)، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُطَالِبَ بِعَبْدٍ بِتِلْكَ الصِّفَةِ سَلِيمًا؛ لَوْ قُوعِ الطَّلَاقِ بِالْمُعْطَى، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكَ عَلَى عَبْدٍ صِفَتُهُ كَذَا فَقَبِلْتُ، وَأَعْطَتْهُ عَبْدًا بِتِلْكَ الصِّفَةِ مَعِيًّا.. لَهُ رَدُّهُ، وَالْمُطَالَبَةُ بِعَبْدٍ سَلِيمٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَقَعَ قَبْلَ الْإِعْطَاءِ بِالْقَبُولِ عَلَى عَبْدٍ فِي الذِّمَّةِ، وَفِي وَجْهِهِ فِي مَسْأَلَةِ الْكِتَابِ: لَا يَرُدُّ الْعَبْدُ؛ بَلْ يَأْخُذُ أَرَشَ (٢) الْعَيْبِ، (وَلَوْ قَالَ) فِي التَّغْلِيْقِ بِالْإِعْطَاءِ: (عَبْدًا) وَلَمْ يَصِفْهُ (..طَلَّقْتُ بِعَبْدٍ) عَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ (إِلَّا مَغْضُوبًا فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ الْإِعْطَاءَ يَقْتَضِي التَّمْلِيكَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَا يُمَكِّنُ تَمْلِيكَ الْمَغْضُوبِ، وَالثَّانِي: تُطْلَقُ بِالْمَغْضُوبِ كَالْمَمْلُوكِ؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ لَا يَمْلِكُ الْمُعْطَى، وَإِنْ كَانَ مَمْلُوكًا لَهَا؛ لِمَا سَيَأْتِي، فَلَا مَعْنَى لِإِعْتِبَارِ مِلْكِهَا لَهُ (وَلَهُ مَهْرٌ مِثْلُ) بَدَلُ الْمُعْطَى؛ لِتَعْدْرِ مِلْكِهِ لَهُ؛ لِأَنَّهُ يُؤْخَذُ عَوَضًا، وَهُوَ مَجْهُولٌ عِنْدَ التَّغْلِيْقِ، وَالْمَجْهُولُ لَا يَصْلُحُ عَوَضًا، وَلَا يَأْتِي قَوْلٌ بِالرَّجُوعِ إِلَى الْقِيَمَةِ؛ لِأَنَّ الْمَجْهُولَ لَا تُعْرَفُ قِيمَتُهُ حَتَّى يَرْجَعَ إِلَيْهَا.

وَيُعْلَمُ مِمَّا تَقَدَّمَ: اشْتِرَاطُ الْفَوْرِ فِي التَّغْلِيْقِ بِـ"أَنْ" دُونَ "مَتَى"، وَاقْتِصَارُ الْمُصَنِّفِ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَغْضُوبِ، وَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَكُ مِثْلَهُ فِيمَا ذَكَرَ؛ لِأَنَّهُ مَغْضُوبُ الْبُغْضِ.

وَلَوْ وَصَفَهُ بِصِفَةٍ دُونَ صِفَةِ السَّلَمِ فَأَعْطَتْهُ بِتِلْكَ الصِّفَةِ.. طَلَّقْتَ، وَلَهُ مَهْرٌ مِثْلُ بَدَلِهِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، كَمَا قَالَهُ الْمَاوَرِدِيُّ (٣)

(وَلَوْ مَلَكَ طَلَقَةً فَقَطَّ فَقَالَتْ: طَلَّقْنِي ثَلَاثًا بِأَلْفٍ، فَطَلَّقَ الطَّلَقَةَ.. فَلَهُ أَلْفٌ؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ بِتِلْكَ الطَّلَقَةِ مَقْصُودُ الثَّلَاثِ، وَهُوَ الْحُرْمَةُ الْكُبْرَى (وَقِيلَ: ثَلَاثُهُ)، تَوْزِيْعًا لِلْمُسَمَّى عَلَى الْعَدَدِ

(٢) يعني: إمام الحرمين الجويني. ينظر: نهاية المطالب (٣٩١/١٣).

(٣) الأرش في البيع: ما يأخذه المشتري من البائع من فرق في الثمن إذا أطلع على عيب في المبيع، أو نقص في السلعة، وأروش الجنائي: ات والجراحات من ذلك: لأنها جابرة لها عما حصل فيها من النقص، والأرش في الأصل: دية الجراحات. النهاية لابن الأثير. مادة (أرش).

(١) الحاوي (٣٢١/١٢)

الْمَسْئُولُ، كَمَا لَوْ كَانَ يَمْلِكُ الثَّلَاثَ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً، (وَقِيلَ: إِنْ عَلِمْتَ الْحَالَ) وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَمْلِكُ إِلَّا طَلَقَهُ، (..فَأُلْفَ)؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ وَالْحَالَةَ هَذِهِ: كَمَلٍ لِي الثَّلَاثَ، (وَالْأَلَا.. فُتْلُثُ)؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَالْأَوَّلُ: (١) نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْمُخْتَصَرِ (٢)، وَالثَّانِي (٣): قَالَهُ الْمَزْنِيُّ (٤) وَالْمُفَصَّلُ: حَمَلَ الْأَوَّلَ عَلَى حَالَةِ الْعِلْمِ، وَالثَّانِي عَلَى حَالَةِ الْجَهْلِ، وَقِيلَ: يَرْجِعُ إِلَى مَهْرِ الْمُثَلِّ، وَقِيلَ: لَا شَيْءَ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُطْلَقْ كَمَا سَأَلْتُ. (وَلَوْ طَلَبْتَ طَلَقَهُ بِالْأَلْفِ فَطَلَّقَ) طَلَقَهُ، (بِمِائَةٍ.. وَقَعَ بِمِائَةٍ)؛ لِرِضَاهُ بِهَا (وَقِيلَ: بِالْأَلْفِ) كَمَا لَوْ سَكَتَ عَنِ الْعَوَضِ، وَيَلْغُو ذِكْرُ الْمِائَةِ مُوَافَقَةً لَهَا، (وَقِيلَ: لَا يَقَعُ)؛ لِلْمُخَالَفَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ بِالْأَلْفِ، فَقَبِلْتَ بِمِائَةٍ، وَالْفَرْقُ ظَاهِرٌ، (وَلَوْ قَالَتْ: طَلَّقْنِي غَدًا بِالْأَلْفِ، فَطَلَّقَ غَدًا أَوْ قَبْلَهُ.. بَانَتْ)؛ لِأَنَّهُ حَصَلَ مَقْصُودُهَا، وَزَادَ بِتَعْجِيلِهِ فِي الثَّانِيَةِ، (بِمَهْرٍ مِثْلٍ) قَطْعًا (وَقِيلَ فِي قَوْلٍ: بِالْمُسَمَّى). وَفِي الْقَوْلِ الْآخَرِ: الظَّاهِرُ بِمَهْرِ الْمُثَلِّ، وَوَجْهُ الْقَطْعِ بِهِ: بِأَنَّ هَذَا الْخُلْعَ دَخَلَهُ شَرْطُ تَأْخِيرِ الطَّلَاقِ، وَهُوَ فَاسِدٌ لَا يُعْتَدُّ بِهِ، فَيَسْقُطُ مِنَ الْعَوَضِ مَا يُقَابَلُهُ وَهُوَ مَجْهُولٌ، فَيَكُونُ الْبَاقِي مَجْهُولًا، وَالْمَجْهُولُ يَتَعَيَّنُ الرَّجُوعُ فِيهِ إِلَى مَهْرِ الْمُثَلِّ، وَقِيلَ: إِنْ طَلَّقَهَا عَالِمًا بِبُطْلَانِ مَا جَرَى مِنْهَا.. وَقَعَ رَجْعِيًّا، وَلَا يَجِبُ مَالٌ، وَلَوْ قَصَدَ ابْتِدَاءَ الطَّلَاقِ.. وَقَعَ رَجْعِيًّا، فَإِنْ اتَّهَمْتُهُ..

(٢) يعني: الألف

(٣) يقصد مختصر المزني. وهو من أشهر المختصرات عند الشافعية. ويعد من الكتب الخمسة التي يعول عليها فقهاؤهم. وقد شرحه كثيرون، منهم: الماوردي في كتاب "الحاوي الكبير"، والقاضي أبي الطيب في "التعليقة الكبرى" ويقال: إن النهاية للجويني شرح له أيضا، قال الذهبي في السير (١٣٤/١٠): وامتألت البلاد بـ"مختصر المزني" في الفقه.... بحيث يقال: كانت البكريكون في جهازها نسخة بـ"مختصر" المزني"، وينظر المسألة في مختصر المزني (٢٩٢/٨) مطبوع مع الأم للإمام الشافعي.

(٤) يعني: ثلث الألف

(٥) في مختصره (٢٩٢/٨) هذا: والمزني، هو: الإمام العلامة فقيه الملة، أبو إبراهيم إسماعيل، بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن مسلم المزني المصري تلميذ الشافعي وصاحبه، قال الشافعي: "المزني ناصر مذهبي"، مولده سنة ١٥٧هـ، ووفاته سنة ٢٦٤هـ من أهم مصنفاته "المختصر"، و"الجامع الكبير"، و"الجامع الصغير" سير أعلام النبلاء للذهبي (١٣٤/١٠)، طبقات الشافعية لابن قاضي شعبة (٥٨/١)

حَلَفَ، قَالَهُ ابْنُ الرَّفْعَةِ (١)، وَلَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مُضِيِّ الْغَدِ.. نَفَذَ رَجْعِيًّا؛ لِأَنَّهُ خَالَفَ قَوْلَهَا فَكَانَ مُبْتَدَأًا، فَإِنْ ذَكَرَ مَا لَا.. فَلَا بُدَّ مِنَ الْقَبُولِ.

(وَأِنْ قَالَ: إِذَا دَخَلْتُ) الدَّارَ (فَأَنْتَ طَالِقٌ بِأَلْفٍ، فَقَبِلْتُ، وَدَخَلْتُ.. طَلَّقْتُ عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لَوْجُودِ الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ مَعَ الْقَبُولِ، وَقِيلَ: لَا تُطْلَقُ؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَا تَقْبَلُ التَّغْلِيْقَ، فَيَمْتَنِعُ مَعَهُ ثُبُوتُ الْمَالِ، فَيَنْتَفِي الطَّلَاقُ الْمَرْبُوطُ بِهِ، وَأَشَارَ بِـ"الْفَاءِ" فِي قَوْلِهِ: "فَقَبِلْتُ"، إِلَى اسْتِزَاطِ اتِّصَالِ الْقَبُولِ، وَقَالَ الْقَفَالُ (٢): يَحْتَمِلُ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ فِي الْحَالِ، وَبَيْنَ أَنْ يَقْبَلَ عِنْدَ وُجُودِ الصِّفَةِ (بِالْمُسَمَّى)، كَمَا فِي الطَّلَاقِ الْمُنْجَزِ. (وَفِي وَجْهِ أَوْ قَوْلٍ: بِمَهْرٍ مِثْلٍ)؛ لِأَنَّ الْمُعَاوَضَةَ لَا تَقْبَلُ التَّغْلِيْقَ، وَإِنْ قَبِلَهُ الطَّلَاقُ.. فَيُؤَثِّرُ فِي فَسَادِ الْعَوَضِ وَيُرْجَعُ إِلَى مَهْرٍ الْمِثْلِ، وَظَاهِرُ الْعِبَارَةِ: أَنَّ الْمَالَ إِنَّمَا يَجِبُ بِالطَّلَاقِ، وَهُوَ فِي الْمُسَمَّى وَجْهٌ، وَالْأَصَحُّ فِي "أَصْلِ الرُّوضَةِ": وَجُوبُ تَسْلِيمِهِ فِي الْحَالِ، وَتَبَعَ (٣) "الْمُحَرَّرُ" فِي التَّرَدُّدِ فِي أَنَّ الْخِلَافَ وَجْهَانِ أَوْ قَوْلَانِ، وَفِي "الرُّوضَةِ وَأَصْلُهَا" (٤) وَجْهَانِ، وَيُقَالُ: قَوْلَانِ.

(١) هو: العلامة أحمد بن محمد بن علي الأنصاري، أبو العباس، نجم الدين، المعروف بابن الرفعة المصري، حامل لواء الشافعية في عصره، مولده سنة ٦٤٥هـ، ووفاته سنة ٧١٠هـ من أهم مصنفاة: "كفاية النبيه في شرح التنبيه"، و"المطلب العالي في شرح الوسيط". ينظر: طبقات الشافعية لابن قاضي شعبة (٢١١/٢)، والأعلام للزركلي (٢٢٢/١).

(٢) القفال: اسم يشترك فيه اثنان من فقهاء الشافعية وكل منهما أبو بكر؛ لكنهما يتميزان بالاسم والنسبة، أحدهما: القفال الشاشي الكبير، أبو بكر محمد بن علي بن إسماعيل، المتوفى سنة ٣٦٥هـ، والثاني: القفال الصغير المروزي، أبو بكر عبد الله بن أحمد المتوفى سنة ٤١٧هـ، وهو المراد هنا. فحيث أطلق القفال في كتب المتأخرين فهو المروزي الصغير، أما الشاشي الكبير فلا يذكر إلا مقيدا، كما يتميزان بأن القفال الصغير يكثر ذكره في كتب الفقه، أما الشاشي الكبير فيكثر ذكره في كتب الحديث والتفسير.

(١) أي: النووي في "المهاج" تبع عبارة "المحرر" للرافعي، في التردد هل الخلاف: قولان أو وجهان؟ والمطلع على كلام النووي - رحمه الله - يعلم أنه اتخذ منهجا هو: التفريق بين كلام الشافعي - رحمه الله - وكلام الأصحاب، حيث يعبر عن كلام الشافعي بالأقوال، وعن كلام الأصحاب بالأوجه، تأدبا مع الإمام الشافعي - رحمه الله.

(٢) قوله: "وفي الروضة وأصلها" يعني أن: ما اختصره النووي في "الروضة" من كلام الرافعي في "فتح العزيز"، لا تفاوت بينهما في المعنى.

(وَيَصِحُّ اخْتِلَاعُ أَجْنَبِيٍّ وَإِنْ كَرِهَتْ الزَّوْجَةُ) ذَلِكَ، وَالْزَّامَةُ الْمَالَ فِدَاءً لَهَا كَالْتِزَامِ الْمَالِ لِعِشْقِ السَّيِّدِ عَبْدَهُ، وَقَدْ يَكُونُ لَهُ فِي ذَلِكَ غَرَضٌ صَحِيحٌ، كَتَخْلِيصِهَا مِنْ يُسِيءُ الْعِشْرَةَ لَهَا، وَيَمْنَعُهَا حُقُوقَهَا، وَسَوَاءٌ اخْتَلَعَهَا بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَمْ بِلَفْظِ خُلْعٍ - بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ طَلَاقٌ - فَإِنْ قُلْنَا: إِنَّهُ فَسَخٌ.. لَمْ يَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْفَسْخَ بِلَا سَبَبٍ لَا يَنْفَرِدُ بِهِ الزَّوْجُ، فَلَا يَصِحُّ طَلَبُهُ مِنْهُ.

(وهو (١) كاخْتِلَاعِهَا لَفْظًا وَحُكْمًا) فَهُوَ مِنْ جَانِبِ الزَّوْجِ: ابْتِدَاءُ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شَوْبُ تَغْلِيْقٍ، وَمِنْ جَانِبِ الْأَجْنَبِيِّ: ابْتِدَاءُ مُعَاوَضَةٍ فِيهَا شَوْبُ جَعَالَةٍ، فَإِذَا قَالَ الزَّوْجُ لِلْأَجْنَبِيِّ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِكَ فَقَبِلَ، أَوْ قَالَ الْأَجْنَبِيُّ لِلزَّوْجِ: طَلَّقْ امْرَأَتَكَ عَلَى أَلْفٍ فِي ذِمَّتِي، فَأَجَابَهُ... وَقَعَ الطَّلَاقُ بَائِنًا بِالْمُسَمَى، وَلِلزَّوْجِ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ قَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ نَظَرًا لِشَوْبِ التَّغْلِيْقِ، وَلِلْأَجْنَبِيِّ أَنْ يَرْجِعَ قَبْلَ إِبَاقَةِ الزَّوْجِ نَظَرًا لِشَوْبِ الْجَعَالَةِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ (وَلَوْ كِيلُهَا) فِي الْاِخْتِلَاعِ (أَنْ يَخْتَلِعَ لَهُ)، كَمَا لَهُ أَنْ يَخْتَلِعَ لَهَا؛ بِأَنْ يُصْرَحَ بِالِاسْتِقْلَالِ (٢) أَوْ الْوَكَالَةِ (٣) أَوْ يَنْوِي ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ يُصْرَحْ، وَلَمْ يَنْوِ.. قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَقَعَ لَهَا؛ لِعَوْدِ مَنْفَعَتِهِ إِلَيْهَا. (وَلِأَجْنَبِيٍّ تَوَكِيلُهَا) فِي الْاِخْتِلَاعِ (فَتَتَخَيَّرُ هِيَ) أَيْضًا بَيْنَ الْاِخْتِلَاعِ لَهَا وَالِاِخْتِلَاعِ لَهُ؛ بِأَنْ تُصْرَحَ أَوْ تَنْوِي ذَلِكَ كَمَا تَقَدَّمَ، فَإِنْ أَطْلَقَتْ.. وَقَعَ لَهَا؛ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الْغَزَالِيِّ، وَحَيْثُ صَرَحَ بِالْوَكَالَةِ عَنْهَا أَوْ عَنِ الْأَجْنَبِيِّ.. فَالزَّوْجُ يُطَالِبُ الْمُوَكَّلَ، وَإِلَّا.. طَالِبُ الْمُبَاشَرِ، ثُمَّ يَرْجِعُ عَلَى الْمُوَكَّلِ حَيْثُ نَوَى الْخُلْعَ لَهُ. (وَلَوْ اخْتَلَعَ رَجُلٌ وَصَرَحَ بِوَكَالَتِهِ كَاذِبًا) فِيهَا (لَمْ تُطَلَّقْ)؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ مَرْبُوطٌ بِالْمَالِ وَلَمْ يَلْتَزِمَهُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا (وَأَبُوهَا كَأَجْنَبِيٍّ فَيَخْتَلِعُ بِمَالِهِ) أَي: يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ (فَإِنْ اخْتَلَعَ بِمَالِهَا وَصَرَحَ بِوَكَالَةٍ) عَنْهَا كَاذِبًا (أَوْ وَلَايَةٍ.. لَمْ تُطَلَّقْ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيِّ فِي ذَلِكَ، وَلَا وَكِيلٍ فِيهِ، (أَوْ بِاسْتِقْلَالٍ.. فَخُلْعٌ بِمَغْضُوبٍ)؛ لِأَنَّهُ بِالنَّصْرِفِ الْمَذْكُورِ فِي مَالِهَا غَاصِبٌ لَهُ، فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَيَلْزِمُهُ مَهْرٌ مِثْلُ، وَفِي قَوْلٍ: بَدَلَ الْمَالِ الْمَبْدُولِ؛ كَمَا تَقَدَّمَ أَوَّلَ الْبَابِ فِي اخْتِلَاعِ الْأَمَةِ بِعَيْنِ مَالِ السَّيِّدِ، وَإِنْ لَمْ يُصْرَحْ بِشَيْءٍ مِمَّا ذَكَرَ؛ كَأَنْ اخْتَلَعَهَا بِعَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ ذَكَرَ أَنَّهُ مِنْ مَالِهَا

(٣) أي: اختلاع الأجنبي.

(٤) وذلك إذا اختلع لنفسه، وفي هذه الحالة هو المطالب بالعوض، وليست الزوجة

(٥) وذلك إذا اختلع لها، وفي هذه الحالة لا يطالب الوكيل بالعوض، وإنما تطالب به الزوجة، ويرجع عليها به.

مُقْتَصِرًا عَلَى ذَلِكَ... وَقَعَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا؛ لِلْحَجَرِ عَلَيْهِ فِي مَالِهَا بِمَا ذَكَرَ، كَمَا فِي خُلْعِ
السَّفِيهِةِ، وَخَرَجَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ (١) مِنَ الْخُلْعِ بِمَغْضُوبٍ: وَقُوعَ الطَّلَاقِ بَائِنًا، وَيَعُودُ الْقَوْلَانِ
فِي الْوَاجِبِ.

(١) هو: الإمام أبو علي الحسين بن محمد المروزي. ويقال له أيضًا: المروذي. بالذال المعجمة وتشديد الراء
الثانية وتخفيفها، شيخ الشافعية بخراسان، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، وإذا أطلق "
القاضي" في كتب الشافعية، فهو المقصود، من أهم مصنفاته: "التعليق الكبير"، و"شرح فروع
ابن الحداد، توفي سنة ٤٦٢ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء للذهبي (١٨/٢٦١، ٢٦٢)، وتهذيب الأسماء
واللغات للنووي (١/١٦٤).

الاختلاف في الخلع أو في عوضه

(فَصْلٌ) (ادْعَتْ خُلْعًا فَأَنْكَرَ.. صَدَّقَ بِيَمِينِهِ)؛ إِذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ^(١)، فَإِنْ أَقَامَتْ بِهِ بَيِّنَةٌ رَجُلَيْنِ.. قُضِيَ بِهَا، وَلَا مَالٍ؛ لِأَنَّهُ يُنْكَرُهُ؛ إِلَّا أَنْ يَعُودَ وَيَعْتَرِفَ بِالْخُلْعِ، فَيَسْتَحَقَّهُ. قَالَهُ الْمَاورِدِيُّ^(٢) (وَإِنْ قَالَ: طَلَّقْتُكَ بِكَذَا، فَقَالَتْ): طَلَّقْتَنِي (مَجَانًا.. بَأَنْتَ) ^(٣) بِقَوْلِهِ (وَلَا عَوْضَ) عَلَيْهَا؛ إِذْ الْأَصْلُ عَدَمُهُ، فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي نَفْسِهِ، وَلَهَا النِّفْقَةُ، فَإِنْ أَقَامَ بَيِّنَةٌ بِهِ أَوْ شَاهِدًا وَخَلَفَ مَعَهُ.. ثَبَتَ، كَمَا قَالَهُ فِي الْبَيَانِ^(٤)، (وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي جِنْسِ عَوْضِهِ أَوْ قَدْرِهِ) أَوْ صِفَتِهِ؛ كَأَنَّ قَالَ: خَالَعْتُكَ عَلَى دَنَانِيرٍ^(٥)، فَقَالَتْ: بَلْ عَلَى دَرَاهِمٍ^(٦)، أَوْ قَالَ: عَلَى مِائَتَيْنِ، فَقَالَتْ: بَلْ عَلَى مِائَةٍ، أَوْ قَالَ: عَلَى صِحَاحٍ، فَقَالَتْ: بَلْ عَلَى مُكْسَرَةٍ، ^(٧) (وَلَا بَيِّنَةٌ) لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا، (..تَخَالَفَا) كَالْمُتَبَايِعِينَ فِي كَيْفِيَةِ الْحَلْفِ وَمَنْ يَبْدَأُ بِهِ، ثُمَّ يَفْسَخَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ الْحَاكِمُ: الْعَوْضَ، وَتَبَيَّنَ. (وَوَجِبَ مَهْرٌ مِثْلٍ)؛ لِأَنَّهُ الْمُرَادُ، فَإِنْ كَانَ لِأَحَدِهِمَا بَيِّنَةٌ.. سَقَطَتْ، وَفِي قَوْلٍ: يُفْرَعُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، كَأَنَّ قَالَ: سَأَلْتُكَ ثَلَاثَ طَلَقَاتٍ بِأَلْفٍ فَأَجَبْتَنِي، وَقَالَ: بَلْ سَأَلْتُ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ فَأَجَبْتُكَ.. تَخَالَفَا، وَوَجِبَ مَهْرٌ مِثْلٍ، وَالْقَوْلُ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ.. قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ^(٨) (وَلَوْ خَالَعَ بِأَلْفٍ وَنَوِيًا نَوْعًا) مِنْ نَوْعَيْنِ مَثَلًا بِالْبَلَدِ لَا غَالِبَ مِنْهُمَا كَدَرَاهِمَ فِضَّةٍ أَوْ فُلُوسًا (..لَزِمَ) ^(٩) (إِلْحَاقًا لِلْمَنُويِّ بِالْمَلْفُوظِ (وَقِيلَ): لَزِمَ (مَهْرٌ مِثْلٍ)؛ لِلْجَهَالَةِ فِي اللَّفْظِ، وَلَا عِبْرَةَ بِالنِّيَّةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا شَيْئًا..

(٢) أي: عدم الخلع، وبقاء النكاح.

(٣) الحاوي الكبير (٣٥٥/١٢).

(٤) قال الدميري: قوله: (بانت) ظاهره: أنه لا نفقة لها، والمنقول: وجوبها إلى آخر العدة، فلو عادت واعترفت

بعد اليمين بما ادعاه.. لزمها دفعه إليه، قاله الماوردي. النجم الوهاج (٤٧٣/٧).

(٥) ينظر: البيان للعمرائي (٥٩/١٠).

(٦) الدينار: عملة من الذهب، وهو المتقال، وزنه بالمعاصر (٤،٢٥) أربعة جرامات، وخمسة وعشرون بالمائة.

الفتح المبين أ.د/ محمد الحفناوي، ص ٢٢٧.

(٧) الدرهم: عملة من الفضة، وزنه عند الحنفية (٣،١٢٥)، جراما وعند الجمهور (٢،٩٧٥) جراما

(٨) هذا إذا اختلفا في القيمة، أما إن كانت قيمتهما واحدة فلا فرق.

(٩) والقاعدة: أن من كان القول قوله في شيء، كان القول قوله في صفته وعدده.

(١٠) أي: ما نوياء، فإذا كان في البلد نقد غالب.. نزل عليه، وإلا.. بطلت التسمية.

لَزِمَ مَهْرُ الْمِثْلِ جَزْمًا، (وَلَوْ قَالَ: أَرَدْنَا بِالْأَلْفِ: دَنَانِيرَ، فَقَالَتْ: بَلْ دَرَاهِمَ) فَضَّةً (أَوْ فُلُوسًا) وَيَعْرِفُ كُلُّ مِنْهُمَا مُرَادَ الْآخِرِ بِالْقَرِينَةِ (..تَحَالَفًا عَلَى الْأَوَّلِ) الْأَصْحُ، وَهُوَ: لُزُومُ الْمُنَوِّي كَالْمَلْفُوظِ؛ لِأَنَّهُ يُرْجَعُ إِلَى الْإِخْتِلَافِ فِي جِنْسِ الْعَوَضِ، (..وَوَجِبَ مَهْرُ مِثْلِ بِلَا تَحَالَفٍ فِي الثَّانِي) لِمَا تَقَدَّمَ فِيهِ (١)، (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) ..

(١) ولأن هذا نزاع في القصد والنية، ولا مطلع عليهما، وإذا امتنع التحالف، ووقع الاختلاف.. صار العوض مجهولاً، فيجب الرجوع إلى مهر المثل. النجم الوهاج (٤٧٤/٧).

كتاب الطلاق^(١)

(٢) الطلاق في اللغة: مأخوذ من الفعل "طلق"، وهو حل القيد مطلقاً، حسياً كان أو معنوياً، ومنه الإطلاق، وهو: الترك والإرسال، يقال: أطلق الرجل الأسير، وطلقه: إذا رفع القيد عنه، وطلق الرجل زوجته، وأطلق زوجته: إذا رفع عنها قيد النكاح، وطلق امرأته تطليقاً، وطلَّقَتْ هي تطلق من باب قتل يقتل، فهي طالق، وطالقة- بالهاء-، والفصيح المشهور بدون هاء.. لسان العرب ٢٢٦/١٠، والقاموس المحيط ١٢٠٠/٢، ومختار الصحاح، ص ١٩٠، والمصباح المنير، ص ٢٢٤، مادة (ط ل ق).

وشرعاً: حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه نهائياً: به المحتاج (٤١٣/٦).
حكمه: الأصل فيه أنه مشروع، وقد ثبتت هذه المشروعية بالكتاب والسنة والإجماع
أما الكتاب: فقوله تعالى: " {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ...} [الطلاق: ١]" وقوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِنْ سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].

ومن السنة: أحاديث

منها: أن رسول الله - ﷺ - (طلق حفصة ثم راجعها) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب المراجعة (٢٢٨٠)، والنسائي في الطلاق، باب: الرجعة (٣٥٦٠)، وابن ماجه في الطلاق، باب: حدثنا سويد (٢٠١٦)، وابن حبان في الطلاق، باب: الرجعة (٤٢٧٥)، والحاكم في الطلاق (٢٧٩٦)، وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي.

ومنها: ماروي في الصحيحين (أن ابن عمر - ﷺ - طلق امرأته وهي حائض، فأمره النبي - ﷺ - بارتجاعها، ثم طلاقها بعد طهرها إن شاء) أخرجه البخاري في الطلاق، باب: قول الله تعالى {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ} (٥٢٥١)، ومسلم في الطلاق، باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها (١٤٧١).

ومنها: قوله - ﷺ -: (ما أحل الله شيئاً أبغض إليه من الطلاق) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: كراهية الطلاق (٢١٧٧)، وابن ماجه في الطلاق، باب: حدثنا سويد (٢٠١٦)، والحاكم في الطلاق (٢٧٩٧) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، وقال الذهبي: "صحيح على شرط مسلم".

وصححه السيوطي في الجامع الصغير (٥٣): لكن وصفه بعض الحفاظ بأنه مرسل، كالمنذري، وابن حجر، وابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود، عون المعبود (٢٧٢/٤)، والتلخيص الحبير (٢٠٥/٣) والبيغض المذكور في الحديث منصرف إلى السبب الجالب للطلاق، وهو: سوء العشرة، وقلة الموافقة الداعية إلى الطلاق: لا إلى نفس الطلاق، فإن الله سبحانه وتعالى أباح الطلاق، عون المعبود (٢٧١/٤) بتصرف. وأما الإجماع: فلقد أجمع علماء الأمة على مشروعية الطلاق: لكنهم اختلفوا في الحكم الأصلي له هل هو الحظر أو الإباحة؟ والاتفاق قائم بينهم على أنه تعتريه الأحكام الخمسة من وجوب وندب وإباحة وحرمة وكراهة المغني لابن قدامة (٦٦/٧).

حكمة مشروعية الطلاق: شرع الطلاق للتخلص من رابطة الزوجية إذا تبين أنها مصدر الشقاء، واستحالت العشرة بين الزوجين، وذلك لسبب من الأسباب التالية:

- ١- تبأى: ن أخلاق الزوجين وعدم توافق طبعيهما، مما يترتب عليه عدم تحقق الرحمة والمودة.
- ٢- التحقق من عدم الوصول إلى بعض مقاصد النكاح، وهي الإنجاب، لعدم قدرة أحد الزوجين على ذلك.

٣- التحقق من وجود عيب يمنع من الاستمتاع بين الزوجين أو ينفر منه.

(يُشْتَرَطُ لِنُفُوذِهِ.. التَّكْلِيفُ)، فِي الْمُطَلِّقِ، أَي: أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا^(١)، فَلَا يَنْفُذُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ^(٢)، قَالَ الْمُصَنِّفُ زِيَادَةً عَلَى الرَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ، (إِلَّا السَّكَرَانُ) أَي: فَإِنَّهُ يَنْفُذُ طَلَاقُهُ، كَمَا سَيَأْتِي وَهُوَ غَيْرُ مُكَلَّفٍ، كَمَا نَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فِي كُتُبِ الْأُصُولِ، قَالَ: "وَمُرَادُهُمْ أَنَّهُ غَيْرُ مُخَاطَبٍ حَالَ السَّكَرِ، وَمُرَادُنَا هُنَا - أَي: حَيْثُ لَمْ يُسْتَثْنِ - أَنَّهُ مُكَلَّفٌ بِقَضَاءِ الْعِبَادَاتِ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ. انْتَهَى"^(٣)، وَانْتِفَاءُ تَكْلِيفِهِ؛ لِانْتِفَاءِ الْفَهْمِ الَّذِي هُوَ شَرْطُ التَّكْلِيفِ، فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ الصَّلَاةُ، وَنُفُوذُ طَلَاقِهِ مِنْ قَبِيلِ رَبْطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ، كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ فِي الْمُسْتَصْفَى^(٤) وَأَجَابَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى﴾ [النساء: ٤٣] الَّذِي اسْتَدَّ إِلَيْهِ الْجَوْنِيُّ، وَغَيْرُهُ فِي تَكْلِيفِ السَّكَرَانِ، بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ: مَنْ هُوَ فِي أَوَائِلِ السَّكَرِ وَهُوَ الْمُنْتَشِي؛ لِبَقَاءِ عَقْلِهِ^(٥).

ألفاظ الطلاق وما يتعلق بها

(وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ (بِصَرِيحِهِ بِلَا نِيَّةٍ، وَبِكِنَايَةٍ بِنِيَّةٍ)، وَالْكِنَايَةُ: مَا تَحْتَمِلُ مَعْنَى الصَّرِيحِ وَغَيْرِهِ، (فَصَرِيحُهُ: الطَّلَاقُ)؛ لِاشْتِهَارِهِ فِيهِ لُغَةً وَشَرْعًا، (وَكَذَا: الْفِرَاقُ، وَالسَّرَاحُ عَلَى الْمَشْهُورِ)؛ لَوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ بِمَعْنَاهُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ [الأحزاب: ٤٩]، وَقَالَ: ﴿أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾ [الطلاق: ٢]، وَالثَّانِي^(٦): أَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ؛ لِأَنَّهُمَا لَمْ يَشْتَهَرَا اشْتِهَارَ الطَّلَاقِ، وَيُسْتَعْمَلَانِ فِيهِ وَفِي غَيْرِهِ، وَمِثَالُ لَفْظِ الطَّلَاقِ: كَطَلَّقْتُكَ، وَأَنْتِ طَالِقٌ، وَمُطَلِّقَةٌ، يَفْتَحُ الطَّاءُ (وَا يَا طَالِقُ)؛ لَا: "أَنْتِ طَالِقٌ"، وَ"الطَّلَاقُ" فِي

٤- عدم المعاشرة بالمعروف بينهما إما بتحقيق الأي: ذاء البدني أو النفسي لأحدهما، أو عدم الإنفاق

من الزوج. لكل هذه الأسباب كان تشريع الطلاق لراحة الزوجين ورفع العناء عنهما.

(١) ويشترط أيضا: أن يكون زوجا أو نائبا عنه، فلا يصح من غيره تنجيذا ولا تعليقا، ويشترط أيضا: الاختيار، فلا ينفذ من المكره..

(٢) لا تنجيذا ولا تعليقا: لأن عبارتهما غير معتبرة، والقلم مرفوع عنهما، فلا يلزمهما حكم..

(٣) روضة الطالبين (٢٣/٨).

(٤) المستصفي من علم الأصول هو أحد مؤلفات الإمام الغزالي المتوفى ٥٠٥ هـ، والكتاب مطبوع متداول، وللغزالي أيضا في علم الأصول كتاب "المنحول"، و"شفاء الغليل".

(٥) المستصفي من علم الأصول (١٦٠/١).

(٦) يعني: مقابل المشهور في الفراق والسراح أنهما صريحان.

الأصح؛ لأن المصَادِرَ إِنَّمَا تُسْتَعْمَلُ فِي الْأَعْيَانِ تَوْسِعًا فَيَكُونَانِ كِنَايَتَيْنِ. وَالثَّانِي (١): أَنَّهُمَا صَرِيحَانِ، كَقَوْلِهِ: يَا طَالِقُ، وَيُقَاسُ بِمَا ذُكِرَ: "فَارَقْتُكَ"، و"سَرَّحْتُكَ" فَهُمَا صَرِيحَانِ، وَأَنْتَ مُفَارِقَةٌ، و"مُسَرَّحَةٌ"، وَيَا مُفَارِقَةً، وَيَا مُسَرَّحَةً.. فَهِيَ صَرِيحَةٌ، وَقِيلَ: كِنَايَةٌ؛ لِأَنَّ الْوَارِدَ فِي الْقُرْآنِ مِنَ اللَّفْظَيْنِ.. الْفِعْلُ دُونَ الْإِسْمِ؛ بِخِلَافِ الطَّلَاقِ، قَالَ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨]، وَأَنْتَ فِرَاقٌ، وَ"الْفِرَاقُ"، وَ"سَرَّاحٌ"، وَ"السَّرَّاحُ".. فَهِيَ كِنَايَاتٌ فِي الْأَصَحِّ.

(وَتَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ بِالْعَجْمِيَّةِ.. صَرِيحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِشُهْرَةِ اسْتِعْمَالِهَا عِنْدَ أَهْلِهَا شُهْرَةً اسْتِعْمَالِ الْعَرَبِيَّةِ عِنْدَ أَهْلِهَا، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: وَجْهَانِ، أَحَدُهُمَا: أَنَّهَا كِنَايَةٌ؛ اقْتِصَارًا فِي الصَّرِيحِ عَلَى الْعَرَبِيِّ؛ لُزُودِهِ فِي الْقُرْآنِ، وَتَكَرُّرِهِ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرْعِ، (وَأَطْلَقْتُكَ وَأَنْتَ مُطْلَقَةٌ) بِسُكُونِ الطَّاءِ (.. كِنَايَةٌ)؛ لِعَدَمِ اسْتِثْنَائِهِ فِي مَعْنَى الطَّلَاقِ (٢) (وَلَوْ اسْتِثْنَاهُ لَفُظَ لِلطَّلَاقِ كَالْحُلَالِ) بِالضَّمِّ (أَوْ حَلَالِ اللَّهِ عَلَيَّ حَرَامٌ) أَوْ أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ (.. فَصَرِيحٌ فِي الْأَصَحِّ) عِنْدَ مَنْ اسْتِثْنَاهُ عَنْهُمْ؛ لِغَلَبَةِ الْإِسْتِعْمَالِ، وَحُصُولِ التَّفَاهُمِ بِهِ عَنْهُمْ، (قُلْتُ: الْأَصَحُّ أَنَّهُ كِنَايَةٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) (٣)؛ لِأَنَّ الصَّرِيحَ إِنَّمَا يُؤْخَذُ مِنْ وَرُودِ الْقُرْآنِ بِهِ، وَتَكَرُّرِهِ عَلَى لِسَانِ حَمَلَةِ الشَّرِيعَةِ، وَلَيْسَ الْمَذْكُورُ كَذَلِكَ؛ أَمَّا مَنْ لَمْ يَشْتَهَرْ عَنْهُمْ.. فَهُوَ كِنَايَةٌ فِي حَقِّهِمْ قَطْعًا، وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ حَرَامٌ وَلَمْ يَقُلْ عَلَيَّ.. فَهُوَ كِنَايَةٌ قَطْعًا.

(وَكِنَايَتُهُ): أَيِ: الطَّلَاقِ (كَأَنْتَ خَلِيَّةٌ بَرِيَّةٌ) أَيِ: مِنْ الزَّوْجِ (٤) (بِتَّةٌ) أَيِ: مَقْطُوعَةٌ الْوُصْلَةُ (بِتْلَةٌ) أَيِ: مَتْرُوكَةُ النِّكَاحِ (بَائِنٌ) أَيِ: مُفَارِقَةٌ (اعْتَدَيْ، اسْتَبْرَأَ رَحِمَكَ) أَيِ: لِأَنِّي طَلَّقْتُكَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمَدْخُولُ بِهَا، وَغَيْرُهَا، وَقِيلَ: إِنَّ ذَلِكَ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا لَعَوًا؛ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مَحَلًّا لِلْعِدَّةِ، وَاسْتَبْرَاءُ الرَّحِمِ (الْحَقِي بِأَهْلِكَ) أَيِ: لِأَنِّي طَلَّقْتُكَ (حَبْلُكَ عَلَى

(١) يعني: مقابل الأصح في أنت طلاق، وأنت الطلاق، وأنها ليسا صريحان في الطلاق

(٢) وقيل: صريح؛ لتقارب الإطلاق والتطليق والإكرام والتكريم..

(٣) هذه الجملة من زيادات النووي على الرافعي واستدراكاته عليه في التصحيح. قال الدميري في النجم

الوهاج (٤٨٥/٧): "وهذا - يعني ما صححه النووي من كونه كناية - عليه الأكثرون، وهو منصوص

"الأم"، و"البويطي".

(٤) وإنما كانت كناية؛ لاحتمال أنها خالية من غير الزوج.

غَارِبِك) أَي: خَلَيْتُ سَبِيلَكَ كَمَا يُخْلَى الْبُعِيرُ فِي الصَّخْرَاءِ وَزِمَامُهُ عَلَى غَارِبِهِ، وَهُوَ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الظَّهْرِ وَارْتَفَعَ مِنَ الْعُنُقِ؛ لِيَرْعَى كَيْفَ يَشَاءُ (لَا أُنْدَهُ سَرَبِكَ) (١) أَي: "لَا أَهْتَمُّ بِشَأْنِكَ وَالسَّرَبُ - يَفْتَحُ السَّيْنِ وَسُكُونِ الرَّاءِ -: الْإِبِلُ، وَمَا يُرْعَى مِنَ الْمَالِ وَأَنْدَهُ": أَزْجُرُ (أَغْرَبِي) بِمُهِمَلَةٍ ثُمَّ زَاي؛ أَي: مِنَ الزَّوْجِ (أَغْرَبِي) بِمُعْجَمَةٍ ثُمَّ رَاءٍ؛ أَي: صِيرِي غَرِيبَةً بِلَا زَوْجٍ (دَعِينِي) (٢)، وَدَعِينِي (٣)؛ لِأَنَّكَ مُطَلَّعَةٌ (أَوْ نَحْوَهَا) كَتَجَرَدِي؛ أَي: مِنَ الزَّوْجِ، وَتَرْوِدِي، أَخْرَجِي، سَافِرِي؛ لِأَنِّي طَلَّقْتُكَ. (وَالْإِعْتَاقُ.. كِنَايَةٌ طَلَاقٍ وَعَكْسُهُ)؛ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي إِزَالَةِ الْمَلِكِ، (٤) فَإِذَا قَالَ لِرُؤُوسَتِهِ: أَعْتَقْتُكَ، أَوْ أَنْتَ حُرَّةٌ وَنَوَى الطَّلَاقَ.. طَلَّقْتَ، وَإِذَا قَالَ لِعَبْدِهِ: طَلَّقْتُكَ وَنَوَى الْعِتْقَ.. عَتَقَ (وَلَيْسَ الطَّلَاقُ كِنَايَةً ظَهَارٍ وَعَكْسُهُ) وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي إِفَادَةِ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ تَنْفِيزَ كُلِّ مِنْهُمَا فِي مَوْضُوعِهِ مُمَكِّنٌ فَلَا يُغْدَلُ عَنْهُ.

(وَلَوْ قَالَ) لِرُؤُوسَتِهِ: (أَنْتَ عَلَيَّ حَرِيمٌ، أَوْ حَرَمْتُكَ، وَنَوَى طَلَاقًا أَوْ ظَهَارًا.. حَصَلَ) أَي:.. الْمُنَوِيُّ؛ لِأَنَّ الظَّهَارَ يَفْتَضِي التَّحْرِيمَ إِلَى أَنْ يُكْفَرَ، فَجَازَ أَنْ يُكْنِيَ عَنْهُ بِالْحَرَامِ، وَالطَّلَاقُ سَبَبٌ مُحَرِّمٌ، وَهَذَا الطَّلَاقُ رَجْعِيٌّ. وَإِنْ نَوَى فِيهِ عَدَدًا.. وَقَعَ مَا نَوَاهُ (أَوْ نَوَاهُمَا) أَي: الطَّلَاقُ وَالظَّهَارُ مَعًا (..تَخَيَّرَ وَتَبَتَ مَا اخْتَارَهُ) مِنْهُمَا (٥) (وَقِيلَ): الْوَاقِعُ (طَلَاقٌ)؛ لِأَنَّهُ أَقْوَى بِإِزَالَتِهِ الْمَلِكَ (وَقِيلَ: ظَهَارٌ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ، وَلَا يَتُبْنَانِ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ يُزِيلُ النِّكَاحَ، وَالظَّهَارَ يَسْتَدْعِي بَقَاءَهُ (أَوْ) (٦) تَحْرِيمُ عَيْنِهَا أَوْ فَرْجِهَا أَوْ وَطْئِهَا (..لَمْ تَحْرُمْ) عَلَيْهِ، (وَعَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ) كَمَا لَوْ قَالَ ذَلِكَ لِأَمَتِهِ أَخَذًا مِنْ قِصَّةِ مَارِيَةَ لَمَّا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ".. نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ} [التَّحْرِيمُ: ١] إِلَى أَنْ قَالَ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التَّحْرِيمُ: ٢] أَي: أَوْجَبَ عَلَيْكُمْ كَفَّارَةَ أَيْمَانِكُمْ، وَالْأَصَحُّ: أَنَّ وَجُوبَ الْكَفَّارَةِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْوَطْءِ، وَقِيلَ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ،

(٥) قوله: (لا أنداه سربك) بفتح السين -أي: لا أزجر إبلك. دقائق المهاج، ص ٦٩.

(١) أي: اتركيني

(٢) من الوداع.

(٣) فتاب أحدهما مناب الآخر.

(٤) هذا إذا نواهما دفعة واحدة، فإن نواهما مرتباً.. فعن ابن الحداد: إن تقدم الظهار.. حصلاً، أو الطلاق..

فالظهار موقوف، فإن راجع.. فصحيح، والرجعة عود، وإلا.. فلغو..

(٥) أي: أونوى.

كَالْيَمِينِ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ . (وَكَذَا) عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ، (إِنْ لَمْ تَكُنْ نِيَّةً فِي الْأَظْهَرِ) (١) وَالثَّانِي: ذَلِكَ اللَّفْظُ مِنْهُ، (لَعُو) فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ وَنَحْوُهُ إِذَا اشْتَهَرَ عِنْدَ قَوْمٍ لِلطَّلَاقِ كَانَ صَرِيحًا فِيهِ عَنْهُمْ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ، فَإِذَا نَوَى بِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ غَيْرَ الطَّلَاقِ.. لَعْتَ نِيَّتُهُ وَتَعَيَّنَ الطَّلَاقُ.

(وَإِنْ قَالَهُ) أَي: أَنْتَ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ نَحْوُهُ (لَأَمْتِهِ وَنَوَى عِتْقًا.. نَبَتْ) أَوْ طَلَقًا أَوْ ظَهَارًا.. لَعَا؛ إِذْ لَا مَجَالَ لَهُ فِي الْأَمَةِ (أَوْ تَحْرِيمٍ عَيْنَهَا، أَوْ لَا نِيَّةً) لَهُ (..فَكَالزَّوْجَةِ) فِيمَا تَقَدَّمَ، فَلَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ يَمِينٍ قَطْعًا فِي الْأُولَى، وَعَلَى الْأَظْهَرِ فِي الثَّانِيَةِ، وَقِيلَ: قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْأَمَةَ هِيَ الْأَصْلُ فِي وُرُودِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ، (وَلَوْ قَالَ: هَذَا الثُّوبُ أَوْ الطَّعَامُ أَوْ الْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَيَّ.. فَلَعُو) (٢)؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ قَادِرٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ، فَإِنَّهُ قَادِرٌ عَلَى تَحْرِيمِهِمَا بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ.

(وَشَرَطُ نِيَّةِ الْكِنَايَةِ: اقْتِرَانُهَا بِكُلِّ اللَّفْظِ، وَقِيلَ: يَكْفِي بِأَوَّلِهِ)، وَيَنْسَحِبُ مَا بَعْدَهُ عَلَيْهِ، وَقِيلَ: يَكْفِي بِآخِرِهِ، لِأَنَّهُ وَقْتُ الْوُقُوعِ، فَلَوْ تَقَدَّمَتْ أَوْ تَأَخَّرَتْ.. لَعْتَ قَطْعًا، وَفِي "أَصْلِ الرُّوْضَةِ": لَوْ اقْتَرَنْتَ بِأَوَّلِ اللَّفْظِ دُونَ آخِرِهِ أَوْ عَكْسُهُ.. طَلَقْتَ عَلَى الْأَصَحِّ (٣)، وَرَجَحَ فِي "الشَّرْحِ الصَّغِيرِ" فِي اقْتِرَانِهَا بِأَوَّلِهِ وَقُوعِ الطَّلَاقِ، (وَإِشَارَةُ نَاطِقٍ بِطَّلَاقٍ) كَمَا قَالَتْ لَهُ: طَلَقْنِي فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ أَذْهَبِي (..لَعُو)؛ لِأَنَّ عُدُولَهُ عَنِ الْعِبَارَةِ إِلَى الْإِشَارَةِ يُفْهَمُ أَنَّهُ غَيْرُ قَاصِدٍ لِلطَّلَاقِ، وَإِنْ قَصَدَهُ بِهَا فَهِيَ لَا تُقْصَدُ لِلْإِفْهَامِ إِلَّا نَادِرًا. (وقيل: كِنَايَةٌ؛ لِحُصُولِ

(٦) لعموم ما تقدم من تحريم مارية، وفي الصحيحين: البخاري (٤٩١١)، ومسلم (١٤٧٣) عن ابن عباس -

ﷺ أنه كان يقول: في ذلك كفارة يمين، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، ولأن

لفظة التحريم صريحة في وجوب الكفارة، فلا معنى للنية. النجم الوهاج (٧/٤٩٠).

(١) لا يتعلق به كفارة ولا غيرها، لما روى الترمذي (٣٠٥٤) عن ابن عباس - ﷺ - أن رجلا أتى النبي - ﷺ - فقال: يا

رسول الله: إني إذا أصبت اللحم.. انتشرت للنساء وأجد شهوة، وإني حرمته على نفسي، فأنزل الله

تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحَرَّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ) [المائدة: ٨٧]، وقال: "حديث حسن

غريب". وحكى ابن الصلاح في طبقاته عن أبي عبيد علي بن الحسين بن حربويه: أنه أوجب الكفارة

على من حرم ذلك، وسوى بينه وبين تحريم البضع من الزوجة..

(٢) روضة الطالبين (٨/٢٣).

الإفهام بها) في الجملة^(١) (وَيُعْتَدُ بِإِشَارَةِ أُخْرَسَ فِي الْعُقُودِ) كَالْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَغَيْرِهِمَا. (وَالْحُلُولُ) كَالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَغَيْرِهِمَا لِلضَّرُورَةِ^(٢)، (فَإِنْ فَهِمَ طَلَّاقُهُ بِهَا كُلَّ أَحَدٍ.. فَصَرِيحَةٌ، وَإِنْ أُخْتُصَّ بِفَهْمِهِ فُطْنُونَ) أَي: أَهْلُ الْفُطْنَةِ وَالذِّكَاةِ (..فَكِنَايَةٌ) تَحْتَاجُ إِلَى النَّيَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَوْقَعَ الطَّلَاقَ بِإِشَارَتِهِ الْمَفْهُمَةِ.. نَوَى، أَوْ لَمْ يَنْوِ، وَلَيْسَ فِي "الشَّرْحَيْنِ"^(٣) وَلَا فِي "الرُّوْضَةِ" تَرْجِيحٌ لِوَاحِدَةٍ مِنَ الْمَقَالَتَيْنِ، وَمَا ذُكِرَ فِي الطَّلَاقِ، يُقَالُ فِي غَيْرِهِ. (وَلَوْ كَتَبَ نَاطِقٌ طَلَّاقًا) كَأَنَّ كَتَبَ: زَوَّجَنِي طَالِقٌ، (وَلَمْ يَنْوِهِ.. فَلَعُوْ) وَتَكُونُ كِتَابَتُهُ لِنَجَرَةِ الْقَلَمِ أَوْ الْمِدَادِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَفِي وَجْهِ: أَنَّ الْكِتَابَةَ صَرِيحَةً كَالْعِبَارَةِ يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ^(٤)، (وَإِنْ نَوَاهُ.. فَالْأَظْهَرُ وَقُوعُهُ)؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ طَرِيقٌ فِي إِفْهَامِ الْمُرَادِ كَالْعِبَارَةِ، وَقَدْ اقْتَرَنَتْ بِالنِّيَةِ، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهَا فِعْلٌ، وَالْفِعْلُ لَا يَصْلُحُ كِنَايَةً عَنِ الطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ بَيْتِهِ وَنَوَى الطَّلَاقَ، وَقَطَعَ قَاطِعُونَ بِالْأَوَّلِ، وَآخَرُونَ بِالثَّانِي^(٥). وَهُمَا فِي الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ؛ لِأَنَّ الْحَاضِرَ قَدْ يَكْتُبُ إِلَى الْحَاضِرِ، لِاسْتِحْيَائِهِ مِنْهُ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، وَقِيلَ: هُمَا فِي الْغَائِبِ، وَكِتَابَةُ الْحَاضِرِ لَعُوْ قَطْعًا؛ لِأَنَّهَا عَلَى خِلَافِ الْغَائِبِ، وَقِيلَ: هُمَا فِي الْحَاضِرِ وَكِتَابَةُ الْغَائِبِ كِنَايَةً قَطْعًا.

وَيَتَحَصَّلُ مِنْ هَذَا الْخِلَافِ لِلْمُخْتَصِرِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ أَوْ أَجْزَاءٍ، ثَالِثُهَا: أَنَّهَا كِنَايَةٌ فِي حَقِّ الْغَائِبِ دُونَ الْحَاضِرِ، وَيَجْرِي الْخِلَافُ فِي غَيْرِ الطَّلَاقِ مِمَّا لَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ كَالْإِغْتِاقِ وَالْإِبْرَاءِ وَالْعَفْوِ عَنِ الْقِصَاصِ، وَمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْقَبُولِ فِيهِ عَلَى وَقُوعِ الطَّلَاقِ.. وَجْهَانِ، أَرْجَحُهُمَا فِي غَيْرِ النِّكَاحِ، كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارَةِ وَالْهَبَةِ.. الْإِنْعِقَادُ، وَفِي النِّكَاحِ.. الْمَنْعُ؛ لِأَنَّ

(٣) ووجه ثالث: أنه إن وقعت جواباً للسؤال، بأن قالت: طلقني، فأشار بيده اذهبي، ونوى.. كان كناية. وإلا.. فلا.

(٤) قال الزركشي: إشارة الأخرس كعبارة الناطق في العقود والحلول والدعاوى والأقارير وغيرها. المنشور في القواعد للزركشي (١٦٤/١).

(١) يعني: "الشرح الكبير" المسمى: "فتح العزيز شرح الوجيز"، و"الشرح الصغير" كلاهما للإمام أبي القاسم عبد الكريم الراعي القزويني، المتوفى سنة ٦٢٣ هـ. وهما شرحان على "الوجيز" للإمام الغزالي، المتوفى ٥٠٥ هـ.

(٢) وصورة مسألة الكتاب: أن لا يتلفظ بما كتبه، فإن تلفظ بها، واقتربت بها نية.. طَلَّقَتْ جِزْمًا.

(٣) قال الدميري: فكان الأولى أن يعبر بالمذهب.

الشُّهُودَ شَرْطٌ فِيهِ، وَلَا إِطْلَاعٌ لَهُمْ عَلَى النِّيَّةِ، وَالْخِلَافُ فِي الْغَائِبِ وَالْحَاضِرِ.. كَمَا سَبَقَ، وَكِتَابَةُ الْأَخْرَسِ بِالطَّلَاقِ.. كِنَايَةً، وَقِيلَ: صَرِيحٌ، وَلَوْ تَلَفَّظَ النَّاطِقُ بِمَا كَتَبَهُ.. وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ؛ إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ قِرَاءَةً مَا كَتَبَهُ.. فَيُقْبَلُ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ.

وُفِّرَ عَلَى وَفُوعِ الطَّلَاقِ بِالْكِتَابَةِ مَسَائِلٌ فِيهَا تَغْلِيْقٌ بِشَرْطٍ، ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (فَإِنْ كَتَبَ: إِذَا بَلَغَكَ كِتَابِي فَأَنْتَ طَالِقٌ.. فَإِنَّمَا تُطَلِّقُ بِبُلُوغِهِ) رِغَايَةً لِلشَّرْطِ، (وَإِنْ كَتَبَ: إِذَا قَرَأْتَ كِتَابِي) فَأَنْتَ طَالِقٌ (وَهِيَ قَارِئَةٌ فَقَرَأَتْهُ.. طَلَّقَتْ) قَالَ الْإِمَامُ: كَذَلِكَ لَوْ طَالَعَتْهُ وَفَهَمَتْ مَا فِيهِ، وَلَمْ تَتَلَفَّظْ بِشَيْءٍ.. تُطَلِّقُ بِاتِّفَاقِ عُلَمَائِنَا (١) (وَإِنْ قُرِئَ عَلَيْهَا.. فَلَا) تُطَلِّقُ بِذَلِكَ، (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِانْتِفَاءِ الشَّرْطِ الْمَقْدُورِ عَلَيْهِ، وَالثَّانِي: تُطَلِّقُ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ: إِطْلَاعُهَا عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ وَجِدَ (وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَارِئَةً فَقُرِئَ عَلَيْهَا.. طَلَّقَتْ)؛ لِأَنَّ الْقِرَاءَةَ فِي حَقِّ الْأُمِّيِّ مَحْمُولَةٌ عَلَى الْإِطْلَاعِ عَلَى مَا فِي الْكِتَابِ، وَقَدْ وَجِدَ.

تفويض الطلاق إلى الزوجة

(فَصْلٌ: لَهُ تَفْوِيْضُ طَلَقِهَا إِلَيْهَا، كَأَنْ يَقُولَ لَهَا: طَلَّقِي نَفْسَكَ إِنْ شِئْتَ. وَالْأَصْلُ فِيهِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرَ نِسَاءٍ بَيْنَ الْمَقَامِ مَعَهُ وَبَيْنَ مُفَارَقَتِهِ (٢)، لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} [الأحزاب: ٢٨] إِلَى آخِرِهِ، (وَهُوَ تَمْلِيْكٌ) لِلطَّلَاقِ (فِي الْجَدِيدِ) (٣)، فَيُشْتَرَطُ لَوْفُوعُهُ: تَطْلِيْقُهَا عَلَى فَوْرٍ؛ لِأَنَّ تَطْلِيْقَهَا نَفْسَهَا مُتَضَمِّنٌ لِلْقَبُولِ، فَلَوْ أَخَّرْتَهُ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنِ الْإِجَابِ.. لَمْ يَقَعْ الطَّلَاقُ. (وَإِنْ قَالَ: طَلَّقِي) نَفْسَكَ، (بِأَلْفٍ فَطَلَّقَتْ.. بَانَتْ وَلَزِمَهَا أَلْفٌ) وَهُوَ (٤) تَمْلِيْكٌ بِالْعَوَضِ كَالْبَيْعِ، وَإِذَا لَمْ يُذَكَّرْ عَوَضٌ.. فَهُوَ كَالْهَبَةِ. (وَفِي قَوْلٍ) نُسِبَ إِلَى الْقَدِيمِ: (تَوَكِيْلٌ) بِالطَّلَاقِ (فَلَا يُشْتَرَطُ) فِي تَطْلِيْقِهَا، (فَوْرٌ فِي الْأَصَحِّ) كَمَا فِي تَوَكِيْلِ الْأَجْنَبِيِّ، وَالثَّانِي (٥): يُشْتَرَطُ؛ لِأَنَّ التَّفْوِيْضَ يَتَضَمَّنُ تَمْلِيْكَهَا نَفْسَهَا بِلَفْظٍ تَأْتِي بِهِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي جَوَابًا عاجِلًا. (وَفِي اشْتِرَاطِ

(٤) نهاية المطالب (١٤/٨١).

(١) حديث تخيير نساء النبي - ﷺ - أخرجه البخاري (٤٩٦٢)، ومسلم (٣٦٨٠).

(٢) لأنه يتعلق بغرضها، فنزل منزلة قوله: (ملكك).

(٣) يعني: التفويض.

(٤) هو احتمال للقاضي حسين. وليس وجهاً محققاً. النجم الوهاج (٤٩٧/٧).

قَبُولُهَا) لَفْظًا (خِلَافَ الْوَكِيلِ) الْمُتَقَدِّمِ فِي بَابِ الْوَكَالَةِ، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ أَوْجُهُ، أَصَحُّهَا: لَا يُشْتَرَطُ، وَثَالِثُهَا: يُشْتَرَطُ فِي الْإِثْنَيْنِ بِصِغَةِ الْعَقْدِ نَحْوُ: وَكَأَنَّكَ بِطَلَاقِ نَفْسِكَ دُونَ صِغَةِ الْأَمْرِ نَحْوُ: طَلَّقِي نَفْسَكَ، (وَعَلَى الْقَوْلَيْنِ: لَهُ الرَّجُوعُ) عَنِ التَّفْوِيزِ (قَبْلَ تَطْلِيلِهَا)؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ وَالتَّوَكِيلَ يَجُوزُ الرَّجُوعُ فِيهِمَا قَبْلَ الْقَبُولِ وَالتَّصَرُّفِ، (وَلَوْ قَالَ: إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَطَلَّقِي نَفْسَكَ (..لَعَا عَلَى التَّمْلِيكِ) (١) كَمَا لَوْ قَالَ: مَلَكَكَ هَذَا الْعَبْدُ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ؛ لِأَنَّ التَّمْلِيكَ لَا يَقْبَلُ التَّغْلِيْقَ، وَجَازَ عَلَى قَوْلِ التَّوَكِيلِ (٢)، كَمَا لَوْ وَكَّلَ أَجْنَبِيًّا بِتَطْلِيلِ زَوْجَتِهِ بَعْدَ شَهْرٍ. وَتَقَدَّمَ فِي الْوَكَالَةِ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَغْلِيلُهَا بِشَرْطٍ فِي الْأَصَحِّ، وَأَنَّهُ إِذَا نَجَرَهَا وَشَرَطَ لِلْمُتَصَرِّفِ شَرْطًا جَازًا. فَلْيَتَأَمَّلْ (٣) الْجَمْعُ بَيْنَ مَا هُنَا وَمَا هُنَاكَ، (وَلَوْ قَالَ: أَبْيَنِي نَفْسَكَ فَقَالَتْ: أَبْنْتُ، وَنَوِيَا) عِنْدَ قَوْلِهِمَا الطَّلَاقَ (..وَقَعَ)، كَمَا يَقَعُ بِالصَّرِيحِ (وَالْأَيُّ) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ يَنْوِيَا أَوْ أَحَدُهُمَا (..فَلَا) يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْوِ.. لَمْ يُفَوِّضِ الطَّلَاقَ، وَإِذَا لَمْ تَنْوِ هِيَ.. مَا امْتَلَكْتَ، (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقِي نَفْسَكَ، (فَقَالَتْ: أَبْنْتُ، وَنَوْتُ، أَوْ: أَبْيَنِي نَفْسَكَ، (وَنَوَى، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُ.. وَقَعَ) الطَّلَاقُ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَافُ لَفْظِهِمَا (٤) (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقِي نَفْسَكَ، (وَنَوَى ثَلَاثًا، فَقَالَتْ: طَلَّقْتُ، وَنَوْتُهُنَّ) بِأَنْ عَلِمَتْ نِيَّتَهُ (..فَثَلَاثٌ)؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ يَحْتَمِلُ الْعِدَّةَ، وَقَدْ نَوِيَاهُ، (وَالْأَيُّ) أَيُّ: وَإِنْ لَمْ تَنْوِ هِيَ عِدَّةً (..فَوَاحِدَةٌ فِي الْأَصَحِّ)، وَقِيلَ: ثَلَاثٌ؛ حَمَلًا عَلَى مَنْوِيَّتِهِ، (وَلَوْ قَالَ: طَلَّقِي نَفْسَكَ ثَلَاثًا، فَوَحَّدَتْ أَوْ عَكْسُهُ) أَيُّ: قَالَ: طَلَّقِي نَفْسَكَ وَاحِدَةً، فَطَلَّقْتُ ثَلَاثًا (..فَوَاحِدَةٌ)؛ لِأَنَّهَا الْمَوْقِعُ فِي الْأُولَى، وَالْمَادُونُ فِيهِ فِي الثَّانِيَةِ

(٥) يعني على القول بأن التفويض تمليك، يكون الطلاق هنا لاغيا؛ لأنه كما قال المصنف: التملك لا يقبل التعليق.

(٦) يعني على القول بأن التفويض توكيل، يكون الطلاق هنا واقعا، قياسا على توكيل الأجنبي المعلق.

(١) قوله: (فليتأمل) حقيقة التأمل: إعمال الفكر، وفقهاء الشافعية يفرقون بين: (تأمل)، و(فتأمل)، و(فليتأمل)، فيقولون: (تأمل) إشارة إلى الجواب القوي، وقولهم: (فتأمل) إشارة إلى الجواب الضعيف، وقولهم: (فليتأمل) إشارة إلى الجواب الأضعف، وقيل: معنى (تأمل) أن في هذا المحل دقة، ومعنى (فتأمل) أن في هذا المحل أمرا زائدا على الدقة بتفصيل، وكذلك الأمر بالنسبة لقولهم: (فليتأمل) مع زيادة: بناء على أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى. الفتح المبين (ص ١٦٥).

(٢) وقال ابن خيران وابن حربوية: لا يقع؛ للمخالفة.

(فصل: مَرَّ بِلِسَانِ نَائِمٍ طَلَاقٌ.. لَعَا)؛ لِإِنْتِفَاءِ الْقَصْدِ إِلَيْهِ (١)، وَإِنْ قَالَ بَعْدَ الْإِسْتِيقَاطِ: أَجَزْتُ ذَلِكَ (٢)، وَالْمُعْمَى عَلَيْهِ كَالنَّائِمِ، (وَلَوْ سَبَقَ لِسَانُ بِطَلَاقٍ بِلَا قَصْدٍ.. لَعَا)؛ لِمَا تَقَدَّمَ (٣) (وَلَا يُصَدَّقُ ظَاهِرًا إِلَّا بِقَرِينَةٍ) كَأَنَّ دَعَاها بَعْدَ طَهْرِهَا مِنَ الْحَيْضِ إِلَى فِرَاشِهِ، وَأَرَادَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتِ الْآنَ طَاهِرَةٌ، فَسَبَقَ لِسَانُهُ، وَقَالَ: أَنْتِ الْآنَ طَالِقَةٌ، (وَلَوْ كَانَ اسْمُهَا طَالِقًا، فَقَالَ: يَا طَالِقُ (٤) وَقَصَدَ النِّدَاءَ.. لَمْ تُطَلَّقْ، وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ فِي الْأَصَحِّ حَمَلًا عَلَى النِّدَاءِ؛ لِقُرْبِهِ، وَالثَّانِي: تُطَلَّقُ اخْتِطَاطًا (٥)، وَلَوْ قَصَدَ الطَّلَاقَ.. طُلِّقَتْ. (وَإِنْ كَانَ اسْمُهَا طَارِقًا أَوْ طَالِبًا) أَوْ طَالِعًا، (فَقَالَ: يَا طَالِقُ، وَقَالَ: أَرَدْتُ النِّدَاءَ) بِاسْمِهَا (فَأَلْتَفَّ الْحَرْفُ) بِلِسَانِي (..صَدَقَ)؛ لظُهُورِ الْقَرِينَةِ، (وَلَوْ خَاطَبَهَا بِطَلَاقٍ هَازِلًا، أَوْ لَاعِبًا) (٦) كَأَنَّ تَقُولَ لَهُ فِي مَغْرَضِ الْإِسْتِهْزَاءِ أَوْ الدَّلَالِ وَالْمَلَاعِبَةِ: طَلَّقْنِي، فَيَقُولُ: طَلَّقْتُكَ، (أَوْ وَهُوَ يَظُنُّهَا أَجَنَبِيَّةً؛ بَأَنَّ كَانَتْ فِي ظُلْمَةٍ، أَوْ أَنْكَحَهَا لَهُ وَلِيَّهُ أَوْ وَكِيلُهُ، وَلَمْ يَعْلَمْ) بِذَلِكَ (..وَقَعَ) الطَّلَاقُ؛ لِقَصْدِهِ إِيَّاهُ، وَالْهَزْلُ وَاللَّعِبُ وَظَنُّ غَيْرِ الْوَاقِعِ لَا يَدْفَعُهُ، وَفِي الْحَدِيثِ: {ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: الطَّلَاقُ، وَالتَّكَاحُ، وَالرَّجْعَةُ} (٧) قَالَ التِّرْمِذِيُّ: "حَسَنٌ غَرِيبٌ" وَالْحَاكِمُ: "صَحِيحُ الْإِسْنَادِ" (وَلَوْ لَفَظَ أَعْجَمِيٌّ بِهِ (٨) بِالْعَرَبِيَّةِ وَلَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ) كَأَنَّ لُقْنَه (..لَمْ يَقَعْ)؛ لِإِنْتِفَاءِ قَصْدِهِ.

(٣) ولرفع القم عن النائم أيضا.

(٤) يعني: فلغو أيضا.

(٥) يعني من عدم القصد، وكذلك يلغو: إذا تلفظ بالطلاق حاكيا كلام غيره، وكذلك الفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره ودرسه.

(٦) قال الدميري: ضبط المصنف (يا طالق) بتسكين القاف، وكأنه يشير إلى أنه إذا قال: يا طالق - بالضم.. لا تطلق - أي: مطلقا - : لأنه يرشد إلى العلمية، وإن قال: يا طالقا بالنصب.. تعين صرفه إلى التطبيق، وينبغي في الحالين أن لا يرجع إلى دعوى خلافه. النجم الوهاج (٥٠٠/٧).

(٧) وذلك لصراحة اللفظ.

(٨) قال الدميري: الهزل واللعب في كلام الفقهاء واللغويين كالمترادف، وقال في "الفائق": الهزل واللعب من وادي الاضطراب، والذي يشهد له الاستعمال: أن الهزل يخص الكلام، واللعب أعم، وقد يقال: الهزل قصد اللفظ دون المعنى، بأن يختار التلفظ بالكلمة ولأي رضى بمعناها. النجم الوهاج (٥٠١/٧).

(٢) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: الطلاق على الهزل (٢١٩٦)، والترمذي في الطلاق، باب: الهزل في الطلاق (١١٨٤)، وقال: "هذا حديث حسن غريب"، والحاكم في أول الطلاق (٢٨٠٠) وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد" وقال الذهبي: "فيه لين".

(٣) أي: الطلاق.

(وَقِيلَ: إِنْ نَوَى) بِهِ (مَعْنَاهَا) أَي: الْعَرَبِيَّةُ (..وَقَعَ)؛ لِأَنَّهُ نَوَى الطَّلَاقَ، وَرَدَّ: بِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَى الطَّلَاقِ.. لَا يَصِحُّ قَضْؤُهُ، وَلَوْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ وَقَصَدَ بِهِ قَطْعَ النِّكَاحِ.. لَمْ تُطْلَقْ، كَمَا لَوْ أَرَادَ الطَّلَاقَ بِكَلِمَةٍ لَا مَعْنَى لَهَا.

(وَلَا يَقَعُ طَلَاقٌ مُكْرَهٍ)؛ لِحَدِيثٍ: {لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ} (١) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَفَسَّرَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ: الْإِغْلَاقَ بِالْإِكْرَاهِ، (فَإِنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ اخْتِيَارٍ؛ بِأَنْ أُكْرِهَ عَلَى ثَلَاثٍ فَوَحْدَ، أَوْ صَرِيحٍ أَوْ تَغْلِيْقٍ فَكُنَى أَوْ نَجَزَ، أَوْ عَلَى طُلُقَتْ، فَسَّرَحَ أَوْ بِالْعُقُوسِ) أَي: أَكْرِهَ عَلَى وَاحِدَةٍ فثَلَاثَ، أَوْ عَلَى كِنَايَةٍ فَصَّرَحَ، أَوْ عَلَى تَنْجِيزٍ فَعَلَّقَ، أَوْ عَلَى أَنْ يَقُولَ سَرَحْتُ فَقَالَ طُلُقَتْ، (..وَقَعَ) الطَّلَاقُ (٢)، وَلَوْ وَافَقَ الْمُكْرَهَ، وَنَوَى الطَّلَاقَ.. وَقَعَ؛ لِاخْتِيَارِهِ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ؛ لِلْإِكْرَاهِ، وَمُجَرَّدُ النِّيَّةِ لَا يُعْمَلُ، (وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ: قُدْرَةُ الْمُكْرَهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَدَ بِهِ) عَاجِلًا (بِوَلَايَةٍ أَوْ تَغْلِبٍ، وَعَجْزُ الْمُكْرَهِ عَنْ دَفْعِهِ بِهَرَبٍ وَغَيْرِهِ) كَالِاسْتِغَاثَةِ بِغَيْرِهِ، (وُظِنَ أَنَّهُ إِنْ اِمْتَنَعَ.. حَقَّقَهُ (٣)، وَيَحْصُلُ)، الْإِكْرَاهُ: (بِتَخْوِيفٍ بِضَرْبٍ شَدِيدٍ، أَوْ حَبْسٍ، أَوْ إِثْلَافٍ مَالٍ، وَنَحْوِهَا)، كَأَخْذِ الْمَالِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلَافِ طَبَقَاتِ النَّاسِ وَأَحْوَالِهِمْ. (وَقِيلَ: يُشْتَرِطُ قَتْلٌ)؛ فَالتَّخْوِيفُ بِغَيْرِهِ لَا يَحْصُلُ بِهِ إِكْرَاهٌ، (وَقِيلَ) (٤): يُشْتَرِطُ (قَتْلٌ) أَوْ قَطْعُ لَطَرَفٍ مَثَلًا، (أَوْ ضَرْبٌ مُخَوِّفٌ)، أَي: يَخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ، فَالتَّخْوِيفُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ بِهِ إِكْرَاهٌ، وَلَا يَحْصُلُ الْإِكْرَاهُ بِالتَّخْوِيفِ بِالْعُقُوبَةِ

(٤) أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على غلط (٢١٩٣). وابن ماجه في الطلاق، باب: طلاق المكره والناسي (٢٠٤٦)، والحاكم في أول الطلاق (٢٨٠٢) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه".

(٥) لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به.

(١) أي: أن المكره يغلب على ظنه أنه إذا امتنع من فعل ما أَرَادَهُ المكره، فإن المكره سيحقق ما توعد به في الإكراه من إلحاق الأذى.

(٢) قال الدميري: هذه الأوجه الثلاثة هي الموجودة للمتقدمين من العراقيين وغيرهم. ووراءها أربعة أخرى: أحدها- وهو الأرجح عند الإمام -: لا يحصل الإكراه إلا إذا خوفه بما يسلب الاختيار، ويجعله كالهارب من الأسد الذي يتخطى النار والشوك ولا يبالي والثاني- وهو المختار عند القاضي -: تشترط عقوبة بدنية يتعلق بها قود: ليخرج عنه أخذ المال والحبس المؤبد. الثالث: تشترط عقوبة شديدة تتعلق ببدنه، فيدخل فيه الحبس الطويل، وكذا النفي من البلد؛ لشدة مفارقتها للوطن.

الرابع- وهو الأصح في "الروضة" -: لا يشترط سقوط الاختيار: بل إذا أكرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما يهدد به.. حصل الإكراه. النجم الوهاج (٥٠٥/٧)

الْأَجَلَةَ، كَقَوْلِهِ: لِأَصْرَبِكَ غَدًا (وَلَا تُشْتَرِطُ) فِي عَدَمِ وَقُوعِ طَلَاقِ الْمُكْرَهِ (التَّوْرِيَّةُ؛ بِأَنْ يَنْوِي غَيْرَهَا)، أَيْ: غَيْرَ زَوْجَتِهِ، كَأَنْ يَنْوِي بِقَوْلِهِ: "طَلَقْتُ فَاطِمَةَ" غَيْرَ زَوْجَتِهِ. (وَقِيلَ: إِنْ تَرَكَهَا بِلَا غَدَرٍ) مِنْ جَهْلٍ بِهَا، أَوْ دَهْشَةٍ أَصَابَتْهُ لِلْإِكْرَاهِ (..وَقَعَ) طَلَاقُهُ؛ لِإِسْعَارِ تَرْكِهَا بِالِاخْتِيَارِ، وَرَدَّ: بِالْمَنْعِ^(١)

(وَمَنْ أَتَمَّ بِمُزِيلِ عَقْلِهِ مِنْ شَرَابٍ، أَوْ دَوَاءٍ .. نَفَذَ طَلَاقَهُ، وَتَصَرَّفَهُ لَهُ وَعَلَيْهِ قَوْلًا وَفِعْلًا) كَالنِّكَاحِ، وَالْعِنَقِ، وَالْبَيْعِ، وَالشِّرَاءِ، وَالْإِسْلَامِ، وَالزِّدَّةِ، وَالْقَتْلِ، وَالْقَطْعِ، (عَلَى الْمَذْهَبِ، وَفِي قَوْلٍ: لَا) يَنْفُذُ شَيْءٌ مِنْ تَصَرُّفِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ لَهُ فَهْمٌ وَقَصْدٌ صَحِيحٌ^(٢). وَيُجَابُ: بِأَنْ مَا عِنْدَهُ مِنَ الْفَهْمِ وَالْقَصْدِ، يَكْفِي فِي تَفْوِذِ التَّصَرُّفِ، إِذْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ رَبِطِ الْأَحْكَامِ بِالْأَسْبَابِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنِ الْغَزَالِيِّ^(٣)، (وَقِيلَ): يَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ (عَلَيْهِ) كَالطَّلَاقِ، وَالْإِقْرَارِ، وَالضَّمَانِ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ؛ لِيُنْزَجَرَ، دُونَ تَصَرُّفٍ لَهُ كَالنِّكَاحِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ، وَأَصْلُ الْخِلَافِ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- نَصَّ عَلَى وَقُوعِ طَلَاقِ السَّكَرَانِ^(٤)، وَثَقُلَ عَنْهُ فِي ظَهَارِهِ قَوْلَانِ عَنِ الْقَدِيمِ طُرْدًا فِي غَيْرِهِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِ، وَفِي تَصَرُّفَاتٍ مِنْ شَرَبِ دَوَاءٍ مُجَنَّبًا لِغَيْرِ تَدَاوٍ، وَنَفَى بَعْضُهُمْ قَوْلَ الْمَنْعِ، وَطُرِدَ الْآخَرُ فِي جِنْسِ الْمُنْصُوصِ مِنَ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي عَلَيْهِمَا فَقَطْ، فَحَصَلَ مِنْ ذَلِكَ مَا حَكَاهُ الْمُصَنِّفُ.

وَاحْتَرَزَ بِقَوْلِهِ: (أَتَمَّ) عَمَّنْ لَمْ يَأْتُمْ بِمَا ذَكَرَ، كَمَنْ أَوْجَرَ^(٥) مُسْكِرًا، أَوْ أَكْرَهَ عَلَى شُرْبِهِ، أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْكِرٌ، أَوْ تَنَاوَلَ دَوَاءً مُجَنَّبًا بِقَصْدِ التَّدَاوِي، وَيَرْجَعُ فِي حَدِّ السَّكَرَانِ إِلَى الْغُرْبِ، فَإِذَا انْتَهَى تَغْيِيرُ الشَّارِبِ إِلَى حَالَةٍ يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ السَّكَرَانِ عَرَفًا، فَهُوَ مَحَلُّ الْكَلَامِ. وَعَنِ الشَّافِعِيِّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّهُ: الَّذِي اخْتَلَّ كَلَامُهُ الْمَنْظُومُ وَانْكَشَفَ سِرُّهُ الْمَكْتُومُ، وَحَقَّقَ الْإِمَامُ^(٦)، فَقَالَ: شَارِبُ الْخَمْرِ تَغْيِيرُهُ ثَلَاثَةُ أَحْوَالٍ، إِحْدَاهَا: هِرَّةٌ وَنَشَاطٌ إِذَا دَبَّتْ

(٣) لأنه مجبر على اللفظ، ولا نية له تشعر بالاختيار. صححه الدميري.

(٤) واختاره: المزني، وابن سريج، وأبو طاهر الزبائدي، وأبو سهل الصعلوكي، وابنه سهل.

(٥) في أول كتاب الطلاق. قبل ألفاظ الطلاق بأسطر.

(١) الأم (٥٥٨/٦).

(٢) أَوْجَرَ: أَيْ: صُبَّ فِي فَمِهِ يَقَالُ: أَوْجَرَ الْعَلِيلَ، أَيْ: صَبَّ الْوَجُورَ فِي حَلْقِهِ، وَالْعَلِيلُ الدَّوَاءُ: جَعَلَهُ فِي فِيهِ.

المعجم الوسيط (١٠٤١/٢) باب الواو.

(٣) يعني: إمام الحرمين عبد الملك الجويني.

الْخَمْرُ فِيهِ وَلَمْ تَسْتَوِلْ عَلَيْهِ، وَالثَّانِيَّةُ: نِهَائَةُ السُّكْرِ، وَهِيَ: أَنْ يَصِيرَ طَافِحًا يَسْقُطُ كَالْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ لَا يَتَكَلَّمُ وَلَا يَكَادُ يَتَحَرَّكُ، وَالثَّالِثَةُ: مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَهُمَا وَهِيَ: أَنْ تَخْتَلِطَ أَحْوَالُهُ فَلَا تَنْتَظِمُ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ وَيَبْقَى تَمْيِيزُ وَكَلَامٌ وَفَهْمٌ^(١)؛ فَهَذِهِ الثَّانِيَّةُ.. مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي طَلَاقِ السُّكْرَانِ، وَأَمَّا الْأُولَى.. فَيَنْفُذُ الطَّلَاقُ فِيهَا قَطْعًا؛ لِبَقَاءِ الْعَقْلِ. وَأَمَّا الثَّانِيَّةُ.. فَلَا يَنْفُذُ فِيهَا؛ إِذْ لَا قَصْدَ لَهُ كَالْمُغْمَى عَلَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ عَلَى الْخِلَافِ؛ لِتَعَدِّيهِ بِالتَّسَبُّبِ إِلَى هَذِهِ الْحَالَةِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ: "وَهَذَا أَوْفَقُ، لِإِطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ"^(٢).

(وَلَوْ قَالَ: رُبْعُكَ، أَوْ بَعْضُكَ، أَوْ جُزْؤُكَ، أَوْ كِبْدُكَ، أَوْ شَعْرُكَ، أَوْ ظُفْرُكَ) أَوْ سِنَّكَ، أَوْ يَدُكَ، أَوْ رِجْلُكَ (طَالِقٌ.. وَقَعَ) الطَّلَاقُ قَطْعًا؛ بِطَرِيقِ السَّرَايَةِ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ إِلَى الْبَاقِي كَمَا يَسْرِي فِي الْعَتَقِ، وَقِيلَ: بِطَرِيقِ التَّغْيِيرِ بِالْجُزْءِ عَنِ الْكُلِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ الطَّلَاقُ فِي الْمُضَافِ إِلَيْهِ وَحْدَهُ، بِخِلَافِ الْعَتَقِ. تَظْهَرُ فَإِنْدَهُمَا: فِيمَا إِذَا قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ فَيَمِينُكَ طَالِقٌ، فَقُطِعَتْ يَمِينُهَا ثُمَّ دَخَلْتُ: إِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي.. طُلَقْتُ، وَإِلَّا.. فَلَا، (وَكَذَا دَمُكَ) طَالِقٌ.. يَقَعُ بِهِ الطَّلَاقُ (عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّ بِهِ قِوَامَ الْبَدَنِ، وَفِي وَجْهِ: لَا يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ كَفَضْلَةٍ، وَقُطِعَ بَعْضُهُمْ: بِالْأَوَّلِ (لَا فَضْلَةَ كَرِيقٍ وَعَرَقٍ) كَأَنَّ قَالَ: رِيْقُكَ، أَوْ عَرَقُكَ طَالِقٌ.. فَإِنَّهَا لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّهَا غَيْرُ مُتَّصِلَةٍ اتِّصَالَ خِلْقَةٍ^(٣) بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ، (وَكَذَا مِنْي وَلَبَنٌ) كَأَنَّ قَالَ: مِنْيْكَ، أَوْ لَبَنُكَ طَالِقٌ.. فَإِنَّهُمَا لَا يَقَعُ بِهِمَا الطَّلَاقُ (فِي الْأَصَحِّ)، وَالثَّانِي: يَقَعُ بِهِمَا؛ لِأَنَّ أَصْلَ كُلِّ مِنْهُمَا الدَّمُ، وَدُفِعَ: بِأَنَّهُمَا تَهَيَّأَ لِلْخُرُوجِ بِالِاسْتِحَالَةِ فَاشْتَبَهَا الْفَضْلَةُ، (وَلَوْ قَالَ لِمَقْطُوعَةٍ يَمِينٍ: يَمِينُكَ طَالِقٌ.. لَمْ يَقَعْ عَلَى الْمَذْهَبِ) وَالثَّانِي: فِي وَفُوعِهِ وَجْهَانِ، تَخْرِيجًا عَلَى الْوَجْهَيْنِ فِي أَنَّ الْوُفُوعَ عِنْدَ وُجُودِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ بِطَرِيقِ السَّرَايَةِ، أَوْ بِطَرِيقِ التَّغْيِيرِ عَنِ الْكُلِّ بِالْجُزْءِ؟ إِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي.. وَقَعَ، وَإِلَّا.. فَلَا، وَدُفِعَ التَّخْرِيجُ: بِأَنَّهُ عَلَى الْقَوْلِ بِالثَّانِي لَا بُدَّ مِنْ وُجُودِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ لِتَنْتَظِمَ الْإِضَافَةُ.

(٤) نهأى: المطالب (١٦٩/١٤، ١٧٠).

(٥) فتح العزيز (٥٦٦/٨)، وروضة الطالبين (٦٣/٨).

(١) فلا يلحقها حل ولا تحریم، وإنما البدن وعاء لها، وفيهما وجه ضعيف، ويجريان في سائر الفضلات كالبول

والمخاط، وفي الأخلاط كالبلغم.

(وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْكَ طَالِقٌ وَنَوَى تَطْلِيلَهَا.. طَلَّقْتُ)؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ حَجْرًا مِنْ جِهَتِهَا، حَيْثُ لَا يَنْكِحُ مَعَهَا أُخْتَهَا، وَلَا أَرْبَعًا، وَيَلْزِمُهُ صَوْنُهَا، فَصَحَّ إِضَافَةُ الطَّلَاقِ إِلَيْهِ؛ لِحِلِّ السَّبَبِ الْمُقْتَضِي لِهَذَا الْحَجْرِ مَعَ النِّيَّةِ، (وَأِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا.. فَلَا) تُطْلَقُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ كِنَايَةً مِنْ حَيْثُ إِضَافَتُهُ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، (وَكَذَا إِنْ لَمْ يَنْوِ) مَعَ نِيَّةِ الطَّلَاقِ (إِضَافَتُهُ إِلَيْهَا).. لَا تُطْلَقُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا مَحَلُّ الطَّلَاقِ، وَقَدْ أُضِيفَ إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ، فَلَا بُدَّ فِي وُقُوعِهِ مِنْ صَرْفِهِ بِالنِّيَّةِ إِلَى مَحَلِّهِ، وَالثَّانِي: تُطْلَقُ؛ لَوْجُودِ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى التَّعَرُّضِ لِلْمَحَلِّ (وَلَوْ قَالَ: أَنَا مِنْكَ بَائِنٌ.. أَشْطَرُ نِيَّةِ الطَّلَاقِ، وَفِي الْإِضَافَةِ) إِلَيْهَا (..الْوَجْهَانِ) أَصَحُّهُمَا: الْإِشْتِرَاطُ، فَإِذَا نَوَى الطَّلَاقَ مُضَافًا إِلَيْهَا.. وَقَعَ، وَإِلَّا.. فَلَا؛ لِمَا تَقَدَّمَ، (وَلَوْ قَالَ: اسْتَبْرِئِي رَجَمِي مِنْكَ.. فَلَعُوْ) وَإِنْ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ غَيْرُ مُنْتَظَمٍ فِي نَفْسِهِ، وَالْكِنَايَةُ شَرْطُهَا: اخْتِمَالُ اللَّفْظِ لِلْمَعْنَى الْمُرَادِ، (وَقِيلَ: إِنْ نَوَى طَلَاقَهَا وَقَعَ) وَالْمَعْنَى الْمُرَادُ: اسْتَبْرِئِي الرَّجْمَ الَّتِي كَانَتْ لِي.

محل الطلاق والولاية عليه

(فَصُلِّ: خِطَابُ الْأَجْنَبِيَّةِ بِطَّلَاقٍ، كَقَوْلِهِ لَهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، (وَتَغْلِيْقُهُ بِنِكَاحٍ وَغَيْرِهِ) كَقَوْلِهِ: إِنْ نَكَحْتُكَ فَأَنْتَ طَالِقٌ، أَوْ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَنْكِحُهَا فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ فَأَنْتَ طَالِقٌ (..لَعُوْ) أَي: فَلَا تُطْلَقُ عَلَى زَوْجِهَا، وَلَا بِنِكَاحِهَا، وَلَا بِدُخُولِهَا الدَّارَ بَعْدَ نِكَاحِهَا؛ لِإِنْتِفَاءِ الْوِلَايَةِ مِنَ الْقَائِلِ عَلَى الْمَحَلِّ^(١)، وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {لَا طَّلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ} صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ^(٢)، (وَالْأَصَحُّ: صِحَّةُ تَغْلِيْقِ الْعَبْدِ ثَالِثَةً، كَقَوْلِهِ: إِنْ عُتِقْتُ أَوْ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، (فَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا.. فَيَقَعَنَّ إِذَا عُتِقَ، أَوْ دَخَلْتَ بَعْدَ عِتْقِهِ)؛ لِأَنَّهُ يَمْلِكُ أَصْلَ النِّكَاحِ، وَهُوَ يُفِيدُ الطَّلَاقَ الثَّلَاثَ بِشَرْطِ الْحُرِّيَّةِ وَقَدْ وُجِدَ، وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْلِكُ تَنْجِيزَهَا،

(٢) المحل هنا: الزوجة، والمراد: أن القائل- الأجني الذي حلف بالطلاق- لا يملك الولاي:ة عليها : لأنه ليس زوجها لها.

(٣) هذا الحديث روي بهذا اللفظ، وبلفظ: "لا طلاق قبل النكاح" وبلفظ: "لا طلاق فيما لأي:ملك". من طرق عن أم المؤمنين عائشة، وعبد الله بن عباس، وابن عمر، ومعاذ وغيرهم- رضي الله عنهم- والمصنف عزاه إلى الترمذي، وهو من روأي:ة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ولفظه في الترمذي: "...ولا طلاق له فيما لا يملك". أخرجه الترمذي في كتاب الطلاق، باب: لا طلاق قبل النكاح (١١٨١) أما اللفظ الذي ذكره المصنف ففي مستدرک الحاكم وسنن الدارمي والبيهقي وغيرهم.

فَلَا يَمْلِكُ تَغْلِيْقَهَا.. فَيَقَعُ فِيْمَا ذَكَرَ طُلُقَتَانِ، (وَيَلْحَقُ) الطَّلَاقُ (رَجْعِيَّةً)؛ لِبَقَاءِ الْوَلَايَةِ عَلَيْهَا بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ (لَا مُخْتَلَعَةً)؛ لِإِنْتِفَاءِ الْوَلَايَةِ عَلَيْهَا، (وَلَوْ عَلَّقَهُ بِدُخُولِ) مَثَلًا (فَبَاءَتْ) بِطَّلَاقِ قَبْلِ الدُّخُولِ بِهَا أَوْ بَعْدَهُ (ثُمَّ نَكَحَهَا ثُمَّ دَخَلَتْ.. لَمْ يَقَعْ إِنْ) كَانَتْ (دَخَلَتْ فِي الْبَيْتُونَةِ)؛ لِإِنْحِلَالِ الْيَمِينِ بِالدُّخُولِ فِيهَا (وَكَذَا) لَا يَقَعْ (إِنْ لَمْ تَدْخُلْ) فِي الْبَيْتُونَةِ (فِي الْأَظْهَرِ)؛ لِإِرْتِفَاعِ النِّكَاحِ الَّذِي عَلَّقَ فِيهِ، وَالثَّانِي: يَقَعْ؛ لَوْجُودِ الصِّفَةِ فِي النِّكَاحِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُوجَدَ قَبْلَهُ (وَفِي ثَالِثٍ (١): يَقَعْ إِنْ بَاءَتْ بِدُونِ ثَلَاثٍ)؛ لِأَنَّهَا لِعَوْدِهَا بِبَاقِي الثَّلَاثِ تَعُودُ بِصِفَتِهِ مِنَ التَّغْلِيْقِ الْمَذْكُورِ؛ بِخِلَافِ مَا إِذَا بَاءَتْ بِثَلَاثٍ.. فَلَا يَقَعْ؛ لِاسْتِيفَائِهِ بِالثَّلَاثِ مَا عَلَّقَ، (وَلَوْ طُلُقَ دُونَ ثَلَاثٍ، وَرَاجَعَ أَوْ جَدَّدَ وَلَوْ بَعْدَ زَوْجٍ.. عَادَتْ بِبَقِيَّةِ الثَّلَاثِ) دَخَلَ بِهَا الزَّوْجُ، أَمْ لَمْ يَدْخُلْ (وَإِنْ ثَلَّثَ) أَيِ: طُلُقَ ثَلَاثًا، وَجَدَّدَ بَعْدَ زَوْجٍ دَخَلَ بِهَا وَفَارَقَهَا، (..عَادَتْ بِثَلَاثٍ) كَمَا لَوْ ابْتَدَأَ نِكَاحَهَا (وَلِلْعَبْدِ طُلُقَتَانِ فَقَطْ، وَلِلْحَرِّ ثَلَاثٌ) سِوَاءٍ كَانَتْ الزَّوْجَةُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا حُرَّةً أَمْ أَمَةً، وَالْمُبْعُضُ (٢) وَالْمُدَبَّرُ (٣) وَالْمُكَاتَبُ (٤) كَالْقَيْنِ (٥) (وَيَقَعُ) الطَّلَاقُ، (فِي مَرَضٍ مَوْتِهِ) كَمَا يَقَعُ فِي صِحَّتِهِ (وَيَتَوَارَثَانِ) أَيِ: الزَّوْجُ الْمَرِيضُ وَالزَّوْجَةُ (فِي عِدَّةٍ رَجْعِيٍّ)؛ لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ فِي الرَّجْعِيَّةِ بِلُحُوقِ الطَّلَاقِ بِهَا، كَمَا تَقَدَّمَ، وَصِحَّةِ الْإِيلَاءِ وَالظَّهَارِ وَاللِّعَانِ مِنْهَا، كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّجْعَةِ، وَوُجُوبِ النِّفْقَةِ لَهَا، كَمَا سَيَأْتِي فِي النِّفَقَاتِ (لَا بَائِنٌ) (٦)؛ لِإِنْقِطَاعِ الزَّوْجِيَّةِ (وَفِي الْقَدِيمِ: تَرْتُّهُ)؛ لِأَنَّ تَطْلِيْقَهَا بِغَيْرِ اخْتِيَارِهَا يَدُلُّ عَلَى قَصْدِهِ حَرَمَانَهَا مِنَ الْإِرْثِ، فَيُعَاقَبُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، فَإِنْ اخْتَارَتْ الطَّلَاقَ؛ بِأَنْ سَأَلَتْهُ، أَوْ اخْتَلَعَتْ، أَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى مَشِيئَتِهَا، فَشَاءَتْهُ.. لَمْ تَرْتُ جَزْمًا.

تعدد الطلاق بنية العدد فيه

(٤) يعني: في قول ثالث.

(٥) المبعوض: هو العبد الذي اعتق بعضه وبقي بعضه الآخر رقيقًا.

(٦) المكاتب، هو: العبد الذي كاتب سسيده على أن يسدد ثمنه على أقساط بعدها يعتق، ويملك حريته.

(٧) المدبّر: هو العبد الذي قال له سيده: "أنت حردبروقي" أي: بعدها، فإذا مات سيده أصبح حرا.

(٨) القن: هو العبد الخالص العبودة، وهو العبد الذي ملك هو وأبواه.

(٩) يعني: المطلقة طلاقا بائنا في مرض الموت بدون طلب منها أو اختلاع لا ترث من زوجها.

(فَصْلٌ: قَالَ: طَلَّقْتُكَ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ وَنَوَى عَدَدًا مِنْ طُلُقَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ (..وَقَعَ) مَا نَوَاهُ، (وَكَذَا الْكِنَايَةُ) إِذَا نَوَى فِيهَا عَدَدًا.. وَقَعَ مَا نَوَاهُ؛ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ، وَسِوَاهُ فِي هَذَا: الْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا، كَمَا زَادَهُ فِي "الرَّوْضَةِ" (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ وَاحِدَةً) بِالنَّصْبِ، (وَنَوَى عَدَدًا.. فَوَاحِدَةً) عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ (وَقِيلَ: الْمُنَوَّى) (١) عَمَلًا بِالنِّيَّةِ، وَصَحَّحَ الثَّانِي فِي "أَصْلِ الرَّوْضَةِ" (٢) تَبَعًا لِلْبَغَوِيِّ، وَغَيْرِهِ، وَالْأَوَّلُ: صَحَّحَهُ الْغَزَالِيُّ (٣)، وَعِبَارَةُ "الْمُحَرَّرِ" فِيهِ: رَجَّحَ (٤). (قُلْتُ: وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ وَاحِدَةً) بِالرَّفْعِ (وَنَوَى عَدَدًا.. فَالْمُنَوَّى) (٥)؛ حَمَلًا لِلتَّوْحِيدِ عَلَى التَّفَرُّدِ عَنِ الزَّوْجِ بِالْعَدَدِ الْمُنَوَّى؛ لِقُرْبِهِ مِنَ اللَّفْظِ، (وَقِيلَ: وَاحِدَةً، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ السَّابِقَ إِلَى الْفَهْمِ مِنْ ذَلِكَ: التَّطْلِيقُ بِوَاحِدَةٍ، وَلَوْ ذَكَرَ قَبْلَ وَاحِدَةٍ "طَالِقٌ".. فَفِيهِ الْخِلَافُ، (وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَقُولَ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَمَاتَتْ قَبْلَ تَمَامِ طَالِقٍ.. لَمْ يَقَعْ)؛ لِخُرُوجِهَا عَنْ مَحَلِّ الطَّلَاقِ قَبْلَ تَمَامِ لَفْظِهِ (أَوْ بَعْدَهُ قَبْلَ ثَلَاثًا.. فَثَلَاثٌ)؛ لِتَضَمُّنِ إِرَادَتِهِ الْمَذْكُورَةِ لِقَصْدِ الثَّلَاثِ، وَقَدْ تَمَّ مَعَهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ فِي حَيَاتِهَا (وَقِيلَ: وَاحِدَةً)، كَمَا لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى أَنْتَ طَالِقٌ لِأَنَّهُ الَّذِي صَادَفَ الْحَيَاةَ (وَقِيلَ: لَا شَيْءَ)؛ لِأَنَّ الْكَلَامَ الْوَاحِدَ لَا يُفْصَلُ بَعْضُهُ عَنْ بَعْضٍ فِي الْحُكْمِ، وَلَا يُعْطَى بَعْضُهُ حُكْمَ كُلِّهِ، وَحَقَّقَ إِسْمَاعِيلُ الْبُوشَنجِيُّ (٦) فَقَالَ: إِنَّ نَوَى الثَّلَاثِ يَقُولُهُ أَنْتَ طَالِقٌ، وَقَصْدَ أَنْ يُحَقِّقَهُ بِاللَّفْظِ.. فَثَلَاثٌ، وَإِلَّا.. فَوَاحِدَةً (وَأِنْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، أَنْتَ طَالِقٌ، وَتَخَلَّلَ فَصْلٌ)، بَيْنَ هَذِهِ الصِّيَغِ؛ كَأَنَّ سَكَتَ بَيْنِهَا فَوْقَ سَكَتِهِ

(٢) يقصد بها أنه: يقع العدد الذي نواه.

(٣) روضة الطالبين (٧٦/٨).

(٤) الوجيز، ص ٣٨٨.

(٥) المحرر، ص ٢٣١.

(٦) يقصد بها أنه: يقع العدد الذي نواه.

(٧) هو: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبُوشَنجِيِّ الْإِمَامِ أَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي الْقَاسِمِ، فقيه شافعي، مولده سنة ٤٦١ هـ، ووفاته سنة ٥٦٣ هـ، قال تاج الدين السبكي: وهو مشهور عند الفقهاء بالبوشنجي وعند المحدثين بالخرجدي، وقال: "قلت: البوشنجي بضم الباء بعدها واو ساكنة ثم شين معجمة مفتوحة ثم نون ساكنة ثم الجيم نسبة إلى بوشنج بلدة قديمة على سبعة فراسخ من هراة والنسبة إليها بوشنجي وفوشنجي بالفاء والباء الموحدة من تحت... والخرجدي بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الجيم وسكون الراء الأخرى وكسر الدال المهملة نسبة إلى خرجرد بلدة من بلاد بوشنج هراة. طبقات الشافعية (٥٠-٤٨/٧).

التَّنْفِيسِ وَنَحْوَهَا) (..فَثَلَاثُ)، فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ التَّأْكِيدَ.. لَمْ يُقْبَلْ، وَيُدَيَّنُ (١) (وَالَا) أَي: وَإِنْ لَمْ يَتَخَلَّلْ فَصْلٌ (فَإِنْ قَصَدَ تَأْكِيدًا) بِمَا بَعْدَ الْأُولَى لَهَا (..فَوَاحِدَةٌ)؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ فِي الْكَلَامِ مَغْهُودٌ وَالتَّكَرُّارُ مِنْ وَجْهِ التَّأْكِيدِ (أَوْ اسْتِثْنَاءًا.. فَثَلَاثُ، وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ فِي الْأَظْهَرِ) عَمَلًا بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِأَنَّ التَّأْكِيدَ مُحْتَمَلٌ فَيُؤْخَذُ بِالْيَقِينِ، (وَإِنْ قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ تَأْكِيدًا وَبِالثَّالِثَةِ اسْتِثْنَاءًا أَوْ عَكْسًا) أَي: قَصَدَ بِالثَّانِيَةِ اسْتِثْنَاءًا، وَبِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الثَّانِيَةِ، (..فَتَيْنَتَانِ أَوْ بِالثَّالِثَةِ تَأْكِيدَ الْأُولَى) مَعَ الْإِسْتِثْنَاءِ بِالثَّانِيَةِ (..فَثَلَاثُ فِي الْأَصَحِّ) لِيَتَخَلَّلَ الْفَاصِلُ، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ إِلَّا تَيْنَتَانِ؛ لِأَنَّ الْفَصْلَ الْيَسِيرَ يَحْتَمَلُ، (وَإِنْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، وَطَالِقٌ.. صَحَّ قَصْدُ تَأْكِيدِ الثَّانِي بِالثَّالِثِ)؛ لِمَسَاوِيهِمَا (لَا الْأَوَّلُ بِالثَّانِي)؛ لِاخْتِصَاصِ الثَّانِي بِوَاوِ الْعَطْفِ الْمَوْجِبِ لِلتَّغَايُرِ (وَهَذِهِ الصُّورُ فِي مَوْطُوءَةٍ، فَلَوْ قَالَ هُنَّ لِعَظْمَاهَا.. فَطَلْقَةٌ بِكُلِّ حَالٍ)، لِأَنَّهَا تَبِينُ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ، فَلَا يَقَعُ، أَي: لِعَظْمِ الْمَذْخُولِ بِهَا. (وَلَوْ قَالَ لِهَذِهِ) أَي: لِعَظْمِ الْمَذْخُولِ بِهَا: (إِنْ دَخَلَتْ فَأَنْتَ طَالِقٌ، وَطَالِقٌ، فَدَخَلَتْ.. فَتَيْنَتَانِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُمَا جَمِيعًا مُعَلَّقَتَانِ بِالْمَذْخُولِ، وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ إِلَّا وَاحِدَةٌ، كَمَا لَوْ نَجَرَ، وَلَوْ أَخَّرَ الشَّرْطَ (٢) .. فَقِيلَ: عَلَى الْوَجْهَيْنِ، وَقِيلَ: يُقْطَعُ بِوُقُوعِ التَّيْنَتَيْنِ؛ لِإِتِفَاقِ احْتِمَالِ الشَّرْطِ بِأَحَدِ اللَّفْظَيْنِ؛ بِخِلَافِهِ فِي الْأَوَّلِ (وَلَوْ قَالَ لِمَوْطُوءَةٍ: أَنْتَ طَالِقٌ طَلْقَةٌ مَعَ طَلْقَةٍ (أَوْ مَعَهَا طَلْقَةٌ.. فَتَيْنَتَانِ) مَعًا، وَقِيلَ مُرْتَبًا، وَيُسَبِّحُ عَلَيْهِمَا قَوْلُهُ: (وَكَذَا غَيْرُ مَوْطُوءَةٍ فِي الْأَصَحِّ) فَعَلَى الْمَعْنَى: يَقَعُ تَيْنَتَانِ، وَعَلَى التَّرْتِيبِ: وَاحِدَةٌ تَبِينُ بِهَا. (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ (طَلْقَةٌ قَبْلَ طَلْقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا طَلْقَةٌ.. فَتَيْنَتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ، وَطَلْقَةٌ فِي غَيْرِهَا) تَبِينُ بِهَا لِلتَّرْتِيبِ (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ (طَلْقَةٌ بَعْدَ طَلْقَةٍ، أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ.. فَكَذَا) أَي: يَقَعُ تَيْنَتَانِ فِي مَوْطُوءَةٍ وَوَاحِدَةٌ فِي غَيْرِهَا، (فِي الْأَصَحِّ) فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ فِي مَوْطُوءَةٍ إِلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ الْمَعْنَى: بَعْدَ طَلْقَةٍ مَمْلُوكَةٍ لِي أَوْ قَبْلَهَا طَلْقَةٌ مَمْلُوكَةٌ لِي، وَعَلَى الْأَوَّلِ قِيلَ: تَقَعُ الْمُنْجَزَةُ أَوَّلًا، وَتَغْفُيُهَا الْمُضْمَنَةُ، وَيَلْغُو ذِكْرُ بَعْدَ وَقَبْلَ.

(١) يعني: لم يقبل في الحكم والقضاء: لكن يقبل ديانة فيما بينه وبين الله تعالى.

(٢) بأن قال: "أنت طالق، وطلّق إن دخلت".

وَالْأَصَحُّ فِي "أَصْلِ الرُّوضَةِ" وَقُوعُ الْمُضْمَنَةِ أَوَّلًا، ثُمَّ الْمُنْجَرَّةُ^(١) وَعَلَى هَذَا قِيلَ: يَقَعُ فِي غَيْرِ الْمَوْطُوعَةِ ثِنْتَانِ، وَيَلْغُو ذِكْرُ بَعْدَ وَقَبْلُ، وَكَأَنَّهُ قِيلَ: طَلَّقْتَنِي (وَلَوْ قَالَ): أَنْتَ طَالِقٌ (طَلَّقَهُ فِي طَلْقَةٍ، وَأَزَادَ: مَعَ) طَلْقَةٍ (..فَطَلَّقْتَانِ) وَلَفْظُهُ "فِي" تُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى "مَعَ"، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ} [الأعراف: ٣٨] (أَوْ الظَّرْفُ، أَوْ الْحِسَابُ، أَوْ أَطْلَقَ.. فَطَلَّقَهُ)^(٢)؛ لِأَنَّهَا مُقْتَضَى الظَّرْفِ، وَمَوْجِبُ الْحِسَابِ، وَالْمُحَقِّقُ فِي الْإِطْلَاقِ (وَلَوْ قَالَ): أَنْتَ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَةٍ فِي نِصْفِ طَلْقَةٍ.. فَطَلَّقَهُ بِكُلِّ حَالٍ) مِمَّا ذَكَرَ مِنْ إِرَادَةِ الْمَعِيَّةِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ، أَوْ الظَّرْفُ، أَوْ الْحِسَابُ، أَوْ عَدَمُ شَيْءٍ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَتَبَعُضُ، وَلَفْظُهُ "نِصْفِ" الثَّانِيَةِ مَكْتُوبَةٌ فِي هَامِشِ نُسْخَةِ الْمُصَنَّفِ بِغَيْرِ خَطِّهِ، وَهِيَ صَوَابٌ كَمَا ذَكَرْتُ فِي "الْمَحَرَّرِ"^(٣)، وَ"الشرح"^(٤)، إِذْ لَوْ أَسْقِطْتُ وَأُرِيدَ الْمَعِيَّةُ.. وَقَعَ طَلَّقْتَانِ، كَمَا فِي "الشرح".^(٥) (وَلَوْ قَالَ): أَنْتَ طَالِقٌ (طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ وَقَصَدَ مَعِيَّةً.. فَثَلَاثٌ، أَوْ ظَرْفًا.. فَوَاحِدَةٌ، أَوْ حِسَابًا وَعَرَفَهُ.. فَثِنْتَانِ)؛ لِأَنَّهُمَا مُوجِبُهُ^(٦)، (وَأِنْ جَهَلَهُ وَقَصَدَ مَعْنَاهُ) عِنْدَ أَهْلِ الْحِسَابِ، (..فَطَلَّقَهُ، وَقِيلَ: ثِنْتَانِ)؛ لِقَصْدِهِ مَعْنَى الْحِسَابِ، وَضَعِفَ: بِأَنَّ مَا لَمْ يُعْلَمْ.. لَا يَصِحُّ قَصْدُهُ، (وَأِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا.. فَطَلَّقَهُ)؛ لِأَنَّهَا الْمُحَقِّقُ (وَفِي قَوْلٍ: ثِنْتَانِ إِنْ عَرَفَ حِسَابًا) حَمَلًا عَلَيْهِ. (وَلَوْ قَالَ): أَنْتَ طَالِقٌ (بَعْضُ طَلْقَةٍ.. فَطَلَّقَهُ، أَوْ نِصْفِي طَلْقَةٍ.. فَطَلَّقَهُ؛ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ كُلَّ نِصْفٍ مِنْ طَلْقَةٍ) .. فَيَقَعُ طَلْقَتَانِ، وَقُوعُ الطَّلْقَةِ بِذِكْرِ بَعْضِهَا مُبْهَمًا أَوْ مُعَيَّنًا، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ^(٧) وَغَيْرُهُ: بِطَرِيقِ السَّرَايَةِ، وَإِمَامُ الْحَرَمَيْنِ: بِطَرِيقِ التَّعْيِيرِ بِالْبَعْضِ عَنِ الْكُلِّ، (وَالْأَصَحُّ أَنْ قَوْلُهُ): أَنْتَ طَالِقٌ (نِصْفَ طَلْقَتَيْنِ) .. يَقَعُ بِهِ (طَلْقَةً)؛ لِأَنَّهَا نِصْفُهُمَا، وَقِيلَ:

(١) روضة الطالبين (٨/٨١)

(٢) يعني: لو قال: أنت طالق طلاقة في طلاقة. وأراد الظرف، أو الحساب، أو أطلق ذلك دون إرادة شيء، ففي ذلك كله.. تقع طلاقة.

(٣) المحرر، ص ٣٣٢.

(٤) الشرح الكبير المعروف بفتح العزيز (٩/١٨)

(٥) المرجع السابق

(٦) قوله: (موجبه) يَفْتَحُ الْجِيمُ أَي: مقتضاه. تحرير ألفاظ التنبيه (١/٢٦٥).

(٧) هو الشيخ أبو حامد الأسفراي: يني، أحمد بن محمد المتوفى سنة ٤٠٦ هـ. ومن فقهاء الشافعية أيضا: أبو حامد

المروزي، أحمد بن بشر بن عامر، المتوفى سنة ٣٦٢ هـ. إلا أن الأسفراي: يني يأتي مقيدا في كتب

الشافعية بالشيخ. والمروزي يأتي مقيدا بالقاضي، فلا يلتبسان.

طَلَّقَتَانِ؛ نَظَرًا إِلَى نِصْفِ كُلِّ طَلْقَةٍ، (و) أَنَّ قَوْلَهُ: أَنْتِ طَالِقٌ، (ثَلَاثَةُ أَنْصَافِ طَلْقَةٍ، أَوْ نِصْفِ طَلْقَةٍ، وَثُلُثُ طَلْقَةٍ) .. يَقَعُ بِهِ (طَلَّقَتَانِ)؛ نَظَرًا فِي الْأُولَى إِلَى زِيَادَةِ النِّصْفِ الثَّالِثِ عَلَى الطَّلْقَةِ فَيُحْسَبُ مِنْ أُخْرَى، وَفِي الثَّانِيَةِ إِلَى تَكَرُّرِ لَفْظِ طَلْقَةٍ مَعَ الْعَطْفِ، وَقِيلَ: لَا يَقَعُ فِيهِمَا إِلَّا طَلْقَةٌ؛ إِنْغَاءً لِلزَّائِدِ فِي الْأُولَى، وَنَظَرًا فِي الثَّانِيَةِ إِلَى أَنَّ الْمُضَافَيْنِ مِنْ أَجْزَاءِ الطَّلْقَةِ. (وَلَوْ قَالَ): أَنْتِ طَالِقٌ (نِصْفَ وَثُلُثَ طَلْقَةٍ .. فَطَلْقَةٌ) لَا طَلَّقَتَانِ؛ لِإِنْتِفَاءِ تَكَرُّرِ لَفْظِ طَلْقَةٍ، وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفَ طَلْقَةٍ، ثُلُثَ طَلْقَةٍ .. لَمْ يَقَعْ إِلَّا وَاحِدَةٌ؛ لِإِنْتِفَاءِ الْعَطْفِ (وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ: أَوْقَعْتُ عَلَيْكَ، أَوْ بَيَّنَّكَ طَلْقَةً، أَوْ طَلَّقْتَيْنِ، أَوْ ثَلَاثًا، أَوْ أَرْبَعًا .. وَقَعَ عَلَى كُلِّ طَلْقَةٍ)؛ لِأَنَّ مَا ذَكَرَ إِذَا وُزِعَ عَلَيْهِنَّ خَصَّ كُلًّا مِنْهُنَّ طَلْقَةً أَوْ بَعْضَهَا، فَتَكْمُلُ (فَإِنْ قَصِدَ تَوَزِيعَ كُلِّ طَلْقَةٍ عَلَيْهِنَّ .. وَقَعَ) عَلَى كُلِّ مِنْهُنَّ (فِي ثِنْتَيْنِ: ثِنْتَانِ، وَفِي ثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ: ثَلَاثٌ) (١)، كَمَا يَقَعُ فِي وَاحِدَةٍ: وَاحِدَةٌ، وَعِنْدَ الْإِطْلَاقِ: لَا يُحْمَلُ اللَّفْظُ عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ؛ لِبُعْدِهِ عَنِ الْفَهْمِ، (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ بَيِّنَنَّكَ: بَعْضَهُنَّ) أَيِ: ثَلَاثَةً، وَفُلَانَةً مَثَلًا (.. لَمْ يُقْبَلْ ظَاهِرًا فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّ ظَاهِرَ اللَّفْظِ يَقْتَضِي شَرِكَتَهُنَّ، وَيُدَيِّنُ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ؛ لِاحْتِمَالِ "بَيِّنَنَّكَ" لِمَا أَرَادَ؛ بِخِلَافِ "عَلَيْكَ"، فَلَا يُقْبَلُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ بَعْضَهُنَّ جَزْمًا، قَالَهُ الْإِمَامُ (٢) وَالْبَعْوِيُّ (٣) (وَلَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ لِأُخْرَى: أَشْرَكَكَ مَعَهَا، أَوْ: أَنْتِ كَهَيِّ) أَوْ مِثْلَهَا (.. فَإِنْ نَوَى) بِذَلِكَ طَلَّاقَهَا (طَلَّقَتْ، وَإِلَّا .. فَلَا) تُطَلَّقُ؛ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِغَيْرِ الطَّلَاقِ، (وَكَذَا لَوْ قَالَ آخِرُ ذَلِكَ لِامْرَأَتِهِ) أَيِ: قَالَ لَهَا بَعْدَ أَنْ طَلَّقَ رَجُلًا امْرَأَتَهُ: أَشْرَكَكَ مَعَهَا، أَوْ: أَنْتِ كَهَيِّ، أَوْ مِثْلَهَا: فَإِنْ نَوَى طَلَّاقَهَا بِذَلِكَ .. طَلَّقَتْ، وَإِلَّا .. فَلَا؛ لِمَا ذَكَرَ.

الاستثناء في الطلاق

(١) وقع في نسخة "المحرر": "وفي ثلاث: ثلاث، وفي أربع: أربع" قال في الدقائق: وهو غلط: لسبق قلم أومن

الناسخ. والصواب: ما في المنهاج، كما ورد هنا "في ثلاث وأربع: ثلاث". ينظر: دقائق المنهاج"، ص ٦٩.

(٢) نهاية المطلب (١٩٣/١٤)

(٣) التهذيب (٨٦/٦) الاستثناء هو إخراج بعض من كل إخراج الشيء من حكم دخل فيه

(فَصْلٌ: يَصِحُّ الْإِسْتِثْنَاءُ^(١) فِي الطَّلَاقِ، كَأَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا وَاحِدَةً.. فَيَقَعُ ثِنْتَانِ (بِشَرْطِ اتِّصَالِهِ) بِالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَإِنْ انفَصَلَ.. لَمْ يُوْثَرْ (وَلَا يَضُرُّ) فِي الْإِتِّصَالِ (سَكَنَتُهُ تَنْفُسٍ، وَعِيٍّ)^(٢)؛ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ فَاصِلًا، بِخِلَافِ الْكَلَامِ الْيَسِيرِ الْأَجْنَبِيِّ.. فَيُضَرُّ عَلَى الصَّحِيحِ (قُلْتُ: وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَنْوِيَ الْإِسْتِثْنَاءَ قَبْلَ فَرَاغِ الْيَمِينِ فِي الْأَصَحِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَالثَّانِي: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ؛ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَبْدُو لَهُ الْإِسْتِثْنَاءُ بَعْدَ تَمَامِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، وَاعْتَرَضَ ذَلِكَ: بِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ رَفْعُ الطَّلَاقِ بَعْدَ وَقُوعِهِ. (وَيُشْتَرَطُ: عَدَمُ اسْتِغْرَاقِهِ) لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا.. لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِثْنَاءُ، وَوَقَعَ الثَّلَاثُ (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا ثَنَيْنِ وَوَاحِدَةً.. فَوَاحِدَةً، وَقِيلَ: ثَلَاثُ) الثَّانِي يَجْمَعُ الْمُسْتَثْنَى فَيَكُونُ مُسْتِغْرَقًا وَالْأَوَّلُ لَا يَجْمَعُهُ، وَيُلْغَى قَوْلُهُ: وَوَاحِدَةً؛ لِحُصُولِ اسْتِغْرَاقِ بِهَا (أَوْ): أَنْتَ طَالِقٌ، (ثَنَيْنِ وَوَاحِدَةً إِلَّا وَاحِدَةً.. فَثَلَاثُ، وَقِيلَ: ثِنْتَانِ) الثَّانِي يَجْمَعُ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ مُسْتِثْنَاءً مِنَ الثَّلَاثِ، وَالْأَوَّلُ لَا يَجْمَعُهُ فَتَكُونُ الْوَاحِدَةُ مُسْتِثْنَاءً مِنَ الْوَاحِدِ فَيُلْغَوُ الْإِسْتِثْنَاءُ. (وَهُوَ) أَيِ: الْإِسْتِثْنَاءُ (مِنْ نَفِيٍّ إِبْتِثَاتٍ)^(٣) وَعَكْسُهُ) أَيِ: مِنْ الْإِبْتِثَاتِ نَفِيٍّ^(٤) (فَلَوْ قَالَ): أَنْتَ طَالِقٌ (ثَلَاثًا إِلَّا ثَنَيْنِ إِلَّا طَلْقَةً.. فَثِنْتَانِ)؛ لِأَنَّ الْمُسْتَثْنَى الثَّانِي مُسْتَثْنَى مِنَ الْأَوَّلِ، فَيَكُونُ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَقِيقَةِ وَاحِدَةً، (أَوْ: ثَلَاثًا إِلَّا ثَلَاثًا إِلَّا ثَنَيْنِ.. فَثِنْتَانِ)؛ لِمَا ذَكَرَ. (وَقِيلَ: ثَلَاثُ)؛ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ الْأَوَّلَ مُسْتِغْرَقٌ، فَيُلْغَوُ، وَالثَّانِي مُرْتَبِّ عَلَيْهِ، فَيُلْغَوُ أَيْضًا (وَقِيلَ: طَلْقَةً)؛ لِأَنَّ الْإِسْتِثْنَاءَ الثَّانِي صَحِيحٌ، فَيَعُودُ إِلَى أَوَّلِ الْكَلَامِ^(٥) (أَوْ: خَمْسًا إِلَّا ثَلَاثًا.. فَثِنْتَانِ، وَقِيلَ: ثَلَاثُ) اعْتِبَارًا لِلْإِسْتِثْنَاءِ مِنَ الْمَلْفُوظِ؛ لِأَنَّهُ لَفْظِيٌّ، وَقِيلَ: مِنْ الْمَمْلُوكِ، (أَوْ:

(٤) الْإِسْتِثْنَاءُ: هُوَ إِخْرَاجُ بَعْضِ الْجُمْلَةِ بِلَفْظٍ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا، مَا خُوِذَ مِنْ ثَنِيَّتٍ، أَيِ: عَطْفَتْ. تَحْرِيرُ أَلْفَاظِ التَّنْبِيهِ (٢٦٥/١).

(١) وَكَذَلِكَ: عَرُوضُ السَّعَالِ، وَانْقِطَاعُ الصَّوْتِ، هَذَا: وَالْعِي- بِالْفَتْحِ- الْعَجْزُ، وَالتَّعَبُ، وَعَدَمُ الْإِطَاقَةِ، وَيُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى عَدَمِ الْاهْتِدَاءِ لَوَجْهِ الْمُرَادِ، وَبِالْكَسْرِ: الْحَصَرُ، وَالْعَجْزُ فِي النَّطْقِ خَاصَّةً، وَهُوَ الْمُرَادُ هُنَا. أَوْ هُوَ: الْعَجْزُ عَنِ التَّغْيِيرِ اللَّفْظِيِّ بِمَا يُفِيدُ الْمَعْنَى الْمَقْصُودَ. وَعَدَمُ الْاهْتِدَاءِ لَوَجْهِ الْمُرَادِ وَالْعَجْزُ عَنْ أَذَانِهِ. تَاجُ الْعُرُوسِ، الْمَعْجَمُ الْوَسِيطُ، بَابُ الْعَيْنِ (٦٤٣/٣).

(٢) بِالِاتِّفَاقِ. ذَكَرَهُ الدِّمِيرِيُّ

(٣) خَالَفَ فِيهَا أَبُو حَنِيفَةَ- رَحِمَهُ اللَّهُ-

(٤) وَضَابِطُ جَرِيَانِ هَذَا الْخِلَافِ: أَنْ يَتَعَدَّدَ الْإِسْتِثْنَاءُ، وَيَكُونُ الْأَوَّلُ مُسْتِغْرَقًا لِلْمُسْتَثْنَى مِنْهُ دُونَ الثَّانِي،

كَقَوْلِهِ: عَشْرَةٌ إِلَّا عَشْرَةٌ إِلَّا أَرْبَعَةٌ.

ثَلَاثًا إِلَّا نِصْفَ طَلْقَةٍ.. فَثَلَاثٌ عَلَى الصَّحِيحِ)، تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْبَاقِي بَعْدَ الْإِسْتِثْنَاءِ، وَقِيلَ: ثِنْتَانِ؛ تَكْمِيلًا لِلنِّصْفِ الْمُسْتَثْنَى.

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ إِنْ لَمْ يَشَأِ اللَّهُ) أَي: طَلَاكَ (وَقَصَدَ التَّغْلِيْقَ.. لَمْ يَقَعْ) أَي: الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْمُغْلَقَ عَلَيْهِ - مِنْ مَشِيئَةِ اللَّهِ أَوْ عَدَمِهَا - غَيْرُ مَعْلُومٍ، وَلِأَنَّ الْوُقُوعَ بِخِلَافِ مَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُحَالٌ، وَقَالَ "صَاحِبُ التَّلْخِيصِ" (١): بِالْوُقُوعِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ رَبَطَ الْوُقُوعَ بِمَا يُضَادُّهُ مِنْ عَدَمِ مَشِيئَةِ اللَّهِ لَهُ، فَهُوَ كَمَا إِذَا قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ طَلَاً لَا يَقَعُ عَلَيْكَ، وَاحْتَرَزَ بِـ"قَصْدِ التَّغْلِيْقِ" عَنْ قَصْدِ التَّبَرُّكِ بِذِكْرِ اللَّهِ.. فَإِنَّهُ يَقَعُ. (وَكَذَا يَمْنَعُ) التَّغْلِيْقُ بِالْمَشِيئَةِ: (انْعِقَادُ تَغْلِيْقٍ) نَحْوُ: أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، (وَعِنْتُ) نَحْوُ: أَنْتَ حُرٌّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، (وَيَمِينُ) نَحْوُ: وَاللَّهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ (وَنَذَرُ) نَحْوُ: لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، (وَكُلُّ تَصَرُّفٍ) غَيْرُ مَا ذَكَرَ كَبَيْعٍ، وَغَيْرِهِ، (وَلَوْ قَالَ: يَا طَالِقُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.. وَقَعَ فِي الْأَصَحِّ؛ نَظَرًا لِصُورَةِ النِّدَاءِ الْمُشْعِرِ بِحُصُولِ الطَّلَاقِ حَالَتَهُ، وَالْحَاصِلُ لَا يُغْلَقُ بِالْمَشِيئَةِ، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ؛ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى بِالنِّدَاءِ: إِثْنَاءُ الطَّلَاقِ، وَهُوَ يَقْبَلُ التَّغْلِيْقَ بِالْمَشِيئَةِ، (أَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ) أَي: الطَّلَاقُ (..فَلَا) يَقَعُ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ اسْتِثْنَاءَ الْمَشِيئَةِ يُوجِبُ حَصْرَ الْوُقُوعِ فِي حَالَةِ عَدَمِ الْمَشِيئَةِ، وَذَلِكَ تَغْلِيْقٌ بِعَدَمِ الْمَشِيئَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِيهِ، وَالثَّانِي: يَقَعُ؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ وَجَعَلَ الْمُخْلِصَ عَنْهُ الْمَشِيئَةَ، وَهِيَ غَيْرُ مَعْلُومَةٍ، فَلَا يَحْصُلُ الْخَلَاصُ.

الشك (٢) في الطلاق

(١) صاحب التلخيص: هو أبو العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري الشافعي، المعروف بابن القاص، المتوفى سنة ٣٣٥ هـ. وكتاب "التلخيص" هذا هو مختصر في فروع الفقه الشافعي، قال عنه حاجي خليفة في كشف الظنون (٤٧٩/١): "وهو: مختصر ذكر في كل باب: مسائل منصوبة، ومخرجة ثم أمور: ذهبت إليها الحنفية. على خلاف قاعدتهم. وهو أجمع كتاب في فنه للأصول والفروع على صغر حجمه، وخفة محمله. وقد شرحه جمع. منهم: أبو عبد الله الاسترابادي المتوفى ٣٨٦ هـ، يعرف بالختن، وأبو بكر القفال الشافعي المتوفى ٣٦٥ هـ، وأبو علي السنجي المتوفى ٤٢٧ هـ، وقيل: ٤٣٠ هـ.

(٢) قال النووي - رحمه الله -: "الشك حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به: التردد بين وجود الشيء وعدمه سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهما. وعند الأصوليين: إن تساوى الاحتمالان فهو شك، وإلا

(فَصْلُ: شَكٌّ فِي طَلَاقٍ مُنْجَزٍ أَوْ مُعَلَّقٍ: أَي: هَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ أَوْ لَا (..فَلَا) يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: بَقَاءُ النِّكَاحِ (أَوْ: فِي عَدَدٍ) كَأَنَّ شَكَّ هَلْ وَقَعَ عَلَيْهِ طَلَقَانِ أَوْ وَاحِدَةً (..فَالْأَقْلُ) يَأْخُذُ بِهِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ، (وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ) فِيمَا ذُكِرَ؛ بِأَنْ يُخْتَاطَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي أَصْلِ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ.. رَاجَعَ؛ لِيَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنَ الْحِلِّ، أَوْ الْبَائِنِ بِدُونِ ثَلَاثٍ (١).. جَدَّدَ النِّكَاحَ، أَوْ بِثَلَاثٍ.. أَمْسَكَ عَنْهَا، وَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا؛ لِتَحِلَّ لِغَيْرِهِ يَقِينًا، وَإِنْ كَانَ الشَّكُّ فِي الْعَدَدِ.. أَخَذَ بِالْأَكْثَرِ، فَإِنْ شَكَّ فِي وَقُوعِ طَلَقَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ.. لَمْ يَنْكِحْهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ ذَا الطَّائِرِ غُرَابًا فَأَنْتَ طَالِقٌ، وَقَالَ آخَرُ: إِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَاِمْرَأَتِي طَالِقٌ، وَجْهَل.. لَمْ يُحْكَمْ بِطَلَاقِ أَحَدٍ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ انْفَرَدَ بِمَا قَالَهُ.. لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوعِ طَلَاقِهِ، فَتَغْلِيْقُ الْآخِرِ لَا يُغَيِّرُ حُكْمَهُ (فَإِنْ قَالَهَا رَجُلٌ لِرُجُوعَتِيهِ.. طَلَّقَتْ إِحْدَاهُمَا)؛ لَوْجُودِ إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ (وَلَزِمَهُ الْبَحْثُ) عَنِ الطَّائِرِ (وَالْبَيَانُ) لِرُجُوعَتِيهِ إِنْ اتَّضَحَ لَهُ؛ لِثَلَاثِ الْمُطَلَّقةِ مِنْ غَيْرِهَا، وَعَلَيْهِ الْامْتِنَاعُ عَنْهُمَا إِلَى أَنْ يَتَبَيَّنَ الْحَالُ، (وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَاهُمَا بِغَيْرِهَا) كَأَنَّ خَاطِبَهَا بِالطَّلَاقِ أَوْ نَوَاهَا عِنْدَ قَوْلِهِ: "إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ"، (ثُمَّ جَهَلَهَا) بِأَنْ نَسِيَهَا (..وَقَفَ) الْأَمْرُ مِنْ قُرْبَانٍ، وَغَيْرِهِ (حَتَّى يَذْكَرَ) الْمُطَلَّقةَ، أَي: يَتَذَكَّرَهَا (وَلَا يُطَالَبُ بِبَيَانِ) لِلْمُطَلَّقةِ (إِنْ صَدَّقْتَاهُ فِي الْجَهْلِ) بِهَا، فَإِنْ كَذَّبْتَاهُ، وَبَادَرَتْ وَاحِدَةً وَقَالَتْ: أَنَا الْمُطَلَّقةُ.. لَمْ يَكْفِهِ فِي الْجَوَابِ "لَا أَذْرِي" بَلْ يَخْلِفُ: أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا، فَإِنْ نَكَلَ (٢).. حَلَفَتْ وَقُضِيَ بِطَلَاقِهَا.

(وَلَوْ قَالَ لَهَا وَلِلْأَجْنَبِيَّةِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ، وَقَالَ: قَصَدْتُ الْأَجْنَبِيَّةَ).. قُبِلَ فِي الْأَصَحِّ بِبَيِّنَةٍ؛ لِإِحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ، وَالثَّانِي: لَا يَقْبَلُ، وَتُطَلَّقُ زَوْجَتُهُ؛ لِأَنَّهَا مَحِلُّ الطَّلَاقِ، فَلَا يَنْصَرِفُ عَنْهَا إِلَى الْأَجْنَبِيَّةِ بِالْقَصْدِ (وَلَوْ قَالَ: زَيْنَبُ طَالِقٌ) وَاسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبُ (وَقَالَ: قَصَدْتُ أَجْنَبِيَّةً) اسْمُهَا زَيْنَبُ يَعْرِفُهَا، (..فَلَا) يَقْبَلُ (عَلَى الصَّحِيحِ)؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ

فالراجح ظن، والمرجوح وهم، وقول الفقهاء موافق للغة، قال ابن فارس وغيره: الشك خلاف اليقين. ينظر: تحرير ألفاظ التنبيه (٣٦/١).

(١) قوله: (أو البائن) يعني: أو كان الشك في الطلاق البائن، وقوله: (بدون الثلاث): يعني- بينونة صغرى- فإنه يجدد النكاح، والبينونة الصغرى: هي التي طُلِّقَتْ قبل الدخول، أو المختلعة، أو الرجعية التي انتهت عدتها دون مراجعة زوجها لها.

(٢) النكول، هو: الامتناع عن اليمين.

(١)، وَيُدَيِّنُ (٢)، وَالشَّانِي: يُقْبَلُ بِمِثْلِهِ؛ لِاحْتِمَالِ اللَّفْظِ لِذَلِكَ، (وَلَوْ قَالَ لِرُجُوعَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَقَصْدٌ مُعَيَّنَةٌ) مِنْهُمَا (.. طَلَّقْتُ، وَالْأ.. فَأَحْدَاهُمَا، وَيَلْزُمُهُ: الْبَيَانُ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، وَالتَّعْيِينُ فِي الثَّانِيَةِ)؛ لَتُعَرَّفَ الْمُطْلَقَةُ مِنْهُمَا، (وَتُعْزَلَانِ عَنْهُ إِلَى الْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ (٣)، وَعَلَيْهِ الْبِدَارُ بِهَمَا) أَي: بِالْبَيَانِ أَوْ التَّعْيِينِ فِي الطَّلَاقِ الْبَائِنِ، وَكَذَا الرَّجْعِيُّ فِي وَجْهِهِ، فَإِنْ أَخَّرَ.. عَصَى، وَإِنْ امْتَنَعَ.. عَزَرَ، وَالْأَصَحُّ فِي الرَّجْعِيِّ: لَا بَدَارَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ زَوْجَةً، (وَنَفَقَتُهُمَا فِي الْحَالِ) إِلَى أَنْ يُبَيَّنَ أَوْ يُعَيَّنَ؛ لِحَبْسِهِمَا عِنْدَهُ حَبْسَ الزَّوْجَاتِ إِلَى ذَلِكَ، وَإِذَا بَيَّنَّ أَوْ عَيَّنَّ.. لَا يَسْتَرِدُّ الْمَضْرُوفَ إِلَى الْمُطْلَقَةِ لِمَا ذُكِرَ.

(وَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِاللَّفْظِ) فِي حَالَتَيِ التَّعْيِينِ وَعَدَمِهِ (٤)، (وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يُعَيَّنْ.. فَعِنْدَ التَّعْيِينِ) (٥)؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَنْزِلُ إِلَّا فِي مَحَلٍّ مُعَيَّنٍ، وَدَفِعَ هَذَا: بِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْهُمَا إِلَى التَّعْيِينِ، كَمَا تَقَدَّمَ، فَلَوْلَا وَقُوعُ الطَّلَاقِ قَبْلَهُ.. لَمْ يُنْمَعْ مِنْهُمَا، (وَالْوُطْءُ) لِإِحْدَاهُمَا (لَيْسَ بَيَانًا) فِي الْحَالَةِ الْأُولَى أَنَّ الْمُطْلَقَةَ: الْأُخْرَى؛ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَطَأَ الْمُطْلَقَةَ (وَلَا تَعْيِينًا) فِي الْحَالَةِ الثَّانِيَةِ لِغَيْرِ الْمُوطُوءَةِ لِلطَّلَاقِ؛ بَلْ يُطَالَبُ بِالْبَيَانِ وَالتَّعْيِينِ، فَإِنْ بَيَّنَّ الْمُطْلَقَةَ بِغَيْرِ الْمُوطُوءَةِ.. قَبْلَ، وَكَذَا بِالْمُوطُوءَةِ؛ لَكِنَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَالْمَهْرُ؛ لِجَهْلِهَا بِأَنَّهَا الْمُطْلَقَةُ، وَلَهُ أَنْ يُعَيَّنَ لِلطَّلَاقِ غَيْرَ الْمُوطُوءَةِ، وَكَذَا الْمُوطُوءَةُ؛ لَكِنَّ عَلَيْهِ الْمَهْرُ؛ بِنَاءً عَلَى وَقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ اللَّفْظِ، (وَقِيلَ): الْوُطْءُ (تَعْيِينٌ).. فَلَا يُنْمَعُ مِنْ وَطْءِ أُيْتِهِمَا شَاءَ، (وَلَوْ قَالَ مُشِيرًا إِلَى وَاحِدَةٍ: هَذِهِ الْمُطْلَقَةُ.. فَبَيَانٌ) لَهَا، أَوْ: هَذِهِ الزَّوْجَةُ.. فَبَيَانٌ أَنَّ غَيْرَهَا الْمُطْلَقَةُ (٦) (أَوْ) قَالَ مُشِيرًا إِلَى كُلِّ مِنْهُمَا: (أَرَدْتُ هَذِهِ وَهَذِهِ، أَوْ: هَذِهِ؛ بَلْ هَذِهِ) أَوْ: هَذِهِ مَعَ هَذِهِ، أَوْ: هَذِهِ هَذِهِ (..حُكِمَ بِطَلَاقِهَا) فِي الظَّاهِرِ؛ لِإِقْرَارِهِ بِمَا قَالَهُ، وَرُجُوعُهُ

(٣) حيث صرح باسم زوجته، فالظاهر: انصرافه إليها؛ بخلاف المسألة التي قبلها؛ فإن قوله: (إحداكما)

يتناولهما تناوولا واحدا، ولم يوجد منه تصريح باسم زوجته، ولا إشارة بالطلاق إليها.

(٤) يعني: يدين فيما بينه وبين الله فيما ادعاه من عدم القصد لزوجه.

(٥) لأن الزوجة اشتهت بالمطلقة، واجتمع الحل والحرمة، فغلب جانب التحريم احتياطا للأبضاع، فامتنع الجمع.

(١) أما في المعينة.. فبلا خلاف، وأما في المهمة.. فوجهان: أحدهما: كذلك. قاله الدميري.

(٢) أي: يقع الطلاق عند التعيين.

(٣) عملا بقول الزوج؛ إذ لا يعلم إلا من جهته، وما لا يعلم إلا من جهة الشخص؛ فالقول قوله فيه.

بِذِكْرِ "بَل" عَنْ الْإِقْرَارِ بِطَّلَاقِ الْأُولَى.. لَا يُقْبَلُ، أَمَّا فِي الْبَاطِنِ.. فَأَلْمُطْلَقَةُ: مَنْ نَوَاهَا فَقَطُّ. قَالَهُ الْإِمَامُ (١) قَالَ: "فَإِنْ نَوَاهُمَا جَمِيعًا.. فَأَلْوَجْهُ أَنَّهُمَا لَا يُطْلَقَانِ؛ إِذْ لَا وَجْهَ لِحَمْلِ "إِحْدَاكُمَا" عَلَيْهِمَا جَمِيعًا (٢) وَلَوْ قَالَ: أَرَدْتُ هَذِهِ، ثُمَّ هَذِهِ، أَوْ هَذِهِ، فَهَذِهِ.. حُكِمَ بِطَّلَاقِ الْأُولَى فَقَطُّ، كَمَا فِي "التَّهْذِيبِ" (٣) وَ"التَّتِمَّةِ"؛ لِفَضْلِ الثَّانِيَةِ بِالتَّرْتِيبِ وَالتَّغْيِيبِ، وَنَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَاضِي حُسَيْنٍ فِي "تَمِّ"، وَاعْتَرَضَهُ: بِتَضَمُّنِ الْكَلَامِ الْإِعْتِرَافَ بِالطَّلَاقِ فِيهِمَا، فَلْيُحْكَمْ بِوُقُوعِهِ فِيهِمَا، كَمَا فِي "الْوَاوِ" وَسَكَتَ عَنْ ذِكْرِ "الْفَاءِ" وَهِيَ كَاتِبَةٌ (٤)، قَالَ الرَّافِعِيُّ: "وَالْحَقُّ: الْإِعْتِرَاضُ" (٥)؛ لَكِنْ رَجَحَ فِي "الرَّوْضَةِ": الْأَوَّلَ (٦)، وَلَوْ قَالَ عِنْدَ الْمُطَالَبَةِ بِالتَّغْيِينِ: هَذِهِ الْمُطْلَقَةُ وَهَذِهِ، أَوْ: بَلْ هَذِهِ، أَوْ: ثُمَّ هَذِهِ.. تَعَيَّنَتْ الْأُولَى، وَلَعَا ذِكْرُ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّ التَّغْيِينَ: إِنْشَاءُ اخْتِيَارٍ؛ لَا إِخْبَارٍ عَنْ سَابِقٍ، وَلَيْسَ لَهُ إِلَّا اخْتِيَارٌ وَاحِدَةٌ، فَيُلْغُو ذِكْرُ اخْتِيَارِهِ غَيْرِهَا، (وَلَوْ مَاتَتْ أَوْ إِحْدَاهُمَا قَبْلَ بَيَانٍ وَتَغْيِينٍ.. بَقِيََتْ مُطَالَبَتُهُ)، أَي: الْمُطَالَبَةُ لِلْمُطْلَقِ بِهِمَا، فَإِذَا بَيَّنَّ أَوْ عَيَّنَّ.. لَمْ يَرِثْ مِنَ الْمُطْلَقَةِ إِنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا، وَإِنْ قِيلَ بِوُقُوعِهِ عِنْدَ التَّغْيِينِ؛ لِسَبْقِ الْإِقْيَاعِ، وَيَرِثُ مِنَ الْأُخْرَى.

(وَلَوْ مَاتَ) قَبْلَ الْبَيَانِ أَوْ التَّغْيِينِ، (..فَالْأُظْهَرُ قَبُولُ بَيَانٍ وَارِثِهِ، لَا) قَبُولُ (تَغْيِينِهِ)؛ لِأَنَّ الْبَيَانَ: إِخْبَارٌ يُمَكِّنُ وَقُوفَ الْوَارِثِ عَلَيْهِ بِخَبَرٍ أَوْ قَرِينَةٍ، وَالتَّغْيِينُ: اخْتِيَارُ شَهْوَةٍ، فَلَا يَخْلُفُهُ الْوَارِثُ فِيهِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ بَيَانُهُ وَتَغْيِينُهُ كَمَا يَخْلُفُهُ فِي حُقُوقِهِ؛ كَالرَّدِّ بِالْغَيْبِ، وَالْأَخْذُ بِالشَّفْعَةِ وَغَيْرِهِمَا، وَالثَّلَاثُ: لَا يُقْبَلُ بَيَانُهُ، وَلَا تَغْيِينُهُ؛ لِأَنَّ حُقُوقَ النِّكَاحِ لَا تُورِثُ (وَلَوْ قَالَ: إِنْ كَانَ) هَذَا الطَّائِرُ، (غُرَابًا فَأَمْرَاتِي طَالِقٌ، وَإِلَّا فَعَبْدِي حُرٌّ، وَجَهْلٌ.. مُنِعَ مِنْهُمَا)؛ لِزَوَالِ مِلْكِهِ عَنْ إِحْدَاهُمَا، فَلَا يَسْتَمْتِعُ بِالزَّوْجَةِ، وَلَا يَسْتَحْدِمُ الْعَبْدَ، وَلَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ (إِلَى الْبَيَانِ)؛ لِتَوَقُّعِهِ، وَعَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا إِلَيْهِ (فَإِنْ مَاتَ.. لَمْ يُقْبَلْ بَيَانُ الْوَارِثِ عَلَى الْمَذْهَبِ)، لِأَنَّهُ يُتَّهَمُ فِي بَيَانِ أَنَّ الطَّائِرَ غُرَابٌ بِمَنْعِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْإِرْثِ، وَإِبْقَاءِ الْعَبْدِ فِي الرِّقِّ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: فِيهِ

(٤) نهاية المطلب (١٤/٢٤٨).

(٥) نهاية المطلب (١٤/٢٥٠).

(٦) التهذيب للبيغوي (٦/١١٠).

(٧) نهاية المطلب (١٤/٢٥٠).

(٨) فتح العزيز (٩/٤٨).

(٩) وهو الحكم بطلاقهما. روضة الطالبين (٨/١٠٦).

قَوْلَا الطَّلَاقِ الْمُبْهَمِ بَيْنَ الرُّوَجَتَيْنِ، (بَلْ يُقْرَعُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ) فَلَعَلَّ الْقُرْعَةَ تَخْرُجُ عَلَى الْعَبْدِ، فَإِنَّهَا مُؤَثِّرَةٌ فِي الْعِتْقِ دُونَ الطَّلَاقِ (فَإِنْ قُرِعَ) أَي: خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهِ (..عُتِقَ)، بِأَنْ كَانَ التَّغْلِيْقُ فِي الصِّحَّةِ، أَوْ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ، وَخَرَجَ مِنَ الثُّلُثِ، .. وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ؛ إِلَّا إِذَا ادَّعَتْ أَنَّهَا طُلِّقَتْ بِالتَّعْيِينِ، وَكَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا (أَوْ: قُرِعَتْ) أَي: خَرَجَتْ الْقُرْعَةُ عَلَيْهَا (..لَمْ تُطْلَقْ) إِذْ لَا أَثَرَ لِلْقُرْعَةِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْوَرَعُ: أَنْ تَتْرَكَ الْمِيرَاثَ، (وَالْأَصْحَحُ: أَنَّهُ لَا يَرِقُ) (١) أَي: لَا يَرْجِعُ إِلَى تَمَحُّضِ الرِّقِّ؛ بَلْ يَبْقَى عَلَى حَالِهِ مِنْ تَغْلِيْقِ عِتْقِهِ، وَيَسْتَمِرُّ الْإِشْكَالُ بِحَالِهِ، وَالثَّانِي: يَرِقُ، فَيَتَصَرَّفُ فِيهِ الْوَارِثُ كَيْفَ يَشَاءُ، وَيَزُولُ الْإِشْكَالُ، وَوَجْهُهُ: أَنَّ الْقُرْعَةَ تُؤَثِّرُ فِي الرِّقِّ كَالْعِتْقِ، فَكَمَا يُعْتَقُ إِذَا خَرَجَتْ عَلَيْهِ.. يَرِقُ إِذَا خَرَجَتْ عَلَى عَدِيلِهِ، وَدُفِعَ: بِأَنَّهَا لَمْ تُؤَثِّرْ فِي عَدِيلِهِ فَلَا تُؤَثِّرُ فِيهِ.

الطلاق السني والبدعي (٢)

(فِصْلُ: الطَّلَاقُ سُنِّيٌّ وَبِدْعِيٌّ، وَيَحْرُمُ الْبِدْعِيُّ، وَهُوَ ضَرْبَانِ، أَحَدُهُمَا: (طَّلَاقٌ فِي حَيْضٍ مَمْسُوسَةٍ) أَي: مَوْطُوءَةٍ، وَحُرْمَةُ هَذَا؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١] أَي: فِي الْوَقْتِ الَّذِي يَشْرَعْنَ فِيهِ فِي الْعِدَّةِ، وَبَقِيَّةُ الْحَيْضِ لَا تُحْسَبُ مِنَ الْعِدَّةِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ: تَضَرُّرُهَا بِطُولِ مَدَّةِ التَّرَبُّصِ، (وَقِيلَ: إِنْ سَأَلْتَهُ) أَي: سَأَلْتَ الطَّلَاقَ فِي الْحَيْضِ (..لَمْ يَحْرَمْ)؛ لِإِضَاهَا بِطُولِ الْمُدَّةِ، (وَيَجُوزُ خُلُوعُهَا فِيهِ)؛ لِحَاجَتِهَا إِلَى الْخَلَاصِ بِالْمُفَارَقَةِ، حَيْثُ افْتَدَتْ بِالْمَالِ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩] (لَا أَجْنَبِي) أَي: لَا يَجُوزُ خُلُوعُهَا فِي الْحَيْضِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْلَمْ فِيهِ وَجُودَ حَاجَتِهَا إِلَى الْخَلَاصِ بِالْمُفَارَقَةِ، وَالثَّانِي: يَجُوزُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْأَجْنَبِيَّ إِنَّمَا

(٢) قال الدميمري: وقوله: (يرق) ضبطه المصنف - بفتح أوله، وكسر ثانيه -، وهو الصواب.

(١) اتفق العلماء على أن الطلاق ينقسم إلى سني وبدعي: لأنه يقع تارة حلالا، وتارة حراما، ولهم في تفسير

السني والبدعي اصطلاحان:

الأول: أن السني: ما لا يحرم إيقاعه، والبدعي: ما يحرم، وعلى هذا فلا قسم سواهما.

والثاني: وهو المشهور: أن السني: طلاق مدخول بها ليست بحامل ولا صغيرة، ولا أيسة.

والبدعي: طلاق المدخول بها في حال حيض أو نفاس، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حملها، وعلى هذا يخرج عن

القسمين قسم ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، مثل: طلاق غير المدخول بها، وطلاق الحامل، والصغيرة،

والأيسة، فيكون الطلاق ثلاثة أقسام.

يَبْذُلُ الْمَالَ لِحَاجَتِهَا إِلَى الْخَلَاصِ، وَيَحْرُمُ الطَّلَاقُ فِي النِّفَاسِ كَالْحَيْضِ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْمُحَرِّمَ (١) شَامِلٌ لَهُ، (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ مَعَ آخِرِ حَيْضِكَ.. فَسُئِلَ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِاسْتِقْبَالِهِ الشَّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ: الطُّهْرُ الْمُخْتَوِشُ بِدَمِينٍ، وَهُوَ الْأَظْهَرُ، كَمَا سَيَأْتِي فِي "الْعِدَّةِ"، وَالثَّانِي: بِدَعْيٍ؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقُرْءَ: الْإِنْتِقَالُ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضِ، فَلَا يَسْتَعْقِبُ الشَّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ (أَوْ: مَعَ آخِرِ طُهُرٍ) عَيْنَهُ (لَمْ يَطَّأَهَا فِيهِ.. فَبَدَعِيَ عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ الشَّرُوعَ فِي الْعِدَّةِ بِنَاءً عَلَى الرَّاجِحِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْءِ، وَقِيلَ: سُئِلَ؛ بِنَاءً عَلَى مُقَابِلِهِ. فَأَلْمَزَادُ بِالْمَذْهَبِ هُنَا، الْمَعْبَرُ بِهِ فِي "الرَّوَضَةِ" (٢) أَيْضًا: الرَّاجِحُ.

(و) الضَّرْبُ الثَّانِي (٣): (طَلَّاقٌ فِي طُهُرٍ وَطِئَ فِيهِ مَنْ قَدْ تَحَبَّلَ) بِأَنَّ لَا تَكُونُ صَغِيرَةً وَلَا آيِسَةً، (وَلَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ) وَحُرْمَةٌ هَذَا؛ لِأَدَائِهِ إِلَى النَّدَمِ عِنْدَ ظُهُورِ الْحَمْلِ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُطَلِّقُ الْحَائِلَ دُونَ الْحَامِلِ، وَعِنْدَ النَّدَمِ قَدْ لَا يُمَكِّنُ التَّذَارُكُ، فَيَتَضَرَّرُ الْوَلَدُ، (فَلَوْ وَطِئَ حَائِضًا، وَطَهَّرَتْ، فَطَلَّقَهَا) (٤).. فَبَدَعِيَ (فِي الْأَصَحِّ)، فَيَحْرُمُ؛ لِاحْتِمَالِ الْغُلُوقِ الْمُؤَدِّي إِلَى النَّدَمِ، كَمَا تَقَدَّمَ، وَالثَّانِي: لَيْسَ بِبَدَعِيٍّ، فَلَا يَحْرُمُ؛ لِإِشْعَارِ بَقِيَّةِ الْحَيْضِ بِبَرَاءَةِ الرَّجْمِ، وَدَفْعِ: بِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ الْبَقِيَّةُ مِمَّا دَفَعَتْهُ الطَّبِيعَةُ أَوَّلًا، وَهَيَّأَتْهُ لِلْخُرُوجِ، (وَيَجِلُّ خُلْعُهَا) أَي: الْمَوْطُوءَةُ فِي الطُّهْرِ، (وَطَلَّاقٌ مَنْ ظَهَرَ حَمْلُهَا)؛ لِأَنَّ أَخَذَ الْعَوْضِ، وَظُهُورِ الْحَمْلِ (٥) يُبْعَدُ احْتِمَالُ النَّدَمِ، وَلَوْ كَانَتْ الْحَامِلُ تَرَى الدَّمَ، وَقُلْنَا: هُوَ حَيْضٌ لَمْ يَحْرُمِ الطَّلَاقُ فِيهِ؛ لِأَنَّ عِدَّتَهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ.

(تَنْبِيْهٌ): سَكُوتُ الْمُصَنِّفِ عَنْ بَيَانِ مَعْنَى السُّنِّيِّ وَحُكْمِهِ، يُشْعِرُ بِأَنَّهُ: مَا عَدَا الْبَدْعِيَّ، وَأَنَّهُ جَائِزٌ، وَذَلِكَ مَا شِى عَلَى أَحَدِ الْإِصْطِلَاحِيْنَ: أَنَّ السُّنِّيَّ الْجَائِزَ، وَالْبَدْعِيَّ الْحَرَامَ، وَالْإِصْطِلَاحُ الثَّانِي - الْمَشْهُورُ - : أَنَّ السُّنِّيَّ بَعْضُ الْجَائِزِ، كَطَلَّاقِ مَمْسُوسَةٍ فِي طُهُرٍ لَمْ

(٢) وهو: تَضَرُّرُهَا بِطُولِ مَدَّةِ التَّرِيصِ.

(٣) روضة الطالبين (٥/٨).

(٤) يعني: من الطلاق البدعي.

(١) تعبير المصنف بـ (الفاء) يشير إلى أن صورة المسألة: أن يطلقها قبل أن يمسه.

(٢) يعني: أخذ العوض في الخلع. وظهور الحمل في طلاق من ظهر حملها يبعد احتمال الندم.

يَطَّأَهَا فِيهِ، وَلَيْسَتْ بِحَامِلٍ، وَأَنْ طَلَّقَ الْحَامِلُ، وَالْأَيَّاسَةُ، وَالصَّغِيرَةُ، وَغَيْرُ الْمَمْسُوسَةِ، لَيْسَ بِسُنِّيٍّ، وَلَا بِدُعِيٍّ، وَهُوَ جَائِزٌ، وَالْأَمْرُ فِي ذَلِكَ يَسِيرٌ، وَالْأَوَّلُ لِانْضِبَاطِهِ أَوْلَى.

(وَمَنْ طَلَّقَ بِدُعِيًّا.. سُنَّ لَهُ الرَّجْعَةُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ طَهْرٍ؛ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: مَرَّةٌ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطْلِقْهَا طَاهِرًا^(١) أي: قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا إِنْ أَرَادَ، كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي بَعْضِ رَوَايَاتِهِمَا، وَيُقَاسُ غَيْرُ هَذِهِ الصُّورَةِ مِنَ الْبِدْعِيِّ عَلَيْهَا، (وَلَوْ قَالَ لِحَائِضٍ) مَمْسُوسَةٍ أَوْ لِنَفْسَاءَ: (أَنْتَ طَالِقٌ لِلْبِدْعَةِ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ^(٢))، أَوْ لِلْسُنَّةِ^(٣).. فَحِينَ تَطْهَرُ، وَلَا يَتَوَقَّفُ الْوُقُوعُ عَلَى الْإِغْتِسَالِ (أَوْ) قَالَ (لِمَنْ فِي طَهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ) وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا: (أَنْتَ طَالِقٌ لِلْسُنَّةِ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَإِنْ مُسَّتْ فِيهِ.. فَحِينَ تَطْهَرُ بَعْدَ حَيْضٍ، أَوْ) قَالَ لِمَنْ طَهَّرَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ، (لِلْبِدْعَةِ فِي الْحَالِ).. يَقَعُ (إِنْ مُسَّتْ فِيهِ، وَإِلَّا) أَي: وَإِنْ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ وَهِيَ مَدْخُولٌ بِهَا (..فَحِينَ تَحِيضُ) أَي: تَرَى دَمَ الْحَيْضِ، فَإِنْ انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَلَمْ يَعُدْ.. تَبَيَّنَ أَنَّ الطَّلَاقَ لَمْ يَقَعْ، وَهَذَا -كَمَا رَأَيْتَ- خِطَابٌ لِمَنْ يَكُونُ طَلَّاقُهَا سُنِّيًّا أَوْ بِدْعِيًّا، فَلَوْ قَالَ لِمَنْ لَا يَتَّصِفُ طَلَّاقُهَا بِذَلِكَ، كَغَيْرِ الْمَمْسُوسَةِ، وَالصَّغِيرَةِ، وَغَيْرِهِمَا: أَنْتَ طَالِقٌ لِلْسُنَّةِ أَوْ الْبِدْعَةِ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ مُطْلَقًا، وَيَلْغُو ذِكْرُ السُّنَّةِ وَالْبِدْعَةِ، (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ طَلِّقَةً حَسَنَةً، أَوْ أَحْسَنَ الطَّلَاقِ، أَوْ أَجْمَلُهُ.. فَكَالسُّنَّةِ) فَإِنْ كَانَتْ فِي حَيْضٍ.. لَمْ يَقَعْ حَتَّى تَطْهَرَ، أَوْ فِي طَهْرٍ لَمْ تُمَسَّ فِيهِ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ، أَوْ مُسَّتْ فِيهِ.. وَقَعَ حِينَ تَطْهَرُ بَعْدَ حَيْضٍ، (و^(٤)) طَلِّقَةً قَبِيحَةً، أَوْ أَقْبَحَ الطَّلَاقِ، أَوْ أَفْحَشَهُ.. فَكَالْبِدْعَةِ) فَإِنْ كَانَتْ فِي حَيْضٍ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ، وَكَذَا فِي طَهْرٍ مُسَّتْ فِيهِ، وَإِلَّا.. فَحِينَ تَحِيضُ، وَلَوْ خَاطَبَ بِهِذِهِ الْأَلْفَافِ مَنْ لَيْسَ طَلَّاقُهَا سُنِّيًّا وَلَا بِدْعِيًّا؛ كَالْحَامِلِ، وَالْأَيَّاسَةِ، وَغَيْرِهِمَا.. وَقَعَ فِي

(٣) أخرجه مسلم في كتاب الطلاق، باب: طلق طلاق، (٣٦٥٠).

(٤) لاتصال طلاقها بالبدعة.

(٥) يعني: قال لها: أنت طالق للسنة.

(١) يعني: وقال لزوجته: أنت طالق طليقة قبيحة، أو أقبح الطلاق... فحكمه حكم البدعة.

الْحَالِ مُطْلَقًا، كَمَا لَوْ قَالَ: لِلْسُنَّةِ أَوْ لِلْبِدْعَةِ (أَوْ) (١): سُنِّيَّةٌ بِدْعِيَّةٌ، أَوْ حَسَنَةٌ قَبِيحَةٌ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ)، وَيَلْعُو ذِكْرُ الصِّفَتَيْنِ؛ لِتَضَادِهِمَا.

(وَلَا يَحْرُمُ جَمْعُ الطَّلَاقَاتِ) أَي: أَنْ يُطْلَقَ ثَلَاثًا دَفْعَةً؛ لِإِنْتِفَاءِ الْمُحَرِّمِ لَهُ، وَالْأَوَّلَى لَهُ تَرْكُهُ، بِأَنْ يُفَرِّقَهُنَّ عَلَى الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهَرِ؛ لِيَتِمَّكَنَ مِنَ الرَّجْعَةِ أَوْ التَّجْدِيدِ إِنْ نَدِمَ (وَلَوْ قَالَ) لِمَمْسُوسَةٍ (.. أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، أَوْ ثَلَاثًا لِلْسُنَّةِ، وَفَسَّرَ بِتَفْرِيقِهِمَا عَلَى أَقْرَاءٍ) أَي: قَالَ: إِنَّهُ نَوَى فِي كُلِّ قَرَأٍ طَلَقَةً (.. لَمْ يُقْبَلْ) فِي الظَّاهِرِ؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِمُقْتَضَى اللَّفْظِ مِنْ وَقُوعِ الثَّلَاثِ دَفْعَةً فِي الْحَالِ فِي الْأَوَّلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ إِنْ كَانَتْ الْمَرْأَةُ طَاهِرًا، وَحِينَ تَطْهَرُ إِنْ كَانَتْ حَائِضًا، وَلَا سُنَّةٌ فِي التَّفْرِيقِ، (إِلَّا مِمَّنْ يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَ الْجَمْعِ) لِلثَّلَاثِ دَفْعَةً كَالْمَالِكِيِّ.. فَيُقْبَلُ؛ (لِمُوَافَقَةِ تَفْسِيرِهِ لِإِعْتِقَادِهِ، وَالْأَصَحُّ) عَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ.. (أَنَّهُ يُدَيِّنُ) فِيمَا نَوَاهُ، فَيَعْمَلُ بِهِ فِي الْبَاطِنِ إِنْ كَانَ صَادِقًا، بِأَنْ يُرَاجِعَهَا وَيَطْلُبَهَا، وَلَهَا تَمْكِينُهُ إِنْ ظَنَّتْ صَدَقَهُ بِقَرِينَةٍ، وَإِلَّا.. فَلَا، وَفِي ذَلِكَ قَالَ الشَّافِعِيُّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-: لَهُ الطَّلَبُ، وَعَلَيْهَا الْهَرَبُ (٢)، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُدَيِّنُ؛ لِأَنَّ اللَّفْظَ لَا يَحْتَمِلُ الْمُرَادَ، وَالنِّيَّةُ إِنَّمَا تَعْمَلُ فِيمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ، (وَيُذَيِّنُ مَنْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ وَقَالَ: أَرَدْتُ إِنْ دَخَلْتُ الدَّارَ (أَوْ إِنْ شَاءَ زَيْدٌ)؛ بِخِلَافٍ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ؛ لِأَنَّهُ يَرْفَعُ حُكْمَ الطَّلَاقِ وَمَا قَبْلَهُ يُخَصِّصُهُ بِحَالٍ دُونَ حَالٍ، (وَلَوْ قَالَ: نِسَائِي طَوَالِقٌ، أَوْ كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ بَعْضَهُنَّ) كـ "فُلَانَةٌ وَفُلَانَةٌ" دُونَ "فُلَانَةٍ" (.. فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ ظَاهِرًا)؛ لِمُخَالَفَتِهِ لِعُيُومِ اللَّفْظِ الْمَحْضُورِ أَفْرَادُهُ الْقَلِيلَةُ، (إِلَّا لِقَرِينَةٍ؛ بِأَنْ خَاصَمْتَهُ) زَوْجَتُهُ (وَقَالَتْ) لَهُ: (تَزَوَّجْتَ) عَلَيَّ؟ (فَقَالَ) مُنْكَرًا لِذَلِكَ: (كُلُّ امْرَأَةٍ لِي طَالِقٌ، وَقَالَ: أَرَدْتُ غَيْرَ الْمُخَاصِمَةِ).. فَيُقْبَلُ فِي ذَلِكَ؛ رِعَايَةً لِلْقَرِينَةِ، وَالثَّانِي: يُقْبَلُ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ الْعَامِّ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهِ شَائِعٌ، وَالثَّلَاثُ: لَا يُقْبَلُ مُطْلَقًا، وَالْقَرِينَةُ الْحَالِيَةُ

(٢) يعني: أوقال لزوجته: أنت طالق طلقة سنية بدعية، أو حسنة قبيحة.. وقع في الحال.

(٣) فيقال للمرأة: أنت بائن للثلاث في الظاهر، وليس لك مطاوعته، وتحرم عليك الخلوة به، ولك أن تطلبي من الحاكم أن يحكم عليه بالفرقة وتزوجي: إلا إذا غلب على ظنك صدقه بقريته. فإن استوى عندها الأمران.. كره لها تمكينه، ويقال له: لا نمكنك منها، ولك ذلك فيما بينك وبين الله إن كنت صادقا، فإن ادعى عليها تصديقه.. ففي تحليفه وجهان. أفاده الدميري.

لَا تَصْرِفُ مِثْلَ هَذَا الْعَامِّ عَنْ عُمُومِهِ، وَإِنَّمَا تَصْرِفُهُ اللَّفْظِيَّةُ، كَالِاسْتِثْنَاءِ، وَعَلَى عَدَمِ الْقَبُولِ يُدَيَّنُ.

تعليق الطلاق

فَصْلٌ (قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ فِي شَهْرٍ كَذَا، أَوْ فِي غُرَّتِهِ، أَوْ أَوَّلِهِ)، أَوْ رَأْسِهِ، (..وَقَعَ) الطَّلَاقُ (بِأَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ)، وَهُوَ أَوَّلُ جُزْءٍ مِنَ اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْهُ، وَوَجْهٌ "فِي شَهْرٍ كَذَا" بِأَنَّ الْمَعْنَى: إِذَا جَاءَ شَهْرٌ كَذَا، وَمَجِيئُهُ يَتَحَقَّقُ بِمَجِيئِ أَوَّلِ جُزْءٍ مِنْهُ، (أَوْ: فِي نَهَارِهِ، أَوْ أَوَّلِ يَوْمٍ مِنْهُ.. فَيَفْجَرُ أَوَّلَ يَوْمٍ) مِنْهُ؛ عَلَى قِيَاسِ مَا تَقَدَّمَ (أَوْ: آخِرَهُ.. فَيَاخِرُ جُزْءٍ مِنَ الشَّهْرِ، وَقِيلَ: بِأَوَّلِ النِّصْفِ الْآخِرِ) (١) إِذْ كُلُّهُ آخِرُ الشَّهْرِ.. فَيَقَعُ بِأَوَّلِهِ، وَرَدَّ: بِسَبْقِ الْأَوَّلِ إِلَى الْفَهْمِ.

(وَلَوْ قَالَ لَيْلًا: إِذَا مَضَى يَوْمٌ) فَأَنْتَ طَالِقٌ، (..فَيَغْرُوبُ شَمْسُ عَدِهِ) تُطْلَقُ، (أَوْ نَهَارًا) (٢).. فَبِئْسَ مِثْلُ وَقْتِهِ مِنْ عَدِهِ) تُطْلَقُ (أَوْ: الْيَوْمُ) أَي: قَالَ: إِذَا مَضَى الْيَوْمُ فَأَنْتَ طَالِقٌ (فَإِنْ قَالَهُ نَهَارًا.. فَيَغْرُوبُ شَمْسُهُ) تُطْلَقُ، (وَالْأَيُّ) أَي: وَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ نَهَارًا، بِأَنَّ قَالَهُ لَيْلًا (..لَعَا) أَي: لَا يَقَعُ شَيْءٌ (وَبِهِ) أَي: بِمَا ذَكَرَ، (يُقَاسُ شَهْرٌ وَسَنَةٌ) وَالشَّهْرُ وَالسَّنَةُ، فَإِذَا قَالَ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا: إِذَا مَضَى شَهْرٌ فَأَنْتَ طَالِقٌ.. طُلِّقْتَ بِمَضِيِّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَمِنْ لَيْلَةِ الْحَادِي وَالثَّلَاثِينَ أَوْ يَوْمِهِ يُقَدَّرُ مَا سَبَقَ التَّعْلِيلُ مِنْ لَيْلَتِهِ أَوْ يَوْمِهِ. وَإِذَا قَالَ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ: إِذَا مَضَتْ سَنَةٌ فَأَنْتَ طَالِقٌ.. طُلِّقْتَ بِمَضِيِّ أَحَدِ عَشَرَ شَهْرًا بِالْأَهْلَةِ، مَعَ إِكْمَالِ الْأَوَّلِ مِنَ الثَّلَاثِ عَشَرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا، وَإِذَا قَالَ: إِذَا مَضَى الشَّهْرُ، أَوْ قَالَ: السَّنَةُ فَأَنْتَ طَالِقٌ.. طُلِّقْتَ بِمَضِيِّ بَقِيَّةِ ذَلِكَ الشَّهْرِ، أَوْ تِلْكَ السَّنَةِ، (أَوْ) قَالَ: (أَنْتَ طَالِقٌ أَمْسٍ، وَقَصْدُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَالِ مُسْتَبْدًا إِلَيْهِ.. وَقَعَ فِي الْحَالِ) وَلَعَا قَصْدُهُ الْإِسْتِنَادُ إِلَى أَمْسٍ؛ لِاسْتِحَالَتِهِ، (وَقِيلَ: لَعُو) أَي: لَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ؛ لِقَصْدِهِ بِهِ مُسْتَحِيلًا (أَوْ قَصْدُ أَنَّهُ طُلِّقَ أَمْسٍ وَهِيَ الْآنَ مُعْتَدَّةٌ.. صَدَقَ بِبَيْمِنِهِ) فِي ذَلِكَ، وَتَكُونُ عِدَّتُهَا مِنْ أَمْسٍ الْمَذْكُورِ إِنْ صَدَقْتُهُ، وَمِنْ وَقْتِ الْإِقْرَارِ إِنْ كَذَّبْتُهُ.

(أَوْ قَالَ: طُلِّقْتَ فِي نِكَاحٍ آخَرَ) أَي: غَيْرَ هَذَا النِّكَاحِ (فَإِنْ غُرِفَ) الطَّلَاقُ الْمَذْكُورُ بِنِكَاحِهِ، (..صَدَقَ بِبَيْمِنِهِ) فِي إِزَادَتِهِ (وَالْأَيُّ.. فَلَا) يُصَدَّقُ، وَيُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ،

(١) يعني: أول جزء من ليلة السادس عشر.

(٢) يعني: قال نهارًا: إذا مضى يوم فأنت طالق.

كَمَا قَالَهُ فِي "الشَّرْحِ الصَّغِيرِ"، وَنَقَلَ فِيهِ عَنِ الْإِمَامِ: أَنَّهُ يَنْبَغِي (١) أَنْ يُقْبَلَ فِيمَا قَالَهُ؛ لِاحْتِمَالِهِ، وَاقْتَصَرَ فِي "الْكَبِيرِ" (٢) عَلَى بَحْثِ الْإِمَامِ، مِنْ غَيْرِ عَزْوٍ إِلَيْهِ، وَتَبِعَهُ فِي "الرَّوْضَةِ" (٣)، وَالْأَوَّلُ: نَقْلُهُ الْإِمَامَ (٤) وَالْبَغْوِيُّ (٥) عَنْ الْأَصْحَابِ.

(وَأَدَوَاتُ التَّغْلِيْقِ: "مَنْ"، كَمَنْ دَخَلَتْ) فِي الدَّارِ مِنْ زَوْجَاتِي.. فَهِيَ طَالِقٌ، (وَ"إِنْ"، وَ"إِذَا"، وَ"مَتَى"، وَ"مَتَى مَا"، وَ"كُلَّمَا") نَحْوُ: إِنْ دَخَلْتَ الدَّارَ، وَإِذَا، أَوْ مَتَى، أَوْ مَتَى مَا، أَوْ كُلَّمَا دَخَلْتَهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ (وَ"أَي"؛ كَأَيِّ وَقْتٍ دَخَلْتَ) الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، (٦) (وَلَا يَقْتَضِيْنَ فَوْرًا) فِي الْمُعْلَقِ عَلَيْهِ (إِنْ عُلِقَ بِإِثْبَاتٍ) أَي: بِمُثَبِّتٍ؛ كَالدُّخُولِ فِيمَا ذَكَرَ (٧) (فِي غَيْرِ خُلْعٍ) أَمَّا فِيهِ، فَيُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي بَعْضِهَا؛ لِلْمَعَاوِضَةِ، نَحْوُ: إِنْ ضَمِنْتَ، أَوْ: إِذَا أُعْطِيتَ كَمَا تَقَدَّمَ، (إِلَّا: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ).. فَإِنَّهُ يَقْتَضِي الْفَوْرَ فِي الْمَشِيئَةِ؛ لِتَضَمُّنِهِ تَمْلِيكَ الطَّلَاقِ، كَطَّلَقِي نَفْسَكَ (وَلَا تَكَرَّرَا؛ إِلَّا كُلَّمَا) فَإِنَّهَا تَقْتَضِيهِ (٨) وَسَيَأْتِي التَّغْلِيْقُ بِالنَّفْيِ (وَلَوْ قَالَ: إِذَا طَلَقْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ عُلِقَ بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ.. فَطَلَقْتَانِ) وَاحِدَةً بِالتَّطْلِيْقِ بِالتَّنْجِيزِ أَوْ التَّغْلِيْقِ بِصِفَةٍ وَجِدَتْ، وَأُخْرَى بِالتَّغْلِيْقِ بِهِ، (أَوْ) قَالَ: (كُلَّمَا وَقَعَ طَلَاقِي) عَلَيْكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَطَلَّقَ.. فَثَلَاثٌ فِي مَمْسُوسَةٍ) وَاحِدَةً بِالتَّنْجِيزِ، وَثِنْتَانِ بِالتَّغْلِيْقِ بِ"كُلَّمَا"، وَاحِدَةً بِوُقُوعِ

(١) كلمة (ينبغي): الأغلب فيها استعمالها في المندوب تارة، والوجوب تارة أخرى، وتحمل على أحدهما بالقرينة، وقد تستعمل للجواز والترجيح. الفتح المبين، ص ١٦٩، ١٧٠.

(٢) يعني: الشرح الكبير، المعروف بفتح العزيز (٦٦/٩).

(٣) أي: الإمام النووي تبع الرافعي في بحث إمام الحرمين من غير عزو إليه. ينظر: روضة الطالبين (٨/١٢٠)، (١٢١).

(٤) في نهاية المطلب (١١٥/١٤، ١١٦).

(٥) في التهذيب (٤٨/٦).

(٦) ظاهر كلام المصنف حصر أدوات التعليق في السبعة المذكورة، كما صرح به ابن الرفعة وغيره، وليس كذلك؛ فإن من الأدوات (إذ ما) على مذهب سيبويه، و(ما) الشرطية، و(مهما)، و(أيان)، و(إذ ما)، و(أيا ما) كقوله تعالى، و(أين)، و(حيثما)؛ لتعميم الأمكنة. أفاده الديميري.

(٧) يعني: إن قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، فتعليقه طلاقها بدخول الدار، لا يقتضي وقوعه على الفور؛ لأن القصد: التعليق به متى وجد، من غير دلالة على فورية، ولا تراخ.

(٨) يعني: تعليق الطلاق بأحد صيغه، لا يقتضي تكراراً؛ إلا صيغة (كلما)، فإنها تقتضي التكرار من بين هذه الصيغ المذكورة.

الْمُنْجَزَةِ، وَأُخْرَى بِوُقُوعِ هَذِهِ الْوَاحِدَةِ (وَفِي غَيْرِهَا) أَي: غَيْرِ الْمَمْسُوسَةِ (.. طَلْقَةً)؛ لِأَنَّهَا تَبِينُ بِالْمُنْجَزَةِ، فَلَا يَقَعُ الْمُعْلَقُ بَعْدَهَا.

(وَلَوْ قَالَ وَتَحْتَهُ أَرْبَعٌ) وَلَهُ عَيْدٌ: (إِنْ طَلَّقْتُ وَاحِدَةً فَعَيْدٌ حُرٌّ، وَإِنْ) طَلَّقْتُ (ثَنَيْنِ) (عَبْدَانِ) حُرَّانِ، (وَإِنْ) طَلَّقْتُ (ثَلَاثًا فَثَلَاثَةٌ) مِنْ عِبِيدِي أَحْرَارٌ، (وَإِنْ) طَلَّقْتُ (أَرْبَعًا فَأَرْبَعَةٌ) مِنْ عِبِيدِي أَحْرَارٌ (فَطَلَّقَ أَرْبَعًا مَعًا، أَوْ مَرْتَبًا.. عُتِقَ عَشْرَةٌ) مِنْ عِبِيدِهِ؛ وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى، وَاثْنَانِ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ، وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ، وَأَرْبَعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ، وَمَجْمُوعُ ذَلِكَ عَشْرَةٌ. (وَلَوْ عَلَّقَ بِـ"كُلَّمَا" .. فَخَمْسَةَ عَشَرَ) عَبْدًا (عَلَى الصَّحِيحِ) وَاحِدٌ بِطَلَاقِ الْأُولَى، وَثَلَاثَةٌ بِطَلَاقِ الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقٌ وَاحِدَةً، وَطَلَاقُ ثَنَيْنِ وَأَرْبَعَةٍ بِطَلَاقِ الثَّالِثَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقٌ وَاحِدَةً وَطَلَاقُ ثَلَاثِ، وَسَبْعَةٌ بِطَلَاقِ الرَّابِعَةِ؛ لِأَنَّهُ صَدَقَ بِهِ طَلَاقٌ وَاحِدَةً وَطَلَاقُ اثْنَتَيْنِ غَيْرِ الْأُولَيَيْنِ وَطَلَاقُ أَرْبَعٍ، وَالْوَجْهُ الثَّانِي: يُعْتَقُ سَبْعَةُ عَشَرَ ؛ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الثَّنَيْنِ فِي طَلَاقِ الثَّالِثَةِ، وَالثَّالِثِ: يُعْتَقُ عَشْرُونَ؛ بِاعْتِبَارِ صِفَةِ الثَّلَاثِ أَيْضًا فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ، وَالرَّابِعِ: يُعْتَقُ ثَلَاثَةَ عَشَرَ؛ بِإِسْقَاطِ صِفَةِ الثَّنَيْنِ فِي طَلَاقِ الرَّابِعَةِ. (وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِنَفْيِ فِعْلٍ.. فَأَلْمَذَهَبُ: أَنَّهُ إِنْ عَلَّقَ بِـ"إِنْ"؛ كَمَا لَمْ تَدْخُلِي) أَي: الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ (.. وَقَعَ عِنْدَ الْيَأْسِ مِنَ الدُّخُولِ) كَأَنْ مَاتَتْ قَبْلَهُ، فَيَحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ قُبَيْلَ الْمَوْتِ (أَوْ بِغَيْرِهَا) كـ"إِذَا" (.. فَعِنْدَ مُضِيِّ زَمَنِ يُمَكِّنُ فِيهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ) مِنْ وَقْتِ التَّغْلِيْقِ وَلَمْ تَفْعَلِ.. يَقَعُ الطَّلَاقُ، هَذَا هُوَ الْمَنْصُوصُ فِي صَوْرَتِي: "إِنْ"، وَ"إِذَا"، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا: أَنَّ "إِنْ" حَرْفُ شَرْطٍ لَا إِشْعَارَ لَهُ بِالزَّمَانِ، وَ"إِذَا" ظَرْفُ زَمَانٍ كـ"مَتَى" فِي التَّنَاقُلِ لِلْأَوْقَاتِ؛ فَإِذَا قِيلَ: مَتَى أَلْفَاكَ.. صَحَّ أَنْ تَقُولَ: مَتَى سِئْتُ، أَوْ إِذَا سِئْتُ، وَلَا يَصِحُّ: إِنْ سِئْتُ.

فَقَوْلُهُ: إِنْ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ مَعْنَاهُ: إِنْ فَاتَكَ دُخُولُهَا، وَفَوَاتُهُ بِالْمَوْتِ، وَقَوْلُهُ: إِذَا لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ مَعْنَاهُ: أَيُّ وَقْتٍ فَاتَكَ الدُّخُولُ.. فَيَقَعُ الطَّلَاقُ بِمُضِيِّ زَمَنِ يُمَكِّنُ فِيهِ الدُّخُولَ، وَلَمْ يُؤْتِ بِهِ، وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: فِي كُلِّ مِنَ الصَّوْرَتَيْنِ: قَوْلَانِ، بِتَخْرِيجِ (١) قَوْلِ

(١) صورة التخريج عند الشافعية: أن يجيب الإمام الشافعي - رحمه الله - بحكمين مختلفين في صورتين

متشابهتين. ولم يظهر ما يصلح للفرق بينهما، فينقل الأصحاب جوابه في كل صورة إلى الأخرى،

فيحصل في كل صورة منهما قولان: منصوص، ومخرَج، المنصوص في هذه هو المخرَج في تلك،

والمنصوص في تلك هو المخرَج في هذه، فيقال: فهما قولان بالنقل والتخريج. والغالب في مثل هذا:

مِنْ كُلِّ مِنْهُمَا إِلَى الْآخَرَى. أَحَدُهُمَا: أَنَّ الطَّلَاقَ إِنَّمَا يَقَعُ فِيهِمَا عِنْدَ الْيَأْسِ مِنَ الْفِعْلِ، لَا بِمُضِيِّ زَمَنِ يُمَكِّنُ فِيهِ الْفِعْلُ وَلَمْ يُفْعَلْ؛ كَمَا فِي طَرَفِ الْإِثْبَاتِ لَا يَخْتَصُّ التَّغْلِيْقُ بِالزَّمَانِ الْأَوَّلِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَقَعُ فِي كُلِّ مِنْهُمَا بِمُضِيِّ زَمَنِ يُمَكِّنُ فِيهِ الْفِعْلُ وَلَمْ يُفْعَلْ؛ لِأَنَّهُ أَوَّلُ وَقْتٍ حَصَلَ فِيهِ عَدَمُ الْفِعْلِ الْمُعْلَقِ بِهِ، وَالطَّلَاقُ يَقَعُ بِأَوَّلِ حُصُولِ الصِّفَةِ، وَالْحَقُّوَابُ "إِذَا" غَيْرَهَا مِنْ أَحْوَاتِهَا فِيمَا ذُكِرَ، كَمَا شَمِلَتْهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ، نَحْوُ: مَتَى، أَوْ: أَيُّ وَقْتٍ لَمْ تَدْخُلِي الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ.. فَتُطْلَقُ بِمُضِيِّ زَمَنِ يُمَكِّنُ فِيهِ الدُّخُولُ، وَلَمْ تَأْتِ بِهِ عَلَى الرَّاجِحِ (وَلَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ أَنْ دَخَلْتَ) الدَّارَ، (أَوْ أَنْ لَمْ تَدْخُلِي بِفَتْحٍ "أَنْ" .. وَقَعَ فِي الْحَالِ)؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى لِلدُّخُولِ أَوْ لِعَدَمِهِ بِتَقْدِيرِ لَمْ التَّغْلِيلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ﴾ [القلم: ١٤] وَسَوَاءٌ كَانَ فِيمَا عَلَّلَ بِهِ صَادِقًا أَمْ كَاذِبًا. (قُلْتُ: إِلَّا فِي غَيْرِ نَحْوِي.. فَتَغْلِيْقُ فِي الْأَصَحِّ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ)؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ قَضَاهُ لَهُ، وَهُوَ لَا يُمَيِّزُ بَيْنَ "أَنْ"، وَ"إِنْ"، وَالثَّانِي: يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ فِي الْحَالِ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: قَصَدْتُ التَّغْلِيْقَ.. فَيُصَدَّقُ بِمِيقَانِهِ. قَالَ الرَّافِعِيُّ: "وَهَذَا أَشْبَهُ" (١) أَيِ: بِالْتَّرْجِيحِ، وَرَجَّحَهُ ابْنُ الصَّبَّاحِ (٢)، وَصَحَّحَ الْأَوَّلَ فِي "الرَّوْضَةِ" (٣).

تعليق الطلاق بالحمل، والولادة

(فَصْلٌ: عُلِقَ بِحَمْلٍ، كَأَنَّ قَالَ: إِنْ كُنْتُ حَامِلًا فَأَنْتِ طَالِقٌ: (فَإِنْ كَانَ) بِهَا (حَمْلٌ ظَاهِرٌ.. وَقَعَ) الطَّلَاقُ فِي الْحَالِ (وَإِلَّا) أَيِ: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَمْلٌ ظَاهِرٌ.. نُظِرَ: (فَإِنْ) وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ التَّغْلِيْقِ.. بَانَ وَقُوعُهُ) حِينَ التَّغْلِيْقِ؛ لِوُجُودِ الْحَمْلِ حِينَئِذٍ؛ إِذْ أَقَلُّ مُدَّتِهِ:

عدم إطباق الأصحاب على التخرج: بل منهم من يُخْرِجُ، ومنهم من يبدي فرقا. لكن هل يمكن نسبة القول المخرج هذا للشافعي؟ الأصح - كما ذكر النووي في المجموع، ونقله عنه الشريبي والرملي -: أن القول المخرج لا ينسب للشافعي؛ لأنه ربما روجع فيه، فذكر فارقا. المجموع (٤٣/١)، ومغني المحتاج (٣٦/١)، ونهاية المحتاج (٥٠/١).

(٢) فتح العزيز (٨٥/٩).

(٣) ابن الصباغ: هو أبو نصر عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد، المعروف بابن الصباغ، قاضي المذهب، وفقهه الشافعية بالعراق في وقته، مولده سنة ٤٠٠ هـ، ووفاته سنة ٤٧٧ هـ. من أهم مصنفاته كتاب: "العدة"، و"تذكرة العالم والطريق السالم"، و"الشامل" في الفقه، قال ابن خلكان: وهو من أجود كتب أصحابنا، وأصحها نقلاً وأثبتها أدلة، وفيات الأعيان (٢١٧/٣)، (٢١٨)، طبقات السبكي (٤٦٤/١)، وما بعدها.

(٤) روضة الطالبين (١٣٦/٨، ١٣٧).

سِتَّةَ أَشْهُرٍ (أَوْ): وَلَدَتْ (لَأَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ) مِنَ التَّغْلِيْقِ (أَوْ: بَيْنَهُمَا) أَي: بَيْنَ السِتَّةِ أَشْهُرٍ وَالْأَرْبَعِ سِنِينَ (وَوُطِئَتْ) بَعْدَ التَّغْلِيْقِ، (وَأَمَكْنَ حُدُوثُهُ بِهِ) أَي: حُدُوثُ الْحَمْلِ بِالْوُطْءِ -بِأَنَّ كَانَ بَيْنَ الْوُطْءِ وَالْوَضْعِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ -(.فَلَا) يَقَعُ بِالتَّغْلِيْقِ طَلَقٌ؛ لِتَبَيُّنِ انْتِفَاءِ الْحَمْلِ مُدَّةَ الْحَمْلِ الْأُولَى، إِذْ أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْلِ: أَرْبَعُ سِنِينَ^(١)؛ وَلِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الْحَمْلِ مِنَ الْوُطْءِ بَعْدَ التَّغْلِيْقِ فِي الثَّانِيَةِ، وَالْأَصْلُ: بَقَاءُ النِّكَاحِ (وَالْأَيُّ) أَي: وَإِنْ لَمْ يَطَّأَهَا

1(تحديد أكثر مدة الحمل بأربع سنوات عند الشافعية ومن وافقهم لا دليل على تقريره: إلا التجربة والاعتماد على الواقع آنذاك، كما ورد في قصة محمد بن عجلان، والتي ورد فيها أن امرأته ولدت ثلاثة أبطن كل بطن في أربع سنين، فقد روى الوليد بن مسلم قال: "قُلْتُ لِمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ إِنِّي حُدِثْتُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ: لَا تَزِيدُ الْمَرْأَةَ عَلَى حَمْلِهَا عَلَى سَنَتَيْنِ قَدَرِ ظِلِّ الْمَغْرَلِ فَقَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ هَذِهِ جَارَتُنَا امْرَأَةُ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ امْرَأَةٌ صَدَّقَ وَزَوْجُهَا رَجُلٌ صَدَّقَ حَمَلَتْ ثَلَاثَةَ أَبْطُنٍ فِي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً تَحْمِلُ كُلُّ بَطْنٍ أَرْبَعَ سِنِينَ" أخرجه الدارقطني في النكاح، باب: المهر (٢٨٢)، والبيهقي في العدد، بباب: ما جاء في أكثر مدة الحمل (١٥٦١).

وهذا الكلام لا يؤيده الواقع العملي مطلقاً في ظل التقدم الطبي الحديث، ويتعارض مع كلام الأطباء، حيث تحدث الأطباء عن إمكانية تأخر الحمل عن التسعة أشهر، وقالوا: بأنه قد يتأخر أسبوعاً أو أسبوعين، وقد يصل التأخر إلى شهر؛ لكن لا يمكن أن يزيد عن ذلك، وقد بينت بعض الإحصائيات أن (٦٠%) من المواليد يكونون في مدة الحمل الطبيعية وهي تسعة أشهر، والـ (٤٠%) الباقية يزيدون عن المدة الطبيعية؛ لكن بأسبوع أو أسبوعين، وهذه النسبة التي تتأخر، منها: (٢٥%) يلدن في الأسبوع الثاني والأربعين، أي: بعد (٢٤٩) يوم، و(١٢%) يلدن في الأسبوع الثالث والأربعين، أي: بعد (٣٠١) يوم، و(٣%) يلدن في الأسبوع الرابع والأربعين، أي: بعد (٣٠٨) يوم، ومن النادر أن ينجم الموت جنين بقي في الرحم خمسة وأربعين أسبوعاً، ويذكر المتخصصون من الأطباء: أنه يستحيل حدوث حمل ممتد لعدة سنين، حيث إن الجنين منذ الشهر السادس ينمون نمو كبيراً، وطاقة الأم لا تتحمل القدرة على حمله وإمداده بالغذاء إذا استمر وجوده في رحمها عدة سنين، فالجنين يكون وزنه في السادس (٧٠٠) جرام تقريباً، بينما في التاسع يصل لـ (٣٤٠٠) جرام تقريباً، وعليه: فإن المدة الطبيعية للحمل هي (٢٨٠) يوم، تحسب من آخر حيضة حاضتها المرأة، وبما أن الحمل في العادة يحدث في اليوم الرابع عشر من بدء الحيض، فإن مدة الحمل الحقيقية تكون (٢٦٦) يوم.

ولا تعارض بين ما ذكره الأطباء وما ذكره الفقهاء، فإن الفقهاء اعتمدوا في حكمهم على التجربة والواقع الذي شاهدوه، فقد سمعوا أن امرأة ولدت في أربع سنين، فقررروا هذا الحكم؛ لعدم وجود دليل من القرآن أو السنة يحدد ذلك؛ لكن هل حملها ظل أربع سنوات في بطنها؟ هذا تخمين وظن، بينما الأطباء بنوا حكمهم على علم وتشخيص، فيكون هو المعتمد في الحكم الشرعي، وما ذكره الفقهاء يمكن تفسيره: بأن المعهود عند العرب قديماً أن انقطاع الدورة الشهرية عند المرأة يكون بسبب الحمل، لا غير؛ لكن ما أثبتته الأطباء: أن انقطاع الدم عند المرأة قد يكون بسبب الحمل وقد يكون لسبب آخر، وهذا يعني: أن المرأة قد تقضي شهوراً بل سنوات لا ينزل عليها الدم، فتتوهم هي أو غيرها: أنه انقطع حيضها بسبب الحمل، والحقيقة: أنه ليس حملاً، بل هو سبب طبي منع من نزول الدم، ولعل هذا هو الذي حدث لامرأة محمد بن عجلان، انقطع عنها الدم فتخيلت أنها حامل، وحصل التبويض الحقيقي في المدة الطبيعية فحملت، فتخيلوا أنها ظلت هذه المدة كاملة وهي حامل، فضلاً عن أن هناك ما يسمى بالحمل الكاذب، والذي تشعر فيه المرأة =بنفس أعراض الحمل، وهي في الحقيقة غير حامل، أضف إلى ذلك أن هذا الأمر لم يتكرر، وغير موجود في عصرنا، ولو وجد لنقل عبر وسائل الإعلام، فدل على صحة التفسير الذي ذكرناه. والله أعلم

بَعْدَ التَّغْلِيْقِ أَوْ وَطْنَهَا بَعْدَهُ وَلَمْ يُمَكِّنْ حُدُوثَ الْحَمْلِ بِذَلِكَ الْوَطْءِ - بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْوَضْعِ دُونَ سِتَّةِ

أَشْهُرٍ - (..فَالْأَصَحُّ وَقُوعُهُ) (١)؛ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الْحَمْلِ عِنْدَ التَّغْلِيْقِ، ظَاهِرًا، وَالثَّانِي: لَا يَقَعُ؛ لِاحْتِمَالِ حُدُوثِ الْحَمْلِ بَعْدَ التَّغْلِيْقِ بِاسْتِدْخَالِهَا مَنِئِهِ، وَالْأَصْلُ: بَقَاءُ النِّكَاحِ.

تَنْبِيْهُ: التَّعَرُّضُ لِلْوَطْءِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ ظَاهِرٌ يُشْعِرُ بِجَوَازِهِ، وَجَوَازِ الْإِسْتِمْتَاعِ، وَهُوَ الْأَصَحُّ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْحَمْلِ، وَبَقَاءُ النِّكَاحِ، وَقِيلَ: يَحْرُمُ ذَلِكَ، احتِيَاظًا فِي مَحَلِّ التَّرَدُّدِ إِلَى أَنْ يَسْتَبْرَأَ بِقُرْعٍ، وَقِيلَ: بِثَلَاثَةٍ، (وَإِنْ قَالَ: إِنْ كُنْتُ حَامِلًا بِذَكَرٍ، فَطَلَقْتُ) أَي: فَأَنْتِ طَالِقٌ طَلَقَةً (أَوْ) (٢) أَنْثَى، فَطَلَقْتَيْنِ، فَوَلَدْتُهُمَا.. وَقَعَ ثَلَاثٌ؛ لِتَبَيُّنِ وُجُودِ الصِّفَتَيْنِ، وَتَنْقِضِي الْعِدَّةِ فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ بِالْوِلَادَةِ، (أَوْ) قَالَ: (إِنْ كَانَ حَمْلُكَ ذَكَرًا، فَطَلَقْتُ، أَوْ: أَنْثَى فَطَلَقْتَيْنِ، فَوَلَدْتُهُمَا.. لَمْ يَقَعْ شَيْءٌ)؛ لِأَنَّ قَضِيَّةَ اللَّفْظِ: كَوْنُ جَمِيعِ الْحَمْلِ ذَكَرًا أَوْ أَنْثَى، (أَوْ) قَالَ: (إِنْ وَلَدْتَ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَوَلَدْتَ اثْنَيْنِ مُرْتَبًا.. طَلَقْتَ بِالْأَوَّلِ)؛ لِوُجُودِ الصِّفَةِ (وَانْقِضَتْ عِدَّتُهَا بِالثَّانِي)، سَوَاءً كَانَ مِنْ حَمْلِ الْأَوَّلِ - بِأَنْ كَانَ بَيْنَ وَضْعِهِمَا دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ - أَمْ مِنْ حَمْلِ آخَرَ - بِأَنْ وَطْنَهَا بَعْدَ وَلَادَةِ الْأَوَّلِ، وَأَتَتْ بِالثَّانِي لِأَقَلِّ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ -

(وَإِنْ قَالَ: كُلَّمَا وَلَدْتَ) فَأَنْتِ طَالِقٌ، (فَوَلَدْتَ ثَلَاثَةً مِنْ حَمْلٍ)، مُرْتَبًا (..وَقَعَ بِالْأَوَّلَيْنِ طَلَقَتَانِ، وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهَا (بِالثَّالِثِ، وَلَا يَقَعُ بِهِ ثَالِثَةٌ عَلَى الصَّحِيحِ)؛ إِذْ بِهِ يَتِمُّ انْفِصَالُ الْحَمْلِ الَّذِي تَنْقُضِي بِهِ الْعِدَّةَ، فَلَا يُقَارَنُ طَلَاقٌ، وَالثَّانِي: يَقَعُ بِهِ طَلَقَةٌ ثَالِثَةٌ، وَتَعْتَدُ بَعْدَهُ بِالْأَقْرَاءِ، وَلَا مَحْدُورَ فِي مُقَارَنَةِ الطَّلَاقِ؛ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى لَوْ قَالَ لِلرَّجْعِيَّةِ: أَنْتِ طَالِقٌ مَعَ انْقِضَاءِ عِدَّتِكَ.. يَقَعُ الطَّلَاقُ مَعَهُ، وَالْأَوَّلُ: الْمَشْهُورُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي "الْأَمِّ" (٣)

(١) وكذلك ثبوت النسب.

(٢) قال الدميري: تعبير المصنف هنا بـ(أو) لا يستقيم، والصواب (الواو)؛ لأن التصوير في الجمع بين التعليقين، أي: قال: إن كنت حاملاً بذكر.. فطلقة، وإن كنت حاملاً بأنثى.. فطلقتين، فإن ولدت ذكراً أو ذكراً أو ذكوراً... بان وقوع طلاقة، وإن ولدت أنثى أو اثنتين أو إناث... بان وقوع طلقتين.

(٣) الأم (٢٣٨/٥).

وغيره، والثاني: منقولٌ عن "الإملاء" (١)، وبعضهم: أثبتته، والأكثرُونَ: نفوه وقطعوا بالأول، فلو عُبِّرَ الْمُصَنِّفُ بِذَلِكَ "الصَّحِيح" بِـ"المذهب" لَوْفِي بِاصْطِلَاحِهِ فِي ذَلِكَ هُنَا (٢)، وَلَوْ وَلَدَتْ اثْنَيْنِ كَمَا ذَكَرَ.. وَقَعَ بِالأَوَّلِ طَلْقُهُ، وَتَنَقُّضِي الْعِدَّةِ بِالثَّانِي، وَهَلْ يَقَعُ بِهِ ثَانِيَةٌ وَتَعْتَدُ بَعْدَهُ؟ فِيهِ الْخِلَافُ الْمَذْكُورُ، وَلَوْ وَلَدَتْ أَرْبَعَةً.. فَيَقَعُ بِالثَّلَاثَةِ ثَلَاثٌ، وَتَنَقُّضِي الْعِدَّةِ بِالرَّابِعِ، (وَلَوْ قَالَ لِأَرْبَعٍ) حَوَامِلُ: (كُلَّمَا وَلَدَتْ وَاحِدَةً) مِنْكُنَّ (فَصَوَّاحِبُهَا طَوَالِقُ، فَوَلَدَنَ مَعًا.. طَلَّقَنَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا)؛ لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ ثَلَاثَ صَوَّاحِبٍ، فَيَقَعُ بِوِلَادَتِهَا عَلَى كُلِّ مِّنِ الثَّلَاثَةِ طَلْقُهُ، وَلَا يَقَعُ بِهَا عَلَى نَفْسِهَا شَيْءٌ، وَيَعْتَدُنَ جَمِيعًا بِالأَقْرَاءِ، وَ"صَوَّاحِبُ": جَمْعُ صَاحِبَةٍ كَضَارِبَةٍ وَضَوَّارِبٍ، وَقَوْلُهُ "ثَلَاثًا" الثَّانِي (٣): دَافِعٌ لِاحْتِمَالِ إِرَادَةِ طَلَاقِ الْمَجْمُوعِ ثَلَاثًا (أَوْ) وَلَدَنَ (مُرْتَبًا.. طَلَّقَتْ الرَّابِعَةَ ثَلَاثًا) بِوِلَادَةِ كُلِّ مِّنِ صَوَّاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً، وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوِلَادَتِهَا (وَكَذَا الأَوَّلَى) طَلَّقَتْ ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلِّ مِّنِ صَوَّاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً (إِنْ بَقِيَتْ عِدَّتُهَا) عِنْدَ وَلَادَةِ الرَّابِعَةِ (و) .. طَلَّقَتْ (الثَّانِيَةَ طَلْقَةً) بِوِلَادَةِ الأَوَّلَى (وَالثَّانِيَةَ طَلَّقَتَيْنِ) بِوِلَادَةِ الأَوَّلَى وَالثَّانِيَةِ، (وَانْقَضَتْ عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا) وَالأَوَّلَى تَعْتَدُ بِالأَقْرَاءِ، وَفِي اسْتِثْنَائِهَا الْعِدَّةَ لِلطَّلَاقِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ: الْخِلَافُ فِي طَلَاقِ الرَّجْعِيَّةِ، وَهُوَ طَرِيقَانِ: أَحَدُهُمَا: تَسْتَأْنِفُ فِي قَوْلِ، وَتَبْنِي فِي قَوْلِ، وَالثَّانِي: الْقَطْعُ بِالْبِنَاءِ، وَالرَّاجِحُ: الْبِنَاءُ؛ إِنْ أَثْبَتْنَا الْخِلَافَ.

(٤) (الإملاء): هو أحد كتب الإمام الشافعي - رحمه الله - وله أيضا (الأمالى) قال في كشف الظنون (١/١٦٩): "وقد يتوهم أن (الإملاء) هو: (الأمالى)، وليس كذلك. ومصطلح الإملاء هو: أن يقعد عالم، وحوله تلامذته بالمحابر، والقراطيس، فيتكلم العالم بما فتح الله - سبحانه وتعالى - عليه من العلم، ويكتبه التلامذة، فيصير كتابا، ويسمونه: الإملاء، والأمالى. وكذلك كان السلف من: الفقهاء، والمحدثين، وأهل العربية، وغيرها، في علومهم... وعلماء الشافعية يسمون مثله: (التعليق). كشف الظنون (١٦٠/١)

(١) حيث أثبت بعضهم القول الثاني، ونفاه البعض الآخر، وقطعوا بقول واحد، وهذا يطلق عليه في المذهب الشافعي مصطلح "الطرق": وهي اختلاف الأصحاب في حكاية الأقوال عن الإمام الشافعي، وفي مثل هذه الحالات يعبر النووي فيها بمصطلح "المذهب" ليبين الراجح من الطريقتين، هل هو إثبات القول أو نفيه؟ لذا ذكر الشيخ جلال الدين المحلي هنا أنه كان من الأفضل أن يعبر النووي - رحمه الله بـ "المذهب" بدلا من تعبيره بـ "الصحيح".

(٢) المذكور في جملة (طلقن ثلاثا ثلاثا).

(وَقِيلَ: لَا تُطَلَّقُ الْأُولَى) أَصْلًا (وَتُطَلَّقُ الْبَاقِيَاتُ طَلْقَةً طَلْقَةً) بِوِلَادَةِ الْأُولَى؛ لِأَنَّهِنَّ صَوَاحِبُهَا عِنْدَ وِلَادَتِهَا؛ لِاشْتِرَاكِ الْجَمِيعِ فِي الزَّوْجِيَّةِ حِينَئِذٍ، وَبِطَّلَاقِهَا انْتَفَتْ الصُّحْبَةُ بَيْنَ الْجَمِيعِ، فَلَا تُؤَثِّرُ وِلَادَتُهُنَّ فِي حَقِّ الْأُولَى، وَلَا وِلَادَةُ بَعْضِهِنَّ فِي حَقِّ بَعْضٍ، وَدُفِعَ هَذَا: بِأَنَّ الطَّلَاقَ الرَّجْعِيَّ لَا يَنْفِي الصُّحْبَةَ وَالزَّوْجِيَّةَ، فَإِنَّهُ لَوْ حَلَفَ بِطَّلَاقِ نِسَائِهِ.. دَخَلَتْ الرَّجْعِيَّةُ فِيهِ، (وَإِنْ وَلَدَتْ ثِنْتَانِ مَعًا، ثُمَّ ثِنْتَانِ مَعًا.. طَلَّقَتِ الْأُولَيَانِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا). أَي: طُلِّقَ كُلُّ مِنْهُمَا ثَلَاثًا بِوِلَادَةِ كُلِّ مِنْ صَوَاحِبِهَا الثَّلَاثِ طَلْقَةً (وَقِيلَ: طَلْقَةً) فَقَطَّ بِوِلَادَةِ رَفِيقَتِهَا وَانْتَفَتْ الصُّحْبَةُ مِنْ حِينَئِذٍ (وَالْأُخْرَيَانِ.. طَلَّقَتَيْنِ طَلَّقَتَيْنِ) أَي: طُلِّقَ كُلُّ مِنْهُمَا طَلْقَتَيْنِ بِوِلَادَةِ الْأُولَيَيْنِ، وَلَا يَقَعُ عَلَيْهِمَا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى شَيْءٌ، وَتَنْقُضِي عِدَّتُهُمَا بِوِلَادَتِهِمَا، وَعَلَى مَا تَقَدَّمَ نَقْلُهُ عَنِ "الإِمْلَاءِ" يَقَعُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا طَلْقَةٌ أَيْضًا بِوِلَادَةِ الْأُخْرَى، وَيَعْتَدَانِ بِالْأَقْرَاءِ.

تعليق الطلاق بالحيض

(وَتُصَدَّقُ بِبَيْمِنِهَا فِي حَيْضِهَا إِذَا عَلَّقَهَا) أَي: عَلَّقَ طَلَّاقُهَا (بِهِ) وَقَالَتْ: حِضْتُ، وَأَنْكَرَهُ الزَّوْجُ؛ لِأَنَّهَا أَعْرَفُ مِنْهُ بِهِ، وَيَتَعَذَّرُ إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهِ وَإِنْ شُوهِدَ الدَّمُ؛ لِحُجُوزِ أَنْ يَكُونَ دَمُ اسْتِحَاضَةٍ (لَا فِي وِلَادَتِهَا) (١) إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقُ بِهَا، فَقَالَتْ: وَلَدْتُ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ، وَقَالَ: هَذَا الْوَلَدُ مُسْتَعَارٌ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِإِمْكَانِ إِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عَلَيْهَا، وَالثَّانِي: تُصَدَّقُ فِيهَا بِبَيْمِنِهَا؛ لِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ فِي رَحِمِهَا: حَيْضًا، وَطَهْرًا، وَوَضْعُ حَمْلٍ فِي الْعِدَّةِ (وَلَا تُصَدَّقُ فِيهِ) (٢) فِي تَعْلِيلِ غَيْرِهَا) كَأَنَّ قَالَ: إِنْ حِضَّتْ فَضَرَّتْكَ طَالِقٌ، فَقَالَتْ: حِضْتُ، وَأَنْكَرَ الزَّوْجُ؛ إِذْ لَوْ صَدَّقَتْ فِي ذَلِكَ بِبَيْمِنِهَا.. لَزِمَ الْحُكْمُ لِلْإِنْسَانِ بِبَيِّنٍ غَيْرِهِ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ، فَيُصَدَّقُ الزَّوْجُ جُزْيًا عَلَى الْأَصْلِ فِي تَصْدِيقِ الْمُنْكَرِ.

(وَلَوْ قَالَ) لِامْرَأَتِي: (إِنْ حِضْتُمَا فَأَنْتُمَا طَالِقَانِ) وَالْمَعْنَى: أَنَّ طَلَاقَ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا مُعْلَقٌ بِحَيْضِهَا جَمِيعًا - وَيُنْبَنِي عَلَيْهِ مَا سَيَأْتِي مِنْ تَكْذِيبِ إِحْدَاهُمَا - (فَرَعَمَتَاهُ، وَكَذَّبَهُمَا.. صَدِيقَ بَيْمِنِهِ، وَلَا يَقَعُ) الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ: عَدَمُ الْحَيْضِ، وَبَقَاءُ النِّكَاحِ، (وَإِنْ

(١) يعني: إن علق طلاقها على ولادتها، فقالت: ولدت، فإنها لا تصدق في ولادتها؛ لأنه ممكن إقامة البينة عليه

: بخلاف الحيض، فلا يعرف ذلك إلا من جهتها؛ لذا فإنها تصدق ببيمينها لو ادعت وجوده

(٢) يعني: في ادعاء وجود الحيض.

كَذَّبَ وَاحِدَةً فَقَطُ (..طَلَّقَتْ فَقَطُ) إِذَا حَلَقَتْ أَنَّهَا حَاضَتْ؛ لِثُبُوتِ حَيْضِهَا بِيَمِينِهَا، وَحَيْضُ صَرَّتِهَا بِتَصْدِيقِ الرُّوجِ لَهَا، وَالْمُصَدِّقَةُ: لَا يَثْبُتُ فِي حَقِّهَا حَيْضُ صَرَّتِهَا بِيَمِينِهَا؛ لِأَنَّ الْيَمِينَ لَا تُؤَثِّرُ فِي حَقِّ غَيْرِ الْحَالِفِ.. فَلَمْ تُطْلَقْ.

تعليق الطلاق بالطلاق والوطء

(وَلَوْ قَالَ: "إِنْ" أَوْ "إِذَا"، أَوْ مَتَى طَلَّقْتُكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، فَطَلَّقَهَا.. وَقَعَ الْمُنْجَزُ فَقَطُ) أَيُّ: دُونَ الْمُعْلَقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ.. لَمْ يَقَعْ الْمُنْجَزُ؛ لِزِيَادَتِهِ عَلَى الْمَمْلُوكِ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنْجَزُ.. لَمْ يَقَعْ الْمُعْلَقُ؛ لِأَنَّهُ مَشْرُوطٌ بِهِ، فَوُقُوعُهُ مُحَالٌ، بِخِلَافِ وَقُوعِ الْمُنْجَزِ (وَقِيلَ): وَقَعَ (ثَلَاثًا) الطَّلَاقُ الْمُنْجَزُ، وَثِنْتَانِ مِنَ الْمُعْلَقِ، وَلَعَثَ الثَّالِثَةُ؛ لِأَدَائِهَا إِلَى الْمُحَالِ، (وَقِيلَ: لَا شَيْءَ) يَقَعُ مِنَ الْمُنْجَزِ وَالْمُعْلَقِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ الْمُنْجَزُ.. لَوْقَعَ الْمُعْلَقُ قَبْلَهُ بِحُكْمِ التَّغْلِيْقِ، وَلَوْ وَقَعَ الْمُعْلَقُ.. لَمْ يَقَعْ الْمُنْجَزُ، وَإِذَا لَمْ يَقَعْ الْمُنْجَزُ.. لَمْ يَقَعْ الْمُعْلَقُ، وَهَذَا الْوَجْهُ، وَالْأَوَّلُ: فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَغَيْرِهَا، وَالثَّانِي: فِي الْمَدْخُولِ بِهَا؛ إِذْ غَيْرُهَا لَا يَتَعَاقَبُ عَلَيْهَا طَلَاْقَانِ، وَالثَّالِثُ (١): قَالَهُ ابْنُ سُرَيْجٍ (٢) وَبِهِ اشْتَهَرَتِ الْمَسْأَلَةُ بِالسَّرِيْجِيَّةِ، وَاخْتَارَهُ كَثِيرٌ مِنَ الْأَصْحَابِ، كَمَا اخْتَارَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ: الْأَوَّلُ (٣) (وَلَوْ قَالَ: إِنْ ظَاهَرْتُ مِنْكَ أَوْ آئِثْتُ أَوْ لَاعَنْتُ أَوْ فَسَخْتُ) النِّكَاحَ (بِعَيْنِكَ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ وَجَدَ الْمُعْلَقُ بِهِ) مِنَ الظَّهَارِ أَوْ غَيْرِهِ (..فَفِي صِحَّتِهِ: الْخِلَافُ) فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّاجِحُ: يَبْصَحُ، وَيَلْغُو تَغْلِيْقُ الطَّلَاقِ؛ لِاسْتِحَالَةِ وَقُوعِهِ، وَعَلَى الثَّالِثِ: يَلْغُوَانِ جَمِيعًا، وَلَا يَأْتِي الثَّانِي هُنَا.

(١) وهو: عدم وقوع شيء من المنجز ولا من المعلق.

(٢) هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج، الفقيه الشافعي، من عظماء الشافعيين، وأئمة المسلمين، وكان يقال له: الباز الأشهب، وكان يفضل على جميع أصحاب الإمام الشافعي، حتى على المزني، بلغت كتبه أربع مائة مصنف، وقام بنصرة مذهب الشافعي وكان الشيخ أبو حامد الإسفراييني يقول: نحن نجري مع أبي العباس في ظواهر الفقه دون دقائقه توفي - رحمه الله سنة ٣٠٦ هـ. وسريج: قال السبكي: "هو بضم السين المهملة وفتح الراء المهملة وسكون الياء المثناة من تحتها والجيم". ووفيات الأعيان (٦٧/١)، وبقات السبكي (٨٧/٢).

(٣) وهو: وقوع المنجز فقط.

(وَلَوْ قَالَ: إِنْ وَطِئْتُكَ) وَطِئًا (مُبَاحًا فَأَنْتَ طَالِقٌ قَبْلَهُ، ثُمَّ وَطِئَ.. لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ (قَطْعًا)؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَقَعَ.. لَخَرَجَ الْوَطْءُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا، وَخُرُوجُهُ عَنْ ذَلِكَ مُحَالٌ، وَسَوَاءٌ ذَكَرَ ثَلَاثًا أَمْ لَا، وَإِنَّمَا لَمْ يَأْتِ خِلَافٌ بِالْوُقُوعِ مِنَ الْوَجْهِ الثَّانِي فِي مَسْأَلَةِ التَّغْلِيْقِ بِالطَّلَاقِ السَّابِقَةِ؛ لِأَنَّ التَّغْلِيْقَ بِهِ يُقْصَدُ بِهِ: سَدُّ بَابِ الطَّلَاقِ، فَعُومِلَ قَائِلُهُ بِنَقِيضِ قَصْدِهِ، بِأَنَّهُ أَوْقَعَ عَلَيْهِ مَعَ الْمَنْجَزِ بَعْضَ الْمُعْلَقِ تَغْلِيْظًا، وَالتَّغْلِيْقُ هُنَا: لِكَوْنِهِ بَغْيَرِ الطَّلَاقِ لَا يَسُدُّ بَابَهُ، (وَلَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا)؛ كَأَنَّ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شِئْتِ (..أُشْتَرِطْتُ) أَي: مَشِيئَتُهَا (عَلَى فَوْرِ)؛ لِتَضَمُّنِ ذَلِكَ لِتَمْلِيكِهَا الطَّلَاقَ؛ كَطَلْقِي نَفْسِكَ، كَمَا تَقَدَّمَ (أَوْ: غَيْبَةً) كَأَنَّ قَالَ: زَوَّجْتِي طَالِقٌ إِنْ شَاءَتْ (أَوْ: بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ) كَأَنَّ قَالَ لَهُ: إِنْ شِئْتَ فَرَزَّوْجَتِي طَالِقٌ (..فَلَا) يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي الْمَشِيئَةِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِي، وَبُعْذُهُ فِي الْأَوَّلِ بِانْتِفَاءِ الْخِطَابِ فِيهِ، وَالثَّانِي: يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ؛ نَظَرًا إِلَى تَضَمُّنِ التَّمْلِيكِ فِي الْأَوَّلِ وَالْإِلَى الْخِطَابِ فِي الثَّانِي، وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ زَوَّجْتِي طَالِقٌ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ.. فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ فَوْرٌ قَطْعًا؛ لِانْتِفَاءِ التَّمْلِيكِ وَالْخِطَابِ (وَلَوْ قَالَ الْمُعْلَقُ: بِمَشِيئَتِهِ) مِنَ الزَّوْجَةِ أَوْ الْأَجْنَبِيِّ (شِئْتُ كَارِهًا بَقْلَبِهِ.. وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (١) (وَقِيلَ: لَا يَقَعْ بَاطِنًا)؛ لِانْتِفَاءِ الْمَشِيئَةِ فِي الْبَاطِنِ. وَدُفِعَ ذَلِكَ: بِأَنَّ مَا فِي الْبَاطِنِ لِحَفَائِهِ لَا يُقْصَدُ التَّغْلِيْقُ بِهِ وَإِنَّمَا يُقْصَدُ التَّغْلِيْقُ بِاللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَيْهِ، وَقَدْ وَجِدَ فِيمَا نَحْنُ فِيهِ، (وَلَا يَقَعْ بِمَشِيئَةِ صَبِيٍّ وَصَبِيٍّ) عَلَقَ الطَّلَاقَ بِهَا، كَأَنَّ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الصَّبِيَّةِ: أَنْتَ طَالِقٌ إِنْ شِئْتَ، أَوْ لِأَجْنَبِيٍّ صَبِيٍّ: إِنْ شِئْتَ فَرَزَّوْجَتِي طَالِقٌ، فَقَالَ كُلُّ مِنْهُمَا: شِئْتُ.. لَا يَقَعْ الطَّلَاقُ وَإِنْ كَانَ مُمْتِزًا؛ لِأَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ لِقَوْلِ غَيْرِ الْبَالِغِ فِي التَّصَرُّفَاتِ، (وَقِيلَ: يَقَعْ بِمُمِيزٍ) أَي: بِمَشِيئَتِهِ، فَتُعْتَبَرُ كَمَا أُعْتَبِرَتْ فِي اخْتِيَارِ أَحَدِ الْأَبَوَيْنِ، وَلَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَةِ بَالِغٍ مَجْنُونٍ مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ، فَقَالَ: شِئْتُ.. لَمْ يَقَعْ قَطْعًا؛ لِأَنَّ الْمَجْنُونِ لَيْسَ لَهُ قَصْدٌ صَحِيحٌ، (وَلَا رُجُوعَ لَهُ) أَي: لِلْمُعْلَقِ (قَبْلَ الْمَشِيئَةِ) مِنَ الْمُعْلَقِ بِمَشِيئَتِهِ؛ نَظَرًا إِلَى أَنَّهُ تَغْلِيْقٌ فِي الظَّاهِرِ، وَإِنْ تَضَمَّنَ تَمْلِيكًا؛ كَمَا لَا يَرْجِعُ فِي التَّغْلِيْقِ بِالْإِعْطَاءِ قَبْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مُعَاوَضَةً.

(١) لوجود المعلق عليه، وهو لفظ المشيئة.

(وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ زَيْدٌ طَلَقَةً، فَشَاءَ طَلَقَةً.. لَمْ تُطْلَقْ)؛ نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْمَعْنَى: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ هَا.. فَلَا تُطْلَقُ أَصْلًا بِكَمَا لَوْ قَالَ: إِلَّا أَنْ يَدْخُلَ زَيْدٌ الدَّارَ فَدَخَلَهَا، (وَقِيلَ: يَقَعُ طَلَقُهُ)؛ نَظَرًا إِلَى الْمَعْنَى: إِلَّا أَنْ يَشَاءَ طَلَقَةً، فَلَا يُزَادُ عَلَيْهَا (وَلَوْ عَلَّقَ) الزَّوْجَ الطَّلَاقَ (بِفِعْلِهِ) كَانَ عُلْقُهُ بِدُخُولِ الدَّارِ (فَفَعَلَ) الْمُعْلَقُ بِهِ (نَاسِيًا لِلتَّغْلِيْقِ، أَوْ) ذَاكِرًا لَهُ (مُكْرَهَا) عَلَى الْفِعْلِ، أَوْ طَائِعًا جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعْلَقُ عَلَيْهِ، (..لَمْ تُطْلَقْ فِيهِ الْأَظْهَرُ)؛ لِحَدِيثِ ابْنِ مَاجَةَ وَغَيْرِهِ: {إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالتَّسْيَانَ وَمَا أُسْتُكِرْهُوا عَلَيْهِ} (١) أَي: لَا يُؤَاخِذُهُمْ بِذَلِكَ، وَالثَّانِي: تُطْلَقُ؛ لَوْجُودِ الْمُعْلَقِ بِهِ، وَلَيْسَ التَّسْيَانُ وَنَحْوُهُ دَافِعًا لِلْوُقُوعِ (أَوْ) عَلَّقَ الطَّلَاقَ (بِفِعْلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يُبَالَى بِتَغْلِيْقِهِ) فَلَا يُخَالِفُهُ فِيهِ لَصَدَاقَةٌ أَوْ نَحْوُهَا، (وَعَلِمَ بِهِ.. فَكَذَلِكَ) أَي: إِذَا فَعَلَهُ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهَا، أَوْ جَاهِلًا.. لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ فِي الْأَظْهَرِ (وَالْأَيُّ) أَي: وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُبَالَى بِتَغْلِيْقِهِ؛ كَالسُّلْطَانِ، أَوْ كَانَ يُبَالَى بِهِ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ، وَلَمْ يَقْصِدِ الزَّوْجُ إِعْلَامَهُ بِهِ بِكَمَا فِي "الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا" (..فَيَقَعُ) الطَّلَاقُ بِفِعْلِهِ (قَطْعًا)، وَإِنْ اتَّفَقَ فِي بَعْضِ صُورِهِ نَسْيَانٌ أَوْ نَحْوُهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ حِينَئِذٍ مُجَرَّدُ التَّغْلِيْقِ بِالْفِعْلِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْصَمَّ إِلَيْهِ قَصْدُ الْمَنْعِ مِنْهُ بِأَنْ قَصَدَ الْإِعْلَامَ بِهِ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِالتَّغْلِيْقِ مَنْ يُبَالَى بِفِعْلِهِ، فَيَأْتِي فِي الْوُقُوعِ: الْخِلَافُ، كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ "الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا".

(فَصَلَّ: قَالَ لِرَوْجَتِهِ: (أَنْتَ طَالِقٌ وَأَشَارَ بِأَصْبُعَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ.. لَمْ يَقَعْ عَدَدٌ إِلَّا بِنِيَّةٍ) لَهُ عِنْدَ قَوْلِهِ: طَالِقٌ، وَلَا اعْتِبَارَ بِالْإِشَارَةِ هُنَا، (فَإِنْ قَالَ مَعَ ذَلِكَ) الْقَوْلَ وَالْإِشَارَةَ: (هَكَذَا.. طَلَّقْتَ فِي أَصْبُعَيْنِ طَلَقَتَيْنِ، وَفِي ثَلَاثِ ثَلَاثًا)، كَمَا تُطْلَقُ فِي أَصْبُعِ طَلَقَةٍ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتَ بِالْإِشَارَةِ) فِي الصُّورَةِ الثَّانِيَةِ (الْمَقْبُوضَتَيْنِ.. صَدَقَ بِيَمِينِهِ) فَلَا يَقَعُ أَكْثَرُ مِنْ طَلَقَتَيْنِ (وَلَوْ قَالَ عَبْدٌ) لِرَوْجَتِهِ: (إِذَا مَاتَ سَيِّدِي فَأَنْتَ طَالِقٌ طَلَقَتَيْنِ، وَقَالَ سَيِّدُهُ) لَهُ: (إِذَا مِتُّ فَأَنْتَ حُرٌّ.. فَعُتِقَ بِهِ) أَي: بِمَوْتِ السَّيِّدِ؛ بِأَنْ خَرَجَ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ (..فَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تَحْرُمُ) عَلَيْهِ (بَلْ لَهُ الرَّجْعَةُ) فِي الْعِدَّةِ (وَتَجْدِيدُ) بَعْدَ انْقِضَائِهَا (قَبْلَ زَوْجٍ)، وَالثَّانِي: تَحْرُمُ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجٍ. وَمَعْلُومٌ: أَنَّ الطَّلَاقَ وَالْعِتْقَ وَقَعَا مَعًا، فَالْأَوَّلُ غَلَبَ الْعِتْقُ؛ فَكَأَنَّهُ تَقَدَّمَ،

(٢) أخرجه ابن ماجه في الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢٠٥٤) قال في الزوائد: إسناده صحيح إن سلم من

الانقطاع، والطبراني في الأوسط (٨٢٧٣) عن ابن عباس - رضي الله عنهما -

وَالثَّانِي عَكْس، فَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الْعَبْدُ مِنَ الثُّلُثِ.. بَقِيَ رِقٌّ مَا زَادَ عَلَيْهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ الْمُبْعُضَ كَالْقَيْ فِي عَدَدِ الطَّلَاقِ، (وَلَوْ نَادَى إِحْدَى زَوْجَتَيْهِ، فَأَجَابَتْهُ الْأُخْرَى، فَقَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ، وَهُوَ يَظُنُّهَا الْمُنَادَاةَ.. لَمْ تُطْلَقِ الْمُنَادَاةُ)؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُخَاطَبْ بِالطَّلَاقِ، وَظَنَّ خِطَابَهَا بِهِ: لَا يَقْتَضِي وَقُوعَهُ عَلَيْهَا، (..وَتُطْلَقُ الْمُجِيبَةُ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِأَنَّهَا خُوِطِبَتْ بِالطَّلَاقِ، وَالثَّانِي: لَا تُطْلَقُ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُقْصَدْ بِالطَّلَاقِ، وَقِيلَ: الْوُجْهَانِ فِي الْوُقُوعِ بَاطِنًا، وَلَا خِلَافَ (١) فِي الْوُقُوعِ ظَاهِرًا، وَاحْتِمَالِ الْإِمَامِ: نَفْيِ الْخِلَافِ فِي الْوُقُوعِ ظَاهِرًا، وَثُبُوتِهِ فِي طَّلَاقِ الْمُنَادَاةِ؛ لِأَنَّهَا الْمَقْصُودَةُ بِالطَّلَاقِ (٢)، وَمَشَى عَلَى ذَلِكَ الْغَزَالِيُّ جَارِمًا بِهِ.

(وَلَوْ عَلَّقَ بِأَكْلِ رُمَانَةٍ وَعَلَّقَ بِنِصْفِ) كَأَنَّ قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ رُمَانَةً فَأَنْتَ طَالِقٌ، وَإِنْ أَكَلْتُ نِصْفَ رُمَانَةٍ فَأَنْتَ طَالِقٌ، فَأَكَلْتُ رُمَانَةً (..فَطُلُقَتَانِ)؛ لِحُصُولِ الصِّفَتَيْنِ بِأَكْلِهَا، وَلَوْ كَانَ التَّغْلِيْقَانِ بِ"كُلَّمَا".. طُلُقْتُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهَا أَكَلْتُ رُمَانَةً مَرَّةً، وَنِصْفَ رُمَانَةٍ مَرَّتَيْنِ، (وَالْحَلْفُ بِالطَّلَاقِ: مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَثٌّ) عَلَى الْفِعْلِ (أَوْ مَنَعٌ) مِنْهُ، (أَوْ تَحْقِيقُ خَبَرٍ) لِيَصْدُقَ فِيهِ، (فَإِذَا قَالَ: إِنْ حَلَفْتُ بِطَّلَاقٍ فَأَنْتَ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ لَمْ تَخْرُجِي، أَوْ إِنْ خَرَجْتِ، أَوْ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْأَمْرُ كَمَا قُلْتُ فَأَنْتَ طَالِقٌ.. وَقَعَ الْمُعْلَقُ بِالْحَلْفِ)؛ لِأَنَّ مَا قَالَهُ حَلَفٌ بِأَقْسَامِهِ السَّابِقَةِ (..وَيَقَعُ الْآخَرُ إِنْ وَجِدَتْ صِفَتُهُ) مِنَ الْخُرُوجِ، أَوْ عَدَمِهِ، أَوْ عَدَمِ كَوْنِ الْأَمْرِ كَمَا قَالَهُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ (وَلَوْ قَالَ) بَعْدَ التَّغْلِيْقِ بِالْحَلْفِ: (إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ، أَوْ جَاءَ الْحُجَّاجُ فَأَنْتَ طَالِقٌ.. لَمْ يَقَعِ الْمُعْلَقُ بِالْحَلْفِ)؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِحَثٍّ، وَلَا مَنَعٍ، وَلَا تَحْقِيقِ خَبَرٍ، وَيَقَعُ الْمُعْلَقُ بِالصِّفَةِ إِذَا وَجَدَتْ، (وَلَوْ قِيلَ لَهُ اسْتَخْبَارًا: أَطَلَقْتَهَا؟) أَيْ: زَوْجَتَكَ (فَقَالَ: نَعَمْ.. فَأَقْرَأَ بِهِ) أَيْ: بِالطَّلَاقِ؛ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا.. فَهِيَ زَوْجَتُهُ فِي الْبَاطِنِ (فَإِنْ قَالَ: أَرَدْتُ) طَلَاقًا (مَاضِيًا، وَرَاجِعًا.. صُدِّقَ بِيَمِينِهِ) فِي ذَلِكَ، (وَإِنْ قِيلَ) لَهُ (ذَلِكَ التِّمَاسًا لِإِنْشَاءٍ، فَقَالَ: نَعَمْ..

(١) قوله: (ولا خلاف) يقصد به داخل المذهب الشافعي، وكذلك (اتفقوا)، و(هذا مجزوم به)، و(قطعا)، أما

إذا قال (هذا مجمع عليه)، فيقصد به: ما اجتمعت عليه الأئمة. الفتح المبين، ص ١٦٧.

(٢) نهاية المطالب للجويني (١٤/٢٩٨).

فَصْرِيحٌ؛ لِأَنَّ نَعْمَ قَائِمَ مَقَامِ "طَلَّقْتُهَا" الْمُرَادِ بِذِكْرِهِ فِي السُّؤَالِ، (وَقِيلَ (١): كِنَايَةً) فَتَحْتَاجُ إِلَى النِّيَّةِ.

(فَصْلٌ: عَلَّقَ الطَّلَاقُ (بِأَكْلِ رَغِيفٍ أَوْ رُمَانَةٍ)؛ كَأَنَّ قَالَ: إِنَّ أَكَلَتِ هَذَا الرِّغِيفَ، أَوْ هَذِهِ الرُّمَانَةَ، أَوْ رَغِيفًا أَوْ رُمَانَةً، فَأَنْتِ طَالِقٌ (فَبَقِيَ) مِنْ ذَلِكَ بَعْدَ أَكْلِهَا لَهُ، (لُبَابَةٌ أَوْ حَبَّةٌ.. لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ؛ لِأَنَّهُ يَصْدُقُ أَنَّهَا لَمْ تَأْكُلِ الرِّغِيفَ، أَوْ الرُّمَانَةَ، وَإِنْ تَسَامَحَ أَهْلُ الْعُرْفِ فِي إِطْلَاقِ أَكْلِ الرِّغِيفِ أَوْ الرُّمَانَةِ فِي ذَلِكَ، وَقَالَ الْإِمَامُ فِي فُتَاتٍ يَدِقُّ مُدْرَكُهُ: لَا أَثَرُ لَهُ فِي بَرٍّ وَلَا حَنِثٍ؛ نَظَرًا لِلْعُرْفِ (وَلَوْ أَكَلَا) أَي: الزَّوْجَانِ (تَمَرًا وَخَلَطًا نَوَاهُمَا، فَقَالَ) لَهَا: (إِنَّ لَمْ تُمَيِّزِي نَوَاكِ) عَنْ نَوَايِ (فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَجَعَلْتُ كُلَّ نَوَاةٍ وَحْدَهَا.. لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ، (إِلَّا أَنْ يَقْصِدَ تَغْيِيئًا) لِنَوَاهَا عَنْ نَوَاهُ.. فَلَا يَخْلُصُ مِنَ الْيَمِينِ بِمَا فَعَلَتْ (وَلَوْ كَانَ بِقِمِّهَا تَمَرَةٌ، فَعَلَّقَ بِبَلْعِهَا، ثُمَّ بِرَمِيِّهَا، ثُمَّ بِإِمْسَاكِهَا) كَأَنَّ قَالَ: إِنَّ بَلْعَتِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ رَمَيْتِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَإِنْ أَمْسَكْتِهَا فَأَنْتِ طَالِقٌ، (فَبَادَرْتُ مَعَ فَرَاغِهِ) مِنَ التَّغْلِيْقِ (بِأَكْلِ بَعْضٍ) مِنْهَا (وَرَمِي بَعْضٌ.. لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ؛ فَإِنْ لَمْ تُبَادِرْ بِأَكْلِ الْبَعْضِ.. وَقَعَ الطَّلَاقُ لِلْإِمْسَاكِ (وَلَوْ اتَّهَمَهَا بِسَرَقَةٍ، فَقَالَ: إِنَّ لَمْ تَصْدُقِينِي فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَالَتْ) كَلَامَيْنِ، أَحَدُهُمَا: (سَرَقْتُ)، وَالْآخَرُ: (مَا سَرَقْتُ.. لَمْ تُطَلِّقِي)؛ لِأَنَّهَا صَادِقَةٌ فِي أَحَدِ الْكَلَامَيْنِ، (وَلَوْ قَالَ: إِنَّ لَمْ تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ حَبِّ هَذِهِ الرُّمَانَةِ قَبْلَ كَسْرِهَا)، فَأَنْتِ طَالِقٌ (..فَالْخَلَاصُ) مِنَ الْيَمِينِ: (أَنْ تَذْكُرَ عَدَدًا يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَنْقُصُ عَنْهُ) بِكَمَائَةٍ (ثُمَّ تَزِيدُ وَاحِدًا وَاحِدًا)، فَتَقُولُ: مِائَةٌ وَوَاحِدٌ، مِائَةٌ وَاثْنَانِ، وَهَكَذَا (حَتَّى تَبْلُغَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهَا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ)، فَتَكُونُ مُخْبِرَةً بِعَدِيدِهَا، (وَالصُّوْرَتَانِ): هَذِهِ، وَالَّتِي قَبْلَهَا (فَيَمْنٌ لَمْ يَقْصِدْ تَغْيِيئًا)، فَإِنْ قَصَدَهُ.. فَلَا يَخْلُصُ مِنَ الْيَمِينِ بِمَا ذَكَرْتُهُ.

(وَلَوْ قَالَ لِثَلَاثٍ: مَنْ لَمْ تُخْبِرْنِي بِعَدَدِ رَكَعَاتِ فَرَائِضِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَتْ وَاحِدَةً: سَبْعَ عَشْرَةَ)، أَي: فِي الْغَالِبِ (وَأُخْرَى: خَمْسَ عَشْرَةَ) أَي: يَوْمَ جُمُعَةٍ (وِثَالِثَةٌ: إِحْدَى عَشْرَةَ) أَي: لِمُسَافِرٍ (..لَمْ يَقَعْ) طَلَاقٌ (عَلَى وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ؛ لِصَدَقِهِنَّ فِيمَا ذَكَرْنَهُ مِنَ الْعَدَدِ ؛

(١) قال الدميري: المصنف تبع "المحرر" في حكاية هذا وجها، وهو في "الشرح"، و"الروضة": قول، وإنما قال

الدميري هذا: لأن مصطلح (وقيل:) يستعمل في الأوجه، وليس في الأقوال، كما ذكر النووي في

مقدمته، حيث قال: "وحيث أقول: (وقيل: كذا) فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه.

كَمَا تَقَدَّمَ، (وَلَوْ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ إِلَى حِينٍ، أَوْ زَمَانٍ، أَوْ بَعْدَ حِينٍ)، أَوْ زَمَانٍ (.. طَلَّقْتَ بِمُضِيِّ لَحْظَةٍ)؛ لِصَدَقِ الْحِينُ وَالزَّمَانُ بِهَا، وَإِلَى "بِمَعْنَى "بَعْدَ"، (وَلَوْ عَلَّقَ) الطَّلَاقَ (بِرُؤْيَةِ زَيْدٍ، أَوْ لَمْسِهِ، أَوْ قَذْفِهِ.. تَتَأَوَّلُهُ) التَّعْلُوقُ، (حَيًّا وَمَيِّتًا)، أَمَّا فِي الرُّؤْيَةِ وَاللَّمْسِ: فَوَاضِحٌ، وَأَمَّا فِي الْقَذْفِ: فَلِأَنَّ قَذْفَ الْمَيِّتِ كَقَذْفِ الْحَيِّ فِي الْإِثْمِ وَالْحُكْمِ، وَيَكْفِي رُؤْيَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْبَدَنِ، أَوْ لَمْسُهُ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، وَلَا يَكْفِي لَمْسُ الشَّعْرِ وَالظُّفْرِ (بِخِلَافِ ضَرْبِهِ) إِذَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِهِ.. فَلَا يَتَأَوَّلُهُ التَّعْلِيقُ مَيِّتًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ فِي التَّعْلِيقِ بِالضَّرْبِ: التَّشْوِيشُ، وَالْمَيِّتُ لَا يُحْسُ بِالضَّرْبِ حَتَّى يَتَشَوَّشَ بِهِ، (وَلَوْ خَاطَبْتَهُ) زَوْجَتُهُ (بِمَكْرُوهِ كَذِيَا سَفِيهِ) "يَا خَسِيسٌ"، فَقَالَ: (إِنْ كُنْتَ كَذَاك) أَي: سَفِيهَا أَوْ خَسِيسًا (فَأَنْتَ طَالِقٌ: إِنْ أَرَادَ مُكَافَأَتَهَا بِإِسْمَاعٍ مَا تَكَرَّهُ.. طَلَّقْتَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَفَهُ) أَوْ خِسَةً، (أَوْ: التَّعْلِيقُ.. أُغْتَبِرَتِ الصِّفَةُ)، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً.. لَمْ تُطْلَقْ (وَكَذَا إِنْ لَمْ يَقْصِدْ) شَيْئًا.. تُعْتَبَرُ الصِّفَةُ (فِي الْأَصَحِّ)؛ نَظَرًا لِمَوْضِعِ اللَّفْظِ، فَلَا تُطْلَقُ عِنْدَ عَدَمِهَا، وَالتَّانِي: لَا تُعْتَبَرُ الصِّفَةُ؛ بَلْ يُحْكَمُ بِوُقُوعِ الطَّلَاقِ فِي الْحَالِ؛ نَظَرًا إِلَى الْغُرْفِ فِي قَصْدِ الْمُكَافَأَةِ بِمَا ذُكِرَ (وَالسَّفَةُ مُنَافٍ لِطَّلَاقِ التَّصَرُّفِ) أَي: هُوَ صِفَةٌ لَا يَكُونُ لِلشَّخْصِ مَعَهَا مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، كَأَنْ يَبْلُغَ مُبَذَّرًا يُصْبِغُ الْمَالَ فِي غَيْرِ وَجْهِهِ الْجَائِزِ، (وَالْخَسِيسُ، قِيلَ: مَنْ بَاعَ دِينَهُ بِدُنْيَاهُ) بِأَنْ تَرَكَ دِينَهُ؛ لِاشْتِغَالِهِ بِدُنْيَاهُ (وَيُشَبِّهُ أَنْ يُقَالَ: هُوَ مَنْ يَتَعَاطَى غَيْرَ لَائِقٍ بِهِ بَخْلًا) بِمَا يَلِيْقُ بِهِ.

كِتَابُ الرَّجْعَةِ

هِيَ: الرَّدُّ إِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِي الْعِدَّةِ. ^(١)

(شَرَطُ الْمُزْتَجِعِ: أَهْلِيَّةُ النِّكَاحِ بِنَفْسِهِ) بِأَنْ يَكُونَ بَالِغًا، عَاقِلًا، فَلَا يَصِحُّ رَجْعُهُ مُزْتَدٍ وَلَا صَبِيٍّ وَلَا مَجْنُونٍ ^(٢).

(وَلَوْ طَلَّقَ فَجُنَّ فَلِلْوَلِيِّ الرَّجْعَةُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ حَيْثُ لَهُ ابْتِدَاءُ النِّكَاحِ) بِأَنْ يَحْتَاجَ الْمَجْنُونُ إِلَيْهِ كَمَا تَقَدَّمَ وَالْخِلَافُ مَبْنِيٌّ عَلَى الْخِلَافِ فِي جَوَازِ التَّوَكُّيلِ فِي الرَّجْعَةِ فَالصَّحِيحُ جَوَازُهُ كَالْتَّوَكُّيلِ فِي ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ النِّكَاحِ وَالرَّجْعَةِ يُسْتَبَاحُ بِهِ مُحَرَّمٌ.

(وَتَحْصُلُ) الرَّجْعَةُ (بِرَاجَعَتِكَ وَرَجَعْتُكَ وَارْتَجَعْتُكَ) وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ صَرِيحَةٌ ^(٣).

وَيُسْتَحَبُّ الْإِضَافَةُ مَعَهَا كَأَنْ يَقُولَ: رَاجَعْتُكَ إِلَيَّ، أَوْ إِلَى نِكَاحِي.

(وَالْأَصَحُّ: أَنَّ الرَّدَّ وَالْإِمْسَاكَ) كَقَوْلِهِ: رَدَدْتُكَ، أَوْ مَسَكْتُكَ (صَرِيحَانِ) أَيْضًا؛ لِوُرُودِهِمَا فِي الْقُرْآنِ، قَالَ تَعَالَى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} [البقرة: ٢٢٨] أَيْ فِي الْعِدَّةِ {إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨] أَيْ رَجْعَةً كَمَا قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، وَقَالَ تَعَالَى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩].

وَالثَّانِي: أَنَّهُمَا كِنَايَتَانِ يُحْتَاجُ مَعَهُمَا إِلَى النِّيَّةِ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ ^(٤) لَمْ يَتَكَرَّرْ فِي الْقُرْآنِ، وَالثَّانِي ^(٥) يَحْتَمِلُ الْإِمْسَاكَ فِي الْبَيْتِ أَوْ بِالْيَدِ.

(١) هذا هو التعريف الشرعي أو الاصطلاحي للرجعة، وأما التعريف اللغوي فهي: المرة من الرجوع، والدليل عليها:

- ١- قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا}؛ "بِرَدِّهِنَّ" الرد الرجعة.
- ٢- ويدل لها من السنة قوله ﷺ لعمر: (مره فليراجعها).
- ٣- وقوله ﷺ: "أتاني جبريل فقال لي: راجع حفصة؛ فإنها صوامة قوامة، وإنها زوجتك في الجنة".
- ٤- أجمعت الأمة على جواز الرجعة.

(٢) لا تصح الرجعة ممن ذكر: لأنهم ليسوا أهلاً لبدء النكاح بأنفسهم.

(٣) لقوله ﷺ في حديث ابن عمر: (فليراجعها).

(٤) أي لفظ: الرَّد.

(٥) أي لفظ: الإمساك.

(وَأَنَّ التَّرْوِيجَ وَالنِّكَاحَ) كَقَوْلِهِ: تَرَوَّجْتُكَ، أَوْ نَكَحْتُكَ (كِتَابَتَانِ) ^(١).

وَالثَّانِي: هُمَا صَرِيحَانِ؛ لِأَنَّهُمَا صَالِحَانِ لِابْتِدَاءِ الْحِلِّ، فَلَأَن يَصْلُحَا لِلتَّذَارُكِ أُولَى. وَدُفِعَ هَذَا: بِأَنَّ مَا كَانَ صَرِيحًا فِي بَابِهِ لَا يَكُونُ صَرِيحًا فِي غَيْرِهِ كَالطَّلَاقِ ^(٢).

(وَلْيُقْل: رَدَدْتُهَا إِلَيَّ، أَوْ إِلَى نِكَاحٍ) بِنَاءٌ عَلَى أَنَّ الرَّدَّ صَرِيحٌ وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِنِيَّةٍ.

وَقِيلَ: لَا تُشْتَرِطُ الْإِضَافَةُ الْمَذْكُورَةُ كَمَا فِي لَفْظِ الرَّجْعَةِ.

وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لَفْظَ الرَّجْعَةِ مَشْهُورٌ فِي مَعْنَاهَا بِخِلَافِ لَفْظِ الرَّدِّ الْمُطْلَقِ لِإِيْهَامِهِ الْمَعْنَى الْمُقَابِلَ لِلْقَبُولِ أَوْ الرَّدِّ إِلَى الْأَبْوَيْنِ بِسَبَبِ الْفِرَاقِ.

(وَالْجَدِيدُ: أَنَّهُ لَا يَشْتَرِطُ الْإِشْهَادُ) فِي الرَّجْعَةِ؛ لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ اسْتِدَامَةِ النِّكَاحِ السَّابِقِ ^(٣).

وَالْقَدِيمُ الْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ فِي الْجَدِيدِ أَيْضًا: أَنَّهُ يُشْتَرِطُ أَيْضًا لَا لِكَوْنِهَا بِمَنْزِلَةِ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ؛ بَلِ الظَّاهِرُ قَوْلُهُ تَعَالَى: {فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطَّلَاق: ٢] أَيْ عَلَى الْإِمْسَاكِ الَّذِي هُوَ بِمَعْنَى الرَّجْعَةِ، وَعَلَى الْمَفَارِقَةِ.

وَأُجِيبَ: بِحَمْلِ ذَلِكَ عَلَى الْإِسْتِحْبَابِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى {وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: ٢٨٢] لِلأَمْنِ مِنَ الْجُحُودِ.

(فَتَصِحُّ بِكِنَايَةِ) ^(٤) بِنَاءٌ عَلَى عَدَمِ الْإِشْتِرَاطِ.

وَلَا تَصِحُّ بِهَا مَعَ النِّيَّةِ بِنَاءٌ عَلَى الْإِشْتِرَاطِ؛ لِأَنَّ الشُّهُودَ لَا يَطْلَعُونَ عَلَى النِّيَّةِ.

فَرُعُ: تَصِحُّ الرَّجْعَةُ بِغَيْرِ الْعَرَبِيَّةِ. وَقِيلَ: لَا. وَقِيلَ: إِنَّ أَحْسَنَ الْعَرَبِيَّةِ لَمْ تَصِحَّ بِغَيْرِهَا، وَإِلَّا صَحَّتْ بِهَا.

(١) أي الأصح: أن التزويج والنكاح من ألفاظ الكناية في الرجعة: لعدم استعمالهما في الرجعة.

(٢) والتزويج والنكاح صريحان في باب النكاح، وبالتالي لا يمكن أن يكونا صريحان في باب الرجعة.

(٣) ولأثر عمران بن حصين رضي الله عنه سئل عن راجع امرأته ولم يشهد فقال عمران: (راجع في غير سنة فليشهد الآن) فلو كان الإشهاد شرطاً.. لما كان للإشهاد على ما سبق معنى.

(٤) أي تصح الرجعة إذا كانت بلفظ من ألفاظ الكناية.

(وَلَا تُقْبَلُ) الرَّجْعَةُ (تَغْلِيْقًا) كَالنِّكَاحِ^(١) فَإِذَا قَالَ: رَاجِعْتُكَ إِنْ شِئْتَ فَقَالَتْ: شِئْتُ لَا تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ.

(وَلَا تَحْصُلُ بِفِعْلِ كَوَطِءٍ) وَمُقَدِّمَاتِهِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حُرْمَ بِالطَّلَاقِ كَمَا سَيَأْتِي وَمَقْصُودُ الرَّجْعَةِ حُلُّهُ فَلَا تَحْصُلُ بِهِ.

(وَتَخْتَصُّ الرَّجْعَةُ بِمَوْطُوءَةٍ طَلَّقَتْ بِلَا عَوْضٍ لَمْ يَسْتَوْفِ عَدَدَ طَلَقِهَا بَاقِيَةً فِي الْعِدَّةِ) بِخِلَافِ مَنْ طَلَّقَتْ قَبْلَ الْوُطْءِ^(٢)، أَوْ بَعْدَهُ بِعَوْضٍ^(٣)، أَوْ بِدُونِهِ وَاسْتَوْفِيَ عَدَدُ طَلَقِهَا، أَوْ لَمْ يُسْتَوْفَ وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا لِحُصُولِ النِّيُّونَةِ فِيمَا ذَكَرَ، وَبِخِلَافِ مَنْ انْفَسَخَ نِكَاحُهَا لِاخْتِصَاصِ الرَّجْعَةِ بِالطَّلَاقِ^(٤).

(مَحَلٌّ لِحَلٍّ لَا مُرْتَدَّةٌ) فَإِنَّهَا لَا تَحِلُّ لِأَحَدٍ كَمَا تَقْدَمُ فِي مَحَلِّهِ. فَلَوْ ارْتَدَّتِ الرَّجْعِيَّةُ فِي الْعِدَّةِ لَمْ تَصَحَّ رَجْعَتُهَا، لِأَنَّهَا آيَلَةٌ إِلَى الْفِرَاقِ بِالرَّدِّ حَتَّى لَوْ رَاجَعَهَا، ثُمَّ عَادَتْ إِلَى الْإِسْلَامِ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا بُدَّ مِنْ اسْتِنَافِ الرَّجْعَةِ.

(وَإِذَا ادَّعَتْ انْقِضَاءَ عِدَّةٍ أَشْهُرٍ) كَأَنَّ تَكُونَ آيَسَةً (وَأَنْكَرَ: صَدَّقَ بِبَيِّنَةٍ) لِرُجُوعِ ذَلِكَ إِلَى الْإِخْتِلَافِ فِي وَقْتِ طَلَاقِهِ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيهِ.

(أَوْ وَضَعَ حَمْلٌ لِمُدَّةٍ إِمْكَانٍ وَهِيَ مِمَّنْ تَحِيضُ لَا آيَسَةٌ فَالْأَصَحُّ: تَصْدِيقُهَا بِبَيِّنَةٍ)؛ لِأَنَّ النِّسَاءَ مُؤْتَمِنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ، وَالثَّانِي: لَا وَتُطَالَبُ بِالْبَيِّنَةِ لِإِمْكَانِهَا، فَإِنَّ الْقَوَائِلَ تَشْهَدُنَ الْوِلَادَةَ غَالِبًا.

أَمَّا الْآيَسَةُ مِنَ الْحَيْضِ فَلَا تُصَدَّقُ فِي دَعْوَى الْوَضْعِ، لِأَنَّهَا لَا تَحْبِلُ.

وَأَمَّا مُدَّةُ الْإِمْكَانِ فَبَيِّنَتُهَا بِقَوْلِهِ:

- (وَإِنْ ادَّعَتْ وَلَادَةً) وَلَدٍ (تَامَ فِيمَا كَانَهُ سِتَّةَ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ) لَحْظَةً لِلْوُطْءِ وَلَحْظَةً لِلْوِلَادَةِ.

(١) بجامع أن كلا من النكاح والرجعة سببا لحل الزوجة للزوج.

(٢) فغير الموطوءة كالمطلقة قبل الدخول بها لا رجعة لها؛ إذ لا عدة لها، والرجعة إنما تكون في العدة.

(٣) فلو كان الطلاق بعد الدخول ولكن كان بعوض فلا تصح الرجعة؛ لأن المطلقة بالعوض بائن تملك نفسها.

(٤) فإن فسخ نكاح الزوجة فلا رجعة؛ لأن الله تعالى أناط الرجعة بالطلاق فاقتصت به.

- (أَوْ) وَلَادَةٌ (سَقَطَ مُصَوِّرٌ ادَّعَتْ الْمُعْتَدَّةُ فَمِائَةً وَعِشْرُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ.
- (أَوْ) وَلَادَةٌ (مُضْغَةٌ بِلاَ صُورَةٍ فَتَمَانُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ.
- وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ أَقْسَامُ الْحَمْلِ الَّذِي تَنْقُضِي بِهِ الْعِدَّةَ عَلَى خِلَافِ فِي الثَّالِثِ يَأْتِي فِي بَابِهَا.
- فَإِنْ ادَّعَتْ الْوَضْعَ فِي أَيِّ قِسْمٍ لِأَقَلِّ مِمَّا ذُكِرَ فِيهِ لَمْ تُصَدَّقْ وَكَانَ لِلزَّوْجِ رَجْعُهَا.
- وَقَوْلُهُ مِنْ وَقْتِ النِّكَاحِ بِنَاءٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ إِمْكَانِ اجْتِمَاعِ الزَّوْجَيْنِ وَقَتِ النِّكَاحِ. وَفِي غَيْرِ الْغَالِبِ كَالْمَشْرِقِيِّ مَعَ الْمَغْرِبِيَّةِ تَكُونُ الْمُدَّةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ حِينِ إِمْكَانِ الْاجْتِمَاعِ.
- وَدَلِيلُ الْمُدَّةِ الْأُولَى - أَيْ اعْتِبَارُ مُدَّةِ الْحَمْلِ بِسِتَّةِ أَشْهُرٍ - قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥] مَعَ قَوْلِهِ {وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤].
- وَدَلِيلُ الْمُدَّةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّلَاثَةِ حَدِيثُ الصَّحِيحَيْنِ «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» إِلَى آخِرِهِ^(١).
- (أَوْ) ادَّعَتْ (انْقِضَاءَ أَقْرَاءٍ:
- فَإِنْ كَانَتْ حُرَّةً وَطَلَّقَتْ فِي طَهْرٍ فَأَقَلُّ الْإِمْكَانِ: اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ) وَذَلِكَ بِأَنْ تَطْلُقَ وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الطَّهْرِ لَحْظَةٌ ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَطْهَرُ أَقَلَّ الطَّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهَرُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ لَحْظَةً.
- وَهَذِهِ اللَّحْظَةُ لِاسْتِبَانَةِ الْقَرءِ الثَّالِثِ، وَلَيْسَتْ مِنْ نَفْسِ الْعِدَّةِ.
- وَقِيلَ: هِيَ مِنْهَا حَتَّى تَصِحَّ الرَّجْعَةُ فِيهَا.
- وَاللَّحْظَةُ الْأُولَى قِيلَ: لَا تُعْتَبَرُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ إِنَّ الْقَرءَ الْإِنْتِقَالَ مِنْ طَهْرٍ إِلَى دَمٍ، وَيُصَوَّرُ عَلَى ذَلِكَ بِمَا إِذَا عَلِقَ بِأَخْرِ جُزْءٍ مِنْ طَهْرِهَا

(١) صحيح البخاري، كتاب: بدء الخلق، باب: ذكر الملائكة، ح: (٣٢٠٨)، صحيح مسلم، كتاب: القدر، باب: كيفية خلق الأدمي في بطن أمه، ح: (٢٦٤٣).

- (أَوْ فِي حَيْضٍ فَسَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ^(١)) وَذَلِكَ بِأَنْ يُعْلَقَ الطَّلَاقُ بِآخِرِ جُزْءٍ مِنَ الْحَيْضِ، ثُمَّ تَطْهَرُ أَقَلَّ الطَّهْرِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، ثُمَّ تَحِيضُ أَقَلَّ الْحَيْضِ يَوْمًا، وَلَيْلَةً، ثُمَّ تَطْهَرُ وَتَحِيضُ كَذَلِكَ، ثُمَّ تَطْهَرُ أَقَلَّ الطَّهْرِ، ثُمَّ تَطْعَنُ فِي الْحَيْضِ لَحْظَةً. وَهَذِهِ اللَّحْظَةُ لِلِاسْتِبَانَةِ كَمَا تَقَدَّمَ وَلَا حَاجَةَ هُنَا إِلَى لَحْظَةٍ فِي الْأَوَّلِ.

تَنْبِيْهُ: قَوْلُهُ فِي طَهْرِ الْمَسْأَلَتَيْنِ: أَيُّ مَسْبُوقٍ بِحَيْضٍ، أَمَّا مَنْ ابْتَدَأَهَا الْحَيْضُ بَعْدَ الطَّلَاقِ، فَأَقَلُّ الْإِمْكَانِ فِيهَا - حُرَّةٌ - ثَمَانِيَّةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ بِنَاءً فِيهِمَا عَلَى الرَّاجِحِ أَنَّ الْقَرَّةَ الطَّهْرُ الْمُحْتَوِشُ بِدَمَيْنِ فَإِنْ قُلْنَا بِالْمَرْجُوحِ، فَالْحُكْمُ كَحُكْمِ مَنْ حَاضَتْ قَبْلَ الطَّلَاقِ وَقَدْ تَقَدَّمَ.

(وَتُصَدِّقُ) الْمَرْأَةُ فِي ادِّعَاءِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِأَقَلِّ مَدَّةِ الْإِمْكَانِ بِيَمِينِهَا (إِنْ لَمْ تُخَالِفْ) فِيمَا ادَّعَتْهُ (عَادَةً) لَهَا (دَائِرَةً)^(٢).

وَكَذَا إِنْ خَالَفتْ فِي الْأَصَحِّ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَنَغَيَّرُ^(٣). وَالثَّانِي: لَا تُصَدِّقُ لِلتَّهْمَةِ.

(وَلَوْ وَطِئَ) الرَّوْجُ (رَجْعِيَّةً وَاسْتَأْنَفَتْ الْأَقْرَاءَ مِنْ وَقْتِ الْوُطْءِ: رَاجَعَ فِيمَا كَانَ بَقِيَ) مِنْ أَقْرَاءِ الطَّلَاقِ دُونَ مَا يُزَادُ عَلَيْهَا لِلْوُطْءِ.

(وَيُحَرِّمُ الْإِسْتِمْتَاعَ بِهَا) أَيُّ بِالرَّجْعِيَّةِ بِوُطْءٍ وَغَيْرِهِ؛ لِأَنَّهَا مُفَارَقَةٌ كَالْبَائِنِ^(٤).

(فَإِنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ) وَإِنْ اعْتَقَدَ تَحْرِيمَهُ لِشُبْهَةِ اخْتِلَافِ الْعُلَمَاءِ فِي حِلِّهِ، فَإِنَّ الْإِمَامَ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ بِحِلِّهِ لِحُصُولِ الرَّجْعَةِ بِهِ عِنْدَهُ.

(١) أي لو ادعت المرأة انقضاء العدة بالأقراء وقد طلقت في حيض فأقل مدة إيمان تصدق فيها هي: سبعة وأربعون يومًا ولحظة.

(٢) لقوله تعالى: {وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ}، ولأنه لا يعرف إلا من جهتها فصدمت عند الإمكان.

(٣) أي الأصح: تُصَدِّقُ الْمَرْأَةُ فِي ادِّعَاءِ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ بِأَقَلِّ مَدَّةِ الْإِمْكَانِ بِيَمِينِهَا حَتَّى إِنْ خَالَفتْ فِيمَا ادَّعَتْهُ عَادَةً لَهَا دَائِرَةً؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ قَدْ تَنَغَيَّرَتْ وَهِيَ مُؤْتَمَنَةٌ.

(٤) يُحَرِّمُ عَلَى الزَّوْجِ الْإِسْتِمْتَاعَ بِالرَّجْعِيَّةِ بِالْوُطْءِ وَمَقْدَمَاتِهِ كَلْمَسٍ أَوْ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ بَغْيَرِهَا؛ وَالِدَلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:

١- لِأَنَّ ابْنَ عَمَرَ: طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ بِمَسْكَنِ حَفْصَةَ، وَكَانَتْ طَرِيقَهُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَانَ يَسْلُكُ الطَّرِيقَ الْآخَرَ. مِنْ

أَدْبَارِ الْبُيُوتِ كَرَاهَةً أَنْ يَسْتَأْذِنَ عَلَيْهَا حَتَّى يَرَا جَعَهَا.

٢- وَلِأَنَّ النِّكَاحَ يَبِيحُ الْوُطْءَ فَيُحَرِّمُهُ الطَّلَاقُ لِأَنَّهُ ضِدُّهُ، فَالزَّوْجَةُ صَارَتْ بِالطَّلَاقِ مُفَارَقَةً كَالْبَائِنِ.

(وَلَا يُعْزَرُ^(١) إِلَّا مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ^(٢))، بِخِلَافِ مُعْتَقِدِ حِلِّهِ وَالْجَاهِلِ بِتَحْرِيمِهِ^(٣).

(وَيَجِبُ مَهْرُ الْمَثَلِ إِنْ لَمْ يُرَاجَعْ^(٤)).

وَكَذَا إِنْ رَاجَعَ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمُنْصُوصِ^(٥).

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي: لَا يَجِبُ فِي قَوْلٍ مُخْرَجٍ مِنْ نَصِّهِ، فِيمَا إِذَا ارْتَدَّتْ بَعْدَ الدُّخُولِ فَوُطِّئَهَا الزَّوْجُ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَا يَجِبُ مَهْرٌ، وَخُرَجَ قَوْلٌ بِوُجُوبِهِ مِنَ النَّصِّ فِي وَطْءِ الرَّجْعِيَّةِ وَالرَّاجِعِ تَقْرِيرُ النَّصِّ.

وَالْفَرْقُ أَنَّ أَثَرَ الرَّدَّةِ يَرْتَفِعُ بِالْإِسْلَامِ، وَأَثَرُ الطَّلَاقِ لَا يَرْتَفِعُ بِالرَّجْعَةِ، وَالْحِلُّ بَعْدَهَا كَالْمُسْتَقَادِ بَعْدَ آخَرِ.

(وَيَصِحُّ إِيْلَاءٌ، وَظَهَارٌ، وَطَّلَاقٌ، وَلِعَانٌ) مِنَ الرَّجْعِيَّةِ؛ لِبَقَاءِ الْوِلَايَةِ عَلَيْهَا بِمِلْكِ الرَّجْعَةِ.

(وَيَتَوَارَثَانِ) أَيُّ الزَّوْجِ وَالرَّجْعِيَّةُ لِبَقَاءِ آثَارِ الزَّوْجِيَّةِ فِيهَا بِصَحَّةِ مَا ذُكِرَ.

وَالْغَرَضُ مِنْ جَمْعِهِمُ الْخَمْسَ هُنَا الْإِشَارَةُ إِلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: الرَّجْعِيَّةُ زَوْجَةٌ فِي خَمْسِ آيَاتٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى أَيُّ آيَاتِ الْمَسَائِلِ الْخَمْسِ الْمَذْكُورَةِ، وَسَيَأْتِي فِي التَّفَقَّاتِ وَجُوبُ نَفَقَتِهَا.

(وَإِذَا ادَّعَى وَالْعِدَّةُ مُنْقَضِيَّةً رَجَعَتْ فِيهَا فَأَنْكَرَتْ:

- فَإِنْ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الْإِنْقِضَاءِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَ: رَاجَعْتُ يَوْمَ الْخَمِيسِ فَقَالَتْ: بَلِ السَّبْتِ: صَدِّقْتُ بِبَيِّنِهَا) أَنَّهَا لَا تَعْلَمُهُ رَاجِعَ يَوْمَ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ إِلَى يَوْمِ السَّبْتِ.

(١) التعزير هو: تأديب دون الحد على معصية لاحت فيها ولا كفارة.

(٢) يُعْزَرُ الزوج معتقد حرمة وطء مطلقته قبل رجعتها؛ لإقدامه على ما يعلم أنه ممتنع عليه.

(٣) لَا يُعْزَرُ الزوج معتقد حل وطء مطلقته قبل رجعتها أو الجاهل بتحريمه؛ للعدو في فعله.

(٤) أي إذا لم يراجع الزوج زوجته بعد هذا الوطء: يجب عليه مهر المثل في هذه الحالة؛ لأنه لم يكن له وطؤها، ولنلا يخلو الوطء عن عقروعية.

(٥) أي إذا راجع الزوج زوجته بعد هذا الوطء: يجب عليه مهر المثل في هذه الحالة على المذهب المنصوص عليه.

- (أَوْ عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَقَالَتْ: انْقَضَتْ الْخَمِيسَ، وَقَالَ: السَّبْتُ: صَدَّقَ بِيَمِينِهِ) أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ انْقِضَائِهَا إِلَى يَوْمِ السَّبْتِ.
- (وَإِنْ تَنَازَعَا فِي السَّبْقِ بِلَا اتِّفَاقٍ) بِأَنَّ اقْتِصَرَ الزَّوْجُ عَلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ سَابِقَةٌ، وَالزَّوْجَةُ عَلَى أَنَّ انْقِضَاءَ الْعِدَّةِ سَابِقٌ: (فَالْأَصْلُ تَرْجِيحُ سَبْقِ الدَّعْوَى فَإِنْ ادَّعَتْ الْإِنْقِضَاءَ، ثُمَّ ادَّعَى رَجْعَةً قَبْلَهُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا) أَنَّ عِدَّتَهَا انْقَضَتْ قَبْلَ الرَّجْعَةِ وَسَقَطَتْ دَعْوَى الزَّوْجِ.
- (أَوْ ادَّعَاهَا) أَيِ الرَّجْعَةِ (قَبْلَ انْقِضَاءِ) الْعِدَّةِ (فَقَالَتْ: بَعْدَهُ: صَدَّقَ) بِيَمِينِهِ أَنَّهُ رَاجَعَ قَبْلَ انْقِضَائِهَا.
- (قُلْتُ: فَإِنْ ادَّعَا مَعًا: صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ) نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنِ الْبَغَوِيِّ وَغَيْرِهِ، وَأَسْقَطَ النَّوَوِيُّ الْعَزْوَ مِنَ الرَّوْضَةِ، وَالْوَجْهَ الثَّانِي: تَصْدِيقُهَا مُطْلَقًا، وَالثَّلَاثُ: تَصْدِيقُهُ.
- (وَمَتَى ادَّعَاهَا) أَيِ الرَّجْعَةِ (وَالْعِدَّةُ بَاقِيَةٌ) وَأُنْكَرَ:
- (صَدَّقَ بِيَمِينِهِ)؛ لِقُدْرَتِهِ عَلَى إِثْنَائِهَا.
- وَقِيلَ: هِيَ الْمُصَدِّقَةُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الرَّجْعَةِ، فَإِنْ أَرَادَهَا أَنْشَأَهَا.
- (وَإِذَا طَلَّقَ دُونَ ثَلَاثٍ، وَقَالَ: وَطِئْتُ فَلِي رَجْعَةٌ، وَأُنْكَرْتُ) وَطَأُّهُ:
- (صُدِّقَتْ بِيَمِينٍ) أَنَّهُ مَا وَطِئَهَا؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْوُطْءِ.

كِتَابُ الْعِدَّةِ

جَمْعُ عِدَّةٍ وَهِيَ: مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَعْرِفَ بَرَاءَةَ رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ.

(عِدَّةُ النِّكَاحِ صُرْبَانِ:

الْأَوَّلُ: مُتَعَلِّقٌ بِفُرْقَةٍ حَيٍّ بِطَلَاقٍ وَفَسْخٍ) كَلْعَانٍ وَرَضَاعٍ.

(وَأَيْمًا تَجِبُ: بَعْدَ وَطْءٍ) بِخِلَافِ مَا قَبْلَهُ؛ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ

فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ} [الأحزاب: ٤٩]

(أَوْ اسْتِذْخَالَ مَنِيه)؛ لِأَنَّهُ كَالْوَطْءِ.

(وَإِنْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ) كَمَا فِي الصَّغِيرِ تَعَبُّدًا.

(لَا بِخُلُوةٍ فِي الْجَدِيدِ)^(١)، وَالْقَدِيمِ: تُقَامُ مَقَامَ الْوَطْءِ؛ لِأَنَّهَا مَظْنُونَةٌ^(٢).

(وَعِدَّةُ حُرَّةٍ ذَاتِ أَقْرَاءٍ) بِأَنْ كَانَتْ نَحِيضٌ (ثَلَاثَةً) قَالَ تَعَالَى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ

ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ^(٣).

(وَالْقُرْءُ) الَّذِي هُوَ وَاحِدُ الْأَقْرَاءِ الَّتِي يُعْتَدُّ بِهَا: (الطُّهْرُ) أَيُّ الْمُرَادِ بِهِ ذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ

تَعَالَى {فَطَلَّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١] أَيُّ فِي زَمَنِهَا وَهُوَ زَمَانُ الطُّهْرِ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ فِي

الْحَيْضِ حَرَامٌ، كَمَا تَقَدَّمَ وَزَمَنُ الْعِدَّةِ يَعْقُبُ زَمَنَ الطَّلَاقِ.

وَقَدْ يُرَادُ بِالْقُرْءِ: الْحَيْضُ؛ كَمَا فِي حَدِيثِ النَّسَائِيِّ وَغَيْرِهِ «تَتَرَكُّ الصَّلَاةُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا»^(١):

وَالْقُرْءُ بِالْفَتْحِ وَالضَّمِّ: مُشْتَرَكٌ بَيْنَ الطُّهْرِ وَالْحَيْضِ.

(١) أي لا تجب العدة بالخلوة الصحيحة ؛ لعموم قوله تعالى: {مَنْ قَبْلَ أَنْ تَمْسُوهُنَّ}.

(٢) وأيضا لقول عمر وعلي رضي الله عنهما: إذا أغلق بابا وأرخى سترا فلها الصداق كاملا وعليها العدة.

(٣) وشملت عبارة المصنف: ما إذا شربت دواء حتى حاضت وهو كذلك، كما تسقط الصلاة عنها به؛ وروي عن سعيد

بن منصور عن ابن عمر: أنه سئل تشرب الدواء ليرتفع حيضها حتى تطوف وتنفر.. فلم يربذلك بأسا

وبعث لهن ماء الأراك.

وَقِيلَ: إِنَّهُ حَقِيقَةٌ فِي الطُّهْرِ مَجَازٌ فِي الْحَيْضِ وَيُجْمَعُ عَلَى أَقْرَاءٍ وَقُرُوءٍ وَأَقْرُؤٍ.

(فَإِنْ طَلَّقَتْ طَاهِرًا) وَقَدْ بَقِيَ مِنْ زَمَنِ الطُّهْرِ شَيْءٌ: (انْقَضَتْ بِالطَّغْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ) ؛
لِحُصُولِ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ فِي ذَلِكَ بِأَنْ يُحْسَبَ مَا بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ، الَّذِي طَلَّقَتْ فِيهِ قَرَأًا سِوَاءَ
جَامِعٍ فِيهِ أَمْ لَا.

وَلَا بُعْدَ فِي تَسْمِيَةِ قُرَائِنِ وَبَعْضِ الثَّالِثِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ كَمَا فُسِّرَ قَوْلُهُ تَعَالَى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ
مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] بِشَوَالٍ وَذِي الْقَعْدَةِ وَبَعْضِ ذِي الْحِجَّةِ.

فَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ زَمَنِ الطُّهْرِ شَيْءٌ كَأَنَّ قَالَ: أَنْتَ طَالِقٌ آخِرَ طَهْرِكَ: فَإِنَّمَا تَنْقُضِي عِدَّتَهَا
بِالطَّغْنِ فِي حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ.

(أَوْ) طَلَّقَتْ (حَائِضًا: فِي رَابِعَةٍ) أَيْ فَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا بِالطَّغْنِ فِي حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ لِتَوْقُفِ
حُصُولِ الْأَقْرَاءِ الثَّلَاثَةِ عَلَى ذَلِكَ.

(وَفِي قَوْلٍ: يُشْتَرَطُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بَعْدَ الطَّغْنِ) فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فِي الْأُولَى وَالرَّابِعَةِ فِي
الثَّانِيَةِ، لِيُعْلَمَ أَنَّهُ حَيْضٌ.

(وَهَلْ يُحْسَبُ طَهْرٌ مَنْ لَمْ تَحِضْ) أَصْلًا ثُمَّ حَاضَتْ فِي أَثْنَاءِ عِدَّتِهَا بِالْأَشْهُرِ (قَرَأًا ؟

قَوْلَانِ: بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْقَرَأَ انْتِقَالَ مِنْ طَهْرٍ إِلَى حَيْضٍ أَمْ طَهْرٌ مُحْتَوِشٌ) بِفَتْحِ الْوَاوِ
(بِدْمِينِ).

إِنْ قُلْنَا بِالْأَوَّلِ ^(٢) فَيُحْسَبُ وَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا بِالطَّغْنِ فِي حَيْضَةٍ ثَالِثَةٍ.

أَوْ بِالثَّانِي ^(٣) فَلَا يُحْسَبُ، وَإِنَّمَا تَنْقُضِي عِدَّتَهَا بِالطَّغْنِ فِي حَيْضَةٍ رَابِعَةٍ

(وَالثَّانِي أَظْهَرُ) فَكَذَا الْمَبْنِيُّ عَلَيْهِ.

(١) رواه أبو داود في سننه، كتاب: الطهارة، باب: المرأة تستحاض، ح: (٢٨١)، وابن ماجه في سننه، كتاب: أبواب

الطهارة، باب: ما جاء في المُسْتَحَاضَةِ الَّتِي قَدْ عَدَّتْ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَمِرَّ بِهَا الدَّمُ، ح: (٦٢٠).

(٢) وهو القول القائل بأنَّ الْقَرَأَ عبارة عن مجرد الانتقالِ مِنَ الطُّهْرِ إِلَى الْحَيْضِ.

(٣) وهو القول القائل بأنَّ الْقَرَأَ عبارة عن طهر محتوش بدمين.

(وَعِدَّةٌ مُسْتَحَاضَةٌ) غَيْرِ مُتَحَيِّرَةٍ^(١) (بِأَقْرَائِهَا الْمَرْدُودَةِ) هِيَ (إِلَيْهَا) حَيْضًا وَطَهْرًا وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي الْحَيْضِ أَنَّ الْمُعْتَادَةَ^(٢) تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالطَّهْرِ، وَالْمُمَيَّزَةُ^(٣) إِلَى التَّمْيِيزِ الْفَاصِلِ بَيْنَهُمَا، وَالْمُبْتَدَأَةُ^(٤) تُرَدُّ فِي الْحَيْضِ إِلَى أَقْلِهِ^(٥)، وَفِي قَوْلٍ إِلَى غَالِبِهِ^(٦)، وَفِي الطَّهْرِ إِلَى بَاقِي الشَّهْرِ أَيْ الثَّلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ حِينَ رَأَتْ الدَّمَ فَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ عَدَدِيَّةٍ.

(وَمُتَحَيِّرَةٍ)^(٧) بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ فِي الْحَالِ.

وَقِيلَ: بَعْدَ الْيَأْسِ؛ لِتَوْقُعِهَا قَبْلَهُ لِلْحَيْضِ الْمُسْتَقِيمِ.

وَعُورِضٌ: بِتَضَرُّرِهَا بِطَوِيلِ الْإِنْتِظَارِ وَالتَّعَطُّلِ.

وَعَلَى الثَّانِي: لَا يُزَادُ فِي ثُبُوتِ الرَّجْعَةِ وَحَقِّ السُّكْنَى عَلَى الثَّلَاثَةِ أَشْهُرٍ بِخِلَافِ حُرْمَةِ نِكَاحِ غَيْرِ الزَّوْجِ لَهَا اخْتِطَاطًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا.

وَالِإِعْتِبَارُ بِالْأَشْهُرِ الْهَلَالِيَّةِ فَعَلَى الْأَوَّلِ إِنْ انْطَبَقَ الطَّلَاقُ عَلَى أَوَّلِ الْهَلَالِ فَذَلِكَ.

وَأِنْ وَقَعَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ الْهَلَالِيِّ: فَإِنْ بَقِيَ مِنْهُ أَكْثَرُ مِنْ خَمْسَةِ عَشَرَ يَوْمًا حُسِبَ ذَلِكَ قَرَأَةً؛ لِإِشْتِمَالِهِ عَلَى طَهْرٍ لَا مَحَالَةَ وَتَعَدُّ بَعْدَهُ بِشَهْرَيْنِ هَلَالِيَيْنِ أَوْ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَمَا دُونَهَا.

(١) المستحاضة غير المتحيرة: تشمل الأنواع الثلاثة الآتية: المعتادة، والمميزة، والمبتدأة.

(٢) المستحاضة المعتادة هي: التي سبق لها حيض وطهر فتد إلهما قدرا ووقتا.

(٣) المستحاضة المميزة هي: التي ترى دما قويا وضعيفا؛ فيكون الدم الضعيف استحاضة والقوي حيض، ولكن بشروط مذكورة في باب الحيض.

(٤) المستحاضة المبتدأة المراد بها هنا: المبتدأة غير المميزة؛ التي ترى الدم بصفة واحدة، فلا تميز بين دم الحيض والاستحاضة.

(٥) أقل الحيض هو: يوم وليلة.

(٦) غالب الحيض أي: غالب عادة النساء في الحيض وهو: ست أو سبع.

(٧) المستحاضة متحيرة وهي: التي المرأة التي كانت لها عادة في الحيض ثم نسيت عاداتها قدرا ووقتا. وسميت بذلك: لأنها تحيرت في نفسها. وعدتها على الراجح: ثلاثة أشهر في الحال.

فَفِي وَجْهِ: يُحْسَبُ قَرَأَ أَيْضًا، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ طَهَّرَ، وَأَنَّ الْحَيْضَ فِي أَوَّلِ الْهَلَالِ. وَالْأَصَحُّ: لَا يُحْسَبُ قَرَأَ لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا.

وَعَلَى هَذَا قَالَ أَكْثَرُهُمْ: لَا اعْتِبَارَ بِالْبَاقِي وَتَعْتَدُ بَعْدَهُ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ هِلَالِيَّةٍ، لِأَنَّ الْأَشْهُرَ لَيْسَتْ مُتَّصِلَةً فِي حَقِّهَا حَتَّى تَبْنِيَ عَلَى الْمُنْكَسِرِ، وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ إِلَى تَأْصُلِهَا فِي حَقِّهَا كَمَنْ لَمْ تَحِضْ، أَوْ يَيْسَتْ وَعَلَى هَذَا تَمَكُّتُ شَهْرَيْنِ هِلَالِيَّيْنِ وَتُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ ثَلَاثِينَ، أَوْ تَمَكُّتُ تِسْعِينَ يَوْمًا مِنَ الطَّلَاقِ عَلَى الْخِلَافِ الْآتِي قَرِيبًا فِي الْآيَةِ.

(وَحَرَّةٌ لَمْ تَحِضْ) أَصْلًا (أَوْ يَيْسَتْ) مِنَ الْحَيْضِ (بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) قَالَ تَعَالَى (وَاللَّائِي يَيْسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) [الطلاق: ٤] وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ: أَيَّ فَعِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ.

وَالْمُرَادُ بِالْأَشْهُرِ: الْهِلَالِيَّةُ.

وَالْأَمْرُ ظَاهِرٌ إِنْ انْطَبَقَ الطَّلَاقُ عَلَى أَوَّلِ الشَّهْرِ كَأَنَّ عَلَقَهُ بِهِ أَوْ بِإِسْلَاحِ مَا قَبْلَهُ.

(فَإِنْ طَلَّقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ: فَبَعْدَهُ هِلَالَانِ وَتُكْمِلُ الْمُنْكَسِرَ ثَلَاثِينَ) يَوْمًا مِنَ الرَّابِعِ. وَقِيلَ: بِإِنْكَسَارِ شَهْرٍ يَنْكَسِرُ مَا بَعْدَهُ، لِأَنَّ الْمُنْكَسِرَ يَتِمُّ بِمَا يَلِيهِ فَيَنْكَسِرُ أَيْضًا فَتَعْتَدُ بِتِسْعِينَ يَوْمًا مِنَ الطَّلَاقِ.

(فَإِنْ حَاضَتْ فِيهَا) أَيَّ فِي الْأَشْهُرِ (وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ) لِأَنَّهَا الْأَصْلُ فِي الْعِدَّةِ وَقَدْ قَدَرْتُ عَلَيْهَا قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ بَدْلِهَا فَتَنْقَلُ إِلَيْهَا كَالْمُتَيَّمِّ إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فِي خِلَالِ التَّيَّمِّ.

(وَمَنْ انْقَطَعَ دَمُهَا:

- لِعِلَّةٍ) تُعْرِفُ (كَرَضَاعٍ وَمَرَضٍ: تَصْبِرُ حَتَّى تَحِيضَ) فَتَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ (أَوْ تَيْأَسَ فَبِالْأَشْهُرِ) وَإِنْ طَالَتْ مُدَّةُ الْإِنْتِظَارِ^(١).

(١) والدليل على هذا أن حَبَانَ بُنْ مُنْقَذٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَحِيحٌ وَهِيَ تُرَضِعُ ابْنَتَهُ، فَمَكَّثَتْ سَبْعَةَ عَشَرَ شَهْرًا لَا تَحِيضُ يَمْنَعُهَا الرِّضَاعُ أَنْ تَحِيضَ، ثُمَّ مَرِضَ حَبَانَ بَعْدَ أَنْ طَلَّقَهَا بِسَبْعَةِ أَشْهُرٍ أَوْ ثَمَانِيَةٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ امْرَأَتَكَ تُرِيدُ أَنْ تَرِثَ، فَقَالَ لِأَهْلِهِ: احْمِلُونِي إِلَى عَثْمَانَ، فَحَمَلُوهُ إِلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ شَأْنَ امْرَأَتِهِ وَعِنْدَهُ عَلِيٌّ بُنْ أَبِي طَالِبٍ، وَزَيْدٌ بُنْ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُمَا عَثْمَانُ: «مَا تَرَيَانِ؟» فَقَالَا: «نَرَى أَنَّهَا تَرِثُهُ إِنْ مَاتَ وَبَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ

- (أَوْ لَا لِعِلَّةٍ) تُعْرِفُ (فَكَذَا فِي الْجَدِيدِ) تَصْبُرُ حَتَّى تَحِيضَ فَتَعْتَدَ بِالْأَقْرَاءِ، أَوْ تَيَأَسَ فَتَعْتَدَ بِالْأَشْهُرِ^(١).

(وَفِي الْقَدِيمِ: تَتَرَبَّصُ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ) مُدَّةَ الْحَمْلِ غَالِبًا^(٢).

(وَفِي قَوْلٍ) مِنَ الْقَدِيمِ (أَرْبَعَ سِنِينَ) أَكْثَرَ مُدَّةِ الْحَمْلِ.

وَفِي قَوْلٍ مُخَرَّجٍ عَلَيْهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ أَقَلَّ مُدَّةِ الْحَمْلِ لِيُظْهِرَ أَمَارَتَهُ فِيهَا وَجَبَتْ الْأَقْرَاءُ. (ثُمَّ تَعْتَدُ بِالْأَشْهُرِ) إِذَا لَمْ يَظْهَرْ حَمْلٌ.

(فَعَلَى الْجَدِيدِ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْيَأْسِ) فِي الْأَشْهُرِ رُجُوعًا إِلَى الْأَصْلِ وَيُحْسَبُ مَا مَضَى مِنَ الطُّهْرِ قَرَأً ١.

(أَوْ بَعْدَهَا^(٣) فَأَقُولُ:

أَظْهَرُهَا: إِنْ نَكَحْتَ) زَوْجًا آخَرَ (فَلَا شَيْءَ) عَلَيْهَا (وَالَا فَلَا أَقْرَاءَ) عَلَيْهَا.

وَالثَّانِي: لَا شَيْءَ عَلَيْهَا مُطْلَقًا لِانْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فِي الظَّاهِرِ بِالْأَشْهُرِ.

وَالثَّالِثُ: عَلَيْهَا أَنْ تَعْتَدَ بِالْأَقْرَاءِ مُطْلَقًا لِتَبَيُّنِ أَنَّهَا مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ لَا آيَسَةً فَيَتَبَيَّنُ بَطْلَانُ النِّكَاحِ.

(وَالْمُعْتَبَرُ) فِي الْيَأْسِ:

- عَلَى الْجَدِيدِ: (يَأْسُ عَشِيرَتِهَا) مِنَ الْأَبَوَيْنِ؛ لِتَقَارُبِهِنَّ فِي الطَّنْبِ فَإِذَا بَلَغَتْ السِّنَّ الَّذِي يَنْقَطِعُ فِيهِ حَيْضُهُنَّ فَقَدْ بَلَغَتْ سِنَّ الْيَأْسِ.

مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي قَدْ يَسُنَّ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ اللَّاتِي لَمْ يَبْلُغْنَ الْمَحِيضَ، ثُمَّ هِيَ عَلَى عِدَّةِ حَيْضِهَا مَا كَانَ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ، فَرَجَعَ حَبَانُ إِلَى أَهْلِهِ، فَأَخَذَ ابْنَتَهُ، فَلَمَّا فَقَدَتْ الرِّضَاعَ حَاضَتْ حَيْضَةً ثُمَّ حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ تُوُفِّيَ حَبَانُ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ الثَّالِثَةَ، فَاعْتَدَتْ عِدَّةَ الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَوَرِثَتُهُ. (١) لأن الأشهر شرعت للتي لم تحض والتي آيست وهذه غيرهما؛ ولأنها ترجو عود الدم فلم تعد بالأشهر قبل سن اليأس كالتى انقطع دمها لعارض.

(٢) ليعرف فراغ الرحم لأن الغالب أن الحمل لا يمكن في البطن أكثر من ذلك.

(٣) أي بعد الأشهر.

- (وَفِي قَوْلٍ) يَأْسُ (كُلِّ النِّسَاءِ) بِحَسَبِ مَا يَبْلُغُ مِنْ خَبَرِهِ وَيُعْرِفُ. وَأَقْصَاهُ: اثْنَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً. وَقِيلَ: سِتُّونَ. وَقِيلَ: خَمْسُونَ.

(قُلْتُ: ذَا الْقَوْلُ أَظْهَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَنُقِلَ تَرْجِيحُهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ عَنِ الْأَكْثَرِينَ، وَقَالَ فِي الْكَبِيرِ: إِبْرَادُ أَكْثَرِهِمْ يَفْتَضِي تَرْجِيحَهُ، وَفِي الْمُحَرَّرِ أَنَّ الْأَوَّلَ أَقْرَبُ إِلَى التَّرْجِيحِ.

فَضَّلَ: عِدَّةُ الْحَامِلِ بِوَضْعِهِ أَيِ الْحَمْلِ؛ قَالَ تَعَالَى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

- (بِشَرْطِ^(١)): نِسْبَتُهُ إِلَى ذِي الْعِدَّةِ وَلَوْ احْتِمَالًا كَمَنْفِي بِلْعَانٍ):

فَإِذَا لَاعَنَ الْحَامِلَ وَنَفَى الْحَمْلَ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ، وَإِنْ انْتَفَى عَنْهُ فِي الظَّاهِرِ لِإِمْكَانِ كَوْنِهِ مِنْهُ.

وَالْمَرْأَةُ مُصَدِّقَةٌ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ عِنْدَ الْإِمْكَانِ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ نِسْبَةُ الْحَمْلِ إِلَى صَاحِبِ الْعِدَّةِ فَلَا تَنْقُضِي بِوَضْعِهِ؛ كَأَنْ مَاتَ صَبِيٌّ لَا يَنْزِلُ وَامْرَأَتُهُ حَامِلٌ فَتَنْقُضِي عِدَّتُهَا بِالْأَشْهُرِ لَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ لِانْتِفَائِهِ عَنْهُ.

وَكَذَا مَنْ مَاتَ، أَوْ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَأَتَتْ بِوَلَدٍ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنَ النِّكَاحِ لَا تَنْقُضِي عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ؛ لِانْتِفَائِهِ عَنِ الزَّوْجِ.

- (وَأَنْفِصَالِ كُلِّهِ حَتَّى ثَانِي تَوَآمِنٍ) لظَاهِرِ الْآيَةِ^(٢).

(وَمَتَى تَخَلَّلَ دُونَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) بَيْنَ الْوَضْعَيْنِ (فَتَوَآمَنَ)، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَخَلَّلَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْثَّانِي حَمْلٌ آخَرُ.

(وَتَنْقُضِي بِمَيِّتٍ) كَالْحَيِّ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ.

(لَا عِلْقَةَ)^(١) لِأَنَّهَا لَا تُسَمَّى حَمْلًا وَلَا يُتَيَقَّنُ كَوْنُهَا أَصْلَ الْوَلَدِ.

(١) أي أن الحمل الذي تنقضي العدة بوضعه لا بد في من شرطين: الأول: نسبة الحمل إلى صاحب العدة، والثاني:

انفصال الحمل كاملاً

(٢) أي قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

(وَبِمُضْغَةٍ فِيهَا صُورَةُ آدَمِيٍّ خَفِيَّةٌ أَخْبَرَ بِهَا الْقَوَائِلُ) ^(٢) لِظُهُورِهَا عِنْدَهُنَّ كَمَا لَوْ كَانَتْ ظَاهِرَةً عِنْدَ غَيْرِهِنَّ أَيْضًا بِظُهُورِ يَدٍ، أَوْ أَصْبُعٍ، أَوْ ظَفَرٍ أَوْ غَيْرِهَا.

(فَإِنْ لَمْ تَكُنْ صُورَةً) أَصْلًا لَا ظَاهِرَةً وَلَا خَفِيَّةً تَعْرِفُهَا الْقَوَائِلُ (وَقُلْنَ: هِيَ أَصْلُ آدَمِيٍّ) لَوْ بَقِيَتْ لَتَصَوَّرَتْ (انْقَضَتْ) بِوَضْعِهَا (عَلَى الْمَذْهَبِ) الْمُنْصُوصِ؛ لِحُصُولِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ.

وَفِي قَوْلٍ: لَا تَنْقُضِي بِهِ؛ خُرَجَ مِنْ نَصِّهِ عَلَى أَنَّ أُمِّيَّةَ الْوَلَدِ لَا تَنْبُتُ بِذَلِكَ لِانْتِفَاءِ اسْمِ الْوَلَدِ وَقَطْعِ بَعْضِهِمْ بِالْأَوَّلِ.

وَلَوْ شَكَّتِ الْقَوَائِلُ فِي أَنَّهَا لَحَمٌ آدَمِيٍّ: لَمْ تَنْقُضِ بِوَضْعِهَا قِطْعًا.

(وَلَوْ ظَهَرَ فِي عِدَّةٍ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ حَمْلٌ لِلزَّوْجِ: اعْتَدَّتْ بِوَضْعِهِ) وَلَا اعْتَبَارَ بِمَا مَضَى مِنَ الْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ لَوْجُودِ الْحَمْلِ ^(٣).

(وَلَوْ ارْتَابَتْ فِيهَا) أَيُّ فِي الْعِدَّةِ الْمَذْكُورَةِ لِثِقَلِ وَحَرَكَةِ تَجْدُهَا: (لَمْ تَنْكِحْ) آخَرَ بَعْدَ تَمَامِهَا (حَتَّى تَزُولَ الرَّيْبَةُ) ^(٤).

فَإِنْ نَكَحَتْ فَالِنِكَاحُ بَاطِلٌ لِلتَّرَدُّدِ فِي انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

(أَوْ بَعْدَهَا) أَيُّ ارْتَابَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ (وَبَعْدَ نِكَاحِ) الْآخَرِ: (اسْتَمَرَّ) النِّكَاحُ لِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فِي الظَّاهِرِ وَتَعَلَّقَ حَقُّ الزَّوْجِ الثَّانِي.

(إِلَّا أَنْ تَلِدَ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ عَقْدِهِ) فَيَنْبَيِّنُ بَطْلَانُهُ ^(٥)، وَالْوَلَدُ لِلْأَوَّلِ بِخِلَافِ مَا إِذَا وَلَدَتْ لِسِتَّةِ أَشْهُرٍ فَأَكْثَرَ فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي.

(أَوْ بَعْدَهَا قَبْلَ نِكَاحِ) الْآخَرِ ^(٦): (فَلْتَضْبِرْ) عَنِ النِّكَاحِ نَدْبًا (لِلزَّوْلِ الرَّيْبَةُ) ^(٧).

(١) أي لا تنقضي العدة بوضع علقة.

(٢) أي تنقضي العدة بها؛ لحديث سبيعة الأسلمية، فإن النبي ﷺ لم يسألها عن صفة حملها.

(٣) لأن الأقراء والأشهر العدة بهما يدلان على البراءة ظاهرا، والحمل يدل عليها قطعاً.

(٤) وزوال الريبة يكون: إما بمضي زمن يزعم النساء أنها لا تلد فيه أو غير ذلك.

(٥) أي تبين بطلان النكاح الثاني.

(٦) أي ارتابت بعد انتهاء الأشهر أو الأقراء وقبل نكاح زوج آخر.

(٧) احتياطاً وورعاً؛ لقوله ﷺ: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

فَإِنْ نَكَحَتْ قَبْلَ زَوَالِهَا^(١):

- (فَالْمَذْهَبُ) الْمَنْصُوصُ: (عَدَمُ إِبْطَالِهِ فِي الْحَالِ) لِأَنَّا حَكَمْنَا بِإِنْقِصَاءِ الْعِدَّةِ فِي الظَّاهِرِ، وَلَا نَنْقُضُ الْحُكْمَ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ بَلْ نَقِفُ (فَإِنْ عَلِمَ مُقْتَضِيهِ) أَيُّ مُقْتَضِي إِبْطَالِهِ بِأَنْ وَلَدَتْ لِذَوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْهُ (أَبْطَلْنَاهُ) وَإِلَّا فَلَا نُبْطِلُهُ.

- وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِي إِبْطَالِهِ قَوْلَانِ: لِلتَّرَدُّدِ فِي انْتِفَاءِ الْمَانِعِ فِي الْحَالِ، وَإِنْ بَانَ انْتِفَاؤُهُ بِنَاءً عَلَى الْقَوْلَيْنِ فِيمَنْ بَاعَ مَالَ مُوَرِّثِهِ عَلَى ظَنِّ حَيَاتِهِ، فَبَانَ مَيِّتًا وَأَظْهَرُهُمَا الصِّحَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِهِ.

(وَلَوْ أَبَانَهَا) بِخُلْعٍ، أَوْ غَيْرِهِ (فَوَلَدَتْ لِأَرْبَعِ سِنِينَ) فَمَا دُونَهَا مِنْ وَقْتِ الْإِبَانَةِ: (لِحَقِّهِ) الْوَلَدُ^(٢).

(أَوْ الْأَكْثَرُ) مِنْهَا^(٣): (فَلَا) يَلْحَقُهُ؛ لِأَنَّ مُدَّةَ الْحَمْلِ قَدْ تَبْلُغُ أَرْبَعَ سِنِينَ وَهِيَ أَكْثَرُ مُدَّتِهِ كَمَا أَسْتَفْرَى.

(وَلَوْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا) وَالْحَالُ مَا تَقَدَّمَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ بِوَلَدٍ لِأَرْبَعِ سِنِينَ:

- (حُسِبَتْ الْعِدَّةُ مِنَ الطَّلَاقِ)؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالْبَائِنِ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ فَكَذَا فِي أَمْرِ الْوَلَدِ الَّذِي هُوَ نَتِيجَتُهُ.

- (وَفِي قَوْلٍ: مِنْ انْصِرَامِ الْعِدَّةِ)؛ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالْمَنْكُوحَةِ فِي مُعْظَمِ الْأَحْكَامِ.

(وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ الْعِدَّةِ فَوَلَدَتْ لِذَوْنِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ) مِنَ النِّكَاحِ: (فَكَأَنَّهَا لَمْ تَنْكِحْ) وَيَكُونُ الْحُكْمُ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْإِثْنَيْنِ بِالْوَلَدِ لِأَرْبَعِ سِنِينَ، أَوْ أَكْثَرَ إِلَى آخِرِهِ^(٤).

(وَإِنْ كَانَ لِسِتَّةٍ) فَأَكْثَرَ (فَالْوَلَدُ لِلثَّانِي) لِقِيَامِ فِرَاشِهِ^(١)، وَإِنْ أَمَكْنَ كَوْنُهُ مِنَ الْأَوَّلِ.

(١) أي قبل زوال الرتبة في الحالة الأخيرة.

(٢) لقيام الإمكان؛ فإن الحمل قد يبلغ ذلك.

(٣) أي: ولو أبان الزوج زوجته بخُلْعٍ، أو غيره فولدت لأكثر من أربع سنين.

(٤) أي: إن ولدت لأربع سنين فأكثر.. لم يلحق، أو لأقل من ذلك.. لحق. وحيث لحق.. فنكاح الثاني باطل، وإلا..

فصحيح.

(وَلَوْ نَكَحَتْ فِي الْعِدَّةِ فَاسِدًا فَوَلَدَتْ:

- إِنْ وَلَدَتْ لِلْإِمْكَانِ مِنَ الْأَوَّلِ) دُونَ الثَّانِي: (لِحَقِّهِ وَانْقَضَتْ) عِدَّتُهُ (بِوَضْعِهِ، ثُمَّ تَعَدَّتْ لِلثَّانِي.
- أَوْ لِلْإِمْكَانِ مِنَ الثَّانِي) دُونَ الْأَوَّلِ: (لِحَقِّهِ) كَأَنَّ أَتَتْ بِهِ لِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ.

- (أَوْ) لِلْإِمْكَانِ (مِنْهُمَا عُرِضَ عَلَى قَائِفٍ^(٢)) فَإِنْ أَلْحَقَهُ بِأَحَدِهِمَا فَكَالْإِمْكَانِ مِنْهُ فَقَطُّ) وَقَدْ تَقَدَّمَ حُكْمُهُ. وَإِنْ أَلْحَقَهُ بِهِمَا، أَوْ اشْتَبَهَ الْحَالُ عَلَيْهِ، أَوْ لَمْ يَكُنْ قَائِفٌ: اُنْتَظِرْ بُلُوغَهُ وَانْتِسَابَهُ بِنَفْسِهِ.

- وَإِنْ أَتَتْ بِهِ لَزِمَانٍ لَا يُعَيَّنُ كَوْنُهُ فِيهِ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَأَنَّ وَلَدَتْهُ لِدُونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ نِكَاحِ الثَّانِي وَلِأَكْثَرِ مِنْ أَرْبَعِ سِنِينَ مِنَ طَّلَاقِ الْأَوَّلِ الْبَائِنِ: فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَاحِدًا مِنْهُمَا.

فَصُلِّ: إِذَا (لَزِمَهَا عِدَّتَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ) وَاحِدٍ (بِأَنْ طَلَّقَ، ثُمَّ وَطِئَ فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ، أَوْ أَشْهُرٍ جَاهِلًا) فِي بَائِنٍ^(٣)، أَوْ رَجْعِيَّةٍ بِأَنَّهَا الْمُطَلَّقةُ (أَوْ عَالِمًا فِي رَجْعِيَّةٍ) بِذَلِكَ أَيْضًا بِخِلَافِ الْبَائِنِ فَإِنَّ وَطْءَ الْعَالِمِ لَهَا وَطْءٌ زَنَى لَا حُرْمَةَ لَهُ:

- (تَدَاخَلَتَا^(٤)) فَتَبْتَدِئُ عِدَّةً بِالْأَقْرَاءِ أَوْ الْأَشْهُرِ (مِنْ الْوُطْءِ وَيَدْخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ)^(٥) وَتِلْكَ الْبَقِيَّةُ وَاقِعَةٌ عَنِ الْجِهَتَيْنِ، وَلَهُ الرُّجْعَةُ فِيهَا فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ دُونَ مَا بَعْدَهَا.

(فَإِنْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا حَمَلًا وَالْأُخْرَى أَقْرَاءً) بِأَنْ طَلَّقَهَا حَائِلًا، ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْأَقْرَاءِ وَأَحْبَلَهَا، أَوْ طَلَّقَهَا حَامِلًا، ثُمَّ وَطِئَهَا قَبْلَ الْوُضْعِ وَهِيَ تَرَى الدَّمَ مَعَ الْحَمْلِ وَقُلْنَا بِالرَّاجِحِ: إِنَّهُ حَيْضٌ وَبِالْمَرْجُوحِ إِنَّ الْعِدَّةَ لَا تَنْقُضِي بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ، لِأَنَّهَا لَا تَدُلُّ عَلَى الْبَرَاءَةِ.

(١) والفراس الثاني أقوى لتأخره.

(٢) القائف هو: الذي يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود، ويقوم مقامه في عصرنا تحليل DNA

(٣) بأن ظنها زوجته الأخرى، أو نسي الطلاق أو نسي التحريم.

(٤) أي العدتان.

(٥) لأن مقصود عدة الوطء والطلاق واحد فيندرج فيها ما بقي من عدة الطلاق.

(تَدَاخَلَتَا) أَي دَخَلَتْ الْأَقْرَاءُ فِي الْحَمْلِ (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِاتِّحَادِ صَاحِبَيْهِمَا^(١) (فَتَنْقُضِيَانِ بِوَضْعِهِ) وَهُوَ وَقَعَ عَنِ الْجِهَتَيْنِ. (وَيُرَاجَعُ قَبْلَهُ) فِي الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ سَوَاءً كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْوَطْءِ أَمْ لَا.

(وَقِيلَ: إِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنَ الْوَطْءِ فَلَا) يُرَاجَعُ زَمَانُهُ بِنَاءً عَلَى انْقِطَاعِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ، وَسُقُوطِهَا بِالْوَطْءِ.

وَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ: أَنَّهُمَا لَا تَتَدَاخَلَانِ؛ لِاخْتِلَافِ جِنْسَيْهِمَا^(٢).

وَعَلَى هَذَا: إِنْ كَانَ الْحَمْلُ لِعِدَّةِ الطَّلَاقِ اعْتَدَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بِالْأَقْرَاءِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ قَبْلَهُ.

أَوْ لِعِدَّةِ الْوَطْءِ أَتَمَّتْ بَعْدَ وَضْعِهِ بَقِيَّةَ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي تِلْكَ الْبَقِيَّةِ.

وَكَذَا قَبْلَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُكْمَلِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ.

وَقِيلَ: لَا؛ لِأَنَّهَا فِي عِدَّةِ الشُّبْهَةِ.

أَمَّا إِذَا قُلْنَا بِالْأَصَحِّ وَهُوَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ:

فَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ لِعِدَّةِ الْوَطْءِ وَمَضَتْ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ الْوَضْعِ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ بَعْدَ ذَلِكَ.

وَإِنْ وَضَعَتْ الْحَمْلَ قَبْلَ تِمَامِ الْأَقْرَاءِ فَقَدْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الْوَطْءِ وَعَلَيْهَا بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ وَلِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ، وَبَعْدَهُ إِلَى تِمَامِ الْأَقْرَاءِ.

وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ لِعِدَّةِ الطَّلَاقِ وَمَضَتْ الْأَقْرَاءُ قَبْلَ الْوَضْعِ فَذَلِكَ، أَوْ لَمْ تَمُضْ: أَكْمَلَتْ مَا بَقِيَ مِنْهَا بَعْدَ الْوَضْعِ وَلَهُ الرَّجْعَةُ إِلَى الْوَضْعِ.

(أَوْ) لَزِمَهَا عِدَّتَانِ (لِشَخْصَيْنِ بِأَنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ زَوْجٍ، أَوْ شُبْهَةٍ فَوُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ، أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ، أَوْ كَانَتْ زَوْجَةً مُعْتَدَّةً عَنِ شُبْهَةٍ فَطُؤَتْ:

(١) ولأن كلا منهما عدة فأشبهها المنجاستين.

(٢) ولأن التداخل يليق بالمتفقات بدليل أن الحدود تآبى التداخل في المتفقات منها دون المختلفات، وهنا العدتان كل منهما مختلف عن الأخرى.

فَلَا تَدْخُلُ) لِتَعْدُدِ الْمُسْتَحِقَّ بَلْ تَعْتَدُ لِكُلِّ مِنْهُمَا عِدَّةً كَامِلَةً^(١).

(فَإِنْ كَانَ حَمْلٌ قَدِّمَتْ عِدَّتَهُ) سَابِقًا كَانَ أَمْ لَاحِقًا، لِأَنَّ عِدَّةَ الْحَمْلِ لَا تَقْبَلُ التَّأخيرَ فَإِنْ كَانَ مِنَ الْمُطْلَقِ ثُمَّ وَطِئَتْ بِشَبْهَةٍ فَإِذَا وَضَعَتْ انْقَضَتْ عِدَّةُ الطَّلَاقِ، ثُمَّ تَعْتَدُ بِالْأَقْرَاءِ لِلشَّبْهَةِ بَعْدَ طَهْرِهَا مِنَ النِّفَاسِ وَلِلزَّوْجِ الرَّجْعَةُ قَبْلَ الْوَضْعِ.

قَالَ الرَّوْيَانِيُّ: إِلَّا وَقْتُ وَطْءِ الشَّبْهَةِ لِخُرُوجِهَا حِينَئِذٍ عَنْ عِدَّتِهِ بِكَوْنِهَا فِرَاشًا لِلْوَطْءِ.

وَإِنْ كَانَ الْحَمْلُ مِنْ وَطْءِ الشَّبْهَةِ فَإِذَا وَضَعَتْ انْقَضَتْ عِدَّتُهُ، ثُمَّ تَأْتِي بِعِدَّةِ الْمُطْلَقِ، أَوْ بَقِيَّتِهَا بَعْدَ الطَّهْرِ مِنَ النِّفَاسِ، وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي الْبَقِيَّةِ، وَفِي وَقْتِ النِّفَاسِ لِأَنَّهُ مِنَ الْعِدَّةِ كَالْحَيْضِ، الَّذِي يَقَعُ فِيهِ الطَّلَاقُ.

(وَالْأَيُّ) أَيُّ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَمْلٌ (فَإِنْ سَبَقَ الطَّلَاقُ) وَطْءِ الشَّبْهَةِ: (أَتَمَّتْ عِدَّتَهُ) لِقَوَّتِهَا بِاسْتِنَادِهَا إِلَى عَقْدٍ جَائِزٍ (ثُمَّ اسْتَأْنَفَتْ الْأُخْرَى) أَيُّ عِدَّةً وَطْءِ الشَّبْهَةِ عَقَبَ عِدَّةَ الطَّلَاقِ.

(وَلَهُ الرَّجْعَةُ فِي عِدَّتِهِ) وَيَأْتِي فِي وَقْتِ الْوُطْءِ مَا تَقَدَّمَ عَنِ الرَّوْيَانِيِّ.

(فَإِذَا رَاجَعَ: انْقَطَعَتْ وَشَرَعَتْ فِي عِدَّةِ الشَّبْهَةِ وَلَا يَسْتَمْتَعُ بِهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا) رِعَايَةً لِلْعِدَّةِ.

(وَإِنْ سَبَقَتْ الشَّبْهَةُ) الطَّلَاقُ (قَدِّمَتْ عِدَّةَ الطَّلَاقِ) لِقَوَّتِهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

(وَقِيلَ) عِدَّةُ (الشَّبْهَةِ) لِسَبْقِهَا وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْوُطْءُ بِنِكَاحٍ فَاسِدٍ انْقَطَعَتْ بِهِ عِدَّةُ الطَّلَاقِ أَيُّ إِلَى أَنْ يُفَرِّقَ الْقَاضِي بَيْنَهُمَا.

فَصْلٌ: عَاشِرُهَا^(٢) أَيُّ مُطْلَقَتَهُ (كَزَوْجٍ بَلَا وَطْءٍ^(٣)) فِي عِدَّةِ أَقْرَاءٍ أَوْ أَشْهُرٍ:

فَأَوْجُهُ: أَصَحُّهَا: إِنْ كَانَتْ بَائِنًا انْقَضَتْ، وَإِلَّا فَلَا^(١).

(١) والدليل على ذلك أيضا ما روى مالك عن عمر، والبيهقي عن علي أنهما قالا: "إذا كان على المرأة عدتان من شخصين.. لا تتداخلان"، ولا مخالف لهما من الصحابة إلا ما نقل عن ابن مسعود ولم يثبت.

(٢) المراد بالمعاشرة: الخلوة، وكذلك النوم معها، ولا يضر دخول داروهي فيها من غير خلوة.

(٣) الأحكام المذكور في معاشرة المطلق لمن طلقها معاشرته الأزواج في كل شيء إلا في الوطء فلا يطؤها. وأما إن كان يطؤها سيأتي بيانه في قوله: "وَلَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ - مَعَ الْمَعَاشِرَةِ..."

وَالثَّانِي: تَنْقِضِي مُطْلَقًا^(٢).

وَالثَّالِثُ: لَا تَنْقِضِي مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهَا بِالْمُعَاشَرَةِ تُشْبِهُ الزَّوْجَاتِ دُونَ الْمُطَلَّقاتِ.

وَالثَّانِي نَظَرَ إِلَى أَنَّ الْقَصْدَ مِنَ الْعِدَّةِ مُضِيَّ الْمُدَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَذَلِكَ حَاصِلٌ مَعَ الْمُعَاشَرَةِ.

وَالأَوَّلُ نَظَرَ إِلَى قِيَامِ شُبْهَةِ الْفِرَاشِ فِي الرَّجْعِيَّةِ دُونَ الْبَائِنِ.

(وَلَا رَجْعَةَ بَعْدَ الْأَقْرَاءِ، أَوْ الْأَشْهَرِ) فَإِنْ لَمْ تَنْقُضِ بِهِمَا الْعِدَّةَ احْتِيَاظًا.

(قُلْتُ: وَيَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ) كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ مُقْتَضَى الْإِحْتِيَاظِ.

(وَلَوْ عَاشَرَهَا أَجْنَبِيٌّ) بِلَا وَطْءٍ، أَوْ مَعَهُ (انْقَضَتْ^(٣)) وَاللَّهُ أَعْلَمُ).

وَلَوْ وَطِئَ الزَّوْجُ - مَعَ الْمُعَاشَرَةِ - الْبَائِنُ عَالِمًا: انْقَضَتْ لِأَنَّهُ وَطِئَ زَنَى لَا حُرْمَةَ لَهُ.

أَوْ جَاهِلًا، أَوْ الرَّجْعِيَّةَ مُطْلَقًا فَقَط. تَقَدَّمَ فِي الْفَصْلِ السَّابِقِ: أَنَّ الْوُطْءَ يَجِبُ بِهِ عِدَّةٌ تُبْتَدَأُ مِنْهُ وَتَنْدَخُلُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى لِكُنْ لَا تَشْرَعُ الرَّجْعِيَّةُ فِيهَا مَا دَامَ الزَّوْجُ يَطْوُهَا كَمَا قَالَهُ فِي التَّتِمَّةِ^(٤).

وَلَوْ كَانَتْ الْمُعَاشَرَةُ فِي عِدَّةٍ حَمَلٍ انْقَضَتْ بِوَضْعِهِ بِلَا شَكٍّ مُطْلَقًا.

(وَلَوْ نَكَحَ مُعْتَدَّةً بَظَنِّ الصِّحَّةِ وَوَطِئَ: انْقَطَعَتْ) عِدَّتُهَا (مِنْ حِينِ وَطِئَ)؛ لِحُصُولِ الْفِرَاشِ بِالْوُطْءِ^(٥). (وَفِي قَوْلٍ أَوْ وَجْهِ: مِنَ الْعَقْدِ^(٦)) ؛ لِأَنَّهَا بِهِ مُغْرِضَةٌ عَنِ الْعِدَّةِ.

(١) ووجه هذا: أن مخالطة البائن محرمة لا تؤثر في العدة كوطئها في الدبر، وفي الرجعية الشبهة قائمة وهو بالمعاشرة والمخالطة مستفرش لها، فلا يحسب زمن استفراشه من العدة، كما لو نكحت غيره في العدة.. لا يحسب زمن استفراشه عن العدة.

(٢) لأن هذه المخالطة لا توجب عدة فلا تمنعها.

(٣) لأنه لا شبهة له، قال الإمام: "لا نعرف خلافاً أنها لو كانت تخالط الأجانب تنقضي عدتها وإن تعرضت لسخط الله تعالى".

(٤) لا تشرع الرجعية في العدة ما دام يطؤها؛ لأن العدة لبراءة الرحم وهي مشغولة بما يشغل الرحم.

(٥) لأن هذا نكاح فاسد، والنكاح الفاسد لا حرمة له، ولا تجعل المرأة فراشاً ما لم يوجد الوطء.

(٦) أي: انْقَطَعَتْ عِدَّتُهَا مِنْ حِينِ الْعَقْدِ لَا الْوُطْءِ

وَتَعُودُ إِلَيْهَا مِنْ حِينَ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، وَقِيلَ مِنْ آخِرِ الْوَطْآتِ الْوَاقِعَةِ فِي النِّكَاحِ، وَإِذَا لَمْ يَطَأْ لَمْ تَنْقَطِعِ الْعِدَّةُ لِانْتِفَاءِ الْفِرَاشِ، وَقِيلَ تَنْقَطِعُ لِمَا ذَكَرَ مِنَ الْإِعْرَاضِ عَنْهَا بِالْعَقْدِ.

(وَلَوْ رَاجَعَ حَائِلًا ثُمَّ طَلَّقَ: اسْتَأْنَفَتْ) سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَمْ لَا؛ لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إِلَى النِّكَاحِ الَّذِي وَطِئَتْ فِيهِ.

(وَفِي الْقَدِيمِ: تَبْنِي) عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ الْعِدَّةِ قَبْلَ الرَّجْعَةِ (إِنْ لَمْ يَطَأْ) بَعْدَهَا.

(أَوْ) رَاجَعَ تَنْقُضِي عِدَّتِهَا سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ الرَّجْعَةِ أَمْ لَا فَلَوْ وَضَعَتْ بَعْدَ الرَّجْعَةِ ثُمَّ طَلَّقَهَا (حَامِلًا) ثُمَّ طَلَّقَهَا (فَبِالْوَضْعِ).

فَلَوْ وَضَعَتْ ثُمَّ طَلَّقَ اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً بِالْأَقْرَاءِ سَوَاءٌ وَطِئَهَا بَعْدَ الْوَضْعِ أَمْ لَا؛ لِعَوْدِهَا بِالرَّجْعَةِ إِلَى النِّكَاحِ الَّذِي وَطِئَتْ فِيهِ.

(وَقِيلَ: إِنْ لَمْ يَطَأْ بَعْدَ الْوَضْعِ فَلَا عِدَّةَ) عَلَيْهَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْحَامِلَ تَبْنِي لِعُذْرِ بِنَاءِ الْأَقْرَاءِ عَلَى الْحَمْلِ.

وَفِي الرُّوُضَةِ وَأَصْلُهَا أَنَّهُ إِنْ وَطِئَ قَبْلَ الْوَضْعِ أَوْ بَعْدَهُ اسْتَأْنَفَتْ، فَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا فَكَذَلِكَ، وَقِيلَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا فَتَنْفِي الْوُطْءِ شَامِلٌ لِمَا قَبْلَ الْوَضْعِ وَبَعْدَهُ فِي حِكَايَةِ هَذَا الْوَجْهِ فَلَوْ زَادَ عَلَى قَوْلِهِ هُنَا بَعْدَ الْوَضْعِ أَوْ قَبْلَهُ، أَوْ حَدَفَهُ كَمَا فِي الْمُحَرَّرِ لَوَفَّى بِمَا ذَكَرَ.

(وَلَوْ خَالَعَ مَوْطُوءَةً، ثُمَّ نَكَحَهَا) فِي الْعِدَّةِ. (ثُمَّ وَطِئَ، ثُمَّ طَلَّقَ: اسْتَأْنَفَتْ) عِدَّةً لِأَجْلِ الْوُطْءِ (وَدَخَلَ فِيهَا الْبَقِيَّةُ) مِنَ الْعِدَّةِ السَّابِقَةِ، لِأَنَّهَا مِنْ شَخْصٍ وَاحِدٍ.

وَقَالَ الْفَارِقِيُّ: لَمْ يَبْقَ بَعْدَ النِّكَاحِ وَالْوُطْءِ عِدَّةٌ حَتَّى يُقَالَ: تَدْخُلُ فِي غَيْرِهَا، وَلَوْ طَلَّقَ قَبْلَ الْوُطْءِ بَنَتْ عَلَى مَا سَبَقَ مِنَ الْعِدَّةِ، وَأَكْمَلَتْهَا وَلَا عِدَّةَ لِهَذَا الطَّلَاقِ، لِأَنَّهُ فِي نِكَاحٍ جَدِيدٍ بِخِلَافِ مَا تَقَدَّمَ فِي الرَّجْعِيَّةِ.

فَصَلِّ: عِدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ^(١) لَوَفَاةٍ، وَإِنْ لَمْ تُوْطَأْ: أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرَةُ أَيَّامٍ بَلَيَالِيهَا قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] أَيُّ عَشْرٍ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا.

وَتَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الصَّغِيرَةُ وَالْكَبِيرَةُ وَالْمَدْخُولُ بِهَا وَغَيْرُهَا، وَذَاتُ الْأَقْرَاءِ وَغَيْرُهَا وَزَوْجَةُ الصَّبِيِّ وَغَيْرِهِ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ الْمُحْمُولَةِ عَلَى الْغَالِبِ مِنَ الْحَرَائِرِ الْحَائِلَاتِ.

وَتَعْتَبَرُ الْأَشْهُرُ بِالْأَهْلَةِ مَا أَمَكْنَ فَإِنْ مَاتَ أَوَّلُ الْهَلَالِ: فَوَاضِحٌ.

أَوْ فِي خِلَافِ شَهْرٍ بَقِيَ مِنْهُ عَشْرَةُ أَيَّامٍ أَوْ أَقَلُّ: ضَمَّتْ إِلَى ذَلِكَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بِالْأَهْلَةِ وَأَكْمَلَتْ بَقِيَّةَ الْعَشْرِ مِمَّا بَعْدَهَا.

أَوْ أَكْثَرَ مِنْ عَشْرَةِ أَيَّامٍ: ضَمَّتْ إِلَى ذَلِكَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ بِالْأَهْلَةِ، وَأَكْمَلَتْ عَلَيْهِ مِمَّا بَعْدَهَا بَقِيَّةَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا. وَقِيلَ: إِذَا انْكَسَرَ شَهْرٌ اعْتَبِرَتْ الْأَشْهُرُ كُلُّهَا بِالْعَدَدِ ثَلَاثِينَ ثَلَاثِينَ.

(وَإِنْ مَاتَ عَنْ رَجْعِيَّةٍ: انْتَقَلَتْ إِلَى) عِدَّةِ (وَفَاةٍ) وَسَقَطَتْ بَقِيَّةُ عِدَّةِ الطَّلَاقِ^(٢).

(أَوْ بَائِنٍ^(٣) فَلَا) تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ تُكْمَلُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ.

(وَحَامِلٍ بِوَضْعِهِ^(٤)) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأُولَاثِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فَهُوَ مُقَيَّدٌ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ^(٥).

(بِشَرْطِهِ السَّابِقِ) مِنْ انْفِصَالِ كُلِّهِ وَنِسْبَتِهِ إِلَى ذِي الْعِدَّةِ وَلَوْ اِحْتِمَالًا كَمَنْفِيٍّ بِلِغَانٍ.

(فَلَوْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ حَامِلٍ فَبِالْأَشْهُرِ) لَا بِالْوَضْعِ؛ لِأَنَّ الْحَمْلَ مَنْفِيٌّ عَنْهُ لِعَدَمِ انْزَالِهِ.

(وَكَذَا مَمْسُوحٌ) - أَيُّ: مَقْطُوعُ الذِّكْرِ وَالْأُنثَيَيْنِ - فَإِنَّهُ إِذَا مَاتَ عَنْ حَامِلٍ:

(١) أي غير حامل.

(٢) وهذا الحكم مجمع عليه.

(٣) أي مات زوجها وهي في عدة من طلاق بائن: حينئذ لا تنتقل إلى عِدَّةِ الْوَفَاةِ بَلْ تُكْمَلُ عِدَّةُ الطَّلَاقِ؛ لأنها ليست بزوجه.

(٤) أي أن عدة المتوفى عنها زوجها لو كانت حاملًا هي: وضع الحمل.

(٥) ولحديث سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةِ أَنَّهَا نَفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بَلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، «فَأَذِنَ لَهَا فَنَكَحَتْ».

- اَعْتَدْتُ بِالْأَشْهَرِ لَا بِالْوَضْعِ (إِذْ لَا يَلْحَقُهُ) الْوَلَدُ (عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّهُ لَا يَنْزِلُ، وَلَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِأَنْ يُخْلَقَ لَهُ وَلَدٌ.

- وَقَالَ الْإِصْطَخَرِيُّ وَغَيْرُهُ: يَلْحَقُهُ لِأَنَّ مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبَ وَهُوَ يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ وَهُمَا بَاقِيَانِ^(١)، وَيُحْكَى ذَلِكَ قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا بِالْوَضْعِ عَلَى هَذَا.

(وَيَلْحَقُ مَجْبُوبًا^(٢) بَقِيَ أَنْثِيَاهُ) لِبَقَاءِ أَوْعِيَةِ الْمَنِيِّ وَقَدْ يَصِلُ إِلَى الرَّجَمِ بِغَيْرِ إِيْلَاجٍ (فَتَعْتَدُ) زَوْجَتُهُ الْحَامِلُ (بِهِ) أَيُّ بِالْوَضْعِ لَوْفَاتِهِ. وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا لِطَلَّاقِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ الْوُطْءُ.

(وَكَذَا مَسْلُولٌ) خُصِيَّتَاهُ (بَقِيَ ذَكَرُهُ) يَلْحَقُهُ الْوَلَدُ (عَلَى الْمَذْهَبِ)^(٣).

وَقِيلَ: لَا يَلْحَقُهُ، لِأَنَّهُ لَا مَاءَ لَهُ^(٤).

وَدُفِعَ: بِأَنَّهُ قَدْ يُبَالِغُ فِي الْإِيْلَاجِ فَيَلْتَدُ وَيُنْزِلُ مَاءً رَقِيقًا.

(وَلَوْ طَلَّقَ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ) مُعَيَّنَةً، أَوْ مُبْهَمَةً كَأَنَّ قَالَهُمَا: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَنَوَى مُعَيَّنَةً أَوْ لَا (وَمَاتَ قَبْلَ بَيَانِ) لِلْمُعَيَّنَةِ (أَوْ تَعْيِينِ) لِلْمُبْهَمَةِ:

- (فَإِنْ كَانَ لَمْ يَطَأْ) وَاحِدَةً مِنْهُمَا (اعْتَدْنَا لَوْفَاةً) لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا كَمَا تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُفَارَقَةً بِالطَّلَاقِ تَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ مُفَارَقَةً بِالمَوْتِ فَأَخَذْنَا بِهِ اخْتِيَاطًا.

- (وَكَذَا إِنْ وَطِئَ) كُلًّا مِنْهُمَا (وَهُمَا ذَوَاتَا أَشْهَرٍ) سَوَاءً كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَمْ رَجْعِيًّا (أَوْ أَقْرَاءِ وَالطَّلَاقُ رَجْعِيًّا) فَإِنَّهُمَا يَعْتَدَانِ عِدَّةَ الْوُفَاةِ، وَإِنْ احْتَمَلَ أَنْ لَا يَلْزِمَهُمَا إِلَّا عِدَّةُ الطَّلَاقِ الَّتِي هِيَ أَقَلُّ مِنْ عِدَّةِ الْوُفَاةِ فِي ذَاتِ الْأَشْهَرِ وَكَذَا ذَاتِ الْأَقْرَاءِ بِنَاءً عَلَى الْغَالِبِ مِنْ أَنَّ كُلَّ

(١) أي: مَعْدِنَ الْمَاءِ الصُّلْبُ والمجرى الذي يَنْفُذُ مِنْ ثُقْبَةٍ إِلَى الظَّاهِرِ

(٢) المَجْبُوبُ هو: مَنْ قَطَعَ ذَكَرَهُ وَبَقِيَتِ الْخُصِيَّتَانِ.

(٣) يَلْحَقُ الْمَسْلُولُ الْوَلَدُ: لِبَقَاءِ آلَةِ الْجَمَاعِ: وَبِالتَّالِي تَعْتَدُ زَوْجَتُهُ الْحَامِلُ بِالْوَضْعِ.

(٤) وَهَنَاكَ وَجْهٌ ثَالِثٌ وَهُوَ: قِيلَ: إِنْ قَالَ أَهْلُ الْخَبَرَةِ: لَا يُولَدُ لَهُ لَمْ يَلْحَقْهُ وَلَا لِحَقَهُ، وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ فِي مِثْلِ عَصْرِنَا،

وَأَهْلُ الْخَبَرَةِ هُمُ الْأَطِبَاءُ الْمُتَخَصِّصِينَ فِي الْحُكْمِ عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَاتِ.

شَهْرٍ لَا يَخْلُو عَنْ حَيْضٍ وَطَهْرٍ أَخْذًا بِالِاخْتِيَاظِ أَيْضًا، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الرَّجْعِيَّةَ تَنْتَقِلُ إِلَى عِدَّةِ الْوَفَاةِ أَيْضًا.

- (فَإِنْ كَانَ) الطَّلَاقُ فِي ذَوَاتِي الْأَقْرَاءِ . (بَائِنًا اعْتَدَّتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا) بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ وَثَلَاثَةٍ مِنْ أَقْرَائِهَا) اخْتِيَاظًا أَيْضًا.

(وَعِدَّةُ الْوَفَاةِ مِنَ الْمَوْتِ، وَالْأَقْرَاءُ مِنَ الطَّلَاقِ) فَلَوْ مَضَى قُرْءٌ أَوْ قُرْءَانِ قَبْلَ الْمَوْتِ: اعْتَدَّتْ بِالْأَكْثَرِ مِنْ عِدَّةِ وَفَاةٍ، وَمِنْ قُرْأَيْنِ، أَوْ قُرْءٍ.

(وَمِنْ غَابٍ) بِسَفَرٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبْرُهُ:

- لَيْسَ لِرُؤُوسِهِ نِكَاحٌ) لِعَظِيمِهِ (حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ، أَوْ طَلَاقُهُ)؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بِبَيِّنٍ فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِبَيِّنٍ.

- وَعَنْ الْقَفَالِ لَوْ أَخْبَرَهَا عَذْلٌ بِوَفَاتِهِ حَلَّ لَهَا أَنْ تُنْكَحَ غَيْرُهُ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى.

- (وَفِي الْقَدِيمِ: تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُ لَوَفَاةٍ وَتُنْكَحُ) غَيْرُهُ قَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - رَوَاهُ مَالِكٌ^(١).

وَتَحْسُبُ الْمُدَّةَ: مِنْ وَقْتِ انْقِطَاعِ الْخَبَرِ.

لَكِنْ تَقْتَضِرُ^(٢) إِلَى ضَرْبِ الْقَاضِي لَهَا فِي الْأَصَحِّ فَلَا يَحْسُبُ مَا مَضَى قَبْلَهُ.

وَإِذَا ضَرَبَهَا بَعْدَ ظُهُورِ الْحَالِ عِنْدَهُ فَمَضَتْ: فَلَا بُدَّ مِنَ الْحُكْمِ بِوَفَاتِهِ وَخُصُولِ الْفُرْقَةِ فِي الْأَصَحِّ.

وَهَلْ يَنْفُذُ الْحُكْمُ بِالْفُرْقَةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا كَالْفَسْخِ بِالْغَنَةِ، أَوْ ظَاهِرًا فَقَطْ: وَجْهَانِ: مُسْتَنَدُ الثَّانِي أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لَمَّا عَادَ الْمَفْقُودُ مَكَّنَهُ مِنْ أَخْذِ زَوْجَتِهِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ^(٣).

(١) موطأ مالك، كتاب: الطلاق، باب: مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْيَتَامَى زَوْجَهَا، ح: (٢١٣٤)

(٢) أي ابتداء المدة.

(٣) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب: العدد، باب: مَنْ قَالَ بِتَخْيِيرِ الْمَفْقُودِ إِذَا قَدِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ، ح:

(١٥٥٧٠).

- (فَلَوْ حَكَمَ بِالْقَدِيمِ) أَيِّ بِمَا قَبِلَ فِيهِ مِنَ الْوَفَاءِ وَحُصُولِ الْفُرْقَةِ بَعْدَ الْمُدَّةِ (قَاضٍ):
- (نُقِضَ) حُكْمُهُ (عَلَى الْجَدِيدِ فِي الْأَصَحِّ)؛ لِمَخَالَفَتِهِ لِلْقِيَاسِ الْجَلِيِّ فَإِنَّهُ لَا يَحْكُمُ بِوَفَاتِهِ فِي قِسْمَةِ مِيرَاثِهِ. وَلَا فَارِقَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ فُرْقَةِ النِّكَاحِ.
- وَالْوَجْهُ الثَّانِي: لَا يُنْقَضُ حُكْمُهُ بِمَا ذُكِرَ؛ لِاخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ فِيهِ.
- (وَلَوْ نَكَحَتْ بَعْدَ التَّرْبُصِ وَالْعِدَّةِ فَبَانَ) الزَّوْجُ (مَيْتًا) وَقَتَ الْحُكْمِ بِالْفُرْقَةِ^(١):
- (صَحَّ) النِّكَاحُ (عَلَى الْجَدِيدِ) أَيْضًا (فِي الْأَصَحِّ)؛ لِخُلُوهُ مِنَ الْمَانِعِ فِي الْوَاقِعِ.
- وَالثَّانِي: لَا يَصِحُّ؛ لِانْتِفَاءِ الْجَزْمِ بِخُلُوهِ مِنَ الْمَانِعِ وَقَتَ عَقْدِهِ.
- وَلَوْ بَانَ الزَّوْجُ حَيًّا بَعْدَ أَنْ نَكَحَتْ^(٢):
- فَهُوَ عَلَى الْقَدِيمِ: عَلَى زَوْجِيَّتِهِ كَالْجَدِيدِ^(٣)؛ لِتَبَيُّنِ الْخَطَا فِي الْحُكْمِ لَكِنْ لَا يَطُوعًا حَتَّى تَعْتَدَّ لِلثَّانِي.
- وَقِيلَ: هِيَ زَوْجَةُ الثَّانِي؛ لِازْتِفَاعِ نِكَاحِ الْأَوَّلِ بِنَاءً عَلَى نَفْوذِ الْحُكْمِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا.
- وَقِيلَ: الْأَوَّلُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنَ الثَّانِي وَبَيْنَ أَنْ يَتْرُكَهَا وَيَأْخُذَ مِنْهُ مَهْرَ مِثْلِ لِقَضاءِ عَمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِذَلِكَ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ^(٤).
- (وَيَجِبُ الْإِحْدَادُ)^(٥) عَلَى مُعْتَدَّةٍ وَفَاءً؛ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيْتٍ، فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»^(١) أَيُّ: فَإِنَّهَا يَحِلُّ لَهَا الْإِحْدَادُ عَلَيْهِ أَيُّ يَجِبُ بِالْإِجْمَاعِ عَلَى إِزَادَتِهِ.

(١) أي لوقولنا بالقول القديم ونكحت بعد التربص والعدة فبان الزوج ميتًا وقت الحكم بالفرقة، فهل يصح النكاح على القول الجديد؟

(٢) أي لوقولنا بالقول القديم ونكحت بعد التربص والعدة فبان الزوج حيًا بعد أن نكحت، فهي زوجة لمن؟

(٣) أي أنها زوجة الأول.

(٤) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب: العدد، باب: مَنْ قَالَ بِتَخْيِيرِ الْمُفْقُودِ إِذَا قَدِمَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الصَّدَاقِ وَمَنْ أَنْكَرَهُ، ح:

(١٥٥٧٠).

(٥) الْإِحْدَادُ: مَا خُذَ مِنَ الْحَدِّ، وَهُوَ الْمَنْعُ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَمْنَعُ مِنَ الزَّيْنَةِ وَنَحْوِهَا.

(لَا رَجْعِيَّة) أَي لَا يَجِبُ عَلَيْهَا لِتَوَقُّعِ الرَّجْعَةِ^(٢)، قَالَ بَعْضُهُمْ: وَالْأَوَّلَى أَنْ تَتَزَيَّنَ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِلَى رَجْعَتِهَا.

وَرَوَى أَبُو ثَوْرٍ عَنِ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا الْإِحْدَادُ

(وَيُسْتَحَبُّ لِبَائِنٍ) بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ^(٣)، (وَفِي قَوْلٍ: يَجِبُ) كَمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا؛ بِجَامِعِ الْإِعْتِدَادِ عَنْ نِكَاحٍ^(٤).

وَفَرَّقَ: بِأَنَّهَا^(٥) مَجْفُوءَةٌ بِالطَّلَاقِ، فَلَا يَلِيقُ بِهَا إِجَابُ الْإِحْدَادِ بِخِلَافِ الْمُتَوَفَى عَنْهَا زَوْجُهَا. (وَهُوَ^(٦)) تَرَكَ لُبْسَ مَصْبُوعٍ لِزَيْنَةٍ، وَإِنْ خَشِنَ؛ لِحَدِيثِ الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ «كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحَدِّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَأَنْ نَكْتَحِلَ وَأَنْ نَتَطَيَّبَ وَأَنْ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوعًا»^(٧).

(وَقِيلَ: يَحِلُّ مَا صُبِغَ غَزْلُهُ ثُمَّ نُسِجَ) كَالْبُرُودِ لِانْتِفَاءِ الزَّيْنَةِ فِيهِ بِخِلَافِ مَا صُبِغَ بَعْدَ النَّسِجِ كَالْمَعْصَرِ وَالْمَرْعَرِ.

(وَيُبَاحُ غَيْرُ مَصْبُوعٍ مِنْ قُطْنٍ وَصُوفٍ وَكَتَّانٍ).

وَكَذَا إِبْرَيْسَمُ^(٨) أَي حَرِيرٌ (فِي الْأَصَحِّ) كَالْكَتَّانِ، إِذَا لَمْ تُحْدِثْ فِيهِ زَيْنَةً، كَنُقْشٍ. وَالثَّانِي: يُحَرِّمُ، لِأَنَّهُ لُبْسُهُ تَزْيِينٌ.

فَعَلَى هَذَا يُحَرِّمُ الْعَتَابِيُّ^(٩) الَّذِي غَلَبَ فِيهِ الْإِبْرَيْسَمُ.

(١) صحيح البخاري، كتاب: الجنائز، باب: إحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا، ح: (١٢٨٠)، صحيح مسلم، كتاب: الطلاق،

بَابُ: وَجُوبِ الْإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ، ح: (١٤٨٦).

(٢) ولبقاء أكثر أحكام النكاح في حق المعتدة الرجعية.

(٣) أي يُسْتَحَبُّ الْإِحْدَادُ لِبَائِنٍ بِخُلْعٍ أَوْ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ؛ لِأَنَّ النِّصَّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُتَوَفَى عَنْهَا، وَلَيْسَتْ الْبَائِنُ فِي مَعْنَاهَا.

(٤) أي يَجِبُ الْإِحْدَادُ لِبَائِنٍ بِخُلْعٍ أَوْ بِطَلَاقِ ثَلَاثٍ؛ قِيَاسًا عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بِجَامِعِ الْإِعْتِدَادِ عَنْ نِكَاحٍ.

(٥) أي المعتدة البائنة.

(٦) أي: الإحْدَادُ.

(٧) صحيح البخاري، كتاب: الحيض، باب: الطَّيِّبُ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ غُسْلِهَا مِنَ الْمَحِيضِ، ح: (٣١٣)، صحيح مسلم، كتاب:

الطلاق، بَابُ: انْقِضَاءِ عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَغَيْرِهَا بِوَضْعِ الْحَمْلِ، ح: (٩٣٨).

(٨) الإبريسم: حرير مخلوط بالقطن.

وَيَبَاحُ الْخَزْ^(١) قَطْعًا لِاسْتِتَارِ الْإِبْرَيْسِمِ فِيهِ بِالصُّوفِ الَّذِي هُوَ سِدَادُهُ.

(و) يَبَاحُ (مَصْبُوعٌ لَا يَقْصِدُ لَزِينَةً) بَلْ لِمُصِيبَةٍ أَوْ اِحْتِمَالٍ وَسَخٍ كَالْأَسْوَدِ وَالْكُحْلِيِّ لِانْتِفَاءِ الزَّيْنَةِ.

وَإِنْ تَرَدَّدَ الْمَصْبُوعُ بَيْنَ الزَّيْنَةِ وَغَيْرِهَا كَالْأَخْضَرِ وَالْأَزْرَقِ:

- فَإِنْ كَانَ بَرَّاقًا صَافِي اللَّوْنِ حُرِّمَ؛ لِأَنَّهُ مُسْتَحْسَنٌ يَتَزَيَّنُ بِهِ.

- أَوْ كَدِرًا، مُشَبَّعًا فَلَا ؛ لِأَنَّ الْمُشَبَّعَ مِنَ الْأَخْضَرِ يُقَارِبُ الْأَسْوَدَ، وَمِنْ الْأَزْرَقِ يُقَارِبُ الْكُحْلِيَّ.

(وَيُحَرِّمُ حُلِيَّ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ)؛ لِحَدِيثِ «الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَا تَلْبَسُ الْمُعْصَفَرِ مِنَ الثِّيَابِ وَلَا الْمُمَشَّقَةَ وَالْكُحْلِيَّ وَلَا تَخْتَضِبُ، وَلَا تَكْتَحِلُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ^(٣).

وَالْمُمَشَّقَةُ الْمَصْبُوعَةُ بِالْمِشْقَةِ بِكَسْرِ الْمِيمِ وَهِيَ الْمَغْرَةُ بِفَتْحِهَا، وَيُقَالُ: طِينٌ أَحْمَرُ يُشَبِّهُهَا^(٤).

وَيَسْتَوِي فِي الْحُلِيِّ الْخُلْخَالُ وَالسَّوَارُ وَالْخَاتَمُ وَغَيْرُهَا؛ لِإِطْلَاقِ الْحَدِيثِ، وَقَالَ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ: يَجُوزُ لَهَا التَّخْتُمُ بِخَاتَمِ الْفِضَّةِ كَالرَّجُلِ، وَإِنَّمَا يُحَرِّمُ عَلَيْهَا مَا تَخْتَصُّ النِّسَاءُ بِحِلِّهِ.

(وَكَذَا) يُحَرِّمُ (لَوْلُو فِي الْأَصَحِّ)؛ لِظُهُورِ الزَّيْنَةِ فِيهِ^(٥)، وَالثَّانِي: لَا يُحَرِّمُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ كَالذَّهَبِ وَلَا يُحَرِّمُ عَلَى الرَّجُلِ.

(١) الْعَتَابِيُّ: صَنَفَ مِنَ الْأَقْمِشَةِ الْغَلِيظَةِ الْمَتَمُوجَةِ، وَسَمِيَتْ بِهَذَا نِسْبَةً إِلَى مَكَانٍ بِبَغْدَادٍ هِيَ الْعَتَابِيَّةُ كَانَتْ تَصْنَعُ هَذِهِ الْأَقْمِشَةَ.

(٢) الْخَزْ: نَسِيجٌ مِنْ حَرِيرٍ خَالِصٍ، أَوْ مِنْ حَرِيرٍ وَصُوفٍ، وَهَذَا الْآخِرُ هُوَ الْمُرَادُ هُنَا.

(٣) سَنَنَ أَبُو دَاوُدَ، كِتَابُ: الطَّلَاقِ، بَابُ: فِيمَا تَجْتَنِبُ الْمَعْتَدَةُ فِي عِدَّتِهَا، ح: (٢٣٠٣). سَنَنَ النَّسَائِيُّ، كِتَابُ: الطَّلَاقِ، بَابُ: مَا تَجْتَنِبُ الْحَادَّةُ مِنَ الثِّيَابِ الْمُصَبَّغَةِ، ح: (٣٥٣٥).

(٤) الْمُرَادُ هُنَا الثِّيَابُ الْمَصْبُوعَةُ بِلَوْنٍ أَحْمَرَ صَرِيحٍ أَوْ أَحَدَى دَرَجَاتِهِ كَاللَّوْنِ الَّذِي بِنَاصِعِ الْحَمْرَةِ، أَوْ لَوْنِ الشَّقْرَةِ الْمَخْلُوطِ بِالْكَدْرَةِ.

(٥) وَلِأَنَّهُ حُلِيٌّ: قَالَ تَعَالَى: {يُحْلَوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤًا}

قَالَ الرَّوْيَانِيُّ: وَلَوْ تَحَلَّتْ بِنُحَاسٍ أَوْ رَصَاصٍ مُمَوَّهٍ بِذَهَبٍ، أَوْ فِضَّةٍ أَوْ مُشَابِهِ لَهُمَا بِحَيْثُ لَا يُعْرِفُ إِلَّا بَعْدَ التَّأَمُّلِ لَمْ يَجُزْ. وَإِلَّا فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَرَتَّبُونَ بِمِثْلِهِ، لَمْ يَجُزْ أَيْضًا أَوْ يَسْتَعْمِلُونَهُ لِمَنْفَعَةٍ يَتَوَهَّمُونَهَا فِيهِ جَازٌ.

(و) يُحَرِّمُ (طِيبٌ فِي بَدَنِ وَثُوبٍ)؛ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ: "وَأَنْ نَتَطَيَّبَ" (وَطَعَامٌ وَكُحْلٌ) غَيْرَ مُحَرَّمٍ قِيَاسًا عَلَى الْبَدَنِ وَالثُّوبِ.

(و) يُحَرِّمُ (الْكُحْلَ بِإِثْمِدٍ^(١)) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ طِيبٌ؛ لِحَدِيثِ أُمِّ عَطِيَّةَ السَّابِقِ: "وَأَنْ نَكْتَحِلَ" (إِلَّا لِحَاجَةٍ كَرَمَدٍ) فَتَكْتَحِلُ بِهِ لَيْلًا وَتَمْسُحُهُ نَهَارًا، فَإِنْ دَعَتْ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِي النَّهَارِ جَازَ فِيهِ.

وَالْكُحْلُ الْأَصْفَرُ - وَهُوَ الصَّبِرُ - بِكُسْرِ النَّبَاءِ، كَالْإِثْمِدِ فِي الْحُرْمَةِ، لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ وَهِيَ حَادَّةٌ عَلَى أَبِي سَلَمَةَ، وَقَدْ جَعَلَتْ عَلَى عَيْنَيْهَا صَبْرًا، فَقَالَ مَا هَذَا يَا أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: هُوَ صَبِرٌ لَا طِيبَ فِيهِ فَقَالَ: اجْعَلِيهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيهِ بِالنَّهَارِ»^(٢).

أَمَّا الْكُحْلُ الْأَبْيَضُ كَالثُّوْتِيَا:

- فَلَا يُحَرِّمُ، لِأَنَّهُ لَا زِينَةَ فِيهِ.

- وَقِيلَ: يُحَرِّمُ عَلَى الْبَيْضَاءِ حَيْثُ تَتَزَيَّنُ بِهِ.

- وَقِيلَ: لَا يُحَرِّمُ الْأَصْفَرُ عَلَى الْبَيْضَاءِ.

- وَقِيلَ: لَا يُحَرِّمُ الْإِثْمِدُ عَلَى السَّوْدَاءِ؛ لِأَنَّهُ بِسَوَادِهِ لَا يُفِيدُهَا جَمَالًا.

(و) يُحَرِّمُ (الْإِسْفِيدَاجُ)^(٣) بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ (وَدِمَامٌ)^(١) - بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَكُسْرِهَا وَهُوَ الْمُسَمَّى بِالْحُمْرَةِ -؛ لِأَنَّهُمَا يَتَرَتَّبَانِ بَعْضُهُمَا الْوَجْهَ.

(١) الإِثْمِدُ: حَجَرٌ يُتَّخَذُ مِنْهُ الْكُحْلُ.

(٢) سنن أبوداود، كتاب: الطلاق، باب: فيما تجتنب المعتدة في عدتها، ح: (٢٣٠٥).

(٣) الْإِسْفِيدَاجُ: هُوَمَا يَتَّخَذُ مِنْ رِصَاصٍ يَطْلَى بِهِ الْوَجْهَ لِيَبْيَضَهُ.

وَكَذَا يُحَرِّمُ الْإِثْمُ فِي الْحَاجِبِ؛ لِأَنَّهُ يُتَرَيَّنُ بِهِ.

(وَحِصَابُ حَنَاءٍ) وَنَحْوُهُ لِحَدِيثِ أَبِي دَاوُدَ السَّابِقِ، وَلَا تَخْتَضِبُ، وَذَلِكَ فِيمَا يَظْهَرُ مِنَ الْبَدَنِ كَالْوَجْهِ، وَالْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ وَلَا يُحَرِّمُ فِيمَا تَحْتَ الثِّيَابِ ذَكَرَهُ الرُّوْيَانِيُّ.

(وَيَحِلُّ تَجْمِيلُ فِرَاشٍ وَأَثَاثٍ) بِأَنْ تُزَيَّنَ بَيْتُهَا بِالْفِرَاشِ وَالسُّتُورِ، وَغَيْرِهِمَا؛ لِأَنَّ الْحِدَادَ فِي الْبَدَنِ لَا فِي الْفِرَاشِ وَالْمَكَانِ.

(و) يَحِلُّ (تَنْظُفُ بِغَسْلِ رَأْسٍ وَقَلَمٍ) لِأَطْفَارٍ (وَارِزَالَةٍ وَسَخٍ).

قُلْتُ: وَيَحِلُّ امْتِشَاطُ وَحَمَامٍ إِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ خُرُوجٌ مُحَرَّمٌ) وَاسْتِحْدَادٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ كُلَّهُ لَيْسَ مِنَ الزَّيْنَةِ.

(وَلَوْ تَرَكَتِ الْإِحْدَادَ) الْوَاجِبَ عَلَيْهَا كُلَّ الْمُدَّةِ، أَوْ بَعْضَهَا: (عَصَتْ) وَانْقَضَتْ الْعِدَّةُ كَمَا لَوْ فَارَقَتْ الْمُسْكَنَ) الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهَا مُلَازِمَتُهُ فَإِنَّهَا تَعْصِي وَتَنْقُضِي عِدَّتَهَا، بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ.

(وَلَوْ بَلَغَتْهَا الْوَفَاءُ بَعْدَ الْمُدَّةِ) أَيُّ مُدَّةٍ عِدَّةِ الْوَفَاءِ: (كَانَتْ مُنْقَضِيَةً) لِمُضِيِّ مُدَّتِهَا^(١).

(وَلَهَا) أَيُّ الْمَرْأَةِ (إِحْدَادٌ عَلَى غَيْرِ زَوْجٍ) مِنَ الْمَوْتِ (ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ) فَمَا دُونَهَا. (وَتَحَرَّمَ الزِّيَادَةُ) عَلَيْهَا؛ وَذَلِكَ مَاخُذٌ مِنْ حَدِيثِي الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقَيْنِ، وَقَدْ ذَكَرَ هَذِهِ الْمَسَائِلَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ بِحُرْمَةِ الزِّيَادَةِ.

(١) الْيَمَامُ: الْحُمْرَةُ الَّتِي يُورَدُ بِهَا الْحَدُّ.

(٢) وبالتالي لا حداد عليها حينئذ.

فَصَلِّ: تَجِبُ سُكْنَى لِمُعْتَدَّةٍ طَلَّقَ وَلَوْ بَائِنٌ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ حَامِلًا كَانَتْ أَوْ حَائِلًا؛ قَالَ تَعَالَى {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ} [الطلاق: ٦].

(إِلَّا نَاشِزَةً) بِأَنْ طَلَّقَتْ حَالَ نُشُوزِهَا، فَإِنَّهَا لَا سُكْنَى لَهَا فِي الْعِدَّةِ^(١).

وَلَوْ نَشِزَتْ فِي الْعِدَّةِ، سَقَطَتْ سُكْنَاهَا فَإِنْ عَادَتْ إِلَى الطَّاعَةِ، عَادَ حَقُّ السُّكْنَى وَقِيلَ: إِنْ نَشِزَتْ عَلَى الزَّوْجِ وَهِيَ فِي بَيْتِهِ فَلَهَا السُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ، وَإِنْ خَرَجَتْ وَاسْتَعَصَتْ عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، فَلَا سُكْنَى لَهَا.

(وَلِمُعْتَدَّةٍ وَفَاةٍ فِي الْأَظْهَرِ)^(٢)؛ لِحَدِيث «فُرَيْعَةَ بَضَمَ الْفَاءِ بِنْتُ مَالِكٍ أُخْتُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ زَوْجَهَا قُتِلَ فَسَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهَا، وَقَالَتْ إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْنِي فِي مَنْزِلٍ يَمْلِكُهُ فَأَذِنَ لَهَا فِي الرَّجُوعِ. قَالَتْ فَأَنْصَرَفْتُ حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحَجْرَةِ أَوْ فِي الْمَسْجِدِ دَعَانِي فَقَالَ: أُمْكِنِي فِي بَيْتِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ، قَالَتْ: فَأَعْتَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» صَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ^(٣).

وَالثَّانِي: لَا سُكْنَى لَهَا، كَمَا هُوَ قَضِيَّةٌ إِذْنِ النَّبِيِّ لِفُرَيْعَةَ أَوَّلًا^(٤).

وَقَوْلُهُ لَهَا ثَانِيًا: " أُمْكِنِي فِي بَيْتِكَ " مَحْمُولٌ عَلَى النَّدْبِ جَمْعًا بَيْنَهُمَا^(٥).

وَيُجَابُ: بِأَنْ حَمَلَهُ عَلَى الْوُجُوبِ أَرْجَحُ^(١).

(١) لأن الناشز لا تستحق النفقة والسكنى في صلب النكاح فبعد البيونة أولى.

(٢) أي تجب السكنى للمعتدة من وفاة في الأظهر.

(٣) أخرجه أحمد في مسنده. برقم: (٢٧٠٨٧)، والنسائي في سننه، كتاب: الطلاق، ب: عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ، رقم: (٣٥٣٢)، والحاكم في المستدرک، کتاب: الطلاق، برقم (٢٨٣٣)، وقال: "هَذَا حَدِيثٌ

صَحِيحُ الْإِسْنَادِ مِنَ الْوُجْهَيْنِ جَمِيعًا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ".

(٤) واستدل أيضا لهذا القول بما يلي:

١- ما روى البهقي بإسناد صحيح: أن عليا ؓ نقل ابنته أم كلثوم من دار الإمارة بعدما استشهد

عمر رضي الله عنهم بسبع ليال.

٢- ولأنه لا نفقة لها فلا سكنى لها.

(٥) هذه مناقشة لدليل القول الأول.

(وَفَسَخَ عَلَى الْمَذْهَبِ) ^(٢) كَالطَّلَاقِ بِجَامِعِ فُرْقَةِ النِّكَاحِ وَفِي الْحَيَاةِ ^(٣). وَسَوَاءُ الْفَسْخُ بِرَدِّهٖ وَإِسْلَامٍ وَرَضَاعٍ وَعَيْبٍ.

وَالطَّرِيقُ الثَّانِي أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهُمَا: لَا تَجِبُ؛ لِأَنَّ وُجُوبَهَا بَعْدَ زَوَالِ النِّكَاحِ مُسْتَبَعَدٌ، وَالنَّصُّ إِنَّمَا وَرَدَ فِي الْمُطْلَقَةِ فَيَبْقَى غَيْرُهَا عَلَى الْأَصْلِ.

وَالثَّالِثُ: إِنْ كَانَ لَهَا مَدْخَلٌ فِي ارْتِفَاعِ النِّكَاحِ، كَأَنْ فَسَخَتْ بِعَيْبِ الزَّوْجِ أَوْ فَسَخَ هُوَ بِعَيْبِهَا فَلَا سَكْنَى لَهَا قَطْعًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَدْخَلٌ فِي ارْتِفَاعِهِ كَأَنْ انْفَسَخَ بِإِسْلَامِ الزَّوْجِ أَوْ رَدِّهِ وَالرَّضَاعِ مِنْ أَجْنَبِيٍّ، فَفِي وُجُوبِ السَّكْنَى لَهَا الْقَوْلَانِ.

وَالرَّابِعُ: كَالثَّالِثِ فِي شِقِّهِ الْأَوَّلِ، وَيَجِبُ فِي الشَّقِّ الثَّانِي قَطْعًا ^(٤).

(وَتَسْكُنُ فِي مَسْكَنِ كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفُرْقَةِ) ^(٥) وَلَيْسَ لِزَوْجٍ وَغَيْرِهِ إِخْرَاجُهَا وَلَا لَهَا خُرُوجٌ مِنْهُ. فَلَوْ اتَّفَقَتْ مَعَ الزَّوْجِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ لَمْ يَجْزُ وَعَلَى الْحَاكِمِ الْمَنْعُ مِنْهُ، لِأَنَّ فِي الْعِدَّةِ حَقَّ اللَّهِ تَعَالَى، وَقَدْ وَجَبَ فِي ذَلِكَ الْمَسْكَنِ قَالَ تَعَالَى {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١].

وَإِضَافَةُ الْبُيُوتِ إِلَيْهِنَّ: مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مَسْكَنُهُنَّ قَالَ فِي النِّهَايَةِ: وَالرَّجْعِيَّةُ كَغَيْرِهَا فِي ذَلِكَ، قَالَ فِي الْمَطْلَبِ وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ.

وَفِي الْحَاوِيِ وَالْمُهَذَّبِ أَنَّ لِلزَّوْجِ أَنْ يُسْكِنَهَا حَيْثُ شَاءَ كَالزَّوْجَةِ وَجَزَمَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي نَكْتِ التَّنْبِيهِ.

(١) وهذا جواب على المناقشة.

(٢) أي تجب السكنى للمعتدة من فسخ على الراجح من حكاية المذهب.

(٣) أي قياساً على الطَّلَاقِ بِجَامِعِ أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي كُلِّ مَعْتَدَةٍ عَنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ بِفُرْقَةٍ فِي الْحَيَاةِ.

(٤) ذكر الشارح رحمه الله ثلاثة أقوال فقط : لأن القول الثاني: وهو وجوب السكنى لمعلوم بدليله من الطريق الأول (المذهب).

(٥) ولكن يشترط أن يكون هذا المسكن لانفا بها حال الطلاق، ويمكن بقاؤها فيه؛ لكونه ملكاً للزوج أو مستأجراً.

(قُلْتُ وَلَهَا الْخُرُوجُ فِي عِدَّةٍ وَفَاءٍ. وَكَذَا بَائِنٌ^(١) فِي النَّهَارِ لِشِرَاءِ طَعَامٍ وَغَزْلٍ وَنَحْوِهِ) لِحَاجَتِهَا إِلَى ذَلِكَ وَعَبَّرَ فِي الرُّوْضَةِ كَأَصْلِهَا بِشِرَاءِ طَعَامٍ أَوْ قُطْنٍ أَوْ بَيْعِ غَزْلٍ. (وَكَذَا لَيْلًا إِلَى دَارِ جَارَةٍ لَغَزْلِ وَحَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا) لِلتَّائِسِ فِيهَا لَكِنْ (بِشَرْطِ أَنْ تَرْجِعَ وَتَبَيَّتَ فِي بَيْتِهَا).

وَفِي الْبَائِنِ قَوْلٌ قَدِيمٌ أَنَّهَا لَا تَخْرُجُ لِمَا ذَكَرَ^(٢)، بِخِلَافِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا لِمَا وَرَدَ فِيهَا مِنْ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ «أَنَّ رَجُلًا أَسْتَشْهَدُوا بِأَحَدٍ فَقَالَتْ نِسَاؤُهُمْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ فِي بُيُوتِنَا، فَتَبَيَّتْ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ، فَأَذِنَ لِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَتَحَدَّثَنَّ عِنْدَ إِحْدَاهُنَّ، فَإِذَا كَانَ وَقْتُ النَّوْمِ تَأْوِي كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا» رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ^(٣).

أَمَّا الرَّجْعِيُّ فَلَا تَخْرُجُ، لِمَا ذَكَرَ^(٤)، إِلَّا بِإِذْنِهِ كَالزَّوْجَةِ إِذْ عَلَيْهِ الْقِيَامُ بِكَفَايَتِهَا.

(وَتَنْتَقِلُ مِنَ الْمَسْكَنِ لَخَوْفٍ مِنْ هَدْمٍ أَوْ غَرَقٍ) عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا (أَوْ عَلَى نَفْسِهَا) مِنْ فُسَاقٍ مُجَاوِرِينَ لَهَا (أَوْ تَأَذَّتْ بِالْجِيرَانِ أَوْ هَمَّ بِهَا أَدَى شَدِيدًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ كُلُّهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ.

وَمِمَّا يُصَدَّقُ بِهِ الْجِيرَانُ: الْأَحْمَاءُ وَقَدْ فسر ابن عباس رضي الله عنها قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ} [الطلاق: ١] بِالْبَدَاءِ بِاللِّسَانِ عَلَى الْأَحْمَاءِ (وَلَوْ انْتَقَلَتْ إِلَى مَسْكَنِ بِإِذْنِ الزَّوْجِ فَوَجَبَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ وُصُولِهَا إِلَيْهِ: اغْتَدَّتْ فِيهِ عَلَى النَّصِّ) لِأَنَّهَا مَأْمُورَةٌ بِالْمَقَامِ فِيهِ.

وَقِيلَ: تَعْتَدُّ فِي الْأَوَّلِ لِأَنَّهَا لَمْ تَحْصُلْ وَقْتُ الْفِرَاقِ فِي الثَّانِي

(١) أي الراجح أن البائنة تخرج بالنهار لشراء طعام ونحوه: لحديث مسلم عن جابر قال: طلقت خالتي سلمى، فأرادت أن تجذ نخلها، فزجرها رجل إن تخرج، فأنت النبي ﷺ فقال: (خذي نخلك؛ فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفًا).

وأما دليل جواز خروج المتوفى عنها زوجها نهاراً لحاجة هو: الحديث الآتي ذكره، والقياس على البائنة بل هي أولى.

(٢) أي لعموم قوله تعالى: "ولا يخرجن من بيوتهن".

(٣) أخرجه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: العدد، باب: كَيْفِيَّةُ سُكْنَى الْمُطَلَّاقَةِ وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا، برقم (١٥٥١٢).

(٤) أي لعموم قوله تعالى: "ولا يخرجن من بيوتهن".

وَقِيلَ: تَتَخَيَّرُ بَيْنَهُمَا لِأَنَّهَا غَيْرُ مُسْتَقَرَّةٍ فِي وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَالَةَ الْفِرَاقِ، وَلَهَا تَعَلُّقٌ بِكُلِّ مِنْهُمَا.
 وَقِيلَ: تَعْتَدُّ فِي أَقْرَبِهِمَا إِلَيْهَا عِنْدَ الْفِرَاقِ، وَإِنْ اسْتَوَيَا تَخَيَّرَتْ.
 أَمَّا إِذَا وَجِبَتْ الْعِدَّةُ بَعْدَ وُصُولِهَا إِلَى الثَّانِي: فَتَعْتَدُّ فِيهِ جَزْمًا.
 وَإِنْ لَمْ تَنْقُلِ الْأَمْتِعَةَ مِنَ الْأَوَّلِ.
 (أَوْ بِغَيْرِ إِذْنٍ فِيهِ الْأَوَّلِ) تَعْتَدُّ^(١).
 (وَكَذَا لَوْ أَدْنَى ثُمَّ وَجِبَتْ قَبْلَ الْخُرُوجِ) مِنْهُ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ فِيهِ^(٢).
 (وَلَوْ أَدْنَى فِي الْإِنْتِقَالِ إِلَى بَلَدٍ فَكَمَسَكَنِ) فِيمَا ذَكَرَ: فَإِنْ وَجِبَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنَ الْبَلَدِ
 أَيْ قَبْلَ فِرَاقِ عُمُرَانِهِ اعْتَدَّتْ فِي مَسْكَنِهَا مِنْهُ.
 أَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ وَقَبْلَ الْوُصُولِ إِلَى الثَّانِي، فَفِيهِ الْخِلَافُ السَّابِقُ.
 أَوْ بَعْدَ الْوُصُولِ إِلَيْهِ، اعْتَدَّتْ فِيهِ جَزْمًا.
 (أَوْ) أَدْنَى (فِي سَفَرٍ حَجٍّ أَوْ تِجَارَةٍ ثُمَّ وَجِبَتْ فِي الطَّرِيقِ: فَلَهَا الرُّجُوعُ وَالْمُضِيُّ)^(٣) وَهِيَ
 مُعْتَدَّةٌ فِي سَيْرِهَا.
 (فَإِنْ مَضَتْ) وَبَلَغَتْ الْمَقْصِدَ (أَقَامَتْ) فِيهِ (لِقَضَاءِ حَاجَتِهَا ثُمَّ يَجِبُ الرُّجُوعُ) فِي الْحَالِ،
 (لِتَعْتَدَّ الْبَقِيَّةَ فِي الْمَسْكَنِ)^(٤)
 فَإِنْ كَانَتْ الْعِدَّةُ تَنْقُضِي فِي الطَّرِيقِ: وَجِبَ الرُّجُوعُ أَيْضًا فِي الْأَصَحِّ؛ لِلْقُرْبِ مِنْ مَوْضِعِ
 الْعِدَّةِ.
 وَإِنْ لَمْ تَمْضِ اعْتَدَّتْ الْبَقِيَّةَ فِي مَسْكَنِهَا.

(١) أي إذا انتقلت الزوجة إلى مسكن آخر بغير إذن الزوج فوجب عليها العدة بموت زوجها أو طلاقه لها: اعتدت في البيت الأول: لعصيانها بالخروج بدون إذن الزوج.

(٢) أي وجبت العدة عليها قبل الخروج من المنزل الأول فإنها تعتد فيه: لأنه المنزل الذي وجبت فيه العدة.

(٣) لأن في قطعها عن السفر مشقة، لا سيما إذا بعدت عن البلد وخافت الانقطاع عن الرفقة.

(٤) عملاً بحسب الحاجة.

وَلَوْ وَجَبَتْ الْعِدَّةُ قَبْلَ الْخُرُوجِ مِنْ مَسْكِنِهَا: لَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ.

أَوْ بَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهُ لِلسَّفَرِ وَلَمْ تُفَارِقْ عُمُرَانَ الْبَلَدِ: ^(١)

لَزِمَهَا الْعَوْدُ إِلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا لَمْ تَشْرَعْ فِي السَّفَرِ.

وَقِيلَ: تَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْعَوْدِ وَالْمُضِيِّ لِتَضَرُّرِهَا بِتَرْكِهِ الْمُقَوِّتِ لِعَرَضِهَا.

وَقِيلَ: فِي سَفَرِ الْحَجِّ تَتَخَيَّرُ، وَفِي سَفَرِ التِّجَارَةِ، يَلْزِمُهَا الْعَوْدُ.

وَالْعُمْرَةُ كَالْحَجِّ فِي جَمِيعِ مَا ذَكَرَ.

(وَلَوْ خَرَجَتْ إِلَى غَيْرِ الدَّارِ الْمَأْلُوفَةِ) لِسُكْنَاهَا (فَطَلَّقَ وَقَالَ مَا أَذْنْتُ فِي الْخُرُوجِ: صَدَقَ

بِیْمِينِهِ) لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ، فَيَجِبُ رُجُوعُهَا فِي الْحَالِ إِلَى دَارِ الْمَأْلُوفَةِ.

وَلَوْ وَافَقَهَا عَلَى الْإِذْنِ فِي الْخُرُوجِ، لَا يَجِبُ الرُّجُوعُ فِي الْحَالِ.

(وَلَوْ قَالَتْ نَقَلْتَنِي) أَيِ أَذْنْتُ فِي النُّقْلَةِ إِلَى هَذِهِ الدَّارِ فَأَعْتَدْتُ فِيهَا (فَقَالَ بَلْ أَذْنْتُ) فِي

الْخُرُوجِ إِلَيْهَا (لِحَاجَةٍ) ذَكَرَهَا فَأَعْتَدِي فِي الْأُولَى:

(صَدَقَ) بِیْمِينِهِ (عَلَى الْمَذْهَبِ)؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ الْإِذْنِ فِي النُّقْلَةِ.

وَمُقَابِلُهُ: تَصْدِيقُهَا بِیْمِينِهَا لِأَنَّ الظَّاهِرَ مَعَهَا، بِكُونِهَا فِي الثَّالِثَةِ.

وَهُمَا قَوْلَانِ مُحْكِيَانِ، فِيمَا لَوْ اخْتَلَفَتِ الزَّوْجَةُ، وَوَارِثُ الزَّوْجِ وَالْمَذْهَبُ تَصْدِيقُهَا، لِأَنَّهَا

أَعْرِفُ بِمَا جَرَى مِنَ الْوَارِثِ، بِخِلَافِ الزَّوْجِ.

(وَمَنْزِلُ بَدْوِيَّةٍ وَبَيْتُهَا مِنْ شَعْرِ كَمَنْزِلِ حَضْرِيَّةٍ) ^(٢) فَعَلَيْهَا مُلَازِمَتُهُ إِلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا.

فَإِنْ ارْتَحَلَ فِي أَتْنَائِهَا قَوْمُهَا: ارْتَحَلَتْ مَعَهُمْ لِلضَّرُورَةِ.

أَوْ أَهْلُهَا فَقَطْ وَفِي الْبَاقِيْنَ قُوَّةٌ وَعَدَدٌ: ^(١)

(١) أي وجبت العدة بعد الخروج من المسكن للسفر ولكن لم تفارق عُمُرَانَ الْبَلَدِ فهل يلزمها العودة أم لا ؟.

(٢) فإن كان أهلها نازلين على ما لا ينتقلون عنه ولا يظعنون إلا لحاجة: فهي كالحضريّة من كل وجه، وإن كانوا ينتقلون

شتاء وصيفًا ففي التفصيل المذكور.

فَقِيلَ: تَعْتَدُ بَيْنَهُمْ لَيْتِسْرَهُ.

وَالْأَصْحُ: تَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالْإِزْتِحَالِ؛ لِأَنَّ مُفَارَقَةَ الْأَهْلِ عَسِرَةٌ مُوحِشَةٌ.

(وَإِذَا كَانَ الْمَسْكَنُ) مَمْلُوكًا (لَهُ وَيَلِيقُ بِهَا تَعَيَّنَ) لِأَنَّ تَعْتَدَ فِيهِ لِمَا تَقَدَّمَ^(٢).

(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُهُ)^(٣) إِلَّا فِي عِدَّةٍ ذَاتِ أَشْهُرٍ فَكُمُسْتَأْجَرٍ^(٤) فَيَصِحُّ فِي الْأَظْهَرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْإِجَارَةِ.

(وَقِيلَ بَاطِلٌ) قَطْعًا.

وَالْفَرْقُ: أَنَّ الْمُسْتَأْجَرَ يَمْلِكُ الْمَنْفَعَةَ وَالْمُعْتَدَّةُ لَا تَمْلِكُهَا، فَكَأَنَّ الْمُطْلَقَ بَاعَهُ وَاسْتَتْنَى مَنَفَعَتَهُ لِنَفْسِهِ مُدَّةً مَعْلُومَةً، وَذَلِكَ بَاطِلٌ.

(أَوْ مُسْتَعَارًا لَزِمَتْهَا فِيهِ)^(٥).

فَإِنْ رَجَعَ الْمُعِيرُ وَلَمْ يَرْضَ بِأَجَرَةٍ: نُقِلَتْ^(٦). بِخِلَافِ مَا إِذَا رَضِيَ بِهَا فَتَلَزَمَ الْمُطْلَقُ، وَلَا تُنْقَلُ.

(وَكَذَا مُسْتَأْجَرًا انْقَضَتْ مُدَّتُهُ) فَإِذَا إِذَا لَمْ يَرْضَ مَالِكُهُ بِتَحْدِيدِ إِجَارَةِ تُنْقَلُ مِنْهُ بِخِلَافِ مَا إِذَا رَضِيَ بِذَلِكَ.

(أَوْ) مَمْلُوكًا (لَهَا اسْتَمَرَّتْ) فِيهِ لُزُومًا (وَطَلَبَتْ الْأَجَرَةَ) مِنَ الْمُطْلَقِ^(١)، قَالَهُ صَاحِبُ الْمَذْهَبِ وَالتَّهْذِيبِ.

(١) أي ارتحل أهلها فقط دون قومها وفي الباقيين من القوم قُوَّةٌ وَعَدَدٌ. فهل ترحل مع أهلها أم تبقى من الباقيين تعتد فيهم؟

(٢) أي تعين استدامة الزوجة في هذا المسكن وليس لها مفارقتها ولا تخرج منه إلا بالعذر السابق.

(٣) أي لا يصح بيع هذا المسكن إن كانت تعتد بالأقراء أو الحمل؛ لأن المنفعة مستحقة لها، وأخر المدة غير معلوم، فإن انتهت العدة جاز بيعه.

(٤) أي يُخْرَجُ بيع المسكن في مسألتنا على بيع الدار المستأجرة لمدة معلومة، والأظهر: أنه يصح بيع الدار المستأجرة، كذلك يصح هنا بيع مسكن الزوجية إذا كانت المعتدة في عدة أشهر.

(٥) أي لزمّت المعتدة المسكن المستعار قياساً على البيت المستأجر.

(٦) أي نقلت منه وجوباً؛ لحديث: (لا يحل ما امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه).

وَقَالَ صَاحِبُ الشَّامِلِ وَغَيْرُهُ، وَصَحَّحَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ: تَتَخَيَّرُ بَيْنَ الْإِسْتِمْرَارِ فِيهِ بِإِعَارَةٍ أَوْ إِجَارَةٍ وَهُوَ أَوْلَى، وَبَيْنَ طَلَبِ النَّقْلِ إِلَى غَيْرِهِ.

(فَإِنْ كَانَ مَسْكَنُ النِّكَاحِ نَفِيسًا فَلَهُ النَّقْلُ إِلَى لَائِقٍ بِهَا^(٢) أَوْ خَسِيسًا فَلَهَا الْإِمْتِنَاعُ) مِنَ الْإِسْتِمْرَارِ فِيهِ، وَطَلَبُ النَّقْلِ إِلَى لَائِقٍ بِهَا^(٣).

وَحَيْثُ تُنْقَلُ يَنْبَغِي أَنْ تُنْقَلَ إِلَى قَرِيبٍ مِنَ الْمُنْقُولِ عَنْهُ بِحَسَبِ مَا يُمَكِّنُ.

وَزَاهِرٌ كَلَامِهِمْ: أَنَّ ذَلِكَ وَاجِبٌ، وَاسْتَبْعَدَ الْغَزَالِيُّ الْوُجُوبَ وَتَرَدَّدَ فِي الْإِسْتِحْبَابِ

(وَلَيْسَ لَهُ مَسَاكِنُهَا وَمَذَاخِلُهَا) حَيْثُ فَضَّلَتْ الدَّارَ عَلَى سَكْنَى مِثْلِهَا لِمَا يَقَعُ فِيهِمَا مِنَ الْخُلُوةِ بِهَا، وَهِيَ حَرَامٌ كَالْخُلُوةِ بِأَجْنَبِيَّةٍ^(٤).

(فَإِنْ كَانَ فِي الدَّارِ مَحْرَمٌ لَهَا مُمَيَّزٌ ذَكَرٌ أَوْ مَحْرَمٌ (لَهُ) مُمَيَّزٌ (أُنْثَى أَوْ زَوْجَةٌ أُخْرَى) كَذَلِكَ (أَوْ امْرَأَةٌ أَجْنَبِيَّةٌ جَازَ) مَا ذَكَرَ^(٥)؛ لِإِنْتِفَاءِ الْمَحْدُورِ فِيهِ، وَلَكِنْ يُكْرَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُؤْمَنُ مَعَهُ النَّظَرُ.

وَلَا عِبْرَةٌ بِالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يُمَيَّزُ^(٦).

(وَلَوْ كَانَ فِي الدَّارِ حُجْرَةٌ^(٧) فَسَكَنَهَا أَحَدُهُمَا وَالْآخَرُ الْآخَرَى:

- فَإِنْ اتَّحَدَتِ الْمَرَافِقُ كَمَطْبَخٍ وَمُسْتَرَاحٍ وَمِصْعَدًا إِلَى السَّطْحِ (أَشْطَرِطَ مَحْرَمٌ) حَدَرًا مِنَ الْخُلُوةِ فِيمَا ذَكَرَ.

- (وَالَا فَلَا) يُشْتَرِطُ^(٨).

(١) لأن السكني حق لها عليه فلزم أجرته المطلق.

(٢) لأنه الواجب عليه، والمراد: نقلها إلى أقرب موضع من مسكن النكاح: حتى لا يطول ترددها في الخروج

(٣) لأن ذلك حق لها يتجدد يوما فيوماً.

(٤) ويعصي لو فعل ذلك؛ لقوله تعالى: {وَلَا تُضَاوِرُنَّ لِنُصْرَتِهِمْ عَلَيْكُمْ} أراد بذلك المسكن. ولأنه يؤدي إلى الخلوة بها وهي

محرمة، وسواء كانت بائناً أورجعية.

(٥) أي جاز في هذه الحالة السكن معها في مكان مستقل خاص به وحده، والدخول عليها مع الاستئذان.

(٦) أي لا عبرة بالمحرم غير المميز كالمجنون.

(٧) أي لا عبرة بالمحرم غير المميز كالمجنون.

(وَيَنْبَغِي أَنْ يُغْلَقَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ بَابٍ وَأَنْ لَا يَكُونَ مَمَرٌ إِحْدَاهُمَا) يَمُرُّ فِيهِ (عَلَى الْأُخْرَى) ؛
حَدَّرًا مِنَ الْخَلْوَةِ فِي ذَلِكَ.

(وَسُفْلٌ وَغُلُوٌّ كَدَارٍ وَحُجْرَةٍ) فِيمَا ذَكَرَ مِنْ أَنَّهُ إِنْ اتَّحَدَتِ الْمَرَافِقُ اشْتُرِطَ مُحَرَّمٌ وَإِلَّا لَمْ
يُشْتَرِطُ.

(١) الْحُجْرَةُ: كل منزل محوط.

كتاب^١ الرضاع

تَقَدَّمَ الْحُرْمَةُ كَالنَّسَبِ فِي بَابِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النِّكَاحِ^٢ وَالْكَلامُ هُنَا فِي بَيَانِ مَا يَحْصُلُ بِهِ وَحُكْمُ غُرُوضِهِ بَعْدَ النِّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَيَأْتِي.

شروط الرضاع: الشرط الأول: أن يكون الرضاع بلبن امرأة حية حياة مستقرة:

(إِنَّمَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ أُمْرَأَةٍ حَيَّةٍ^٣ بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِينَ^٤) فَلَا يَثْبُتُ بِلَبَنِ رَجُلٍ^٥ لِأَنَّهُ لَمْ يُخْلَقْ لِغِذَاءِ الْوَلَدِ وَلَا بِلَبَنِ خُنْثَى^٦ مَا لَمْ تَظْهَرْ أُثُوثُهُ^٧ وَلَا بِلَبَنِ بَهِيمَةٍ حَتَّى إِذَا شَرِبَ مِنْهُ صَغِيرَانِ ذَكَرٌ وَأُنْثَى لَمْ يَثْبُتْ بَيْنَهُمَا أُخُوَّةٌ لِأَنَّهُ لَا يَصْلُحُ لِغِذَاءِ الطِّفْلِ صِلَاحِيَّةً لَبَنِ الْإِنْسَانِيَّاتِ، وَلَا بِلَبَنِ مَيْتَةٍ كَأَنِ ارْتَضَعَ مِنْهَا طِفْلٌ أَوْ حَلَبَ وَأَوْجَرَهُ^٨ لِأَنَّهُ مِنْ جُنَّةٍ مُنْفَكَّةٍ عَنِ الْحِلِّ وَالْحُرْمَةِ، كَالْبَهِيمَةِ

^١ الكتاب لغة الضم واصطلاحاً مجموعة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومباحث
^٢ الرضاع: بفتح الراء، ويجوز كسرهما، وإثبات التاء معهما - لغة: اسم لمص الثدي وشرب لبنه وشرعاً: اسم لحصول لبن
 امرأة أو ما حصل منه في معدة طفل أو دماغه
 والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣] [النساء:
 ٢٣]، فذكر الله في جملة الأعيان المحرمات: الأم المرضعة، والأخت من الرضاعة، فدل على: أن له تأثيراً في
 التحريم.

وروت عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي ﷺ قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة» متفق عليه
 وإنما جعل الرضاع سبباً للتحريم: لأن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءاً للرضيع باعته به فأشبهه منها في النسب.
^٣ تقدمت الحرمة بالرضاع في باب ما يحرم من النكاح حيث أجمع العلماء على أصله، وإنما يؤثر الرضاع في تحريم
 النكاح، وثبوت المحرمية المفيدة لحلل الخلوة والنظر دون أحكام النسب: كالميراث والنفقة وغيرهما.
^٤ خرج باللبن غيره كان امتص من الثدي دماً أو قيحاً
^٥ حية حياة مستقرة حال انفصال اللبن منها
^٦ تسع سنين قمرية
^٧ إذا درلرجل لبن فريضه طفل لم يؤثر: لأن اللبن من أثر الولادة، وهي مختصة بالنساء، ولأنه ليس معدة للتغذية كغيره
 من المائعات.

^٨ الخنثى: على وزن فعلى من الخنث وهو اللين والتكسروفي الشرع: من له آلة الرجل وآلة المرأة ولم تظهر علامة
 علم بها أنه ذكر أو أنثى.
^٩ لبن الخنثى المشكل لا يقتضي أنوثته على المذهب، بل يوقف أمره، فإن بانث أنوثته تعلق به الحكم، وإلا فلا.
^{١٠} الإيجار: صب اللبن في الحلق لحصول التغذية به كالارتضاع

وَلَا يَلْبَنُ مَنْ لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ لِأَنَّهَا لَا تَحْتَمِلُ الْوِلَادَةَ وَاللَّبَنُ الْمُحَرَّمُ فَرَعُهَا بِخِلَافٍ مَنْ بَلَغَتْهَا لَوْصُولُهَا لِسِنَّ الْحَيْضِ وَسَوَاءٌ فِيهَا الْبُكَرُ وَالْخَلِيَّةُ وَغَيْرُهُمَا^١.

(وَلَوْ حَلَبَتْ) لَبَنَهَا^٢ وَمَاتَتْ (فَأَوْجَرَ بَعْدَ مَوْتِهَا حَرَّمَ) بِالتَّشْدِيدِ (فِي الْأَصَحِّ)^٣ لِانْفِصَالِهِ مِنْهَا وَهُوَ حَلَالٌ مُحْتَرَمٌ^٤ وَالثَّانِي لَا يُحَرِّمُ لِبَعْدِ إثْبَاتِ الْأُمُومَةِ بَعْدَ الْمَوْتِ

لا يشترط بقاء اسمه لبنا:

(وَلَوْ جَبَنَ أَوْ نُزِعَ مِنْهُ زُبْدٌ) وَأُطْعِمَ الطِّفْلُ (حَرَّمَ) بِالتَّشْدِيدِ لِحُصُولِ التَّغْذِي بِهِ^٥ (وَلَوْ خُلِطَ^٦ بِمَائِهِ^٧ حَرَّمَ إِنْ غَلَبَ^٨) بِفَتْحِ الْغَيْنِ عَلَى الْمَائِعِ، (فَإِنْ غَلِبَ) بِضَمِّ الْغَيْنِ بِأَنْ زَالَتْ أَوْصَافُهُ الطَّعْمُ وَاللَّوْنُ وَالرَّيْحُ، (وَشَرِبَ الْكُلَّ قِيلَ أَوْ الْبَعْضَ حَرَّمَ فِي الْأَظْهَرِ^٩) لَوْصُولِ اللَّبَنِ إِلَى الْجَوْفِ وَالثَّانِي لَا يُحَرِّمُ لِأَنَّ الْمَغْلُوبَ الْمُسْتَهْلَكَ كَالْمَعْدُومِ وَالْأَصَحُّ أَنَّ شَرِبَ الْبَعْضِ لَا يُحَرِّمُ لِانْتِفَاءِ تَحَقُّقِ وُصُولِ اللَّبَنِ مِنْهُ إِلَى الْجَوْفِ. فَإِنْ تَحَقَّقَ كَأَنَّ بَقِيَ مِنَ الْمَخْلُوطِ أَقْلٌ مِنْ قَدْرِ اللَّبَنِ حَرَّمَ جَزْأً عَلَى الْأَظْهَرِ^{١٠}.

^١ سواء كانت مزوجة أم بكرًا أم بخلافهما. وقيل: لا يحرم لبن البكر؛ لأن ولد الرضاع تابع لولد النسب ولا ولد لها، وكذلك الثيب التي لا زوج لها ولا ولد ولا حمل

^٢ قوله "ولو حلبت لبنها" أي من محله المعبود، فإذا خرج من غيره فالذي يتجه أنه إن كان من صورة الثدي المعبود ومن محل يمكن فيه خروج اللبن منه أعطي حكمه، وإلا فلا.

^٣ الأصح من صبيغ الترجيح بين الأوجه للأصحاب، وحيث يكون الوجه الآخر قوي الدليل يصل إلى درجة الصحيح، إلا أن الذي قيل عنه أصح أقوى دليلاً.

^٤ قوله "وهو حلال محترم" ربما يفيد هذا أن لبن الميتة نجس ليس بحلال وليس كذلك ولكن معناه أنه لا حرمة له وإلا فهو حلال بعد موتها.

^٥ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ﷺ قال: (إنما الرضاعة من المجاعة) (متفق عليه) وهذا أبلغ في دفع المجاعة؛ لأنه تحصل به التغذية.

^٦ قوله "ولو خلط" أي اللبن المحلوب في خمس مرات كما هو معلوم ظاهر

^٧ تقييد المصنف ب (المانع) لا حاجة إليه؛ فإن الخلط بالجامد كالدقيق كذلك لاشتراكهما في التغذية

^٨ سواء كان المانع حلالاً أو حراماً؛ لأن المغلوب كالمعدوم، والمراد بغلبته: ظهور إحدى صفاته، إما اللون أو الطعم أو الرائحة. وقيل: بأن لا يخرج عن التغذية، وقطع الجمهور بالأول.

^٩ الأظهر: يستعمل هذا الاصطلاح للترجيح بين أقوال الشافعي، وللفظ الأظهر يدل على ظهور مقابله، ولا يأتي به النووي إلا حينما تكون الأقوال المخالفة قوية من حيث الدليل لكن الذي عبر عنه بالأظهر أقوى دليلاً منها وأظهر.

^{١٠} وهذا الخلاف فيما إذا لم نتحقق وصول اللبن، فإن تحققنا انتشاره في الخليط وحصول بعضه في المشروب أو كان الباقي من المخلوط أقل من قدر اللبن ثبت التحريم قطعاً، والأصح: أنه يشترط كون اللبن قدراً يمكن أن يسقى منه خمس دفعات لو انفرد عن الخليط.

(وَيُحَرِّمُ) بِالتَّشْدِيدِ (إِيْجَارٌ) ^١ وَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ فِي الْحَلْقِ لِيَصِلَ إِلَى الْجَوْفِ لِحُصُولِ التَّغْذِي بِذَلِكَ ^٢ (وَكَذَا إِسْعَاطٌ) وَهُوَ صَبُّ اللَّبَنِ فِي الْأَنْفِ ^٣ لِيَصِلَ إِلَى الدِّمَاغِ فَإِنَّهُ يَحْرُمُ (عَلَى الْمَذْهَبِ) لِأَنَّ الدِّمَاغَ جَوْفٌ لِلتَّغْذِي كَالْمَعْدَةِ ^٤. وَالطَّرِيقُ الثَّانِي فِيهِ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يُحَرِّمُ لانتفاء التَّغْذِي بِهِ (لَا حُقْنَةُ فِي الْأَظْهَرِ) لانتفاء التَّغْذِي بِهَا لَأنَّهَا لِإِسْهَالِ مَا انْعَقَدَ فِي الْأَمْعَاءِ وَالثَّانِي تُحَرِّمُ كَمَا يَحْصُلُ بِهَا الْفِطْرُ

الشرط الثاني أن يكون الرضيع حيا حياة مستقرة:

(وَشَرْطُهُ رَضِيعٌ حَيٌّ) ^٥ يَعْنِي أَنْ يَكُونَ الرَّضِيعُ حَيًّا فَلَا أَثَرَ لَوْصُولِ اللَّبَنِ إِلَى مَعْدَةِ الْمَيِّتِ لَخُرُوجِهِ عَنِ التَّغْذِي

الشرط الثالث: أن يكون الرضيع دون الحولين:

(لَمْ يَبْلُغْ سَنَتَيْنِ) فَإِنْ بَلَغَهُمَا لَمْ يُحَرِّمِ ارْتِضَاعُهُ ^٦ لِحَدِيثِ "الْإِرْضَاعُ إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ" ^٧ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالدَّارِقُطْنِيُّ، وَتَعْتَبِرُ السَّنَتَانِ بِالْأَهْلَةِ فَإِنْ انْكَسَرَ الشَّهْرُ الْأَوَّلُ كَمَلَ بِالْعَدَدِ مِنَ الشَّهْرِ الْخَامِسِ وَالْعِشْرِينَ وَابْتَدَأُوهُمَا مِنْ وَقْتِ انْفِصَالِ الْوَلَدِ بِتَمَامِهِ.

الشرط الرابع: أن ترضعه خمس رضعات متفرقات:

^١ قضية إطلاقه التحريم بمجاوزة اللبن الحلق وإن لم يصل المعدة كما يفطر بمثله الصائم، وليس مرادا فقد اعتبر الرافعي في المحرر الوصول إلى المعدة، وجري عليه النووي في روضة الطالبين، فلو تقاياه قبل وصول اللبن

إلى المعدة لم يحرم

^٢ قوله "لحصول التغذية" أي بحسب الشأن، والغالب

^٣ قوله "في الأنف" خرج به الأذن والعين

^٤ المذهب: لفظ المذهب يستعمل للترويج بين الطرق في حكاية أقوال الإمام، أو وجوه الأصحاب

^٥ المعدة والدماغ هما المراد بالجوف وأنه يحصل التغذية بالواصل إليهما

^٦ الحقنة: ما يدخل في الدبر أو القبل من دواء، ثم أطلقت على ما يحتقن به المريض من الأدوية.

^٧ قوله "رضيع حي" فلا أثر لوصله إلى جوف الميت بالاتفاق لخروجه عن التغذية ونبات اللحم

^٨ الرضاع في الحولين يتعلق به التحريم والحرمة، سواء كان الرضيع يستغني بالطعام والشراب عن اللبن أو لا يستغني

لقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةُ} البقرة ٢٣٣ فقد جعل

تمام الرضاعة في الحولين فأفهم بأن الحكم بعد الحولين بخلافه ولم يفرق بين أن يكون الولد مستغنيا

عنه، أو غير مستغن عنه، وللخير المذكور

^٩ روي مرفوعا عن ابن عباس والصحيح أنه موقوف عليه.

(وَحَمْسُ رَضَعَاتٍ^١) رَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عَائِشَةَ لَمَّا أَنْزَلَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ فَسِخَنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ^٢. (وَضَبْطُهُنَّ بِالْعُرْفِ^٣ فَلَوْ قَطَعَ إِغْرَاضًا تَعَدَّدَ أَوْ لِلْهُوَ وَعَادَ فِي الْحَالِ أَوْ تَحَوَّلَ مِنْ ثَدْيٍ إِلَى ثَدْيٍ فَلَا تَعَدَّدُ

(وَلَوْ حَلَبَ مِنْهَا دَفْعَةً وَأَوْجَرَهُ خَمْسًا أَوْ عَكْسَهُ)^٤ أَيَّ حَلَبٍ مِنْهَا فِي خَمْسِ مَرَّاتٍ وَأَوْجَرَهُ فِي مَرَّةٍ (فَرَضْعَةً) نَظَرًا إِلَى انفِصَالِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى وَإِجَارِهِ فِي الثَّانِيَةِ (وَفِي قَوْلِ خَمْسٍ) نَظَرًا إِلَى إِجَارِهِ فِي الْأُولَى وَإِنْفِصَالِهِ فِي الثَّانِيَةِ

الشك في عدد الرضعات ووقته:

(وَلَوْ شَكَّ هَلْ رَضَعَ خَمْسًا أَمْ أَقَلَّ أَوْ هَلْ رَضَعَ فِي الْحَوْلَيْنِ أَمْ بَعْدُ^٥ فَلَا تَحْرِيمٌ) لِلشَّكِّ فِي سَبَبِهِ^٦ (وَفِي الثَّانِيَةِ^٧ قَوْلٌ^٨ أَوْ وَجْهٌ^٩ بِالتَّحْرِيمِ) نَظَرًا إِلَى أَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ الْمُدَّةِ^{١٠}.

ما يترتب على الرضاع:

(وَتَصِيرُ الْمُرْضِعَةُ أُمًّا^١ وَالَّذِي مِنْهُ اللَّبَنُ أَبَاهُ^٢ وَتَسْرِي الْحُرْمَةُ إِلَى أَوْلَادِهِ^٣) فَهُمْ إِخْوَةُ الرَّضِيعِ وَأَخَوَاتُهُ

^١ إذا ثبت أن التحريم يتعلق بخمس رضعات فمن شرط الخمس أن تكون متفرقات. فإذا التقم الصبي الثدي، وارتمع منه، فأقل أو أكثر، ثم قطع الرضاع باختياره من غير عارض حسب ذلك رضعة.

^٢ صحيح مسلم - كتاب الرضاع - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة.

^٣ ضبطهن بالعرف لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة فيرجع فيه إليه.

^٤ إذا حلب من المرأة لبن دفعة وأوجره بأن وصل إلى جوف الرضيع علي خمس مرات، أو حلب منها خمسا وأوجر الرضيع دفعة، فرضعة واحدة في صورتين اعتبارا في الأولى بحالة الانفصال من الثدي، وفي الثانية بحالة وصوله إلى جوفه دفعة واحدة وفي قول خمس رضعات في صورتين اعتبارا في الأولى بحالة وصوله إلى جوفه، واعتبارا في الثانية إلى حالة الانفصال من الثدي. وإذا حلب منها خمس دفعات وأوجره في خمس دفعات من غير خلط فهو خمس قطعاً.

^٥ في الحولين أم بعد الحولين أو شك في أنه لبن امرأة أو بهيمة، وأنه حلب في حياتها أم بعد موتها.

^٦ لا تحريم لأن الأصل عدم ما ذكر.

^٧ المسألة الثانية وهي الشك هل رضع في الحولين أم بعدها.

^٨ قول: من اصطلاحات النووي الدالة على القول المرجوح، وأن الراجح خلافها، فهي بهذه الصياغة تدل على ضعفها.

^٩ الأوجه هي آراء أصحاب الشافعي المخرجة على أصوله وقواعده وقد تكون اجتهادا لهم أحيانا غير مبني على أصوله وقواعده وهذه لا تكون من المذهب وإنما تنسب لصاحبها.

^{١٠} الأصل بقاء الحولين.

تعددت المرضعة وصاحب اللبن واحد:

(وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ خَمْسٌ مُسْتَوْلَدَاتٍ^١ أَوْ أَرْبَعٌ نِسْوَةٌ وَأُمٌّ وَلَدٌ^٢ فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ صَارَ ابْنُهُ فِي الْأَصَحِّ^٣) لِأَنَّ لَبَنَ الْجَمِيعِ مِنْهُ. (فَيَحْرُمُنَ عَلَى الطِّفْلِ لِأَنَّهُنَّ مَوْطُوعَاتُ أَبِيهِ)، وَلَا أُمُومَةٌ لَهُنَّ مِنْ جِهَةِ الرِّضَاعِ^٤، وَالثَّانِي لَا يَصِيرُ ابْنُهُ لِأَنَّ الْأُبُوَّةَ تَابِعَةٌ لِلْأُمُومَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّ انفِصَالَ اللَّبَنِ عَنْهَا مُشَاهِدٌ وَلَا أُمُومَةٌ فَلَا أُبُوَّةٌ فَلَا يَحْرُمُنَ عَلَيْهِ

(وَلَوْ كَانَ بَدَلُ الْمُسْتَوْلَدَاتِ بَنَاتٍ أَوْ أَخَوَاتٍ) فَرَضَعَ طِفْلٌ مِنْ كُلِّ رَضْعَةٍ، (فَلَا حُرْمَةً) بَيْنَ الرَّجُلِ وَالطِّفْلِ، (فِي الْأَصَحِّ)^٥ لِأَنَّ الْجَدَّ لِلْأُمِّ أَوْ الْخَوُولَةَ إِنَّمَا تَثْبُتُ بِتَوَسُّطِ الْأُمُومَةِ وَلَا أُمُومَةٌ هُنَا، وَالثَّانِي تَثْبُتُ الْحُرْمَةُ تَنْزِيلًا لِلْبَنَاتِ أَوْ الْأَخَوَاتِ مَنْزِلَةَ الْوَاحِدَةِ، كَمَا فِي الْمُسْتَوْلَدَاتِ.

وَعَلَى هَذَا قَالَ الْبَغَوِيُّ^٦ تَحْرُمُ الْمَرْضَعَاتُ لِكَوْنِهِنَّ أَخَوَاتِ الطِّفْلِ أَوْ عَمَّاتِهِ، وَاعْتَزَّضَهُ الرَّافِعِيُّ^٧ وَالْمُصَنِّفُ بِأَنَّ ذَلِكَ إِنَّمَا يَصِحُّ لَوْ كَانَ الرَّجُلُ أَبًا وَلَيْسَ بِأَبٍ وَهُوَ إِمَّا جَدٌّ لِأُمِّ، أَوْ

^١ اعلم أن الحرمة تسري من المرضعة إلى أصولها وفروعها وحواشيها، ومن الرضيع إلى فروعه فقط فإذا تحققت شروط الرضاع فإن المرضعة تصير أما للرضيع لقوله تعالى {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرِّضَاعَةِ} النساء ٢٣، فنص على هاتين لا لاختصاص الحكم بهما، بل للتنبيه بهما على ما في معناهما.

^٢ عن عائشة: أن أفلح أبا أبي القعيس استأذن عليها بعدما أنزل الحجاب فقالت: والله لا أذن له حتى أستاذن رسول الله ﷺ. فإن أبا أبي القعيس ليس هو أرضعني وإنما أرضعتني امرأته، فأخبرت النبي ﷺ بذلك فقال: (انذني فإنه عمك تربت يمينك) قال عروة: فبذلك كانت عائشة تقول: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) متفق عليه.

^٣ أولاد الرضيع، احتز المصنف بقوله: " أولاده " عن أبائه وإخوته، فلا تسري الحرمة إليهم، فلأبيه وأخيه نكاح المرضعة وبناتها ولزوج المرضعة أن يتزوج بأم الطفل وأخته.

^٤ الاستيلاء جعل الأمة أم ولد.

^٥ أم الولد: هي الأمة التي ولدت من سيدها في ملكه، فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة

^٦ لأنه ارتضع من لبنه خمس رضعات متفرقات، فهو كما لو ارتضع ذلك من واحدة منهن.

^٧ لأن كل واحدة منهن لم ترضعه خمس رضعات فلم يرتضع منهن رضاعاً تاماً.

^٨ لأنه لو ثبت التحريم لكان الرجل جدًّا لأم في صورة البنات، وخالا في إرضاع الأخوات، والجدودة والخوولة لا تثبتان إلا بتوسط الأمومة.

^٩ البغوي: العلامة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي المتوفي ٥١٦ هـ.

خَالٌ، فَيَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ يَحْرُمَنْ لِكَوْنِهِنَّ كَالْخَالَاتِ لِأَنَّ بِنْتَ الْجَدِّ لِلْأُمِّ إِذَا لَمْ تَكُنْ أُمًّا تَكُونُ خَالَةً. وَكَذَا أُخْتُ الْخَالِ (وَأَبَاءُ الْمُرْضِعَةِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَجْدَادٌ لِلرَّضِيعِ)^٢ فَإِنْ كَانَ أُنْثَى حُرِّمَ عَلَيْهِمْ نِكَاحُهَا، (وَأُمَّهَاتُهَا) مِنْ نَسَبٍ وَرَضَاعٍ (جَدَّاتُهَا) فَإِنْ كَانَ ذَكَرًا حُرِّمَ عَلَيْهِ نِكَاحُهَا، (وَأَوْلَادُهَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ إِخْوَتُهَا^٣ وَإِخْوَتُهَا وَأَخَوَاتُهَا) مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (أَخْوَالُهَا وَخَالَاتُهَا) فَيَحْرُمُ التَّنَاحُجُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَكَذَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَوْلَادِ الْأَوْلَادِ بِخِلَافِ أَوْلَادِ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ، لِأَنَّهُمْ أَوْلَادُ أَخْوَالِهِ وَخَالَاتِهِ

(وَأَبُو ذِي اللَّبَنِ) أَيُّ أَبُو الْمُنْسُوبِ إِلَيْهِ اللَّبَنُ (جَدُّهُ وَأَخُوهُ عَمُّهُ وَكَذَا الْبَاقِي)^٤ فَأُمُّهُ جَدَّتُهُ. وَوَلَدُهُ أَخُوهُ أَوْ أُخْتُهُ وَأَخُوهُ وَأُخْتُهُ عَمُّهُ أَوْ عَمَّتُهُ، وَأَوْلَادُ الرَّضِيعِ^٥ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَحْفَادُ الْمُرْضِعَةِ وَالْفُحْلِ

(وَاللَّبَنُ لِمَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدًا^٦ نَزَلَ بِهِ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطِئَ شُبْهَةً^٧ لَا زِنَى^٨)، لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لِلْبَنِ الزِّنَى فَلَا يَحْرُمُ عَلَى الزَّانِي أَنْ يَنْكِحَ الصَّغِيرَةَ الْمُرْتَضِعَةَ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ لَكِنْ يُكْرَهُ.

(وَلَوْ نَفَاهُ) أَيُّ نَقَى الرَّوْجَ الْوَلَدَ، (يَلْعَانُ^٩ انْتَفَى اللَّبَنُ النَّازِلُ بِهِ) حَتَّى لَوْ أُرْتَضِعَتْ بِهِ صَغِيرَةٌ حَلَّتْ لِلنَّافِي فَلَوْ أُسْتُلِحِقَ الْوَلَدُ لِحَقِّ الرَّضِيعِ أَيْضًا.

^١ الرافعي: شيخ الشافعية عالم العجم والعرب إمام الدين أبو القاسم عبد الكريم ابن العلامة أبي الفضل محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين الرافعي القزويني المتوفي ٦٢٣ هـ.

^٢ فإن الحرمة تسري إلى أصولها

^٣ فإن الحرمة تسري إلى فروعها

^٤ قوله "وكذا الباقي" من أقارب صاحب اللبن على هذا القياس فأمه جدته وأولاده إخوته وأخواته وإخوته أعمامه وعماته، فإن الحرمة تسري إلى أصول صاحب اللبن وفروعه وحواشيه.

^٥ قوله "وأولاد الرضيع" خرج به أصوله وحواشيه فلا حرمة بينهم وبين المرصعة وذو اللبن وفارق أصولهما وحواشيهما بأن اللبن جزء منهما وهما وحواشيهما جزء من أصولهما، فسرت الحرمة إلى الجميع وليس للرضيع جزء إلا فروعها فسرت الحرمة إليهم فقط.

^٦ قوله "نسب إليه ولد" أي ألحق به ولو بمجرد الإمكان من حين العقد

^٧ الشبهة: اسم من الاشتباه وهو الالتباس، والشبهة في الشرع: ما لم يتيقن كونه حراماً أو حلالاً، أو ما جهل تحليله على الحقيقة وتحريمه على الحقيقة، ومن صور الوطء بشبهة كمن وطئ نائمة في فراشه ظلماً زوجته.

^٨ قوله "لا زنا" لعدم احترامه.

^٩ اللعان: لغة مشتق من اللعن، وهو الإبعاد والطرده، وفي الشرع: عبارة عن كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطم فراشه وألحق العار به.

(وَلَوْ وُطِئَتْ مَنكُوحَةً) أَيْ وَطِئَهَا وَاحِدٌ، (بِشُبْهَةٍ أَوْ وَطِئَ اثْنَانِ) امْرَأَةً (بِشُبْهَةٍ قَوْلَدَتْ) بَعْدَ ذَلِكَ الْوَطْءِ وَلَدًا (فَاللَّبْنُ) النَّازِلُ بِهِ (لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ) فِيمَا ذَكَرَ (بِقَائِفٍ^١ أَوْ غَيْرِهِ)^٢ بِأَنْ انْحَصَرَ الْإِمْكَانُ فِيهِ فِي الصُّورَةِ الْأُولَى^٣، وَكَذَا الثَّانِيَةُ^٤ وَالْقَائِفُ حَيْثُ لَا يَنْحَصِرُ الْإِمْكَانُ فِي وَاحِدٍ، فَالْمُرْتَضِعُ مِنْ ذَلِكَ اللَّبَنِ وَلَدٌ رَضَاعٍ لِمَنْ لَحِقَهُ الْوَلَدُ.

(وَلَا تَنْقَطِعُ نِسْبَةُ اللَّبَنِ عَنْ زَوْجٍ مَاتَ أَوْ طَلَّقَ) وَلَهُ لَبْنٌ، (وَإِنْ طَالَتْ الْمُدَّةُ) كَعَشْرِ سِنِينَ بِأَنْ ارْتَضَعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مُتَرْتِبُونَ (أَوْ انْقَطَعَ) اللَّبْنُ (وَعَادَ) لِأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُحَالُ عَلَيْهِ إِذْ الْكَلَامُ فِي الْخَلِيَّةِ^٥، وَقِيلَ إِنْ عَادَ بَعْدَ أَرْبَعِ سِنِينَ لَا يُسَبِّبُ إِلَيْهِ كَمَا لَوْ أَتَتْ بِوَلَدٍ بَعْدَهَا، (فَإِنْ نَكَحَتْ آخَرَ) وَوَلَدَتْ مِنْهُ فَاللَّبْنُ بَعْدَ الْوِلَادَةِ لَهُ، وَقَبْلَهَا لِلْأَوَّلِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ وَقْتُ ظُهُورِ لَبَنِ حَمَلِ الثَّانِي، وَيُقَالُ إِنْ أَقَلَّ مُدَّةٌ يَحْدُثُ فِيهَا اللَّبْنُ لِلْحَمَلِ أَرْبَعُونَ يَوْمًا، (وَكَذَا إِنْ دَخَلَ) وَقْتُهِ يَكُونُ اللَّبْنُ لِلْأَوَّلِ دُونَ الثَّانِي لِأَنَّ اللَّبْنَ غِذَاءٌ لِلْوَلَدِ لَا لِلْحَمَلِ فَيَتَّبِعُ الْمُتَفَصِّلَ وَسَوَاءٌ زَادَ اللَّبْنُ عَلَى مَا كَانَ أَمْ لَا، وَسَوَاءٌ انْقَطَعَ وَعَادَ لِلْحَمَلِ أَمْ لَا، (وَفِي قَوْلِ الثَّانِي) فِيمَا إِذَا انْقَطَعَ ثُمَّ عَادَ لِلْحَمَلِ، (وَفِي قَوْلِ لَهَا) وَفِي قَوْلِ إِنْ زَادَ فَلَهُمَا وَإِلَّا فَلِلْأَوَّلِ^٦.

^١ القائف: من يعرف النسب بفراسته ونظره إلى أعضاء المولود.

^٢ أو لمن لحقه الولد بسبب غيره بأن انحصر الإمكان في واحد منهما، أو لم يكن قائف، أو ألحقه بهما أو نفاه عنهما، أو أشكل عليه الأمر وانتسب الولد لأحدهما بعد بلوغه أو بعد إفاقة من جنون ونحوه، فالرضيع من ذلك اللبن ولد رضاع لمن لحقه ذلك الولد: لأن اللبن تابع للولد.

^٣ الصورة الأولى: وطئت امرأة منكوحه بشبهة

^٤ الصورة الثانية: وطئ اثنان امرأة بشبهة

^٥ الخلية: فعيلة بمعنى فاعلة أي خالية من الزوج وهو خال منها

^٦ بيان المسألة: لا تنقطع نسبة اللبن عن صاحبه كزوج مات أو طلق وله اللبن وإن طالبت المدة كعشر سنين وله لبن ارتضع منه جماعة مرتبون، وكذلك ينسب اللبن إليه إذا انقطع ثم عاد إذ لم يحدث ما يحال اللبن عليه، إذ الكلام في الخلية فاستمرت نسبته إليه.

فإن نكحت المرأة التي بها اللبن بعد موت أو طلاق من زوج آخر وولدت منه فاللبن بعد الولادة للآخر (الثاني) لأن اللبن يتبع الولد والولد للثاني فكذلك اللبن، واللبن وقبل الولادة يكون للأول (من مات أو طلق) إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني لأن الأصل بقاء الأول ولم يحدث ما يغيره، وقيل: إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحمل أربعون يوما وقيل: أربعة أشهر والمنصوص: أنه يرجع فيه إلى القوالب. وكذلك يكون اللبن للأول إن دخل وقت ظهور لبن حمل الثاني لأن اللبن غذاء للولد لا للحمل فيتبع المنفصل، وفي قول اللبن للثاني) لأن الحمل ناسخ فقطع حكم ما قبله كالولادة، وفي قول لهما معا لأن احتمال الأمرين يوجب تساويهما.

حكم الرضاع الطارئ على النكاح:

(فَصْلُ: تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَأَرْضَعْتُهَا أُمُّهُ أَوْ أُخْتُهِ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (أَوْ زَوْجَةً أُخْرَى) لَهُ (انْفُسَخَ نِكَاحُهُ) مِنَ الصَّغِيرَةِ^١ لِأَنَّهَا صَارَتْ أُخْتَهُ أَوْ بِنْتَ أُخْتِهِ أَوْ بِنْتَ زَوْجَتِهِ مِنَ الْكَبِيرَةِ، لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ، (وَلِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ مَهْرِهَا)^٢ الْمُسَمَّى إِنْ كَانَ صَحِيحًا وَإِلَّا فَنِصْفُ مَهْرٍ مِثْلِهَا.

(وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرٍ مِثْلٍ وَفِي قَوْلٍ كُلُّهُ^٣) لِأَنَّهَا أَتَلَفَتْ عَلَيْهِ الْبُضْعَ وَهُوَ مُتَقَوِّمٌ بِمَهْرِ الْمِثْلِ وَالْأَوَّلُ^٤ أُعْتَبِرَ مَا يَجِبُ لَهُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ

(وَلَوْ رَضَعَتْ^٥ مِنْ نَائِمَةٍ فَلَا غَرْمَ) عَلَيْهَا^٦ لِأَنَّهَا لَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا (وَلَا مَهْرٌ لِلْمُرْتَضِعَةِ) لِأَنَّ الْإِنْفِسَاخَ حَصَلَ بِفِعْلِهَا وَذَلِكَ يَسْقُطُ الْمَهْرُ قَبْلَ الدُّخُولِ.

(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ) زَوْجَتَانِ (كَبِيرَةٌ وَصَغِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْ أُمُّ الْكَبِيرَةِ^٧ الصَّغِيرَةَ انْفُسَخَتْ الصَّغِيرَةُ وَكَذَا الْكَبِيرَةُ فِي الْأَظْهَرِ) لِأَنَّهُمَا صَارَتَا أُخْتَيْنِ وَلَا سَبِيلَ إِلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أُخْتَيْنِ وَالثَّانِي يَخْتَصُّ الْإِنْفِسَاخَ بِالصَّغِيرَةِ لِأَنَّ الْجَمْعَ حَصَلَ بِإِرْضَاعِهَا، (وَلَهُ) عَلَى الْأَظْهَرِ، (نِكَاحٌ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا) لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ عَلَيْهِ جَمْعُهُمَا^٨.

^١ انفسخ نكاحه من الصغيرة وحرمت عليه أبدا لأن ما يوجب الحرمة المؤبدة كما يمنع ابتداء النكاح يمنع استدامته، وإذا ثبت التحريم انقطع النكاح.

^٢ للصغيرة علي الزوج نصف مهرها لأنه فراق قبل الدخول، وأشار بإضافة المهر إليها إلى أنه نصف المسمى الصحيح، أو نصف مهر المثل إن كان فاسداً.

^٣ أي المهر كله.

^٤ للزوج على المرضعة نصف مهر مثل لأنها فوتت عليه ملك النكاح سواء أقصدت بإرضاعها فسخ النكاح أم لا، أما استحقاقه النصف فلأنه الذي يغرمه فاعتبر ما يجب له بما يجب عليه.

^٥ رضع الصغيرة خمس رضعات من نائمة.

^٦ أي المرضعة.

^٧ احترز بأم الكبيرة عما لو أرضعت الكبيرة نفسها الصغيرة والكبيرة موطوءة فلا يرجع الزوج عليها بمهر مثلها لنلا يخلو نكاحها عن مهر فتصير كالموهوبة، وذلك من خصائص النبوة.

^٨ إذا كان للرجل زوجتان كبيرة وصغيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاح الصغيرة لأنها صارت أختا للكبيرة، ولا سبيل إلى الجمع بين الأختين، وكذا ينفسخ نكاح الكبيرة في الأظهر لأنها صارت أختا للصغيرة ولا سبيل

(وَحُكْمُ مَهْرِ الصَّغِيرَةِ) عَلَى الرَّوْجِ (وَتَغْرِيمُهُ الْمُرْضِعَةَ مَا سَبَقَ) ^١ فَعَلَيْهِ لِلصَّغِيرَةِ نِصْفُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ، وَفِي قَوْلٍ كُلُّهُ.

(وَكَذَا الْكَبِيرَةُ إِنْ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً) ^٢ لَهَا عَلَيْهِ نِصْفُ الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ وَلَهُ عَلَى أُمِّهَا الْمُرْضِعَةِ نِصْفُ مَهْرِ الْمِثْلِ وَفِي قَوْلٍ كُلُّهُ. (فَإِنْ كَانَتْ مَوْطُوءَةً فَلَهُ عَلَى الْمُرْضِعَةِ مَهْرُ مِثْلِ فِي الْأَظْهَرِ) كَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ لِبِنْتِهَا الْمُسَمَّى الصَّحِيحِ بِكَمَالِهِ. وَالثَّانِي لَا شَيْءَ عَلَيْهَا لِأَنَّ النُّبُضَ بَعْدَ الدُّخُولِ لَا يَتَقَوَّمُ لِلرَّوْجِ.

(وَلَوْ أَرْضَعَتْ بِنْتُ الْكَبِيرَةِ الصَّغِيرَةَ حُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا)، لِأَنَّهَا صَارَتْ أُمَّ زَوْجَتِهِ (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ) حُرِّمَتْ أَبَدًا (إِنْ كَانَتْ الْكَبِيرَةُ مَوْطُوءَةً) لِأَنَّهَا صَارَتْ بِنْتُ زَوْجَتِهِ الْمَوْطُوءَةِ بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً فَلَا تَحْرُمُ هِيَ ^٣، (وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ فَطَلَّقَهَا فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَةً صَارَتْ أُمَّ امْرَأَتِهِ) فَتَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا ^٤.

(وَلَوْ نَكَحَتْ مُطَلَّقَتَهُ صَغِيرًا وَأَرْضَعَتْهُ بِلَبْنِهِ حُرِّمَتْ عَلَى الْمُطَلَّقِ وَالصَّغِيرِ أَبَدًا) لِأَنَّهَا صَارَتْ زَوْجَةً ابْنِ الْمُطَلَّقِ وَأُمَّ الصَّغِيرِ وَزَوْجَةً أَبِيهِ ^٥.

(وَلَوْ زَوَّجَ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصَّغِيرَ) بِنَاءً عَلَى الْقَوْلِ الْمَرْجُوحِ أَنَّهُ يُزَوَّجُهُ، (فَأَرْضَعَتْهُ لَبْنُ السَّيِّدِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ) لِأَنَّهَا أُمُّهُ وَمَوْطُوءَةٌ أَبِيهِ، (وَعَلَى السَّيِّدِ) لِأَنَّهَا زَوْجَةُ ابْنِهِ ^٦

إلى الجمع بين الأختين والثاني يختص بالانفساخ بالصغيرة لأن الجمع حصل بإرضاعها، وعلى الأظهر له نكاح من شاء منهما على الانفراد، لأنهما أختان والمحرّم عليه جمعهما.

^١ علي الزوج للصغيرة نصف المسمى الصحيح أو نصف مهر مثل، وله على أمها المرضعة نصف مهر المثل، وقيل: كله.

^٢ حكمها في غرم الزوج مهرها وتغريمه المرضعة ما سبق في الصغيرة لاشتراكهما في عدم الوطء.

^٣ إذا أرضعت بنت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة حرمت الكبيرة أبدا لأنها جدة امرأته، وكذا تحرم الصغيرة أبدا إن كانت الكبيرة موطوءة لأنها ربيبته أي بنت زوجته، فإن لم تكن الكبيرة موطوءة لم تحرم الصغيرة لأن الربية لا تحرم إلا بالدخول.

^٤ إذا كان للرجل زوجة صغيرة فطلقها فأرضعها امرأة صارت المرأة أم امرأته فتحرم عليه أبدا.

^٥ إذا طلق الرجل زوجته الكبيرة فتزوجت مطلقته صغيرا وأرضعته بلبن مطلقها حرمت على المطلق والصغير أبدا أما المطلق فلأنها صارت زوجة ابنه وأما الصغير فلأنها صارت أمه أو زوجة أبيه.

^٦ إذا زوج السيد أم ولده عبده الصغير فأرضعته لبن السيد حرمت على العبد أبدا لأنها أمه وموطوءة أبيه، وحرمت على السيد كذلك لأنها زوجة ابنه.

(وَلَوْ أَرْضَعَتْ مَوْطُوءَتُهُ الْأُمَّةُ صَغِيرَةً تَحْتَهُ بِلَبْنِهِ أَوْ لَبَنٍ غَيْرِهِ، بِأَنْ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ (حُرِّمَتْهَا عَلَيْهِ) أَبَدًا لِصَيْرُورَةِ الْأُمَّةِ أُمَ زَوْجَتِهِ وَالصَّغِيرَةِ بِنْتَهُ أَوْ بِنْتِ مَوْطُوءَتِهِ^١

(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ فَأَرْضَعَتْهَا أَنْفَسَخَتْ) لِصَيْرُورَةِ الصَّغِيرَةِ بِنْتًا لِلْكَبِيرَةِ وَاجْتِمَاعُ الْأُمِّ وَالْبِنْتِ فِي النِّكَاحِ مُمْتَنِعٌ (وَحُرِّمَتْ الْكَبِيرَةُ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُ زَوْجَتِهِ، (وَكَذَا الصَّغِيرَةُ إِنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِلَبْنِهِ) لِأَنَّهَا بِنْتُهُ (وَالْأَيُّ بِأَنْ كَانَ الْإِرْضَاعُ بِلَبَنٍ غَيْرِهِ، (فَرِيبَةً) لَهُ فَإِنْ دَخَلَ بِالْكَبِيرَةِ حُرِّمَتْ عَلَيْهِ تِلْكَ وَالْأَيُّ فَلَا^٢.

(وَلَوْ كَانَ تَحْتَهُ كَبِيرَةٌ وَثَلَاثُ صَغَائِرٍ فَأَرْضَعَتْهُنَّ حُرِّمَتْ أَبَدًا) لِأَنَّهَا أُمُ زَوْجَاتِهِ، (وَكَذَا الصَّغَائِرُ إِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ بِلَبْنِهِ أَوْ لَبَنٍ غَيْرِهِ وَهِيَ مَوْطُوءَةٌ) لِأَنَّهُنَّ بَنَاتُهُ أَوْ بَنَاتُ مَدْخُولَتِهِ وَسَوَاءٌ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا أَمْ مُرْتَبًا (وَالْأَيُّ لَمْ تَكُنْ مَوْطُوءَةً^٣.

(فَإِنْ أَرْضَعَتْهُنَّ مَعًا بِإِيجَارِهِنَّ) الرِّضْعَةَ، (الْخَامِسَةَ أَنْفَسَخْنَ) لِصَيْرُورَتِهِنَّ أَخَوَاتٍ وَاجْتِمَاعِهِنَّ مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ (وَلَا يَحْرُمْنَ مُؤَبَّدًا) لِانْتِفَاءِ الدُّخُولِ بِأَمْنِهِنَّ فَلَهُ تَجْدِيدُ نِكَاحِ كُلِّ مِنْهُنَّ مِنْ غَيْرِ جَمْعٍ بَيْنَ بَعْضِهِنَّ^٤.

^١ إذا أرضعت موطوءته الأمة زوجة صغيرة تحت السيد (لبنه أو لبن غيره بأن تزوجت غيره أو وطئها بشبهة حرمت الموطوءة والصغيرة علي السيد أبدا لصيرورة الأمة أم زوجته والصغيرة بنته إن رضعت لبنه، أو بنت موطوءته إن رضعت لبن غيره.

^٢ إذا كان للرجل زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحهما لصيرورة الصغيرة بنتا للكبيرة وامتنع الجمع بينهما، وحرمت الكبيرة عليه أبدا لأنها أم زوجته و، كذلك تحرم الصغيرة أبدا إن كان الإرضاع بلبنه لأنها صارت بنته، وأن كان الإرضاع بلبن غيره فريبة له تحرم عليه أبدا إن دخل بالكبيرة ولا تحرم إن لم يدخل بالكبيرة.

^٣ إذا كان للرجل أربع نسوة إحداهن كبيرة وثلاث صغيرات فأرضعتن الكبيرة معا أو مرتبا بلبنه أو لبن غيره حرمت الكبيرة أبدا لأنها صارت أم زوجاته، وكذا تحرم الصغائر إن أرضعتن بلبنه لأنهن صرن بناته، أو لبن غيره والكبيرة موطوءة له لأن الصغائر صرن بنات زوجته المدخول بها، وإن لم يكن اللبن له ولم تكن الكبيرة موطوءة له فلا تحرم الصغار.

^٤ (تابع الصورة السابقة) إذا كان للرجل أربع نسوة إحداهن كبيرة وثلاث صغيرات فأرضعتن الكبيرة معا بإيجارهن الرضعة الخامسة انفسخن لصيرورتهن أخوات واجتماعهن مع الأم في النكاح، ولا يحرمن الصغار مؤبدا لانتهاء الدخول بأمنهن فله تجديد نكاح من شاء منهن بلا جمع في نكاح

(أَوْ) أَرْضَعْتُهُنَّ (مُرْتَبًا لَمْ يَحْرُمَنْ) مُؤَبَّدًا لِمَا ذَكَرَ (وَتَنْفَسُخُ الْأُولَى) بِإِرْضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ الْأُمِّ فِي النِّكَاحِ (وَالثَّالِثَةُ) بِإِرْضَاعِهَا لِاجْتِمَاعِهَا مَعَ أُخْتِهَا الثَّانِيَةِ فِي النِّكَاحِ (وَتَنْفَسُخُ الثَّانِيَةُ) بِإِرْضَاعِ الثَّالِثَةِ لِمَا ذَكَرَ مِنْ اجْتِمَاعِهِمَا فِي النِّكَاحِ (وَفِي قَوْلٍ لَا يَنْفَسُخُ) لِأَنَّ اجْتِمَاعَ الْأُخْتَيْنِ إِنَّمَا حَصَلَ بِالثَّالِثَةِ، فَيَخْتَصُّ الْإِنْفَسَاخُ بِهَا كَمَا لَوْ نَكَحَ امْرَأَةً عَلَى أُخْتِهَا^١.
(وَيَجْرِي الْقَوْلَانِ فِيمَنْ تَحْتَهُ صَغِيرَتَانِ أَرْضَعْتُهُمَا أَجْنَبِيَّةً مُرْتَبًا أَتَنْفَسَخَانِ أَمْ الثَّانِيَةُ) فَقَطُّ الْأَظْهَرُ انْفَسَاخُهُمَا لِمَا ذَكَرَ وَلَوْ أَرْضَعْتُهُمَا مَعًا بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ انْفَسَخَ نِكَاحُهُمَا جَزْمًا لِمَا تَقَدَّمَ. وَالْمُرْضِعَةُ تَحْرُمُ عَلَيْهِ أَبَدًا لِأَنَّهَا أُمُّ زَوْجَتَيْهِ^٢.

الإقرار بالرضاع والاختلاف فيه:

فَصَلِّ (قَالَ هُنْدُ بِنْتِي أَوْ أُخْتِي بِرِضَاعٍ أَوْ قَالَتْ هُوَ أَخِي) أَوْ ابْنِي بِرِضَاعٍ (حُرِّمَ تَنَاقُحُهُمَا) مُوَآخَذَةً لِكُلِّ مِنْهُمَا بِإِقْرَارٍ بِشَرْطِ الْإِمْكَانِ فَلَوْ قَالَ فَلَانَهُ بِنْتِي وَهِيَ أَكْبَرُ سِنًا مِنْهُ فَلَعَوُ^٤
(وَلَوْ قَالَ: زَوْجَانِ بَيْنَنَا رِضَاعٌ مُحَرَّمٌ^٥ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا) عَمَلًا بِقَوْلِهِمَا (وَسَقَطَ الْمُسَمَى وَوَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إِنْ وَطِئَ) وَإِنْ لَمْ يَطَأْ فَلَا يَجِبُ شَيْءٌ^٦

^١ (تابع الصورة السابقة) إذا كان للرجل أربع نسوة إحداهن كبيرة وثلاث صغيرات فأرضعتن الكبيرة مرتبًا لم يحرم مؤبداً، وينفسخ نكاح الأولى بإرضاعها مع الكبيرة لاجتماع الأم وبنتها في النكاح، ولا ينفسخ نكاح الثانية بمجرد إرضاعها إذ لا موجب له، وينفسخ نكاح الثالثة بإرضاعها لصيرورتها أختاً للثانية الباقية في نكاحه، وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة لأنهما صارتا أختين معا فأشبه ما لو أرضعتها معا وفي قول لا ينفسخ نكاح الثانية بل يختص الانفساخ بالثالثة لأن الجمع إنما حصل بها كما لو نكح امرأة على أختها.
^٢ يجري القولان فيمن تحته زوجتان صغيرتان أرضعتها أجنبية مرتباً أينفسخان أم الثانية يختص الانفساخ بها فقط، والأظهر منهما انفساخهما.

وخرج بقوله "مرتبا" ما إذا أرضعتها معا فإنه ينفسخ نكاحهما قولاً واحداً لأنهما صارتا أختين معا. ولا خلاف في تحريم المرضعة على التابيد: لأنها صارت أم زوجته.

^٣ لفظ هند يصرف ولا يصرف، إن شئت جمعته جمع التكسير فقلت: هنود، وإن شئت جمعته جمع مؤنث سالم فقلت هندات.

^٤ إن صدقاً حرم تناكحهما ظاهراً وباطناً، وإلا فظاهراً فقط، ولورجع المقر لم يقبل رجوعه.

^٥ احتراز المصنف بقوله "رضاع محرم" عما لو قال: بيننا رضاع واقتصر عليه فإنه يوقف التحريم على بيان العدد.

^٦ إذا قال زوجان بيننا رضاع محرم بشرط الإمكان فرق بينهما عملاً بقولهما وسقط المسمى إذا أضيف الرضاع إلى ما قبل الوطء لفساده؛ لأنه لم يصادف محلاً، ووجب لها مهر مثل إن وطئها وهي معذورة بنوم أو إكراه أو نحو

(وَإِنْ ادَّعى^١ رِضَاعًا فَأُنْكِرَتْ انْفِسَاحُ^٢) النِّكَاحُ مُوَآخَذَةً لَهُ بِقَوْلِهِ، (وَلَهَا الْمُسَمَّى إِنْ وَطِئَ^٣ وَإِلَّا فَنِصْفُهُ^٤) وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا وَلَهُ تَحْلِيلُهَا قَبْلَ الْوَطْءِ، وَكَذَا بَعْدَهُ إِنْ كَانَ مَهْرُ الْمِثْلِ أَقَلَّ مِنَ الْمُسَمَّى، فَإِنْ تَكَلَّتْ حَلْفَ هُوَ وَلَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ بَعْدَ الْوَطْءِ وَلَا شَيْءَ قَبْلَهُ .

(وَإِنْ ادَّعَتْهُ) أَيِ الرِّضَاعِ (فَأُنْكِرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ إِنْ زُوِّجَتْ بِرِضَاها). مِنْهُ لِيَتَضَمَّنَ رِضَاها الْإِقْرَارَ بِحِلِّهِ لَهَا (وَإِلَّا) بِأَنْ زَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ (فَالْأَصَحُّ تَصْدِيقُهَا) بِيَمِينِهَا وَالثَّانِي يُصَدِّقُ هُوَ بِيَمِينِهِ وَمَحَلُّ الْخِلَافِ إِذَا لَمْ تُمْكِنْهُ فَإِنْ مَكَّنَتْهُ فَكَمَا لَوْ رَضِيَتْ^٥

(وَلَهَا) فِي الصُّورَتَيْنِ^٦ (مَهْرٌ مِثْلُ إِنْ وَطِئَ وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهَا) عَمَلًا بِقَوْلِهَا فِيمَا لَا تَسْتَحِقُّهُ وَالْوَرَعُ لِلزَّوْجِ، فِيمَا إِذَا ادَّعَتْ الرِّضَاعَ أَنْ يَدَعَ نِكَاحَهَا بِطَلْقَةٍ لِيَحِلَّ لِغَيْرِهِ إِنْ كَانَتْ كَاذِبَةً.

كيفية يمين الرضاع نفيا وإثباتا:

(وَيُخْلَفُ مُنْكَرُ رِضَاعٍ عَلَى نَفْيِ عِلْمِهِ^٧ وَمُدَّعِيهِ عَلَى بَيِّنَةٍ^٨) رَجُلًا كَانَ أَوْ امْرَأَةً لِأَنَّ الْإِرْضَاعَ فِعْلٌ الْغَيْرِ وَفِعْلُ الْغَيْرِ يَخْلِفُ مُدَّعِيهِ عَلَى الْبَيِّنَةِ وَمُنْكَرُهُ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ كَمَا سَيَأْتِي فِي مَحَلِّهِ، وَلَوْ تَكَلَّ الْمُنْكَرُ أَوْ الْمُدَّعِي عَنْ الْيَمِينِ وَرُدَّتْ عَلَى الْآخَرِ حَلْفَ عَلَى الْبَيِّنَةِ^٩.

ذلك، فإن لم يطق أو وطن بلا عذر لها لم يجب شيء، أما إذا أضيف الإرضاع إلى ما بعد الوطء فالواجب المسعى.

^١ الدعوى: مشقة من الدعاء، وهو الطلب، وفي الشرع: قول يطلب به الإنسان إثبات حق على الغير.

^٢ قوله "انفساح" وإن كذبت المرأة المنسوب إليها الرضاع مؤاخذه له.

^٣ لها المسعى إن وطن لاستقراره بالدخول.

^٤ إن لم يطق فنصفه لورود الفرقة منه.

^٥ إذا ادعت الزوجة الرضاع فأنكر الزوج ذلك صدق بيمينه إن زوجت برضاها ممن عرفته بعينه أو عين لها فسكتت حيث يكفي سكوتها لتضمن رضاها به الإقرار بحلها له فلا يقبل منها نقيضه، وإذا حلف الزوج على نفي الرضاع استمرت الزوجية ظاهرا وعلمها منع نفسها منه ما أمكن إن كانت صادقة، وإن زوجت بغير رضاها كأن زوجها المجرى لجنون أو بكارة أو أذنت مطلقا ولم تعين الزوج فالأصح تصديقها بيمينها لاحتمال ما تدعيه ولم يسبق منها ما يناقضه والثاني: يصدق الزوج بيمينه لاستدامة النكاح الجاري على الصحة ظاهرا.

^٦ أي زوجت برضاها أم بغير رضاها كما في الحاشية السابقة.

^٧ لأنه ينفي فعل غيره.

^٨ لأنه يثبت، ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

بم يثبت الرضاع؟:

(وَيُثْبِتُ) الرِّضَاعُ (بشهادة رجلين^٢ أو رجل وامرأتين وبأربع نسوة^٣) لاختصاص النساء بالإطلاع عليه غالباً كالولادة وكل ثنتين برجل وما يقبل فيه النساء يقبل فيه الرجال والنوعان، (والإقرار به شرطه رجلان) لأنه مما يطلع عليه الرجال غالباً؛

(وتقبل شهادة المرضعة^٤ إن لم تطلب أجره) عن الرضاع (ولا ذكرت فعلها) كأن شهدت بأن بينهما رضاعاً بوصفه^٥ الآتي، (وكذا إن ذكرته^٦ فقالت أرضعته) أو أرضعتها بالوصف الآتي (في الأصح) لأنها غير متهمه في ذلك، والثاني لا يقبل ذكرها فعل نفسها كما لو شهدت بولادتها وفرق الأول باتهامها في الولادة إذ يتعلق بها النفقة والميراث وسقوط القصاص، أما إذا طلبت أجره الرضاع فلا تقبل لاتهامها بذلك^٨.

تفصيل الشهادة في الرضاع:

(والأصح أنه لا يكفي) في الشهادة أن يقال (بينهما رضاع محرّم) لاختلاف المذاهب في شروط التحريم (بل يجب ذكر وقت^٩) للرضاع للاحتراز عما بعد الحولين (وعدد^{١٠})

والبت: القطع، والابتنات: الانقطاع. ويقال لا أفعله "بته" ولا أفعله "البتة" لكل أمر لا رجعة فيه.

^١ إذا نكحت المرأة عن اليمين وردت على الزوج أو نكل الزوج عن اليمين وردت على المرأة فاليمين المردودة على البت: لأنها مثبتة.

^٢ يثبت الرضاع بشهادة رجلين كسائر الحقوق، لكن إذا شهدا ثم قالوا تعمدنا النظر إلى الثدي لا لتحمل الشهادة قال الرافعي: لم تقبل شهادتهما لأنهما فاسقان، واعترضه المصنف بأن مجرد النظر صغيرة لا ترد بها الشهادة من غير إصرار فإذا أصر لا تصح شهادته.

^٣ لا يثبت بأقل من أربع نسوة إذ كل امرأتين بمثابة رجل.

^٤ لا يثبت الإقرار بالرضاع إلا برجلين لأن الإقرار يكون باللسان، فيطلع عليه الرجال.

^٥ تقبل شهادة المرضعة بأن كانت تمام النصاب كأن تشهد المرضعة مع ثلاث نسوة ولا تكفي شهادتها وحدها.

^٦ قوله "بوصفه" يفيد أنه لا بد من تفصيلها في الشهادة كغيرها أي ذكرت فعلها.

^٨ قوله "لاتهامها" لعود نفعه عليها.

^٩ قوله "بل يجب" يفيد بأنه إذا مات الشاهد مثلاً قبل تفصيله وجب التوقف على المعتمد.

^{١٠} ذكر العدد يوجب أن يقول: خمس متفرقات، لأن غالب الناس يجهل أن الانتقال من ثدي إلى ثدي، أو قطع الرضيع للهو وتنفس ونحوهما وعوده رضعة واحدة.

لِلرَضَعَاتِ لِلاَحْتِرَازِ عَمَّا دُونَ خَمْسٍ، (وَوُصُولُ اللَّبَنِ جَوْفَهُ^١ وَيُعْرَفُ ذَلِكَ^٢ بِمُشَاهَدَةِ حَلْبِ) بِفَتْحِ اللَّامِ، (وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ^٣ أَوْ قَرَائِنٍ^٤ كَالْتِقَامِ ثَدْيٍ وَمَصِّهِ وَحَرَكَه حَلْقِهِ بِتَجَرُّعٍ وَازْدِرَادٍ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا لِبَوْنٍ^٥) فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللَّبَنِ وَقِيلَ يَحِلُّ لَهُ ذَلِكَ أَخْذًا بِظَاهِرِ الْحَالِ، وَلَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ الْقَرَائِنِ بَلْ يَعْتَمِدُهَا، وَيَجْزِمُ بِالشَّهَادَةِ^٦. وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ أَنَّهُ يَكْفِي بَيْنَهُمَا رَضَاعٌ مُحَرَّمٌ. قَالَ الرَّافِعِيُّ وَيَحْسُنُ أَنْ يُقَالَ يَكْفِي ذَلِكَ^٧ مِنَ الْفَقِيهِ الْعَارِفِ^٨ أَيُّ بِالرَّضَاعِ الْمُحَرَّمِ، وَلَا يَكْفِي مِنْ غَيْرِهِ وَقَدْ سَبَقَ فِي الْأَخْبَارِ بِنَجَاسَةِ الْمَاءِ، وَالْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ^٩ لَا يُشْتَرِطُ فِيهِ التَّعَرُّضُ لِلشُّرُوطِ مِنَ الْفَقِيهِ، وَيُشْتَرِطُ مِنْ غَيْرِهِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِهِ فِي الشَّهَادَةِ، وَالثَّانِي لَا يُشْتَرِطُ^{١٠} لِأَنَّ الْمُقَرَّرَ لَا يَحْتَاجُ فَلَا يُقَرَّرُ إِلَّا عَنْ تَحْقِيقٍ وَفِي قَبُولِ الشَّهَادَةِ الْمُطْلَقَةِ عَلَى الْإِقْرَارِ بِالرَّضَاعِ وَجْهَانِ تَبَعًا لَهُ^{١١}.

^١ ويجب ذكر وصول اللبن جوف الرضيع في الأصح في كل رضعة كما يشترط ذكر الإيلاج في شهادة الزنا
^٢ أي وصول اللبن إلي جوفه.

^٣ ازدرد مادتها زرد، يقال زرد اللقمة بلعها وزرد اللبن بلع اللبن الذي مصه.

^٤ قوله "أو قرائن" دالة على وصول اللبن إلي جوفه لأن مشاهدة القرائن قد تفيد اليقين، وبتقدير أن لا تفيده فتفيد الظن القوي.

^٥ قوله "لبون": أي ذات لبن وهو يفيد أنه إذا لم يعلم أنها ذات لبن فلا يحل له أن يشهد وهو الأصح لأن الأصل عدم اللبن.

^٦ ولا يكفي في أداء الشهادة ذكر القرائن بل يعتمدها ويجزم بالشهادة. والمراد أن يعلم أن في ثديها حالة الإرضاع أو قبله لبنا وإلا فقد يعلم أنها لبون ولا يكون في ثديها حينئذ لبن كأن حلبته أو أرضعت غيره.

^٧ أي يكفي في الشهادة أن يقال بينهما رضاع محرم فقط دون تفصيل

^٨ العارف عند القاضي الموافق له مذهبه، وليس في المسألة اختلاف ترجيح وشرط ابن الرفعة كونهما مقلدين لأن الاجتهاد قد يتغير وهو واضح.

^٩ الإقرار بالرضاع لا يشترط فيه التعرض للشروط من الفقيه الموثوق بمعرفته ويشترط من غيره كما استحسنة الرافعي، وفرق بين الشهادة والإقرار بأن المقريحتا لنفسه فلا يقر إلا عن تحقيق

^{١٠} فلا فرق فيه بين العارف وغيره.

^{١١} قوله "تبعاً له" فالمتعمد القبول مع الإطلاق كما في قبول الإقرار كذلك، وقد سبق القول بأن الإطلاق إنما يقبل من العارف وحينئذ فالشهادة على الرضاع وعلى الإقرار به كالإقرار به.

كتاب النفقات

جَمَعَ نَفَقَةً وَأَسْبَابُ وَجُوبِهَا ثَلَاثَةٌ^٢ مَلِكُ النِّكَاحِ^٣ وَمَلِكُ الْيَمِينِ^٤ وَقَرَابَةُ الْبُعْضِيَّةِ^٥ وَسَنَاتِي

تختلف نفقة الزوجة باعتبار حال الزوج يسارا وإعسارا:

وَبَدَأَ بِأَوَّلِهَا^٦ فَقَالَ (عَلَى مُوسِرٍ^٧ لِزَوْجَتِهِ^٨ كُلَّ يَوْمٍ مَدُّ طَعَامٍ وَمُعْسِرٍ مَدُّ وَمُنْتَوَسِطٍ مَدُّ وَنِصْفُ) وَاحْتَجَّ الْأَصْحَابُ^٩ لِأَصْلِ التَّفَاوُتِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ} الْآيَةَ وَاعْتَبَرُوا النَّفَقَةَ بِالْكَفَّارَةِ بِجَامِعٍ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مَالٌ يَجِبُ بِالشَّرْعِ وَيَسْتَقِرُّ فِي الذِّمَّةِ، وَأَكْثَرُ مَا وَجَبَ فِي الْكَفَّارَةِ لِكُلِّ مَسْكِينٍ مَدَانٍ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْأَذَى فِي الْحَجِّ^{١٠} وَأَقْلُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِكُلِّ مَسْكِينٍ مَدُّ وَذَلِكَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَالظَّهَارِ وَوَقَاعِ رَمَضَانَ فَأَوْجِبُوا عَلَى الْمُوسِرِ الْأَكْثَرَ وَعَلَى الْمُعْسِرِ الْأَقْلَ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ مَا بَيْنَهُمَا كَمَا تَقَدَّمَ^{١١}

^١ النفقة: لغة الإخراج. وشرعا: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤونته وتشمل الطعام والكسوة والسكنى.

^٢ النفقة قسمان: نفقة تجب للإنسان على نفسه إذا قدر عليها وعليه أن يقدمها على نفقة غيره. ونفقة تجب على الإنسان لغيره. قالوا: وأسباب وجوبها ثلاثة: النكاح والقرابة. والملك

^٣ النكاح يوجب النفقة للزوجة علة الزوج

^٤ ملك اليمين يوجب النفقة للعبد على السيد

^٥ القرابة البعضية توجب النفقة لكل واحد من القريبين على الآخر؛ لشمول البعضية والشفقة.

^٦ بدأ المصنف بنفقة الزوجات لأنها واجبة بالنص والإجماع بطريق المعاوضة في مقابلة التمكين من الاستمتاع، ولا تسقط بمضي الزمان، فهي أقوى من غيرها.

^٧ الموسر: هو الذي يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه وحق من تلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله..

^٨ الأصل في وجوبها قوله تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} النساء ٣٤ والقيم على الغير: هو المتكفل بأمره. ولما روي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال في خطبته في حجة الوداع (ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف) صحيح مسلم، ولما روي عن عائشة أن هند بنت عتبة قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم فقال ﷺ (خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف) صحيح البخاري.

^٩ الأصحاب. فقهاء الشافعية الذين لهم اجتهادات فقهية خاصة خرجوها على أصول الإمام الشافعي وقواعده، وهم بذلك ينسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه.

^{١٠} أي الحلق

^{١١} اعتبر الأصحاب النفقة بالكفارة بجامع أن كلا منهما مال يجب بالشرع ويستقر في الذمة، وأكثر ما وجب في الكفارة لكل مسكين مدان وذلك في كفارة الأذى في الحج، وأقل ما وجب له مد في نحو كفارة الظهار فأوجبوا على الموسر الأكثر وهو مدان لأنه قدر الموسع وعلى المعسر الأقل، وهو المد الواحد لأنه

لا تفاوت في النفقة بين امرأة وأخرى:

يَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الزَّوْجَةُ الْمُسْلِمَةُ وَالذَّمِيَّةُ وَالْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ، وَلَا يُعْتَبَرُ حَالُ الْمَرْأَةِ فِي شَرَفِهَا وَغَيْرِهِ، وَلَا يُعْتَبَرُ كِفَايَتُهَا كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ لِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّهَا أَيَّامَ مَرَضِهَا وَشَبَعِهَا ^١.

مقدار المد:

(وَالْمُدُّ ^٢ مِائَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ دِرْهَمًا وَثُلُثُ دِرْهَمٍ) لِأَنَّهُ رَطْلٌ وَثُلُثُ بَغْدَادِيٍّ وَرَطْلٌ بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَلَاثُونَ دِرْهَمًا كَمَا تَقَدَّمَ فِي زَكَاةِ النَّبَاتِ. (قُلْتُ الْأَصَحُّ مِائَةٌ وَأَحَدٌ وَسَبْعُونَ وَثَلَاثَةٌ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) بِنَاءً عَلَى مَا رَجَّحَهُ هُنَاكَ مِنْ أَنَّ الرَّطْلَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَّةٌ وَعِشْرُونَ وَارْبَعَةٌ أَسْبَاعٍ دِرْهَمٍ.

ضابط الإيسار والإعسار:

(وَمِسْكِينُ الزَّكَاةِ) وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي قِسْمِ الصَّدَقَاتِ أَنَّهُ مِنْ قَدَرٍ عَلَى مَالٍ أَوْ كَسْبٍ يَقَعُ مَوْقِعًا مِنْ كِفَايَتِهِ وَلَا يَكْفِيهِ، (مُعْسِرٌ ^٣ وَمَنْ فَوْقَهُ ^٤ إِنْ كَانَ لَوْ كُلِّفَ مُدَيْنٍ رَجَعَ مِسْكِينًا فَمُتَوَسِّطٌ ^٥ وَإِلَّا فَمُوسِرٌ ^٦) وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالرُّخْصِ وَالْغَلَاءِ ^٧، وَقِيلَ: الْمُوسِرُ مَنْ يَزِيدُ دَخْلُهُ عَلَى خَرْجِهِ،

يكتفي به الزهيد ويتقنع به الرغيب، وعلى المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره، ولو اكتفى منه بمد لضرها فلزمه مد ونصف، وقيل، ونسب للقديم: أن نفقة الزوجة منوطة بالكفاية كنفقة القريب لقوله ﷺ (خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف)، وأجيب بأننا لو اعتبرناها بالكفاية كنفقة القريب لسقطت نفقة المريضة ومن هي مستغنية بالشعب في بعض الأيام، وليس كذلك، فإذا بطلت الكفاية حسن تقريبها من الكفارة.

^١ نفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة: فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، وهي مقدرة غير معتبرة بكفايتها، قوله تعالى: {لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله} [الطلاق: ٧].

^٢ المد مختلف فيه: قال الرافعي: المد مائة وثلاثة وسبعون درهما وثلث درهم فهو ما يسع رطلا وثلثا من حب الشعير بناء على أن رطل بغداد مائة وثلثون درهما، وخالفه المصنف فقال الأصح أنه مائة وأحد وسبعون درهما (وثلاثة أسباع درهم، بناء على أن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم).

^٣ المعسر: هو: الذي لا يقدر على النفقة بماله ولا كسبه.

^٤ أي المسكين

^٥ المتوسط: هو من كان أعلى حالا من المعسر، وأدنى حالا من الموسر.

^٦ الموسر: هو الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه.

^٧ لابد من النظر إلى الرخص والغلاء، وقلة العيال وكثرتها، حتى إن الشخص قد تجب عليه لزوجة واحدة نفقة الموسر، ولا تجب عليه لو كان ذا زوجتين أو أكثر إلا نفقة المتوسط أو المعسر.

وَالْمُعْسِرُ عَكْسُهُ وَالْمُتَوَسِّطُ مَنْ اسْتَوَى دَخْلُهُ وَخَرَجُهُ وَقِيلَ يُرْجَعُ فِي الثَّلَاثَةِ^١ إِلَى الْعَادَةِ وَتَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ وَالْبِلَادِ.

(فَرَعُ): الْعَبْدُ^٢ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ وَكَذَا الْمُكَاتَبُ^٣ وَالْمُبْعَعُ^٤، وَإِنْ كَثُرَ مَالُهَا وَلِضَعْفِ مَلِكِ الْمُكَاتَبِ وَنَقْصِ حَالِ الْآخَرِ^٥

المعتبر في النفقة غالب قوت البلد:

(وَالْوَاجِبُ غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ)^٦ مِنَ الْحِنْطَةِ وَغَيْرِهَا، (قُلْتُ فَإِنْ اخْتَلَفَ) غَالِبُ قُوتِ الْبَلَدِ أَوْ قُوتِهَا مِنْ غَيْرِ غَالِبٍ، (وَجَبَ لَأَيْقُ بِهِ^٧) أَيُّ بِالزَّوْجِ^٨

(وَيُعْتَبَرُ الْيَسَارُ^٩ وَغَيْرُهُ^{١٠} طُلُوعُ الْفَجْرِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) لِأَنَّهُ الْوَقْتُ الَّذِي يَجِبُ فِيهِ التَّسْلِيمُ^{١١}، فَالْمُوسِرُ حِينَئِذٍ عَلَيْهِ نَفَقَةُ الْيَسَارِ، وَإِنْ أَعْسَرَ فِي أَثْنَاءِ النَّهَارِ وَالْمُعْسِرُ بِعَكْسِهِ^{١٢}. ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ^{١٣}.

^١ الموسر والمعسر والمتوسط

^٢ العبد: الرقيق الذي لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق ومقدماته.

^٣ المكاتب: أن يكتب السيد عبده أو أمته على مال منجم أي مقسط فإذا أداه العبد صار حراً.

^٤ المبعوض: هو العبد الذي يكون بعضه حراً وبعضه عبداً كأن يكون حراً يوماً أو شهراً وعبد يوماً أو شهراً.

^٥ العبد وإن كان مكاتباً أو مبعوضاً وإن كثر ماله فمعسر لضعف ملك المكاتب ونقص حال المبعوض وعدم ملك غيرهما.

^٦ أي بلدهما من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها حتى يجب اللحم في حق أهل البوادي الذين يعتادونه لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، وقياساً على الفطرة والكفارة فالتعبير بالبلد جرى على الغالب.

^٧ قوله "وجب لأيق به" يساراً وعدمه ولا عبرة بإسرافه وتقتيره.

^٨ قال المصنف: إذا اختلف قوت بلد الزوج والزوجة ولا غالب فيه أو اختلف الغالب وجب لأيق بالزوج لا بها، وقال الماوردي: إن نزلت عليه في بلده اعتبر غالب قوت بلده، وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها، وإن نزل ببلدة ولم تألف خلاف قوت بلدها قيل لها: هذا حقك فأبدليه قوت بلدك إن شئت، ولو انتقلا عن بلدهما لزمه من غالب قوت ما انتقلا إليه.

^٩ إذا اختلف الزوجان في اليسار فادعت المرأة يسار زوجها وأنكره الزوج فالقول قوله ما لم يتحقق له مال.

^{١٠} من توسط وإعسار

^{١١} قوله "لأنه الوقت الذي يجب فيه التسليم" أي من حيث إن لها المطالبة به، ولا يلزمها الصبر عليه وليس لها حبسه ولا للحاكم إجبارها، لأنه واجب موسع وليس لها مطالبتة بنفقة مستقبلية

^{١٢} يعتبر اليسار وقت طلوع الفجر في كل يوم اعتباراً بوقت الوجوب حتى لو أيسر بعده أو أعسر لم يتغير حكم نفقة ذلك اليوم، وإنما وجب لها ذلك بفجر اليوم؛ لأنها تحتاج إلى طحنه وعجنه وخبزه.

^{١٣} الشرح: هو كتاب فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي، وقد شرح فيه الرافعي كتاب الوجيز للغزالي.

(وَعَلَيْهِ تَمْلِيكُهَا^١ حَبًّا)^٢ كَالْكَفَّارَةِ (وَكُذًا) عَلَيْهِ (طَحْنُهُ وَخَبْزُهُ فِي الْأَصَحِّ)^٣ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا
وَالثَّانِي^٤ لَا كَالْكَفَّارَةِ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ^٥ بِأَنَّهَا فِي حَبْسِهِ وَالثَّالِثُ^٦ إِنْ كَانَتْ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ الَّذِينَ
عَادَتْهُمْ الطَّحْنُ وَالْخَبْزُ بِأَنْفُسِهِمْ، فَلَا وَإِلَّا فَتَنَعَم

(وَلَوْ طَلَبَ أَحَدُهُمَا بَدَلَ الْحَبِّ) مِنْ خُبْزٍ أَوْ غَيْرِهِ أَيْ طَلَبَتْهُ هِيَ أَوْ بَذَلَهُ هُوَ بِالْمُعْجَمَةِ، (لَمْ
يُجْبَرْ الْمُتَمَتِّعُ) مِنْهُمَا^٧

مدي جواز الاعتياض عن النفقة:

(فَإِنْ اغْتَاظَتْ^٨) عَنْهُ شَيْئًا^٩ (جَازَ^٩ فِي الْأَصَحِّ^{١٠} إِلَّا خُبْرًا وَدَقِيقًا)، فَلَا يَجُوزُ (عَلَى
الْمَذْهَبِ)^{١١} أَمَّا الْجَوَازُ فِي غَيْرِهِمَا كَالدَّرَاهِمِ وَالْدَّنَانِيرِ وَالنِّيَابِ فَلِأَنَّهُ اعْتِيَاظٌ عَنْ طَعَامٍ
مُسْتَقَرٍّ فِي الذِّمَّةِ لِمُعَيَّنٍ، كَالِاعْتِيَاظِ عَنْ الطَّعَامِ الْمَغْضُوبِ الْمُتْلَفِ وَوَجْهُ الْمُنْعِ الْقِيَاسُ
عَلَى الْمُسْلِمِ فِيهِ وَالْكَفَّارَةِ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ الْاعْتِيَاظُ عَنْهُمَا قَبْلَ قَبْضِهِمَا^{١٢} وَانْفَصَلَ الْأَوَّلُ^{١٣}
فِي قِيَاسِهِ عَنْ ذَلِكَ بَأَنَّ الْمُسْلِمَ فِيهِ غَيْرُ مُسْتَقَرٍّ وَطَعَامُ الْكَفَّارَةِ لَا يَسْتَقَرُّ لِمُعَيَّنٍ وَأَمَّا الْجَوَازُ
فِي الْخُبْزِ وَالْدَّقِيقِ الَّذِي قَطَعَ بِهِ النُّعُوقُ، فَلِأَنَّهَا تَسْتَحِقُّ الْحَبَّ وَالْإِصْلَاحَ وَقَدْ فَعَلَهُ، فَإِذَا
أَخَذَتْ مَا ذَكَرَ فَقَدْ أَخَذَتْ حَقَّهَا لَا عَوَضَهُ، وَرَجَّحَ الْعِرَاقِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، مِنْ الْوَجْهَيْنِ فِي ذَلِكَ

^١ تعبير المصنف بالتمليك يقتضي اعتبار الإيجاب والقبول. وليس مرادًا، بل الواجب الدفع إليها..

^٢ علي الزوج تملك زوجته الطعام حبا سليما لأنه أكمل في النفع من الخبز والدقيق فتصرف فيه كيف شاءت قياسا على الكفارة وزكاة الفطر.

^٣ وكذا على الزوج طحن الحب وعجنه وخبزه في الأصح وأن عليه مؤنة ذلك ببذل مال أو يتولاه بنفسه أو بغيره لأن الحب لا يتناول في العادة بدون ذلك، وتكليفها له ليس من المعاشرة بالمعروف.

^٤ الثاني وهو مقابل الأصح: لا يلزمه الطحن والعجن كالكفارات

^٥ فرق الأول "الأصح" بأنها في حبسه، فعليه أن يكفيها مؤنة ذلك بخلاف الكفارة

^٦ إذا طلبت الزوجة بدل الحب خبزا أو قيمة وامتنع الزوج أو طلب الزوج إعطاء ذلك وامتنعت لم يجبر الممتنع منهما لأنه غير الواجب، والاعتياض شرطه التراضي

^٧ اعتاض وتعوض أخذ العوض، واستعاض أي طلب العوض.

^٨ نقدا أو غيره من العروض

^٩ قوله "جاز" بشرط القبض في المجلس خروجا من بيع الدين بالدين لأنه هنا بيع دين لمن هو عليه.

^{١٠} إن اعتاضت الزوجة عما وجب لها نقدا أو غيره من العروض جاز اعتياضها في الأصح لأنه طعام مستقر في الذمة لمعين، فجاز أخذ العوض عنه بالتراضي كالقرض.

^{١١} ولا يجوز الاعتياض عما وجب لها بالخبر أو الدقيق ونحوهما من الجنس على المذهب لما فيه من الربا.

^{١٢} وإلا صار من الربا المحرم.

^{١٣} الأول: الأصح

الْمَنْعُ لِأَنَّهُ رَبًّا، هَذَا كُلُّهُ فِي الْإِغْتِيَاظِ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ وَالْحَالِيَةِ، وَأَمَّا الْمُسْتَقْبَلَةُ فَلَا يَجُوزُ الْإِغْتِيَاظُ عَنْهَا قَطْعًا وَلَا يَجُوزُ الْإِغْتِيَاظُ مِنْ غَيْرِ الزَّوْجِ قَطْعًا^١.

سقوط نفقة الزوجة بالأكل مع زوجها:

(وَلَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ^٢ كَالْعَادَةِ سَقَطَتْ^٣ نَفَقَتُهَا فِي الْأَصَحِّ)؛ لِإِكْتِفَاءِ الزَّوْجَاتِ بِهِ فِي الْأَعْصَارِ وَالْأَمْصَارِ، وَجَرَيَانِ النَّاسِ عَلَيْهِ فِيهَا وَالثَّانِي لَا تَسْقُطُ، لِأَنَّهُ لَمْ يُؤَدِّ الْوَاجِبَ، وَتَطَوُّعَ بغيرِهِ (قُلْتُ^٤ ° إِلَّا أَنْ تَكُونَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ^٥ وَلَمْ يَأْذَنْ وَلِيُّهَا وَاللَّهُ أَعْلَمُ) فِي أَكْلِهَا مَعَهُ فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ لَا تَسْقُطُ عَنْهُ جُزْمًا، كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ بِخِلَافِ مَا إِذَا أَدَّى الْوَلِيُّ^٦ فِيهِ الْخِلَافُ. قَالَ: وَلِيَكُنَّ السَّقُوطُ مُفَرَّعًا عَلَى جَوَازِ إِغْتِيَاظِ الْخُبْرِ، وَأَنْ يُجْعَلَ مَا جَرَى قَائِمًا مَقَامَ الْإِغْتِيَاظِ يَغْنِي إِنْ لَمْ يُلَاحَظْ مَا جَرَى عَلَيْهِ النَّاسُ فِي الْأَعْصَارِ كَمَا تَقَدَّمَ.

للزوجة أدم ولحم مع نفقتها:

(وَيَجِبُ^٨ أَدَمُ^٩ غَالِبُ الْبَلَدِ^{١٠} كَزَيْتٍ وَسَمْنٍ وَجُبْنٍ وَتَمْرٍ) وَخَلٍ (وَيُخْتَلَفُ بِالْفُصُولِ)، فَيَجِبُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مَا يُنَاسِبُهُ^{١١} (وَيَقْدَرُهُ قَاضٍ^{١٢} بِاجْتِهَادِهِ^{١٣} وَيُقَاوِثُ^{١٤}) فِي قَدَرِهِ (بَيْنَ مُوسِرٍ وَغَيْرِهِ)،

^١ لا يجوز الاعتياض عن النفقة المستقبلية لأنها معرضة للسقوط بالنشوز وغيره بخلاف الحالية والماضية، فإنه يجوز الاعتياض عنها من الزوج، أما من غيره فلا يجوز قطعاً في النفقة الحالية والمستقبلية أما الماضية فيجوز من غير الزوج بناء على صحة بيع الدين لغير من هو عليه.

^٢ قول المصنف: (معه) ليس بقيد، فلو أرسل إليها الطعام أو أحضرته وأكلته وحدها فكذلك الحكم

^٣ قوله "سقطت" فما أكلته بدل عن الواجب، ومحل السقوط إن أكلت قدر الواجب فأكثر، وإلا رجعت بقدر ما بقي من الواجب وتصدق بيمينها في قدره

^٤ لجريان العادة به في زمن النبي ﷺ وبعده من غير نزاع ولا إنكار ولا خلاف، ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده، ولو كان لا يسقط مع علم النبي ﷺ بإطباقهم عليه لأعلمهم بذلك، ولقضاه من تركه من مات ولم يوفه، وهذا لا شك فيه

^٥ يرى المصنف أنه تسقط نفقة الزوجة بالأكل مع زوجها إلا أن تكون الزوجة غير رشيدة كصغيرة أو سفية بالغة ولم يأذن وليها في أكلها معه فلا تسقط نفقتها جزماً بأكلها معه ويكون الزوج متطوعاً.

^٦ أي محجوراً عليها.

^٧ قوله "أذن الولي" أي صريحاً باللفظ ولا يكفي علمه، ولا بد من كون المصلحة في أكلها معه، وإلا لم يصح الإذن

^٨ يجب للزوجة على زوجها الأدم

^٩ ما يؤتد به.

^{١٠} الواجب أدم من غالب بلد الزوجة، فإن لم يكن أدم غالب فما يليق به لا بها.

^{١١} يختلف الأدم باختلاف الفصول فيفرض لها في كل فصل ما يليق به ويعتاده الناس، فيجب الرطب في وقته واليابس في وقته.

وغيره)، فيَنْظُرُ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الْمُدَّ فَيَقْرِضُهُ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَضِعْفُهُ عَلَى الْمُوسِرِ وَمَا بَيْنَهُمَا عَلَى الْمُتَوَسِّطِ، وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَكِيلَةِ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ أَيْ: أَوْقِيَّةٍ^٣ فَتَقْرِبُ.

(و) يَجِبُ (لَحْمٌ^٤ يَلِيقُ بِبِسَارِهِ، وَإِعْسَارِهِ كَعَادَةِ الْبَلَدِ)^٥. وَمَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رَطْلٍ^٦ لَحْمٍ فِي الْأُسْبُوعِ الَّذِي حُمِلَ عَلَى الْمُعْسِرِ، وَجُعِلَ بِاعْتِبَارِ ذَلِكَ عَلَى الْمُوسِرِ رَطْلَانِ وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ رَطْلٌ وَنِصْفٌ، وَأَنْ يَكُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِأَنَّهُ أَوْلَى بِالتَّوَسُّعِ فِيهِ مَحْمُولٌ عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ عَلَى مَا كَانَ أَتْيَامُهُ بِمَضَرٍ مِنْ قَلَّةِ اللَّحْمِ فِيهَا، وَيَزَادُ بَعْدَهَا بِحَسَبِ عَادَةِ الْبَلَدِ. وَقَالَ الْبَغَوِيُّ^٧ يَجِبُ فِي وَقْتِ الرُّخْصِ رَطْلٌ عَلَى الْمُوسِرِ كُلِّ يَوْمٍ وَعَلَى الْمُعْسِرِ كُلِّ أُسْبُوعٍ، وَعَلَى الْمُتَوَسِّطِ كُلِّ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ وَفِي وَقْتِ الْغَلَاءِ فِي أَيَّامٍ مَرَّةً عَلَى مَا يَرَاهُ الْحَاكِمُ. وَقَالَ الْقَفَّالُ^٨ وَغَيْرُهُ. لَا مَزِيدَ عَلَى مَا ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي جَمِيعِ الْبِلَادِ لِأَنَّ فِيهِ كِفَايَةً لِمَنْ قَنَعَ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَتَبِعَهُ الْمُصَنِّفُ، وَيُشَبِّهُ أَنْ يُقَالَ لَا يَجِبُ الْأُدْمُ فِي يَوْمِ اللَّحْمِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُوا لَهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُقَالَ إِذَا أُوجِبْنَا عَلَى الْمُوسِرِ اللَّحْمَ كُلَّ يَوْمٍ يَلْزَمُهُ الْأُدْمُ أَيْضًا لِيَكُونَ أَحَدُهُمَا غَدَاءً وَالْآخَرُ عَشَاءً عَلَى الْعَادَةِ

(وَلَوْ كَانَتْ تَأْكُلُ الْخُبْزَ وَحْدَهُ وَجَبَ الْأُدْمُ)^٩ وَلَا نَظَرَ إِلَى عَادَتِهَا^{١٠} وَالْأَصْلُ فِي جُوبِهِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} وَلَيْسَ مِنَ الْمَعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ تَكْلِيفُهَا الصَّبْرَ عَلَى الْخُبْزِ وَحْدَهُ.

^١ قوله "ويقدره قاض" أي عند تنازعهما ولو تبرمت من الأدم فلها إبداله إن شاءت، ولا يلزم الزوج إبداله إلا إن كانت غير مميزة أو سفمية، وليس لها من يقوم بأمورها، فاللائق أنه يلزم الزوج إبداله.

^٢ يقدره القاضي باجتهاده إذ لا توقيف فيه من جهة الشرع

^٣ الأوقية: وزن من الأوزان وهي أربعون درهما.

^٤ قوله "ويجب لحم" يفيد يعطفه على الأدم أنه ليس منه، وقد يطلق اسم الأدم عليه.

^٥ يجب للزوجة علي زوجها لحم يليق ببساره وتوسطه وإعساره كعادة البلد فإن أكلوا اللحم في كل يوم مرة فلها كذلك، ولا يتقدر بوزن كرطل، بل يعتبر فيه تقدير القاضي.

^٦ الرطل: معيار يوزن به، وهو اثنتا عشرة أوقية.

^٧ الحسين بن مسعود بن محمد العلامة محيي السنة أبو محمد البغوي، المتوفي ٥١٦ هـ.

^٨ محمد بن علي بن إسماعيل أبو بكر الشاشي القفال، المتوفي ٣٦٥ هـ.

وجوب كسوة الزوجة على زوجها ٣:

(وَكِسْوَةٌ) أَي وَعَلَى الزَّوْجِ كِسْوَةُ الزَّوْجَةِ. قَالَ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (تَكْفِيهَا) أَي عَلَى قَدَرِ كِفَايَتِهَا، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِطُولِهَا وَقِصَرِهَا وَهَزَالِهَا وَسَمِنِهَا وَبِاخْتِلَافِ الْبِلَادِ فِي الْحَرِّ وَالْبُرْدِ، وَلَا يَخْتَلِفُ عَدَدُ الْكِسْوَةِ بِبَسَارِ الزَّوْجِ وَإِعْسَارِهِ وَلَكِنَّهُمَا يُؤَيِّزَانِ فِي الْجُودَةِ وَالرَّدَاءَةِ

(فَيَجِبُ قَمِيصٌ ° وَسَرَاوِيلٌ ٦ وَخِمَارٌ ٧ لِلرَّأْسِ ٥) (وَمِكَعَبٌ ٨) أَوْ نَحْوُهُ ٩ يُدَاسُ فِيهِ هَذَا فِي كُلِّ مِّنْ فَصْلِ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا سَيَأْتِي أَنَّهَا تُعْطَى الْكِسْوَةُ أَوَّلَ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ (وَتُرَادُ فِي الشِّتَاءِ) عَلَى ذَلِكَ (جُبَّةٌ ١) مَحْشُوءَةٌ أَوْ نَحْوَهَا لِلْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ، فَإِنْ لَمْ تَكْفِ لِشِدَّةِ الْبُرْدِ زَيْدٌ عَلَيْهَا بِقَدَرِ الْحَاجَةِ وَقِيلَ لَا يَجِبُ السَّرَاوِيلُ فِي الصَّيْفِ وَفِي الْحَاوِي ١٠ أَنَّ نِسَاءَ أَهْلِ الْقُرَى إِذَا لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُنَّ أَنْ يَلْبَسْنَ فِي أَرْجُلِهِنَّ شَيْئًا فِي الْبُيُوتِ لَمْ يَجِبْ لِأَرْجُلِهِنَّ شَيْءٌ.

^١ إن قيل: لم سكت المصنف عن المشروب ولا شك في وجوبه ؟ أجيب بأنه يؤخذ من قوله فيما بعد: (تجب آلات أكل وشرب)، فإذا وجب الظرف فكذا المظروف.

^٢ إذا كانت عاداتها تأكل الخبز وحده وجب لها الأدم ولا نظر لعاداتها لأنه حقها كما لو كانت تأكل بعض الطعام فإنها تستحق جميعه.

^٣ يدل على وجوب الكسوة قوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، ولما روى أن رسول الله ﷺ قال في حديث: وحقن عليكم أن تحسنوا إلين في كسوتهن وطعامهن «سنن الترمذي،

^٤ ولأن الكسوة كالقوت في أن البدن لا يقوم إلا بها، فتجب كسوتهما على قدر الكفاية.

^٥ قوله "عدد الكسوة" بخلاف جنسها ونوعها، والعبرة في التعدد بأمثالها ولو انتقلت إلى بلد اعتبر أهلها.

^٦ القميص: ثوب مخطط يستر جميع البدن، وفي ذلك إشعار بوجوب الخياطة على الزوج.

^٧ سراويل: ثوب مخطط يستر أسفل البدن ويصون العورة.

^٨ الخمار: ما تغطي به ويلحق به الكوفية ونحوها.

^٩ المكةب: مداس الرجل ونحوه كالنعل والخف والقبقاب وجميع ذلك حيث جرت العادة به.

^{١٠} يجب للزوجة في الشتاء جبة محشوة قطناً أو فروة بحسب العادة لدفع البرد، فإن اشتد البرد فجبتان، أو فروتان فأكثر بقدر الحاجة، والتعبير بالشتاء جرى على الغالب، وإلا فالعبرة بالبلاد الباردة، وإذا لم تستغن في البلاد الباردة بالثياب عن الوقود وجب لها من الحطب والفحم بقدر العادة.

^{١١} كتاب الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي ت ٤٥٠هـ.

(وَجِئْسَهَا) أَيِ الْكِسْوَةِ (قُطْنٌ) ^١ فَتَكُونُ لِمَرْأَةِ الْمُؤَسِّرِ مِنْ لَيْنِهِ وَلِمَرْأَةِ الْمُعْسِرِ مِنْ غَلِيظِهِ وَلِمَرْأَةِ الْمُتَوَسِّطِ مِمَّا بَيْنَهُمَا

(فَإِنْ جَرَتْ عَادَةُ الْبَلَدِ لِمِثْلِهِ) أَيِ الزَّوْجِ (بِكُتَّانٍ) ^٢ أَوْ حَرِيرٍ وَجَبَ فِي الْأَصَحِّ، وَيُفَاوِثُ بَيْنَ الْمُؤَسِّرِ وَالْمُعْسِرِ فِي مَرَاتِبِ ذَلِكَ الْجِنْسِ، وَالثَّانِي لَا يَجِبُ بَلْ يَكْفِي الْإِقْتِصَارُ عَلَى الْقُطْنِ لِأَنَّ غَيْرَهُ رُعُونَةٌ (وَيَجِبُ مَا تَقَعْدُ عَلَيْهِ كَزَلْيَةٍ) ^٣ بِكُسْرِ الزَّايِ أَيِ لِمَرْأَةِ الْمُتَوَسِّطِ (أَوْ لِبَدٍ) ^٤ فِي الشِّتَاءِ (أَوْ حَصِيرٍ) ^٥ فِي الصَّيْفِ كِلَاهُمَا لِمَرْأَةِ الْمُعْسِرِ، وَلِلْمُؤَسِّرِ طَنْفَسَةٌ ^٦ فِي الشِّتَاءِ وَنَطْعٌ ^٧ فِي الصَّيْفِ

(وَكَذَا فِرَاشٌ لِلنَّوْمِ فِي الْأَصَحِّ) ^٨ فَيَجِبُ مُضْرِبَةٌ ^٩ وَثِيرَةٌ ^{١٠} أَوْ قَطِيفَةٌ. وَالثَّانِي لَا بَلْ تَنَامُ عَلَى مَا تَقَعْدُ عَلَيْهِ نَهَارًا (وَمَخْدَةٌ) ^{١١} وَلِحَافٌ (أَوْ نَحْوُهُ) (فِي الشِّتَاءِ) فِي الْبِلَادِ الْبَارِدَةِ. وَذَكَرَ الْغَزَالِيُّ الْمَلْحَقَةَ ^{١٢} أَيِ فِي الصَّيْفِ وَسَكَتَ غَيْرُهُ عَنْهَا.

وَفِي الْبَحْرِ ^١ لَوْ كَانُوا لَا يَغْتَادُونَ فِي الصَّيْفِ لِنَوْمِهِمْ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ لَمْ يَلْزَمْ شَيْءٌ آخَرُ آخَرُ وَلْيَكُنْ مَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ لِمَرْأَةِ الْمُعْسِرِ مِنَ الْمُرْتَفِعِ، وَلِمَرْأَةِ الْمُعْسِرِ مِنَ النَّازِلِ وَلِمَرْأَةِ الْمُتَوَسِّطِ مِمَّا بَيْنَهُمَا

^١ وجنس الكسوة ثوب يتخذ من القطن لأنه لباس أهل الدين، وما زاد عليه ترفه ورعونة، ويختلف ذلك بحال الزوج من يسار وإعسار وتوسط فيجب لامرأة الأول من لينه، والثاني من غليظه، والثالث مما بينهما.

^٢ إذا جرت عادة البلد أن يكون جنس الكسوة من كتان أو حرير وجب في الأصح مع وجوب التفاوت في مراتب ذلك الجنس بين المؤسّر وغيره عملاً بالعادة. والثاني: لا يلزمه ذلك بل يقتصر على القطن، وتعتبر العادة في الصفاقة ونحوها. نعم لو جرت العادة بلبس الثياب الرفيعة التي لا تسترو ولا تصح فيها الصلاة فإنه لا يعطى منها، لكن من الصفيق الذي يقرب منه في الجودة.

^٣ زلية بكسر الزاي شيء مضرب صغير وقيل بساط صغير في الصيف والشتاء.

^٤ لبد: بساط تجلس عليه في الشتاء.

^٥ حصير: بساط تجلس عليه في الصيف

^٦ طنفسة: بساط صغير تخين له وبرة كبيرة، وقيل: كساء في الشتاء.

^٧ نطع: قطعة من الجلد تقعد عليه المرأة.

^٨ للعادة الغالبة به.

^٩ مضربة بقطن

^{١٠} وثيرة: لينة.

^{١١} سميت بذلك لملاصقتها للخد ولا يجب أكثر من واحدة وإن جرت العادة بالأكثر.

^{١٢} الملحقة: هي المعروفة بالملاية الآن فتجب لها إن احتاجت للخروج لنحو حمام مثلاً ويغني عنها الإزار المعروف.

للزوجة على زوجها آلة التنظيف:

(و) عَلَيْهِ (آلَةٌ تُنْظَفُ^٢ كَمْشَطٌ^٣ وَدُهْنٌ) مِنْ زَيْتٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَمَا يُغْسَلُ بِهِ الرَّأْسُ)^٤ مِنْ سِدْرٍ أَوْ نَحْوِهِ (وَمَرْتَكَ^٥ وَنَحْوَهُ لِدَفْعِ صُنَانٍ) إِذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بِالْمَاءِ وَالتُّرَابِ

(لَا كُحْلٌ وَخَضَابٌ وَمَا يَزِينُ)^٦ بِفَتْحِ الْيَاءِ غَيْرُ مَا ذَكَرَهُ فَإِنَّهُ لَا يَجِبُ فَإِنْ أَرَادَ الزَّيْنَةُ بِهِ هَيَّأَهُ لَهَا تَتَزَيَّنُ بِهِ (وَدَوَاءٌ مَرَضٍ وَأَجْرَةٌ طَبِيبٍ وَحَاجِمٍ)^٧، وَقَاصِدٌ فَلَا يَجِبُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ لِحِفْظِ الْبَدَنِ (وَلَهَا طَعَامٌ أَيَّامَ الْمَرَضِ وَأُدْمُهَا)^٨ وَصُرِفَ ذَلِكَ إِلَى الدَّوَاءِ وَنَحْوِهِ

(وَالْأَصْحُ وَجُوبُ أَجْرَةِ حَمَامٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ)^٩ فَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا تَعْتَادُ دُخُولَهُ فَلَا تَجِبُ، وَالثَّانِي لَا تَجِبُ إِلَّا إِذَا اشْتَدَّ الْبَرْدُ، وَعَسِرَ الْغُسْلُ إِلَّا فِي الْحَمَامِ، وَعَلَيْهِ الْغَزَالِيُّ وَحَيْثُ وَجِبَتْ. قَالَ الْمَاورِدِيُّ إِنَّمَا تَجِبُ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً

(و) الْأَصْحُ وَجُوبُ (ثَمَنِ مَاءٍ غُسْلٍ جَمَاعٍ وَنِفَاسٍ) إِذَا اخْتَاجَتْ إِلَى شِرَائِهِ (لَا حَيْضٌ وَاحْتِلَامٌ فِي الْأَصْحِ)، وَالْفَرْقُ أَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهِ فِي الْأَوَّلِ^{١٠} مِنْ قَبْلِ الزَّوْجِ^{١١} بِخِلَافِهَا فِي

^١ كتاب بحر المذهب في فروع المذهب الشافعي لأبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني ت ٥٠٢ هـ.

^٢ للزوجة علي زوجها آلة تنظيف من الأوساخ التي تؤذيها

^٣ المشط: اسم للآلة المستعملة في ترجيل الشعر.

^٤ يجب للزوجة ما تغسل به الرأس من سدر ونحوه على حسب العادة، لاحتياجها إلى ذلك، والرجوع في قدره إلى العادة، وكذا ما تغسل به الثياب والأيدي والأواني من صابون ونحوه.

^٥ مرتك: مادة أصلها من الرصاص تقطع رائحة الإبط لأنها تحبس العرق وإن طرحت في الخل أبدلت حموضته حلاوة

^٦ لا يجب للزوجة علي زوجها كحل و خضاب عطرولا ما تزين به من آلات الحلي لزيادة التلذذ وكمال الاستعمال، وذلك حق له فلا يجب عليه، فإن هيأه لها وجب عليها استعماله.

^٧ لا يجب للزوجة علي زوجها دواء مرض ولا أجره طبيب وحاجم ونحو ذلك كفاصد لأن ذلك لحفظ الأصل فلا يجب على مستحق المنفعة كعمارة الدار المستأجرة.

^٨ وهنا يجب التوقف والقول بذلك فيه نظر، وأنه مجرد اجتهاد يناسب العصر والبيئة التي قيل فيها، ولا يجب الأخذ به، وأن تحمل الزوج لأجرة الطبيب و ثمن الدواء هو ما يمكن القول به، فقد أمر الله تعالى معاشره الزوجة بالمعروف في قوله تعالى { وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ } النساء جزء من آية ١٩، وليس من المعاشرة بالمعروف عدم تحمل الزوج أجره طبييها ولا ثمن دواءها.

^٩ للزوجة أيام المرض أدمها وكسوتها وآلة تنظيفها ودهنها وغير ذلك من جميع ما سبق.

^{١٠} يجب للزوجة في الأصح أجره حمام بحسب العادة إن كانت عاداتها دخوله للحاجة إليه عملا بالعرف، وذلك في كل شهر مرة كما قاله الماوردي، والثاني: لا تجب لها الأجرة إلا إذا اشتد البرد وعسر الغسل إلا في الحمام، أما لو كانت من قوم لا يعتادون دخوله فلا تجب لها أجرته.

^{١١} الجماع والنفاس

أي بسببه.

الثاني^١ وَيُقَاسُ بِذَلِكَ مَاءُ الْوُضُوءِ، فَيُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ عَنْ لَمْسِهِ وَغَيْرِهِ، وَمُقَابِلِ الْأَصَحِّ فِي الْأَوَّلِ يَنْظُرُ إِلَى وَجُوبِ التَّمَكُّينِ عَلَيْهَا، وَفِي الثَّانِي يَنْظُرُ إِلَى حَاجَتِهَا^٢ عَلَى أَنَّهُ فِي الرُّوْضَةِ^٣ فِي الْإِحْتِلَامِ قَالَ لَا يَلْزَمُ قَطْعًا أَخْذًا مِنْ سِيَاقِ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ^٤، كَمَا أَخَذَ هُنَا مِنَ الْمُحَرَّرِ^٥ الْخِلَافَ وَهُوَ صَحِيحٌ فَإِنَّ الْوُجُوبَ مَنْقُولٌ عَنْ فَتَاوَى الْقَفَالِ^٦.

يجب للزوجة على زوجها متاع البيت:

(وَلَهَا) عَلَيْهِ (آلَاتُ أَكْلِ^٧ وَشُرْبِ وَطَبْخِ كَقَدْرِ وَقَصْعَةٍ^٨ وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ^٩ وَنَحْوَهَا) كَمِغْرَفَةٍ.

إعداد مسكن الزوجية حق واجب على الزوج ١٠:

(وَمَسْكَنٌ) أَيُّ وَلَهَا عَلَيْهِ تَهْيِئَةُ مَسْكَنِ (يَلِيقُ بِهَا^{١١}) عَادَةً مِنْ دَارٍ أَوْ حُجْرَةٍ أَوْ غَيْرِهِمَا. (وَلَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِلْكَهُ) بَلْ يَجُوزُ كَوْنُهُ مُسْتَأْجَرًا وَمُسْتَعَارًا^{١٢}.

للزوجة خادمة إن كانت ممن يُخدم مثلها في بيت أبيها:

(وَعَلَيْهِ لِمَنْ يَلِيقُ بِهَا خِدْمَةُ نَفْسِهَا إِخْدَامُهَا)^١، لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشِرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا، وَالْعَبْرَةُ فِي ذَلِكَ^٢ بِحَالِهَا فِي بَيْتِ أَبِيهَا^٣ مَثَلًا دُونَ أَنْ تَرْتَفَعَ بِالْإِنْتِقَالِ إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا (بَحْرَةٍ

^١ الحيض والاحتلام.

^٢ يجب ثمن ماء الغسل من الحيض لكثرة وقوع الحيض، وفي عدم إيجابه إجحاف بها.

^٣ كتاب روضة الطالبين للإمام النووي

^٤ سبقت ترجمته

^٥ كتاب المحرر لأبي القاسم عبد الكريم بن محمد الرافعي.

^٦ سبقت ترجمته

^٧ يجب للزوجة متاع البيت من آلات الأكل ونحوها مما لا غنى عنه كمغرفة ويعتبر فيها عدة أمثالها كخزف أو خشب أو نحاس أو صيني أو غيره وما تغسل فيه ثيابها لأن المعيشة لا تتم بدون ذلك فكان من المعاشرة بالمعروف.

^٨ القصعة: بفتح القاف معروفة، وهي ما تشبع العشرة، والجمع قصاع

^٩ الجرة بالفتح إناء معروف يصنع من الخزف والجمع جرار

^{١٠} يجب للزوجة مسكن لأن المطلقة يجب لها ذلك لقوله تعالى: {أَسْكُنُوهُنَّ} [الطلاق: ٦]. فالزوجة أولى، ولقوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]. ومن المعروف أن يسكنها بمسكن، ولأنها تحتاج إليه للاستئجار عن العيون عند التصرف والاستمتاع، ويقمها من الحر والبرد، فوجب عليه كالكسوة. ويعتبر ذلك بيساره وإعساره وتوسطه.

^{١١} قوله "يليق بها" وفارق اعتبار غيره بالزوج لأنه إمتاع وغيره تمليك، ولأنه يمكنها إبداله بخلاف المسكن

^{١٢} قوله "ومستعاراً" ومنه ما لو سكن معها في ملكها أو ملك أبيها، فإن سكن في ذلك بغير إذن لزمته الأجرة.

(بِحَرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ بِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَنْ صَحِبَتْهَا مِنْ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ لِيُخْدَمَ) إِنْ رَضِيَ بِهَا^١ (وَسِوَاءَ فِي هَذَا مُوسِرٌ وَمُعْسِرٌ وَعَبْدٌ) وَمُكَاتَبٌ^٢

وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهَا بِنَفْسِهِ فِي الْأَصَحِّ لِأَنَّهَا تَسْتَحِي مِنْهُ، وَتَتَغَيَّرُ بِذَلِكَ كَصَبِّ الْمَاءِ عَلَيْهَا وَحَمْلِهِ إِلَيْهَا لِلْمُسْتَحَمِّ أَوْ لِلشَّرْبِ وَنَحْوِ ذَلِكَ^٣. وَلَهُ أَنْ يَفْعَلَ مَا لَا تَسْتَحِي مِنْهُ قَطْعًا^٤ كَالْكُنْسِ وَالطَّبْخِ وَالْعَسَلِ.

(فَإِنْ أَخْدَمَهَا بِحَرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بِأَجْرَةٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُهَا) أَيُّ غَيْرِ الْأُجْرَةِ (أَوْ بِأَمْتِهِ أَنْفَقَ عَلَيْهَا بِالْمَلِكِ أَوْ بِمَنْ صَحِبَتْهَا لَزِمَهُ نَفَقَتُهَا)^٥ وَلِزْوَمِ نَفَقَتِهَا تَقَدَّمَ فَهُوَ مُكْرَرٌ (وَجِنْسُ طَعَامِهَا) أَيُّ الْمَصْحُوبَةِ (جِنْسُ طَعَامِ الزَّوْجَةِ)^٦، وَقَدْ سَبَقَ (وَهُوَ) فِي الْقَدْرِ^٧ (مُدٌّ عَلَى مُعْسِرٍ) كَالْمَخْدُومَةِ لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَقُومُ بِدُونِهِ غَالِبًا (وَكَذَا مُتَوَسِّطٌ) عَلَيْهِ مُدٌّ (فِي الصَّحِيحِ)^٨

^١ يجب علي الزوج إعدام زوجته الحرة التي لا يليق بها خدمة نفسها بأن كانت ممن تُخدم في بيت أبيها مثلا لقوله تعالى {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩] ومن المعاشرة بالمعروف أن يقيم لها من يخدمها، وذلك إما بحرة أو أمة أو مستأجرة، أو بالإنفاق على من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة لحصول المقصود بجميع ذلك.

^٢ أي في كونها ممن يليق بها أو تخدم نفسها

^٣ قوله "في بيت أبيها" أي كون مثلها يخدم عادة في بيت أبيها، وإن لم تخدم بالفعل لبخل من أبيها.

^٤ كلام المصنف يقتضي تعيين الإناث للإعدام وليس مرادا، فيجوز كون الخادم صبيا مميّزا مراهقا، أو محرما، أو مملوكا لها، أو ممسوحا، ولا يجوز بكبير ولا شيخ لتحريم النظر، ولا بذمية لمسلمة إذ لا تؤمن عداوتها الدينية ولتحريم النظر، وهذا في الخدمة الباطنة. أما الظاهرة كقضاء الحوائج من السوق فيتولاها الرجال وغيرهم.

ويُفهم من كلامه أيضا أنه لا يلزم أكثر من واحدة وإن كانت عاداتها الأكثر وهو كذلك إلا لنحو مرض لا يكفي فيه واحدة مثلا.

^٥ ويستوي وجوب الإعدام الزوج الموسر والمتوسط والمعسر) والمكاتب والعبد كسائر المون لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف المأمور بها.

^٦ ويفهم من قول المصنف "إعدامها" أن الزوج لو قال: أنا أخدمها بنفسني ليسقط عني مؤنة الخادم لم يلزمها الرضا به، ويجوز ذلك إذا رضيت بفعله.

^٧ يجوز له فعل ما لا تستحي منه قطعاً برضاها، ولا تجبره عليه ولا تمنعه منه

^٨ فإن كانت المصحوبة مملوكة للزوجة ملكت نفقتها كما تملك نفقة نفسها، وإن كانت المصحوبة حرة ملكت المصحوبة نفقة نفسها كما تملك الزوجة نفقة نفسها

^٩ جنس طعام خادم الزوجة جنس طعام الزوجة إذ من المعروف أن لا تخصص عن خادماتها.

^{١٠} وفي وجه يرجع في نفقة الخادم إلى رأي الحاكم إذ لا أصل لتقديرها في الشرع.

^{١١} الصحيح: لفظ للترجيح بين وجوه الأصحاب، ويستعمل حين يكون المقابل وجها ضعيفا أو واهيا، وذلك لضعف مدركه.

وَمُوسِرٌ مُدٌّ وَثُلُثٌ^١ اِغْتِبَارًا، بِثُلُثِي نَفَقَةِ الْمَخْدُومَةِ فِيهِمَا وَقِيلَ عَلَى الْمُتَوَسِّطِ مُدٌّ وَثُلُثٌ كَالْمُوسِرِ، وَقِيلَ وَسُدُسٌ لِيَحْصُلَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَرَاتِبِ فِي الْخَادِمَةِ كَالْمَخْدُومَةِ وَقِيلَ عَلَى كُلِّ مِنَ الثَّلَاثَةِ مُدٌّ فَقَطُّ

(وَلَهَا) أَيْضًا (كِسْوَةٌ تَلِيْقُ بِحَالِهَا)^٢ مِنْ قَمِيصٍ وَمِقْنَعَةٍ^٣ وَخُفٍّ وَمِلْحَفَةٍ لِحَاجَتِهَا إِلَى الْخُرُوجِ وَجِبَّةٍ فِي الشِّتَاءِ لَا سِرَاوِيلَ عِنْدَ الْجُمُهورِ. وَيَجِبُ لَهَا مَا تَفْرِشُهُ وَمَا تَتَّعَى بِهِ كَقِطْعَةٍ لِبَدٍ وَكِسَاءٍ فِي الشِّتَاءِ وَبَارِيَةٍ فِي الصَّيْفِ وَمَخْدَةٍ، وَيَكُونُ ذَلِكَ دُونَ مَا يَجِبُ لِلْمَخْدُومَةِ جِنْسًا وَنَوْعًا.

(وَكَذَا) لَهَا (أُذْمٌ عَلَى الصَّحِيحِ) لِأَنَّ الْعَيْشَ لَا يَتِمُّ بِدُونِهِ، وَيَكُونُ مِنْ جِنْسِ أُذْمِ الْمَخْدُومَةِ وَدُونَهُ نَوْعًا وَقَدْرُهُ بِحَسَبِ الطَّعَامِ^٤، وَالثَّانِي لَا أُذْمَ لَهَا وَيُكْتَفَى بِمَا يَفْضُلُ عَنِ الْمَخْدُومَةِ (لَا آلَةٌ تَنْظِيفٍ)^٥ لِأَنَّ اللَّائِقَ بِهَا أَنْ تَكُونَ شَعْتَةً لِيَلَّا تَمْتَدَّ إِلَيْهَا الْأَعْيُنُ (فَإِنْ كَثُرَ وَسَخٌ وَتَأَذَّتْ^٦ بِقَمَلٍ وَجَبَ أَنْ تَرْفَعَهُ^٧) بِمَا يُزِيلُ ذَلِكَ مِنْ مُشْطٍ وَدُهْنٍ وَغَيْرِهِمَا^٨.

^١ لأن نفقة المخدمومة مدان وهذه تابعة لها فلا تساويها، ولا يمكن إيجاب مد ونصف لثلا يساوي بينها وبين نفقة المتوسط.

^٢ وللخادمة كسوة تليق بحالها ولو على متوسط ومعسر من قميص ومقنعة وخف ورداء للخروج صيفا وشتاء، حرا كان الخادم أو رقيقا اعتاد كشف الرأس أم لا لاحتياجه إلى ذلك، ومحل وجوب الخف والرداء للخادم إن كان أنثى أما الخادم الذكر فلا، لاستغنائه عنه، ولا يجب للخادم سراويل على أرجح الوجهين بخلاف المخدمومة فإنه يجب لأنه للزينة وكمال الستر، ويجب للخادم ذكرا كان أو أنثى جبة للشتاء بحسب العادة، ويجب له ما يفرشه وما يتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وبارية في الصيف ومخدة، ويكون ذلك دون ما يجب للمخدمومة جنسا ونوعا، ويفاوت فيه بين الموسر وغيره.

^٣ مقنعة: ما يستر الرأس والعنق.

^٤ البارية: نوع من الفرش ينسج من القصب كالحصير.

^٥ قوله "وقدره بحسب الطعام" فيكون بقدر ثلثي ما يجب للمخدمومة كما في النفقة.

^٦ كمشط ودهن لأنها تراد للترتين، والخادم لا يترين. بل اللائق بحالها عكس ذلك لثلا تمتد إليها العين.

^٧ قوله "وتأذت" أي الخادمة الأنثى ومثلها الذكر.

^٨ أي تنعم بأن يعطيها ما يزيل ذلك.

^٩ يتضح مما سبق أن نفقة الخادمة مساوية لنفقة المخدمومة في الجنس والنوع وناقصة في القدر، وأن الأدم مساو لها في الجنس وناقص في القدر والنوع. وأن الكسوة مساوية لها في القدر لكونها بالكفاية وناقصة في الجنس والنوع.

(وَمَنْ تَخْدُمُ نَفْسَهَا فِي الْعَادَةِ^١ إِنْ اِحْتَاَجَتْ إِلَى خِدْمَةٍ لِمَرَضٍ أَوْ زَمَانَةٍ^٢ وَجَبَ إِخْدَامُهَا) كَمَا ذَكَرَ حُرَّةٌ كَانَتْ أَوْ أَمَةً (وَلَا إِخْدَامَ لِرَقِيقَةٍ^٣) حَيْثُ لَا حَاجَةَ لِنَقْصِهَا، جَمِيلَةٌ كَانَتْ أَمْ لَا، (وَفِي الْجَمِيلَةِ وَجْهٌ) لِجَرَيَانِ الْعَادَةِ بِإِخْدَامِهَا.

(وَيَجِبُ فِي الْمُسْكَنِ إِمْتَاعٌ^٤) لَا تَمْلِكُ، كَمَا تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ كَوْنُهُ مِلْكَهُ (و) فِي (مَا يُسْتَهْلَكُ كَطَعَامٍ تَمْلِكُ)^٥ كَالْكَفَّارَةِ وَالْحَقِّ بِهِ نَحْوُهُ كَأَدَمٍ وَدُهْنٍ (وَتَتَصَرَّفُ فِيهِ) أَيُّ فِيمَا يُسْتَهْلَكُ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ لِمِلْكِهَا لَهُ

(فَلَوْ قَتَرْتَ بِمَا يَضُرُّهَا^٦ مَنَعَهَا) مِنْ ذَلِكَ^٧، وَيُمْلِكُهَا أَيْضًا نَفَقَةُ مَصْحُوبَتِهَا الْمَمْلُوكَةِ لَهَا أَوْ الْحُرَّةِ وَلَهَا أَنْ تَتَصَرَّفَ فِي ذَلِكَ وَتَكْفِيَهَا مِنْ مَالِهَا.

(وَمَا دَامَ نَفْعُهُ كَكِسْوَةٍ وَظُرُوفٍ طَعَامٍ وَمُشْطٍ تَمْلِكُ)^٨ كَالنَّفَقَةِ. (وَقِيلَ إِمْتَاعٌ) لِلِانْتِفَاعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ كَالْمُسْكَنِ وَالْخَادِمِ فَيَجُوزُ كَوْنُهُ مُسْتَأْجَرًا وَمُسْتَعَارًا عَلَى هَذَا دُونَ الْأَوَّلِ

(وَتُعْطَى الْكِسْوَةُ أَوَّلَ شِتَاءٍ وَصَيْفٍ) مِنْ كُلِّ سَنَةٍ^٩، وَمَا يَبْقَى سَنَةً فَأَكْثَرُ كَالْفُرْشِ وَجَبَّةِ الْحَرِيرِ يُجَدِّدُ وَقْتُ تَجْدِيدِهِ عَلَى الْعَادَةِ (فَإِنْ تَلَفَتْ فِيهِ) أَيُّ فِي الشِّتَاءِ أَوْ الصَّيْفِ أَيُّ قَبْلَ

^١ ومن تخدم نفسها في العادة ليس لها أن تتخذ خادما وتنفق عليه من مالها إلا بإذن زوجها فإن احتاجت حرة كانت أو أمة إلى خدمة لمرض بها أو زمانة وجب إخدامها لأنها لا تستغني عنه، ولا إخدام حال الصحة لزوجة رقيقة سواء كانت كاملة الرقم أم مبعوضة لأن العرف أن تخدم نفسها جميلة كانت أم لا، وفي الجميلة وجه: يوجب إخدامها لجريان العادة به.

^٢ الزَّمن: المبتلى وقد زمن زمانة علي وزن علم وجمع الزمن الزماني.

^٣ أي من فيها رق.

^٤ لنقصها عن الحرية وبه يرد على الوجه القائل بوجوب إخدام الجميلة.

^٥ لأنه مجرد انتفاع كالخادم

^٦ يجب في ما يستهلك لعدم بقاء عينه كطعام وأدم ودهن ولحم وزيت تملك، ولو بلا صيغة فيكفي أن ينوي ذلك عما يستحقه عليه، سواء أعلمت نيته أم لا كالكفارة.

^٧ أويضر الزوج أويضرهما أو الخادم.

^٨ إذا قترت الزوجة بعد قبض نفقتها بما يضرها بأن ضيق على نفسها منعها زوجها من ذلك، وكذا لو لم يضرها ولكن ينفره عنها لحق الاستمتاع.

^٩ ما دام نفعه مع بقاء عينه، ككسوة وفرش وظروف طعام وآلة التنظيف ومشط تملك في الأصح لأن الله تعالى جعل كسوة الأهل أصلا للكسوة في الكفارة والطعام والطعام تملك فيها بالاتفاق وكذا الكسوة فوجب هنا مثله، وقيل: هو إمتاع كالمسكن والخادم بجامع الانتفاع مع بقاء العين بخلاف الطعام.

مُضَيِّهِ، (بِلا تَقْصِيرٍ^٢ لَمْ تُبَدَّلْ إِنْ قُلْنَا تَمْلِكُ) فَإِنْ قُلْنَا إِمْتَاعٌ أُبْدِلَتْ^٣، (فَإِنْ مَاتَتْ فِيهِ لَمْ تُرَدْ) عَلَى التَّمْلِكِ، وَتُرَدُّ عَلَى الْإِمْتَاعِ (وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مُدَّةٌ فَدَيْنٌ) عَلَى التَّمْلِكِ وَلَا شَيْءٌ عَلَى الْإِمْتَاعِ^٤.

موجبات النفقة وموانعها:

فَضْلُ: (الْجَدِيدُ^٥ أَنَّهَا) أَيْ النِّفْقَةُ^٦ (تَجِبُ) يَوْمًا فَيَوْمًا (بِالْتَّمَكِينِ^٧ لَا الْعَقْدِ^٨) وَالْقَدِيمُ^٩ تَجِبُ بِالْعَقْدِ وَتُسْتَقَرُّ بِالْتَّمَكِينِ فَلَوْ امْتَنَعَتْ مِنْهُ سَقَطَتْ (فَإِنْ اخْتَلَفَا فِيهِ) أَيْ فِي التَّمَكِينِ (صَدَّقَ) عَلَى الْجَدِيدِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَصُدِّقَتْ عَلَى الْقَدِيمِ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ مَا وَجَبَ^{١٠}.

^١ تعطى الزوجة الكسوة أول فصل الشتاء وأول فصل الصيف لقضاء العرف بذلك ولأنه وقت الحاجة إليها. هذا إن وافق النكاح أول الفصل وإلا وجب إعطاؤها في أول كل ستة أشهر من حين الوجوب، هذا في كسوة البدن،

أما ما يبقى منه كالفرش والبسط فتجدد في وقتها وذلك كل ما جرت العادة بتجديده

^٢ قوله "بلا تقصير" ليس شرطاً لعدم الإبدال، فإنها مع التقصير أولى أن لا تبدل.

^٣ إذا أعطى الزوج الكسوة أول فصل مثلاً ثم تلفت في أثناء ذلك الفصل بلا تقصير) من الزوجة لم تبدل إن قلنا بالأصح إنها تملك لأنه وفاها ما عليه كالنفقة إذا تلفت في يدها، وإن قلنا بمقابل الأصح من أنها إمتاع أُبدلت.

^٤ إذا مات الزوج أو أبانها بطلاق أو غيره أو ماتت في أثناء الفصل لم تُرد على القول بأنها تملك لأنه دفعها وهي واجبة عليه كما في نفقة اليوم، فإن كسوة الفصل كنفقة اليوم، وترد على القول بأنها إمتاع، وقيل: ترد مطلقاً لأنها لمدة لم تأت كنفقة المستقبل.

^٥ الجديد: ما قاله الإمام الشافعي بمصر، وأودعه كتابيه الأم والرسالة الجديدة.

^٦ قوله "أي النفقة" لو قال أي المؤن لكان أولى ليشمل الأدم والكسوة وغيرهما

^٧ تجب النفقة وتوابعها بالتمكين التام الناشئ عن العقد لأنها سلمت ما ملك عليها فتستحق ما يقابله من الأجرة، ولا يرد نحو وطاء الشبهة ومنه النكاح الفاسد بعد علمه بالفساد لا قبله..

^٨ ولا تجب النفقة بالعقد لأن النبي ﷺ تزوج عائشة ودخل بها بعد سنين ولم يقل أنه أنفق عليها قبل الدخول ولو كان حقاً لها لساقه إليها.

^٩ القديم: ما قاله الإمام الشافعي بالعراق أو قبل انتقاله إلى مصر وهو خلاف الجديد، وقد رجع الشافعي عن القديم وقال عنه: «لا أجعل في حل من رواه عني»، وإذا كان في المسألة قولان قديم وجديد فالجديد هو الصحيح وعليه العمل والقديم مرجوع عنه.

^{١٠} إذا اختلف الزوجان في التمكن فقالت: مكنت في وقت كذا وأنكر ولا بينة صدق الزوج لأن الأصل عدم التمكن وعليها البينة وهذا تفرع على الجديد، فإن قلنا بالقديم فالقول قولها لأن الأصل استمرار ما وجب بالعقد وهو يدعي السقوط فعليه البيان.

(فَإِنْ لَمْ تَعْرِضْ عَلَيْهِ مُدَّةً)، وَهُوَ سَأَتِ عَنْ الطَّلَبِ أَيْضًا (فَلَا نَفَقَةَ فِيهَا) عَلَى الْجَدِيدِ (لِإِتِّفَاعِ التَّمَكِينِ)، وَتَجِبُ نَفَقَةُ تِلْكَ الْمُدَّةِ عَلَى الْقَدِيمِ إِذْ لَا مُسْقِطَ، (وَإِنْ عَرَضَتْ) عَلَيْهِ كَأَنْ بَعَثَتْ إِلَيْهِ أَنِّي مُسَلِّمَةٌ نَفْسِي إِلَيْكَ وَالتَّغْرِيعُ عَلَى الْجَدِيدِ، وَهِيَ عَاقِلَةٌ بِالْغَةِ، (وَجَبَتْ) نَفَقَتُهَا (مِنْ بُلُوغِ الْخَبَرِ) لَهُ^١

(فَإِنْ غَابَ) أَيْ كَانَ غَائِبًا عَنْ بَلَدِهَا وَرَفَعَتْ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ مُظَهِّرَةً لَهُ التَّسْلِيمَ. (كَتَبَ الْحَاكِمُ^٢ لِحَاكِمِ بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ) الْحَالُ (فَيَجِيءُ) لَهَا يَتَسَلَّمُهَا (أَوْ يُوكِّلُ) مَنْ يَجِيءُ لَهَا يَتَسَلَّمُهَا، وَتَجِبُ النَّفَقَةُ مِنْ وَقْتِ التَّسْلِيمِ وَيَكُونُ الْمَجِيءُ بِنَفْسِهِ أَوْ وَكِيلِهِ حِينَ عِلْمِهِ بِالْحَالِ مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ، (فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ) مَا ذَكَرَ (وَمَضَى زَمَنٌ وَصُولِهِ) إِلَيْهَا (فَرَضَهَا الْقَاضِي)^٣ فِي مَالِهِ وَجَعَلَ كَالْمُسَلِّمِ لَهَا لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضِ الْبُغْوَئِيُّ وَغَيْرُهُ، لِلرَّفْعِ إِلَى الْحَاكِمِ وَكَتَبَهُ بَلَنَ قَالُوا تَجِبُ النَّفَقَةُ مِنْ حِينَ يَصِلُ الْخَبَرُ إِلَيْهِ، وَيَمُضِي زَمَانٌ إِمَّاكَانِ الْقُدُومِ عَلَيْهَا حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ^٤ تَبَعًا لِلشَّرْحِ^٥

(وَالْمُعْتَبَرُ فِي مَجْنُونَةٍ وَمَرَاهِقَةٍ عَرَضُ وَلِيٍّ) لَهُمَا^٦ وَلَا عِبْرَةَ بَعْرِضِهِمَا أَنْفُسَهُمَا عَلَى الزَّوْجِ. نَعَمْ لَوْ سَلِمَتْ الْمَرَاهِقَةُ نَفْسَهَا فَتَسَلَّمَهَا الزَّوْجُ وَنَقَلَهَا إِلَى دَارِهِ وَجَبَتْ النَّفَقَةُ

سقوط النفقة بالنشوز:

^١ إن لم تعرض عليه زوجته مدة مع سكوته عن طلبها ولم تمتنع فلا نفقة لها في هذه المدة على الجديد لعدم التمكين، وتجب على القديم. وعلى الجديد إن عرضت عليه وهي عاقلة مع حضوره في بلدها كان بعثت إليه تخبره أنني مسلمة نفسي إليك فاختر أن أتيك حيث شئت أو تأتي إلي وجبت نفقتها من حين بلوغ الخبر له لأنه حينئذ مقصر.

^٢ إذا الزوج غاب عن بلدها قبل عرضها إليه ورفعت الأمر إلى الحاكم مظهرة له التسليم كتب الحاكم وجوباً لحاكم بلده إن عرف محله ليعلمه الحال فيجيء الزوج لها يتسلمها أو يوكل من يجيء يتسلمها له أو يحملها إليه، وتجب النفقة من وقت التسليم.

^٣ إن لم يفعل شيئاً من الأمرين مع إمكان المجيء أو التوكيل ومضى زمن وصوله فرضها القاضي، وصورة الفرض: أن تمضي إلى لحاكم وتظهر له التسليم والطاعة بعد ثبوت الزوجية عنده فيكتب إلى حاكم بلد الزوج بذلك، فإذا أعلمه.. فقد حصل الغرض هذا إذا عرف مكانه، فإن لم يعرف كتب الحاكم إلى حكام البلاد التي تردها القوافل من تلك البلدة في العادة وأخذ منها كفيلاً بما تصرفه لاحتمال وفاته أو طلاقه.

^٤ حكاها النووي في روضة الطالبين

^٥ فتح العزيز شرح الوجيز للرافعي

^٦ المعتبر في زوجة مجنونة ومراهقة عرض ولي لهما على أزواجهما لأنه المخاطب بذلك

(وَتَسْقُطُ) ^١ النَّفَقَةُ ^٢ (بِشُؤْرِ) أَيِ خُرُوجٍ عَنِ طَاعَةِ الزَّوْجِ ^٣. (وَلَوْ بِمَنْعٍ لِّمَسِّ بِلَا عُدْرِ) ^٤ أَيِ تَسْقُطُ نَفَقَةُ كُلِّ يَوْمٍ بِالنُّشُوزِ بِلَا عُدْرِ فِي كُلِّهِ، وَكَذَا فِي بَعْضِهِ فِي الْأَصَحِّ ^٥ وَنُشُوزِ الْمَجْنُونَةِ وَالْمَرَاهِقَةِ كَالْعَاقِلَةِ الْبَالِغَةِ.

(وَعَبَالَةِ زَوْجٍ) أَيِ كَبَرِ آتِيهِ بِحَيْثُ لَا تَحْمِلُهَا الزَّوْجَةُ، (أَوْ مَرَضٍ) بِهَا (يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ عُدْرٍ) ^٦ فِي النُّشُوزِ عَنِ الْوَطْءِ ^٧

(وَالْخُرُوجُ مِنْ بَيْتِهِ بِلَا إِذْنٍ) مِنْهُ (نُشُوزٌ) ^٨ لِأَنَّ لَهُ عَلَيْهَا حَقَّ الْحَبْسِ فِي مُقَابِلَةِ وَجُوبِ النَّفَقَةِ، (إِلَّا أَنْ يُشْرِفَ عَلَى انْهَادٍ) ^٩ فَتَخْرُجُ خَوْفًا مِنَ الضَّرَرِ

(وَسَفَرُهَا) ^{١٠} بِإِذْنِهِ مَعَهُ ^{١١} لِحَاجَتِهِ أَوْ لِحَاجَتِهَا، (أَوْ) وَحْدَهَا (لِحَاجَتِهِ لَا يُسْقُطُ) ^{١٢} النَّفَقَةُ (وَلِحَاجَتِهَا يُسْقُطُ فِي الْأَظْهَرِ) ^{١٣} لِانْتِفَاءِ التَّمَكُّينِ وَالثَّانِي لَا تَسْقُطُ لِإِذْنِهِ فِي السَّفَرِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَجْرَى الْقَوْلَيْنِ فِي سَفَرِهَا لِحَاجَتِهَا مَعَهُ.

^١ المراد بالسقوط عدم الوجوب

^٢ تسقط النفقة وبقية المؤن

^٣ قوله "خروج عن طاعة الزوج" وإن لم تخرج من بيته أو قدر على تسلمها، فإذا استمتع بها حالة النشوز لم تسقط نفقتها.

^٤ بمنع لمس أو غيره من مقدمات الوطء، ونبه المصنف باللمس على أدنى درجات الاستمتاع فليفهم أن ما فوقه من باب أولى

^٥ تسقط نفقة كل يوم بنشوز وذلك بخروج المرأة عن طاعة الزوج بعد التمكين والعرض لأنها تجب بالتسليم فتسقط بالمنع.

^٦ إذا نشزت المرأة بعض النهار فالأصح: سقوط نفقتها كما لو نشزت كل اليوم، والثاني: تستحق بقسطه، وبه قطع المصنف في كتاب روضة روضة الطالبين.

^٧ وكبر آلة الزوج بحيث لا تحتلمها الزوجة أو مرض بها يضرها معه الوطء عذر في منعها من وطئه فتستحق النفقة مع منع الوطء لعذرها إذا كانت عنده لحصول التسليم الممكن، ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه.

^٨ قوله "عن الوطء" لا عن الاستمتاع

^٩ والخروج من بيته بلا إذن نشوز سواء كان الزوج حاضراً أم غائباً، وسواء كان لسفر عبادة كالجهاد أو للاعتكاف أو غيرهما؛ لمخالفتها الواجب عليها.

^{١٠} إلا أن يشرف البيت على انهدام فليس بنشوز للعذر، وكذا لو كان المنزل لغير الزوج فأخرجت منه، أو أكرهت على الخروج من بيته ظلماً، أو تخربت المحلة بغرق أو حرق وبقي البيت مفرداً، أو خافت على نفسها، وغير ذلك مما يعد الخروج به عذراً.

^{١١} خرج بالسفر خروجها في البلد ولو لصناعة بإذنه أو علم رضاه فليس مسقطاً.

^{١٢} قوله "بإذنه معه" لا حاجة لإذنه في سفرها معه، لكن إن نهاها عن السفر معه ولم ترجع فهي ناشزة

(وَلَوْ نَشَرْتَ فَعَابَ فَأَطَاعَتْهُ) كَأَنَّ خَرَجَتْ مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ ثُمَّ عَادَتْ بَعْدَ غَيْبَتِهِ، (لَمْ تَجِبْ) نَفَقَتُهَا زَمَنَ الطَّاعَةِ (فِي الْأَصَحِّ) لِإِنْفَاءِ التَّسْلِيمِ وَالتَّسَلُّمِ، وَالثَّانِي تَجِبُ لِعَوْدِهَا إِلَى الطَّاعَةِ (وَطَرِيقُهَا) عَلَى الْأَوَّلِ فِي الْوُجُوبِ^٣، (أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ) بَعْدَ رَفْعِهَا الْأَمْرَ إِلَيْهِ (كَمَا سَبَقَ) أَيَّ لِحَاكِمٍ بَلَدِهِ لِيُعْلِمَهُ بِالْحَالِ فَإِنْ عَادَ أَوْ وَكَيْلُهُ وَاسْتَأْنَفَ تَسْلِيمَهَا عَادَتْ النِّفَقَةُ وَإِنْ مَضَى زَمَنُ إِمْكَانِ الْعَوْدِ وَلَمْ يُوجَدْ عَادَتْ أَيْضًا

(وَلَوْ خَرَجَتْ فِي غَيْبَتِهِ لِرِيزَارَةٍ) لِأَهْلِهَا^٤ (وَنَحْوِهَا)، كَعِيَادَةِ لَهُمْ (لَمْ تَسْقُطْ)^٥ نَفَقَتُهَا مُدَّةَ ذَلِكَ قَالَهُ الْبَغَوِيُّ^٦

(وَالْأَظْهَرُ أَنَّ لَا نَفَقَةَ لِصَغِيرَةٍ) لَا تَحْتَمِلُ الْوُطْءَ لِتَعَذُّرِهِ لِمَعْنَى فِيهَا كَالنَّاشِزَةِ، وَالثَّانِي تَسْتَحِقُّهَا^٧ وَهِيَ مَعْدُورَةٌ فِي فَوَاتٍ وَطَنُهَا كَالْمَرِيضَةِ، وَالرِّتْقَاءِ^٨ وَفَرَّقَ الْأَوَّلُ^٩ بِأَنَّ الْمَرَضَ يَطْرُقُ وَيَزُولُ وَالرِّتْقَاءُ مَانِعٌ دَائِمٌ قَدْ رَضِيَ بِهِ، وَالْخِلَافُ حَيْثُ غَرِضَتْ عَلَى الزَّوْجِ أَوْ سَلِمَتْ لَهُ وَإِلَّا فَالْحُكْمُ مَا سَبَقَ فِي الْكَبِيرَةِ، وَشَمِلَتْ الْعِبَارَةُ مَا إِذَا كَانَ الزَّوْجُ صَغِيرًا أَيْضًا وَهُوَ أَوْلَى بِعَدَمِ الْوُجُوبِ مِنَ الْكَبِيرِ^{١٠}

^١ إذا سافرت المرأة مع زوجها بإذنه سواء كان السفر لحاجته أو لحاجتها لا تسقط نفقتها، وكذلك إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجته فلا تسقط

^٢ إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجتها تسقط نفقتها في الأظهر لأنها استبدلت عن تمكينها شغلا لها، والثاني: لا تسقط لإذنه في السفر.

^٣ وعلى الأول - القائل بعدم وجوب النفقة - طريقها في عود استحقاق النفقة لها بعد طاعتها في غيبة زوجها أن يكتب الحاكم بعد رفعها الأمر إليه كما سبق في ابتداء التسليم فيكتب لحاكم بلده ليعلمه بالحال، فإن عاد أو وكيله واستأنف تسلمها عادت النفقة، وإن مضى زمن إيمان العود ولم يعد ولا بعث وكيله عادت النفقة.

^٤ قوله "لأهلها" ولو غير محارم حيث لا ربة وخرج بهم الأجانب مطلقا.

^٥ إذا خرجت المرأة في غيبة زوجها لا على وجه النشوز بل لزيارة لأقاربها أو جيرانها ونحوها كعيادتهم وتعزيثهم لم تسقط نفقتها إذ لا يعد ذلك نشوزا عرفا.

^٦ سبقت ترجمته.

^٧ لها النفقة لأنها حبست عنده، وفوات الاستمتاع بسبب هي معذورة فيه فأشبهت المريضة والرتقاء، وهذا مبني على أن النفقة تجب بالعقد.

^٨ الرقيق: انسداد مدخل الذكر من الفرج بعظم زنجوه فلا يستطاع جماعها.

^٩ القائل بأنه لا نفقة لها.

^{١٠} إذا تزوج الصغير الصغيرة فلا نفقة عليه في الأظهر لأنها إذا لم تجب على الكبير بزواجه من الصغيرة فهو أولى

بعدم الوجوب من الكبير، وقال البعض بل العكس أولى فتجب على الصغير إذ في الكبير منفعة ممكنة حيل بينه وبينها بخلاف الصغير.

(و) الْأَظْهَرُ (أَنَّهَا تَجِبُ لِكَبِيرَةٍ عَلَى صَغِيرٍ) لَا يَتَأْتَى مِنْهُ الْجَمَاعُ، وَقَدْ عَرَضَتْ نَفْسَهَا عَلَى وَلِيِّهِ لِأَنَّهُ لَا مَانِعَ مِنْ جِهَتِهَا، وَالْمَانِعُ مِنْ جِهَتِهِ وَالثَّانِي لَا تَجِبُ وَهُوَ مَعْدُورٌ فِي قَوَاتِ الْجَمَاعِ عَلَيْهِ^١

حكم سقوط النفقة بإحرام امرأة:

(وَإِحْرَامُهَا بِحَجٍّ أَوْ عُمَرَةٍ بِلَا إِذْنٍ)^٢ مِنَ الزَّوْجِ (نُشُورٌ لَمْ يَمْلِكْ تَحْلِيلُهَا) بِأَنْ كَانَ مَا أُحْرِمَتْ بِهِ فَرَضًا عَلَى قَوْلٍ^٣ (وَإِنْ مَلَكَ) تَحْلِيلُهَا بِأَنْ كَانَ مَا أُحْرِمَتْ بِهِ تَطَوُّعًا أَوْ فَرَضًا عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي الْحَجِّ (فَلَا) أَيُّ فَلَيْسَ إِحْرَامُهَا بِنُشُورٍ، (حَتَّى تَخْرُجَ فَمُسَافِرَةً لِحَاجَتِهَا)^٤، فَإِنْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا فِي الْأَظْهَرِ كَمَا تَقَدَّمَ. أَوْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ فَنَاشِرَةٌ كَمَا تَقَدَّمَ أَنْ خُرُوجَهَا بِغَيْرِ إِذْنِهِ نُشُورٌ

(أَوْ) أُحْرِمَتْ بِمَا ذَكَرَ^٥. (بِإِذْنٍ فِيهِ الْأَصَحُّ لَهَا نَفَقَةٌ مَا لَمْ تَخْرُجْ)^٦ لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَالثَّانِي لَا نَفَقَةَ لِقَوَاتِ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا وَدْفِعَ^٧ أَنْ قَوَاتُهُ لِسَبَبِ إِذْنِ هُوَ فِيهِ، فَإِذَا خَرَجَتْ فَمُسَافِرَةٌ

^١ تجب لكبيرة على زوج صغير لا يمكن منه جماع في الأظهر إذا سلمت نفسها أو عرضت على وليه، إذ لا مانع من جهتها فأشبهه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب، والثاني: لا تجب عليه لأنها لا يُستمتع بها بسبب هو معذور فيه فلا يلزمه غرم.

^٢ وإحرام الزوجة بحج أو عمرة بلا إذن من الزوج نشور من وقت الإحرام إن لم يملك تحليلها مما أحرمت به - وهو في إحرامها بفرض على قول مرجوح - لأنها منعتة نفسها بذلك، فتكون ناشرة من وقت الإحرام وإن لم تخرج سواء أكان الزوج محرماً أم حلالاً، فإن ملك تحليلها - بأن كان ما أحرمت به تطوعاً أو فرضاً على الأظهر - فلا يكون إحرامها حينئذ نشوزاً فتستحق النفقة لأنها في قبضته وهو قادر على التحليل والاستمتاع، فإذا لم يفعل فهو المفوت على نفسه.

^٣ على قول هو مقابل الأظهر
^٤ وحيث قيل بوجوب نفقتها فتستمر النفقة حتى تخرج من بيتها فإذا خرجت فمسافرة لحاجتها فإن سافرت وحدها بإذنه سقطت نفقتها في الأظهر، أو معه استحققت النفقة أو بغير إذنه فناشرة لا نفقة لها.

^٥ حج أو عمرة.

^٦ قوله "ما لم تخرج" يقتضي أنها لو خرجت سقطت نفقتها وهو كذلك إن خرجت وحدها، فإن خرج معها لم تسقط.

^٧ أُجيب عن الوجه الثاني بأن قوات الاستمتاع تولد من إذنه.

لِحَاجَتِهَا، فَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مَعَهَا لَمْ تَسْقُطْ عَلَى الْمَذْهَبِ، وَإِلَّا فَتَسْقُطُ عَلَى الْأَظْهَرِ كَمَا تَقَدَّمَ^١ وَسَوَاءٌ خَرَجَتْ بِإِذْنِهِ أَمْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لَوْجُودِ الْإِذْنِ فِي الْإِحْرَامِ.

(وَيَمْنَعُهَا) الزَّوْجُ (صَوْمَ نَفْلِ)^٢ مُطْلَقٍ^٣ وَلَهُ قَطْعُهُ إِنْ شَرَعَتْ فِيهِ (فَإِنْ أَبَتْ) بِأَنْ فَعَلَتْهُ عَلَى خِلَافٍ مِنْهُ. (فَنَاشِزَةٌ فِي الْأَظْهَرِ)^٤ لَامْتِنَاعِهَا مِنَ التَّمَكُّنِ بِمَا فَعَلَتْهُ. وَالثَّانِي لَا لِأَنَّهَا فِي قَبْضَتِهِ وَلَهُ إِخْرَاجُهَا مِنْهُ مَتَى شَاءَ وَتَبَعَ الْمُحَرَّرُ^٥ فِي حِكَايَةِ الْخِلَافِ قَوْلَيْنِ وَهُوَ فِي الرُّوْضَةِ^٦ وَالشَّرْحَيْنِ^٧ وَجْهَانِ وَصَوَّبَ

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ قَضَاءَهُ لَا يَتَضَيَّقُ) كَأَنْ لَمْ يَعْتَدَ بِالْفِطْرِ وَقَدْ بَقِيَ مِنْ شَعْبَانَ أَكْثَرُ مِنَ الْفَائِتِ، (كَنْفَلٍ فَيَمْنَعُهَا)^٨ مِنْهُ إِلَى أَنْ يَتَضَيَّقَ وَلَهُ إِزْمَامُهَا الْفِطْرَ إِنْ شَرَعَتْ فِيهِ قَبْلَ التَّضَيُّقِ، فَإِنْ أَبَتْ فَكَمَا تَقَدَّمَ^٩. وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ كَالنَّفْلِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ وَعَلَى هَذَا فِي سُقُوطِ النِّفَقَةِ بِفِعْلِهِ

^١ كما تقدم في سفر المرأة بإذن من زوجها أو بغير إذنه، حيث بينا أنه إذا سافرت المرأة مع زوجها بإذنه سواء كان السفر لحاجته أو لحاجتها لا تسقط نفقتها، وكذلك إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجته فلا تسقط، إذا سافرت وحدها بإذنه لحاجتها تسقط نفقتها في الأظهر لأنها استبدلت عن تمكينها شغلا لها، والثاني: لا تسقط لإذنه في السفر.

^٢ علم من التقييد بالنفل أنه لا يمنعها صوم رمضان، ولا تسقط به النفقة، وهو كذلك بالاتفاق.

^٣ مراده بـ "نفل الصوم النفل المطلق كصوم الإثنين والخميس، أما رواتبه كعرفة وعاشوراء فليس له المنع منه على الصحيح، ولا تسقط به نفقتها كرواتب الصلاة.

^٤ يجوز للزوج منع زوجته من صوم نفل لأنه ليس بواجب عليها وحقه عليها متحتم، وله قطعه أيضا إذا شرعت فيه فإن أبوت وامتنعت من الفطر بعد أمره لها به فناشزة في الأظهر لامتناعها من التمكين وإعراضها عنه بما ليس بواجب، ولما روي عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ قال: (لا تصومن امرأة يوماً سوى شهر رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه) سنن الترمذي، والثاني: أنها لا تكون ناشزة لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء، أما النفل الراتب كعرفة، وعاشوراء فليس له منعها منه على الصحيح.

^٥ المحرر للرافعي.

^٦ روضة الطالبين للنووي.

^٧ الشرحين: هما الشرح الكبير للمسي فتح العزيز شرح الوجيز والشرح الصغير وهما للرافعي، وقد شرح فيهما كتاب الوجيز لأبي حامد الغزالي

^٨ الأصح أن قضاءه من صوم أو صلاة لا يتضيق بأن لم يجب فوراً كفطرها بعذر في رمضان والوقت متسع أو نامت عن الصلاة حتى خرج وقتها حكمه كنفل فيجوز له منعها منه ومن إتمامه لأنه على التراخي وحقه على الفور، والثاني: أنه ليس كالنفل فلا يمنعها منه، وبالأول قطع الأكثرون كما في الروضة.

^٩ فإن أبوت وامتنعت من الفطر بعد أمره لها به فناشزة في الأظهر لامتناعها من التمكين وإعراضها عنه بما ليس بواجب، والثاني: أنها لا تكون ناشزة لأنها في قبضته وله إخراجها منه متى شاء

وَجَهَانِ أَصْحُهُمَا فِي الرَّوْضَةِ السَّقُوطُ، أَمَّا الْأَدَاءُ وَالْقَضَاءُ الَّذِي يُصَيِّقُ^١ فَلَا تُمْنَعُ مِنْهُ وَتَجِبُ نَفَقَةُ زَمَانِهِ وَفِي وَجْهِ جَزَمَ بِهِ الْمُتَوَلَّى^٢ لَا تَجِبُ نَفَقَةُ قَضَاءٍ مَا تَعَدَّدَتْ فِيهِ بِالْفَطْرِ لَتَعْدِيهَا^٣

(و) الْأَصَحُّ (أَنَّهُ لَا مَنَعَ مِنْ تَعْجِيلِ مَكْتُوبَةٍ أَوَّلَ وَقْتِ) لَتَحُوزَ فَضِيلَةً أَوَّلَ الْوَقْتِ^٤ (وَسَنَنَ رَاتِبَةٍ^٥)^٦ لِتَأْكُدهَا بِخِلَافِ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ الْأَصَحُّ يُنْظَرُ إِلَى أَنَّهُ نَفْلٌ.

(فَرَعُ): صَوْمُ الْإِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ كَالنَّفْلِ الْمُطْلَقِ فَيَمْنَعُهَا مِنْهُ قَطْعًا وَصَوْمُ عَرَفَةَ وَعَاشُورَاءَ كَالرَّوَاتِبِ فَلَا يَمْنَعُهَا مِنْهُ فِي الْأَصَحِّ وَصَوْمُ النَّذْرِ الْمُنْشَأُ بِغَيْرِ إِذْنِهِ كَصَوْمِ النَّفْلِ فِيمَا تَقَدَّمَ فِيهِ.

مدى وجوب النفقة والكسوة للمعتدة:

(وَيَجِبُ لِلرَّجْعِيَّةِ^٧ الْمُؤْنُ^٨)^٩ مِنْ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ وَغَيْرِهِمَا لِبَقَاءِ حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَسُلْطَنَتِهِ، (إِلَّا مُؤْنَةً تَنْظُفُ)^{١٠} فَلَا تَجِبُ لَهَا لِمَتَنَاعِ الزَّوْجِ عَنْهَا وَسَوَاءٌ فِي الْوُجُوبِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ وَالْحَائِلُ^{١١} وَالْحَامِلُ

^١ أما ما يتضيق كالفطر تعدياً أو بعذر ولم يبق من شعبان إلا قدره أو أخرت الصلاة عن وقتها بلا عذر فليس له المنع منه والنفقة فيه واجبة على الأصح.

^٢ عبد الرحمن بن مأمون بن علي بن إبراهيم النيسابوري الشيخ أبو سعد المتولي تفقه بمرور على الفوراني وبمرور الروذ على القاضي الحسين وببخارا على أبي سهل الأبيوردي وبرع في الفقه والأصول والخلاف، أحد أصحاب الوجوه في المذهب وصنف التتمة ولم يكمله، وصنف كتاباً في أصول الدين وكتاباً في الخلاف ومختصراً في الفرائض، توفي ببغداد سنة ٤٧٨ هـ.

^٣ وكلام الرافعي مشعر بترجيح سقوط النفقة فيما تعدت فيه بالفطر.

^٤ الثاني: له المنع لاتساع وقت المكتوبة ووجوب حقه على الفور.

^٥ السنن الراتبة: هي السنن التي لها وقت معين سواء كانت مؤكدة أو غير مؤكدة

^٦ قوله "وسنن راتبة" هذا معطوف على الأصح فليس له المنع منها لأنها مكمله للفرائض.

والثاني: له المنع كالنفل المطلق.

^٧ الرجعية: من طلقها زوجها طليقة أو طلقتين ولم تنتهي عدتها.

^٨ مؤنة: اسم لما يتحمله الإنسان من ثقل النفقة التي ينفقها على من يليه من أهله وولده.

^٩ وتجب لرجعية حرة أو أمة حائل أو حامل المؤن من نفقة وكسوة وغيرهما لبقاء حبس الزوج لها وسلطنته عليها وقدترته على التمتع بها بالرجعة، ويستمر وجوبه لها حتى تقر هي بانقضاء عدتها بوضع الحمل أو بغيره فهي المصدقة في استمرار النفقة كما تصدق في بقاء العدة وثبوت الرجعة.

^{١٠} ولا تجب مؤنة تنظيف لامتناع الزوج عنها وانتقاء المعنى الذي وجبت لأجله.

^{١١} غير الحامل.

(فَلَوْ ظُنُنْتَ حَامِلًا فَأَنْتَفَقَ فَبَانَتْ حَائِلًا اسْتَرْجَعَ مَا دَفَعَ بَعْدَ عِدَّتِهَا) ^١ وَتُصَدَّقُ فِي قَدْرِ أَقْرَائِهَا ^٢ بِالْيَمِينِ إِنْ كَذَبَهَا وَإِلَّا فَلَا يَمِينٌ ^٣ (وَالْحَائِلُ الْبَائِنُ بِخُلْعٍ أَوْ ثَلَاثٍ لَا نَفَقَةٌ وَلَا كِسْوَةٌ) ^٤، لَهَا لِإِنتِفَاءِ سُلْطَنَةِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا.

(وَتَجِبَانِ لِحَامِلٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطَّلَاق ^٥، (لَهَا) ^٥ أَيْ لِنَفْسِهَا بِسَبَبِ الْحَمْلِ (وَفِي قَوْلِهِ لِلْحَمْلِ) ^٦ نَفْسِهِ وَهِيَ طَرِيقٌ فِي الْوُضُوءِ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ لَا يَتَغَذَّى بِغِذَائِهَا. (فَعَلَى الْأَوَّلِ) ^٧ لَا تَجِبُ لِحَامِلٍ عَنْ شُبْهَةِ أَوْ نِكَاحٍ فَاسِدٍ) وَتَجِبُ عَلَى الثَّانِي لَهَا عَلَى الْوَاطِئِ لِأَنَّ الْحَمْلَ لَهُ، (قُلْتُ) ^٨ لَا نَفَقَةٌ لِمُعْتَدَةٍ وَفَاءً وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ) ^٩ كَمَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ لِأَنَّهَا بَانَتْ، وَالْحَمْلُ الْقَرِيبُ يَسْقُطُ نَفَقَتُهُ بِالمَوْتِ

^١ إن ظننت - بضم أوله - المطلقة الرجعية حاملاً بولد فأنفق زوجها عليه فبانَتْ بعد إنفاقه حائلاً - غير حامل - وأقرت بانقضاء العدة استرجع ما دفع إليها من النفقة بعد انقضاء عدتها لأنه تبين أن ذلك ليس عليه.

^٢ القرء: الحيض

^٣ القول قولها في عدتها بيمينها إن كذبها. وإن صدقها فقول قولها بون يمين.

^٤ المعتدة الحائل البائن بخلع أو ثلاث طلاقات لا نفقة لها ولا كسوة قطعاً لزوال الزوجية فأشبهت المتوفى عنها.

^٥ تجب النفقة والكسوة لحامل للآية ولأنها مشغولة بمانه فهو مستمتع برحمها فسار كالاستمتاع بها في حال الزوجية إذ النسل مقصود بالنكاح كما أن الوطء مقصود به، والنفقة والكسوة للحامل نفسها وهو الأصح.

^٦ في قول قديم تجب النفقة والكسوة للحمل فقط لوجوب ذلك بوجود الحمل وعدمه بعدم الحمل وإنما صرف لها لتغذيته بغذائها.

^٧ فعلى الأول الأصح - وهو أن النفقة للحامل نفسها - لا تجب نفقة ولا غيرها لحامل عن وطء شبهة وهي غير مزوجة أو لحامل عن نكاح فاسد لأنه لا نفقة لها في حال التمكين فبعده أولى، وعلى الثاني تجب النفقة لأن الحمل له وتلزمه نفقته.

^٨ المصنف.

^٩ المعتدة المتوفى عنها زوجها وإن كانت حاملاً لما روى عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: (ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة) سنن الدارقطني، ولأنها إن كانت حائلاً فقد بانَتْ بالموت والبائن الحائل لا نفقة لها على الزوج في حياته فبعد موته أولى، وإن كانت حاملاً فإن قلنا: النفقة للحمل فقد سقطت لأن نفقة القريب تسقط بالموت، وإن قلنا: للحامل فوجهان: أحدهما: تسقط أيضاً لأنها كالحاضنة للولد ولا تجب نفقة الحاضنة بعد الموت.

(وَنَفَقَةُ الْعِدَّةِ مُقَدَّرَةٌ كَزَمَنِ النِّكَاحِ وَقِيلَ تَجِبُ الْكِفَايَةُ)^١ فَيَزَادُ وَيُنْقُصُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ وَالرَّاجِحِ فِي ارْوُضَةٍ وَأَصْلُهَا بِالْأَوَّلِ

(وَلَا يَجِبُ دَفْعُهَا قَبْلَ ظُهُورِ حَمْلٍ)^٢ سِوَاءٍ جُعِلَتْ لَهَا أَمْ لَهَا، (فَإِذَا ظَهَرَ وَجِبَ) دَفْعُهَا (يَوْمًا بِيَوْمٍ وَقِيلَ) إِنَّمَا يَجِبُ دَفْعُهَا (حِينَ تَضَعُ)^٣ فَتُدْفَعُ دَفْعَةً وَاحِدَةً وَالْأَوَّلُ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْحَمْلَ يُعْرَفُ وَهُوَ الْأَظْهَرُ، وَالثَّانِي عَلَى مُقَابِلِهِ، وَفِي الرُّوْضَةِ وَأَصْلُهَا حِكَايَةُ خِلَافِ الْمُسَائِلَتَيْنِ قَوْلَيْنِ

(وَلَا تَسْقُطُ) نَفَقَةُ الْعِدَّةِ (بِمُضِيِّ الزَّمَانِ عَلَى الْمَذْهَبِ)^٤ وَقِيلَ فِي الْحَامِلِ خِلَافَ مَبْنِيٍّ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَهَا أَوْ لِلْحَمْلِ إِنْ قُلْنَا بِالثَّانِي سَقَطَتْ لِأَنَّ نَفَقَةَ الْقَرِيبِ تَسْقُطُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.

مدي مشروعية فسخ النكاح للإعسار بالنفقة:

فَصْلٌ (أَعْسَرَ^٥ بِهَا) أَيَّ بِالنَّفَقَةِ كَأَنَّ تَلَفَ مَالُهُ أَوْ غُصِبَ. (فَإِنْ صَبَرَتْ)^٦ بِهَا بِأَنَّ أَنْفَقَتْ مِنْ مَالِهَا أَوْ مِمَّا اقْتَرَضَتْهُ، (صَارَتْ دَيْنًا عَلَيْهِ)^٧ وَإِلَّا فَلَهَا الْفَسْخُ عَلَى الْأَظْهَرِ)^٨ كَمَا تَفْسَخُ

^١ نفقة العدة مقدرة كنفقة زمن النكاح من غير زيادة ونقص لأنها من توابعه، وقيل: لا تقدر بل تجب الكفاية فتزاد وتنقص بحسب الحاجة، والراجح في الروضة وأصلها القطع بالأول

^٢ ولا يجب دفع النفقة قبل ظهور الحمل سواء جعلناها للحمل أم للحامل لأنها لم تتحقق سبب الوجوب.

^٣ إذا ظهر الحمل ببينة أو اعتراف الزوج أو تصديقه لها وجب دفع النفقة لها يوماً بيوم أي كل يوم علي الأظهر لقوله تعالى: {فَأَنْفَقُوا عَلَيْهِمْ حَتَّى يَضَعُوا حَمْلَهُمْ} [الطلاق: ٦] : ولأنها لو أخرت إلى الوضع لتضررت، وقيل: لا يجب دفعها يوماً بيوم بل حين تضع فتدفع لها جملة واحدة لأن الأصل البراءة حتى يتيقن السبب، والخلاف مبني على أن الحمل يعلم أم لا، والأول مبني على أن الحمل يعرف وهو الأصح وهو في الشرح للرافعي والروضة للنووي قولان وهو الصواب، والثاني على مقابله.

^٤ ولا تسقط نفقة العدة بمضي الزمان من غير إنفاق على المذهب وإن قلنا بأن النفقة للحمل لأنها هي التي تنتفع بها فتصير ديناً عليه، والطريق الثاني: البناء على الخلاف في أن النفقة لها أو للحمل؟ فإن قلنا لها لم تسقط كنفقة الزوجة، وإن قلنا للحمل سقطت كنفقة القريب.

^٥ أعسر الزوج ولو صغيراً أو مجنوناً.

^٦ إذا أعسر الزوج بنفقة زوجته المستقبلية كتلف ماله فإن صبرت بها وأنفقت على نفسها من مالها أو مما اقترضته صارت ديناً عليه وإن لم يقرضها القاضي كسائر الديون المستقرة.

^٧ صارت ديناً إن لم تمنع نفسها منه زمن الإعسار، فإن منعت نفسها منه لم تصير ديناً عليه.

^٨ إذا أعسر الزوج بالنفقة ولم تصبر فلها الفسخ على الأظهر وقطع به الأكثرون لقوله تعالى: {فِيمَسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩]، فإذا عجز عن الإمساك بالمعروف تعين التسريح بالإحسان، وقوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا}، وزوجة المعسر مستضرة فلم يكن له إمساكها، ولأنها إذا فسخت بالجب

بِالْجَبِّ^١ وَالْعَنَةِ^٢ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِأَنَّ الصَّبْرَ عَنِ الْإِسْتِمْتَاعِ أَسْهَلُ مِنَ الصَّبْرِ عَلَى النَّفَقَةِ،
وَالثَّانِي لَا فُسْخَ لَهَا لِأَنَّ الْمُعْسِرَ مُنْظَرٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى
مَيْسَرَةٍ}.^٣

(وَالْأَصَحُّ أَنْ لَا فُسْخَ) لَهَا (بِمَنْعِ مُوسِرٍ^٣ حَضَرَ أَوْ غَابَ) بِأَنْ لَمْ يُوقَفْهَا حَقُّهَا لِإِنْتِفَاءِ
الْإِعْسَارِ الْمُثْبِتِ لِلْفُسْخِ وَهِيَ مُتِمِّكِنَةٌ مِنْ تَحْصِيلِ حَقِّهَا بِالْحَاكِمِ^٤، وَالثَّانِي لَهَا الْفُسْخُ
لِتَضَرُّرِهَا بِالْمَنْعِ

(وَلَوْ حَضَرَ وَغَابَ مَالُهُ فَإِنْ كَانَ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ^٥) فَمَا فَوْقَهَا (فَلَهَا الْفُسْخُ^٦ وَإِلَّا) بِأَنْ كَانَ
دُونَهَا^٧ (فَلَا يُؤْمَرُ بِالْإِحْضَارِ)^٨ عَاجِلًا (وَلَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ^٩ بِهَا لَمْ يَلْزَمَهَا الْقَبُولُ)^{١٠}، لِمَا فِيهِ
مِنْ مَنَةِ التَّبَرُّعِ

والعنة فبالعجز عن النفقة أولى لأن البدن لا يقوم بدونها بخلاف الوطاء. والثاني: ليس لها الفسخ لعموم
قوله تعالى: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} [البقرة: ٢٨٠]، ولأنه إذا لم يثبت له الخيار بنشوزها
وعجزها عن التمكين. فكذا لا يثبت لعجزه عن مقابله.

^١ المجبوب: من قُطِعَ ذكره.

^٢ العنين: من لا يقدر على الجماع لأفة أصلية أو لمرض أو ضعف أو كبر سن فلا يصل إلى النساء أصلاً.

^٣ قول المصنف: "موسر" ليس بقيد فإنه لو غاب وجهل حاله في اليسار والإعسار فلا فسخ لأن السبب لم
يتحقق.

^٤ لأنه إذا كان حاضراً تتمكن من خلاص حقها منه بالسلطان بأن يلزمه بالحبس وغيره. وفي الغائب يبعث إلى حاكم
بلده إن كان موضعه معلوماً فيلزمه بدفع نفقتها. فإن لم يعرف موضعه بأن انقطع خبره فيه وجهان:
أحدهما: لها الفسخ والثاني: لا فسخ ما دام الزوج موسراً.

^٥ مسافة القصر: أربعة برد والبريد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال والميل أربعة آلاف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام
والقدمان ذراع. وهذا تحديد لمسافة القصر بالمساحة، وأما تحديدها بالزمان فهو سيريومين معتدلين أو
ليلتين معتدلتين أو يوم وليلة وإن لم يعتدلاً بسير الأثقال وهي الإبل المحملة مع اعتبار النزول المعتاد للأكل
والشرب والصلاة والاستراحة.

^٦ هذا إذا لم ينفق عليها بنحو استدانة، فإن أنفق عليها ولو باستدانة فلا فسخ لها

^٧ دون مسافة القصر

^٨ وإن كان ماله دون مسافة القصر فلا فسخ لها ويؤمر بالإحضار بسرعة لأن ما دون مسافة القصر كالحاضر في
البلد

^٩ قوله "رجل" ليس ولداً على والد لزمه إعفافه ولا والداً عن ولد في حجره فيلزمها القبول في ذلك ولا تفسخ

^{١٠} إذا تبرع رجل بالنفقة عن زوج معسر لم يلزمها القبول بل لها الفسخ وقيل: ليس لها الفسخ وبه أفتى الغزالي
لأن المنة على الزوج لا عليها، ولو سلمها المتبرع للزوج ثم سلمه الزوج لها فلا حق لها في الفسخ لأن
المنة على الزوج لا عليها لأنه ملكها بأخذها.

(وَقَدَّرْتُهُ عَلَى الْكَسْبِ^١ كَالْمَالِ)، فَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ كُلَّ يَوْمٍ قَدَرَ النَّفَقَةِ فَلَا خِيَارَ لَهَا^٢، فَإِنَّ النَّفَقَةَ هَكَذَا تَجِبُ وَلَوْ كَانَ يَكْسِبُ^٣ فِي يَوْمٍ مَا يَكْفِي لِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ لَا يَكْسِبُ فِي يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ثُمَّ يَكْسِبُ فِي يَوْمٍ مَا يَكْفِي لِلْأَيَّامِ الْمَاضِيَةِ، فَلَا خِيَارَ فَإِنَّهُ لَيْسَ بِمُعْسِرٍ وَلَا تَشَقُّ الْإِسْتِدَانَةُ لِمِثْلِ هَذَا التَّأخِيرِ الْيُسِيرِ.

(وَأَيْنَمَا تَفْسَخُ بِعَجْزٍ عَنْ نَفَقَةِ مُعْسِرٍ)^٤ فَلَوْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةِ الْمُوسِرِ أَوْ الْمُتَوَسِّطِ فَلَا خِيَارَ لِأَنَّ وَاجِبَهُ الْآنَ نَفَقَةُ الْمُعْسِرِ

الإعسار بالكسوة كالإعسار بالنفقة:

(وَالْإِعْسَارُ بِالْكَسْوَةِ كَهَوِّ النَّفَقَةِ) لِأَنَّ النَّفْسَ لَا تَبْقَى بِدُونِهِ، (وَكَذًا بِالْأُذْمِ وَالْمَسْكَنِ فِي الْأَصَحِّ)^٥ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهِمَا وَالتَّضَرُّرِ بَعْدَمِهُمَا، (قُلْتُ الْأَصَحُّ الْمُنْعُ فِي الْأُذْمِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ)^٦ لِقِيَاسِ النَّفْسِ بِدُونِهِ وَوَجْهَ الْمُنْعِ فِي الْمَسْكَنِ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَهُوَ بَعِيدٌ

حكم فسخ العقد للإعسار بالمهر:

(وَفِي إِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ أَقْوَالٌ^٧ أَظْهَرُهَا تَفْسُخُ^٨ قَبْلَ وَطْءٍ لَا بَعْدَهُ)، لِبَقَاءِ الْمُعْوَضِ قَبْلَ الْوُطْءِ وَتَلْفِهِ بَعْدَهُ كِبَقَاءِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ وَتَلْفِهِ، وَالثَّانِي تَفْسُخُ فِي الْحَالَتَيْنِ^٩ بِنَاءً فِي

^١ قوله "على الكسب" أي الحلال اللائق به فخرج بالحلال الكسب بالخمور وآلات الملاهي وبصناعاتها وبالكهانة والتنجيم، ونحو ذلك فلها الفسخ مع قدرته عليه، وباللائق غير اللائق كفعالة لذي هيئة وقيل لا عبرة بكونه لائقا به

^٢ قدرة الزوج على كسب المال كالقدرة عليه فلو كان يكسب كل يوم قدر النفقة لم فسخ لأنها هكذا تجب وليس عليه أن يدخر للمستقبل

^٣ قوله "فلو كان يكسب" لو قال فلو كان يقدر لكان أنسب بكلام المصنف لأن القادر إذا امتنع من الكسب لم يكن لها الفسخ لأنه كالموسر الممتنع

^٤ وللمرأة فسخ النكاح بعجز زوجها عن نفقة معسر حاضرة لأن الضرر يتحقق بذلك، فلو عجز عن نفقة موسر أو متوسط لم ينفسخ لأن نفقته الآن نفقة معسر فلا يصير الزائد دينا عليه، بخلاف الموسر أو المتوسط إذا أنفق مدا فإنها لا تفسخ ويصير الباقي دينا عليه.

^٥ قوله "والإعسار بالكسوة" أي بأقلها وهو ما لا يستغنى عنه كالقميص بخلاف نحو السراويل والفرش.

^٦ والإعسار بالأدم والمسكن كالإعسار بالنفقة في الأصح للحاجة إليهما لأنه يعسر الصبر على الخبز الذي بلا أدم، ولا بد للإنسان من مسكن يقيه من الحر والبرد. والثاني: لا فسخ بذلك.

^٧ يرى المصنف أن الأصح منع الفسخ في الإعسار بسبب الأدم بخلاف القوت، وهذا ما صححه الرافعي.

^٨ إعسار الزوج بالمهر أقوال: أظهرها تفسخ قبل وطء للعجز عن تسليم العوض مع بقاء المعوض فأشبه ما إذا لم يقبض البائع الثمن حتى حجر على المشتري بالفلس والمبيع باق بعينه، وهذا الفسخ على الفور ولا تفسخ

الثَّانِيَةِ عَلَى أَنَّ الْمَهْرَ فِي مُقَابَلَةِ جَمِيعِ الْوُطْئَاتِ، وَلَمْ تَسْتَوْفِ كِبَاءُ بَعْضِ الْمَبِيعِ فِي يَدِ الْمُفْلِسِ وَالثَّالِثُ لَا تَفْسُخُ فِي الْحَالَتَيْنِ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَيْسَ عَلَى الْأَعْوَاضِ حَتَّى تَفْسُخَ الْعَقْدَ بِتَعْدُّهِ.

لا فسخ للعقد إلا بالرفع للقاضي:

(وَلَا فُسْخَ حَتَّى يَثْبُتَ عِنْدَ قَاضٍ إِعْسَارُهُ) بِإِقْرَارِهِ أَوْ بَيِّنَةٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي، (فَيَفْسُخُهُ) بَعْدَ الثَّبُوتِ (أَوْ يَأْذُنُ لَهَا فِيهِ) وَلَيْسَ لَهَا مَعَ عِلْمِهَا بِالْعَجْزِ الْفُسْخُ قَبْلَ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي وَلَا بَعْدَهُ قَبْلَ إِذْنِ فِيهِ^٢

الإمهال ثلاثا لمن أعسر بالنفقة:

(ثُمَّ فِي قَوْلٍ يُنْجِزُ الْفُسْخَ) لِلْإِعْسَارِ بِالنَّفَقَةِ وَقَدْ وَجُوبِ تَسْلِيمِهَا وَهُوَ طُلُوعُ الْفَجْرِ وَلَا يُلْزَمُ الْإِمْهَالُ بِالْفُسْخِ، (وَالْأَظْهَرُ إِمْهَالُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ)^٤، لِيَتَحَقَّقَ عَجْزُهُ وَهِيَ مُدَّةٌ قَرِيبَةٌ يُتَوَقَّعُ فِيهَا الْقُدْرَةُ بِقَرْضٍ أَوْ غَيْرِهِ. (وَلَهَا الْفُسْخُ صَبِيحَةَ الرَّابِعِ) بِنَفَقَتِهِ (إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ نَفَقَتَهُ^٥) وَلَا فُسْخَ بِمَا مَضَى (وَلَوْ مَضَى يَوْمَانِ بِلَا نَفَقَةٍ وَأَنْفَقَ الثَّالِثَ وَعَجَزَ الرَّابِعَ بَنَتْ) عَلَى الْيَوْمَيْنِ وَفُسْخَتْ صَبِيحَةَ الْخَامِسِ، (وَقِيلَ تَسْتَأْنِفُ)^٦ الثَّلَاثَةَ فَلَا تَفْسُخُ إِلَّا صَبِيحَةَ السَّابِعِ.

بعده لتلف المعوض وصيرورة العوض ديناً في الذمة. والثاني: لا يثبت الفسخ مطلقاً؛ لأن النفس تقوم بدون المهر. والثالث: تفسخ مطلقاً سواء قبل الوطء أو بعده أما قبل الوطء فلما مر وأما بعده فلأن البضع لا يتلف حقيقة بالوطء.

^١ تفسخ في الأظهر سواء كان الإعسار بكل المهر أو بعضه وإن قبضت بعضه الآخر.

^٢ قبل الوطء وبعده

^٣ ولا فسخ بإعسار زوج بشيء مما تقدم من النفقة والكسوة والمسكن والمهر حتى يثبت عند قاض، أو محكم إعساره ببينة أو إقراره فلا بد من الرفع إلى القاضي كما في العنة لأنه محل اجتهاد، وبكفي علم القاضي إذا قلنا: يحكم بعلمه وحينئذ يفسخه بنفسه أو نائبه بعد الثبوت أو يأذن القاضي لها في الفسخ، وليس لها مع علمها بالعجز الفسخ قبل الرفع إلى القاضي ولا بعده قبل الإذن فيه.

^٤ لأن الزوج قد يتعسر عليه وجود النفقة لعوارض ثم تزول وهذه مدة قريبة يمكن تجزئتها باستقراض وغيره.

^٥ فإن سلم فلا فسخ لتبين زوال العارض الذي كان الفسخ لأجله وليس لها جعل ما سلمه عما مضى.

^٦ إذا مضى يومان بلا نفقة وأنفق الثالث وعجز الرابع بنت فتضم إلى اليومين الأولين يوماً آخر ثم تفسخ في اليوم الذي يليه لأنها تتضرر بطول المدة عند الاستئناف، وقيل: تستأنف الأيام الثلاثة من أولها لأن العجز الأول قد

زال، وضعفه البعض بأنه قد يتجدد ذلك عادة فيؤدي إلى ضرر عظيم.

(وَلَهَا الْخُرُوجُ^١ زَمَنَ الْمُهَلَّةِ لِتَحْصِيلِ النَّفَقَةِ^٢)، بِكَسْبٍ أَوْ سُؤَالٍ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ ذَلِكَ لِاتِّفَاقِ الْإِنْفَاقِ الْمُقَابِلِ لِحَبْسِهَا، (وَعَلَيْهَا الرَّجُوعُ لِيَلَّا)^٣ لِأَنَّهُ وَقْتُ الدَّعَةِ قَالَ الرُّوْيَانِيُّ وَلَيْسَ لَهَا مَنْعُهُ مِنَ الْإِسْتِمْتَاعِ بِهَا^٤، وَقَالَ الْبَغَوِيُّ لَهَا مَنْعُهُ قَالَ فِي الرُّوْضَةِ وَهُوَ أَقْرَبُ.

رضا المرأة بإعسار الزوج بالنفقة أو المهر:

(وَلَوْ رَضِيَتْ بِإِعْسَارِهِ) الْعَارِضِ (أَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِإِعْسَارِهِ فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ)^٥ لِأَنَّ الضَّرَرَ يَتَجَدَّدُ وَلَا أَثَرَ لِقَوْلِهَا رَضِيَتْ^٦ بِإِعْسَارِهِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ وَعْدٌ لَا يُلْزَمُ الْوَفَاءُ بِهِ

(وَلَوْ رَضِيَتْ^٨ بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ فَلَا) أَيْ فَلَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ بِذَلِكَ بَعْدَ الرِّضَا بِهِ، لِأَنَّ الضَّرَرَ لَا يَتَجَدَّدُ وَكَذَا لَوْ نَكَحَتْهُ عَالِمَةً بِإِعْسَارِهِ بِالْمَهْرِ لَيْسَ لَهَا الْفَسْخُ بِذَلِكَ فِي الْأَصَحِّ^٩

(وَلَا فَسْخٌ لَوْلِي صَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ بِإِعْسَارِ بِمَهْرٍ وَنَفَقَةٍ)^{١٠} لِأَنَّ الْفَسْخَ بِذَلِكَ مُتَعَلِّقٌ بِالشَّهْوَةِ وَالطَّبْعِ وَهُوَ لِلْمَرْأَةِ لَا مَذْخَلَ لِلْوَلِيِّ فِيهِ وَيُنْفِقُ عَلَيْهِمَا مِنْ مَالِهِمَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا مَالٌ فَنَفَقَتُهُمَا عَلَى مَنْ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُمَا قَبْلَ النِّكَاحِ

^١ لها الخروج وإن أمكنها الكسب في بيتها.

^٢ وغيرها مما لها الفسخ به.

^٣ عليها الرجوع ليلاً إلى منزل الزوج لأن الله تعالى جعله سكناً

^٤ الدعة: السكون.

^٥ للزوج أن يستمتع بها ليلاً لا نهاراً، فلو منعه الاستمتاع بالليل كانت ناشزة، أو بالنهار فلا لأنه وقت كسبها.

^٦ قوله "بعده" أي بعد الرضا أي إن أعسر ثلاثة بعد يوم الرضا، ويتجدد الإمهال إذا طلبت الفسخ بعد الرضا.

^٧ يستثنى اليوم الذي تقول فيه رضيت فإنه يؤثر فيه.

^٨ أي رضيت الرشيدة فلا أثر لرضا غيرها به.

^٩ إذا نكحته عالمة بإعساره بالمهر، ففي الفسخ؟ وجهان: ليس لها الفسخ وهو الأصح كما لورضيت به في النكاح ثم بدا

لها أن تفسخ بخلاف النفقة، والثاني: لها الفسخ وليس لها الامتناع بعد الدخول إذا مكنها من الفسخ

واختارت المقام.

^{١٠} الفسخ حق الزوجة وعليه لا فسخ لولي صغيرة ومجنونة وإن كان فيه مصلحة لهما بإعسار بمهر ونفقة كما لا يطلق

عليهما وإن كان فيه مصلحتهما لأن الخيار يتعلق بالطبع والشهوة فلا يفوز إلى غير مستحقه وينفق عليهما

من مالهما فإن لم يكن لهما مال أنفق عليهما من عليه نفقتهما وتصير نفقتهما ومهرهما ديناً عليه يطالب

به إذا أيسر.

(وَلَوْ أَعْسَرَ زَوْجُ أَمَةٍ^١ بِالنَّفَقَةِ^٢ فَلَهَا الْفَسْخُ)^٣ لِأَنَّهُ حَقُّهَا (فَإِنْ رَضِيَتْ) بِإِعْسَارِهِ (فَلَا فُسْخَ لِلْسَيِّدِ فِي الْأَصَحِّ) وَالثَّانِي لَهُ الْفَسْخُ لِأَنَّ الْمَلِكَ فِي النَّفَقَةِ لَهُ وَضَرَرُ فَوَاتِهَا يَعُودُ إِلَيْهِ وَاجَابَ الْأَوَّلَ بِأَنَّهَا فِي الْأَصْلِ لَهَا وَيَتَلَقَّاهَا السَّيِّدُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَا تُمْلِكُ، (وَلَهُ) أَيُّ لِلْسَيِّدِ بِنَاءً عَلَى الْفَسْخِ (أَنْ يُلْجِئَهَا^٥ إِلَيْهِ) أَيُّ إِلَى الْفَسْخِ، (بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَقُولُ) لَهَا (اْفْسْخِي أَوْ جُوعِي)^٦ فَإِذَا فَسَخْتَ أَنْفَقَ عَلَيْهَا وَاسْتَمْتَعَ بِهَا أَوْ زَوَّجَهَا مِنْ غَيْرِهِ وَكَفَى نَفْسَهُ مُؤَنَّتَهَا.

من أسباب النفقة: القرابة^٧:

فَصْلٌ (يُلْزِمُهُ) أَيُّ الشَّخْصَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى (نَفَقَةُ الْوَالِدِ وَإِنْ عَلَا) مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى (وَالْوَلَدِ وَإِنْ سَقَلَ)^٨ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَالْأَصْلُ فِي الثَّانِي^٩ قَوْلُهُ تَعَالَى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}، وَقَيْسَ الْأَوَّلُ^{١٠} عَلَيْهِ بِجَمَاعِ الْبُعْضِيَّةِ بَلْ هُوَ أَوْلَى لِأَنَّ

^١ أمة ولو مكاتبه.

^٢ خرج بالنفقة المهر فللسيد الفسخ به لأنه حقه

^٣ لها الفسخ وإن لم يرض به السيد ما لم يسلمها النفقة

^٤ فإن رضيت أو كانت صغيرة أو مجنونة.

^٥ قوله "أن يلجئها" أي يضطرها ويكرهها ما لم تكن صغيرة أو مجنونة أو مكاتبه

^٦ الفسخ دفعا للضرر

^٧ تجب النفقة للوالد على الولد والولد على والده، فمتى كان المنفق عليه بعضاً من المنفق بأن كان أحد أصوله أو فروعه وجب، ولا فرق في الطرفين بين الذكور والإناث فتجب نفقة الوالد وإن علا جداً كان أو

جدة، وارثاً كان أو غير وارث

^٨ خرج بالأصول والفروع "وإن علا، وإن سفل" غيرهما من سائر الأقارب كالأخ والأخت والعم والعمة

^٩ الدليل على وجوب نفقة الولد وإن سفل الآية المذكورة، وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ} [الإسراء: ٣١]

فمنع الله من قتل الأولاد خشية الإملاق وهو الفقر، فلو لا أن نفقة الأولاد عليهم لما خافوا الفقر، وقوله

تعالى {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [الطلاق: ٦] فأوجب أجره رضاع الولد على الأب، فدل على أن

نفقته تجب عليه، وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: يا رسول الله، عندي دينار؟ فقال: "

أنفقه على نفسك"، فقال: عندي آخر؟ فقال: أنفقه على ولدك" صحيح ابن حبان. "وروي أن النبي ﷺ

قال لهند بنت عتبة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) "متفق عليه"، ولأن الولد بعض من الأب فكما

يلزمه أن ينفق على نفسه فكذلك يلزمه أن ينفق على ولده.

^{١٠} الدليل على وجوب نفقة الوالد وإن علا قوله تعالى: {وصاحبهما في الدنيا معروفا} [لقمان: ١٥] ومن المعروف القيام

بكفائتهما عند حاجتهما، وروي عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (إن أطيّب ما أكل الرجل من كسبه

وولده من كسبه)، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن نفقة الوالدين للذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في

مال الولد، والأجداد والجندات ملحقون بهما.

حُرْمَةُ الْوَالِدِ أَكْثَرُ، وَالْوَالِدُ بِالتَّعَهُدِ وَالْخِدْمَةِ أَلْيَقُ، (وَإِنْ اخْتَلَفَ دِينُهُمَا) ^١ فَتَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ نَفَقَةُ الْكَافِرِ وَالْعَكْسُ لَوْجُودِ الْبَعْضِيَّةِ.

يَشْتَرِطُ لَوْجُوبِ نَفَقَةِ الْقَرَابَةِ يَسَارِ الْمُنْفَقِ: (بِشَرْطِ يَسَارِ الْمُنْفَقِ ^٢ بِفَاضِلٍ عَنْ قُوَّتِهِ ^٣ وَقُوَّتِ عِيَالِهِ ^٤ فِي يَوْمِهِ) ^٥ وَلَيْلَتِهِ مَا يَضْرِفُهُ إِلَى مَنْ ذَكَرَ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمُوَاسَاةِ.

(وَيُبَاعُ فِيهَا مَا يُبَاعُ فِي الدِّينِ) ^٦ مِنْ عَقَارٍ وَغَيْرِهِ لِشَبَهَةِ بِهِ، وَفِي كَيْفِيَّةِ بَيْعِ الْعَقَارِ وَجْهَانِ ^٧ أَحَدُهُمَا يُبَاعُ كُلُّ يَوْمٍ جُزْءٌ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وَالثَّانِي لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ لِأَنَّهُ يَشُقُّ وَلَكِنْ يَقْتَرِضُ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يَجْتَمَعَ مَا يَسْهُلُ بَيْعُ الْعَقَارِ لَهُ.

(وَيَلْزَمُ ^٨ كَسُوبًا كَسْبُهَا فِي الْأَصَحِّ) ^٩ كَمَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِنَفَقَةِ نَفْسِهِ، وَالثَّانِي لَا كَمَا لَا يَلْزَمُهُ الْكَسْبُ لِقَضَاءِ الدِّينِ.

^١ قوله "وإن اختلف دينهما" فيجب على المسلم منهما نفقة الكافر المعصوم وعكسه لعموم الأدلة ولوجود الموجب وهو البعضية كالتعتق ورد الشهادة، فإن قيل: هلا كان ذلك كالإيراث؟ أجيب: بأن الإرث مبني على المناصرة وهي مفقودة عند اختلاف الدين.

^٢ المنفق من الولد والوالد

^٣ القوت: المونة الشاملة للكسوة والسكنى والأدم وما يتعلق بذلك

^٤ عياله: هم زوجته وخادمها وأم ولده،

^٥ شرط وجوب نفقة القريب شرط يسار المنفق من والد أو ولد لأنها مواساة فاعتبر فيها اليسار، وقيل: لا يشترط يسار الوالد في نفقة ولده الصغير فيستقرض عليه ويؤمر بوفائه إذا أيسر بفاضل عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته سواء أفضل ذلك بكسب أم بغيره، فإن لم يفضل شيء فلا شيء عليه، لقوله ﷺ (ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك) رواه مسلم.

^٦ ويباع في نفقة القريب ما يباع في الدين من عقار وغيره لأن نفقة القريب مقدمة على وفاء الدين وإذا بيع ذلك في الدين ففي المقدم عليه أولى.

^٧ في كيفية بيع العقار وجهان، أحدهما: يباع كل يوم جزء بقدر الحاجة. والثاني: يستقرض إلى أن يجتمع ما يسهل بيع العقار له، قال الأذري: والثاني هو الصحيح أو الصواب، ولو لم يوجد من يشتري إلا الكل وتعدرا لاقتراض يبيع الكل.

^٨ قوله "ويلزم" هو في النفقة الحالة إذا طلبت كالدين.

^٩ يلزم كسوبا إذا لم يكن له مال كسيها في الأصح إذا وجد مباحا يليق به لما عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) "صحيح بن حبان"، ولأن القدرة بالكسب كالقدرة بالمال، ولهذا يحرم عليه الزكاة، وكما يلزمه إحياء نفسه بالكسب فكذا بعضه، والثاني لا يلزمه كما لا يلزمه الكسب

(وَلَا تَجِبُ لِمَالِكَ كِفَايَتُهُ وَلَا مُكْتَسِبُهَا^١) لِإِثْتِفَاءِ حَاجَتِهِ إِلَى غَيْرِهِ.

(وَتَجِبُ لِفَقِيرٍ غَيْرِ مُكْتَسِبٍ إِنْ كَانَ زَمَنًا^٢ أَوْ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا)^٣ لِعَجْزِهِ عَنْ كِفَايَةِ نَفْسِهِ وَالْحَقُّ الْبَغْوِيُّ بِالزَّمَنِ الْمَرِيضِ وَالْأَعْمَى^٤، (وَالْإِلَّا^٥ أَيْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَمَا ذَكَرَ. (فَأَقْوَالُ^٦ أَحْسَنُهَا تَجِبُ) لِأَنَّهُ يَقْبُحُ أَنْ يُكَلَّفَ بَعْضُهُ الْكُسْبَ مَعَ اتِّسَاعِ مَالِهِ، وَالثَّانِي لَا تَجِبُ لِلْقُدْرَةِ عَلَى الْكُسْبِ، (وَالثَّالِثُ) تَجِبُ (لِلْأَصْلِ لَا فَرْعٍ)^٧ لِعِظَمِ حُرْمَةِ الْأَصْلِ (قُلْتُ الثَّالِثُ أَظْهَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) وَإِيرَادُ الرَّافِعِيِّ فِي شَرْحِهِ يُشْعِرُ بِتَرْجِيحِهِ.

مقدار نفقة القرابة:

(وَهِيَ الْكِفَايَةُ^٨ وَتَسْقُطُ بِفَوَاتِهَا^٩ وَلَا تَصِيرُ دَيْنًا عَلَيْهِ)، لِأَنَّهَا مُوَاسَاةٌ لَا يَجِبُ فِيهَا التَّمْلِيكُ (إِلَّا بِفَرْضٍ قَاضٍ) بِالْإِفَاءِ (أَوْ إِذْنِهِ فِي اقْتِرَاضٍ) بِالْقَافِ (لِغَيْبَةٍ أَوْ مَنَعٍ)^{١٠} فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تَصِيرُ

لقضاء دينه ، وأجاب الأول بأن النفقة قدرها يسير ، والدين لا ينضبط قدره ، ولا يكلف القريب أن يسأل الناس ولا أن يقبل الهبة والوصية ، فإن فعل وصار بذلك غنيا لزمه مؤنة قريبه .

^١ ولا تجب النفقة لمالك كفايته ولو زمنا أو صغيرا أو مجنونا لاستغنائه عنها ، ولا تجب أيضا لمن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به لانتفاء حاجته إلى غيره ، وإن كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة .

^٢ الزمن: من به آفة تمنعه من الكسب ، أو من هو عاجز عن الكسب .

^٣ تجب النفقة لفقير غير مكتسب إن كان زَمَنًا أو صَغِيرًا أو مَجْنُونًا لعجزه عن كفاية نفسه ، وفي معناه: العاجز بالمرض والمغنى عليه ، فإذا بلغ الصغير حدًا يمكن أن يتعلم حرفة أو يحمل على الاكتساب في بعض الأيام فعلى الأب الإنفاق عليه .

^٤ قوله "المريض والأعمى" وكذا المتصرف في مال ولده والمشتغل بعلم شرعي والكسب يمنعه منه .

^٥ قوله (وَالْإِلَّا) أي: وإن لم يكن غير المكتسب صغيرًا ولا مجنونًا ولا زَمَنًا

^٦ إذا لم يكن غير المكتسب صغيرًا ولا مجنونًا ولا زَمَنًا ففي وجوب النفقة له أقوال: أحسنها: تجب للأصل والفرع لأنه يقيح بالإنسان أن يكلف قريبه الكسب مع اتساع ماله ، قال الرافعي: والفتوى اليوم عليه ، والثاني: لا تجب لأنه قادر على الاكتساب مستغن عن أن يُحْمَلَ غيره كَلَّهُ ، والثالث: تجب لأصل لا فرع ، وقد قال النووي الثالث أظهر لعموم قوله تعالى: {وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} وليس من المعروف تكليفهما الكسب مع كبر السن . وهذا هو المصحح في الشرحين " الشرح الصغير والشرح الكبير " للرافعي ولا فرق في ذلك بين الابن والبنت .

^٧ قوله "لا فرع" بل يكلف الفرع الكسب لأجل أصله ولو بأمر وليه .

^٨ ونفقة القريب الكفاية لقوله ﷺ لهند بنت بنت عتبة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) ولأنها تجب على سبيل المواساة لدفع الحاجة الناجزة . ويعتبر حاله في سنه وزهاده ورغبته ، ويجب إشباعه ، ويجب له الأدم كما

يجب له القوت ، ويجب له مؤنة خادم إن احتاجه مع كسوة وسكنى لاتقن به وأجرة طبيب وثمر أدوية .

^٩ وتسقط نفقة القريب بفواتها بمضي الزمان ، وإن تعدى المنفق بالمنع لأنها وجبت بدفع الحاجة الناجزة وقد زالت ، بخلاف نفقة الزوجة فإنها معاوضة .

تَصِيرُ دَيْنًا فِي الدِّمَةِ وَصَيَّرُورُثَهَا دَيْنًا بِفَرْضِ الْقَاضِي ذَكَرَهُ الْغَزَالِيُّ^٢، وَقَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ^٣ وَالشَّيْخُ أَبُو إِسْحَاقَ^٤ فِي التَّذَكُّرَةِ وَالْبَنْدِينِجِيِّ^٥ وَغَيْرُهُمْ لَا تَصِيرُ دَيْنًا إِلَّا بِذَلِكَ.

الرضاع الواجب على الأم:

(وَعَلَيْهَا) أَيُّ الْأُمِّ (إِرْضَاعٌ^٦ وَلِدَهَا اللَّبَأُ^٧) بِالْهَمْزِ مِنْ غَيْرِ مَدٍّ لِأَنَّهُ لَا يَعْيشُ غَالِبًا إِلَّا بِهِ، وَهُوَ اللَّبَنُ أَوَّلُ الْوِلَادَةِ وَمُدَّتُهُ يَسِيرَةٌ^٨ (ثُمَّ بَعْدَهُ) أَيُّ بَعْدَ إِرْضَاعِ اللَّبَأِ، (إِنْ لَمْ يُوْجَدْ إِلَّا هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إِرْضَاعُهَا) عَلَى مَنْ وَجِدَ مِنْهُمَا إِبْقَاءَ لَهُ، (وَإِنْ وَجِدْتَا لَمْ تُجْبَرَ الْأُمُّ)^٩ عَلَى الْإِرْضَاعِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي نِكَاحِ أَبِيهِ أَمْ لَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى}.

(فَإِنْ رَغِبَتْ) فِي إِرْضَاعِهِ (وَهِيَ مَنْكُوحَةٌ أَبِيهِ^{١٠} فَلَهُ مَنُوعُهَا) مِنْ إِرْضَاعِهِ (فِي الْأَصَحِّ) لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْإِسْتِمْتَاعَ بِهَا وَقَدْ الْإِرْضَاعُ لِكِنْ يُكْرَهُ لَهُ الْمَنُوعُ. (قُلْتُ الْأَصَحُّ لَيْسَ لَهُ مَنُوعُهَا

^١ ولا تصير ديناً لأنها من باب المواساة فإذا اندفعت الحاجة من غير جهة القريب حصل المقصود، إلا إذا فرض قاض أو أذن في اقتراض لغيبة أو منع فإنها تصير ديناً بذلك.

^٢ محمد بن محمد بن محمد الإمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد الطوسي الغزالي المتوفي ٥٠٥ هـ.

^٣ سهل بن محمد بن سليمان بن محمد الإمام شمس الإسلام أبو الطيب المتوفي سنة ٤٠٤ هـ.

^٤ إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبد الله الشيخ إسحاق الشيرازي المتوفي ٤٧٦ هـ.

^٥ الحسن بن عبيد الله مصغر بن يحيى الشيخ أبو علي البندنجي المتوفي ٤٢٥ هـ.

^٦ قوله "وعليها إرضاع" ولها أخذ الأجرة عنه وطلبها لأنه الذي ملكها.

^٧ اللَّبَأُ: اللَّبَنُ النَّازِلُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ

^٨ علي الأم إرضاع ولدها اللَّبَأُ لأن الولد لا يعيش بدونه غالباً وغيرها لا يغني، كما أنه لا يقوى وتشتد بنيته إلا به. ولها أن تأخذ الأجرة إن كان لمثلها أجرة، ولا يلزمها التبرع بإرضاعه.

^٩ قوله "ومدته يسيرة" ويرجع في قدرها إلى أهل الخبرة من كونه مرة أو أكثر، ولا يتقيد بزمان وقيد به بعضهم بثلاثة أيام.

^{١٠} بعد إرضاع اللَّبَأِ إن لم يوجد إلا الأم أو أجنبية وجب على الموجود منهما إرضاعه إبقاءً للولد، ولهما طلب الأجرة من ماله إن كان. وإلا فممن تلزمه نفقته، وإن وجدت الأم والأجنبية لم تجبر الأم وإن كانت في نكاح أبيه على إرضاعه لقوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى} [الطلاق: ٦]، وإذا امتنعت حصل التعاسر.

^{١١} احترز بـ "منكوحة الأب" عما إذا كانت بانئاً منه فإنها إن تبرعت لم يكن له انتزاعه منها، وإن طلبت أجرة فهي كالتى في نكاحه.

وَصَحَّحَهُ الْأَكْثَرُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ) ^١، لِأَنَّهَا أَشْفَقُ عَلَى الْوَلَدِ مِنَ الْأَجْنَبِيَّةِ وَلَبْنُهَا لَهُ أَصْلَحُ وَأَوْفَقُ.

(فَإِنْ اتَّفَقَا) عَلَى إِرْضَاعِهِ (وَطَلَبَتْ أَجْرَهُ مِثْلَ) لَهُ (أُجِيبَتْ أَوْ فَوْقَهَا فَلَا) ^٢ تُجَابُ إِلَى ذَلِكَ، (وَكَذَا إِنْ تَبَرَّعَتْ أَجْنَبِيَّةٌ أَوْ رَضِيتْ بِأَقَلِّ) مِنْ أَجْرَةِ الْمِثْلِ لَا تُجَابُ الْأُمُّ ^٣ إِلَى طَلَبِ أَجْرَةِ الْمِثْلِ، (فِي الْأَظْهَرِ) ^٤ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} وَالثَّانِي تُجَابُ الْأُمُّ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} مَعَ قَوْلِ شَفَقَتِهَا وَأَوْفَقِيَّةِ لَبْنِهَا

اجتماع الأقارب من جانب المنفق ومن جانب المحتاج:

(وَمَنْ اسْتَوَى فَرْعَاهُ) فِي الْقُرْبِ وَالْإِرْثِ أَوْ عَدَمِهِمَا (أَنْفَقَا) ^٥ بِالسَّوِيَّةِ بَيْنَهُمَا وَإِنْ تَفَاوَتَا فِي الْيَسَارِ كَابْنَيْنِ أَوْ بَنَتَيْنِ وَكَابْنِي ابْنٍ أَوْ بِنْتٍ (وَأِلَّا) أَيَّ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِيمَا ذَكَرَ بِأَنْ كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ وَالْآخَرُ وَارِثًا. (فَالْأَصَحُّ أَقْرَبُهُمَا) ^٦ لِأَنَّ الْقُرْبَ أَوْلَى بِالْإِعْتِبَارِ مِنَ الْإِرْثِ.

^١ إذا رغبت الأم في إرضاع ولدها وهي منكوبة أبيه فلأب منعها من إرضاعه في الأصح لأنه يستحق الاستمتاع بها في الأوقات المصروفة إلى الرضاع، وقال النووي: الأصح ليس له منعها مع وجود غيرها وصححه الأكثرون لأن فيه إضرارا بالولد لأنها عليه أشفق ولبنها له أصلح، ولا تزداد نفقتها للإرضاع، وإن احتاجت فيه إلى زيادة الغذاء لأن قدر النفقة لا يختلف بحال المرأة وحاجتها.

^٢ إذا اتفقا على أن الأم ترضعه وطلبت أجرة مثل أجببت بل هي أولى من غيرها لوفور شفقتها، وهذا مبني على الأصح، وهو أن للزوج استنجاز زوجته لإرضاع ولده وإذا طلبت أجرة فوق أجرة المثل فلا تُجَاب لتضرره وله في هذه الحالة استرضاع أجنبية.

^٣ قوله "لا تجاب الأم" لكن إذا تضرر الرضيع بغير لبن أمه أجببت الأم بالأجرة بلا خلاف.

^٤ للأب استرضاع أجنبية إن تبرعت الأجنبية بإرضاعه أو رضيت بأقل من أجرة المثل ولو بشيء يسير ولا يلزمه إجابة الأم إلى أجرة المثل في الأظهر لأن في تكليفه الأجرة مع المتبرعة أو الزيادة على ما رضيت به إضرارا، وقد قال تعالى:

{وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} [البقرة: ٢٣٣]، والثاني: تجاب الأم لوفور شفقتها.

^٥ من استوى فرعاه في قرب وإرث أو عدمهما، وإن اختلفا في الذكورة وعدمها كابنين أو بنتين أو ابن وبنت أنفقا عليه وإن تفاوتتا في قدر اليسار أو أيسر أحدهما بالمال والآخر بالكسب لأن علة إيجاب النفقة تشملهما، فإن غاب أحدهما أخذ قسطه من ماله، فإن لم يكن مال اقترض عليه الحاكم إن أمكن، وإلا أمر الحاكم الحاضر بالإنفاق بقصد الرجوع على الغائب أو ماله إذا وجده.

^٦ إذا اختلف الفرعان في القرب فالأصح أقربهما لأنه أولى بالاعتبار.

(فَإِنْ اسْتَوَى قَرُبُهُمَا فَبِالْإِثْرِ فِي الْأَصَحِّ)، لِقُوَّةِ قَرَابَتِهِ وَقِيلَ لَا أَثَرَ لِلْإِثْرِ لِعَدَمِ تَوَقُّفِ وَجُوبِ النَّفَقَةِ عَلَيْهِ، (وَالثَّانِي بِالْإِثْرِ ثُمَّ الْقُرْبِ) هَذَا مُقَابِلُ قَوْلِهِ فَالْأَصَحُّ أَقْرُبُهُمَا فَيَقْدَمُ عَلَى هَذَا الْوَرِثُ الْبَعِيدُ عَلَى غَيْرِهِ، الْقَرِيبُ فَإِنْ اسْتَوَى فِي الْإِثْرِ قُدِّمَ أَقْرَبُهُمَا^١

(وَالْوَارِثَانِ) عَلَى الْوَجْهَيْنِ (يَسْتَوِيَانِ أَمْ تُوزَعُ بِحَسَبِهِ)^٢ أَيَّ بِحَسَبِ الْإِثْرِ وَجْهَانِ وَجْهُهُ الْإِسْتِوَاءُ اشْتِرَاكُهُمَا فِي الْإِثْرِ، وَوَجْهُ التَّوْزِيعِ إِشْعَارُ زِيَادَةِ الْإِثْرِ بِزِيَادَةِ قُوَّةِ الْقَرَابَةِ وَسَيَأْتِي تَرْجِيحُهُ فِي الْمَسْأَلَةِ بَعْدَ هَذِهِ، (وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى الْأَبِ)^٣ نَفَقَتُهُ صَغِيرًا كَانَ أَوْ بَالِغًا أَمَّا الصَّغِيرُ فَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} وَأَمَّا الْبَالِغُ فَبِالِاسْتِصْحَابِ، (وَقِيلَ عَلَيْهِمَا لِبَالِغٍ)^٤ لَاسْتِوَائِهِمَا فِي الْقُرْبِ وَهَلْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا أَوْ يُجْعَلُ بَيْنَهُمَا أَثْلَاثًا بِحَسَبِ الْإِثْرِ وَجْهَانِ رَجَحَ مِنْهُمَا الثَّانِي.

(أَوْ أَجْدَادٌ وَجَدَاتٌ)^٥ إِنْ أَذْلَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ فَلِأَقْرَبِ مِنْهُمْ عَلَيْهِ النَّفَقَةُ (وَالَا فَبِالْقُرْبِ وَقِيلَ الْإِثْرِ) كَالْخِلَافِ فِي طَرَفِ الْفُرُوعِ^٦ (وَقِيلَ بِوِلَايَةِ الْمَالِ)^٧ فَإِنَّهَا تُشْعَرُ بِتَفْوِيزِ التَّرْبِيَةِ إِلَيْهِ.

^١ إذا استوي الفرعان في القرب فبالإِثْرِ في الأصح لقوته كابن وابن بنت فيلزم ابن الابن لقوة قرابته. وقيل في وجه ضعيف: لا أثر للإِثْرِ بل القرابة المجردة موجبة للنفقة والإِثْرِ غير مرعي في الباب. والثاني: المعتبر الإِثْرِ فإن فقد فالقرب، فإن كان أحدهما وارثاً دون الآخر فالنفقة على الوارث وإن كان غير الوارث أقرب، فإن تساوى في الإِثْرِ وأحدهما أقرب فالنفقة على الأقرب، وإن تساوى في القرب فالنفقة عليهما.

^٢ الوارثان إذا استويا في أصل الإِثْرِ دون غيره كابن وبنت، هل يستويان في قدر الإنفاق أم يوزع الإنفاق بينهما بحسب الإِثْرِ، غيه وجهان: الأول: التوزيع إشعار بزيادة الإِثْرِ بزيادة قوة القرب، الثاني: الاستواء اشتراكهما في الإِثْرِ، والأول أوجه

^٣ إذا اجتمع للمحتاج أب وأم فالنفقة على الأب صغيراً كان أو كبيراً، أما إذا كان الابن صغيراً فلا خلاف لقوله تعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} ، وكذا إن كان بالغاً في الأصح استصحاباً للحكم الثابت في حال الصغر، وقيل: النفقة عليهما لبالغ لاستوائهما في القرب وإنما قدم الأب في الصغر لولايته عليه وقد زالت، وهل يسوى بينهما أم يجعل بينهما أثلاثاً بحسب الإِثْرِ؟ وجهان: رجح المصنف منهما الثاني.

^٤ لبالغ: أي عاقل والمجنون كالصغير.

^٥ قوله "أجداد وجدات" المراد أجداد فقط أو جدات فقط، فإن اجتمعا فيقدم الأجداد على الجدات وإن كن أقرب منهم.

^٦ قوله "كالخلاف في طرف الفروع" يعلم منه أن ذلك عند الاختلاف في القرب والإِثْرِ معا بأن اجتمع وارث بعيد مع غير وارث قريب كأبي الجد مع أبي الأم فيالقرب.

(وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرَعٌ^٢ فَفِي الْأَصَحِّ عَلَى الْفَرَعِ وَإِنْ بَعْدَ) لِأَنَّهُ^٣ أَوْلَى بِالْقِيَامِ بِشَأْنِ أَصْلِهِ لِعِظَمِ حُرْمَتِهِ، وَالثَّانِي أَنَّهَا عَلَى الْأَصْلِ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ فِي الصَّغَرِ، وَالثَّالِثُ أَنَّهَا عَلَيْهِمَا لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْبَعْضِيَّةِ مِثَالُهُ^٤ أَبٌ وَابْنٌ جَدٌّ وَابْنٌ أَبٌ وَابْنٌ ابْنٌ أُمٌّ وَابْنٌ (أَوْ) لَهُ (مُحْتَاجُونَ) وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كِفَايَتِهِمْ^٥. (يُقَدِّمُ زَوْجَتَهُ) لِأَنَّ نَفَقَتَهَا آكَدُ (ثُمَّ الْأَقْرَبُ وَقِيلَ الْوَارِثُ وَقِيلَ الْوَلِيُّ) عَلَى الْخِلَافِ السَّابِقِ فِي طَرَفِي الْفُرُوعِ وَالْأَصُولِ كَمَا تَقَدَّمَ.

^١ إذا كان للفرع أجداد وجدات إن أدلى بعضهم ببعض فالأقرب منهم، فالأقرب تلزمه النفقة لأن القرب أولى بالاعتبار وإن لم يدل بعضهم ببعض فبالقرب يعتبر لزوم النفقة، وقيل: الإرث على الخلاف، وقيل: بولاية المال لأنها تشعر بتفويض التربية إليه.

^٢ قوله "أصل وفرع" سواء بعد كل منهما أم لا وسواء استويا في القرب إليه أم لا.

^٣ لأن عصوبته أقوى وسواء كان الفرع وارثاً أو غير وارث قريباً أو بعيداً.

^٤ قوله "مثاله" أي اجتماع الأصل والفرع.

^٥ إذا اجتمع على الشخص الواحد محتاجون تلزمه نفقة كل منهم لكنه لا يقدر إلا على كفاية بعضهم يقدم زوجته لأنها أكدر إذ نفقتها لا تسقط بمضي الزمان، ثم بعد نفقتها يقدم الأقرب فالأقرب، فيقدم بعد زوجته ولده الصغير لشدة عجزه، ثم الأم لتأكد حقها بالحمل والوضع والرضاع والتربية، ثم الأب ثم الولد الكبير ثم الجد وإن علا، وقيل يقدم الوارث، وقيل: الولي، والمراد أنه يقدم بعد نفقة الزوجة الأقرب أو الوارث أو الولي.

كتاب الجراح

جمع جراحة وهي إما مزهقة للروح أو مبينة للعضو أو غير ذلك ويأتي معها غيرها كالقتل بمثقل ومسموم وغير ذلك والترجمة للأغلب .

بداية نقول: إن الشافعية يبحثون موضوع الجنايات تحت عنوان: الجراح لأن الجراحة هي السبب الغالب في الاعتداء، ولأنها أكثر طرق الزهوق .

أما غيرهم من الفقهاء كالحنفية فإنهم يبحثونها تحت عنوان: كتاب الجنايات.

وإنصافاً فإن التبويب بالجنايات أولى لشمولها الجناية بالجرح وغيره كالقتل بمثقل كالعصا والحجر، وبمسموم وسحر .

والبعض الآخر كالمالكية . يبحثونها تحت عنوان: الدماء . ناظرين إلى نتيجة الجريمة غالباً

تعريف الجراح لغة واصطلاحاً:

أ. الجراح لغة: جمع جرح وهو الجرح . بفتح الجيم . وفعله من باب: نفع يقال: جرحه يجرحه جرحاً إذا أثر فيه بالسلاح .

والجرح . بضم الجيم . . الإسم . والجمع جروح وجراح، وجاء جمعه على أجراح .

والجراحة اسم الضربة أو الطعنة، ويقال: امرأة جريح ورجل جريح .

والاستجراح: النقصان والعيب والفساد .

ب . وفي الاصطلاح: ما كان في سائر البدن عدا الرأس والوجه .

أنواع الجراح: تنقسم الجراح إلى نوعين:

١. جائفة: وهي التي تصل إلى الجوف من الصدر أو البطن أو الظهر أو الجنين أو ما بين الأنثيين أو الدبر أو الحلق .

ولا تكون الجائفة في اليدين والرجلين ولا في الرقبة، لأنه لا يصل إلي الجوف .

٢. غير الجائفة: وهي التي لا تصل إلي الجوف كالرقبة أو اليد أو الرجل

وتنقسم باعتبار آثارها إلي الآتي:

١. مزهقة للروح .

٢. مبينة للعضو .

٣. لا تحصل واحد منها .

سر جمع صاحب المتن (الإمام النووي) . لكتاب الجراح:

نقول: لما كانت الجراحة تارة تزهق النفس إما بالمباشرة وإما بالسراية، وتارة تُبين عضواً، وتارة لا تفعل شيئاً من ذلك جمعها .

وقوله: أو غير ذلك من الشارح: أي كالموضحة وما معها .

وقوله: معها: أي الجراحة أو الجراح لأنه جماعة .

وقوله: وغير ذلك: أي كالتجويع والسحر وشهادة الزور .

وقوله: والترجمة لأغلب: أي أنه عنون للباب . بالجراحة باعتبار الأغلب لأنه يضم ما يدخل تحته من جنایات وغيرها .

وذكر الشيخ قليوبي قوله: ولو عبر بالجنایة لشمّل كل ذلك بعد تخصيصها بالأبدان فلا

ترد الجنایة علي الأموال .

وهذا أولي من وجهة نظري، لأن إطلاق كلمة جنایة دون تخصيص تطلق علي نحو القذف والزنا والسرقه .

حكم الجراح:

قرر الشارع أحكاماً عند حدوث الجراح بغير حق، سيأتي بيانها .

دليل مشروعية أحكام الجراح بالكتاب والسنة والإجماع:

فأما الكتاب: فقولته تعالى: "يا أيها الذين ءامنوا كتب عليكم القصاص" (١) .

ومن السنة:

١. خبر الصحيحين: اجتنبوا السبع الموبقات! قيل وما هنيا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات.

٢. سئل النبي ﷺ . أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك، قيل: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك مخافة أن يُطعم معك .

٣. قال ﷺ .: لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا وما فيها .

فهذه الأدلة تدل على:

حرمة الاعتداء على النفس وعلى غيرها، ويستحق الفاعل العقوبة المقررة شرعاً في الدنيا، وإذا اقتصر منه الوارث على مال أو مجاناً، فظواهر الشرع تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة إذا تاب وأقيم عليه الحد .

أما من مات مصرراً على القتل فإنه يعاقب في الدنيا والآخرة

الفعل المزهق للروح ثلاثة:

عمد وخطأ وشبه عمد، وسيأتي التمييز بينها وصح الإخبار بها عن الفعل، لأن المراد بها الجنس، ولا قصاص إلا في العمد وهو قصد الفعل والشخص بما يقتل غالباً عدواناً فقتله جرح بالجر بدل ما كسيف أو مثقل بفتح المثلثة والقاف المشددة أي ثقيل كأن رض رأسه

(٢) من الآية: ١٧٨/سورة البقرة .

(٣) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا برقم: ٢٦١٥، وفي كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة برقم: ٦٤٦٥، وفي

كتاب الطب برقم: ٥٤٣١، وسلم في كتاب الإيمان برقم: ٢٥٨

(٤) أخرجه البخاري في كتاب التفسير برقم: ٤٢٠٧، وفي كتاب الأدب برقم: ٥٦٥٥، وفي كتاب الديات

برقم: ٦٤٦٨، ومسلم في كتاب الإيمان برقم: ٢٥٣

(٥) أخرجه الترمذي في كتاب الديات برقم: ١٣٩٥، والنسائي في كتاب التحريم برقم: ٣٩٩٨

(٦) قال بذلك الإمام النووي في شرح صحيح مسلم . مغني المحتاج . ج٤ ص٦ .

بجرح كبير . فإن فقد قصد أحدهما أي الفعل أو الشخص بأن وقع عليه فمات أو رمى شجرة فأصابه فمات، أو رمى شخصاً فأصاب غيره فمات فخطأ .

بدأ المصنف والشارح في تقسيم القتل إلى عمد وغيره، فقال: الفعل الصادر من شخص مباشرة أو سبب جرحاً كان أو غيره (المزهق) أي المسرع للموت أقسامه ثلاثة: عمد وخطأ وشبه عمد .

والتمييز بين هذه الثلاثة:

أن الجاني إن لم يقصد عين المجني عليه فهو الخطأ، وإن قصدها فإن كان بما يقتل غالباً فهو العمد وإلا فشبه العمد .

ومعلوم أن الله قد وصف القتل في كتابه بصفتين عمد وخطأ .

والدليل على شبه العمد ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان عن سفيان ابن عيينه عن عبد الله بن عمر أن النبي ﷺ . قال: ألا إن في قتل عمد الخطأ قتل السوط أو العصا مائة من الإبل مغلظة منها أربعون خلفه في بطونها أولادها (١) .

ومعنى "وصح الإخبار بها عن الفعل" لأن المراد به الجنس .

أي أنه عبر عن هذه الأنواع الثلاثة من القتل بالفعل المزهق، لأن المراد به بيان جنس هذه الأنواع .

والجنس هو: مفهوم كلي له صفات مشتركة المنطبق علي أنواع مختلفة، أو الحقيقة المشتركة، والفعل المزهق يجمع صفات هذه الأنواع المختلفة .

ومعنى (لا قصاص إلا في العمد) أي أن القصاص يتقرر حينما يقصد واحداً أو جماعة بما يقتل غالباً فمات أو ماتوا في الحال أو بالسراية بسبب الجراح، وسواء النفس والطرف .

ودليل وجوب القصاص في هذه الحال: قوله تعالى: "كتب عليكم القصاص في القتلى"

(١) أخرجه أبوداود في كتاب الديات برقم: ٤٥٤٧، والنسائي في كتاب القسامة برقم: ٤٨٠٥، وابن ماجه في

كتاب الديات برقم: ٢٦٢٧ .

وعدم وجوبه في شبه العمد فلحديث أبوداود والنسائي وابن ماجه السابق، وأما في الخطأ فلقوله تعالى: "ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة".

فإنه أوجب الدية ولم يتعرض للقصاص .

ثم عُرف المصنف العمد في النفس بأنه: قصد للفعل العدوان والشخص بما يقتل غالباً قطعاً .

وقوله (جرح) بالجرح بدل من المجروح (بما) يقتل غالباً . كسيف .

وقوله (أو مثقل) جرى علي الغالب لأن القتل بجرح كالسيف أو السكين وبمثقل أي بشيء ثقل كالحجر الكبير من طبيعتهما أنهما يحققا القتل، ولا يمنع من ذكر هذين الشيئين أن يدخل في العمد كذلك القتل بالسحر وشهادة الزور ونحو ذلك .

ويرجع سبب نص المصنف . علي هذين الشيئين (الجرح والمثقل) التنبيه على خلاف أبي حنيفة، فإنه لم يوجب في المثقل كالحجر والدبوس (عمود علي شكل هراوه من ملكة الرأس الثقيلين .

واستدل المصنف علي أن القتل العمد بالمثقل يوجب القصاص خلافاً لأبي حنيفة بالآتي:

١. قال تعالى: "ومن قُتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً" (الاسراء) .

ولاشك أن الذي يُقتل بالحجر أو بالدبوس قُتل مظلوماً.

٢. خبر الصحيحين: أن جارية وُجدت وقد رضّ رأسها بين حجرين، فقبل لها من فعل بك هذا أفلان أو فلان؟ حتى سمي يهودي، فأومأت برأسها، فأخذ اليهودي فاعترف، فأمر رسول الله ﷺ . برض رأسه بالحجارة (١) .

فدل هذا على ثبوت القصاص بالمثقل بالنص مطلقاً، وأيضاً لأن القصاص شرع لصيانة النفوس، فلو لم يجب بالمثقل لما حصلت الصيانة .

(٢) أخرجه البخاري في كتاب الوصايا برقم: ٢٧٤٦. وأخرجه مسلم في كتاب القسامة برقم: ٤٣٤١ .

ومعنى قوله (فإن فقد قصد أحدهما) أي الفعل أو الشخص، بأن وقع عليه فمات، أو رمى شجرة أو دابة فأصابه فمات، أو رمى آدمياً فأصاب غيره فمات، فيكون هذا القتل قتل خطأ، وذلك لعدم قصد عين الشخص . وهذا مثال على فقد قصد الشخص .

أما مثال فقد قصد الفعل، كمن إذا قصد ضربه بصفح السيف فأخطأ وأصاب بجمده، فهنا لم يقصد الفعل بالحد مع أنه قصد الشخص، وأيضاً لو توعدده إمام ظالم وهدده فمات بذلك، فهذا قصد الشخص بالكلام ولم يقصد الفعل الواقع به لعدم صدوره إذ ذاك منه.

وظاهر أن فقد قصد الفعل يلزمه فَقْدُ قصد الشخص وأن الوقوع منسوب للواقع فيصدق عليه الفعل المقسم، وإن قصدهما أي الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً عدواناً فمات فشبه عمد، ومنه الضرب بسوط أو عصا، وسيأتي في كتاب الديات: أن فيه وفي الخطأ الدية، ودليلها آية: "ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ فحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله، وحديث: قَتِيلُ الخطأ شبه العمد قتيل الاسوط والعصا فيه مائة من الإبل، رواه أبوداود وغيره وصححه ابن حبان وغيره .

وبين الشارح بأنه إذا فقد قصد الفعل بأن وقع شخص على آخر فمات، فإن هذا يلزمه فقد قصد الشخص الذي وقع عليه، إذ هذا يقرره الواقع، ويدخل كذلك في حكم الخطأ، وبالتالي يكون داخلاً في أحد أنواع الفعل المزهق للروح وهو الخطأ كما قسم المصنف .

ويدخل كذلك في حكم الخطأ، وبالتالي يكون داخلاً في أحد أنواع الفعل المزهق للروح وهو الخطأ كما قسم المصنف .

ثم قال بعد ذلك المصنف: وإن قصدها أي الفعل والشخص بأي شيء له مدخل في الإهلاك إلا أنه لا يقتل غالباً، وكان هذا القصد عدواناً وترتب عليه الموت فيكون حكمه قتل شبه عمد

وسُمى بذلك لأنه أشبه العمد في القصد، ويسمى أيضاً خطأ عمد، وعمد خطأ، وخطأ شبه العمد، ويشبه الخطأ من حيث إنه لا يقصد بمثل هذا الضرب، فيصير شبهه في سقوط القود .

ومثل الشارح للآلة التي لا تقتل غالباً: بالضرب بسوط أو العصا، ولكن بشروط:

١. أن يكونا خفيفين .

٢. أن يوالي بين الضربات .

٣. ألا يكون الضرب في مقتل .

٤. ألا يكون المضروب صغيراً أو ضعيفاً .

٥. ألا يكون الضرب في حر أو برد مُعين على الهلاك .

٦. أن لا يشتد الألم ويبقى إلى الموت .

وبالتالي إن كان فيه شيء من ذلك فهو عمد، لأنه يقتل غالباً .

ويقاس على العصا: الحجر الخفيف، وكف مقبوضة الأصابع لمن يحمل الضرب به واحتمل موته به .

ثم ذكر حكم الخطأ وشبه العمد الدية كما في كتاب الديات .

ثم ذكر الأدلة التي تدل على ذلك من الكتاب والسنة .

وأجمعوا على وجوب القصاص في العمد بشروطه، وظاهر أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى الثلاثة أيضاً، فلو غرز إبرة بمقتل كالدماغ

والعين والحلق والخاصرة فمات فعمد لظن الموضع وشدة تأثيره، وكذا لو غرزها بغيره أي غير مقتل كالإلية والفخذ إن تورم حتى مات فعمد لظهور أثر الجناية وسرايتها إلى الهلاك، فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد لأنه لا يقتل مثله غالباً، وقيل عمد لأن في

البدن مقاتل خفيه، وموته في الحال يُشعر بإصابة بعضها، وقيل لا شيء فيه من قصاص أو دية لأنه لا يقتل مثله، فالموت بسبب آخر .

ثم انتقل الشارح إلى بيان أفعال قد تلحق بالعمد أو بشبه العمد أو الخطأ، إلا أنه قدم بأن هناك إجماعاً من أهل العلم على وجوب القصاص في العمد إذا تحققت شروطه كاملة، والتي تتمثل في الآتي:

١. وجود القصد العمد لشخص ما . ٢. استعمال الآلة التي تقتل غالباً .

٣. أن يترتب على القصد العمد واستعمال الآلة موت الشخص .

ثم ذكر في مقابلة ذكر المصنف أقسام الفعل المزهق، أقسام الفعل الغير مزهق ورأى أنه أيضاً ينقسم إلى ثلاثة أقسام:

١. قسم يدخل في العمد، وضرب له مثلاً يتمثل في: لو أن إنساناً غرز إبرة في مكان إذا أصيب قتل كالدماغ وأصل أذن وحلق وثغرة نحر وخاصره وغيرها، وذلك لخطر هذه المواضع وشدة تأثير الغرز فيها .

ثم ذكر مسألة تتمثل في الصورة التالية:

وهي ما الحكم إذا غرز إبرة في غير مقتل ولم يظهر أثر ومات في الحال ففي هذه المسألة اختلف في حكمها على ثلاثة أقوال:

الأول: قال تأخذ حكم شبه العمد، وعلل بأنه لا يقتل بمثله غالباً، فأشبهه الضرب بالسوط الخفيف، وهذا هو الأصح .

الثاني: والذي عبر عنه بـ بقي: حكمه حكم العمد، وعلل ذلك بأن في البدن مقاتل خفيفة وموته حالاً يشعُر بإصابة بعضها.

الثالث: وعبر عنه بقي: لا شيء فيه أي لا يلحق بالعمد ولا بشبه العمد ولا بالخطأ، وذلك إحالة للموت بسبب آخر غير الغرز، وبالتالي لا

قصاص ولا دية . ويترتب على ذكر هذه المسألة أنه: إذا تأخر الموت عن الغرز فلا ضمان قطعاً وذلك لعدم تأثيرها في الحال .

ولو غرزها فيما لا يؤلم كجلد عقب ولم يتألم به فمات فلا شيء فيه بحال من قصاص أو دية، لأنه لم يمت به، والموت عقبه قدر، ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب والطلب لذلك حتى مات، فإن مضت مدة يموت مثله فيها غالباً جوعاً أو عطشاً فعمد، وتختلف المدة باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً والزمان حرّاً وبرداً، ففقد الماء في الحر ليس كهو في البر، وإلا أي وإن لم تمض المدة المذكورة، فإن لم يكن به جوع وعطش سابق على الحبس فشبه عمد، وإن كان به بعض جوع وعطش وعلم الحابس الحال فعمد لظهور قصد الإهلاك .

وتابع الشارح في شرح كلام المصنف مبيناً الصور التي تبين أن الفعل غير المزهق ينقسم إلى ثلاثة أقسام، كما انقسم الفعل المزهق إلى عمد وخطأ وشبه عمد فقال:

****** ولو غرزها أي الإبرة فيما لا يؤلم كجلدة عقب ولم يتألم بها وقت إدخالها بأن لم يبالغ في إدخالها فمات فالحكم: لا شيء في غرزها بحال من الأحوال، سواء أ مات في الحال أم بعده وذلك للعلم بأنه لم يمت منه وإنما هو موافقة قدر، كما لو ألقى عليه خرقة أو ضربه بقلم فمات .

أما إذا بالغ فيجب القود قطعاً، كما قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب .
****** ثم تابع الشارح فقال: ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما ومنعه أيضاً الطلب لذلك حتى مات بسبب المنع، فالأمر فيه تفصيل:

إن مضت مدة عليه يموت مثله أي المحبوس فيها غالباً جوعاً أو عطشاً، فيكون حكمه قتل عمد وذلك لظهور قصد الإهلاك به، مع العلم أن المدة تختلف باختلاف حال المحبوس قوة وضعفاً، وكذلك الزمان

حرّاً وبرداً، لأن فقد الماء في الحر ليس كفقده في البرد .

أما لو كان عند المحبوس طعاماً وأمكنه تناوله فلم يتناوله خوفاً أو حزناً، أو أمكنه طلبه ولو بالسؤال فلم يفعل، أو منعه الشراب فترك الأكل

خوف العطش، أو انهدم السقف عليه، أو أمكنه الهرب من غير مخاطره فمات بذلك فلا قصاص ولا دية على حابسه، لأنه قتل نفسه .

ثم بين الفرض الثاني فقال: ولو حبسه ومنعه الطعام والشراب ولم تمض مدة يموت بمثلها ففيه بيان أيضاً:

إن لم يكن به جوع أو عطش سابق على الحبس .

وإن كان به بعض جوع أو عطش وعلم الحابس الحال، وكانت مدة حبسه بحيث لو أضيفت لمدة جوعه أو عطشه السابق بلغت المدة القاتلة، فيكون قتله قتل عمد، وذلك لظهور قصد الإهلاك .

أما إذا لم يبلغ مجموع المدتين ذلك، فهو كما لو يكن به شيء سابق .

وإلا أي وإن لم يعلم الحال فلا، أي فليس بعمد في الأظهر لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بمهلك . والثاني هو: عمد لحصول الهلاك به، والأول قال حصل به وبما قبله فيجب فيه نصف دية شبه العمد . ويجب القصاص بالسبب كالمباشرة، فلو شهدا على رجل بقصاص أي بموجبه فقتل بأن حكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا عنها وقالوا تعمدنا الكذب فيها لزمهما القصاص إلا أن يعترف الولي بعلمه بكذبهما فيها، أي فلا قصاص عليهما، وعلى الولي القصاص، وفي الروضة كأصلها بعد تعمدنا وعلمنا أنه يُقتل بشهادتنا، فإن قالوا لم نعلم أنه يقتل بها، فإن كان ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار بقولهما، أو ممن يخفى عليه لقرب عهده بالإسلام فشبه عمد .

وتابع الشارح تفصيل كلام المصنف فقال: إذا كان الحابس لم يعلم الحال فليس بعمد بل هو شبه عمد في الأظهر، لأنه لم يقصد إهلاكه ولا أتى بما هو مهلك، كما لو دفعه دفعاً خفيفاً فسقط على سكين وراءه وهو جاهل فإنه لا قصاص .

ومقابل الأظهر هو عمد فيجب القصاص لحصول الهلاك به، كما لو ضرب المريض ضرباً يهلكه ولا يهلك الصحيح وهو جاهل بمرضه .

ويقوي ما قالوا بالأظهر وجهة نظرهم بالآتي:

بأن الضرب ليس من جنس المرض فيمكن إحالة الهلاك عليه والجوع من جنس الجوع، والقدر الذي يتعلق منه بصفة لا يمكن إحالة الهلاك عليه حتى لو ضعف من الجوع فضربه ضرباً يقتل مثله وجب القصاص ويترتب على قول الأظهر وجوب نصف دية شبه عمد لحصول الهلاك بالجوعين أو العطشين والذي منه أحدهما .

ثم تابع بيان الأحكام التي تتعلق بوجوب القصاص فقال: ويجب القصاص بالسبب قياساً على القتل بالمباشرة، لأن ماله دخل من الأفعال في الزهوق إما مباشرة، وهي ما يؤثر في الهلاك ويحصله كالجرح ففيها القصاص، وإما شرط وهو ما لا يؤثر في الهلاك ولا يحصله بل

يحصل التلف عنده بغيره، ويتوقف تأثير ذلك الغير عليه كالحفر مع التردّي، فإنه لا يؤثر في التلف ولا يحصله وإنما يؤثر التخطي في صوب الحفرة، والمحصل للتلف التردّي فيها ومصادمتها، لكن لولا الحفر لما حصل التلف، ولهذا سمى شرطاً، ومثله الإمساك للقاتل، وهذا لا قصاص فيه، وإما سبب وهو ما يؤثر في الهلاك ولا يحصله .

ووجه الحصر في ذلك أن الفاعل لا يخلو إما أن يقصد عين المجني عليه أولاً، فإن قصده بالفعل المؤدي إلى الهلاك بلا واسطة فهو المباشرة، وإن لأدى إليه بواسطة فهو السبب كالشهادة بموجب قصاص، وإن لم يقصد عين المجني عليه بالكلية فهو الشرط.

وبعد هذه المقدمة التفصيلية المتعلقة ببيان الفرق بين المباشرة والشرط والسبب نستطيع أن نقول:

إن السبب ينقسم إلى ثلاثة أضرب:

الأول: شرعي: كالشهادة ويقتص من شهود الزور بشرط .

الثاني: عرفي: كتحقديم مسموم لمن يأكله .

الثالث: حسي: كالإكراه على القتل .

ونلاحظ بأن كلاً من المصنف والشارع ذكر أمثلة تبرز من قتل بالسبب بأقسامه الثلاثة: فمثال القسم الأول: لو شهد رجلان على شخص عند قاض بقصاص أي بموجبه في نفس أو طرف، أو شهدا عليه بردة أو سرقة، فقتل المشهود عليه أو قطع بعد حكم القاضي بشهادتهما ثم رجعا عنها وقالا تعمدنا الكذب فيها وعلمنا أنه يقتل ويقطع بشهادتنا لزمهما القصاص، لأنهما تسببا في إهلاكه بما يقتل غالباً فأشبه ذلك الإكراه الحسي، بل هذا أبلغ من الإكراه، لأن المكره قد يؤثر هلاك نفسه على سفك دم محرم، والقاضي لا محيص له عن الحكم بشهادتهما .

أما إذا قال لا نعلم أنه يُقتل بشهادتنا، فإنه ينظر إن كان ممن يخفى عليهما ذلك لقرب عهدهما بالإسلام أو بعدهما عن العلماء لم يجب

عليهما القصاص، بل دية شبه عمد، أما إذا لم يخف عليهما ذلك فلا اعتبار بقولهما، كمن رمى سهماً إلى شخص واعترف بأنه قصده ولكنه قال: لم أعلم أنه يبلغه، فلا اعتبار بقوله ويقتص منه .

ثم استثنى من وجوب القصاص على الشاهدين قوله: إلا أن يعترف الولي أي ولي المقتول بعلمه بكذبهما في شهادتهما حين القتل، فلا قصاص عليهما، لأنهما لم يلجئا إلى قتله حساً ولا شرعاً، فصار قولهما شرطاً محضاً كالمسك مع القاتل، فيجب على الولي القصاص، لأنه أراد بشهادتهما قتله نكأه سهل عملية قتله بتركهما يكذبان وهو يعلم كذبهما .

ثم قال الشارح: إن الإمام النووي في الروضة وأصلها وهو كتاب العزيز للإمام الرافعي ذكر فيها كما هو في أصلها لفظة أو قيد: شهدا بقصاص وقالوا:

تعمدنا وعلمنا أنه يقتل بشهادتنا .

ولو ضيف بمسموم صبيّاً أو مجنوناً فأكله فمات، وجب القصاص وإن لم يقل هو مسموم، ولم يفرقوا بين المميز وغيره، ولا نظروا إلى أن عمده عمد، وللنظر فيه مجال كذا في الروضة كأصلها، وعن القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والمتولي وغيرهم تقييد الصبي بغير المميز .

وأيضاً لو ضيف بمسموم بالغاً عاقلاً ولم يعلم حال الطعام فأكله فمات فدية، وفي قول قصاص، وفي قول لا شيء لتناوله باختياره، والثاني قال: لتغيره والأول قال: يكفي في التغير الدية .

وبدأ الشارح في بيان القسم الثاني من أقسام القتل بالسبب وهو السبب العرفي فقال:

ولوضيف بمسموم يقتل غالباً صبيّاً غير مميز أو مجنوناً فأكله فمات منه وجب عليه القصاص وذلك لأنه ألجأه إلى ذلك، سواء قال له هو مسموم أم لا .

والتقييد في المسألة السابقة بكون الصبي غير مميز هو الراجح والمعتمد، وكذا المجنون يقيد بأن لا يكون له نوع تمييز، وكذا أعجمي أي عبد أعجمي يعتقد وجوب الطاعة لسيده، فإنه يقتضى بموتهم بهذا السم الذي قدمه .

والمرجوح الرأي الذي لم يفرق بين مميز وغيره، ولم ينظروا إلى أن المميز مطلقاً هو يقال في عمده عمد دون غير المميز، لأنه لا يعرف له قصد .

ومن ثم فإن موضوع المميز وغيره مجال للنظروالاجتهاد، وإن كان القاضي أبو الطيب في شرحه لمختصر المزني والماوردي في الحاوي، وابن الصباغ في الشامل، والمتولي في تنمة الإبانة قد ذهبوا إلى أن الحكم السابق وهو وجوب القصاص لمن قدم سماً قاتلاً لصبي غير مميز .

ثم ذكر صورة أخرى متعلقة بالسبب العرفي وهي لو ضيف بالسم بالغاً عاقلاً ولم يعلم الضيف حال الطعام فمات بأكله فعلى المضيف دية ولا قصاص، لأن تناوله باختياره من غير إلقاء وهذا

هو الرأي الأول في هذه المسألة .

(١) وفي قول يجب القصاص ورجحه البغوي في التهذيب وغيره، واستدل لهذا الرأي بقتله .
 ﷺ . اليهودية التي سمت له الشاه بخبيرلما مات بشر بن البراء بن معرور (١) .

وفي قول لا يجب شيئاً من قصاص أو دية تغليباً للمباشرة على السبب ويرى أصحاب القول الأول أن ما انتهوا إليه هو الأولى بالقبول وذلك للآتي .

ولو دُسَ سُمّاً . بالضم والفتح في طعام شخص الغالب أكله منه فأكله جاهلاً بالحال فمات، فعلى الأقوال، وجه الثاني التسبب والأول قال تكفي فيه الدية، وترك المجروح علاج جرح مهلك فمات وجب القصاص، ولا يمنع منه ترك العلاج لأن البرء غير موثوق به لو عالج، ولو ألقاه في ماء لا يُعد مغرقاً بسكون الغين كمنبسط فمكث فيه مضطجعاً أو مستلقياً حتى هلك فهدر، لأنه المهلك نفسه، أو مغرق لا يخلص منه إلا بسباحة .

١. الاستدلال الذي استدل به من قالوا بأنه يجب القصاص ضعيف، وذلك لأنها لم تقدم الشاه إلى الأضياف، بل بعثتها إليه . ﷺ . وهو أضاف أصحابه، وما هذا سبيله لا يلزمه قصاص

٢. وأيضاً لا ينافي القول بوجوب الدية ما في الصحيحين أنه . ﷺ . عفا عنها . لأن ذلك كان في الابتداء، فلما مات بشر أمر بقتلها .

٣. أيضاً قال: يكفي في التغرير الدية رداً على من قال بوجوب القصاص .

ثم تابع الشارح كلامه في عرض صور متعلقة بالسبب العرفي

فقال: ولو دُسَ سُمّاً . في طعام شخص أكله منه فأكله جاهلاً بالحال فمات، فيقال في هذه المسألة بالأقوال الثلاثة التي قيلت في المسألة السابقة، فالأول قال: يكفي فيه الدية، والثاني: القصاص ووجه التسبب، والثالث: لا شيء، وفي كل الأقوال يجب له قيمة الطعام لأن الداس أتلغه عليه .

(٣) أخرجه أبوداود في كتاب الديات برقم: ٤٥١١، ٤٥١٢، وأخرجه البيهقي في السنن في كتاب الجنائيات . ج ٨ ص

وكلام الشارح والمصنف مقيد بما ذكرناه، ومن ثمّ احترز بقوله: في طعام شخص عما إذا دسّه في طعام نفسه فأكل منه شخص عادته الدخول عليه فإنه هدر، لتعديه وهذا أيضاً يكون إذا كان أكله منه نادراً يكون هدرًا، أما لو كان عادته الدخول عليه والكل منه، ففيه الدية .

ثم تابع فقال: ولو ترك المجروح علاج جرح مهلك له فمات وجب القصاص جزماً على الجراح، لأن البرء غير موثوق به لو عولج، والجراحة في نفسها مُهلكة، أما ما لا يهلك كأن قصّده فلم يعصب العرق حتى مات فإنه لا ضمان، لأنه الذي قتل نفسه قياساً على ما لو حبسه وعنده ما يأكل فلم يفعل فلا ضمان .

وتابع فقال: ولو ألقاه في ماء راكد أو جار لا يُعد مغرقاً كمُنسبط فمكت فيه مضطجعاً أو جالساً أو مستلقياً حتى هلك فهدراً قصاص فيه ولا دية، لأنه المهلك نفسه .

أما إذا ألقاه في مثل هذا الماء مكتوفاً بحيث لا يمكنه التخلص فمات وجب القصاص . وأيضاً لو ألقى رجلاً أو صبياً مميزاً في ماء مغرق كنهراً مثلاً لا يخلص منه إلا بسباحة بكسر السين أي عوم، فإن لم يُحسنها أو كان مع إحسانها مكتوفاً أو زَمِناً فهلك فعمد وإن منع منها عارض كريح وموج فهلك فشبه عمد ففيه الدية، وإن أمكنته فتركها فهلك فلا دية في الأظهر، لأنه المهلك نفسه باعراضه عما يُنجيه .

والثاني يقول: قد يمنعه منها دهشة وعارض بطن ن أو في نار يمكن الخلاص منها فمكت فيها حتى هلك ففي الدية القولان أظهرهما عدم وجوبها، ولا قصاص في الصورتين، أي الماء والنار وفي النار وجه بوجوبه بناء على وجوب الدية بخلاف الماء،

والفرق أن النار تُؤثر، فأول المس جراحة يخاف منها بخلاف الماء

وقيل بوجوب القصاص فيه أيضاً .

أي بعوم، ننظر إن كان لم يُحسنها أو كان مع إحسانها مكتوفاً أو زَمِناً أو ضعيفاً فهلك بذلك فعمد فيه القصاص .

ويفهم كذلك من هذا أنالماء الذي لا يتوقع الخلاص منه بالسباحة كبحر أجيّ فيجب فيه القصاص سواء أكان يُحسن السباحة أم لا .

وأيضاً إن أمكنه التخلص بسباحة في ماء مغرق، ولكن منع منها عارض كريح وموج فهلك بسبب ذلك فشبع عمد يجب فيه الدية، أما إذا كان الريح أو غيره موجوداً عند الإلقاء فهو عمد يجب فيه القصاص، ويكون حاله كمن لا يُحسن السباحة.

مسألة: ما الحكم لو أمكنه السباحة ولا يوجد عارض خارجي إلا أنه تركها لعارض داخلي كغضب أو لجأاً ؟

فلا دية في الأظهر لأنه المهلك نفسه باعراضه عما ينجيه،

ومقابل الأظهر: تجب الدية، قياساً على العارض الخارجي، فقد منعه من السباحة دهشة أو عارض باطني .

ويترتب على ما سبق أنه لو شك في لإمكان تخلصه بأن قال المُلقي: كان يمكنه الخروج مما ألقته فيه فقصر، وقال الولي: لم يمكنه، صُدّقَ الولي بيمينه، لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج.

مسألة: ولو ألقاه في نار يمكن معها الخلاص منها فمكت فيها حتى مات ففي الدية القولان في الماء، والأظهر عدم الوجوب، ويعرف الإمكان بقوله أو بكونه على وجه الأرض وإلى جانبه أرض لا نار عليها، وإن اختلفا . المُلقي والولي . صُدّقَ الولي، لأن الظاهر أنه لو أمكنه الخروج لخرج، وقيل صُدّقَ المُلقي لأن الأصل براءة الذمة

ثم تابع بقوله: ولا قصاص في الصورتين وهما الإلقاء في الماء والإلقاء في النار لأنه الذي قتل نفسه وفي الإلقاء في النار وجه بوجوب القصاص بخلاف الماء، والفرق أن النار تحرق بأول ملاقاتها وتؤثر قروحات قاتلة بخلاف الماء .

وعلى القول بعدم القصاص أنه يجب على المُلقي أرش ما أثرت النار فيه من حين الإلقاء .

ولو أمسكه فقتله آخر أو حفر بئر فرداه فيها آخر أو ألقاه من شاهق أي مكان عال فتلقيه آخر فقدده أي قطعه بالسيف نصفين، فالقصاص على القاتل والمردى والقاد فقط، أي دون الممسك والحافر والملقي، ولو ألقاه في ماء مُغرق فالتقمة حوتوجب القصاص في الأظهر، لأن الإلقاء سبب للهلاك . والثاني تجب الدية لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد، أو غير مغرق فالتقمة الحوت فلا يجب قصاص قطعاً وتجب دية شبه العمد .

وذكر الشارح رأياً ثالثاً عبر عنه بقوله: وقيل بوجوب القصاص فيه أيضاً، لأن في الإلقاء في الماء قد تحدث الدهشة، فيموت بالإلقاء ذاته فيجب القصاص .

واحترز بقوله: يمكنه الخلاص منها . أي من النار. عما إذا لم يمكنه لعظمها أو لكونها في وهدة . أرض منخفضة أو واد صغير . أو كونه مكتوفاً أو زَمِناً أو صغيراً أو ضعيفاً فعليه القصاص .

فائدة: إذا اجتمعت المباشرة مع السبب أو الشرط فقد يغلب السبب المباشرة كما سبق في شهود الزور إذا اعترفوا بالتعمد والعلم، فإن القصاص عليهم دون الولي والقاضي الجاهلين بكذب الشهود، وتغلب المباشرة السبب والشرط كما في المسألة التي معنا وهي:

ولو أمسكه شخص فقتله آخر أو حفر بئر فرداه فيها آخر وكانت التردية تقتل غالباً، أو ألقاه من مكان عال فتلقيه آخر فقدده^(١) أي قطعه نصفين مثلاً قبل وصوله الأرض،، فالقصاص على القاتل في الصورة الأولى . أمسكه شخص فقتله آخر- وذلك لحديث: إذا أمسك الرجل الرجل حتى جاء آخر فقتله قُتل القاتل وحُبس الممسك^(٢) .

وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يُحد الزاني دونه، ويُعزر

الممسك لأنه آثم، وإن كان لا قصاص عليه ولا دية، ولهذا قال في الحديث:
وحُبس الممسك .

(٤) القد لغة: القطع طولاً .

(٥) أخرجه الدارقطني في السنن . كتاب الحدود والديات . ج٣ ص ١٤٠ .

ويُفهم من كلام المصنف والشارح أنه يُشترط في القاتل أن يكون مكلفاً، فلو أمسكه وعرضه لمجنون أو سبع ضار فقتله، فالقصاص

على الممسك قطعاً، لأنه يُعد قاتلاً عُرفاً .

وأيضاً يأخذ حكم القصاص المردى في الثانية أي في الصورة الثانية . تقديماً للمباشرة، لأن الحفر شرط ولا أثر له مع المباشرة، ويشترط لثبوت القصاص كون التردية يحصل منها القتل غالباً .

وأيضاً على القاد في الصورة الثالثة . لأن فعله قطع أثر السبب، ولا شيء على الملقى، ويُشترط لثبوت القصاص على القاد أن يكون مكلفاً، أما لو كان القاد مجنوناً ضارباً فالقصاص على الملقى .

مسألة: ولو ألقاه في ماء مغرق لا يمكنه الخلاص منه كُجبة البحر فالتقمه حوت ولوقبل الوصول إلى الماء وجب القصاص في الأظهر لأنه هلك بسبب الإلقاء .

ولو أكرهه على قتل فأتى به فعله أي المكره بكسر الراء القصاص وكذا على المكره بفتحها في الأظهر لأن الإكراه بقوله مثلاً: اقتل هذا وإلا قتلتك يُولد داعية القتل في المكره غالباً يدفع الهلاك عن نفسه وقد آثرها بالبقاء فهما شريكان في القتل، ومقابل الأظهر وجه بأن المكره آلة للمكره، ودفع بأنه آثم بالقتل قطعاً، فإن وجبت الدية بأن عفى عن القصاص إليها وُزعت عليهما .

ولا نظر إلى جهة الهلاك كما لو ألقاه في في بئر مهلكة في أسفلها سكين لم يعلم بها الملقى فهلك بها ومقابل الأظهر تجب الدية، لأن الهلاك من غير الوجه الذي قصد، فانتفض شبهة في نفي القصاص، قياساً على صورة الإلقاء من شاهق .

وواضح أن محل الخلاف ما لم يرفع الحوت رأسه ويلقمه، وإلا وجب القصاص قطعاً . ومحله أيضاً إذا لم يعلم بالحوت الذي في اللجة، فإن علم به وجب القود قطعاً، كما لو ألقاه على أسد في محل وجوده.

مسألة: لو ألقاه في ماء غير مغرق فالتقمه حوت ولم يعلم به الملقى، فلا قصاص قطعاً لأنه لم يقصد إهلاكه، ولم يشعر بسبب الإهلاك، كما لو دفعه دفعاً خفيفاً فوق على سكين فمات ولم يعلم بها الدافع، ويجب في الصورتين دية شبه عمد .

ثم شرع المصنف في الضرب الثالث وهو السبب الحسي فقال: ولو أكرهه على قتل لشخص بغير حق فقتله فعلى المكره . بكسر الراء القصاص، لأنه أهلكه بما يقصد به الإهلاك غالباً، فأشبهه ما لورماه بسهم فقتله، وكذا يجب القصاص على المكره بفتحها في الأظهر، لأنه قتله عمداً عدواناً لاستبقاء نفسه، فأشبهه ما لو قتله المضطر ليأكله، بل أولى لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل بخلاف المكره

ومقايب الأظهر لا قصاص عليه لحديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه (١)، ولأنه آلة المكره فصار كما لو ضربه به .

وقيل: لا قصاص على المكره . بكسر الراء . لأنه متسبب، بل على المكره . بفتحها . فقط لأنه مباشر والمباشرة مقدمة .

ثم بين المصنف والشارح الأثر المترتب على القول بوجوب القصاص، بأنه إذا عفا ولي الدم عن القصاص إلى الدية، فإنها تجب على المكره والمكره ووزعت عليهما بالسوية كالشريكين في القتل وللولي أن يقتص من أحدهما ويأخذ نصف الدية من الآخر وهذا في حالة ما إذا كافأه، أي كانا عبيد .

فإن كافأه أحدهما فقط فالقصاص عليه دون الآخر، فإذا أكره حُر عبداً أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد، ولو أكره بالغ مراهقاً على القتل ففعله، فعلى البالغ القصاص إن قلنا عمد الصبي عمد وهو الأظهر، فإن قلنا خطأ فلا قصاص على البالغ لأنه شريك مخطيء ولا قصاص على الصبي بحال، ولو أكره مراهق بالغاً على قتل فأتى به فلا قصاص على المراهق وعلى البالغ القصاص في الأظهر إن قلنا عمد الصبي عمد،

(١) أخرجه ابن ماجه في كتاب الطلاق . باب: طلاق المكره والناسي . برقم: (٢٠٤٥)

فإن قلنا خطأ فلا قصاص قطعاً، ولو أكره على رمي شاخص علم المكروه . بكسر الراء أنه رجل وظنه المكروه صيداً فرماه فمات فالأصح وجوب القصاص على المكروه بالكسر، ووجه المنع أنه شريك مخطيء، أو على رمي صيد فأصاب رجلاً فمات فلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم يتعمدا قتله .

ثم تابع المصنف والشارح في سرد الصور التي تتعلق بالسبب الحسي فقالا: فإن كافأه أي ساوى المقتول أحدهما فقط بأن كان المقتول ذمياً أو عبداً، وأحدهما كذلك، والآخر مسلم أو حر فالقصاص على المكافئ دون الآخر، فمثلاً إذا أكره حر عبداً أو عكسه على قتل عبد فقتله فالقصاص على العبد لأنهما كالشريكين، وشريك غير المكافئ يقتص منه كشريك الأب.

مسألة: ولو أكره بالغ مراحقاً على القتل ففعله، فعلى البالغ القصاص لوجود مقتضيه هو القتل المحض العدوان، وهذا مبني على القول بأن عمد الصبي عمد وهو الأظهر، وعلى الصبي نصف دية مغلظة، والقول بأن عمد الصبي عمد أي الذي له نوع تمييز . وإن قلنا خطأ فلا قصاص لأنه شريك مخطيء ولا قصاص على الصبي بحال لعدم تكليفه . ومحل الخلاف في عمد الصبي والمجنون، هل هو عمد أو خطأ إذا كان لهما نوع تمييز، وإلا فخطأ قطعاً .

مسألة: ولو أكره مكلفاً على رمي شاخص علم المكروه . بكسر الراء. أنه رجل وظنه المكروه . بفتحها . صيداً أو حجراً أو نحو ذلك فرماه فقتله، فالأصح وجوب القصاص على المكروه . بكسر الراء لأنه

قتله قاصداً للقتل بما يقتل غالباً دون المكروه . بفتحها . فإنه جاهل بالحال فكان كالآلة للمكروه . ومقابل الأصح: لا قصاص على المكروه أيضاً لأنه شريك مخطيء .

(**مسألة:** لو أكرهه علر رمي صيد فأصاب رجلاً أو غيره فمات فلا قصاص على أحد منهما لأنهما لم يتعمداه، ويجب على عاقلة كل منهما نصف الدية .

أو على صعود شجرة فلزق ومات فشبهه عمد، لأنه لا يقصد به القتل غالباً، وقيل هو عمد فيجب القصاص، أو على قتل نفسه بأن قال: اقتل نفسك وإلا قتلتك فقتل نفسه فلا قصاص في الأظهر، لأن ما

جرى ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره والثاني يمنع ذلك .

ولو قال اقتلني وإلا قتلتك فقتله المقول له، فالمذهب لا قصاص عليه للإذن في القتل، وفي قول من الطريق الثاني عليه القصاص بناء على أنه يثبت للوارث ابتداء، والأظهر على عدم القصاص لا دية، والثاني تجب بناء على أنها تثبت للوارث ابتداء، ولو قال: اقتل زيدا أو عمراً وإلا قتلتك فليس بإكراه، فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الأمر غير الإثم .

مسألة: لو أكرهه على صعود شجرة أو على نزول بئر فلزق فمات فشبهه عمد، لأنه لا يقصد به القتل غالباً، ويجب الدية على عاقلة المكره . بكسر الراء، وهو ما جزم به البغوي في التهذيب^(١)، على اعتبار أنه عمد خطأ، والأولى كما حكى ابن القبطان في فروعه نص الشافعي على أنها في ماله .

وقيل: هو عمد، وهذا هو رأي الغزالي، وعليه فيجب به القصاص لأنه تسبب إلى قتله فأشبهه ما لو رماه بسهم .

ومحل الخلاف فيما إذا كانت الشجرة مما ينزلق على مثلها غالباً، أما إذا كانت لا ينزلق على مثلها غالباً فلا يأتي هذا الخلاف، ويكون الحكم في هذه الحال خطأ .

مسألة: لو أكرهه على قتل نفسه بأن قال له: اقتل نفسك أو اشرب هذا السم وإلا قتلتك فقتلها، فلا قصاص في الأظهر، لأن هذا ليس بإكراه حقيقة لاتحاد المأمور به والمخوف به فكأنه اختاره، بعكس ما

لو قال له: اقطع طرف نفسك وإلا قتلتك كان إكراهاً قطعاً، وأيضاً لو هدده بقتل يتضمن تعذيباً كان إكراهاً أيضاً .

والثاني مقابل الأظهر: يجب القصاص قياساً على ما إذا أكرهه على قتل غيره .

ويترتب على الحكم بالأول: أنه لا شيء على الأمر من الدية كما

ذكره الرافعي في باب موجبات الدية، ورأي ابن المقري وجوب نصف الدية، ووجه الأول بأن القصاص إنما يسقط لانتفاء الإكراه فينتفي موجب، فلا يجب على فاعله شيء .

مسألة: ولو قال شخص لآخر: اقتلني وإلا قتلتك فقتله ذلك الشخص فالمذهب أنه لا قصاص على القاتل لأن الإذن شبهة دائرة للحد .

والطريق الثاني قولان: أحدهما موافق للأول، والثاني، يجب عليه القصاص لأن القتل لا يباح بالإذن وثبت للوارث ابتداء، فأشبه ما لو أذن له في الزنا بأتمته، فيجب عليه الحد .

ولكن اعترض على هذا بأن في التشبيه بالمرأة نظر، لأنه يفيد أنه في الحر يجب القصاص وفي الرقيق تجب القيمة، لأنه لا عبرة بإذنه في المال^(١) .

وعلى القول بعدم القصاص فلا تجب الدية أيضاً، بناء على أنها تثبت للمقتول في آخر جزء من حياته ثم تنتقل إلى الوارث وهذا على الأظهر ولهذا تنفذ منها وصاياه، وتُقضى منها ديونه ولو كانت للورثة ابتداء لم يكن كذلك .

ومقابل الأظهر: يجب ولا يؤثر إذنه، بناء على أنها تثبت للورثة ابتداءً عقب هلاك المقتول^(٢) .

مسألة: ولو قال لشخص: اقتل زيداً أو عمراً وإلا قتلتك فليس بإكراه حقيقية، فمن قتله منهما فهو مختار لقتله فيلزمه القصاص له ولا شيء على الأمر غير الإثم .

وقال القاضي حسين: هو إكراه، لأنه لا يتخلص إلا بقتل أحدهما فهو ملجأ إليه .

ويترتب على هذه المسائل: لو أمر السلطان شخصاً بقتل آخر بغير حق والمأمور لا يعلم ظلم السلطان ولا خطأه وجب القود أو الدية أو الكفارة على السلطان، ولا شيء على المأمور، لأنه آتته، ولا بد منه في السياسة، ويُسن للمأمور أن يكفر لمباشرة القتل .

(٢) حاشية قليوبي . ج٤ ص ١٠٣ .

(٣) مغني المحتاج . ج٤ ص ١٧ .

وإن علم بظلمه أو خطئه وجب القود على المأمور إن لم يخف قهره بالبطش بما يحصل به الإكراه، لأنه لا يجوز طاعته حينئذ كما في الحديث الصحيح^(١).

فصار كما لو قتله بغير إذن، فلا شيء على السلطان إلا الإثم فيما إذا كان ظالماً .

أما إذا اعتقد وجوب طاعته في المعصية فالضمان على الإمام لا عليه، لأن ذلك مما يخفى، أما إن خاف قهره فكالمرء، فالضمان بالقصاص وغيره عليهما .

فصل في الجناية من اثنين^(٢)

إذا وجد من شخصين معاً فعلاً مذهباً للروح مذفبان بالمعجزة والمهملة أي مسرعان للقتل كحز للرقبة وقد للجثة أو لا أي غير مذفين كقطع عضوين مات منهما فقاتلان فعليهما القصاص وإن كان أحدهما مذفبان دون الآخر فقياس ما سيأتي أن المذنب هو القاتل كذا في الروضة كأصلها، وإن أنهاه رجل إلى حركة مذبح بأن لم يبق أبصار ونطق وحركة اختيار ثم جنى آخر فالأولقاتل لأنه صيره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني لهلكته حرمة ميت .

بدأ المصنف والشارح بأحكام تتعلق بالجناية من اثنين، ومن بين هذه الأحكام ما يلي:

مسألة: إذا وجد من شخصين فعلاً حال كونهما معاً مجتمعين في زمن واحد مذهباً للروح، وهما مذفبان كحز للرقبة وقد للجثة، أو لا أي غير مذفين كقطع عضوين ومات منهما فالحكم في هذه الحال أنهما قاتلان يجب عليهما القصاص، وكذا الدية إذا وجبت لوجوب السبب منهما .

ومحل هذا الكلام أنه لو كان أحدهما مذفباً دون الآخر، كان المذنب هو القاتل وهو كذلك^(٣).

(١) الحديث قال ﷺ: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وأوكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر

بمعصية فلا سمع ولا طاعة. أخرجه مسلم في كتاب الإمارة برقم: (٤٧٤٠) .

(٢) هذا الفصل عقد لبيان طريقتي المباشرة على المباشرة والسبب على السبب، والحكم فيهما تقديم

الأقوى، والتسوية بين المتعادلين. حاشية عميرة على كنز الراغبين، ج٤ ص١٠٣ .

(٣) التهذيب، ج٧ ص٤٥ .

مسألة: ما الحكم إن لم يوجد الفعلان معاً بالوصف السابق، بل ترتبا، بأن أنهاء رجل مثلاً إلى حركة مذبوح، بأن لم يبق معها إبصار ولا نطق اختياري ولا حركة اختيار، وهي التي يبقى معها الإدراك وهي المستقرة، ثم إن جنى عليه شخص آخر عليه بعد الانتهاء لحركة مذبوح ن فيكون الأول منهما قاتل لأنه صيره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني منهما لهتكه حرمة الميت، كما لو قطع عضواً من ميت^(١)

وإن جنى الثاني قبل الإنهاء إليها، فإن ذفف كحز بعد جرح فالثاني قاتل، وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال، ولا نظر إلى سرية الجرح لولا الحز لاستقرار الحياة عنده، وإلا أي وإن لم يذفف الثاني أيضاً ومات المجنى عليه بالجنايتين كأن أجافاً أو قطع الأول يده من الكوع، والثاني من المرفق فقاتلان بطريق السرية، ولو قتل مريضاً في النزاع وعيشه عيش مذبوح وجب بقتله القصاص لأنه قد يعيش بخلاف من وصل بالجناية إلى حركة مذبوح .

ثم تابع المصنف والشارح بعرض بعض الصور التي من الممكن أن تحدث الجناية من اثنين ومنها ما يلي:

مسألة: ما الحكم إن جنى شخص آخر عليه بعد الانتهاء لحركة مذبوح، فالأول منهما قاتل لأنه صيره إلى حالة الموت، ويعزر الثاني منهما لهتكه حرمة الميت، كما لو قطع عضواً من ميت، ولكن إن جنى الثاني منهما قبل الإنهاء لحركة مذبوح، فالأول مذبوح، فإن ذفف الثاني كحز للرقبة بعد جرح سابق من الأول فالثاني قاتل، فعليه القصاص، لأن الجرح إنما يقتل بالسرية، وحز الرقبة بقطع أثرها، ولا فرق بين أن يتوقع البرء من الجراحة السابقة أن يتيقن الهلاك بها بعد يوم أو أيام، لأن له في الحال حياة مستقرة، وقد عهد عمر . رضى الله عنه . في هذه الحالة وعمل بعهد ووصاياه .

وعلى الأول قصاص العضو أو مال بحسب الحال من عمداً أو غيره، وإلا أي وإن لم يذفف الثاني أيضاً، كأن قطع الأول يده من الكوع والثاني من المرفق ومات المجني عليه بسرابة القطعتين فقاتلان بطريق السراية، ولا يقال إن أثر القطع الثاني أزال أثرالقطع الأول^(١)

مسألة: ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب بقتله القصاص، لأنه قد يعيش، إذ موته غير محقق، لأن المريض لو

انتهى إلى سكرات الموت وبدأت مخايله . أي صورته . فلا يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود، ولكنهم فرّقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحالة غير مقطوع به، وقد يظن ذلك ثم يشفى، بخلاف المقدود ومن في معناه، ولأن المريض لم يسبق فيه فعل بحال القتل وأحكامه حتى يهدر الفعل الثاني^(٢).

(٣) مغني المحتاج. ج٤ ص١٩٠ .

(١) التهذيب. البغوي. ج٧ ص٤٥٠ .

ثانيًا: (الدراسة الموضوعية)

إعداد

أ. د/ إبراهيم عبد الواحد السمان

أ. د/ أحمد محمد برج

أستاذ الفقه المساعد بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

رئيس قسم الفقه بكلية الشريعة والقانون بدمنهور

١٤٤٥ هـ - ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م

تقديم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، علمنا الهدى ودين الحق، والهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين.

أما بعد:

فهذه دراسة يسيرة في بعض موضوعات الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي، غالبها متعلق بفقه الأسرة، أردنا من خلالها أن يقف الطالب على ما رسمه الفقهاء واستنبطوه من أحكام تعالج قضايا الأسرة، فيعلموا ويعلموا غيرهم بعبارة يسيرة، وأسلوب سهل.

كما راعينا في اختيارنا للموضوعات أن تكون أحكامها فيما يحتاجه الناس في حياتهم اليومية فيتأثر بها الطلاب فينفعلوا بها ويتفاعلوا معها، من خلال التطبيق العملي لها، الأمر الذي يكسبهم مهارة الفتيا والتطبيق، وهذا مقصد أساسي من دراسة الفقه.

الله نسأل أن يوفق الطلاب لما فيه خدمة الدين والدنيا، إنه نعم المولى والنصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الوحدة الأولى

مبادئ النكاح ومقدماته.

محتويات الوحدة:

الدرس الأول: تعريف النكاح.

الدرس الثاني: حكم النكاح.

الدرس الثالث: حكمة مشروعية النكاح.

الدرس الرابع: ما يستحب في النكاح.

الدرس الخامس: نظر مريد النكاح إلى المرأة.

الدرس السادس: الخطبة، تعريفها، ودليل مشروعيته، وحكمها بالنظر إلى حال المرأة.

الدرس السابع: حكم الخطبة على الخطبة.

الدرس الثامن: أمور متعلقة بالخطبة والنكاح.

الدرس التاسع: أركان عقد النكاح وبيان كل ركن وشروطه.

أهداف الوحدة تتمثل فيما يلي:-

- ١ - إبراز أحكام النكاح بداية بتعريفه، وحكمه وحكمة مشروعيته.
- ٢ - الإلمام بالأدلة التي تثبت مشروعية النكاح.
- ٣ - إظهار بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالنكاح، ومدى ارتباطها بالواقع المعاصر.
- ٤ - بيان الأحكام الشائكة في موضوع النكاح كي يسهل الأمر على طلاب العلم عند تعرضهم لمثل هذه المسائل.

أهمية الزواج في الإسلام:

لقد ركب الله في الإنسان ميله إلى متع الدنيا، قال الله عز وجل: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ} (١).

هذا الطبيعة الجبلية، والفطرة الإنسانية، أقرتها شريعة الإسلام وقننتها، وراعتها في تشريعاتها لأبناء المنهج الرباني، فبعد أن منع بعض أتباع الشرائع السابقة من تلك الغريزة الإنسانية، وصاروا رهبانا لا يحل لهم أن يتمتعوا بشهوة الميل إلى النساء، جاء الإسلام ليرفع الإصر والمعاناة عن عباد الله الصالحين، حتى لا يحرموا متاع الدنيا مع نعيم الآخرة، وحتى تستقر نفوس العباد، وتنهأ أفئدتهم بالتمتع بما أحله الله لهم، وبما يوافق فطرتهم التي فطرهم الله عليها، فيؤكد رسول الله ﷺ هذا المعنى، ويقول: «تَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَّةِ النَّصَارَى» (٢)، بل ويخبر أن الزواج من سنته الشريفة فقال: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (٣).

وقال أيضا: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطَّيِّبُ، وَجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» (٤).

فكان من أجل نعمة الله على أتباع الدين الحق، أن أباح لهم النكاح.

قال الله عز وجل ممتنا على عباده: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ} (٢٠) وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} (٥).

(١) سورة آل عمران من آية ١٤.

(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب الرغبة في النكاح، رقم ١٣٨٣٩.

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح، رقم ٤٧٧٦. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تافت نفسه إليه ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم ١٤٠١ هـ.

(٤) رواه الإمام النسائي في سننه الصغرى، كتاب عشرة النساء، باب حب النساء، ٣٩٣٩.

(٥) سورة الروم آية ٢١.

والإسلام بتشريعه حريص على أن يبني المجتمع بناء قويا متماسكا طاهرا؛ لذا أمر ببناء الأسر التي لا سبيل لبنائها بناء متكاملا قويا مترابطا إلا عن طريق إشباع الغريزة الفطرية التي بين الرجل والمرأة، وهي ميل كل منهما للآخر، والذي لا يتم إلا عن طريق النكاح، والزواج، فحسب، حتى تنشأ أجيال معلومة النسب والعصبية، حتى تتربط هذه الأجيال ترابطا حميميا ناشئا عن استقرار أسرة نفسيا، واجتماعيا، ودينيا. لذا كان النكاح المشروع في الإسلام متوافقا مع الفطرة السليمة، والغريزة الإنسانية، وأما إخراج تلك الفطرة عن إطارها، فهو سبب لانهايار المجتمع وتفككه، واختلاط للأنسب، وتعدي على حرمان الله عز وجل؛ لذا فالعاقبة تكون وخيمة، خسرانا مبينا، وندامة شديدة. لقد نهى الله عز وجل عن أي علاقة بين رجل وامرأة تتم في خارج إطار النكاح الشرعي أو التسري، وتوعد فاعله بالعقاب الشديد، وبالعذاب الأليم، قال الله عز وجل: {وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا}(١).

(١) سورة الإسراء آية ٣٢.

الدرس الأول: تعريف النكاح.

قبل أن أخوض في سرد النكاح، وحكمه، ومستحباته، أتطرق إلى تعريفه اللغوي والشرعي؛ ليكون مدخلا إلى استيعابه على الوجه الأكمل.

النكاح لغة: هو الضم والجمع (١).

وشرعا: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته (٢).

شرح التعريف: فكلمة "عقد": جنس في التعريف يشمل كل عقد، سواء عقود المعاوضات كعقد البيع، والسلم، والوكالة، أو عقود التبرعات كالهبة بلا ثواب، ولفظ "إباحة وطء": خرج به كل العقود عدا عقد النكاح، لأنها لا تتضمن إباحة وطء، والقول "بلفظ إنكاح" إلى آخره: قيد في التعريف يشمل ركن النكاح (الصيغة).

هل لفظ النكاح حقيقة في العقد، أو الوطء (٣)؟ لفقاء الشافعية في هذه المسألة ثلاثة أوجه:

الأول وهو الأصح عندهم: أن النكاح حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. الثاني: النكاح حقيقة في الوطء، مجاز في العقد، وهو رأي الحنفية. الثالث: النكاح حقيقة في العقد والوطء معا، والقرينة هي التي تحدد المعنى المراد.

(١) طلبية الطلبة لنجم الدين النسفي "٣٨/١"، ط المطبعة العامرة، مكتبة المثنى ببغداد، التعريفات للجرجاني "٢٤٦" ط دار الكتب العلمية-بيروت، ١٤١٣هـ.

(٢) مغني المحتاج للخطيب الشربيني "٢٠٠/٤" ط دار الكتب العلمية، ١٤١٥هـ، وحاشية قليوبي "٢٠٧/٦" ط دار الفكر-بيروت، ١٤١٥هـ.

(٣) المراد بكلمة الحقيقة: أي أنه إذا أطلق لفظ النكاح فبمجرد ذكره، فإن الذهن ينصرف إلى معنى العقد أو الوطء، فإن رجح أنه ينصرف إلى معنى العقد، فأى لفظ نكاح في الكتاب والسنة معناه عقد النكاح، ولا نحمل اللفظ على الوطء إلا إذا كانت هناك قرينة في سياق الكلام تدل على أن المقصود من اللفظ الوطء، وليس حقيقة اللفظ الأصلية التي هي العقد. والعكس.

الدرس الثاني: حكم النكاح.

النكاح جائز عند الشافعية. قال إمام الحرمين "والنكاح على الجملة مرغوب فيه" (١).

وقال الشيرازي "النكاح جائز" (٢). وقال العمراني "النكاح جائز" (٣).

دل على جوازه الكتاب، والسنة، والإجماع: أما الكتاب فأيات منها:

قوله تعالى: {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٤). وجه الدلالة: من وجهين: أحدهما: أنه تعالى علق النكاح بطيب النفس، ولو كان لازماً واجبا للزم بكل حال. والثاني: قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٥)؛ فخير بين النكاح وملك اليمين والتخير بين أمرين يقتضي تساوي حكمهما، فلما كان ملك اليمين مباحا ليس بواجب كان النكاح بمثابة (٦).

أما السنة فأحاديث منها: ١ - قوله ﷺ: «تَتَاكَحُّوا تَكْثُرُوا» (٧).

(١) نهاية المطلب "٢٥/١٢" ط دار المنهاج، ١٤٢٨هـ.

(٢) المهذب "٤٢٣/٢" ط دار الكتب العلمية-بيروت.

(٣) البيان "١٠٥/٩" ط دار المنهاج، ١٤٢٨هـ.

(٤) سورة النساء من آية ٣.

(٥) سورة النساء من آية ٣.

(٦) الحاوي الكبير "٣١/٩".

(٧) رواه عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن أبي هلال مرسلا، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، رقم ١٠٣٩١ (١٧٣/٦)، وعزاه ابن حجر للدلي في مسند الفردوس من طريق عبد الله بن عمر، وهو حديث ضعيف ذكر ابن السبكي في الطبقات أنه لا أصل له، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير، وعزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى أبي بكر بن مردويه في تفسيره وضعفه، ويغني عنه أحاديث أخر.

قال في البدر المنير: ذكره البيهقي في المعرفة عن الشافعي بلاغا، وكذا هو في الأم والمختصر، ورواه ابن ماجه في سننه مسندا من حديث أبي هريرة مرفوعا: «انكحوا فإني مكاتبكم».

وفي إسناده: طلحة بن عمرو، وقد ضعفه، ويغني أحاديث أخر صحيحة في معناه: منها: حديث معقل بن يسار رفعه: «تزوجوا الولود الودود فإني مكاتبكم الأمم»، أخرجه أبو داود، والنسائي "اه بتصرف".

٢- وقوله ﷺ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ» (١).

٣- وقوله ﷺ: «مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَأَةً صَالِحَةً، فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي الشَّطْرِ الثَّانِي» (٢). ٤- في الصحيحين: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ» (٣)، (٤).

أما الإجماع: فقد أجمعت الأمة على مشروعية النكاح، دون أن يخالف أحد في ذلك.

قال العمراني: "وأجمعت الأمة: على جواز النكاح" (٥). قال الرافعي: "الأصل في النكاح بعد إجماع أهل الملل....." (٦). قال الخطيب الشربيني: "والأصل في حله الكتاب والسنة وإجماع الأمة" (٧). هذا هو الأصل في حكم النكاح، إلا أنه تعتريه الأحكام التكليفية الخمسة، بحسب حالة كل إنسان، ومدى حاجته للزواج من عدمها، ومدى قدرته على الوفاء بحقوق الزواج من عدمها؛ لذا فتارة يكون الزواج واجبا، وتارة يكون مسنونا مستحبا، وتارة يكون حراما، وتارة يكون مكروها.

(طبقات الشافعية الكبرى ٦/٣٠٩. التلخيص الحبير، ٣/٢٥٠، وما بعدها. المغني عن حمل الأسفار، للإمام أبي الفضل العراقي، ١/٣٦٩، ط: مكتبة طبرية، الرياض. البدر المنير ٧/٤٢٣، وما بعدها)

(١) مستخرج أبي نعيم على صحيح مسلم، ٣٤٤٢.

(٢) رواه الحاكم في مستدركه، كتاب النكاح، ٢٦٨١، وصحح إسناده وتابعه الذهبي.

(٣) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج) وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح، رقم ٤٧٧٨، ٥/١٩٥٠. ومسلم كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم رقم ١٤٠٠، ٢/١٠١٨.

(٤) ينظر الحاوي الكبير "٣١/٩"، نهاية المطلب "٢٥/١٢"، البيان "١٠٥/٩"، فتح العزيز للرافعي "٤٢٦/٧" ط دارالكتب العلمية- بيروت، مغني المحتاج "٢٠١/٤".

(٥) البيان "١٠٦/٩".

(٦) فتح العزيز "٤٢٦/٧".

(٧) مغني المحتاج "٢٠١/٤".

١- فيكون الزواج واجبا بحيث يأثم الإنسان لو ترك الزواج، إن هو كان قادرا على الزواج، وسيقع يقينا في الحرام أو غلب على ظنه الوقوع في الحرام إن لم يتزوج، وقتئذ تعين عليه الزواج، وذلك لأن ترك الحرام واجب، وما يؤدي إلى الواجب فهو واجب (١).

قال في المجموع: "قال أبو عوانة الإسفرائيني من محدثي أصحاب الشافعي: (إنه يجب للتائق إليه القادر على مؤنته) (٢). وقال أيضا: "وقال الماوردي من أصحابنا: الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب، وقد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به" (٣). وقال شمس الدين الرملي: "نعم لو خاف العنت وتعين طريقا لدفعه مع قدرته وجب" (٤).

٢- ويكون الزواج مسنونا مستحبا، وذلك إذا كانت تشتهيه نفس الإنسان، ويجد أهبتها - وهو المهر والنفقة وما يحتاج إليه، وذلك استدلالا بالسنة، والمعقول:

أما السنة، فمنها: أ- ما روي: أن النبي -ﷺ- قال: «يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة.. فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع.. فعليه بالصوم، فإنه له وجاء». وجه الدلالة: جاء في البيان: "أصل الباءة الجماع، والمراد بالباءة المذكورة في الخبر: المال الذي يملك به الجماع - وهو المهر، والنفقة - فسماه باسم سببه. وأراد: من استطاع منكم المال الذي يتوصل به إلى الباءة.. فليتزوج؛ لأنه قال: «ومن لم يستطع.. فعليه بالصوم» أي: ومن لم يستطع المال، ونفسه تتوق إلى الجماع.. فعليه بالصوم، ليكون له وجاء. يقال للفحل إذا رضت أنثياه: قد وجئ وجاء، يعني: أنه قطع النكاح، لأن الموجوء لا يضرب، فلو كان المراد بالباءة المذكورة في الخبر الجماع.. لم يأمر بالصوم من لا يستطيعه ليكون له وجاء؛ لأنه لا يحتاج إلى ذلك" (٥).

(١) المجموع شرح المذهب "١٢٩/١٦" ط دار الفكر.

(٢) المجموع "١٣٢/١٦".

(٣) المرجع السابق.

(٤) نهاية المحتاج "١٨١/٦".

(٥) ينظر البيان "١١٠/٩-١١١".

ب- وقال سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «لَقَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ...» (١). وجه الدلالة: أن التبتل هو ترك النكاح، فلما كان النهي عنه، دل ذلك بالمفهوم الأمر بالنكاح، وهو دليل الاستحباب، لأنه ثبت أن الأمر ليس للوجوب بقريضة أن بعض الصحابة لم يتزوجوا، مع إقرار النبي ﷺ لحالهم، فدل ذلك على ندب الزواج. ج- ولقوله ﷺ: «لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْفُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي» (٢).

أما المعقول فمنه: أ- أن في النكاح بقاء النسل، وحفظ النسب، والاستعانة على المصالح (٣). ب- ولأن هذا القادر على الزواج إذا لم يتزوج لم يأمن مواقعة الفجور (٤).

٣- أما من تتوق نفسه إلى الجماع، ولا يقدر على المهر والنفقة.. فالمستحب له: أن لا يتزوج، بل يتعاهد نفسه بالصوم، وذلك استدلالاً بالقرآن، والسنة، والمعقول:

أما القرآن: فقوله تعالى: {وَلْيَسْتَغْفِرِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} (٥).

وجه الدلالة: أن الله عز وجل حث من لا يستطيع النكاح على الاستغفار والتغلب على الفاحشة حتى يرزقه الله القدرة على الوفاء بمستلزمات النكاح وواجباته، فدل ذلك على عدم الاستحباب له أن يتزوج في حال عدم قدرته (٦).

أما السنة: فلقوله ﷺ: «ومن لم يستطع.. فعليه بالصوم، فإنه له وجاء».

(١) سنن ابن ماجه، النكاح، باب النهي عن التبتل، ١٨٤٨، وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح.

(٢) سبق تخريجه، وانظر: الحاوي "٣١/٩".

(٣) مغني المحتاج "٢٠٣/٤".

(٤) ينظر الحاوي "٣١/٩"، نهاية المطلب "٢٦/١٢"، البيان "١١٠/٩-١١٤"، فتح العزيز "٤٦٤/٧"، مغني المحتاج "٢٠٣/٤".

(٥) سورة النور من آية ٣٣.

(٦) ينظر مغني المحتاج "٢٠٤/٤".

وجه الدلالة: أن من لم يستطع الباءة لعجزه عنها فعليه بالصوم، وإنما قدره بذلك؛ لأن من لم يستطع الجماع لعدم شهوته لا يحتاج إلى الصوم لدفعها، فعلم من ذلك أن الأفضل والمستحب له ترك الزواج، وكسر شهوته بالصوم (١).

أما المعقول فمن وجهين: أ- لأن المتزوج ولا يجد قدرة على أداء الحق الذي عليه يشغل ذمته بالمهر والنفقة، ففيه ضرر عليه كبير، وتقريط فيما يجب عليه (٢). ب- ولأنه إن تزوج ولا أهبة له، فقد يجبر ذلك خلا في دينه (٣). ٤- ويكون الزواج مكروها في حالة ما إذا كان الإنسان لا تتوق نفسه إلى الجماع من أصل الخلقة، أو لعارض، كمرض، أو عجز، ولا يجد أهبة الزواج، وذلك استدلالا بالآتي: أ- لما فيه من الالتزام بما لا يقدر على الوفاء بمقتضاه، من غير حاجة (٤). ب- ولأنه لو كان عاجزا عن الجماع لأدى ذلك إلى منع المرأة من التحصيل (٥). قال الماوردي: "وفي مثله وردت أخبار الكراهة، وقد أثنى الله تعالى على يحيى بن زكريا في ترك النساء فقال: (وسيدا وحسورا) (٦) وفيه تأويلان:

أحدهما: أن السيد الخليفة والحصور الذي لا يأتي النساء، وهذا قول قتادة. والثاني: أن السيد الفقيه، والحصور الذي لا يقدر على إتيان النساء، وهذا قول سعيد بن المسيب وذكر الله تعالى: ﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ﴾ (٧) والقواعد: "هن اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل، فلا يردن الرجال، ولا يريدن الرجال" (٨).

(١) فتح العزيز "٤٦٤/٧"، مغني المحتاج "٢٠٣/٤".

(٢) البيان "١١٣/٩"، المجموع "١٣١/١٦".

(٣) نهاية المطلب "٢٧/١٢".

(٤) فتح العزيز "٤٦٥/٧".

(٥) مغني المحتاج "٢٠٥/٤".

(٦) سورة آل عمران من أية ٣٩.

(٧) سورة النور من أية ٦٠.

(٨) الحاوي "٣٣/٩".

أما من لا تتوق نفسه إلى الجماع، وهو قادر على المهر والنفقة، ولا يريد العبادة.. فهل يستحب له أن يتزوج؟ اختلف فقهاء الشافعية فيه على قولين: الأول: لا يستحب له أن يتزوج، وصححه العمراني: وذلك للآتي:

أ- لما روي: أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي الزوائد: (نكحت؟ قال: لا، فقال: ما يمنعك منه إلا عجز، أو فجور). ب- ولأنه يشغل ذمته بما لا حاجة به إليه (١).

والثاني: يستحب له أن يتزوج، وصححه الماوردي، والرافعي، والخطيب الشربيني، وذلك للآتي: أ- لقوله ﷺ: «لَكَيْتِ أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي». ب- ولأن النكاح أفضل شيء يشغل به الإنسان عن الحرص في الدنيا. ج- ولطلب الولد، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» (٢). قال ابن المسيب: إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من بعده. د- ولئلا تقضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش (٣). ٦- أما إن كان لا تتوق نفسه للجماع، وعنده القدرة ويجد الأهبة، ولكنه مشغول بالعبادة، فلا يستحب له الزواج اتفاقا عند الشافعية، وانشغاله بالعبادة أولى، وأفضل، وفي معنى التخلي لعبادة التخلي للاشتغال بالعلم (٤)، وذلك للآتي: أ- لأن ذات العبادة أفضل من ذات النكاح قطعاً (٥). ب- ولأنه يلزم ذمته حقوقاً هو مستغني عن أدائها (٦).

٧- ويكون الزواج حراماً، في حالة ما إذا تأكد الرجل أنه بزواجه سيقع في الحرام، كتركه العدل بين الزوجات، أو عدم الإنفاق والقيام بحقوق الزوجية، أو الوقوع في محظور شرعي.

(١) البيان "١١٤/٩".

(٢) رواه الجماعة إلا البخاري، وانظر: الحاوي "٣٣/٩".

(٣) فتح العزيز "٤٦٥/٧"، مغني المحتاج "٢٠٥/٤".

(٤) ينظر الحاوي "٣٣/٩"، فتح العزيز "٤٦٥/٧"، المجموع "١٣١/١٦"، مغني المحتاج "٢٠٥/٤".

(٥) نهاية المحتاج "١٨٣/٦".

(٦) البيان "١١٣/٩".

الدرس الثالث: حكمة مشروعية النكاح.

إن الله عز وجل شرع النكاح لأمر عدة؛ منها: حفظ النسل، فكيف نحفظ نسل البشرية إلا بالتزاوج الذي يتم بين الذكر والأنثى، قال الله تعالى: {وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}(١). فلو لم يكن تزاوج بين الرجل والمرأة لانقرضت البشرية، ولانتهت، ولم يعد لبني آدم أثر، فالزواج يحفظ البشرية، وهو المعين لاستمرارها.

إخراج الماء الذي يضر احتباسه، فإن تركيب جسد الإنسان يحتوي على المنى الذي خلق في الإنسان ليقذف في رحم المرأة، فإن حبس، فإن ذلك يضر بالإنسان ضرراً بالغاً، والضرر مرفوع، ومزال من قبل الشريعة، فشرع الله النكاح ليخرج الماء، ولا يتضرر الجسد، فضلاً عن أن هذا الماء دافع للشهوة، فكيف تقضى إن لم يكن النكاح؟ يقول الدهلوي: "اعلم أن المنى إذا كثرت توالده في البدن صعد بخاره إلى الدماغ، فحبب إليه النظر إلى المرأة الجميلة، وشغف قلبه حبها، ونزل قسط منه إلى الفرج، فحصل الشبق، واشتدت الغلظة، وأكثر ما يكون ذلك في وقت الشباب، وهذا حجاب عظيم من حجب الطبيعة يمنعه من الإمعان في الإحسان، ويهيجه إلى الزنا، ويفسد عليه الأخلاق، ويوقعه في مهالك عظيمة من فساد ذات البين، فوجب إمطة هذا الحجاب"(٢).

نيل اللذة، فالشريعة السمحة ليست ضد متعة الحياة الدنيا، قال الله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ}(٣)، بل هي قننت تلك المتعة ووضعتها في إطارها، وضبطتها حتى تكفل النظام العام، وتحافظ على استقرار، وسلامة المجتمع، فشرع الزواج لكي يتلذذ الإنسان بالحلال ويستمتع به، ويقضي طوره وشهوته، وهذه هي التي في الجنة إذ لا تناسل هناك ولا احتباس.(٤)

(١) سورة الذاريات آية ٤٩.

(٢) حجة الله البالغة لشاه ولي الله الدهلوي "١٨٩/٢" ط دار الجيل-بيروت، ١٤٢٦هـ.

(٣) سورة الأعراف من آية ٣٢.

(٤) أسنى المطالب شرح روض الطالب "٩٨/٣" ط دار الكتاب الإسلامي، مغني المحتاج "٢٠١/٤".

الوصول إلى المودة والرحمة، التي تستقر بها النفس، ويطمئن بها القلب، ويسعد بها الإنسان، حتى تنطبع على جوارح الرجل والمرأة طوابع السكينة والهدوء، فيكون المجتمع مسالما مستقرا متراحما.

الدرس الرابع: ما يستحب في النكاح

إن الإسلام حريص على أن يحيى الفرد حياة كريمة طيبة، حياة يصل فيها إلى الاستقرار النفسي، والمودة والرحمة التي جعلهم الله في الزواج، ومعلوم أن الأرواح تتألف وتتأفر كما قال ﷺ: «الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا انْتَلَفَ، وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ» (١)، والإنسان بفطرته يحب الشيء الحسن، والمتاع الحسن، وخير المتاع المرأة؛ لذا حث الإسلام الرجل على أن يتخير أوجه الجمال والخلق والدين والنعمة الدنيوية في المرأة التي ستشاركه حياته، وسيحيى معها، حتى يتحقق الهدف الأسمى والحكمة المرجوة من الزواج، والمتتبع لكتب السادة الشافعية يجد أنهم قد استخلصوا من أحاديث رسول الله ﷺ بعضا من المستحبات التي يستحب للرجل أن يأخذ بها وهو يختار شريكة عمره، فشرعوا في تبين الصفات المطلوبة في المنكوحة على النحو التالي:

يستحب للرجل أن يختار صاحبة الدين والخلق (٢)؛

لحديث رسول الله ﷺ: «تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَلِجَمَالِهَا وَدِينِهَا فَظَفَرُ بَذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ» (٣)

وجه الدلالة: قال في البيان: "يقال للرجل إذا قل ماله: ترب، أي: افتقر حتى لصق بالتراب. قال الله تعالى: {أَوْ مُسْكِينًا ذَا مَثْرَبَةٍ} (٤). ولم يتعمد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- الدعاء

(١) صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب الأرواح جنود مجندة، ٢٦٣٨، ١٥٩.

(٢) ينظر نهاية المطلب "٢٧/١٢"، البيان "١١٥/٩"، مغني المحتاج "٢٠٦/٤" نهاية المحتاج "١٨٤/٦".

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم ٤٨٠٢، ١٩٥٨/٥، ورواه مسلم في صحيحه،

كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح ذات الدين رقم ٥٣ (١٤٦٦)، ١٠٨٦/٢.

(٤) سورة البلد آية ١٦.

عليه بالفقر، ولكنها كلمة جارية على السنة العرب، يقولونها وهم لا يريدون وقوع الأمر" (١)، فدل ذلك على استحباب اختيار الدينة.

قال الشوكاني معلقا على الحديث: "(فاظفر بذات الدين) فيه دليل على أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره في كل شيء لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة، وقد وقع في حديث عبد الله بن عمرو عند ابن ماجه والبخاري والبيهقي رفعه: «لَا تَزَوَّجُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ، فَعَسَى حُسْنُهُنَّ أَنْ يُزْدِيَهُنَّ، وَلَا تَزَوَّجُوهُنَّ لِأَمْوَالِهِنَّ، فَعَسَى أَمْوَالُهُنَّ أَنْ تُطْغِيَهُنَّ، وَلَكِنْ تَزَوَّجُوهُنَّ عَلَى الدِّينِ، وَلَأَمَّةٌ خَرَمَاءُ سَوْدَاءُ ذَاتُ دِينٍ أَفْضَلُ» (٢).

والمراد بالدين: الطاعات، والأعمال الصالحات، والعفة عن المحرمات.

فعلى الرجل أن يختار المرأة التي تؤدي فروض الله عز وجل، وتتمسك بسنة خير الأنام محمد ﷺ، والتي هي وقافة عند حدود الله، حتى تعين زوجها على مرضات الله رب العالمين، ولا تكون سببا لبعده وانحرافه وتفريطه في جنب الله عز وجل، حتى لا تكون فتنة له في دينه وتلهيه عن واجباته قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (٣).

فإن الإنسان يتأثر حتما بمن يتعايش معه، وإذا كان الرسول ﷺ حذر من جليس السوء، وأنه يؤثر حتما في جليسه عندما قال ﷺ: «مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالسَّوِّءِ، كَمَثَلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيرِ، فَحَامِلُ الْمِسْكِ: إِمَّا أَنْ يُحْذِيكَ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا طَيِّبَةً، وَنَافِخُ الْكِيرِ: إِمَّا أَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ، وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيحًا خَبِيثَةً» (٤).

(١) البيان "١١٥/٩".

(٢) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب تزويج ذات الدين، ١٨٥٩. وانظر: نيل الأوطار "١٢٦/٦" ط دار الحديث- مصر، ١٤١٣هـ.

(٣) سورة التغابن من آية ١٤.

(٤) متفق عليه.

فما بالك بمن تعيش معك حياتك كلها، إذا لم تكن دينة خلوقة فإن الخشية من تفريطها في حق زوجها وأولادها كبيرة، وقد توردهم مورد الضياع، والهالك، والانحراف عن الصراط المستقيم.

فضلا عن أنه إذا لم تكن المرأة دينة فإنه لا يأمن منها الشر، ولا يأمن منها أن تحافظ على بيتها وأولادها، ولا يأمن منها أن تسلك مسلك السوء والشرطان، فلا تؤدي الحق الذي عليها ولا تراعي مسئولياتها، ويظل الإنسان معها تعيسا كئيبا خاسرا، كيف سيأتمنها الإنسان على ماله، وولده، وبيتته، وهي لا تسير وفق منهج رب العالمين، كيف يستأمنها الإنسان على دينه، وهي من أتباع الشياطين، إن للزواج مسئوليات وكل إنسان راعٍ ومسئول عن رعيته، ومن فرط في جنب الله، سيفرط في حق العباد.

وقد بين الغزالي خطورة فساد دين الزوجة فقال: "أن تكون صالحة ذات دين فهذا هو الأصل، وبه ينبغي أن يقع الاعتناء، فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها، وفرجها، أزلت بزوجها، وسودت بين الناس وجهه، وشوشت بالغيرة قلبه، وتنغص بذلك عيشه، فإن سلك سبيل الحمية، والغيرة لم يزل في بلاء ومحنة، وإن سلك سبيل التساهل كان متهاونا بدينه وعرضه ومنسوبا إلى قلة الحمية والأنفة، وإذا كانت مع الفساد جميلة، كان بلاؤها أشد، إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها، ولا يصبر عليها"(١).

كذا يستحب للرجل أن يختار المرأة ذات العقل والحكمة.

قال الشيرازي: "لأن القصد بالنكاح العشرة، وطيب العيش، ولا يكون ذلك إلا مع ذات عقل"(٢).

فالعقل، والحكمة، وفهم الحياة، وزنة الأمور، والصبر على الشدة، أملا في الانفراج، وتفهم سعي الزوج على متاع الحياة، أمور تعين الرجل على أن تستمر حياته مع زوجته في استقرار وسعادة ورضا، أما تلك المرأة التي دائما يغيب عقلها سريعا بسرعة غضبها ونقمتها،

(١) إحياء علوم الدين "٣٧/٢" ط دارالمعرفة-بيروت.

(٢) المهذب "٤٢٤/٢".

أو لا تعي الأمور، ولا تحسن التصرف، ولا تجيد الصبر والالتزان، ولا تتفهم معاني الحياة، ثم هي بسرعة غضبها أو بتفاهة تفكيرها تقسد عيشها، وعيش زوجها معها، وتجعل الحياة كدرة، وتحمل زوجها هما، وحزنا، وكآبة، ماذا ستجني؟ وماذا سيجني زوجها من وراء سوء فكرها، وضحالة عقلها، وعدم وعيها؟

أرأيتم تلك الصحابية الجليلة التي أحسنت تصرفا، وأجادت بحكمتها، وكانت راضية مطمئنة رغم فراق ولدها، لقد بارك الله لها، وأكرمها بحسن صنيعها، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ لِأَبِي طَلْحَةَ، مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ، فَقَالَتْ لِأَهْلِهَا: لَا تُحَدِّثُوا أَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهِ حَتَّى أَكُونَ أَنَا أُحَدِّثُهُ قَالَ: فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ عَشَاءً، فَأَكَلَ وَشَرِبَ، فَقَالَ: ثُمَّ تَصْنَعْتَ لَهُ أَحْسَنَ مَا كَانَ تَصْنَعُ قَبْلَ ذَلِكَ، فَوَقَعَ بِهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَأَصَابَ مِنْهَا، قَالَتْ: يَا أَبَا طَلْحَةَ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ قَوْمًا أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهْلَ بَيْتٍ، فَطَلَبُوا عَارِيَتَهُمْ، أَلَهُمْ أَنْ يَمْنَعُوهُمْ؟ قَالَ: لَا، قَالَتْ: فَاخْتَسِبِ ابْنَكَ، قَالَ: فَعَضِبَ، وَقَالَ: تَرَكْتَنِي حَتَّى تَلْطَخْتُ، ثُمَّ أَخْبَرْتَنِي بِابْنِي فَأَنْطَلَقَ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكُمَا فِي غَابِرٍ لَيْلَتِكُمَا» قَالَ: فَحَمَلْتُ. (١)

ويستحب أن يقصد زواج البكر، إلا لعذر، كأن كانت آلتها تضعف عن افتضاض البكر، استحب له طلب الثيب (٢).

وذلك للآتي:

أ- لما روي أن جابرا تزوج، فقال له النبي ﷺ: «تزوجت؟ فقال: نعم. فقال: بكرة أم ثيبا؟ فقال: ثيبا. فقال ﷺ: فهلا بكرة تلاعبها وتلاعبك؟ فقال: إن أبي قتل، وخلف بنات صغارا، ولم أرد أن أدخل عليهن خرقاء مثلهن». (٣)

(١) رواه مسلم في الفضائل، باب فضائل أبي طلحة الأنصاري، ٢١٤٤ (١٠٧).

(٢) ينظر نهاية المطلب "٢٨/١٢"، البيان "١١٦/٩"، مغني المحتاج "٢٠٦/٤".

(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب تزويج الثيبات، رقم ٤٧٩١، ٤٧٩٢. ورواه مسلم في صحيحه، كتاب الرضاع، باب استحباب نكاح البكر، رقم ٥٥ (٧١٥).

وجه الدلالة: قال الشوكاني: "فيه دليل على استحباب نكاح الأبكار، إلا لمقتضى لنكاح الثيب" (١). ب- وروى ابن ماجه: «عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعَذَبُ أَفْوَهاً، وَأَنْتَقُ أَرْحاماً، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ» (٢). قال شمس الدين الرملي: "(بكرا) للأمر به مع تعليله بأنهن أعذب أفواها: أي ألين كلاماً، أو هو على ظاهره من أطيبته وحلاوته، وأنتق أرحاماً: أي أكثر أولادا وأرضى باليسير من العمل: أي الجماع، وأغر غرة بالكسر: أي أبعد من معرفة الشر والتقطن له، وبالضم: أي غرة البياض أو حسن الخلق وإرادتهما معا أجود.

نعم الثيب أولى للعاجز عن الافتضااض، ولمن عنده عيال يحتاج إلى كاملة تقوم عليهن كما استصوبه -رحمه الله- من جابر لهذا" (٣). ج- وروى أبو نعيم عن شجاع بن الوليد قال: "كان فيمن كان قبلكم رجل حلف لا يتزوج حتى يستشير مائة نفس، وأنه استشار تسعة وتسعين رجلاً واختلفوا عليه، فقال: بقي واحد، وهو أول من يطلع من هذا الفج فأخذ بقوله ولا أعدوه، فبينما هو كذلك؛ إذ طلع عليه رجل راكب قسبة فأخبره بقصته، فقال له النساء ثلاثة: واحدة لك، وواحدة عليك، وواحدة لا لك ولا عليك، فالبكر لك، وذات الولد من غيرك عليك، والثيب لا لك ولا عليك، ثم قال: أطلق الجواد، فقال له: أخبرني بقصتك، فقال: أنا رجل من علماء بني إسرائيل مات قاضينا، فركبت هذه القسبة وتباهلت لأخلص من القضاء". وقد بين الغزالي فوائد زواج البكر في ثلاث أمور:

أحدها: أن تحب الزوج، وتألفه، فيؤثر في معنى الود، وقد قال -رحمه الله-: «عليكم بالودود» والطباع مجبولة على الأنس بأول مألوف (٤). كذلك يستحب للرجل أن يتزوج امرأة خفيفة المهر (٥)،

(١) نيل الأوطار "١٢٦/٦".

(٢) رواه ابن ماجه في سننه، كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار، ١٨٦١.

(٣) نهاية المحتاج "١٨٤/٦".

(٤) إحياء علوم الدين "٤١/٢".

(٥) إحياء علوم الدين، مغني المحتاج "٢٠٧/٤".

استدلّ بالآتي: روى الحاكم عن عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي -ﷺ- قال: «أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا» (١)

وقد نهى رسول الله ﷺ عن المغالاة في المهر. وقد تزوج رسول الله ﷺ بعض نسائه على عشرة دراهم، وأثاث بيت، وكان رحي يد، وجرة، ووسادة من آدم حشوها ليف. وجه الدلالة: هذه أحاديث وأخبار صريحة واضحة تبين أن بركة الزواج في قلة مهره، ويسره على الرجل، لا في غلوه وزيادته. يقول الغزالي: "ولو كانت المغالاة بمهور النساء مكرمة لسبق إليها رسول الله ﷺ، وقد تزوج بعض أصحاب رسول الله ﷺ على نواة من ذهب قيمتها خمسة دراهم" (٢). والزواج في حقيقته ليس مجالا للتكسب، والتجارة، والمغالاة، وليست المرأة سلعة ينازع في قيمتها، وإنما الزواج مجال للتراحم، والتواد، والمهر إنما هو معين على ذلك لكي تسعد المرأة بزوجها، وتطمئن إليه، وتستقر نفسها، فهي ستفارق بيت أبيها الذي عاشت فيه حيناً من الدهر، وهي مستوحشة ما زالت لمكانها الجديد، ولذلك الرجل الذي لم تعرفه على كامل حقيقته بعد، فالمهر يحقق لها بعض السعادة، لأنه كالهديّة تدخل سرورا على النفس، ولا يمكن أن يتوقف ذو لب سوي في تزويج موليته على فرض مهر معين، فالأصل الدين والخلق كما قال ﷺ: «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه...» ومدى قدرة الرجل على النفقة، والقيام بواجبات الحياة، ومسئولياتها هو مناط القبول بعد الدين والخلق، فكيف ستكون المودة والرحمة، وقد تنازع الأهل على المال قلته وكثرته، وجعلوه سببا للبغضاء والحزن بينهم، فكيف يجتمع النقيضان سبب المودة والرحمة مع سبب الشقاق والنزاع، والحكيم هو من وزن الأمور، وقدّر لموليته رجلا إن أحبها أكرمها، وإن كرهها لم يظلمها.

كذا يستحب للرجل أن يتزوج ذات نسب، أي معروفة الأصل، طيبة لنسبتها إلى العلماء والصلحاء، وتكره بنت الزنا، والفاسق، وألحق بها اللقيطة، ومن لا يعرف أبوها (٣)، وذلك

(١) قال العراقي في تخريج الإحياء إسناده جيد.

(٢) إحياء علوم الدين "٢/٤٠".

(٣) ينظر نهاية المطلب "٢٧/١٢"، البيان "١١٦/٩-١١٧"، فتح العزيز "٦٦٧/٧"، المجموع "١٣٧/١٦"، نهاية المحتاج "١٨٤/٦".

للآتي: لقوله ﷺ: «تنكح المرأة لأربع»، فقال: «لحسبها». و (الحسب): الشرف الثابت في الآباء. وقال ﷺ: «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَلَا تُضَيِّعُوهَا فِي غَيْرِ الْأَكْفَاءِ» (١). وقال ﷺ: «إِيَّاكُمْ وَخَضِرَاءَ الدِّمَنِ» (٢)، وَهِيَ الْمَرْأَةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمَنْبِتِ السُّوءِ» (٣). وجه الدلالة: فهذه أحاديث صريحة تبين للرجل أن يختار المرأة من البيت الذي اشتهر بصلاح حاله، ووضوح البيئة، حتى لا يدخل الفساد على بيئته تأثراً ببيئة أهل زوجته. وليس المقصود بذات النسب أن تكون المرأة من بيت كبر القوم، ومن أشرف الجمع، بل المقصد أن تكون المرأة من بيت صلاح واستقامة، وألا يعرف بيتهم ولا قومهم بالفسق والفجور، والتجاوز في حق الله، وحق العباد، درءاً للفساد؛ لئلا يؤثر ذلك مستقبلاً على أولاد الرجل ونسله، فإن المرأة ستربي الأولاد والبنات، فإن كانت من بيئة طيبة طاهرة، وقد تربت على مكارم الأخلاق، فإن النشأ سيخرج من بين يديها، وإن اشتهر أهلها بالسوء، فتلوث الإنسان ببيئتهم كبير، وقد يجر ذلك إلى فساد الأولاد للرحم الفاسدة التي تربط بهم. كذا يستحب للرجل أن يتزوج الودود الولود، ويعرف هذا في المرأة بأقاربها، فإن عرفت المرأة بالعقر، استحب للرجل أن يبتعد عن

(١) رواه ابن ماجه في سننه بلفظ «تَخَيَّرُوا لِنُطْفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الْأَكْفَاءَ، وَأَنْكِحُوا إِلَهُم» كتاب النكاح، باب الأكفاء، رقم ١٩٦٨، ٦٣٣/١. وقال ابن حجر الهيتمي: هو حديث حسن من بعض طرقه وقال ابن حجر: مداره على أناس ضعفاء، وهو حسن. وذكره الشوكاني في الموضوعات.

(الإفصاح عن أحاديث النكاح، ص ١٧. التلخيص الحبير، ٣/ ٣٠٩. المقاصد الحسنة، ص ٢٥٤. الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعية، للشيخ محمد الشوكاني، ص ١٣٠، ط المكتب الإسلامي - بيروت)

(٢) معناه أنه كره نكاح الفاسدة: لأن أولادها يتزعون لما فيها من عرق السوء، وتفسر خضراء الدمن أن النبات ينبت على البعر في الموضع الخبيث فيكون ظاهره حسناً وباطنه قبيحاً. فالدمن جمع دمنة، وهي البعر شيت الفاسدة نسباً وأصلاً بالنبات في البعر بجامع ما في كل من النظارة في الظاهر، والقبح والفساد في الأصل.

(تهذيب اللغة، ٧/ ٤٩. الإفصاح عن أحاديث النكاح، ١/ ١٨)

(٣) رواه الشهاب القضاعي في مسنده، رقم ٩٥٧، ٩٦/٢. والحديث تفرد به الواقدي وهو ضعيف، وقال الدارقطني: لا يصح من وجه. وذكره الشوكاني في الموضوعات.

(مسند الشهاب، أبو عبد الله القضاعي، ط مؤسسة الرسالة، بيروت. الإفصاح، المرجع السابق. المقاصد الحسنة، ١/ ٢٢١. الفوائد المجموعة، ص ١٣٠)

زواجها (١) وذلك للآتي: لقوله ﷺ: «تَنَآكُحُوا (تَكْثُرُوا)» (٢) (٣). وقال ﷺ: «تَزَوَّجُوا الْوُدَّ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ» (٤). وقال ﷺ: «سوداء ولود خير من حسناء عقيم» (٥).

عن مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إني أصبْتُ امرأة ذات حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وأنها لا تَلِدُ، أفأتزوجها؟ قال: «لا» ثم أتاه الثانيةَ فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال: «تزوجوا الْوُدَّ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِّرٌ بِكُمْ الْأُمَمُ» (٦). روى الخطيب في تاريخ بغداد بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: «حَصِيرٌ فِي الْبَيْتِ خَيْرٌ مِنْ امْرَأَةٍ لَا تَلِدُ». وجه الدلالة: الأحاديث صريحة في استحباب زواج المرأة التي تلد، لأننا أمة قوية كثيرة العدد. فإن اقتصر على غير الولود تأكدت الكراهة، وإلا بأن كان معه امرأة ولود أو كان في نيته أن يتزوج أخرى ولودا فقد يقال: إن له ذلك، وظاهر حديث معقل يردده، ولعله كان لن يعدد، والفقه أن يقال: إن كان يقتصر عليها فلا، وإلا جاز، فإن تعميم الكراهة معناه ألا

(١) ينظر نهاية المطلب "٢٨/١٢"، البيان "١١٨/٩"، مغني المحتاج "٢٠٧/٤".

(١٠٦) في رواية: تناسلوا. قال البيروتي في أسنى المطالب عنها ص ١١٥: مرسل، سنده ضعيف.

(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف عن سعيد بن أبي هلال مرسلًا، كتاب النكاح، باب وجوب النكاح وفضله، رقم ١٠٣٩١ (١٧٣/٦)، وعزاه ابن حجر للديلمي في مسند الفردوس من طريق عبد الله بن عمر، وهو حديث ضعيف ذكر ابن السبكي في الطبقات أنه لا أصل له، وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير، وعزاه العراقي في تخريج الإحياء إلى أبي بكرين مردويه في تفسيره وضعفه، ويغني عنه أحاديث أخر.

قال في البدر المنير: ذكره البهقي في المعرفة عن الشافعي بلاغا، وكذا هو في الأم والمختصر، ورواه ابن ماجه في سننه مسندا من حديث أبي هريرة مرفوعا: «انكحوا فإني مكاثربكم».

وفي إسناده: طلحة بن عمرو، وقد ضعفه، ويغني أحاديث أخر صحيحة في معناه: منها: حديث معقل بن يسار -رفعه: - «تزوجوا الولود الودود فإني مكاثربكم الأمم». أخرجه أبو داود، والنسائي "أه بتصرف".

(طبقات الشافعية الكبرى ٣٠٩/٦، التلخيص الحبير، ٣/٢٥٠، وما بعدها. المغني عن حمل الأسفار، للإمام أبي الفضل العراقي، ٣٦٩/١، ط: مكتبة طبرية، الرياض. البدر المنير ٤٢٣/٧، وما بعدها)

(٤) رواه أبو داود في سننه، كتاب النكاح، باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء رقم ٢٠٥٢، ١٧٥/٢. سنن النسائي الكبرى، كتاب النكاح، باب النهي عن نكاح المرأة التي لا تلد، رقم ٥٣٤٢، ٣/٣٧١. والحديث صحيح كما ذكر ابن الملقن في البدر المنير ٤٢٣/٧.

(٥) قال العراقي في تخريج الإحياء: رواه ابن حبان في الضعفاء من رواية يهزبن حكيم عن أبيه عن جده ولا يصح. اهـ.

(٦) رواه أبو داود، كتاب النكاح، باب تزويج الأبكار، ٢٠٥٠، وقال محققه: إسناده قوي.

تتزوج العقيم وهو بعيد عن تيسير الشرع، وإن قلنا تتزوج عقيماً مثلها فيه أيضاً مشقة؛ لأنه قد لا يوجد، فيتجه ما ذكرنا من توجيه الكراهة على الاقتصار على غير الولود فيقطع نسله، والله أعلم. والمتتبع لكتب السادة الشافعية يجد أنهم ذكروا صفات أخرى عديدة، اختلفوا في توصيفها، وضبطها، منها أن تكون المرأة جميلة، ليست ذات قرابة قريبة، وأن يتزوج الرجل من يستحسنها، وألا يكون لها مطلق يرغب في نكاحها، وغير ذلك (١). ولا شك أنهم قصدوا بذلك أن يصل الرجل إلى قدر من المحاسن تطيب بها عشرته، وينصلح بها حاله، وتستقيم بها حياته، لكن جمع كل الصفات الحسنة في امرأة واحدة شيء نادر؛ لذا فعلى العاقل أن يزن الحسنات والسيئات في المرأة، ويرجح بينهما، وينظر في نفسه هل يستطيع أن يتقبل بعض عيوب المرأة أو نقصان صفاتها الحسنة، أو لا يستطيع، وليست تلك الصفات قاعدة يقينية، فقد تخالف في امرأة، فقد يتزوج الرجل بكراً ولا تطيب له عشرة، وقد يتزوج ثيباً ويهناً بها، فالمدار على رزق الله الواسع، وعظيم فضله، وجزيل منانه وثوابه؛ لذا يقول الخطيب الشربيني بعد ذكر كل الصفات المستحسنة في المرأة: "وهذه الصفات كلها قل أن يجدها الشخص في نساء الدنيا، وإنما توجد في نساء الجنان، فنسأل الله -تعالى- أن لا يحرمننا منهن" (٢). وكما أنهم استحسنوا للرجل تلك الصفات، فإنهم أيضاً استحسنوا مثلها للمرأة، فيستحب لولائها أن يزوجه بأفضل صفات الرجل من دين، وتقوى، وحسن خلق، وبما فيه من صفات تهناً به المرأة، وتسعد، ويستقر حالها، ويطمئن قلبها، وفي ذلك يقول الغزالي: "ويجب على الولي أيضاً أن يراعي خصال الزوج، ولينظر لكريمته، فلا يزوجه ممن ساء خلقه، أو خلقه، أو ضعف دينه، أو قصر عن القيام بحقها، أو كان لا يكافئها في نسبها، قال صلى الله عليه وسلم: «النكاح رق فليُنظر أحدكم أين يضع كريمته»، والاحتياط في حقها أهم لأنها رقيقة بالنكاح، لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حال، ومهما زوج ابنته ظالماً،

(١) ينظر البيان "١١٨/٩"، المجموع "١٣٧/١٦"، مغني المحتاج "٢٠٧/٤"، نهاية المحتاج "١٨٤/٦"، حاشية قليوبي "٢٠٨/٣".

(٢) مغني المحتاج "٢٠٧/٤".

أو فاسقا، أو مبتدعا، أو شارب خمر، فقد جنى على دينه، وتعرض لسخط الله لما قطع من حق الرحم، وسوء الاختيار" (١).

الدرس الخامس: نظر مريد النكاح إلى المرأة.

إذا أراد رجل أن يخطب امرأة، سن له أن ينظر إليها، حتى يألفها، ويعرفها، ويستحسنها زوجة مستقبلية تشاركه حياته، فإن الأرواح قد تتآلف وقد تتنافر، فليس مجرد التدين كفيلا بأن يستريح الرجل ويهنأ، بل لا بد من استحسان الخلقة وتناغم القلوب، فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف»، وليس أدل على ذلك من حديث المرأة الصحابية التي طالبت بخلع زوجها، ولم تشكو قسوة معاملته، ولا تقصيره في حقها، وإنما لم تتآلف معه، ولم يعجبها خلقة، "فجميلة بنت سلول، أتت النبي ﷺ، فقالت: والله ما أعتب على ثابت في دين، ولا خلق، ولكني أكره الكفر في الإسلام، لا أطيقه بغضا" (٢) ف قضى النبي ﷺ بالتطليق رغم خلق ثابت ودينه، لكنها الأرواح التي تحب وتكره، وتقبل وترفض؛ لذا كانت السنة إذا أراد الرجل أن يتزوج نظر إلى من يريد لها زوجة له (٣)، استدلالا بالأحاديث الآتية:

١ - في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا». قَالَ: لَا. قَالَ: «فَادْهَبْ فَأَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْنًا» (٤)

٢ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا حَظَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَرَى مِنْهَا مَا يُعْجِبُهُ وَيَدْعُوهُ إِلَيْهَا فَلْيَفْعَلْ». قَالَ جَابِرٌ: فَلَقَدْ حَظَبْتُ امْرَأَةً مِنْ بَنِي سَلَمَةَ فَكُنْتُ أَتَخَبُّ فِي أَصُولِ النَّخْلِ حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا بَعْضَ مَا أَعْجَبَنِي فَتَزَوَّجْتُهَا. (٥). ٣ - روي

(١) إحياء علوم الدين "٤١/٢".

(٢) سنن ابن ماجه، الطلاق، باب المختلعة يأخذ ما أعطاها، ٢٠٥٦، وهو صحيح.

(٣) الحاوي "٣٤/٩"، نهاية المطلب "٣٧/١٢"، البيان "١٢١/٩"، أسنى المطالب "١٠٨/٣"، مغني المحتاج "٢٠٧/٤".

(٤) رواه مسلم، كتاب النكاح، باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها، رقم ٧٤ (١٤٢٤)، ٢ / ١٠٤٠.

(٥) رواه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، رقم ١٣٨٦٩، ٧ / ٨٤.

عن المغيرة بن شعبة: «خَطَبْتُ امْرَأَةً فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟». قُلْتُ: لَا. قَالَ: «فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا». فَأَتَيْتُهَا، وَعِنْدَهَا أَبْوَاهَا، وَهِيَ فِي خَدْرِهَا قَالَ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَيْهَا، قَالَ: فَسَكَتَا. قَالَ: فَرَفَعَتِ الْجَارِيَةُ جَانِبَ الْخَدْرِ فَقَالَتْ: أُحْرِجْ (١) عَلَيْكَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَرَكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ لَمَّا نَظَرْتُ، وَإِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَأْمُرْكَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيَّ أَنْ تَنْظُرَ. قَالَ: فَنَظَرْتُ إِلَيْهَا ثُمَّ تَرَوَّجْتُهَا. قَالَ: فَمَا وَقَعَتْ عِنْدِي امْرَأَةٌ بِمَنْزِلَتِهَا، وَلَقَدْ تَرَوَّجْتُ سَبْعِينَ أَوْ بَضْعًا، وَسَبْعِينَ امْرَأَةً (٢).

وجه الدلالة: أن هذه الأحاديث صريحة في أن النبي ﷺ قد أذن لمن أراد التزوج أن ينظر إلى من يريدتها، فدل ذلك على جواز النظر لها وإن كانت لا تزال أجنبية عنه. وفي قوله ﷺ "يؤدم" قولان: أحدهما: وهو قول أصحاب الحديث: أنه يعني يدوم فقدم الواو على الدال كما قال في ثمر الأراكة: "كلوا منه الأسود فإنه أطيب" بمعنى أطيب فيكون مأخوذاً من الدوام. والقول الثاني: - وهو قول أهل اللغة - أنه المحابة وأن لا يتنافروا مأخوذ من إدام الطعام؛ لأنه يطيب به فيكون مأخوذاً من إدام لا من الدوام (٣).

فرع: محل النظر. فقهاء الشافعية في المشهور عندهم على أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه من أراد خطبتها وكفيها فقط لا يتجاوز ذلك، خلافاً لبعض الفقهاء الذين ضيق بعضهم الأمر، ووسعه آخرون، فمنع بعضهم النظر مطلقاً، وأباح بعضهم النظر إلى ربع الساق

(١) الْجَنْجُ وَالْحَرْجُ الْإِثْمُ، وَالْحَارْجُ الْإِثْمُ، وَالْحَرْجُ وَالْحَرْجُ وَالْمُتَحَرِّجُ الْكَافُ عَنِ الْإِثْمِ وَقَوْلُهُمْ: رَجُلٌ مُتَحَرِّجٌ كَقَوْلِهِمْ: رَجُلٌ مُتَأَثِّمٌ، وَحَرَجَ فُلَانٌ عَلَى فُلَانٍ إِذَا ضَيَّقَ عَلَيْهِ.

(لسان العرب، ٢/٢٣٣)

(٢) رواه بهذا اللفظ بطوله البيهقي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها، رقم ١٣٨٧٢، ٨٤/٧. والحديث إلى قوله أخرى أن يؤدم بينكما قال عنه ابن الملقن: هذا الحديث صحيح، رواه الترمذي، وابن ماجه كذلك والنسائي والدارمي، وقالوا: «أجدر» بدل «أحرى». قال الترمذي: حديث حسن. وصححه ابن حبان، والحاكم، وابن القطان، وابن الصلاح. اهـ بتصرف.

(البدر المنير، ٧/٥٠٣)

(٣) الحاوي الكبير "٢٥/٩".

زيادة على الوجه والكفين، وقال آخرون بحل النظرة إلى ما يظهر في بيتها، وآخرون بحله إلى ما فوق السرة وتحت الركبة، لكن ما يهمنا هو رأي السادة الشافعية.

والشافعية اختلفوا في المسألة على وجهين: الأول: حل النظر للوجه والكفين فقط (١).

والثاني: حل النظر إلى جميع الجسد، عدا ما بين السرة والركبة، كنظر الرجل إلى الرجل (٢). استدلت أصحاب الوجه الأول بالآتي: - روى جابر رضي الله عنه: أن النبي - ﷺ - قال: «إذا أراد أحدكم أن يتزوج امرأة.. فلينظر إلى وجهها وكفيها».

وجه الدلالة: الحديث صريح في إباحة النظر إلى الوجه والكفين، فدل على أنه لا يجوز له النظر إلى غير ذلك (٣). - وقالوا: إنه تم الاقتصار على نظر الوجه والكفين، لخروجهما عن حكم العورة، وإن في الوجه ما يستدل به على الجمال، وفي الكفين ما يستدل به على خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره (٤). ولم يكن ثمة دليل لمن أجاز النظر إلى جميع الجسد عدا ما بين السرة والركبة، إلا قياسهم على نظر الرجل للرجل، وهو قياس واضح الفارق فيه، فتضعف حجة أصحاب هذا الوجه.

فرع: وقت النظر لمن أراد خطبتها:

للشافعية ثلاثة أوجه في الوقت الذي يحل فيه النظر لمن أراد خطبتها: الأول: وهو الأظهر، لا بد أن يكون النظر قبل الخطبة، وبعد العزم على النكاح (٥)، وذلك للآتي: لأنه لو كان النظر بعد الخطبة، قد يفضي الحال إلى تركها، فيشق الأمر عليها (٦).

(١) الحاوي الكبير "٣٣/٩"، البيان "١٢٣/٩".

(٢) فتح العزيز "٤٧٠/٧".

(٣) البيان "١٢٣/٩".

(٤) الحاوي الكبير "٣٥/٩".

(٥) فتح العزيز "٤٦٩-٤٧٠"، مغني المحتاج "٢٠٨/٤".

(٦) فتح العزيز "٤٦٩-٤٧٠"، أسنى المطالب "١٠٨/٣"، مغني المحتاج "٢٠٨/٤".

ولأنه قبل العزم على النكاح لا حاجة إليه (١). الوجه الثاني: أن النظر الجائز هو وقت أن تأذن المرأة له في عقد النكاح. وقالوا: إن هذا الوقت هو وقت الحاجة للنظر، فيتقيد حل النظر به (٢). الوجه الثالث: أن النظر الجائز هو وقت ركون وميل كل واحد لصاحبه. وقالوا: إن هذا الوقت فيه تحرم الخطبة على الخطبة، فلا بد أن يتقيد حل النظر به (٣).

فرع: هل يشترط إذن المرأة لكي يحل النظر؟

اتفق فقهاء الشافعية على أنه لا يشترط علم المخطوبة، أو إذنها، أو إذن وليها بنظر الخاطب إليها، بل قال الأذرعى: إن عدم ذلك أولى، لأنها قد تتزين له بما يغره (٤)، واستدلوا بالآتي: رواية جابر السالفة الذكر وفيها قال: قال رسول الله ﷺ: «إن خطب أحدكم امرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعّل» قال: فخطبت جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحها. وجه الدلالة: الحديث واضح في أن جابراً كان ينظر إلى من كان يريد خطبتها بدون إذنها، فكان يتخبأ لها، وهذا واضح الدلالة في عدم اشتراط الإذن. ولأنه إن كان النظر مباحاً لم يفتقر إلى إذن، وإن كان محظوراً لم يستبح بالإذن (٥). ولأن استئذانها بمثابة تقديم الخطبة، وهو لم يخطب بعد، وحل النظر كان قبل الخطبة (٦).

فرع: هل للخطاب أن يكرر النظر؟

اتفق فقهاء الشافعية على أنه من أراد الخطبة فله أن يكرر النظر للمرأة (٧)، استدلالاً بالآتي:

(١) أسنى المطالب "١٠٨/٣"، ومغني المحتاج "٢٠٨/٤".

(٢) فتح العزيز "٤٧١/٧".

(٣) المرجع السابق.

(٤) الحاوي الكبير "٣٥/٩"، نهاية المحتاج "١٨٦/٦".

(٥) الحاوي الكبير "٣٥/٩".

(٦) نهاية المطالب "٣٨/١٢".

(٧) البيان "١٢٣/٩"، مغني المحتاج "٢٠٨/٤".

روى أبو الدرداء رضي الله عنه: أن النبي ﷺ - قال: «إذا قذف الله في قلب امرئ خطبة امرأة.. فلا بأس أن يتأمل محاسن وجهها».

وجه الدلالة: أنه لا يمكن لمن أراد الخطبة تأمل محاسن المرأة إلا بأن يكرر النظر إليها (١). ولأن التكرار يساعد الرجل على أن يتبين هيئة المرأة فلا يندم بعد النكاح؛ إذ لا يحصل الغرض غالبا بأول نظرة (٢). وللشافعية وجهان في عدد مرات النظر.

الأول: وهو الأولى: أن العدد منوط بالحاجة، فله أن ينظر منها ما شاء إلى أن يتبين هيئتها، سواء كان مرة أو عشر، فلو تبين هيئتها بمرة واحدة حرم له النظر بعد ذلك، وإن لم يتبين له ما شاء إلى أن تنقطع حاجته (٣). والوجه الثاني: وهو للزركشي أن يتقيد الأمر بثلاث مرات فقط، لا يزيد عليها، استدلالا بالآتي: في حديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله ﷺ: «رَأَيْتُكَ فِي الْمَنَامِ يَجِيءُ بِكَ الْمَلَكُ فِي سَرَقَةٍ (٤) مِنْ حَرِيرٍ فَقَالَ لِي هَذِهِ امْرَأَتُكَ، فَكَشَفْتُ عَنْ وَجْهِكَ الثَّوبَ فَإِذَا أَنْتِ هِيَ» (٥).

وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ رأى السيدة عائشة في منامه ثلاث مرات، فكأن هذا دلالة على أنه المشروع في رؤية الرجل لمن أراد خطبتها، استئناسا بمنام رسول الله ﷺ. ٢- ولأن معرفة الرجل للآخر تتحقق بثلاث مرات، فينبغي ألا يزيد عليها (٦).

(١) البيان "١٢٣/٩".

(٢) مغني المحتاج "٢٠٨/٤".

(٣) أسنى المطالب "١٠٩/٣"، مغني المحتاج "٢٠٨/٤".

(٤) معناه قطعة من جيد الحرير. والسَّرَقُ شِقَاقُ الحرير، وقيل هو أجوده، واحدته سَرَقَةٌ. وقيل إنها البيضُ من شَقَق الحرير.

(لسان العرب، ١٠/١٥٥)

(٥) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب النظر إلى المرأة قبل التزويج، رقم ٤٨٣٢، ٥/١٩٦٩. وأخرجه مسلم في صحيحه، كتاب فضائل الصحابة، باب في فضل عائشة ؓ، رقم ٧٩ (٢٤٣٨)، ٤/١٨٨٩.

(٦) مغني المحتاج "٢٠٨/٤"، نهاية المحتاج "١٨٦/٦".

فرع: هل للمرأة النظر إلى الخاطب؟ نعم، فقهاء الشافعية متفقون على أنه كما يجوز للرجل أن ينظر للمرأة، فكذلك للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر إليه، لأنه يعجبها منه ما يعجبه منها، ولهذا قال عمر رضى الله عنه: "لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم فإنه يعجبهم منهم ما يعجبهم منهن" (١).

فرع: إرسال من ينظر إلى من أراد خطبتها: اتفق فقهاء الشافعية على أن للخاطب أن يرسل امرأة لتتظر المخطوبة، ثم تصفها له، ولو بما لا يحل له نظره من غير الوجه والكفين، فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره، وهذا لمزيد الحاجة إليه مستثنى من حرمة وصف امرأة لرجل، وقد روي عن أنس رضى الله عنه، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَبَعَثَ امْرَأَةً لَتَنْتَظِرَ إِلَيْهَا، فَقَالَ: «شُمِّي عَوَارِضَهَا، وَأَنْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِيهَا» قَالَ: فَجَاءَتْ إِلَيْهِمْ فَقَالُوا: أَلَا نُعْذِيكَ يَا أُمَّ فُلَانٍ؟ فَقَالَتْ: لَا أَكُلُ إِلَّا مِنْ طَعَامٍ جَاءَتْ بِهِ فُلَانَةٌ قَالَتْ: فَصَعِدْتُ فِي رَفٍّ لَهُمْ فَنَظَرْتُ إِلَى عُرْقُوبِيهَا، ثُمَّ قَالَتْ: أَفْلِينِي يَا بُنَيَّةُ، قَالَ: فَجَعَلْتُ نُفْلِيهَا وَهِيَ تَشُمُّ عَوَارِضَهَا، قَالَ: فَجَاءَتْ فَأَخْبَرَتْ (٢)، وكذا يرون أن من يرسل للنظر، يمكن أن يكون امرأة، أو نحوها، ممن يحل له نظرها رجلا كان أو امرأة كأخيها، أو مسموح يباح له النظر (٣).

(١) البيان "١٢٣/٩"، المجموع "١٣٩/١٦".

(٢) مسند أحمد ١٣٤٢٤. ورواه الحاكم في المستدرک کتاب النکاح ٢٦٩٩، وصححه على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.

(٣) نهاية المطلب "٣٨/١٢"، فتح العزيز "٤٧٠/٧"، أسنى المطالب "١٠٩/٣".

الدرس السادس: الخطبة، تعريفها، ودليل مشروعيتها، وحكمها بالنظر إلى حال المرأة.

يسبق كل عقد من العقود ذات الشأن والخطر مقدمات، يبين كل واحد من المتعاقدين مطالبه ورغائبه، فإذا تلاقت الرغبات أقدما، فيتم العقد بتلاقي الإرادتين ووجود العبارتين الدالتين على ذلك. وعقد الزواج هو أخطر عقد لعاقديه؛ إذ هو عقد موضوعه الحياة الإنسانية، وهو عقد يعقد على أساس الدوام إلى نهاية الحياة، ولهذا كانت مقدماته لها خطره وشأنه، وإن الشريعة الإسلامية كسائر الشرائع لم تعن بمقدمات أي عقد من العقود سواه، فقد عنيت بها وجعلت لها أحكاما خاصة. ومقدمات عقد الزواج هي ما يسمى في لسان الشرع بالخطبة (١). والخطبة لغة: مصدر بمنزلة الخطب وهو: سبب الأمر. تقول: ما خطبك، وخطبت على المنبر خطبة بالضم، وخطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وخطبت المرأة خطبة بالكسر، والعرب تقول: فلان خطب فلانة إذا كان يخطبها، ويقول الخاطب: خطب فيقول المخطوب إليهم: نكح وهي كلمة كانت العرب تتزوج بها (٢).

وشرعا: التماس الخاطب النكاح من جهة المخطوبة (٣).

حكم الخطبة: الخطبة في الغالب وسيلة للنكاح؛ إذ لا يخلو عنها في معظم الصور، وليست شرطا لصحة النكاح، فلو تم بدونها كان صحيحا، والمعتمد عند الشافعية أن الخطبة مستحبة، وإن كان الأصحاب (٤) قد اكتفوا بالإباحة كما ذكر ذلك الرافعي (١).

(١) الأحوال الشخصية لأبي زهرة "٢٨" ط دار الفكر العربي-القاهرة.

(٢) الصحاح للجوهري "١٢١/١" ط دار العلم للملايين-بيروت، الطبعة الرابعة، عام ١٤٠٧ هـ. لسان العرب لابن منظور "٣٦٠/١" ط دار صادر-بيروت، الطبعة الثالثة، عام ١٤١٤ هـ.

(٣) أسنى المطالب "١١٥/٣"، ومغني المحتاج "٢١٩/٤"، حاشية قليوبي "٢١٤/٣".

(٤) الأصحاب: هم فقهاء الشافعية الذين بلغوا في العلم مبلغا عظيما حتى كانت لهم اجتهاداتهم الفقهية الخاصة، التي خرجوها على أصول الإمام الشافعي، واستنبطوها من خلال تطبيق قواعده، وهم في ذلك منتسبون إلى الإمام الشافعي ومذهبه ويسمون أصحاب الوجوه. وأصحاب الوجوه كثيرون لا يحصون، لكن اشتهر منهم جماعة في استنباط الأحكام من نصوصه، وتوجيهها والتفريع عليها، منهم: أحمد بن يسار، ومحمد بن نصر المروزي، وأبو الطيب بن سلمة، وأبو عبد الله الزبيري، وأبو بكر النيسابوري، وأبو سعيد الإصطخري، وابن القاص، وابن الحداد، وأبو علي الطبري، وابن أبي هريرة، وابن القطان، والقفال الشاشي، وأبو القاسم الصيمري، وغيرهم.

وإن كانت الخطبة يعتري حكمها الأحكام التكليفية، فاستحبها لمن يستحب له النكاح، وكراهتها لمن يكره له النكاح، وكذا لمن يحرم عليه، فيكره للحلال خطبة المحرمة (٢).

دليل مشروعيتها: السنة والعرف: أما السنة: فلقد خطب النبي ﷺ عائشة رضي الله عنها - من أبيها أبي بكر الصديق رضي الله عنه -، وخطب حفصة رضي الله عنها - من أبيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والعرف: أن الناس قد جرى أمرهم على أن الرجل إذا أراد أن ينكح امرأة خطبها أولاً (٣).

أحكام الخطبة بالنظر إلى حال المرأة. المرأة قد تكون في حال يجوز خطبتها فيه، وقد تكون في حال لا يجوز خطبتها فيه، وقد يجوز التصريح للمرأة، وفي حق غيرها لا يجوز إلا التعريض. والتصريح: هو ما يقطع بالرغبة في النكاح، كأريد أن أنكحك، وإذا انقضت عدتك نكحتك. والتعريض: هو ما يحتمل الرغبة في النكاح وعدمها، كقوله: أنت جميلة، ورب راغب فيك، ومن يجد مثلك، ولست بمرغوب عنك، والتعريض مأخوذ من عرض الشيء، وهو جانبه؛ لأنه يظهر بعض ما يريده، و"إذا حلت فآذنيني" أي إذا انقضت عدتك. (٤).

والمرأة لها أحوال متعددة: الحال الأول: أن تكون المرأة خلية من النكاح، أي غير منكوحة، والعدة، أي ليست في مدة العدة، والخطبة، أي لم يسبقه غيره إلى خطبتها، وموانع النكاح، أي ليست محرمة عليه تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً. حكم خطبتها: يجوز خطبتها بالتصريح والتعريض، لا خلاف بين فقهاء الشافعية في ذلك (٥). قال الرافعي "واعلم أن المرأة إما خلية عن النكاح والعدة، فيجوز خطبتها تعريضاً وتصريحاً" (٦).

[مختصر الفوائد المكية للسقاف"ص ١٠٠ طبعة مصطفى البابي الحلبي-مصر، الطبعة الأخيرة].

(١) فتح العزيز "٤٨٣/٧"، أسنى المطالب "١١٥/٣".

(٢) فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل لسليمان العجيلي "١٢٨/٤" ط دار الفكر.

(٣) فتح العزيز "٤٨٣/٧"، أسنى المطالب "١١٥/٣".

(٤) نهاية المطلب "٢٧٢-٢٧٣"، مغني المحتاج "٢١٩/٤"، حاشية قليوبي "٢١٥-٢١٤/٣".

(٥) الحاوي الكبير "٢٤٧/٩"، فتح العزيز "٤٨٣/٧"، مغني المحتاج "٢١٩/٤".

(٦) فتح العزيز "٤٨٣/٧".

قال الخطيب الشربيني "تحل خطبة خلية عن نكاح، و عن عدة وكل مانع من موانع النكاح وأن لا يسبقه غيره بالخطبة، ويجب تعريضا وتصريحا"(١).

الحال الثانية: أن تكون المرأة منكوحة، أي متزوجة ما زالت في عصمة رجل آخر. حكم خطبتها: لا تجوز خطبة المنكوحة تصريحاً أو تعريضاً؛ لأن الخطبة مقدمة للنكاح، ومن كانت في نكاح صحيح لا يجوز للغير أن ينكحها فلا تصح خطبتها، ولا تجوز، بل تحرم(٢). قال الرافعي: "أو منكوحة فيحرم خطبتها تعريضاً وتصريحاً"(٣).

الحال الثالثة: أن تكون المرأة معتدة، وهذه لها ثلاثة أقسام:

أ- أن تكون رجعية. ب- أن تكون بائناً لا تحل للزوج. ج- أن تكون بائناً تحل للزوج.

القسم الأول: المرأة المعتدة عن طلاق رجعي: حكم خطبتها: لا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأن أحكام الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة، ووقوع الطلاق، والظهار منها، ويتوارثان إن مات أحدهما، وتعد عدة الوفاة إن مات الزوج، ومتى أراد الزوج رجعتها في العدة كانت زوجته. ولأنها تكون متغيرة حنقة على زوجها، فقد يحملها ذلك على كذب في ادعاء انقضاء العدة. القسم الثاني: البائن التي لا تحل للزوج، فيما أن تكون مطلقة ثلاثاً، أو متوفى عنها زوجها، فهذان صنفان: الصنف الأول: المعتدة عن وفاة زوجها:

حكم خطبتها: حرام أن يصرح أحد بخطبتها، ويجوز التعريض لها بالخطبة في الصحيح عند الشافعية، وفي وجه ضعيف أنه إن كانت عدة الوفاة بالحمل لم تخطب؛ خوفاً من تكلف إلقاء ولدها(٤)، واستدل المجوزون للتعريض بالخطبة بالكتاب والسنة، والمعقول:

أما الكتاب فأيات منها: قال الله تعالى: {وَلَا تَعْرِمُوا عُدَّةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ}(٥)

(١) مغني المحتاج "٢١٩/٤".

(٢) الحاوي الكبير "٢٤٧/٩" فتح العزيز "٤٨٣/٧"، مغني المحتاج "٢١٩/٤".

(٣) فتح العزيز "٤٨٣/٧".

(٤) فتح العزيز "٤٨٣/٧".

(٥) سورة البقرة من آية ٢٣٥.

وجه الدلالة: أن المقصود بالعزم على عقدة النكاح هو التصريح بالخطبة، وبقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (١) يريد به انقضاء العدة، فيكون التصريح بالخطبة منهيًا عنه.

قال الله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ} (٢)
وجه الدلالة: المقصود بما عرضتم يعني بما عرضتم من جميل القول، أو أكنتم في أنفسكم من عقد النكاح، فدل على جواز التعريض بالخطبة للمتوفى عنها زوجها.

أما السنة: - عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا حَضَرْتُكَ الْمَرِيضَ، أَوْ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤْمِنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ»، قَالَتْ: فَلَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ قَدْ مَاتَ، قَالَ: «قُولِي: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِي مِنْهُ عُقْبَى حَسَنَةً»، قَالَتْ: فَقُلْتُ، فَأَعْقَبَنِي اللَّهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ لِي مِنْهُ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٣). وجه الدلالة: دل الخبر على جواز التعريض بالنكاح في عدة الوفاة.

أما المعقول فمن وجه: قالوا: لأن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ما ربما يبعثها على الإخبار بانقضاء العدة قبل أوانها، وقولها في انقضائها مقبول فتصير منكوبة في العدة، فحظر الله تعالى التصريح بخطبتها حسماً لهذا التوهم، فأما التعريض بخطبتها في العدة بما يخالف التصريح من القول المحتمل فجائز.

الصنف الثاني: المعتدة عن طلاق بائن بينونة كبرى، وهي المطلقة ثلاثاً، أو ما في معناها كالملاعنة، والمحرممة بمصاهرة، أو رضاع. حكم خطبتها: يختلف الحكم إن كان من يريد خطبتها زوجها الذي طلقها ثلاثاً أو غيره، فإن كان زوجها الذي طلقها ثلاثاً فلا يحل له التصريح ولا التعريض بالخطبة، لأنها لا تحل له بعد العدة فحرمت عليه الخطبة.

(١) سورة البقرة من آية ٢٣٥.

(٢) سورة البقرة من آية ٢٣٥.

(٣) صحيح مسلم، الجنائز، باب تلقين الموتى لا إله إلا الله، ٦ (٩١٩)

أما إن كان من يريد خطبتها غير زوجها الذي طلقها، فالتصريح لا يجوز له، بخلاف التعريض فإنه يجوز له، وإن كان المسعودي قد حكى قولاً في الإبانة أن التعريض أيضاً ممنوع (١). استدلل المجوزون للتعريض بالخطبة بالآتي:

١- ما روي أن فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص ثلاثاً فقال لها النبي - ﷺ - وهي في العدة: «إذا أحللت فأذنيني»، وروت أنه قال لها: «إذا حللت فلا تسبقيني بنفسك» (٢). وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «فلا تسبقيني بنفسك» تعريض يحتمل النكاح وعدمه، فجاز. ٢- وجواز التعريض وذلك لأن سلطة الزوج عنها قد انقطعت تماماً، فأشبهت المتوفى عنها زوجها. ٣- ولأن الله تعالى لما أباح التعريض بالخطبة دل على أنه لا يجوز التصريح بها، ولأن التعريض يحتمل النكاح وغيره، والتصريح لا يحتمل غير النكاح، فلا يؤمن أن يحملها الحرص على النكاح أن تخبر بانقضاء عدتها قبل انقضائها. واختلف الشافعية بعد اتفاقهم في حل التعريض، هل التعريض مكروه أم ليس مكروهاً، على قولين: الأول: قاله الشافعي في كتاب "الأم" أنه مكروه؛ لأن الآية واردة في المتوفى عنها زوجها. والقول الثاني: أنه غير مكروه قاله في القديم "والإملاء" قال الشافعي: ولو قال قائل: أمرها في ذلك أخف من المتوفى عنها زوجها جاز ذلك، لأن هناك مطلقاً يمنع من تزويجها قبل العدة.

القسم الثالث: البائن التي تحل للزوج، فهي المختلعة. حكم خطبتها: يختلف الأمر من كون مريد الخطبة زوجها الذي طلقها أو غيره، فإن كان زوجها إذا كانت في عدتها يجوز له أن يصرح بخطبتها؛ لأنه يحل أن يتزوجها في عدتها، وأما غير الزوج فلا يجوز له أن يصرح بخطبتها، وفي جواز تعريضه لها بالخطبة قولان: أحدهما: لا يجوز لإباحتها للمطلق كالرجعية. والقول الثاني: يجوز؛ لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثاً، فانقطعت سلطته عليها، وحصلت البيونة.

(١) البيان "٢٨١/٩".

(٢) رواه مسلم، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها، رقم ٣٨ (١٤٨٠)، ٢/ ١١١٤.

فائدتان: الأولى: في كل ما سبق إذا حرم على الرجل أن يخطب المرأة إلا بالتعريض دون التصريح، حرم عليها أن تجيبه إلا بالتعريض دون التصريح، ليكون جوابها مثل خطبته.

الثانية: وإذا حل التعريض للمرأة بالخطبة، جاز سرا، أو جهرا، لأن التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر (١).

فرع: حكم خطبة المحرم بعمرة أو حج: يكره للمحرم أن يخطب امرأة ولو لم تكن محرمة عند فقهاء الشافعية، كما يكره أن يخطب غير المحرم المحرمة، وذلك للآتي:

لما رواه مسلم عن عثمان رضي الله تعالى عنه مرفوعا: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب». والخطبة تراد لعقد النكاح فإذا كان ممتعا كره الاشتغال بأسبابه؛ ولأنه سبب إلى الحرام (٢).

الدرس السابع: حكم الخطبة على الخطبة

إن الإسلام بتشريعاته حريص على ترابط أفراد المجتمع، وتماسك بنيانه، وإن القرآن الحكيم دعا المؤمنين جميعا إلى أن يكونوا أمة واحدة قوية العقيدة، متينة الروابط، يتساوى أفرادها في الحقوق والواجبات، يتعاونون في جلب الخير لأمتهم، ودفع الشر عنهم، فقال عز من قائل: {وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} (٣)، ودعت السنة الشريفة الأمة إلى الترابط والتراحم، فقال ﷺ: «مثل المؤمنين في توادهم وترايبهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»، وقال أيضا: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا». لذا كانت التشريعات حريصة على أن تعمق هذا المعنى، وأن تدفع كل ما يؤدي للتنازع والعداوة والبغضاء، فينهى الشرع الحكيم عن أن يقدم رجل على خطبة امرأة بعدما سبق إلى خطبتها رجل قبله، حتى لا يكون التنازع، والحدق، والصراع، صح

(١) نهاية المطلب "٢٧٢/١٢"، الحاوي الكبير "٢٤٧/٩-٢٤٩"، البيان "٢٨٠/٩-٢٨٢"، فتح العزيز "٤٨٣/٧"، أسنى المطالب "١١٥/٣".

(٢) الحاوي الكبير "١٢٧/٤"، أسنى المطالب "٥١٣/١".

(٣) سورة آل عمران، من آية ١٠٣.

من حديث ابن عمر، وأبي هريرة، وعقبة بن عامر -رضي الله عنهم- عن النبي ﷺ: «النَّهْيُ عَنْ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ»، وفي بعضها: «إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» وفي بعضها: «حَتَّى يَتْرُكَ أَوْ يَنْكَحَ»، وفي بعضها: «حَتَّى يَنْكَحَ أَوْ يَتْرُكَ» (١)؛ وذلك حتى تصفو العلاقات بين أفراد المجتمع، وأن يحيوا جميعا عباد الله إخوانا.

ولفقاء الشافعية تفصيل في حكم خطبة الرجل على خطبة أخيه، مميزين بين أحوال المرأة المختلفة، فإذا خطب الرجل امرأة لم يخل حالها من خمسة أقسام:

القسم الأول: أن تأذن له في نكاحها، فتحرم بعد إذنها على غيره من الرجال أن يخطبها لنهيهِ -ﷺ- عنه حفظاً للألفة، ومنعاً من الفساد وحسماً للتقاطع، وسواء كان الأول كفأ أو غير كفء. فإن رجع الأول عن خطبته أو رجعت المرأة عن إجابته ارتفع حكم الإذن، وعادت إلى الحال الأولى في إباحة خطبتها لحديث أبي هريرة أن رسول الله -ﷺ- قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك».

فكان تحريم الخطبة هنا مبنيًا على الشروط التالية: أن يكون الخاطب الأول قد أجيب، ولم يترك المخطوبة، ولم يعرض عنها، ولم يفعل الخاطب الأول ما هو في حكم الإعراض، كما لو طال الزمان بعد إجابته بحيث يعد معرضاً، أو نكح من يحرم الجمع بينها وبين المخطوبة. ألا يأذن الخاطب الأول للخاطب الثاني في الخطبة، فإن أذن كان ذلك إعراضاً منه عن الخطبة، وإباحة للثاني أن يخطب. وأن يكون الخاطب الثاني قد علم بخطبة الأول وإجابته، أي ردت عليه المرأة أو وليها بالقبول. أن تكون إجابة الخاطب الأول صراحة، أي ليس هناك تردد من قبل المرأة أو وليها، بل صرحوا بالقبول، والمعتبر في التحريم أن تكون الإجابة من المرأة إن كانت معتبرة الإذن، ومن وليها إن كانت غير معتبرته، ومنها مع الولي إن كان الخاطب غير كفء، ومن السلطان إن كانت مجنونة بالغة فاقدة الأب والجد.

(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب لا يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع، رقم ٤٨٤٨، ٤٨٤٩، ٥/

١٩٧٥. ومسلم في صحيحه، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، رقم ٤٩

(١٤١٢)، ٥٠، (١٤١٢)، ٥١، (١٤١٣)، ٥٦، (١٤١٤)، ١٠٣٢/٢، وما بعدها.

أن تكون خطبة الأول جائزة، لم تقع في الوقت المحرم للخطبة، بأن لم يكن خطبها وهي في عدة، أو في عصمة رجل آخر، فإن خطبها وهي في العدة، وقبلت، ثم انتهت عدتها، فللخاطب الثاني أن يتقدم بخطبته؛ لأن الخطبة الأولى غير جائزة. وأن يكون الخاطب الثاني عالما بحرمة أن يتقدم لخطبة المرأة التي تمت خطبتها للخاطب الأول، فلو لم يعلم بالتحريم لم يكن آثما، لعذره.

القسم الثاني: أن ترد خاطبها، وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال أن يخطبها لأن المقصود بالنهي عن الخطبة رفع الضرر، والمنع من التقاطع، فلو حمل النهي على ظاهره فيمن لم تأذن له حل الضرر عليها.

القسم الثالث: أن تمسك عن خطبتها فلا يكون منها إذن، ولا رضا، ولا يكون منها رد، ولا كراهية، فلفقهاء الشافعية طريقان (١) في المسألة: الطريق الأول: القطع بجواز خطبتها وإن تقدم الأول لها. وذلك عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ أَبَا عَمْرٍو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ، وَهُوَ غَائِبٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكَيْلُهُ بِشَعِيرٍ، فَسَخِطَتْهُ، فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا لَكَ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: «لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ»، فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكِ، ثُمَّ قَالَ: «تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي، اعْتَدِي عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكَ، فَإِذَا حَلَلْتَ فَأَذِنِينِي»، قَالَتْ: فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ، وَأَبَا جَهْمٍ خُطْبَانِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَمَّا أَبُو جَهْمٍ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُغْلُوكَ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ» فَكَرِهَتْهُ، ثُمَّ قَالَ: «انكِحِي أُسَامَةَ»، فَتَكَحَّتْهُ، فَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا، وَاعْتَبَطْتُ بِهِ (٢). فكان الدليل من هذا الحديث من وجهين: أحدهما: أن أحد الرجلين قد خطبها بعد صاحبه فلم يذكر النبي -صلى

(١) الطرق: هي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب. فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان، ويقول الآخر لا يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً، أو يقول أحدهما في المسألة تفصيل ويقول الآخر فيها خلاف مطلق، وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه [مقدمة المجموع للنووي "٦٦/١" ط دار الفكر].

(٢) سبق تخريجه.

الله عليه وسلم - تحريمه. والوجه الثاني: أن النبي - ﷺ - قد خطبها لأسامة بعد خطبتها، فدل على أن الإمساك عن الإجابة لا يقتضي الخطبة.

الطريق الثاني: أن في المسألة قولين: أحدهما: الجواز، والثاني: المنع.

القسم الرابع: أن يخطب رجل امرأة إلى وليها، وكان ممن يخيرها، فعرض له بالإجابة ولم يصرح، مثل أن يقول: أنا أستشير في ذلك، أو أنت مرغوب فيك، أو يشترط شرائط للعقد، مثل: تقديم المهر وغيره، ففي تحريم خطبتها قولان عند الشافعية: أحدهما: وبه قال الشافعي في القديم، أنها تحرم خطبتها بالرضا، استدلالاً بالآتي: قوله ﷺ: «لا يخطب الرجل على خطبة أخيه» (١). وجه الدلالة: أن النهي في الحديث عام في كل خطبة، فلم يفرق بين خطبة وخطبة، فتحرم الخطبة الثانية على الإطلاق.

٢- ولأن في الخطبة الثانية إفساداً، لما يقارب بينهما، فحرمت. والقول الثاني: وبه قال الشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند الشافعية، إنه لا تحرم خطبتها بالرضا حتى يصرح بالإذن، وذلك للآتي: أن النبي - ﷺ - خطب فاطمة بنت قيس - رضي الله عنها - لأسامة - رضي الله عنه - بعد أن أخبرته: أن معاوية وأبا الجهم - رضي الله عنهما - خطباها، ولم يسألها: هل ركنت إلى أحدهما أو رضيت به أم لا؟ فدل على: أن الحكم لا يختلف بذلك، ولأن الظاهر من حالها: أنها ما جاءت تستشيره إلا وقد رضيت بذلك وركنت إليه. ولأن الأصل إباحة الخطبة. ما لم تتحقق شروط الحظر. فعلى هذا إن اقترن برضاها إذن الولي فيه نظر، فإن كانت ثيباً لا تزوج إلا بصريح الإذن، لم تحرم خطبتها، وإن كانت بكراً فيكون الرضا والسكوت منها إذناً حرمت خطبتها برضاها، وإذن وليها.

القسم الخامس: وهو أن يأذن وليها، من غير أن يكون منها إذن، أو رضى، فإن كان هذا الولي ممن يزوج بغير إذن كالأب والجد مع البكر حرمت خطبتها بإذن الولي، وإن كان ممن لا يزوج إلا بإذن منها لم تحرم خطبتها بإذن الولي حتى تكون هي الآذنة فيه (٢).

(١) سبق تخريجه.

(٢) ينظر [الحاوي الكبير] ٢٥١/٩-٢٥٢. نهاية المطلب ١٢/٢٧٤-١٧٧، البيان ٢٨٣/٩-٢٨٥. روضة الطالبين ٣١/٧، مغني المحتاج ٢٢١/٤-٢٢٢.

فرع: حكم الهجوم على الخطبة: المرأة التي لا يعلم أهي مخطوبة أم لا؟ أجيب خاطبها أم رد؟ يجوز لمن لا يعلم ذلك أن يخطبها، وذلك للآتي:

النبي ﷺ خطب فاطمة لأسامة بعد خطبة غيره ولم يكن يعلم أنها أجابت أو ردت. ولأن الأصل الإباحة، والخاطب معذور بالجهل، فيرتفع التحريم (١).

فرع: حكم الخطبة على خطبة الكافر. لا فرق في التحريم بين الخطبة على خطبة المسلم، أو خطبة الكافر، إذا كانت المرأة المخطوبة ذمية، بشرط أن يكون الكافر محترماً، أي معصوم الدم بأن يكون ذمياً، أو معاهداً، أو مستأمناً، وليس محارباً أو مرتداً، وذلك لإطلاق النهي في الحديث: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه».

ولفظ الأخ خرج مخرج الغالب، وفيه دعوة لسرعة الامتنال لتجنب النهي، ليس أكثر (٢).

فرع: حكم نكاح الرجل المرأة التي حرم عليه أن يخطبها لسبق خطبة غيره؟

بعد ما ثبت أن الرجل ليس له أن يخطب على خطبة أخيه، فلو أن رجلاً أقدم على هذا الأمر، وقام بخطبة امرأة سبقت خطبتها لرجل، وتم الأمر للخاطب الثاني، وتزوجها، فما هو حكم الزواج؟ الشافعية متفقون على صحة الزواج رغم حرمة الخطبة (٣).

وذلك للآتي: أن المحرم إنما يفسد العقد إذا قارنه، فأما إذا تقدم عليه.. لم يفسده، كما لو قالت امرأة: لا أتزوج فلاناً حتى أراه متجرداً أو حتى يجامعني، فتجرد لها أو جامعها، ثم تزوج بها. ولأن النهي إذا كان لمعنى في غير المعقود عليه لم يمنع من الصحة كالنهي عن أن يسوم الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لباد.

(١) فتح العزيز "٤٨٦/٧".

(٢) فتح العزيز "٤٨٦/٧"، مغني المحتاج "٢٢١/٤".

(٣) الحاوي الكبير "٢٥٣/٩"، البيان "٢٨٥/٩".

الدرس الثامن: أمور متعلقة بالخطبة والنكاح

فرع: الخطبة قبل الخطبة، وقبل العقد: يستحب للرجل إذا أراد أن يخطب امرأة، أن يقدم خُطبة -بضم الخاء- وهي الكلام المفتوح بحمد الله والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المختتم بالوصية والدعاء قبل الخطبة بكسر الخاء-، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرٌ» (١). فيحمد الله الخاطب، أو نائبه، ويصلي على النبي -ﷺ- ويوصي بتقوى الله، فيقول عقب الخطبة: جئت خاطباً كريمكم فلانة، ويخطب الولي كذلك، ثم يقول: لست بمرغوب عنك أو نحو ذلك (٢). وتستحب أيضاً خطبة -بالضم- قبل العقد، وهي أكد من الأولى، وليست هذه واجبة، بل هي فقط مستحبة (٣)، للحديث السابق: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر»، وليست واجبة استدلالاً بالكتاب، والسنة، والأثر، والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ} (٤). وجه الدلالة: أن الله جعل الإذن شرطاً في النكاح دون الخطبة، فدل ذلك على عدم وجوب الخطبة -بالضم-.

أما السنة: ١- فلأن النبي -ﷺ- حين زوج الواهبة لنفسها من خاطبها قال: «أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» (٥) فلم يخطب. وجه الدلالة: هذا الحديث صريح في عدم وجوب الخطبة -بالضم-، لأنها لو كانت واجبة لما تركها رسول الله ﷺ.

(١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب الهدى في الكلام، رقم ٤٨٤٢، ٤/ ٤٠٩. وابن ماجه، كتاب النكاح، باب خطبة النكاح، رقم ١٨٩٤، ١/ ٦١٠. كلاهما بلفظ (كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو أجذم)، واختلف في وصله وإرساله، فرجح النسائي والدارقطني الإرسال، ويروى: (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر)، وقال ابن الملقن: هذا الحديث حسن.

(٢) تلخيص الحبير، ٣/ ٣٢٢. البدر المنير، ٧/ ٥٢٨.

(٣) فتح العزيز "٤٨٨/٧"، مغني المحتاج "٢٢٣/٤".

(٤) الحاوي الكبير "١٦٣/٩"، فتح العزيز "٤٨٩/٧"، مغني المحتاج "٢٢٤/٤".

(٥) سورة النساء من آية ٢٥.

(٥) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النكاح، باب التزويج على القرآن وبغير صداق، رقم ٤٨٥٤.

أما الأثر: ١- روي أن الحسين بن علي -رضي الله عنها- زوج بعض بنات أخيه الحسن وهو يتعرق عظما أي لم يخطب تشاغلا به. ٢- وروي أن ابن عمر زوج بنته فما زاد على أن قال: قد زوجتها على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.

أما المعقول فمن وجهين: ١- فلأن الخطبة لو وجبت في النكاح لبطل بتركها، وفي إجماعهم على صحة النكاح بتركها دليل على استحبابها دون وجوبها.

ولأن النكاح عقد فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود (١).

فرع: ما تشتمل عليه الخطبة بالضم: إذا ثبت استحباب الخطبة فهي مشتملة على أربعة أمور: أحدها: حمد الله، والثناء عليه. والثاني: الصلاة على نبيه ﷺ.

والثالث: الوصية بتقوى الله وطاعته. والرابع: قراءة آية، والأولى أن تكون مختصة بذكر النكاح كقوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ} (٢). فإن قرأ آية لا تتعلق بذكر النكاح جاز؛ لأن المقصود بها التبرك بكلام الله تعالى. وقال ابن مسعود -رضي الله عنه- علمنا رسول الله ﷺ خطبة الحاجة: «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنُسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنُتَوِّبُ إِلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلِّ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ، وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَقْرَأُ الثَّلَاثَ آيَاتِ: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا﴾ (٣) ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ﴾ (٤) الآية. ثُمَّ تَقْرَأُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا﴾ (٥). ثُمَّ تَتَكَلَّمُ بِحَاجَتِكَ. قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لِأَبِي

(١) الحاوي الكبير "١٦٣/٩-١٦٤".

(٢) سورة النور من آية ٣٢.

(٣) سورة النساء، جزء من آية ١.

(٤) سورة آل عمران، جزء من آية ١٠٢.

(٥) سورة الأحزاب، جزء من آية ٧٠.

إِسْحَاقَ: هَذِهِ فِي خُطْبَةِ النِّكَاحِ أَوْ فِي غَيْرِهَا؟ قَالَ: "فِي كُلِّ حَاجَةٍ" (١) وكان القفال يقول بعدها: أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم، ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب قد سبق، فإن مما قضى الله وقدر أن يخطب فلان بن فلان فلانة بنت فلان على صداق كذا، أقول قولِي هذا، وأستغفر الله لي ولكم أجمعين.

فرع: حكم الخطبة - بالضم - وسط العقد: اختلف فقهاء الشافعية في إنشاء خطبة تتخلل العقد، هل تفسد العقد، أم لا تفسده؟ كأن يقول الولي: باسم الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد رسول الله، أوصيكم بتقوى الله. ويقول - كما روي عن ابن عمر - رضي الله عنهما: "أنكحتك على ما أمر الله به، ومن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان"، ثم يقول الزوج: باسم الله، والحمد لله، وصلى الله على رسول الله، أوصيكم بتقوى الله، قبلت نكاحها.

وكان اختلاف الشافعية فيها على وجهين: الأول: أن ذلك يصح، ولا يفسد عقد النكاح، وهذا وجه ذكره الشيخ أبو حامد، والمحاملي، وابن الصباغ، وهذا هو الصحيح، وقطع به الجمهور، وصححه إمام الحرمين. الثاني: أن هذا الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة - بالضم - يبطل العقد، وهذا وجه حكاه أبو إسحاق عن بعض الأصحاب، وصححه الماوردي.

دليل أصحاب الوجه الأول القائلين بصحة العقد: استدلوا بالمعقول: فقالوا: إن ذلك يصح، لأن الخطبة متعلقة بالنكاح، فلم يؤثر فصلها بين الإيجاب والقبول، كالتييم، والإقامة، بين صلاتي الجمع. ونوقش هذا بأمرين: الأول: بأن هذا الفصل يخالف التيم والإقامة، فإنهما مأمور بهما بين الصلاتين، والخطبة مأمور بها قبل العقد، فقياس مع الفارق، فيبطل.

والثاني: أن هذا الاستشهاد تكلف؛ فإنه لو تخلل بين صلاتي الجمع بمقدار الإقامة ما ليس من مصلحة الصلاة، لم يضر أصلاً، بخلاف عقد النكاح.

(١) رواه أبو داود في سننه. كتاب النكاح. باب في خطبة النكاح. رقم ٢١٢٠، ٢/٢٠٣. والترمذي في سننه، كتاب النكاح. باب ما جاء في خطبة النكاح، رقم ٤١٣/٣. والنسائي في السنن الكبرى، كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكلام عند النكاح. أرقام ٥٥٢٧، ٥٥٢٨، ٥٥٢٩، ٣/٣٢١-٣٢٢، وقال ابن الملقن في البدر المنير، ٧/٥٣١: هذا الحديث صحيح.

دليل أصحاب الوجه الثاني القائلين ببطلان العقد:

استدلوا بالمعقول من وجوه: فقالوا: ١- إن الفصل بين الإيجاب والقبول بالخطبة يبطل العقد، كما لو فصل بينهما بغير الخطبة. ٢- إن هذه الخطبة تطاول ما بين البذل والقبول، فتفسده. ٣- إن أذكار الخطبة ليست من البذل ولا من القبول، وما قيل من أن الخطبة الثانية مندوب إليها في العقد فلم يفسد بها العقد فصحيح إذا كانت في محلها قبل العقد، فأما في خلال العقد فلم يندب إليها فجاز أن يفسد بها العقد (١).

فرع: من استشير في خاطب أو مخطوبة: فعليه أن يذكر ما فيه من مساوئ شرعية، أو عرفية، ولا يكون غيبة محرمة إذا قصد به النصيحة والتحذير لا الإيذاء.

ومن استشير في أمر نفسه في النكاح بينه، كقوله: عندي شح، وخلقي شديد ونحوهما.

وفصل بعض الفقهاء، ومنه قول البارزي لو استشير في أمر نفسه في النكاح، فإن كان فيه ما يثبت الخيار فيه وجب ذكره، وإن كان فيه ما يقلل الرغبة فيه ولا يثبت الخيار، كسوء الخلق والشح، استحب، وإن كان فيه شيء من المعاصي وجب عليه التوبة في الحال وستر نفسه. وحكم ذكر المساويء هو الوجوب، فيجب أن يذكر عيوب الإنسان، ولا يكون ذلك غيبة، ولكن محل الوجوب متوقف على شروط ثلاثة: سلامة العاقبة بأن يأمن الذاهر على نفسه وماله وعرضه. أن يذكر مساوئ من أريد الاجتماع عليه المتعلقة بما لأجله الاجتماع، فيذكر لمن أراد النكاح المساوئ المتعلقة بالنكاح دون البيع مثلاً.

يجب تقديم الأخف فالأخف نحو لا يصلح، أو لا أصلح فإن توقف على ذكر أشخاص العيب ذكرها.

والدليل على جواز ذكر العيوب: ١- قوله ﷺ لفاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها لما أخبرته أن معاوية وأبا جهم رضي الله عنهما خطباها: «أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له».

(١) الحاوي الكبير "١٦٥/٩"، نهاية المطلب "١٨٣/١٢"، البيان "٢٣١/٩-٢٣٢"، فتح العزيز "٤٨٩/٧"، مغني المحتاج "٢٢٥/٤".

وجه الدلالة: فإن النبي ﷺ تعرض لذكر الخاطبين بما يكرها، فدل ذلك على جواز ذكر الإنسان بما يكره فيما يتعلق بأمر النكاح، فلا تكون الغيبة محرمة. وقوله عليه الصلاة والسلام: «أما معاوية: فصعلوك لا مال له» ففيه أنه يجوز أن يعبر بالأغلب على الشيء، ويذكر العموم والمراد به الخصوص؛ لأنه معلوم أنه لا يخلو أن يملك شيئاً من المال وإن قل، كثيابه وما أشبهها، وإنما أراد: أنه لا يملك ما يتعارفه الناس مالا. وقوله عليه الصلاة والسلام: «فلا يضع العصا عن عاتقه». ففيه تأويلان: أحدهما: أنه كان كثير الأسفار، قال الشاعر:

فألقت عصاها واستقر بها النوى... كما قر عينا بالإياب المسافر

والثاني: أنه أراد أنه كان كثير الضرب لزوجته.

٢- ولقوله ﷺ: «إذا استصح أحدكم أخاه فلينصحه».

فرع: الرجوع عن الخطبة: ذهب الشافعية إلى أن الخطبة ليست بعقد شرعي بل هي وعد، وإن تخيل كونها عقداً، فليس ب لازم بل جائز من الجانبين، ولا يكره للولي الرجوع عن الإجابة إذا رأى المصلحة للمخطوبة في ذلك؛ لأن الحق لها وهو نائب عنها في النظر لها، فلا يكره له الرجوع الذي رأى المصلحة فيه، كما لو ساوم في بيع دارها ثم تبين له المصلحة في تركها، ولا يكره لها أيضاً الرجوع إذا كرهت الخاطب؛ لأن النكاح عقد عمري يدوم الضرر فيه، فكان لها الاحتياط لنفسها والنظر في حظها، وإن رجعا عن ذلك لغير غرض كره لما فيه من إخلاف الوعد والرجوع عن القول، ولم يحرم لأن الحق بعد لم يلزمهما، كمن سام سلعة ثم بدا له ألا يبيعهها (١).

فرع: حكم الخاطب يرجع في هديته إذا عدل عن خطبته: قال الشافعية: من خطب امرأة ثم أنفق عليها نفقة ليتزوجها فله الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء أكان مأكلاً أم مشرباً أم حلوى أم حلياً، وسواء رجع هو أم مجيبه، أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها

(١) حاشية الجمل "١٢٩/٤".

فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف. ولو كان ذلك بقصد الهدية لا لأجل تزوجه بها لم يختلف في عدم الرجوع.

وقالوا: لو دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئاً من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس لمخطوبته أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما، أو لأحدهما رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه إن كان قبل العقد مطلقاً، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، لا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقاً (١).

فرع: عرض الولي موليته على ذوي الصلاح: يستحب للولي عرض موليته على ذوي الصلاح والفضل، كما عرض الرجل الصالح إحدى ابنتيه على موسى عليه الصلاة والسلام المشار إليه في قوله تعالى: {إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ} (٢)، وكما فعل عمر رضي الله عنه حيث عرض ابنته حفصة رضي الله تعالى عنها على عثمان، ثم على أبي بكر رضي الله تعالى عنهما (٣).

فرع: من سنن النكاح: أن ينوي الإنسان بالنكاح السنة وصيانة الدين. وأن يدعى للزوجين بالبركة بعد العقد، وبالجمع بخير فيقال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير

- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكُمَا وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ» ٤. - ويكره أن يقول: بالرفاء والبنين، وهو بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق، من قولهم: رفأت الثوب لورود النهي عنه.

- لما روى الإمام النسائي وابن ماجه وغيرهما عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا: بالرفاء والبنين فقال: لا تفعلوا ذلك «فإن رسول الله

(١) حاشية الجمل "١٢٩/٤".

(٢) سورة القصص من آية ٢٧.

(٣) مغني المحتاج "٢٢٥/٤".

(٣) رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةٍ.

ﷺ نهى عن ذلك» قالوا: فما نقول يا أبا زيد؟ قال: قولوا: بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر.

وأن يقدم الولي على العقد أزواج هذه أو زوجتكها على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولو شرطه في نفس العقد لم يبطل؛ لأن المقصود به الموعظة ولأنه شرط يوافق مقتضى العقد والشرع. ويسن للزوج أول ما يلقي زوجته أن يأخذ بناصيتها ويقول: بارك الله لكل منا في صاحبه، وأن يقول عند الجماع: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا (١).

الدرس التاسع: أركان عقد النكاح، وبيان كل ركن وشروطه

إن عقد الزواج كسائر العقود، لا بد فيه من توفر أمور عدة حتى يكون صحيحا على وفق ما أقرته الشريعة السمحة، وتترتب عليه الآثار التي جعلتها الشريعة، من حقوق وواجبات على شريكي الحياة، وإن لم تتوافر فيه هذه الأمور كان العقد عند الشافعية باطلا لا يترتب عليه أي أثر من آثار العقد، ولا ينبني عليه أية حقوق أو واجبات.

وأركان النكاح التي لا بد من توفرها، والتي لا ينعقد ولا يصح النكاح بدونها خمسة:

الولي، الزوج، الزوجة، الشاهدان، الصيغة. ولقد بدأت بالولي نظرا لأهمية هذا الركن عند السادة الشافعية، واعتبارهم أن النكاح يكون باطلا لو تم بدون ولي يتولى أمر العقد، ونظرا لأن الأركان الأخرى من الصيغة والزوجين والشاهدين... الأمة متفقة عليها كأسس وإن اختلفوا في التفاصيل، فأخرت الحديث عنها، بخلاف الولي، الذي خالف في اشتراطه بعض الفقهاء، فنظرا لأهميته بدأت بالحديث عنه.

الركن الأول: الولي. فلا يصح ولا ينعقد النكاح بدون ولي، بل لو تم بدون ولي كان باطلا، هذا اتفاق فقهاء الشافعية جميعا، فلا تصح عبارة المرأة في النكاح إيجابا وقبولا، فلا تزوج

(١) فتح العزيز "٤٩١/٧"، البيان "٢٣٢/٩"، أسنى المطالب "١١٧/٣"، مغني المحتاج "٢٢٥-٢٢٦/٤".

نفسها بإذن الولي ولا بغير إذنه، ولا غيرها لا بولاية ولا بوكالة، ولا تقبل النكاح لا بولاية ولا بوكالة (١).

قال إمام الحرمين: "ولا تصلح عبارتها بعقد النكاح مطلقا، فلا تزوج نفسها، ولا غيرها بولاية، ولا ملك، ولا نيابة، لا موجبة، ولا قابلة" (٢). قال العمراني: "عقد النكاح -عندنا- لا ينعقد إلا بولي ذكر، سواء كانت المرأة صغيرة أو كبيرة، بكرا أو ثيبا، نسيبة أو غير نسيبة" (٣).

واستدل فقهاء الشافعية على أن الولي لا بد منه في عقد النكاح، ولا يجوز للمرأة أن تتولى عقد النكاح بنفسها، بالكتاب والسنة والإجماع، والقياس:

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَرْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٤). وجه الدلالة: أولا هذه الآية نزلت في معقل بن يسار قال: هذه الآية نزلت في شأني، وذلك أنه زوج أخته من رجل، فدخل بها، ثم طلقها فلم يراجعها حتى انقضت عدتها، ثم خطبها فرفضت به، فامتنع معقل من تزويجها منه، وقال: زوجتك أختي وأكرمتك بها فطلقتها؟ والله لا نكحتها أبدا، فنزلت هذه الآية، فقال معقل: سمعا وطاعة، فزوجها منه وكفر عن يمينه. ودلت الآية على ثبوت الولاية من وجهين: أحدهما: نهي الأولياء عن عضلهم، والعضل المنع في أحد التأويلين، والتضييق في التأويل الآخر، فلو جاز لهن التفرد بالعقد لما أثر عضل الأولياء ولما توجه إليهم نهي. والثاني: قوله في سياق الآية: {إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٥). والمعروف ما تناوله العرف بالاختيار وهو الولي وشاهدان.

(١) الحاوي الكبير "٣٨/٩"، نهاية المطلب "٣٩/١٢"، البيان "١٥٢/٩"، مغني المحتاج "٢٣٩/٤".

(٢) نهاية المطلب "٣٩/١٢".

(٣) البيان "١٥٢/٩".

(٤) سورة البقرة من آية ٢٣٢.

(٥) سورة البقرة من آية ٢٣٢.

وأما السنة، فأحاديث منها: ما روي عن أبي موسى أن النبي -ﷺ- قال: «لا نكاح إلا بولي» (١). وروي عن عمران بن حصين بلفظ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل» (٢).

وجه الدلالة: هذا نهى عام في كل نكاح من صغيرة وكبيرة وشريفة ودنية وبكر وثيب.

وقوله: «لا نكاح إلا بولي» يقتضي أن يكون الولي رجلاً، ولو كانت هي المراد لقال: لا نكاح إلا بولية. عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، وإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا - أو قال: اختلفوا - فالسلطان ولي من لا ولي له» (٣). وجه الدلالة: هذا نص في إبطال النكاح بغير ولي من غير تخصيص ولا تمييز. روى الدار قطني عن أبي هريرة أن النبي -ﷺ- أنه قال: «لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها»، وكنا نقول: إن التي تزوج نفسها هي الزانية ٤.

وأما الإجماع: فمبني على أقوال وأفعال الصحابة الذين رووا أحاديث رسول الله ﷺ، وثبت عنهم عدم إقرار النكاح بغير ولي، ولا مخالف لهم.

روي عن الشعبي أنه قال: لم يكن في الصحابة أشد في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب. وروي عن عمر أنه قال: "لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها أو ذي الرأي من أهلها أو السلطان". وجه الدلالة: هذا الأثر فيه تأويلان: أحدهما: قوله "إلا بإذن وليها" إن كان واحداً، أو ذي الرأي من أهلها إن كانوا جماعة، أو السلطان إن لم يكن لها ولي. الثاني: بإذن وليها إن كان لها ولي، فإن لم يكن لها ولي زوجها السلطان بمشورة ذي الرأي من أهلها وذوي أرحامها. وهذا قول من ذكرنا من الصحابة، وليس في التابعين مخالف فثبت أنه إجماع.

(١) رواه أبو داود ٢٠٨٥ والترمذي ١١٠١ وابن ماجه ١٨٨١، وقال ابن الملقن: صححه الحاكم، والبخاري، والترمذي خلاصة البدر المنير، ١٨٧/٢، ط دارالرشد، الطبعة الأولى)

(٢) رواه عبد الرزاق ١٠٤٧٣ ورواه أيضا البيهقي والدارقطني وغيرهما.

(٣) قال ابن الملقن في الخلاصة ١٨٧/٢: رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وابن حبان والحاكم، وقال الترمذي: حسن، وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، وقال ابن الجوزي: رجاله رجال الصحيح، وقال ابن معين: إنه أصح حديث في الباب.

(٢) قال ابن الملقن: إسناده على شرط مسلم.

أما القياس فمن وجوه: أن كل من كان من زوائد عقد النكاح كان شرطاً فيه كالشهود.

ولأن ما اختص من بين جنسه بزيادة عدد كانت الزيادة شرطاً فيه كالشهادة في الزنا.

ولأن من عقد على نفسه واعترض عليه غيره في فسخه دل على فساد عقده كالأمة والعبد إذا زوجا أنفسهما.

ولأن النكاح أحد طرفي الاستباحة فلم تملكه المرأة كالطلاق. ولأن المرأة غير مأمونة على البضع لنقصان عقلها وسرعة انخداعها فلم يجز تفويضه إليها كالمبذر في المال. ولأن لولي المرأة قبل بلوغها حقين: حقاً في طلب الكفاءة، وحقاً في طلب العقد، فلما كان بلوغها غير مسقط لحقه في طلب الكفاءة كان غير مسقط لحقه في مباشرة العقد (١).

ولقد عبر الدهلوي عن أمر اشتراط الولي في النكاح بقوله: "وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم، واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشؤها قلة الحياء واقتضاب على الأولياء وعدم اكتراث لهم، وأيضا يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير، وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها" (٢).

فرع: ومع اشتراط الولي في عقد النكاح، فليس للولي أن يضيق أو يعترض على إنكاح موليته لأهل الكفاءة لها إن هي وافقت ورضيت به زوجاً، بشرط أن تكون المرأة التي تدعو وليها لإنكاحها حرة، بالغة، عاقلة، تدعو إلى كفاء، رضيت به.

فيلزم الولي إنكاحها ولا يسوغ له منعها لقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكَحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (٣). وجه الدلالة: أن الآية نهت الأولياء عن منع مولياتهم من النكاح متى رضيت بالرجل زوجاً. وفي العضل قولان: أحدهما: أنه المنع ومنه قولهم: داء عضال إذا امتنع من أن يداوى، وفلان عضلة أي داهية، لأنه امتنع بدهائه.

(١) ينظر الحاوي الكبير "٣٩-٤٢"، المذهب "٢/٢٤٦"، البيان "٩/١٥٣-١٥٤"، مغني المحتاج "٤/٢٤٢-٢٤٣".

(٢) حجة الله البالغة "٢/١٦٩".

(٣) سورة البقرة من آية ٢٣٢.

والثاني: أنه الضيق، ومنه قولهم قد أعضل بالجيش الفضاء إذا ضاق بهم، وقول عمر قد أعضل بي أهل العراق لا يرضون عن والٍ ولا يرضى عنهم والٍ. وفي قوله: {إِذَا تَرَاصُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ} تأويلان: أحدهما: إذا تراضى الزوجان بالمهر. والثاني: إذا رضيت المرأة بالزواج المكافئ (١).

فإن رفض الولي زواجها انتقلت الولاية للسلطان: لقوله ﷺ: «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له». ولأن هذا حق توجه على الولي تدخله النيابة، فإذا امتنع قام السلطان مقامه، كما لو كان عليه دين فامتنع من أدائه فيجبر على أدائه (٢).

شروط الولي: للولي شروط يجب أن تتوفر فيه، ليكون أهلاً للقيام بمسئولية الولاية حق القيام، وهذه الشروط على النحو الآتي: ١ - الإسلام، ذهب فقهاء الشافعية إلى اشتراط الإسلام في ولاية المسلم على المسلمة. ٢ - من شروط الولي العقل والبلوغ، فلا بد أن يكون الولي بالغاً عاقلاً (٣). فلا تثبت الولاية لمجنون ولا صبي، ولا لمن اختل عقله لهرم أو خبل، وذلك للآتي: لأنهم ليسوا من أهل الولاية. ولأن أهلية الولاية بالقدره على تحصيل النظر في حق المولى عليه وذلك بكمال العقل والرأي ولم يوجد، ألا ترى أن لا ولاية لأي منهم على نفسه فكيف يكون على غيره؟! هذا في المجنون جنونا مطبقاً، أما المجنون جنونا منقطعاً، فاختلف فقهاء الشافعية في حكم ولايته على وجهين: الأول: أن الولاية تذهب عنه كالمجنون المطبق، ويزوج المرأة الولي الأبعد في يوم جنون الولي الأقرب. وهو الصحيح عن ابن كج، وإمام الحرمين. الثاني: أن الجنون المتقطع لا يزيل الولاية، لأنه أشبه بالإغماء. وهو الأصح عند البغوي (٤). واختلف فقهاء الشافعية في أمر المحجور عليه بسفه، هل يكون ولياً في

(١) الحاوي الكبير "٣٧/٩".

(٢) المهذب "٤٢٩/٣".

(٣) مغني المحتاج "٢٥٣/٤-٢٥٤"، كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار للحصني الدمشقي "٣٥٧/١" ط دار الخير - دمشق، عام ١٩٩٤ م.

(٤) فتح العزيز "٥٥٠/٧".

النكاح، على طريقتين: الطريق الأول: أنه لا يكون وليا، لأنه ممنوع من عقد النكاح لنفسه فلم يجز أن يكون وليا لغيره. وهذا هو المشهور. والطريق الثاني: في المسألة وجهان:

الوجه الأول: لا يكون المحجور عليه وليا. والوجه الثاني: له الولاية، لأنه إنما حجر عليه في المال خوفا من إضاعته وقد أمن ذلك في تزويج ابنته فجاز له أن يعقد كالمحجور عليه للفلس. وهذا وجه لأبي العباس ابن سريج، والشيرازي (١).

٣ - من شروط الولاية الحرية، فذهب فقهاء الشافعية إلى أنه يشترط في الولي أن يكون حرا، (٢)، وذلك للآتي: لأنه لا ولاية للمملوك على أحد لأنه ليس من أهل الولاية، ألا ترى أنه لا ولاية له على نفسه. ولأن الولاية تنبئ عن المالكية، والشخص الواحد كيف يكون مالكا ومملوكا في زمان واحد. وأن هذه الولاية ولاية نظر ومصالحة، ومصالح النكاح لا يوقف عليها إلا بالتأمل والتدبر، والمملوك باشتغاله بخدمة مولاه لا يتفرغ للتأمل والتدبر فلا يعرف كون إنكاحه مصلحة. ولأنه ناقص بالرق، بدليل: أنه لا يرث ولا يشهد، وولاية النكاح مبنية على الكمال، فلم تثبت مع وجود النقص. ٤ - من شروط الولاية العدالة، واختلف فقهاء الشافعية في الفاسق هل يلي النكاح أم لا يليه؟ على طرق ستة:

الطريق الأول: أن المسألة فيها قولان: القول الأول: أن الفاسق يلي عقد النكاح، ولا تزول الولاية بالفسق، وحجته الكتاب والمعقول: أما الكتاب: فقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٣). وجه الدلالة: عموم الأمر للأولياء لا فرق بين العدل والفاسق، فلا تزول الولاية بالفسق.

وأما المعقول فمن وجوه: أ- لأن من تعين في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج.

ب- ولأن كل من جاز أن يقبل النكاح لنفسه جاز أن يلي على النكاح غيره كالعدل.

ت- ولأنه لما جاز للفاسق تزويج أمته جاز له تزويج وليته.

(١) الحاوي الكبير "١١٨/٩"، فتح العزيز "٥٥١/٧"، مغني المحتاج "٢٥٤/٤".

(٢) البيان "١٦٩/٩"، فتح العزيز "٥٤٩/٧"، مغني المحتاج "٢٥٣/٤".

(٣) (النور، من آية ٣٢).

ج - ولأنه لما جاز أن يكون الكافر وليا في نكاح ابنته فأولى أن يكون الفاسق وليا في نكاح ابنته. القول الثاني: الولي في النكاح شرط في صحة عقده، فإن كان الولي فاسقا بطل عقده، سواء كان الولي ممن يجبر على النكاح كالأب، أو ممن لا يجبر كالعصباء.

وهذا على الظاهر من مذهب الشافعي، والمشهور من قوله، وحجته السنة والمعقول:

أما السنة: أ- فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل» (١). ب- وما رواه ابن عباس موقوفا: «وأیما امرأة أنکحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل». وجه الدلالة: أنه نفى النكاح إلا أن يكون عن طريق ولي يجيد النظر والتأمل، ويكون مرشدا في فعله، والفاسق غير رشيد في فعله، فلا تصح منه الولاية.

وأما المعقول فمن وجوه: أ- أن الفسق نقص يمنع من الشهادة، فوجب أن يمنع من الولاية كالرق. ب- ولأنها ولاية تمنع منها الرق فوجب أن يمنع منها الفسق كالولاية على المال.

ت- ولأن من تولى عقد النكاح في حق غيره منع الفسق من عقده كالحاكم.

ج- ولأن الولي إنما اشترط في العقد لئلا تحمل المرأة شهوتها على أن تضع نفسها في غير كفاء، أو تزوج نفسها في العدة، فيلحق العار بأهلها، وهذا المعنى موجود في الفاسق؛ لأنه لا يؤمن أن يحمله فسقه على أن يضع المرأة في أحضان غير كفاء، أو يزوجه في العدة، فيلحق العار بأهلها، فلم يجز أن يكون وليا. الطريق الثاني: القطع بمنع تولي الفاسق ولاية النكاح. وهذا قول أبي علي ابن أبي هريرة، وابن القطان، والطبري.

الطريق الثالث: القطع بأن الفسق لا يمنع الولاية. وهذا اختيار القاضي أبي حامد، والقفال، وأبي محمد الجويني. الطريق الرابع: أن الأب والجد لا تزول ولايتهما بفسقهما، وتزول ولاية غيرهما بالفسق. وحجته: كمال شفقة الأب والجد، وقوة ولايتهما على المرأة دون غيرهما.

الطريق الخامس: أن الأب والجد تزول ولايتهما بالفسق، وغيرهما لا تزول ولايته بالفسق.

وهذا قول أبي إسحاق. وحجته: أن الأب والجد لهما حق الإيجاب فقد يضعانها تحت فاسق مثلهما، أما غيرهما فإنه يلي عقد النكاح بإذنهما، فإن لم ينظر لها وأحسن الاختيار نظرت هي لنفسها ولم تأذن له.

(١) قال ابن الملقن في الخلاصة رقم ١٩٤٨: رواه الشافعي في سننه كذلك، والبيهقي بلفظ: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان" قال الطبراني: تفرد به القواريري. قال البيهقي: هو ثقة متفق على عدالته إلا أن المشهور وقفه على ابن عباس: لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد.

الطريق السادس: إن كان الفسق بسبب شرب الخمر فتزول الولاية، لاضطراب النظر وغلبة السكر عليه، وإن كان الفسق بسبب آخر فلا تزول الولاية (١). هذا كله في الولي غير الحاكم، أما إن كان الحاكم هو الولي في عقد النكاح فلا يؤثر فسقه. قال الخطيب الشربيني: "أما الإمام الأعظم فلا يقدح فسقه؛ لأنه لا ينعزل به فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة تفخيماً لشأنه، فعليه إنما يزوج بناته إذا لم يكن لهن ولي غيره كبنات غيره" (٢).

فرع: وعلى القول بأن الفسق يرفع الولاية، فلو أن هذا الولي الفاسق وكل وكيلاً عدلاً كانت وكالته باطلة؛ لأن الفسق قد زالت عنه الولاية فلم يصح منه الوكالة، ولكن لو كان الولي عدلاً فوكل وكيلاً فاسقاً ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: لا يجوز؛ لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها كان أولى أن يبطل ولاية الوكيل مع ضعفها. والوجه الثاني: يجوز ويصح عقده؛ لأنه مأمور والولي من ورائه لاستدراك ذلك. والوجه الثالث: أنه إن كان وكيلاً لولي غيرها على النكاح كالأب بطلت وكالته بفسقه؛ لأنه لا يلزمه استئذانها فصارت ولاية تفويض، وإن كان وكيلاً لمن لا يجبرها على النكاح صحت وكالته لأنه لا يعقد إلا عن استئذانها

من الشروط الواجب توافرها في الولي ألا يكون مكرهاً، بأن يكون مختاراً في عقده النكاح، فلا يصح نكاح الولي الذي أكره على عقد النكاح. بدليل قوله ﷺ: «وُضِعَ عَنْ أُمِّتِي الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ» (٣)، (١).

(١) ينظر الحاوي الكبير ٦١/٩، نهاية المطلب ٥٠/١٢، البيان ١٧٠/٩، فتح العزيز ٥٥٣/٧، مغني المحتاج ٢٥٥/٤.

(٢) مغني المحتاج ٢٥٦/٤.

(٣) روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة عن رسول الله ﷺ، وهذا اللفظ عند الإمام الطبراني في المعجم الأوسط رقم ٨٢٧٣، وقال عنه الإمام الهيثمي: فيه محمد بن مصفى، وثقه أبو حاتم وغيره، وفيه كلام لا يضر، وبقيّة رجاله رجال الصحيح، ومعنى هذا الحديث روي بألفاظ مختلفة من طرق مختلفة لا تخل جميعها عن مقال، وفصل القول فيها الإمام ابن الملقن، والإمام ابن حجر ونقلوا عن النووي قوله عنه أنه حديث حسن، وذكرنا فائدة حسنة تجدر الإشارة إليها وهو أنه يشتهر في كتب الفقهاء والأصوليين ذكر هذا الحديث بلفظ (رُفِعَ عَنْ أُمِّتِي) وهي غير موجودة في مصنفات المحدثين.

(انظر: المعجم الأوسط، للإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني، ١٦١/٨، ط دار الحرمين، القاهرة، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، للإمام أبي الحسن نور الدين الهيثمي، ٢٥٠/٦، ط مكتبة القدسي القاهرة، ١٤١٤هـ).

واختلف فقهاء الشافعية في أمور منها: الأعمى هل له حق الولاية أم لا؟ على وجهين:

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة لا تصح ولايته؛ لأن العمى يمنعه من طلب الحظ لوليته.

والوجه الثاني: أن ولايته ثابتة وعقده صحيح، لأن شعيب زوج موسى بابنته، وكان ضريرا ولأنه قد يصل إلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال لأن معرفة الحظ لا توصل إليه بالمشاهدة والعيان. فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله. وإن قيل بالوجه الأول: أنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا؟ على وجهين: أحدهما: لا يصح توكيله؛ لأنه لما لم تصح منه مباشرة لا تصح عنه الاستنابة من باب أولى. والوجه الثاني: يصح منه التوكيل فيه وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعته وشرائه لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه. ب- الأخرس، في صحة ولايته وجواز عقده وجهان: أحدهما: أن ولايته باقية وعقده صحيح؛ لأنه قد يصل إلى معرفة الحظ وقد تقوم إشارته فيه مقام النطق كما يقوم مقامه في حق نفسه، فعلى هذا يصح منه أن يتولاه بنفسه وأن يوكل.

والوجه الثاني: لا يصح منه العقد؛ لأن إشارته محتملة، وإذا أقيمت في حق نفسه لضرورة مقام نطقه لم تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره فعلى هذا لا يصح منه التوكيل وجها واحدا؛ لأن المعنى في احتمال الإشارة موجود في توكيله لوجوده في عقده فلم يصح منه.

ترتيب الأولياء: الشافعية يرون ترتيب الأولياء في النكاح بحسب الجهة التي يدلون

بها إلى المولى عليها، فتقدم جهة القرابة، ثم الولاء، ثم السلطنة.

وأحق الأولياء بالتزويج أب لأن أغلب الأولياء يدلون به، ثم جد لأب، ثم أبوه وإن علا، لاختصاص كل منهم عن سائر العصابات بالولادة مع مشاركته في العصوبة، ثم أخ لأبوين ثم أخ لأب، لأن الأخ يدلي بالأب فهو أقرب من ابنه، ثم ابن الأخ لأبوين، ثم ابن الأخ لأب

١٩٩٤م. التلخيص الحبير في تخریج أحادیث الرافعي الكبير، للإمام ابن حجر العسقلاني، ١/ ٦٧١، ط دار

الكتب العلمية، الطبعة الأولى، ١٤١٩ هـ، ١٩٩٨م. البدر المنير، ٤/ ١٧٧، روضة الطالبين ٨/ ١٩٣)

(١) الأشباه والنظائر للسيوطي "٢٠٣" ط دار الكتب العلمية- بيروت، ١٤١٤هـ.

وإن سفل؛ لأنه أقرب من العم، ثم عم لأبوين ثم عم لأب، ثم ابن كل منهما وإن سفل، ثم سائر العصبة من القرابة.

أنواع الولاية في النكاح: ذهب فقهاء الشافعية إلى أن الولاية في النكاح بحسب المولى عليه نوعان: ١- ولاية إجبار: وهي تنفيذ القول بالإنكاح على الغير، أي أن يباشر الولي العقد فينفذ على المولى عليه شاء أو أبى. ٢- ولاية اختيار: أو ولاية ندب واستحباب.

وليس في هذه الولاية تنفيذ القول على الغير أو إجباره، ومقتضاها أن نكاح المولى عليه يصح بعد أخذ إذنه أو اختياره.

أولاً: ولاية الإيجاب: تثبت هذه الولاية للأب والجد فقط دون باقي العصبة في حالات متعددة: الأولى: تزويج ابنته البكر صغيرة، أو كبيرة، عاقلة، أو مجنونة بغير إذنها، فلا بد من إجبارهن على النكاح فيزوج الأب ابنته البكر من غير أن يراعي اختيارها ويكون العقد لازماً لها في صغرها وبعد كبرها، وكذلك الجد وإن علا يقوم في تزويج البكر مقام الأب إذا فقد الأب، والإمام الشافعي جعل الإيجاب معتبراً بالبكارة دون الصغر، وذلك استدلالاً بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئُسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ} (١). وجه الدلالة: أن المقصود بقوله تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحْضُنْ}. الصغار، والصغيرة تجب العدة عليها من طلاق الزوج، فدل على جواز العقد عليها في الصغر.

وأما السنة: فما روي عن عائشة أنها قالت: تزوجني رسول الله -ﷺ- وأنا ابنة سبع، ودخل بي وأنا ابنة تسع، ومات عني، وأنا ابنة ثماني عشر.

وجه الدلالة: هذا حديث واضح في صحة زواج البنت الصغيرة، فتزوج الرسول ﷺ السيدة عائشة وهي طفلة صغيرة، والطفلة لا يمكن أن يكون لها اختيار ولا يقبل منها قولها فدل ذلك على صحة إجراء الولي عقد الزواج لها.

(١) سورة الطلاق من آية ٤.

وعن ابن عباس أن النبي -ﷺ- قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها، وإذنها صماتها».

وجه الدلالة: أنه لما جعل الثيب أحق بنفسها من وليها علم أن ولي البكر أحق بها من نفسها ويكون قوله: «والبكر تستأذن في نفسه» محمولا على الاستحباب دون الوجوب استطابة للنفس؛ لأنه لو كان محمولا على الوجوب لصارت أحق بنفسها من وليها كالثيب.

أما المعقول فمن وجوه: ١- أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير رضاها كالأمة وكالبكر الصغيرة.

٢- أن ما استحق بالولاية في نكاح الصغيرة استحق بالولاية في نكاح الكبيرة قياسا على طلب الكفاءة. ٣- أنه لو لم يكن له تزويجها جبرا في الكبر لما كان له تقويت بضعها في الصغر كالطفل يقتل أبوه لما لم يكن لولي تقويت خياره عليه في القود والدية بعد البلوغ لم يكن له تقويته عليه قبل البلوغ، وكان القاتل محبوسا حتى يبلغ فيختار أحد الأمرين.

إذا ثبت هذا: فإن زَوْج الأب أو الجد البكر البالغ.. فالمستحب لهما: استئذانها، وإذنها صماتها للخبر، ولأنها تستحيي أن تأذن بالنطق. والمستحب في الاستئذان أن يرسل إليها نسوة ثقات ينظرن ما في نفسها، والأم بذلك أولى لأنها تطلع على ما لا يطلع عليه غيرها.

فإن لم يستأذناها.. جاز، لأن النبي -ﷺ- قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن» فقصده بذلك التفرقة بينهما، فلو قلنا: إن استئذان البكر واجب.. لما كان بينهما فرق (١). ولكن حفظا لحق الفتاة في أن تأنس بزوجها، وأن تتحقق لها المصلحة المرجوة من زواجها، كانت هناك شروط على الأب والجد في تزويج موليتهم بغير إذنها على النحو الآتي: الأول: أن لا يكون بين الأب أو الجد وبينها عداوة ظاهرة.

الثاني: أن يزوجه من كفاء. الثالث: أن يزوجها بمهر مثلها. الرابع: أن يكون من نقد البلد. الخامس: أن لا يكون الزوج معسرا بالمهر. السادس: أن لا يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كأعمى وشيخ هرم.

(١) الحاوي الكبير ٥٢/٩-٥٣، البيان ١٧٨/٩، فتح العزيز ٥٣٧/٧، مغني المحتاج ٢٤٦/٤.

السابع: أن لا يكون قد وجب عليها الحج، فإن الزوج قد يمنعها لكون الحج على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة ذمتها (١).

الثانية: من حالات الإجبار تزويج - الأب أو الجد - مجنونة أطبق جنونها بالغة محتاجة ولو ثيبا لاكتسابها المهر والنفقة، وربما كان جنونها لشدة الشيق، لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها، ولهما ولاية الإجبار، إن ظهرت مصلحة في تزويجها، والمجنونة ليست من أهل الإذن، ولا يرجى لها حال تصير فيه من أهل الإذن.

الثالثة: من حالات الإجبار تزويج - الأب أو الجد - مجنون بالغ أطبق جنونه وظهرت حاجته للنكاح بظهور رغبته فيه إما بدورانه حول النساء وتعلقه بهن، أو بتوقع شفائه بالوطء بقول عدلين من الأطباء لظهور المصلحة المترتبة على ذلك (٢).

ثانيا: ولاية الاختيار: وهي ولاية لا تتيح لصاحبها أن يزوج المرأة إلا بعد إذنها وجوبا، فلا ينعقد الزواج ولا يتم إلا بإذنها وقبولها ورضائها، وتثبت في حالتين:

الحالة الأولى: تثبت لباقي العصوبة غير الأب والجد، كالإخوة والأعمام في تزويج البكر البالغة، لم يكن لهم إجبارها إجماعا، وليس لهم تزويجها إلا بإذنها، فإن كانت البكر صغيرة فليس لأحد من العصبات تزويجها بحال، وذلك استدلالا بالآتي:

أن قدامة بن مظعون زوج ابنة أخيه من عبد الله بن عمر فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فقال: «إنها يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» (٣). وجه الدلالة: أن الرسول ﷺ لم يجعل لقدامة تزويج موليته حتى البلوغ، لتكون الفتاة كاملة الحق في الإذن من عدمه، فدل ذلك على أنها لا تزوج صغيرة، حتى تبلغ وتبدي رأيها، فلا إجبار عليها.

ولأن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها كالعم مع الثيب طردا، أو كالسيد مع أمتة عكسا.

(١) مغني المحتاج "٢٤٦/٤".

(٢) البيان "١٨٥/٩"، مغني المحتاج "٢٧٧/٤".

(٣) رواه أحمد والدارقطني.

ولأنها ثبتت للأب في الصغيرة من غير تولية فوجب أن يختص بها من بين العصبات كولاية المال (١).

الحالة الثانية: من حالات الاختيار، تزويج الثيب الكبيرة فلا يجوز إجبارها ولا تزويجها إلا باختيارها وعن إذننها سواء كان وليها أبا أو عصبه.

وأما الثيب الصغيرة فليس لأحد من أوليائها أبا كان أو غيره أن يزوجه إلا بعد بلوغها وإذننها، فإن زوجها قبل البلوغ بإذن أو بغير إذن كان النكاح باطلا.

وذلك استدلالا بالآتي: قوله ﷺ: «الثيب أحق بنفسها من وليها».

وجه الدلالة: منطوق الحديث أن الثيب أحق بنفسها في زواجها فتبدي رأيها فلم يكن للولي إجبارها لأنه يصير أحق بها من نفسها. وقال ﷺ: «ليس للولي مع الثيب أمر». وجه الدلالة: أن هذا نفي أن يكون للولي إجبار على الثيب، فكان على عمومته في الصغيرة والكبيرة، فالكبيرة لا تزوج إلا بإذننها، والصغيرة لا تزوج أبدا لأنه لا اعتبار لإذننها قبل بلوغها، فيصبر حتى تبلغ. فلا يصح نكاح الثيب البالغة إلا بإذننها، ولا يصح إذننها إلا بنطقها مع قدرتها على النطق، لقوله ﷺ: «والبكر تستأذن في نفسها وإذننها صماتها»، فلما جعل إذن البكر الصمت.. دل على: أن إذن الثيب النطق. فإن كانت خرساء، وأشارت إلى الإذن بما يفهم منها.. صح تزويجها (٢).

فرع: اجتماع أكثر من ولي للمرأة في درجة واحدة.

إن اجتمع للمرأة أولياء في درجة واحدة، وكانت لهم ولاية اختيار، كالأخوة أو بنيتهم، أو الأعمام أو بنيتهم، فالمستحب: أن يقدم أكبرهم سنا وأعلمهم وأورعهم، وذلك استدلالا بالآتي: لما روي: أن حويصة ومحبيصة دخلا على النبي ﷺ - فبدأ محبيصة بالكلام، فقال له النبي

(١) الحاوي الكبير "٥٣/٩".

(٢) الحاوي الكبير "٦٦/٩"، نهاية المطلب "٤٤/١٢"، البيان "١٨٢/٩".

ﷺ: «كَبِّرَ الْكُبْرَ»، أَوْ قَالَ: «لِيَبْدَأَ الْكُبْرُ»، يعني: قدم أخاك في الكلام؛ لأنه أكبر سناً منك (١).

ولأن الأكبر أخبر بالناس، فكان أولى، والأعلم أعرف بشروط العقد، والأورع أحرص على طلب الحظ لها. فإن زوجها أحدهم بإذنها من غير إذن الباقيين، صح وإن كان أصغرهم سناً، وذلك استدلالاً بالآتي: لقوله ﷺ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ؛ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا». رواه أبو داود. ولأن كل واحد منهم ولي، فجاز له أن يتولى العقد.

فإن تشاحوا، أي اختلفوا وقال كل واحد منهم: أنا أزوج، ولم يقدموا الأكبر الأعلم الأورع.. أقرع بينهم لاستواء استحقاقهم في الولاية، لما روي: «أن النبي -ﷺ- كان إذا أراد أن يسافر بإحدى نسائه.. أقرع بينهما».

فإن خرجت القرعة لأحدهم فزوج، أو أذن لغيره من الأولياء الباقيين أو غيرهم.. صح. وإن زوج واحد ممن لم تخرج عليه القرعة بإذن المرأة.. ففيه وجهان: أحدهما: يصح، لأن خروج القرعة لأحدهم لا يبطل ولاية الباقيين، كما لو زوجها أحدهم قبل القرعة، وهذا هو الأصح عند الشافعية. والثاني: لا يصح، لأن الفائدة في خروج القرعة أن تتعين الولاية بمن خرجت له القرعة، فلو صححنا عقد غيره بغير إذنه.. لبطلت فائدة القرعة.

وأجيب عن هذا: بأن فائدة القرعة قطع النزاع بينهم لا سلب الولاية عمن لم تخرج له (٢).

شروط الزوجين: اتفق فقهاء الشافعية على اشتراط أمرين في كل من الزوج والزوجة:

١- يشترط أن يكون كل من الزوجين حلاً للآخر، وأن لا يقوم بواحد منهما مانع من موانع النكاح. فلا يصح نكاح محرمة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، ولا نكاح مجوسية، أو وثنية أو مرتدة، أو ملاحنته، ولا نكاح ذات زوج، ولا مطلقة ثلاثاً، ولا المعتدة من غيره، ولا نكاح من تحرم جمعها مع زوج له، على التفصيل الذي سيأتي في المحرمات من النساء تأبيداً وتأقيتاً.

(١) رواه مسلم، كتاب القسامة، والمحاربين، باب القسامة.

(٢) البيان "١٦٦/٩-١٦٧"، مغني المحتاج "٢٦٥/٤".

٢- كما يشترطون تعيين كل من الزوجين في عقد النكاح، لأن المقصود في النكاح التعيين فلا يصح بدونه. وتعيين المنكوحة يجب أن يكون بما تتميز به عن غيرها وذلك قد يكون بأحد ثلاثة أشياء: إما بالإشارة، وإما بالاسم، وإما بالصفة. فأما الإشارة فلا تكون إلا إلى حاضرة فنقول: زوجتك هذه المرأة فيصح النكاح عليها، وإن لم يذكر لها اسماً، ولها حالان: موافق، وتخالف فإن كان موافقاً فقد أكد بالإشارة بها قرنه بها من موافقة الاسم، والنسب، والصفة، وإن كان مخالفاً بأن سماها حفصة بنت زيد وهي عمرة بنت بكر، أو وصفها بالطويلة وهي قصيرة صح العقد بالإشارة إليها ولم يؤثر فيه مخالفة الاسم، والنسب، والصفة، لأن الإشارة أبلغ في التعيين من كل اسم وصفة. وأما الاسم فقد يتعين به الغائبة إذا لم يشاركها فيه غيرها، فإن قرن به النسب نظر، فإن لم يشاركها فيه غيرها من النساء تميزت به وصح العقد عليها بما تميزت به من الاسم والنسب، وإن لم ينو الزوج والولي الإشارة إلى المنكوحة. وإن لم يتميز الاسم والنسب عن غيرهما من النساء لمشاركتها فيه لغيرها نظر، فإن نوى الزوج والولي في نفوسهما بالإشارة للمنكوحة صح العقد وعلى هذا أكثر عقود المناكح، وإن لم ينو لم يصح العقد لاشتباه المنكوحة بغيرها وصار بمثابة قوله: قد زوجتك امرأة. وأما الصفة فلا تكون بانفرادها مميزة للمنكوحة عن غيرها لاشتراك الناس في الصفات حتى يقترن بها مع ما يقع به التمييز من اسم، أو نسب، أو نية مثل أن يقول زوجتك بنتي وله بنات فيهن المنكوحة، فلا بد من التمييز إما بالاسم إذا لم يشتركن فيه فنقول حفصة، أو عمرة. وإما بالصفة، إذا لم يشتركن فيها فيقول الطويلة، أو القصيرة، أو يقول: السوداء أو البيضاء أو يقول: الصغيرة أو الكبيرة فتصير الصفة مميزة للمنكوحة ولولاها لاشتبهت (١).

الإشهاد على النكاح: وهذا هو الركن الرابع من أركان النكاح التي يجب توفرها في العقد حتى يكون صحيحاً مترتباً عليه آثاره، فلا يصح النكاح إلا بحضرة شاهدين، فإن فقدت الشهادة على عقد النكاح، كان عقد النكاح باطلاً لا يترتب عليه أي أثر، وإن توفرت الأركان الأخرى.

وذلك استدلالاً بالسنة والمعقول:

(١) الحاوي الكبير "١٥٦/٩-١٥٧" البيان "٢٢٧/٩"، مغني المحتاج "٢٣٤/٤".

أما السنة: ١- فقوله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

٢- عن عائشة أن النبي -ﷺ- قال: «لا نكاح إلا بأربعة: خابط وولي وشاهدين». (١)

أما المعقول فمن وجهين: ١- لأن النكاح عقد خطير يترتب عليه مقاصد يحتاط لها؛ فوجب صيانته عن التجاكد. ٢- ولأن عقد النكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدين إلى ثالث هو الولد الذي يلزم حفظ نسبه خالفها في وجوب الشهادة عليه حفظاً لنسب الولد الغائب لئلا يبطل نسبه. فإذا ثبت وجوب الشهادة في النكاح وأنها شرط في صحته، فإن للشهادة على النكاح شروطاً: أولها: الإسلام، فيشترط فقهاء الشافعية في شاهدي النكاح الإسلام، وذلك في الشهادة على نكاح المسلم المسلمة باتفاق، فلا ينعقد هذا النكاح بشهادة غير المسلم، بل لا بد من التأكد في كون الشاهدين مسلمين، فلا ينعقد بمستور الإسلام بأن لم يعرف إسلام الشاهد بأن يكون في موضع يختلط فيه المسلمون بالكفار ولا غالب، أو يكون ظاهر الإسلام فلا ينعقد النكاح به، بل لا بد من معرفة حاله باطنا لسهولة الوقوف على ذلك، وذلك للآتي: ١- قال الله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (٢). ٢- وقال رسول الله ﷺ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

٣- ولأن الشهادة ولاية، والكافر ليس من أهل الولاية على المسلم (٣).

ثانيها: الذكورة، فلا ينعقد النكاح إلا بشاهدين رجلين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين.

وذلك للآتي: قوله تعالى: {وَأَشْهَدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ} (٤).

(١) قال في الخلاصة ١٩٥٠: رواه البيهقي من رواية أبي هريرة، وقال: في إسناده المغيرة بن موسى البصري، قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن عدي: ثقة. ورواه الدارقطني من رواية عائشة، وقال: في إسناده مجهول. قال الرافعي وروي موقوفاً، قلت: أخرجه كذلك البيهقي في خلافياته، عن ابن عباس، ثم قال: وله شاهد بإسناد صحيح فذكره.

(٢) سورة النساء من آية ١٤١.

(٣) مغني المحتاج "٢٣٦/٤-٢٣٧".

(٤) سورة الطلاق من آية ٢.

وجه الدلالة: أنه لما أمر الله في الرجعة بشاهدين وهي أخف حالا من عقد النكاح كان ذلك في النكاح أولى. ٢- ولأن الفروج لا يسوغ فيها البذل والإباحة فلم يستبح بشهادة النساء كالقصاص. ٣- ولأن ما خص من بين جنسه بشاهدين لم يجز أن يكون ولا أحدهما امرأة كالشهادة على الزنا. ٤- ولأن من لم يكونوا من شهود النكاح بانفرادهم لم يكونوا من شهوده مع غيرهم كالعبيد والكفار (١).

ثالثا: التكليف، فيشترط في شاهدي النكاح التكليف، أي أن يكون كل منهما عاقلا بالغاً، فلا تقبل شهادة مجنون بالإجماع، ولا شهادة صبي، وذلك استدلالاً بالآتي:

١- قول الله تعالى: {وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ} (٢). ٢- ولأن الصبي والمجنون ليسا من أهل الشهادة. ٣- ولأن الشهادة من باب الولاية وهي نفاذ المشيئة لأنها تنفذ القول على الغير، وكل من المجنون والصبي لا ولاية له على نفسه فكيف تكون له ولاية على غيره (٣).

رابعا: العدالة، فلا يصح عقد النكاح إلا بشاهدين عدلين، استدلالاً بالآتي:

١- قوله تعالى: {فَأَمْسِكُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُمْ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوْيَ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} (٤). وجه الدلالة: أن الله عز وجل لما شرط العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها في النكاح المغلظ أولى. ٢- وقال النبي -ﷺ- قال: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل». وجه الدلالة: أن هذا نص صريح في اشتراط العدالة في الشهود. ٣- ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة اعتبرت فيه العدالة كالحقوق.

٤- ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع انعقاد النكاح بها كالرق والكفر.

(١) الحاوي الكبير "٥٩/٩-٦٠"، أسنى المطالب "١٢٢/٣"، مغني المحتاج "٢٣٥/٤".

(٢) سورة البقرة من آية ٢٨٢.

(٣) مغني المحتاج "٣٤٠/٦".

(٤) سورة الطلاق من آية ٢.

٥- ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العبدین لم یثبت بشهادة الفاسقین كالأداء (١).

والعدالة المعتبرة في شهود النكاح عند عقده هي عدالة الظاهر دون الباطن في الصحيح عند الشافعية، وهو المذهب. لأن الظاهر العدالة. ولأننا لو اعتبرنا العدالة الباطنة، لم ينعقد النكاح إلا بحضور الحاكم؛ لأن العامة لا يعرفون شروط العدالة، وقد أجمع المسلمون على جواز انعقاده بغير حضور الحاكم. ومقابل الصحيح لا ينعقد النكاح بمستور الحال، بل لا بد من علم العدالة الباطنة، لأن ما افتقر ثبوته إلى الشهادة، لم يثبت بمجهول الحال، كالأثبات عند الحاكم (٢). فعلى الصحيح إن عقد الزوجان نكاحا بشاهدين لم يخل حالهما من أربعة أقسام:

أ: أن يكونا عدلين في الظاهر والباطن فعقد النكاح بهما صحيح لعدالة ظاهرهما وإثباته عند الحكام جائز لعدالة باطنهما. ب: أن يكونا عدلين في الظاهر دون الباطن فعقد النكاح بهما صحيح لعدالة ظاهرهما لكن إثباته عند الحكام لا يصح إلا باستبراء عدالة باطنهما فيكشف عن عدالة الباطن وقت الأداء لا وقت العقد. ت: أن يكونا فاسقين فالعقد باطل، فلو ظهرت عدالتهما بعد العقد مع تقدم الفسق وقت العقد كان العقد على فساد.

ث: أن يكونا مجهولي الحال لا يعرف فيهما عدالة ولا فسق فهما على ظاهر العدالة والنكاح بهما جائز، لأن الأصل العدالة والفسق طارئ (٣).

خامسا: من شروط الشاهدين الحرية، فلا ينعقد النكاح بشهادة عبد، لأن من فيه رق ليس أهلا للشهادة (٤). سادسا: العدد، فلا يصح النكاح بشاهد واحد، بل لا بد من حضور شاهدين لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل».

ولا فرق بين حضور الشاهدين قصدا أو اتفاقا (٥).

(١) الحاوي الكبير "٦٠/٩"، فتح العزيز "٥١٧/٧-٥١٨".

(٢) البيان "١٢٢/٩"، مغني المحتاج "٢٣٦/٤".

(٣) الحاوي الكبير "٦٤/٩".

(٤) فتح العزيز "٥١٧/٧".

(٥) مغني المحتاج "٢٣٤/٤".

سابعاً: السمع، فيشترط أن يكون شاهداً النكاح سميعين، ولو برفع صوت، إذ المشهود عليه قول فلا بد من سماعه، أي سماع كلام المتعاقدين جميعاً (١).

ثامناً: التيقظ، فيشترط في شاهدي النكاح التيقظ والضبط، فلا ينعقد النكاح بالمغفل الذي لا يضبط (٢). تاسعاً: معرفة لسان العاقدين، فيشترط في شاهدي النكاح معرفة لسان العاقدين، فلا يكفي إخبار ثقة بمعنى قول العاقدين (٣). كانت هذه شروطاً متفقاً عليها عند الشافعية في كونها واجبة التحقق في الشاهدين، وهناك شروط أخرى اختلف فقهاء الشافعية في إثباتها في حق الشاهدين على النحو الآتي: ١- الأعمى، في انعقاد النكاح بشهادته وجهان:

الأول: الانعقاد، لأنه عدل فاهم. والثاني: المنع، وقطع به إمام الحرمين، وذلك لأن الأقوال لا تثبت إلا بالمعينة والسماع، لأنه لا يمكن إثباته بشهادتهما. ولأن الاكتفاء بهما يبطل مقصود شرط الشهادة في النكاح (٤). ٢- الأخرس، خلاف بين الشافعية في انعقاد النكاح بشهادته، مبني على الخلاف في قبول شهادته هل تقبل أو لا؟ (٥)

٣- أن يكون الشاهدان عدوين للزوجين معاً، أو ابنين لهما، ففي انعقاد النكاح بهما وجهان للشافعية: أحدهما: لا ينعقد كالفاسقين، لأن الأداء لا يصح منهما على أحد الزوجين بحال.

والوجه الثاني: هو ظاهر ما نص عليه الشافعي في كتاب الأم إن النكاح بهما منعقد وإن لم يصح منهما أدائهما بخلاف الفاسقين. والفرق بينهما: أن الفاسقين لا يصح منهما أداء هذه الشهادة وصح منهما أداء غيرها من الشهادات (٦).

(١) المرجع السابق.

(٢) روضة الطالبين "٤٥/٧".

(٣) أسنى المطالب "١٢٢/٣".

(٤) نهاية المطلب "٥٣/١٢".

(٥) فتح العزيز "٥١٨/٧".

(٦) الحاوي الكبير "٦١/٩".

الركن الخامس: الصيغة وشروطها: من أركان عقد النكاح المتفق عليها عند الشافعية الصيغة، ولقد أخرج الحديث عنها لما بعد الولي والزوجين والشاهدين، نظرا لأن الصيغة هي الركن المكمل لوجود الأركان السابقة، فلا تتصور صيغة قبل وجود ولي وزوج، فقدمت في الحديث ما رأيت أن وجوده أسبق، وأخرج ما رأيت أنه متأخر الوجود عن الأركان السابقة. وللصيغة شروط ذكرها فقهاء الشافعية، وهي على النحو التالي:

١- الإيجاب والقبول، فاتفق فقهاء الشافعية على أن النكاح ينعقد بالإيجاب والقبول، وذلك باللفظ الذي يدل على ذلك، وما يقوم مقام اللفظ. والإيجاب هو ما يصدر من ولي الزوجة، والقبول هو ما يصدر من الزوج أو وكيله، ويستوي أن يتقدم القبول على الإيجاب أو يتأخر عنه ما دام قد تحدد الموجب والقابل، فلو قال الزوج للولي: زوجني أو تزوجت بنتك كان قبولا، ولو قال الولي بعد ذلك: زوجتك أو أنكحتك كان إيجابا، وانهقد النكاح بذلك (١).

٢- النكاح لا ينعقد إلا بصريح اللفظ دون كناية، وصريحه لفظان: زوجتك، وأنكحتك فلا ينعقد النكاح إلا بهما، فلا ينعقد بغير هذين اللفظين وما اشتق منهما، فلا ينعقد بالهبة والإجارة مع النية.

وذلك استدلالا بالكتاب والسنة والمعقول: أما الكتاب: أ- لأن نص الكتاب ورد بالإنكاح والتزويج فقط، كما في قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} (٢)، وقوله تعالى: {فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} (٣)، ولم يذكر سواهما في القرآن الكريم، فوجب الوقوف معهما تعبدا واحتياطاً، لأن النكاح ينزع إلى العبادات لورود الندب فيه، والأذكار في العبادات تتلقى من الشرع، والشرع إنما ورد بلفظي التزويج والإنكاح. ب- وقوله تعالى: {وَأَمْرًا مُّؤَمَّنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} (٤). وجه الدلالة: أن الله عز وجل قد جعل النكاح بلفظ الهبة خالصا

(١) مغني المحتاج "٢٢٦/٤".

(٢) سورة النساء من آية ٢٢.

(٣) سورة الأحزاب من آية ٣٧.

(٤) سورة الأحزاب من آية ٥٠.

لرسوله دون أمته، فدل ذلك على أن النكاح لا ينعقد إلا باللفظ الصريح الذي جاء به القرآن فقط، وهو الإنكاح والتزويج.

وأما السنة: فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله -ﷺ- في حجة الوداع: «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئاً إنكم إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً، وأن لا يأذن في بيوتكم لأحد تکرهونه، فإن فعلن من ذلك شيئاً فقد حل لكم أن تضربوهن ضرباً غير مبرح، ألا هل بلغت قالوا: اللهم نعم، قال: اللهم فاشهد»^١.

وجه الدلالة: أن قوله ﷺ: «واستحللتم فروجهن بكتاب الله»، وليس في كتاب الله إلا لفظ النكاح والتزويج فدل على أنه لم يستحل الفروج إلا بهما.

أما المعقول فمن وجوه: أ- لأن النكاح عقد على منفعة لم ينعقد بلفظ الهبة كالإجارة. ب- ولأنه عقد معاوضة فلم ينعقد بلفظ الهبة كالبيع. ت- ولأن لفظ الهبة موضوع لعقد لا يتم إلا بالقبض فلم ينعقد به النكاح كالرهن. ث- ولأن ما كان صريحاً في عقد لم يكن صريحاً في غيره كالإجارة والبيع، ولأن ما لم يكن صريحاً في النكاح لم ينعقد به النكاح كالإباحة والإحلال. ح- ولأن الحقيقة في عقد لو صارت حقيقة في غيره لبطلت حقائق العقود، لأن لفظ الكناية يقوم مقام التصريح بالنية وهي مما لا يعلمها الشهود والمشروطون في النكاح إلا بالاختيار فلم ينعقد به النكاح كالإقرار. د- ولأن البيع والهبة ينافيان النكاح بدليل أن من تزوج أمة ثم ابتاعها أو استوهبها بطل نكاحها وما نافي النكاح لم ينعقد به النكاح كالطلاق.

ذ- ولأنه لو انعقد النكاح بلفظ البيع لانعقد البيع بلفظ النكاح، وفي امتناع هذا إجماع وامتناع ذلك حجاج. ر- ولأنه لفظ يوضع لإسقاط ما في الذم فلم ينعقد به النكاح كالإبراء^(٢).

(١) أخرجه الترمذي، وهو صحيح.

(٢) الحاوي الكبير "١٥٣/٩-١٥٤"، نهاية المطلب "١٢/١٧٠"، البيان "٢٢٣/٩".

٣- من شروط الصيغة أن يكون قبول الزوج على الفور من بذل الولي، فإن تراخى ما بينهما بسكوت وإن قل لم يصح العقد إلا أن يكون لبلع ريق أو انقطاع نفس فيصح العقد وإن تخللته هذه السكوتة؛ لأنه لا يمكن الاحتراز منها.

٤- من شروط الصيغة ألا يكون بين إيجاب الولي وقبول الزوج كلام أجنبي، فإن تخلل بينهما كلام ليس منهما لم يصح العقد؛ لأن خروجهما إلى غيره من الكلام قطع لحكم ما تقدم، ولكن لو قال الولي: قد زوجتك بنتي فاقبل النكاح مني لم يكن هذا قطعاً للإيجاب؛ لأنه حث منه على القبول، وهكذا لو قال: قد زوجتك بنتي فقل لي قد قبلت نكاحها لم يكن قطعاً لإيجابه؛ لأنه تفسير لقوله: "فاقبل النكاح مني" فأما إذا قال: قد زوجتك بنتي فأحسن إليها أو قال فاستوصي بها خيراً كان هذا قطعاً لإيجابه؛ لأنها وصية لا تتعلق بالبذل والقبول، ولكن لو قال: قد زوجتكها على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صح العقد ولم يكن ذلك قطعاً؛ لأنه وإن تضمن صفة الوصية فهو بيان لحكم البذل والقبول. ٥- أن تكون الصيغة منجزة غير معلقة، فلو كانت معلقة لم تصح، كما إذا قال إذا طلعت الشمس فقد زوجتك بنتي، ولو قال: زوجتك إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم يصح، وإن قصد التبرك أو أن كل شيء بمشيئة الله تعالى صح.

٦- من شروط الصيغة أن يكون الولي عند قبول الزوج من أهل العقد، فإن قبل الزوج وقد مات الولي أو جن أو أغمي عليه لم يصح العقد لبطلان إيجابه بخروجه من أهل العقد (١).

فرع: النكاح بغير العربية: اختلف فقهاء الشافعية في حكم النكاح بغير العربية على ثلاثة أوجه: أحدهم: أن النكاح لا ينعقد بالعجمية سواء كان عاقده يحسن العربية أو لا يحسنها كما أن القراءة لا تجوز بالعجمية وإن كان لا يحسن العربية. والوجه الثاني: وهو قول جمهور الأصحاب، أن النكاح ينعقد بالعجمية سواء كان عاقده يحسن العربية أو لا يحسنها، لأن لفظه بالعجمية صريح فخرج عن حكم الكناية بالعربية، لأن في كناية العربية احتمال وليس في صريح العجمية احتمال، وخالف القرآن المعجز، لأن إعجازه ونظمه، وهذا المعنى يزول عنه إذا عدل عن لفظه العربي إلى الكلام العجمي. والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد

(١) الحاوي الكبير "١٦٣/٩"، مغني المحتاج "٢٣١/٤".

الإصطخري - أنه إن كان عاقده يحسن العربية لم ينعقد بالعجمية، وإن كان لا يحسن العربية انعقد بالعجمية كأذكار الصلاة تجزئ بالعجمية لمن لا يحسن العربية، ولا تجزئ لمن يحسنها، فعلى هذا لا يجوز أن يجمع بين حال القدوة والعجز، والعدل عن صريح النكاح إلى كنيته قادر والعدل عنه إلى العجمية عاجز فاقد(١).

فرع: حكم انعقاد النكاح بالإشارة: القادر على النطق، لا يصح أن يعدل عنه إلى الإشارة في عقد النكاح، وذلك لخطر عقد النكاح وأهميته، فلا بد فيه من التصريح والوضوح والقطع بما لا يحتمل الإبهام، وطالما كان قادرا على النطق وجب التلفظ به، فلو أشار لم ينعقد.

أما إشارة الأخرس غير القادر على التلفظ، فهي معتبرة شرعا وتقوم مقام عبارة الناطق فيما لا بد فيه من العبارة. وعلى ذلك فإنه يصح إيجاب الأخرس وقبوله النكاح بإشارته إذا كانت الإشارة مفهومة يفهمها العاقد معه ويفهمها الشهود لأن النكاح معنى لا يستفاد إلا من جهته فصح بإشارته كبقية عقود(٢).

فرع: حكم انعقاد النكاح بالكتابة: الكتابة إما أن تكون من الأخرس أو من غيره.

١- أما الأخرس فقد ذهب فقهاء الشافعية إلى أن النكاح يصح وينعقد بالكتابة من الأخرس لأنها أولى من الإشارة. ٢- أما القادر على النطق، فاختلف فقهاء الشافعية في انعقاد النكاح بالكتابة في حقه على وجهين: الوجه الأول: أن النكاح لا ينعقد بالكتابة في مجلس العقد، وهذا هو الصحيح. وذلك لأن الكتابة كناية، والنكاح لا ينعقد بالكنايات.

والوجه الثاني: انعقاد النكاح بالكتابة، إذا كان المكاتب غائبا(٣).

(١) الحاوي الكبير "١٥٥/٩"، نهاية المطلب "١٧١/١٢"، البيان "٢٣٥/٩"، مغني المحتاج "٢٢٩/٤".

(٢) روضة الطالبين "٣٩/٨"، مغني المحتاج "٣٦٢-٣٦٣".

(٣) روضة الطالبين "٣٧/٧"، "٣٩/٨".

الوحدة الثانية

موانع النكاح والخيار فيه وحقوق الزوجين

محتويات الوحدة:

الدرس الأول: المحرمات من النساء .

الدرس الثاني: الخيار في فسخ النكاح .

الدرس الثالث: حقوق الزوجين .

الدرس الأول: المحرمات من النساء .

المحرمات من النساء نوعان:

أ - محرمات على التأبيد، وهن اللائي تكون حرمة نكاحهن مؤبدة، لأن سبب التحريم ثابت لا يزول، كالأمومة، والبنوة، والأخوة.

ب - محرمات على التأقيت، وهن من تكون حرمة نكاحهن مؤقتة؛ لأن سبب التحريم غير دائم، ويحتمل الزوال كزوجة الغير، ومعتدته، والمشاركة بالله.

أولاً: المحرمات تحريماً مؤبداً. - وأسباب تأبيد حرمة التزوج بالنساء ثلاثة، هي:

أ - النسب. ب - الرضاع. ج - المصاهرة.

أ - المحرمات من النسب: فيحرم على الرجل أن يتزوج سبعة من النساء للقرابة التي بينهما، وهن الأم، والبنات، والأخت، والعمة، والخالة، وبنات الأخ، وبنات الأخت.

ودليل تحريمهن: قوله تعالى { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ } ١.

- فأما الأم المحرمة: فهي كل من ولدتك فهي أمك حقيقة أو ولدت من ولدك ذكرًا كان أو أنثى، كأم الأب وإن علت وأم الأم كذلك فهي أمك مجازاً، وإن شئت قلت كل أنثى ينتهي إليها نسبك بواسطة أو غيرها.

- أما البنت المحرمة: فهي كل من ولدتها فبنتك حقيقة أو ولدت من ولدها ذكرًا كان أو أنثى كبنت ابن وإن نزل، وبنات بنت وإن نزلت فبنتك مجازاً، وإن شئت قلت: كل أنثى ينتهي إليك نسبها بالولادة بواسطة أو غيرها.

- أما الأخوات المحرمات، فهي كل امرأة ولدها أبواك، أو أحدهما؛ فهي داخلة تحت اسم الأخوات.

- وأما (بنت الأخ): فيحرم على الرجل بنت أخيه حقيقة- وهي: بنت أخيه لصلبه- ويحرم عليه بنت أخيه مجازا، وهي: كل من تنتسب إلى أخيه بالبنوة من قبل أبنائه وبناته وإن سفلت.

- وأما (بنت الأخت): فيحرم على الرجل بنت أخته حقيقة- وهي: بنت أخته لصلبه- ويحرم عليه بنت أخته مجازا، وهي: كل من تنتسب إلى أخته بالبنوة من بنات أبنائها وبناتها وإن سفلت.

- وأما (العمة): فيحرم على الرجل من يقع عليها اسم العمة حقيقة- وهي: أخت أبيه- سواء كانت أخته لأبيه وأمه، أو لأبيه، أولأمه، ويحرم عليه نكاح من يقع عليها اسم العمة مجازا، وهي: كل أخت لجد من أجداده من قبل أبيه أو من قبل أمه.

- وأما (الخالة): فيحرم على الرجل نكاح من يقع عليها اسم الخالة حقيقة- وهي: أخت أمه لأبيها وأمها، أو لأبيها، أو لأمها- ويحرم عليه من يقع عليها اسم الخالة مجازا، وهي: أخت كل جدة له من قبل أمه أو أبيه ١.

ولقد عبر بعض الشافعية عن المحرمات بالنسب بعبارات وجيزة مختصرة، فقال إمام الحرمين " وإن أوجزت قلت: كل امرأة بينك وبينها قرابة؛ فهي محرمة عليك، إلا أولاد الأعمام والعمات والأخوال والخالات" ٢.

وقال العمراني: " إذا ثبت هذا: فقد عبر بعض أصحابنا عن المحرمات بالنسب، فقال: يحرم على الرجل أصوله، وفصوله، وفصول لأول أصوله، وأول فصل من كل أصل بعده. وهي عبارة حسنة، لأن (أصول الرجل): من ينتسب الرجل إليه بالبنوة من الأمهات. و (فصوله): من ينسب إلى الرجل بالبنوة.

و (فصول أول أصوله): الأخوات وأولادهن وبنات الإخوة.

١ نهاية المطلب "١٢١/١٢"، البيان "٢٣٨/٩-٢٣٩"، مغني المحتاج "٢٨٦/٤-٢٨٩".

٢ نهاية المطلب "١٢٢/١٢".

و (أول فصل من كل أصل بعده): العمات والخالات" ١.

ب- المحرمات بالرضاع: وأما المحرمات بالرضاع فذكر الله تعالى اثنتين الأمهات والأخوات بقوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} ٢. فكان النص متعديا إلى غيره كذوات الأنساب، بدليل ما روته عائشة -رضي الله عنها- عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة" رواه البخاري.

وروي غيرها عنه - ﷺ - أنه قال: "يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" ٣. فوجب إجراء الرضاع في التحريم على حكم النسب فيحرم بالرضاع سبع كما يحرم بالنسب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.

وبيان ذلك أن المرأة إذا أرضعت ولدا بلبن من زوج فالولد المرضع ابن لها وللزوج، لأن اللبن حادث عنها بسبب ينتسب إلى الزوج، فاقضى أن يكون المرضع ابنا لها كالمولود منهما، وإذا كان كذلك كانت المرضعة أما له وكان أمهاتها جداته من أم وآباؤها أجداده من أم وبناتها أخواته من أم وأخوتها أخواله من أم وأخواتها خالاته من أم وكان الزوج أبا له وآباؤه أجداده من أب وأمهم جداته من أب وبنوه إخوته من أب وإخوته أعمامه وأخواته عماته كذلك على ترتيب فتصير المحرمات بالرضاع سبعا كما كان المحرمات بالأنساب سبعا.

- فضايط الأم من الرضاع هو كل من أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك، أو أرضعت صاحب اللبن أو أرضعت من ولدك بواسطة أو غيرها، أو ولدت مرضعتك بواسطة أو غيرها، أو ولدت صاحب اللبن وهو الفحل بواسطة أو غيرها فأمر رضاع.

- وبنات الرضاع: هي كل امرأة ارتضعت بلبنك أو لبن من ولدتها بواسطة أو غيرها أو أرضعتها امرأة ولدتها بواسطة أو غيرها، وكذا بناتها من نسب أو رضاع وإن سفلن.

١ البيان "٢٣٨/٩".

٢ سورة النساء من آية ٢٣.

٣ متفق عليه.

- وضابط أخت الرضاع: هو كل من أرضعتها أمك أو ارتضعت بلبن أبيك أو ولدتها مرضعتك أو ولدك الفحل.

- وضابط عمه الرضاع: هو كل أخت للفحل أو أخت ذكر ولد الفحل بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع.

- وضابط خالة الرضاع هو كل أخت للمرضعة أو أخت أنثى ولدت المرضعة بواسطة أو غيرها من نسب أو رضاع.

وضابط بنات الإخوة وبنات الأخوات من الرضاع هو كل أنثى من بنات أولاد المرضعة والفحل من الرضاع والنسب، وكذا كل أنثى أرضعتها أختك أو ارتضعت بلبن أخيك وبناتها وبنات أولادها من نسب أو رضاع^١

فرع: أربعة حرمن بالنسب ولم يحرمن بالرضاع: استثنى بعض فقهاء الشافعية أربعة يحرمن بالنسب، ولم يحرمن بالرضاع، من قاعدة: يحرمن من الرضاع ما يحرمن من النسب على النحو الآتي: لا يحرمن من أرضعت أخاك، فأما الأخ والأخت في النسب حرام، لأنها أم، أو زوجة أب، وفي الرضاع إن كانت كذلك حرمت، وإلا، فلا، بأن أرضعت أجنبية أخاك أو أختك.

ولا يحرمن من أرضعت نافلتك وهو ولد ولدك، فأما نافلتك في النسب، حرام لأنها بنتك، أو زوجة ابنك، وفي الرضاع قد لا تكون بنتا ولا زوجة ابن، بأن أرضعت أجنبية نافلتك.

ولا يحرمن أم مرضعة ولدك، فجدة ولدك في النسب، حرام، لأنها أمك، أو أم زوجتك، وفي الرضاع قد لا تكون كذلك، بأن أرضعت أجنبية ولدك، فإن أمها جدته، وليست بأمك، ولا بأم زوجتك. ولا يحرمن بنت مرضعة ولدك، فأخت ولدك حرام، لأنها بنتك أو ربيبته، وإذا أرضعت أجنبية ولدك، فبنتها أخته، وليست بنتك ولا ربيبته^٢. قال النووي في الروضة ردا على استثناء هذه الأربع من القاعدة " قال المحققون: لا حاجة إلى استثنائها، لأنها ليست داخلية في الضابط، ولهذا لم يستثنها الشافعي وجمهور الأصحاب - رضي الله عنهم -، ولا

١ الحاوي الكبير "١٩٨/٩"، البيان "٢٤٠/٩"، مغني المحتاج "٢٨٩/٤"، تحفة المحتاج "٣٠٠/٧".

٢ روضة الطالبين "١١٠/٧"، مغني المحتاج "٢٨٩/٤" - ٢٩٠.

استثنت في الحديث الصحيح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» لأن أم الأخ لم تحرم لكونها أم أخ، وإنما حرمت لكونها أما أو حليلة أب، ولم يوجد ذلك في الصورة الأولى، وكذا القول في باقيهن" ١.

التحريم بالمصاهرة: أربع حرمهن الله تعالى تحريم مصاهرة بعقد نكاح على وجه التأيد:
الأولى: أم الزوجة، فإن الرجل إذا عقد النكاح على امرأة.. حرمت عليه كل أم لها، حقيقة أو مجازاً، من جهة النسب أو من جهة الرضاع، سواء دخل بها أو لم يدخل، وذلك للآتي:
١ - لإطلاق قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} ٢.

٢ - ما رواه الترمذي وضعفه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها، فلا يحل له نكاح ابنتها. فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها، وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها، أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها" قال الترمذي (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة، ثم طلقها قبل أن يدخل بها، حل له أن ينكح ابنتها. وإذا تزوج الرجل الابنة، فطلقها قبل أن يدخل بها، لم يحل له نكاح أمها، لقول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}). وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

والثانية: بنت الزوجة: وهي الربيبة بواسطة أو غيرها إن دخلت بها في عقد صحيح أو فاسد، فإنها تحرم بالدخول بالأم، وذلك للآتي:

١ - لإطلاق قوله تعالى بقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ٣.

٢ - حديث الترمذي السابق.

١ روضة الطالبين "١١١/٧".

٢ سورة النساء من آية ٢٣.

٣ سورة النساء من آية ٢٣.

والثالثة: زوجة الابن وهي حليلته، فإن الرجل إذا عقد النكاح على امرأة، حرمت على أب الزوج، سواء دخل بها الزوج أو لم يدخل بها لقوله تعالى {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} ١.

والرابعة: زوجة الأب، فإن الرجل إذا تزوج امرأة، حرمت على ابنه، سواء دخل بها الزوج أم لم يدخل بها، استدلالا بالآتي: لقوله تعالى في الآية الأخرى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ٢.

ثانيا: المحرمات تحريما مؤقتا: هناك نساء لا يحل للرجل أن يتزوجها، حتى يزول المانع الذي حرم من أجله نكاحها، وهؤلاء على النحو الآتي:

الأولى: الجمع بين الأختين، فإن تزوج الرجل امرأة لا يحل له أن يتزوج أختها طالما كانت الأخت الأولى في عصمته، فتكون الأخت الثانية محرمة عليه تحريما مؤقتا حتى يطلق أختها أو تموت، فلا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين في النكاح، سواء كانتا أختين لأب وأم أو لأب أو لأم وسواء كانتا أختين من النسب أو من الرضاع، وذلك استدلالا بالآتي: لقوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} ٣.

ولأن العادة جارية أن الرجل إذا جمع بين ضرتين تباغضتا وتحاسدتا، وتتبع كل واحدة منهما عيوب الأخرى وعوراتها، فلو جوزنا الجمع بين الأختين، لأدى ذلك إلى تباغضهما وتحاسدهما، فيكون في ذلك قطع الرحم بينهما ولا سبيل إليه.

فعلى هذا إن تزوجهما معا في عقد واحد، لم يصح نكاح واحدة منهما، لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى، فبطل الجمع، كما لو ابتاع درهما بدرهمين.

وإن تزوج إحداهما، ثم تزوج الثانية، بطل نكاح الثانية دون الأولى، لأن الجمع اختص بالثانية.

١ سورة النساء من آية ٢٣.

٢ سورة النساء من آية ٢٢.

٣ سورة النساء من آية ٢٣.

الثانية: يحرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها، والمرأة وخالتها، وذلك استدلالاً بالآتي:

١- ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي - ﷺ - قال: «لا تنكح المرأة على عمتها، ولا العمة على ابنة أخيها، ولا المرأة على خالتها، ولا الخالة على ابنة أختها، لا الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى». رواه البخاري تعليقا، والترمذي، وأحمد.

٢- ولأن كل امرأتين لو قلبت كل واحدة منهما ذكرا.. لم يجز له التزوج بالأخرى بالنسب، فوجب أن لا يجوز الجمع بينهما في النكاح، كالأختين.

الثالثة: زوجة الغير ومعتدته، فيحرم على المسلم أن يتزوج من تعلق حق غيره بها بزواج أو عدة من طلاق أو وفاة، أو دخول في زواج فاسد، أو دخول بشبهة، لقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} ١ عطا على المحرمات المذكورات في قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} ٢. والمراد بالمحصنات من النساء المتزوجات منهن، سواء أكان زوجها مسلما أم غير مسلم، كما يحرم على المسلم أن يتزوج معتدة غيره من طلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وتحريم النكاح مؤقت بطلاقها وانتهاء العدة ٣.

الرابعة: المرأة التي لا تدين بدين سماوي: اتفق فقهاء الشافعية على أنه لا يحل للمسلم أن يتزوج امرأة لا تدين بدين سماوي، ولا تؤمن برسول، ولا كتاب إلهي، بأن تكون مشركة تعبد غير الله كالوثنية والمجوسية، وتحريم نكاحها مؤقت حتى تسلم، فإن أسلمت حل نكاحها، لقوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَأَمَّةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ} ٤. وقوله تعالى {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ} ٥. ٦

١ سورة النساء من آية ٢٤.

٢ سورة النساء من آية ٢٣.

٣ البيان ٩/٢٧٠.

٤ سورة البقرة من آية ٢٢١.

٥ سورة الممتحنة من آية ١٠.

٦ البيان ٩/٢٦٠.

الخامسة: الجمع بين أكثر من أربع نسوة: فيحرم على الرجل أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في عصمته، فلا يتزوج بخامسة ما دامت في عصمته أربع سواه، فالخامسة محرمة عليه تحريماً مؤقتاً يزول بفراقه امرأة من الأربع^١.

الدرس الثاني: الخيار في فسخ النكاح والرد بالعيب.

النكاح يفسخ بالعيوب، ويكون للطرف الآخر الحق في استمرار النكاح أو فسخه. والعيوب التي يفسخ بها النكاح تستحق من الجهتين، فيستحقها الزوج إذا وجدت بالزوجة، وهي خمسة عيوب: الجنون، والجذام، والبرص، والقرن، والرتق، وتستحقها الزوجة إذا وجدت بالزوج، وهي خمسة الجنون، والجذام، والبرص، والجب، والعنة، فيشتركان في الجنون، والجذام، والبرص، وتختص الزوجة بالقرن، والرتق، ويختص الزوج بالجب والعنة. أولاً: العيوب المشتركة بين الرجل والمرأة، وهي ثلاثة:

الأول: الجنون، وهو زوال العقل الذي يكون معه تأدية حق سواء خيف منه أم لا، وهو ضربان: مطبق لا يتخلله إفاقة، وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن تارة، ويفيق أخرى وكلاهما سواء، وفيهما الخيار سواء قل زمان الجنون أو كثر، لأن قليله يمنع من تأدية الحق في زمانه، ولأن قليله يصير كثيراً وسواء كان ذلك بالزوج أو بالزوجة.

فأما الإغماء فهو زوال العقل بمرض فلا خيار فيه كالمرض، لأنه عارض يرجى زواله، وأنه قد يجوز حدوث مثله بالأنبياء الذي لا يحدث بهم جنون، فإن زال المرض فلم يزل معه الإغماء صار حينئذ جنونا يثبت فيه الخيار.

وأما البله فهو غلبة السلامة فيكون الأبله سليم الصدر ضعيف العزم، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أكثر أهل الجنة البُلَه) ^٢ يعني الذين غلبت السلامة على صدورهم فلا خيار في البله، لأن الاستمتاع كامل.

١ البيان "١١٨/٩".

٢ رواه البزار وإسناده ضعيف.

وكذلك لا خيار في الحقم وقلة الضبط لكمال الاستمتاع معهما، وإنما يؤثر فيما سواه من تدبير المنزل وتربية الولد.

الثاني: من العيوب المثبتة للخيار الجذام وهو: غفن يكون في الأطراف والأنف يسري فيهما حتى يسقط ويتناثر، وربما سرى إلى النسل وتعدى إلى الخليط، والنفس تعافه وتتفر منه فلا يسمح بالمخالطة ولا تحبب إلى الاستمتاع، وقد روى سعيد عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فروا من المجذوم فراركم من الأسد" ١ ففي الجذام الخيار قليلا كان أو كثيرا، لأن قليله يصير كثيرا، وسواء كان في الزوج أو الزوجة.

والثالث: من عيوبهما: البرص: وهو حدوث بياض في الجلد يذهب معه دم الجلد وما تحته من اللحم وفيه عدوى إلى النسل والمخالطين، وتعافه النفوس، وتتفر منه فلا يكمل معه الاستمتاع وفيه قليله وكثيره الخيار، لأن قليله يصير كثيرا، وسواء كان بالزوج أو الزوجة، استدلالا بالآتي:

رد النبي - ﷺ - - نكاح امرأة وجد بكشحه بياضا فردها ٢.

وجه الدلالة: أنه لما نقل العيب والرد وجب أن يكون الرد، لأجل العيب، فثبت الخيار.

أن البرص عيب يمنع غالب المقصود بالعقد فجاز أن يثبت به خيار الفسخ كالجب.

ولأنه عيب مقصود بعقد النكاح فوجب أن يستحق الفسخ كالعيب في الصداق.

فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام العيوب فوجد الزوج بالزوجة قليلا من برص أو جذام فرضي به ثم انتشر وزاد حتى صار كثيرا لم يكن له خيار، لأن الراضي بقليله راض بكثيره، ولأن قليله في الغالب يصير كثيرا ٣.

١ رواه البخاري.

٢ رواه الحاكم وفي إسناده ضعف.

٣ الحاوي الكبير "٣٤٢-٣٤١/٩"، نهاية المطلب "٤٠٨/١٢"، البيان "٢٩٠-٢٩١/٩"، أسنى المطالب "١٧٦/٣"، مغني المحتاج "٣٤٠/٤".

وأما العيوب المختصة بالرجال، فعيبان:

الأول: العنة وهي العجز عن الوطء للين الذكر وعدم انتشاره، فلا يقدر على إيلاجه فسمي من به العنة عنيًا، وفي تسميته بذلك تأويلان:

أحدهما: أنه سمي عنيًا للين ذكره يعني عند إرادة الوطء وانعطافه مأخوذ من عنان الفرس للينه.

والتأويل الثاني: إنه سمي عنيًا، لأن ذكره يعن عند إرادة الوطء أن يعترض عن يمين الفرج ويساره فلا يلج مأخوذ من العنن، وهو الاعتراض، يقال عزلك الرجل إذا اعترضك عن يمينك أو يسارك^١.

والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ، وهو إجماع الصحابة، وقول جميع الفقهاء، استدلالاً بالآتي:

أ- قوله تعالى { الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ }^٢.

وجه الدلالة: أن الله تعالى خير الأزواج بين أن يمسكوا النساء بمعروف، أو يسرحوهن بإحسان. والإمساك بمعروف لا يكون بغير وطء؛ لأنه هو المقصود بالنكاح، فإذا تعذر عليه الإمساك بمعروف من هذا الوجه.. تعين عليه التسريح بإحسان؛ لأن من خير بين شيئين إذا تعذر عليه أحدهما.. تعين عليه الآخر.

ب- ولأن الله تعالى أوجب على المولي أن يفيء أو يطلق؛ لما يلحقها من الضرر بامتناعه من الوطء، والضرر الذي يلحق امرأة العنين أعظم من امرأة المولي؛ لأن المولي ربما وطئها. فإذا ثبت الفسخ لامرأة المولي.. فلأن يثبت لامرأة العنين أولى^٣.

إذا ثبت أن العنة عيب يثبت به خيار الفسخ، فهو معتبر بشرطين:

١ الحاوي الكبير "٢٦٨/٩".

٢ سورة البقرة من آية ٢٢٩.

٣ البيان "٣٠٣-٣٠٢/٩".

أحدهما: أن لا يكون قد أصابها قط فإن أصابها مرة زال عنه حكم العنة.

والثاني: أن لا يقدر على إيلاج حشفة الذكر فإن قدر على إيلاج الحشفة وإن استعان بيده زال عنه حكم العنة، فإن تكامل الشرطان وتصادق عليهما الزوجان لم يتعجل الفسخ بها، وأجل الزوج لها سنة كاملة بالأهله.

وفي تقدير السنة دليلان:

أحدهما: أنه مروي عن عمر رضي الله عنه-؛ لأنه أجل العنين سنة، وعمر لا يفعل هذا إلا عن توقيف فيكون نصا أو عن اجتهد شاور فيه الصحابة، لأنه كان كثير المشورة في الأحكام فيكون مع عدم الخلاف فيه إجماعا، وإذا تردد بين حالين نص أو إجماع لم يجز بخلافه.

والثاني: إن التأجيل إنما وضع ليعلم حاله، هل هو من مرض طارئ فيرجى زواله أو من نقص في أصل الخلقة فلا يرجى زواله فكانت السنة الجامعة للفصول الأربعة أولى أن تكون أجلا معتبرا؛ لأن فصل الشتاء بارد رطب وفصل الصيف حار يابس، وفصل الربيع حار رطب، وفصل الخريف بارد يابس فإذا مر بالمرض ما يقابله من فصول السنة ظهر وكان سببا لبرئه، فإن كان من برد ففصل الحر يقابله فإن كان من حر ففصل البرد يقابله، وإن كان من رطوبة ففصل اليبوسة يقابله، وإن كان من يبوسة ففصل الرطوبة يقابله، وإن كان مركبا من نوعين فما خالفه في النوعين، هو المقابل له، فإذا مضت عليه الفصول الأربعة وهو بحاله لم يكن مرضا وعلم حينئذ أنه نقص لازم لأصل الخلقة فصار عيبا يوجب الخيار ١.

٢- الثاني من العيوب الخاصة بالرجال الجب، وهو قطع الذكر، فإن كان جميعه مقطوعا فللمرأة الخيار، لأنه أდوم ضررا من العنة التي يرجى زوالها.

وإن كان بعض الذكر مقطوعا نظر في باقيه، فإن كان لا يقدر على إيلاجه إما لضعفه أو لصغره فلها الخيار، وإن كان يقدر على إيلاجه ففي خيارها وجهان:

١ الحاوي الكبير "٣٦٨/٩-٣٧٠"، البيان "٣٠٤/٩".

أحدهما: وهو الصحيح إنه لا خيار لها، لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا خيار فيه. والوجه الثاني: لها الخيار، لأنه نقص لا تكمل به الإصابة.

أما الخصاء وهي قطع الأنثيين مع بقاء الذكر ففي كونه عيبا يوجب خيارها قولان: أحدهما: ليس بعيب ولا خيار لها فيه لقدرته على الإيلاج، وأنه ربما كان أمتع إصابة. والقول الثاني: إنه عيب ولها الخيار، لأنه نقص يعدم معه النسل ١.

وأما العيوب المختصة بالنساء فعيبان:

الأول: القرن: هو عظم يعترض الرحم يمنع من الإصابة.

والثاني الرتق: وهو لحم يسد مدخل الذكر فلا تمكن معه الإصابة.

فيثبت الخيار للزوج إن وجد زوجته بأحد هذين العيبين، فإن رضي وأمسك وإلا فسخ وأبطل النكاح ٢.

والخيار في الفسخ بهذه العيوب إذا ثبت يكون على الفور في المذهب، لأنه خيار عيب فكان على الفور كما في البيع، والمعنى بكونه على الفور أن المطالبة والرفع إلى الحاكم يكونان على الفور، ولا ينافي ذلك ضرب المدة في العنة فإنها حينئذ تتحقق، وإنما يؤمر بالمبادرة إلى الفسخ بعد تحقق العيب.

والوجه الثاني: أن الخيار فيه قولان آخران كخيار العتق. أحدهما: يمتد ثلاثة أيام. والثاني: يبقى إلى أن يوجد صريح الرضى بالمقام معه أو ما يدل عليه ٣.

الأثر المترتب على الفسخ:

أولا: حكم ثبوت المهر.

١ الحاوي الكبير "٣٤٠/٩".

٢ الحاوي الكبير "٣٤١/٩"، البيان "٢٩٠/٩"، مغني المحتاج "٣٤٠/٤".

٣ روضة الطالبين "١٨٠/٧".

إن كان الفسخ قبل الدخول سواء كان العيب منها أو منه، فإنه يسقط المهر.

وذلك لأنه إن كانت المرأة الفاسخة كانت الفرقة من جهتها فسقط مهرها كما لو ارتدت، وإن كان الرجل هو الذي فسخ إلا أنه فسخ لمعنى من جهة المرأة، وهو التدليس بالعيب فصار كأنها اختارت الفسخ.

وإن كان بعد الدخول، فاختلف فقهاء الشافعية في حكم المهر لها على ثلاثة أوجه:
الأول: وهو الأصح أن لها مهر المثل بالإصابة سواء كان الفسخ من جهتها أو من جهته، وذلك للآتي:

لقوله - ﷺ -: " فلها المهر بما استحل من فرجها ".

ولأنه يستند الفسخ إلى سبب قبل العقد فيصير الوطء كالحاصل في نكاح فاسد فوجب مهر المثل.

ولأن الزوج قد استمتع بمعيبة، وهو إنما بذل المسمى على ظن السلامة ولم تحصل.
الوجه الثاني: يجب المسمى.

والثالث: إن فسخ بعيبها، فمهر المثل، وإن فسخت بعيبه، فالمسمى ١.

ثانياً: مما يترتب على الفسخ حكم ثبوت العدة عليها، والنفقة لها.

فأما العدة فواجبة عليها بالإصابة، لأنه فراش يلحق به ولدها.

وأما النفقة فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلاً لارتفاع العقد الموجب لها ولا سكنى لها.

وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملاً، قولان بناء على اختلاف فقهاء الشافعية في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها؟ على قولين:

أحدهما: أنها وجبت لها بالزوجية، فعلى هذا لا نفقة لهذه لارتفاع عقد الزوجية.

١ الحاوي الكبير "٣٤٥/٩"، نهاية المطلب "٤١٢/١٢-٤١٣"، روضة الطالبين "١٨٠/٧-١٨١"، مغني المحتاج "٣٤٣/٤".

والقول الثاني: أن النفقة وجبت لحملها فعلى هذا لها النفقة، لأن حملها في الحقوق كحمل الزوجة ١.

الدرس الثالث: حقوق الزوجين

إن لكل عقد حقوق وواجبات تلزم طرفي العقد، وعقد الزواج كسائر العقود يترتب عليه حقوق تستحق لطرفي الحياة الزوجية، ويوجب واجبات على شريكي الحياة، فللزوجة حقوق وعليه واجبات تجاه زوجها، وللزوجة حقوق وعليها واجبات تجاه زوجها، ومدى ما التزم الطرفان بما لهما وما عليهما، كانت ثمار العقد المرجوة متحققة بإذن الله تعالى، ومتى ما فهم الشريكان ما لهما وما عليهما كان ذلك أقرب لأن توجد المودة والرحمة التي هي مقصود النكاح وبهما يتحقق الاستقرار، ويصل الزوجان إلى طمأنينة القلب وانشرح الصدر.

إن التزام الزوجين بما لهما وما عليها يقطع دابر النزاع والخصام اللذان يؤديان إلى الشقاق والعداوة والبغضاء، وإن معرفة كل طرف بما له وما عليه يريح الإنسان ويساعده في الوصول إلى السعادة المرجوة والسكينة المؤملة.

وللزوجين حقوق مشتركة بينهما، وينفرد كل واحد منهما بحقوق وواجبات تخصه، لذا فأبدأ الحديث بما هو مشترك ثم أعرج على المنفرد.

أولاً: الحقوق المشتركة بين الزوجين: هذه حقوق مشتركة بين الزوج وزوجته، بمعنى أن الرجل عليه أن يبذل ذلك الحق، وكذا المرأة عليها أن تبذل نفس الحق، وهذه الحقوق كالاتي: المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف من الصحبة الجميلة، وكف الأذى، وأن لا يماطل بالواجب عليه مع قدرته، ولا يظهر الكراهة لبذله، بل يبذله ببشر وطلاقة، ولا يتبعه منة ولا أذى، لأن هذا من المعروف المأمور به، وذلك استدلالاً بالآتي: أ - لقوله تعالى: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ٢.

١ الحاوي الكبير "٣٤٦/٩". روضة الطالبين "١٨٣/٧"، مغني المحتاج "٣٤٣/٤".

٢ سورة البقرة من آية ٢٢٨.

ب - قوله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}. ١. وجه الدلالة: أن الله تعالى بين أن لكلا طرفي الزواج حقوقا يجب أن تؤدى بالمعروف، فللنساء حقا، وعليهن حقا.

وليس المقصود بقوله: {وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ٢ تجانس الحقين وتماتلهما، وإنما المقصود وجوبهما ولزومهما. قال الشافعي - رحمه الله تعالى - : (وجماع المعروف بين الزوجين: كف المكروه، وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، لا بإظهار الكراهية في تأديته، فأيهما مطل بتأخير.. فمطل الغني ظلم بتأخير).

قال بعض الشافعية: و (كف المكروه) هاهنا هو: أن لا يؤدي أحدهما الآخر بقول ولا فعل، ولا يأكل أحدهما، ولا يشرب ولا يلبس ما يؤدي الآخر.

وقول الشافعي: (وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه): معناه إذا وجب لها على الزوج نفقة أو كسوة.. بذله لها، ولا يحوجها إلى أن ترفعه إلى الحاكم، فيلزمها في ذلك مؤونة؛ لقوله - ﷺ - : «مطل الغني ظلم» (متفق عليه) وكذلك: إذا دعاها إلى الاستمتاع.. لم تمتنع، ولم تحوجه إلى أن يرفع ذلك إلى الحاكم، فيلزمه في ذلك مؤنة؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه -، وأرضاه: أن النبي - ﷺ - قال: «إذا دعا أحدكم امرأته إلى فراشه فأبت عليه، فبات وهو عليها ساخط.. لعنتها الملائكة حتى تصبح» (متفق عليه)

وقول الشافعي: (لا بإظهار الكراهية في تأديته): معناه إذا طلبت الزوجة حقها منه أو طلب الزوج حقه منها.. بذل كل واحد منهما ما وجب عليه لصاحبه وهو بائس الوجه ضاحك السن؛ لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ» ٣.

وقال - ﷺ - : «لو كنت أما أحدنا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها» ٤.

١ سورة النساء من آية ١٩.

٢ سورة البقرة من آية ٢٢٨.

٣ رواه الترمذي، وصححه.

٤ الحاوي الكبير "٥٦٨/٩". البيان "٥٠١/٩"، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح.

من الحقوق المشتركة بين الزوجين استمتاع كل منهما بالآخر .

فنص الشافعية على أنه يحل لكل من الزوجين الاستمتاع بالآخر، كما يحل له النظر إلى جميع بدن صاحبه وكذا لمسه لحديث: " احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك " ١.

ثانيا: حق الزوج على زوجته: من حق الرجل على زوجته أمور عدة منها:

١- وجوب الطاعة: جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر والتوجيه والرعاية، كما يقوم الولاية على الرعاية، بما خصه الله به الرجل من خصائص جسمية وعقلية، وبما أوجب عليه من واجبات مالية، استدلالا بالآتي:

قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ٢. وجه الدلالة: قال البيضاوي في تفسير الآية: أي يقومون عليهن قيام الولاية على الرعاية، وعللوا ذلك بأمرين: وهبي وكسبي، فقال: {بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ} بسبب تفضيله الرجال على النساء بكمال العقل، وحسن التدبير، ومزيد القوة، وبما أنفقوا في نكاحهن كالمهر والنفقة، فكان له عليها حق الطاعة في غير معصية الله.

وروى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت النبي ﷺ: أي الناس أعظم حقا على المرأة؟ قال: زوجها وقال عليه الصلاة والسلام "لو كنت أما أحدنا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها".

٢- تمكين الزوج من الاستمتاع:

فمن حق الزوج على زوجته تمكينه من الاستمتاع، فإذا تزوج امرأة وكانت أهلا للجماع وجب تسليم نفسها إليه بالعقد إذا طلب، وذلك أن يسلمها مهرها المعجل وتمهل مدة حسب العادة لإصلاح أمرها كاليومين والثلاثة إذا طلبت ذلك لأنه من حاجتها، ولأن ذلك يسير جرت

١ مغني المحتاج "٢١٧/٤"، والحديث رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح.

٢ سورة النساء من آية ٣٤.

العادة بمثله "وقال النبي ﷺ عند قفوله مرة إلى المدينة: أمهلوا حتى تدخلوا ليلاً - أي عشاء - لكي تمتشط الشعثة، وتستحد المغيبة " وما ذلك إلا لإصلاح نفسها.

وللزواج إجبار زوجته على الغسل من الحيض والنفاس، مسلمة كانت أو ذمية؛ لأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له، فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه ١.

ولا يجب على الزوج الاستمتاع بها، لأنه حق له فجاز له تركه كسكنى الدار المستأجرة، ولأن الداعي إليه الشهوة، وذلك ليس إليه.

والمستحب: أن لا يخليها من الجماع؛ استدلالاً بالآتي:

أ- لقوله - ﷺ -: «لكني أصوم وأفطر، وأصلي وأنام، وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي.. فليس مني»

ب- ولأنه إذا لم يجامعها.. لم يؤمن منها الفساد، وربما كان سبباً للعداوة والشقاق بينهما ٢.

٣- عدم الإذن لمن يكره الزوج دخوله

ومن حق الزوج على زوجته ألا تدخل بيته أحداً يكرهه. لحديث: " فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون " ٣.

٤- عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج:

فللزواج أن يمنع زوجته من الخروج إلى المسجد وغيره؛ استدلالاً بالآتي:

روى ابن عمر - رضي الله عنهما - وأرضاهما -: «إِنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ فَقَالَتْ: مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ؟ فَقَالَ: لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ، وَلَا تَصُومُ يَوْمًا تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ؟ فَإِنْ فَعَلَتْ

١ المجموع "٤٠٩/١٦".

٢ البيان "٥٠٣/٩".

٣ المجموع "٤٤٧/١٦"، والحديث رواه الترمذي بإسناد صحيح.

أَثِمْتُ وَلَمْ تُؤْجَرْ، وَلَا تَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ: مَلَائِكَةُ الْعَصَبِ، وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ حَتَّى تَتُوبَ أَوْ (تراجع) قِيلَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا {١}.

وروي: أن النبي - ﷺ - قال: «المرأة عورة، فإذا خرجت.. استشرفها الشيطان» ٢.

ولأنها تقوت بالخروج من يملك عليها من الاستمتاع.

وللزوج أن يمنع زوجته من عيادة أبيها وأمها إذا مرضا، ومن حضور موتها وتشيعهما إذا ماتا؛ استدلالا بالآتي:

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - عن النبي - ﷺ - «أن رجلا خرج وأمر امرأته أن لا تخرج من بيتها، وكان أبوها في أسفل الدار، وكانت في أعلاها فمرض أبوها فأرسلت إلى النبي - ﷺ - فذكرت ذلك له فقال: " أطيعي زوجك " فمات أبوها فأرسلت إلى النبي - ﷺ - فقال: " أطيعي زوجك " فأرسل إليها النبي - ﷺ - -: " إن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجها » ٣.

ولأن عيادة أبيها وأمها وحضور مواراتهما ليس بواجب عليها، فلا تترك له واجبا عليها.

لكن يستحب للزوج أن لا يمنعها من ذلك؛ لأن ذلك ربما أدى إلى العداوة بينهما ٤.

ثالثا: حق الزوجة على زوجها: للمرأة على زوجها حقوق عدة، يجب أن تتوفر لها، وهي كالآتي:

الأول- المهر ويسمى الصداق: والصداق هو ما وجب بِنكاح أو وطء أو تقويت بضع قهرا كرضاع ورجوع شهود. وسمي بذلك لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل في إيجاب المهر. وله سبعة أسماء: الصداق، والنحلة والأجر، والفريضة، والمهر، والعليقة،

١ (رواه أبوداود الطيالسي).

٢ (رواه الترمذي وصححه).

٣ قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عصمة بن المتوكل، وهو ضعيف.

٤ الحاوي "٥٤٨/٩"، البيان "٥٠١/٩".

والعقر؛ لأن الله تعالى سماه: الصداق، والنحلة، والأجر، والفريضة. وسماه النبي - صلى الله عليه وسلم -: المهر، والعليقة، وسماه عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وأرضاه: العقر.

والصداق واجب على الزوج لزوجته بمقتضى عقد النكاح، والأصل في وجوبه الكتاب والسنة والإجماع.

فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ١.

وجه الدلالة: أن الله أمر بإعطاء النساء حقهن، وعبر عن الصداق بالنحلة.

وفيمن توجه إليه هذا الخطاب قولان:

أحدهما: أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين.

والثاني: أنه متوجه إلى الأولياء؛ لأنهم كانوا يملكون في الجاهلية صداق المرأة، فأمرهم الله تعالى بدفع صداقهن إليهن.

فإن قيل: لم سماه الله تعالى نحلة، و (النحلة): العطية بغير عوض، والمهر ليس بعطية، وإنما هو عوض عن الاستمتاع؟ ففيه ثلاث تأويلات:

أحدها: أنه لم يرد بالنحلة العطية؛ وإنما أراد بالنحلة: من الانتحال، وهو: التدين؛ لأنه يقال: انتحل فلان مذهب كذا، أي: تدين به. فكأنه تعالى قال: {وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} ٢ أي: تدينا.

والثاني: أن المهر يشبه العطية؛ لأنه يحصل للمرأة من اللذة في الاستمتاع ما يحصل للزوج وأكثر؛ لأنها أغلب شهوة، والزوج ينفرد ببذل المهر، فكأنها تأخذه بغير عوض.

١ سورة النساء من آية ٤.

٢ سورة النساء من آية ٤.

والثالث: أنه عطية من الله تعالى في شرعنا للنساء؛ لأن في شرع من قبلنا كان المهر للأولياء، ولهذا قال الله تعالى . في قصة شعيب وموسى صلى الله على نبينا وعليهما وسلم . { قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ } ١.

٢- وقال تعالى: { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً } ٢.

وجه الدلالة: أن المراد بالأجر الصداق، وعبر عنه بالأجر؛ لأنه في مقابلة منفعة.

وفي قوله فريضة تأويلان:

أحدهما: يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين.

والثاني: أي مقدرة معلومة.

٣- وقال تعالى { وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً } ٣.

وجه الدلالة: أن الله عز وجل سمى الصداق فريضة، أي مفروض، فكان واجبا.

وأما السنة: فأحاديث منها:

أ- ما روى عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن النبي -ﷺ- قال: " أدوا العلائق، قالوا يا رسول الله وما العلائق؟ قال: ما تراضى به الأهليون " ٤.

ب- وروى عن النبي -ﷺ- أنه قال: " من استحل بدرهمين فقد استحل " ٥ أي طلب الحل.

١ سورة القصص من آية ٢٧.

٢ سورة النساء من آية ٢٤.

٣ سورة البقرة من آية ٢٣٧.

٤ (رواه الدارقطني من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف).

٥ قال في التلخيص الحبير (٣/ ٣٨٦): أَلْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْبَةَ، عَنْ جَدِّهِ بَلْفُظٍ: مَنْ اسْتَحَلَ بِدِرْهِمٍ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ شَاهِينَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ لَهُ مِنْ طَرِيقِ جَارِيَةِ بْنِ هَزْمٍ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ بَلْفُظٍ «يُسْتَحَلُّ النِّكَاحُ بِدِرْهِمَيْنِ فَصَاعِدًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بَلْفُظٍ: «مَنْ أَعْطَى فِي

وانعقد الإجماع على أن ما يصح جعله صداقا يثبت بالتسمية الصحيحة ١.

فإذا تقرر أن الصداق في عقد النكاح واجب فإن تزوجها على غير صداق سميائه في العقد، صح العقد وإن كرهنا ترك التسمية فيه. فالمستحب: أن يسمى الصداق في عقد النكاح؛ استدلالاً بالآتي:

ما روي (أن النبي - ﷺ - لم يتزوج أحداً من نسائه - رضي الله عنهن -، ولا زوج أحداً من بناته - رضي الله عنهن - إلا بصداق سماه في العقد).

وروي: «أن امرأة أتت النبي - ﷺ - فقالت: يا رسول الله، قد وهبت نفسي لك، فصعد النبي - ﷺ - بصره إليها، ثم صوبه، ثم قال: " ما لي اليوم في النساء من حاجة "، فقام رجل من القوم، فقال: زوجنيها يا رسول الله، فقال - ﷺ -: " ما تصدقها؟ "، قال: إزاري. قال: " إن أصدقتها إزارك.. جلست ولا إزار لك "، قال - ﷺ -: " التمس شيئاً "، فالتمس فلم يجد. فقال - ﷺ -: " التمس ولو خاتماً من حديد "، فالتمس فلم يجد، فقال له النبي - ﷺ -: " أمعك شيء من القرآن؟ "، قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فقال - ﷺ -: " زوجتكها بما معك من القرآن » ٢.

ولأنه إذا زوجه بالمهر.. كان أقطع للخصومة.

فإن عقد النكاح بغير صداق.. انعقد النكاح؛ استدلالاً بالآتي:

لقوله تعالى: { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً } (البقرة، من آية ٢٣٦)

وجه الدلالة: أن الله أثبت الطلاق من غير فرض، والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح.

صَدَاقِ امْرَأَةٍ سَوِيًّا، أَوْ تَمَرًا فَقَدْ اسْتَحَلَّ» وَفِي إِسْنَادِهِ مُسْلِمٌ بْنُ رُوْمَانَ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَرُوِيَ مَوْفُوقًا وَهُوَ أَقْوَى.

١ الحاوي الكبير "٣٩٠-٣٩٢"، نهاية المطلب "١٣/١٥"، البيان "٣٦٦/٩-٣٦٧"، مغني المحتاج "٣٦٦/٤-٣٦٧".

٢ (متفق عليه).

وروى عقبة بن عامر - رضي الله عنه -: «أن النبي - ﷺ - زوج رجلاً امرأة، ولم يفرض لها صداقاً، فلما حضرته الوفاة قال: إني تزوجتها بغير صداق، وإني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخبير، فباعته بمائة ألف»^١.

وما روي أن بروع بنت واشق تزوجت بغير مهر فحكم لها رسول الله - ﷺ - بمهر نسائها والميراث. رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح.

ولأن المقصود في النكاح أعيان الزوجين دون المهر، ولهذا يجب ذكر الزوجين في العقد، وإنما العوض فيه تبع. بخلاف البيع؛ فإن المقصود فيه العوض، ولهذا لا يجب ذكر البائع والمشتري في العقد إذا وقع بين وكيليهما.

ح- ولأن المقصود من عقد النكاح التواصل والألفة، والصداق فيه تبع لمقصوده، فخالف عقود المعاوضات من وجهين:

أحدهما: أن رؤية المنكوحة ليست شرطاً فيه.

والثاني: أن ترك العوض فيه لا يفسده.

أما كراهة ترك الصداق في العقد وإن كان جائزاً لثلاثة أمور:

أحدها: لئلا يتشبه بالموهوبة التي تختص برسول الله - ﷺ - دون غيره من أمته.

والثاني: لما فيه من قطع المشاجرة والتنازع إلى الحكام.

والثالث: ليكون ملحقاً بسائر العقود التي تستحق فيها المعاوضات^٢.

مقدار الصداق:

الكلام في هذه المسألة يشتمل على أمرين:

أحدهما: في أكثر المهر.

١ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

٢ الحاوي "٣٩٣-٣٩٤"، البيان "٣٦٨-٣٦٩"، مغني المحتاج "٣٦٧/٤".

والثاني: في أقله.

فأما أكثره فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له، وذلك استدلالاً بالآتي:

١- لقوله تعالى: {وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}.

وجه الدلالة: أن الله عز وجل أخبر أن القنطار يجوز أن يكون صداقاً.

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: (القنطار: سبعون ألف مثقال).

وقال أبو صالح - رحمه الله -: مائة أوقية.

وقال معاذ - رضي الله عنه -: (ألف ومائتا أوقية).

وقال أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه -: (القنطار: ملء مسك ثور ذهباً). و (مسك الثور): جلده.

وروي: (أن عمر - رضي الله عنه - وأرضاه خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه، وقال: يا معشر الناس، لا تغالوا في صدقات النساء، فوالله: لا يبلغني أحد زاد على مهر أزواج رسول الله - ﷺ - إلا جعلت الفضل في بيت المال، فعرضت له امرأة من قريش، فقالت: كتاب الله أولى أن يتبع، إن الله تعالى يعطينا، وتمنعنا يا ابن الخطاب! فقال: أين؟ قالت: قال الله تعالى: {وَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا}١، فقال عمر - رضي الله عنه - وأرضاه: فليضع الرجل ماله حيث شاء). وفي رواية أخرى: أنه قال: (كل الناس أفقه من عمر، فرجع عن ذلك). ٢

٣- وروي: (أنه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم - وأرضاهم، فأصدقها أربعين ألف درهم).

٤- وروي: (أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - وأرضاهما كان يزوج بنات أخيه عبيد الله على صداق عشرة آلاف درهم).

٥- وتزوج أنس - رضي الله عنه - امرأة وأصدقها عشرة آلاف.

١ سورة النساء من آية ٢٠.

٢ سورة النساء من آية ٢٠.

قال الشافعي: (والاقتصاد في المهر أحب إلي من المغالاة فيه)، وذلك للآتي:

١- ما روت عائشة - رضي الله عنها -: أن النبي - ﷺ - قال: «أعظم النكاح بركة أخفه مؤنة».

٢- وروى ابن عباس: أن النبي - ﷺ - قال: «خيرهن أيسرهن مهرا».

٣: عن عقبة بن عامر عن النبي - ﷺ - قال: «خير الصداق أيسره» ١.

والمستحب: أن لا يزيد على خمسمائة درهم، وهو صداق أزواج النبي - ﷺ - وبناته؛ لما روي عن عائشة - رضي الله عنها -: أنها قالت: «كان صداق أزواج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبناته اثنتي عشرة أوقية ونشأ، أتدرون ما النش؟ نصف أوقية». و (الأوقية): أربعون درهما؛ لما روى أبو هريرة: أن النبي - ﷺ - قال: «الأوقية: أربعون درهما» و (النش): عشرون درهما ٢.

أقل الصداق:

مذهب الشافعي رحمه الله أن الصداق غير مقدر، وأن كل ما جاز أن يكون ثمنا، أو مبيعا، أو أجرة، أو مستأجرا جاز أن يكون صداقا قل أو كثر، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والأثر والقياس:

أما الكتاب: فقوله تعالى {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ٣.

وجه الدلالة: أن قوله تعالى: {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} على عمومته، من قليل أو كثير.

وأما السنة فأحاديث، منها:

أ- روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: " من استحل بدرهمين فقد استحل ".

١ رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

٢ الحاوي الكبير "٣٩٦-٣٩٧"، ٩/البيان "٣٧٠-٣٧٣".

٣ سورة البقرة من آية ٢٣٧.

وجه الدلالة: يعني فقد استحل بالدرهمين النكاح، فدل ذلك على جواز الصداق أن يكون درهمين فقط وهما قليل.

وروى عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة تزوجت على نعلين فقال لها رسول الله - ﷺ - "أرضيت من نفسك ومالك بهاتين النعلين؟ فقالت نعم فأجازه..

ث- وروى أبو حازم عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله - ﷺ - قال لرجل خطب منه المرأة التي بذلت نفسها له: "التمس ولو خاتما من حديد".

وجه الدلالة: أن الخاتم من الحديد أقل الجواهر قيمة، فدل على جواز القليل من المهر.

أما الأثر: أ- فما روي عن قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن جابر قال: إنا كنا لننكح المرأة على الحفنة أو الحفنتين من دقيق.

ب- وروى قتادة عن أنس بن مالك قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم.

وأما القياس فمن وجوه: هو أن كل ما صلح أن يكون ثمنا صلح أن يكون مهرا كالعشرة.

ولأنه عقد ثبت فيه العشرة عوضا فصح أن يثبت دونها عوضا كالبيع.

ولأن ما يقابل البضع من البذل لا يتقدر في الشرع كالخلع.

ولأن كل عوض لا يتقدر أكثره لا يتقدر أقله قياسا على جميع الأعواض.

وضابط ما يصح أن يكون صداقا: كل ما صح كونه مبيعا عوضا أو معوضا عينا أو دينا أو منفعة كثيرا أو قليلا ما لم ينته في القلة إلى حد لا يتمول صح كونه صداقا وما لا يتمول كالحصاة وقشرة البصلة وقمع الباذنجانة فلا يصح أن يكون صداقا ١.

أنواع المهر: المهر الواجب نوعان:

١ الحاوي الكبير "٣٩٨-٣٩٩"، المهذب "٤٦٢/٢"، البيان "٣٧٠/٩"، مغني المحتاج "٣٦٧/٤-٣٦٨".

أ - المهر المسمى: وهو العوض المسمى في عقد النكاح والمسمى بعده لمن لم يسم لها في العقد.

ب - مهر المثل: وهو القدر الذي يرغب به في أمثال الزوجة.

فالمهر المسمى، هو ما اتفق فيه طرفي الزواج على مقدار ما يكون مهرًا للمرأة المزوجة، سواء كان قليلاً أو كثيراً بالقدر الذي يتفق مع الضابط الذي ذكر آنفاً وهو أن يكون المسمى متمولاً.

أما مهر المثل فيجب في سبعة مواضع:

أحدها: مفوضة البضع إذا دخل بها الزوج قبل الفرض، أو مات عنها في أحد القولين.

الثاني: مفوضة المهر.

الثالث: إذا فوض الولي بضعها بغير إذنها.

الرابع: إذا نكحت المرأة بمهر فاسد أو مجهول، بأن كان مما لا يتمول كالحصاة، أو كان مجهولاً كدراهم دون تحديد.

الخامس: إذا نكحها نكاحاً فاسداً ووطئها، كالوطء بعقد غير مشهود عليه.

السادس: إذا وطئ امرأة بشبهة، كمن وطئ امرأة ليست زوجة ولا مملوكة يظنها زوجته أو مملوكته.

السابع: إذا أكره امرأة على الزنا.

أما المرأة المفوضة البضع: المالكة لأمر نفسها -وهي الحرة العاقلة البالغة الرشيدة- إذا أذنت لوليها في أن يزوجهها بلا مهر، وقالت: "زوجني بلا صداق"، فزوجها وليها، وصرح بنفي المهر على حسب إذنها، فهذا النكاح هو الذي يسمى نكاح التقويض، لأنها سلمت نفسها بغير مهر، وهو نكاح صحيح ثابت، لقوله تعالى { لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا

لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً^١. ومعناه ولم تفرضوا لهن فريضة، فأقام " أو " مقام " لم " على وجه البذل مجازا.

والمرأة المفوضة المهر، فهي التي تزوجها الرجل ولم يسم لها في العقد مهر، ولا شرط فيه أن ليس لها مهر.

ومهر المثل المعتبر فيه نساء عصابات المرأة، كالأخوات وبنات الإخوة والعمات وبنات الأعمام.

ولا تعتبر بنساء ذوي أرحامها، كأمهاتها وخالاتها، ولا بنساء بلدها من غير عصابات مع وجود نساء عصابات.

لما روي: «أن النبي - ﷺ - قضى في بروع بنت واشق: أن لها مهر نساء قومها» وهذا يقتضي قومها الذين تنسب إليهم. ولأنه إذا لم يكن بد من اعتبارها بغيرها من النساء.. فاعتبارها بنساء عصابات أولى؛ لأنها تساوين في النسب.

وتعتبر بمن هي في مثل حالها في الجمال، والعقل، والأدب، والسن، والبكارة، والثيوبه، والدين، وصراحة النسب.

وإنما اعتبر الجمال؛ لأن له تأثيرا في الاستمتاع، وهو المقصود في النكاح.

واعتبر العقل والأدب؛ لأن مهر العاقلة الأدبية أكثر من مهر من لا عقل لها ولا أدب.

وكذلك مهر الشابة والبكر أكثر من مهر العجوز والثيب. ومهر العفيفة أكثر من مهر الفاسقة.

فإن اختصت أي انفردت واحدة منهن بفضل أي صفة كمال مما ذكر أو نقص عنه زيد في مهرها في صورة الفضل أو نقص منه في صورة النقص لائق بالحال أي حال المرأة المطلوب مهرها بحسب ما يراه الحاكم، فالرأي في ذلك منوط به فيقدره باجتهاده صعودا

١ سورة البقرة من آية ٢٣٦.

وهبوطاً، وهذا كما قال بعض المتأخرين إذا لم يحصل الاتفاق عليه وحصل تنازع ولو سامحت واحدة منهن لم تجب على الباقيات موافقتها اعتباراً بالغالب ١.

استقرار المهر:

الأصل أن الزوجة تملك الصداق بمجرد العقد حالاً كان أو مؤجلاً لأن عقد النكاح عقد يملك الزوج به العوض؛ فتملك الزوجة به المعوض كاملاً كالبيع؛ ولكن هذا الملك عرضة للسقوط كلاً أو بعضاً ما دام لم يوجد ما يؤكد المهر ويقرره، والذي يؤكد المهر أمور على النحو الآتي:

١- الوطء: فاتفق الشافعية على أن المهر يتأكد بوطء الزوج وزوجته؛ وإن كان الوطء حراماً لوقوعه في الحيض أو الإحرام؛ لأن وطء الشبهة يوجب المهر ابتداءً فذا أولى بالتقرير ويستقر بوطأة واحدة.

فيستقر المهر المسمى للزوجة بالوطء في الفرج؛ لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ٢.

وجه الدلالة: أنه لما أثبت للزوج الرجوع بنصف الصداق بالطلاق قبل المسيس.. دل على: أنه لا يرجع عليها بشيء منه بعد المسيس.

وقال في آية أخرى: {وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} ٣

و (الإفضاء): الجماع.

٢- موت أحد الزوجين يثبت الصداق.

فإن مات أحد الزوجين قبل الدخول.. استقر لها المهر كاملاً غير منقوص ٤.

١ الحاوي الكبير ٤٧٢/٩ وما بعدها"، نهاية المطلب "١٠٠/١٣"، البيان "٤٥٠/٩-٤٥١"، مغني المحتاج "٣٨٦-٣٨٤/٤".

٢ سورة البقرة من آية ٢٣٧.

٣ سورة النساء من آية ٢١.

٤ البيان "٤٠٩/٩-٤١٠"، روضة الطالبين "٢٦٣/٧".

حكم الخلوة بالمرأة:

إن خلا الزوج بزوجته ولم يجامعها.. فهل حكم الخلوة حكم الوطء في تقرير المهر ووجوب العدة؟ اختلف فقهاء الشافعية على وجهين:

الأول: أنه لا تأثير للخلوة في تقرير المهر، ولا في وجوب العدة، وهذا قول الشافعي في الجديد.

الثاني: الخلوة كالوطء في تقرير المهر ووجوب العدة.

والدليل على أن الخلوة لا تتعلق بها حكم في كمال مهر، ولا وجوب عدة، الكتاب والقياس أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ^١ والمسييس عبارة عن الوطء لثلاثة معان: أحدها: أنه مروي في التفسير عن ابن عباس، وابن مسعود.

والثاني: أن المسييس كناية لما يستقبح صريحه، وليست الخلوة مستقبحة التصريح فيكني عنها، والوطء مستقبح فكني بالمسييس عنه.

والثالث: أن المسييس لا يتعلق به كمال المهر؛ لأنه لو خلا بها من غير مسيس كمل المهر، ولو وطئها من غير خلوة كمل عليه المهر، ولو مسها من غير خلوة، ولا وطء لم يكمل المهر، فكان حمل المسييس على الوطء الذي يتعلق به لحكم أولى من حمله على غيره، وإذا كان كذلك فقد جعل الطلاق قبل المسييس الذي هو الوطء موجبا لاستحقاق نصف المهر.

وأما القياس فمن وجوه:

أنه طلاق قبل الإصابة فوجب أن لا يكمل به المهر كالطلاق قبل الخلوة.

ولأنها خلوة خلت عن الإصابة فوجب أن لا يكمل بها المهر كالخلوة إذا كان أحدهما محرما أو صائما فرضا.

١ سورة البقرة من آية ٢٣٧.

ولأن ما لا يوجب الغسل لا يوجب كمال المهر كالقبلة من غير خلوة.

ث- ولأن للوطء أحكاما تختص به من وجوب الحد والغسل، وثبوت الإحصان والإحلال للزوج الأول وسقوط العنة وحكم الإيلاء، وإفساد العبادة ووجوب الكفارة، واستحقاق المهر في النكاح الفاسد، وكماله في الصحيح، ووجوب العدة فيهما.

فلما انتقى عن الخلوة جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهر والعدة انتقى عنها هذان اعتبارا بسائر الأحكام.

واستدل من قال بأن الخلوة تقتضي كمال المهر ووجوب العدة بالكتاب والسنة والأثر والقياس:

أما الكتاب: فقول الله تعالى: {وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا (٢٠) وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا } ولهم من الآية دليلان:

أحدهما: عموم قوله {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} إلا ما خصه دليل.

والثاني: قوله {وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ} قال الفراء: معناه وقد خلا بعضكم ببعض؛ لأن الفضاء هو الموضع الواسع الخالي، وقول الفراء فيما تعلق باللغة حجة.

وأما السنة: فما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: " من كشف قناع امرأة فقد وجب لها المهر كاملا ".

وأما الأثر: ١- روي عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه، أنه قال: " ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم ".

٢- وروي عن زرار بن أوفى أنه قال: قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق بابا وأرخص سترًا فقد وجب عليه المهر، دخل بها أو لم يدخل، وقد قال النبي " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ ".

وأما القياس فمن وجوه: ١- أن النكاح عقد على منفعة فوجب أن يكون التمكين من المنفعة بمنزلة استيفائها في استقرار بدلها كالإجارة.

٢- ولأن المهر في مقابلة الإصابة كما أن النفقة في مقابلة الاستمتاع، ثم ثبت أن التمكين من الاستمتاع شرط بمنزلة الاستمتاع في استقرار النفقة فوجب أن يكون التمكين من الإصابة بمنزلة الإصابة في استقرار المهر ١.

سقوط المهر: يسقط المهر كاملاً بكل فرقة حاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها كإسلامها بنفسها، أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها أو فسخا بعيبه، أو بعثتها تحت رقيق، أو ردتها، أو فرقة حاصلة بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر المسمى ابتداء والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر؛ لأنها إن كانت هي الفاسخة، فهي المختارة للفرقة فكأنها أتلقت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلقت المبيع قبل التسليم وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي الفاسخة ٢.

تشطير المهر: اتفق فقهاء الشافعية على أن من طلق زوجته قبل الدخول بها وقد سمى لها مهراً يجب عليه نصف المهر المسمى لقوله تعالى: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ} ٣؛ وهو نص صريح في الباب فيجب العمل به ٤.

الثاني: من حقوق المرأة على زوجها: النفقة.

من حقوق الزوجة على زوجها: النفقة، وقد أجمع فقهاء الشافعية على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن على التفصيل الذي سيأتي.

١ الحاوي الكبير "٩/٥٤٠-٥٤٢هـ".

٢ مغني المحتاج

٣/ سورة البقرة من آية ٢٣٧.

"٤. روضة الطالبين" ٧/٢٨٩.

والحكمة في وجوب النفقة لها أن المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، ممنوعة من الخروج من بيت الزوجية إلا بإذن منه للاكتساب، فكان عليه أن ينفق عليها، وعليه كفايتها، فالنفقة مقابل الاحتباس.

والمقصود بالنفقة توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام، ومسكن، وخدمة.

وذهبوا إلى أن النفقة الواجبة للزوجة على زوجها تشمل الطعام والكسوة والمسكن، وكل ما لا غنى لها عنه.

ووجوب نفقة الزوجة على زوجها ثابت بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب: ١- فقوله تعالى {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ} ١.

وجه الدلالة: دل ذلك على وجوب النفقة، لأنها من الفرض.

٢- وقوله تعالى {لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ٢.

وجه الدلالة: أن الله أمره بالنفقة في حال يسره وإعساره فدل ذلك على وجوبها.

٣- وقال تعالى {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ٣. وجه الدلالة: دلت الآية على وجوب النفقة من وجهين معقول ونص، فالمعقول منها قوله جل وعز: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ}، والقيم على غيره هو المتكفل بأمره، والنص منها قوله {وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ}.

٤- وقال تعالى: {وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ٤.

وجه الدلالة: فلما أوجب نفقتها بعد الفراق إذا كانت حاملا كان وجوبها قبل الفراق أولى.

١ سورة الأحزاب من آية ٥٠.

٢ سورة الطلاق من آية ٧.

٣ سورة النساء من آية ٣٤.

٤ سورة الطلاق من آية ٦.

وأما السنة فأحاديث منها: ١- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رجلاً أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله معي دينار قال أنفقه على نفسك. قال معي آخر قال أنفقه على ولدك. قال معي آخر قال أنفقه على أهلك. قال معي آخر قال أنفقه على خادمك. قال معي آخر قال أنت أعلم. ٢- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنه قال بعد دينار الخادم معي آخر لم يبق غيره قال أنفقه في سبيل الله وهو أدناها أجراً.

٣- وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت جاءت هند-رضي الله عنها- إلى رسول الله - ﷺ - فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه شيء، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف". وجه الدلالة: هذا خبر دل على وجوب النفقة على الزوجة، بدليل إباحة النبي ﷺ لهند أن تأخذ ما يكفيها بالمعروف.

أما المعقول فهو أن الزوجة محبوسة المنافع عليه وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها فوجب لها مؤنتها ونفقتها كما يلزمه لملوكه الموقوف على خدمته وكما يلزم الإمام في بيت المال نفقات أهل النفير لاحتباس نفوسهم على الجهاد ١.

قدر النفقة: ونفقة الزوجة معتبرة بحال الزوج لا بحال الزوجة؛ فيجب لابنة الخليفة ما يجب لابنة الحارس، وهي مقدرة غير معتبرة بكفايتها، وذلك استدلالاً بالآتي:

١- قوله تعالى: {لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} ٢.

وجه الدلالة: أراد الله عز وجل أن الغني ينفق على حسب حاله، والفقير على حسب حاله.

٢- ولقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ٣.

وجه الدلالة: أراد المعروف عند الناس، والعرف والعادة عند الناس: أن نفقة الغني والفقير تختلف.

١ الحاوي الكبير "١١/٤١٤-٤١٧".

٢ سورة الطلاق من آية ٧.

٣ سورة البقرة من آية ٢٣٣.

٣- ولأننا لو قلنا: إن نفقتها معتبرة بكفايتها.. لأدى ذلك إلى أن لا تنقطع الخصومة بينهما ولا يصل الحاكم إلى قدر كفايتها ١.

أنواع النفقة: أولاً: نفقة الطعام والشراب والأدم. ونفقة الطعام والأدم هي مما جرت به عادة كل بلد من الخبز والسمن أو الزيت والتمر والأرز واللبن واللحم ونحو ذلك معتبرة بحال الزوج، فإن كان الزوج موسراً، وهو: الذي يقدر على النفقة بماله أو كسبه.. وجب لها كل يوم مدان (والمد مائة وثلاثة وسبعون درهماً وثلاث درهماً)، وإن كان معسراً؛ وهو: الذي لا يقدر على النفقة بماله ولا كسبه.. وجب عليه كل يوم مد، وهو: رطل وثلاث؛ لأن أكثر ما أوجب الله تعالى في الكفارات للواحد مدان وهو في كفارة الأذى، وأقل ما أوجب الله تعالى للواحد في الكفارة مد.. فقسنا نفقة الزوجات على الكفارة؛ لأن الله تعالى شبه الكفارة بنفقة الأهل في الجنس بقوله: {من أوسط ما تطعمون أهليكم} ٢. فاعتبرنا الأكثر والأقل بالواجب للواحد في الكفارة. وأما المتوسط: فإنه يجب عليه كل يوم مد ونصف مد؛ لأنه أعلى حالا من المعسر، وأدنى حالا من الموسر، فوجب عليه من نفقة كل واحد منهما نصفها.

والواجب في جنس الطعام المذكور غالب قوت البلد أي بلدهما من حنطة أو شعير أو تمر أو غيرها حتى يجب الأقط واللحم في حق أهل البوادي الذين يعتادونه؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور بها، وقياساً على الفطرة والكفارة فالتعبير بالبلد جرى على الغالب ولو اختلفت قوت بلد الزوج والزوجة قال الماوردي: إن نزلت عليه في بلده اعتبر غالب قوت بلده، وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلدها ٣.

ثانياً: الكسوة: أجمع فقهاء الشافعية على أنه تجب الكسوة - بكسر الكاف وضمها - للزوجة على زوجها إذا مكنته من نفسها على الوجه الواجب عليها، استدلالاً بالآتي:

١ البيان "٢٠٤-٢٠٣/١١".

٢ سورة المائدة من آية ٨٩.

٣ البيان "٢٠٤/١١"، مغني المحتاج "١٥٣-١٥٢/٥".

١- لقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ١،

٢- ولما روى الترمذي «أن رسول الله - ﷺ - قال في حديث: وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن».

ولا بد أن تكون الكسوة تكفيها للإجماع على أنه لا يكفي ما ينطلق عليه الاسم، وتختلف كفايتها بطولها وقصرها وسمنها وهزالها، وباختلاف البلاد في الحر والبرد، ولا يختلف عدد الكسوة باختلاف يسار الزوج وإعساره.

يجب للزوجة على زوجها في كل ستة أشهر قميص، وهو ثوب مخيط يستر جميع البدن - وخياطته على الزوج - وسراويل - وهو ثوب مخيط يستر أسفل البدن ويصون العورة - وقد يقوم الإزار أو الفوطة مقام السراويل إذا اعتادت المرأة على لبسهما.

وخمار، وهو ما يغطي به الرأس، ومكعب، وهو مداس الرجل من نعل أو غيره، ويجب لها القبقاب إن اقتضاه العرف. قال الماوردي: ولو جرت عادة نساء أهل القرى أن لا يلبسن في أرجلهن شيئاً في داخل البيوت لم يجب لأرجلهن شيء. ويزاد في الشتاء وفي البلاد الباردة جبة محشوة قطناً، فإن اشتد البرد فجتان فأكثر بقدر الحاجة لدفع البرد، وقد يقوم الفرو مقام الجبة إذا جرت عادة أهل البلد على لبسها. وضابط الواجب في الكسوة: هو إن المرجع في عدد الكسوة وقدرها وجنسها إلى العرف والعادة؛ لأن الشرع ورد بإيجاب الكسوة غير مقدرة، وليس لها أصل ترد إليه، فرجع في عددها وقدرها إلى العرف والعادة ٢.

ثالثاً: آلات التنظيف وأدوات الزينة والطيب: ذهب فقهاء الشافعية إلى أنه يجب للزوجة على زوجها ما تحتاج إليه من المشط - وهو بضم الميم وكسرهما مع إسكان الشين وضمها، اسم لآلة المستعملة في ترجيل الشعر - والدهن لرأسها والسدر أو نحوه مما تغسل به رأسها وما يعود بنظافتها من آلات التنظيف ٣.

١ سورة البقرة من آية ٢٣٣.

٢ الحاوي الكبير "٤٢٩/١١"، البيان "٢٠٨/١١"، مغني المحتاج "١٥٧/٥".

٣ مغني المحتاج "١٥٨/٥".

رابعاً: المسكن: السكنى للزوجة على زوجها واجبة، وهذا الحكم متفق عليه بين فقهاء الشافعية؛ وذلك للآتي: ١- لأن الله تعالى جعل للمطلقة الرجعية السكنى على زوجها. قال تعالى: {أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ} فوجوب السكنى للتي هي في صلب النكاح أولى. ٢- ولأن الله تعالى أوجب المعاشرة بين الأزواج بالمعروف، قال تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ١، ومن المعروف المأمور به أن يسكنها في مسكن تأمن فيه على نفسها ومالها. ٣- كما أن الزوجة لا تستغني عن المسكن؛ للاستتار عن العيون والاستمتاع وحفظ المتاع. فلذلك كانت السكنى حقاً لها على زوجها ٢.

خامساً: نفقة خادم الزوجة: على الزوج إذا تزوج امرأة نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوماً، وذلك للآتي:

- ١- قول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ٣ والخدمة من المعود المعروف.
- ٢- ولقول النبي - ﷺ - خذي ما يكفيك وولديك بالمعروف. فكان الخادم من المعروف.
- ٣- ولأنه ملك منها الاستمتاع الكامل فلزمه لها الكفاية الكاملة، فأما إذا لم يكن مثلها مخدوماً لقياسها بخدمة نفسها لم تلزمه نفقة خادمها لأنه خارج من جملة المعروف المأمور به في حقها.

والاعتبار في العرف بذلك من وجهين:

أحدهما: عرف القدر والمنزلة. فإن عرف ذوي الأقدار بشرف أو يسار أن يخدمهم غيرهم فلا يخدموا أنفسهم. وعرف من انخفض قدره وانحطت رتبته أن يخدم نفسه ولا يخدم.

١ سورة النساء من آية ١٩.

٢ البيان "٢١٠/١١"، مغني المحتاج "١٦٠/٥".

٣ سورة النساء من آية ١٩.

والوجه الثاني: عرف البلاد فإن عادة أهل الأمصار أن يستخدموا ولا يخدموا، وعادة أهل السواد أن يخدموا ولا يستخدموا فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لأنها من ذوي الأقدار وسكان الأمصار لزمه نفقة خادمها

ولا يكون الخادم لها إلا امرأة، أو رجلاً من ذوي محارمها؛ أو مملوكاً لها، أو ممسوحاً، أو صبياً، لأنها تحتاج إلى نظر الخادم، وقد يخلو بها، فلم يجز أن يكون رجلاً أجنبياً ١.

١ الحاوي الكبير "٤١٨/١١-٤١٩"، البيان "٢١١/١١"، مغني المحتاج "١٦١/٥".

الوحدة الرابعة

أحكام الإيلاء عند الشافعية

أهداف الوحدة تتمثل فيما يلي:-

- ١- إلقاء الضوء على معنى الإيلاء، وحكمه، والأصل في شرعيته.
- ٢- بيان أركان الإيلاء كي يكون صحيحاً منتجاً لآثاره.
- ٣- إلقاء الضوء على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة به، ومدى مواكبتها لتطورات العصر الحديث.

تمهيد:-

كان الرجل في الجاهلية يحلف على ألا يمس امرأته مدة قد تصل إلى السنة والسنيتين قاصداً إلحاق الضرر بها حيث أصبحت والحالة هذه كالمعلقة فليست بزوجة لها كافة حقوق الزوجة ولا هي مطلقة حتى تحل لغيره من الأزواج، وهذه الصورة التي يحلف فيها الرجل عدم وطئه لزوجته تسمى إيلاء وكانت مدته غير محددة في الجاهلية، فلما جاء الإسلام وقته بمدة أربعة أشهر يتروى فيها الرجل إما أن يفئ وإما أن يعزم على الطلاق، وفيما يلي بيان أهم الأحكام التي تتعلق بالإيلاء:

الدرس الأول**تعريف الإيلاء وحكمه****أولاً: تعريف الإيلاء:**

الإيلاء لغة^(١): الإيلاء بالمد الحلف وهو الحلف بالله سبحانه وتعالى أو غيره من الطلاق أو العتاق أو الحج أو نحو ذلك، و هو مصدر، يقال آلى يولى إيلاء فهو مول إذا حلف فالإيلاء المصدر، وآلى آلية الاسم، ولا خير في مال عليه آلية ولا في يمين عقدت بالمآثم وجمع الآلية آلايا.

فالإيلاء في اللغة هي كل يمين حلف بها حالف على زوجة، أو غير زوجة في طاعة أو معصية.

وكان الإيلاء طلاقاً في الجاهلية فغير الشرع حكمه مع عدم استعماله أول الإسلام وخصه بالحلف على الامتناع من وطء الزوجة مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر.

الإيلاء شرعاً: حلف زوج على الامتناع من وطء زوجته مطلقاً أو أكثر من أربعة أشهر^(٢).

شرح التعريف^(١):

(١) المطلع ص ٣٤٣، أنيس الفقهاء ص ١٦١.

(٢) نهاية المحتاج ج ٧ ص ٦٨، حاشية الجمل ج ٤ ص ٣٩٤.

-حلف زوج: أي غير محبوب وغير مشلول، بخلاف ما لو طرأ الشلل أو الجب بعد الإيلاء، فلا يمنع من ترتب الأحكام وهو من إضافة المصدر لفاعله، ودخل في الزوج المسلم والكافر والحر والعبد، وقد اشتمل التعريف على جميع الأركان.

-من وطء زوجته: أي غير الرتقاء والقرناء، سواء كانت مسلمة أو كافرة، حرة أو أمة.

-مطلقاً: أي الامتناع من الوطء مطلقاً دون التحديد بمدة.

-أو أكثر من أربعة أشهر: لأن المرأة يعظم ضررها إذا زاد على ذلك، لأنها تصبر عن الزوج أربعة أشهر، وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل.

ثانياً: حكم الإيلاء:

الإيلاء حرام للإيذاء^(٢)، والأصل فيه قوله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)^(٣).

وجه الدلالة^(٤):

-قوله: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ) لا خلاف أنه قد أضمر فيه اليمين على ترك الجماع لاتفاق الجميع على أن الحالف على ترك جماعها مول فترك الجماع مضمّر في الآية عند الجميع فأثبتناه.

قوله (فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) الفاء في اللغة هو الرجوع إلى الشيء ومنه قوله تعالى: (حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ)^(٥) يعني حتى ترجع من البغي إلى العدل الذي هو أمر الله، ومعلوم عند الجميع أن المراد بالفاء هنا هو العودة إلى

(١) حاشية البجيرمي على الخطيب ج ٤ ص ٣.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٤٣.

(٣) سورة: البقرة - الآيات: ٢٢٦، ٢٢٧.

(٤) أحكام القرآن للجصاص ج ٢ ص ٤٥ - ٥٠.

(٥) سورة: الحجرات - الآية: ٩.

الجماع ولا خلاف بين السلف فيه فدل ذلك على أن المضمّر في قوله (لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ) هو الجماع دون غيره.

-قوله تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) ورد في عزيمة الطلاق عند عدم الفئّة ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: عزيمة الطلاق انقضاء الأربعة أشهر وتبين بتطبيقه وهو قول ابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت و عثمان بن عفان.

الوجه الثاني: أنه يوقف بعد مضي المدة فإذا أن يفيء إليها وإما أن يطلقها وهو قول عائشة وأبي الدرداء.

الوجه الثالث: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة رجعية، وهو قول سعيد بن المسيب والزهري وعطاء.

الدرس الثاني

أركان الإيلاء

أركان الإيلاء أربعة، وهي حالف، ومحلوف به، ومدة، ومحلوف عليه.

الركن الأول: الحالف^(١):

الركن الأول من أركان الإيلاء الحالف، ويشترط فيه عدة شروط:

الشرط الأول: كون الحالف زوجًا:

لا ينعقد الإيلاء إلا من الزوج لأن الإيلاء مختص بالنكاح فلا ينعقد بخطاب الأجنبية كالطلاق قال تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤَلِّونَ مِن نِّسَائِهِمْ)^(٢) وليست الأجنبية كالزوجة ؛ لأنه لا يتحقق فيها قصد الإيذاء . فإذا قال رجل لامرأة أجنبية والله لا أطؤك لا ينعقد الإيلاء حتى لو نكحها بعد ذلك، ولا تضرب له المدة وهو الصحيح ويكون حلفه يمينًا فلو وطئها قبل النكاح بزنا أو بشبهة أو وطئها بعد النكاح لزمه كفارة يمين.

وقيل: إذا نكح هذه الأجنبية بعد الحلف عليها صار موليًا لأن اليمين باقية والضرر حاصل.

-الإيلاء من المطلقة:

أ-المطلقة طلاقًا رجعيًا: إذا حلف الرجل على امرأة طلقها طلاقًا رجعيًا أثناء العدة انعقد الإيلاء في عدتها لأن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث ووجوب النفقة ووقوع الطلاق والظهار فكذا الإيلاء، وإذا انعقد إيلاؤه فإن لم يراجعها في العدة سقط حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليه، وإذا راجعها في العدة استقر الإيلاء بالرجعة، وتضرب المدة من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء.

(١) روضة الطالبين ج ٨ ص ٢٢٩ - ٢٣٠، المهذب ج ٢ ص ١٠٥.

(٢) سورة: البقرة- الآية: ٢٢٦.

ب- المطلقة طلاقاً بائناً:

إذا آلى الرجل من امرأة طلقها طلاقاً بائناً فلا ينعقد الإيلاء منها لقوله تعالى: (لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)^(١) وليست المطلقة طلاقاً بائناً من نسائه، وإنما هي كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك بعقد لم يصير مولياً.

ويصح الإيلاء من الزوج العجمي المتزوج بامرأة عربية ومن الزوج العربي المتزوج بعجمية إن عُرف المعنى.

الشرط الثاني: تصور الجماع:

يشترط في الزوج الذي يولى من زوجته تصور الوطء منه أما العاجز عن الوطء فإن كان العجز لعارض مرجو زواله كالمرض والحبس صح إيلاؤه لأنه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه، وإن كان العجز لسبب غير مرجو الزوال كالجب والشلل فلا يصح إيلاؤه لأنها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهباً، ولأن الإيلاء يمين مانعة من الوطء وهذا لا يمنعه يمينه فانه متعذر منه ولا تضر المرأة يمينه.

ويصح إيلاء الخصي ومن بقى من ذكره قدر الحشفة لأنهما قادران على الجماع.

وإذا آلى الرجل من زوجته وهو صحيح ثم جب ذكره لا يبطل إيلاؤه على المذهب.

وإذا آلى الرجل من زوجته الرتقاء أو القرناء لا ينعقد الإيلاء على المذهب لعدم تحقق قصد الإيذاء، وقيل يصح الإيلاء من الزوجة القرناء والرتقاء لكن لا تضرب مدة الإيلاء لأن الامتناع تسبب من جهتها.

ويصح إيلاء الزوج من الزوجة الصغيرة التي يمكن جماعها ولا تضرب المدة حتى تدرك الصغيرة إطاقة الجماع.

(١) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٦.

وإذا حلف الزوج على الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو النفاس لم يكن مولياً بل هو محسن لا تتضرر بذلك ولا تطمع في الوطء فيما ذكر ولأنه ممنوع من الوطء في هذه الحالات فأكد الممنوع منه بالحلف.

فإذا قال والله لا أجامعك إلا في الدبر أنعقد الإيلاء وتضرب له المدة، ويجب عليها ألا تتمكن من الوطء في الدبر.

وإذا قال والله لا أجامعك إلا في الحيض أو في النفاس أو في نهار رمضان، فيه وجهان: الوجه الأول: ينعقد الإيلاء وهو الأرجح لأن الوطء حرام في هذه الأحوال فهو ممنوع من وطئها ويجب عليها الامتناع وتضرب المدة ثم تطالب الزوجة بعدها بالفيئة أو الطلاق فإن فاء إليها في هذه الأحوال سقطت المطالبة في الحال لزوال المضارة به.

الوجه الثاني: لا يكون مولياً لأنه لو جامع في الحيض أو النفاس أو في نهار رمضان حصلت الفيئة، مع حصول الإثم.

ولو كان الزوج بالمشرك والزوجة بالمغرب فحلف أن لا يطؤها انعقد الإيلاء لاحتمال الوصول على غير العادة ولا تضرب المدة إلا بعد اجتماعهما.

الشرط الثالث: البلوغ والعقل:

يشترط في الزوج أن يكون بالغاً عاقلاً أما الصبي والمجنون فلا يصح إيلاؤهما، لأن القلم مرفوع عنهما بنص الحديث الذي قال فيه الرسول: رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق، ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر.

-الإسلام والحرية ليسا بشرط: وليست الحرية ولا الإسلام شرطاً في الزوج لانعقاد الإيلاء حيث يستوي الحر والعبد، والمسلم والكافر في انعقاد الإيلاء من كل منهم سواء لعموم قوله تعالى: (الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نَسَائِهِمْ)^(١)، ولا ينحل الإيلاء بإسلام الكافر.

(١) سورة: البقرة- الآية: ٢٢٦.

والإيلاء من كل زوجة حرة أو أمة، مسلمة أو ذمية سواء لعموم قوله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ) فالآية بعمومها لم تفرق بين الزوجة الحرة والأمة والزوجة المسلمة والذمية، ولأنهن في أحكام الزوجية سواء، فوجب أن يكن في الإيلاء سواء.

-الإيلاء أثناء الردة: وإذا ارتد الزوجان أو أحدهما فحلف الزوج ألا يجامع زوجته انعقد الإيلاء، فإن جمعهما الإسلام في العدة وكان قد بقي من المدة التي حلف ألا يجامع فيها أكثر من أربعة أشهر فهو مول، فإن لم يجمعهما الإسلام في العدة أو جمعهما الإسلام وكان قد بقي من المدة التي حلف ألا يجامع فيها أقل من أربعة أشهر لم يكن الزوج مولياً.

-الإيلاء أثناء الغضب: وإذا حلف الزوج ألا يجامع زوجته أكثر من أربعة أشهر انعقد الإيلاء ولو كان الحلف أثناء الغضب، فالإيلاء في الغضب والرضا سواء، لعموم قوله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)^(١) حيث لم تفرق الآية بين حال الرضا وحال الغضب، ولأنها يمين بالله تعالى فاستوي فيها حال الغضب والرضا كسائر الأيمان.

الركن الثاني: المحلوف به^(٢):

من شروط الإيلاء التي لا ينعقد إلا بها أن يحلف الزوج بالله تعالى، أو باسم من أسمائه، أو بصفة من صفاته، فإذا حلف بالله أو باسمه أو بصفته انعقد الإيلاء لما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت^(٣).

والسر في النهي عن الحلف بغير الله أن الحلف بالشئ يقتضي تعظيمه والعظمة في الحقيقة إنما هي لله وحده وظاهر الحديث تخصيص الحلف بالله خاصة لكن قد اتفق الفقهاء على أن الحلف بالله وذاته وصفاته العلية^(١).

(١) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٦.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٤٤، التكملة الثانية للمجموع ج ١٧ ص ٢٩١.

(٣) صحيح البخاري - كتاب الشهادات - باب كيف يستحلف.

وإذا امتنع الزوج من وطء زوجته بلا يمين لا يثبت حكم الإيلاء وسواء كان هناك عذر أم لا.

وإذا حلف أن لا يجمع زوجته بيمين لا يجب عليه بالحنث فيها شيء كاليمين بالمخلوقات كالأنبياء، والملائكة والسماء والعرش لم يكن موليًا، لأنه خارج عن حكم الأيمان فخرج عن حكم الإيلاء.

وإذا حلف بيمين يجب عليه بالحنث فيها شيء كالحلف بالعتق، أو الطلاق، أو الصدقة، أو الصيام كأن قال: إن وطئتُك فعبدني حر أو أنت طالق، أو مالي صدقة أو على الحج إلى بيت الله، أو صيام يوم أو صلاة ركعتين، أو اعتكاف شهر، فإذا حنث لزمه العتق والصدقة والصوم والطلاق والحج والاعتكاف بالوطء، أما عن انعقاد الإيلاء ففيه قولان:

القول الأول: أنه يكون موليًا سواء كانت يمينه بالعتق أو بالطلاق أو كانت بالصلاة والصيام، وهذا هو قول الشافعي في مذهبه الجديد، ويدل على ذلك قوله تعالى: (لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ)، فلفظ الآية عام في كل حالف دون التقيد بصفة في الحلف، ولأن ذلك يسمى حلفًا، فتأولته الآية لأن الإيلاء هو الحلف ويشمل الحلف بالله تعالى و غيره وفي الحديث الذي رواه ابن عمر أن الرسول قال: (لا تحلفوا بآبائكم)^(١).

القول الثاني: وهو قول الشافعي في القديم لا يكون موليًا ما لم يحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته تعالى لقوله سبحانه: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ)^(٢) ثم قال تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ)^(٤) ثم قال (لَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نَّسَائِهِمْ)^(٥) فعطف الإيلاء على

(١) فتح الباري ج ١١ ص ٥٣١.

(٢) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى.

(٣) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٤.

(٤) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٥.

(٥) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٦.

اليمين بالله فاقتضى أن لا يكون موليًا إلا بالله، ولأن مطلق الأيمان محمولة في الشرع على اليمين بالله لقول الرسول ﷺ: من كان حالًا فليحلف بالله أو ليصمت.

– الألفاظ المستعملة في الإيلاء:

تنقسم الألفاظ المستعملة في الإيلاء إلى أقسام، وهي^(١):

القسم الأول: اللفظ الصريح: إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ صريح في الإيلاء كقوله لا أدخل ذكري في فرجك أو لا أغيبه فيه انعقد الإيلاء سواء قصد الإيلاء أو لم يقصد.

وإذا قال لزوجته والله لا وطئتك ولا جامعتك انعقد الإيلاء إذا أراد به الإيلاء أو أطلق، ولا ينعقد به إذا لم يرد الإيلاء لاحتمال أن يريد لا أطوك بقدمي ولا أجامعك أي لا اجتمع معك.

القسم الثاني: اللفظ الكناية: إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ من ألفاظ الكناية كقوله والله لأسوأئك والله لا قربتك أو والله لا أجمع رأسي برأسك أو لا ضمنا بيت أو لا ضاجعتك أو لتطولن غيبتني عنك إلى ما جرى هذا المجرى من الألفاظ المحتملة للوطء وغيره فلا ينعقد الإيلاء بهذه الألفاظ إلا مع النية والإرادة، فإن أراد بها الإيلاء انعقد الإيلاء، أما إذا أطلق أو لم يرد الإيلاء لم ينعقد بها لأنها كناية والكناية تتوقف على النية والإرادة.

القسم الثالث: ما لم يكن صريحًا ولا كناية: إذا حلف الرجل على زوجته بلفظ ليس بصريح ولا كناية كقوله لا أوحشتك أو لا أحزنتك أو لا كسوتك أو لا أطعمتك أو لا أشربتك أو لا ضربتك فهذا وما شاكله لا ينعقد به الإيلاء وإن أراد به الإيلاء.

تعليق الإيلاء:

والإيلاء يقبل التعليق كالطلاق فإن حلف لا أجامعك إن دخلت الدار فدخلت صار موليًا أو حلف لا أجامعك إن شئت وأراد إن شئت الجماع أو الإيلاء فشاءت صار موليًا كنظيره في الطلاق.

(١) الحاوي ج ١٠ ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

تعليق الطلاق على الفئنة^(١):

إذا علق الزوج الطلاق على الفئنة من الإيلاء بأن قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثاً انعقد الإيلاء لما يلزمه من طلاقها بالوطء، وتحسب للزوج مدة الإيلاء أربعة أشهر ويطالب بعدها بالفئنة أو الطلاق.

فإن طلق بعد انعقاد الإيلاء فطلاقه فيه كطلاقه في غيره، وإن فاء بالوطء فبالقدر الذي يباح له منه وهو أن يولج الحشفة حتى يلتقي بها الختانان، وتكون الزوجة بعد تغييب الحشفة طالق ثلاثاً، فحرم عليه أن يولج باقي ذكره وأن يمكث بعد تغييب الحشفة فيكون تحريم إيلاج الباقي من الذكر كتحريم المكث فيصيران معا محرمين.

وإذا علق طلاق الضرة على الفئنة بأن قال لإحدى زوجتيه إن وطئتك فضرتك طالق فوطئها في مدة الأربعة أشهر أو بعدها طلقت الضرة لوجود الوصف وانحل الإيلاء ؛ لأنه لا يترتب عليه شيء بوطئها بعد ذلك.

تعليق الإيلاء على المشيئة^(٢):

إذا علق الزوج الإيلاء على مشيئة الزوجة بأن قال لها والله لا أقربك إن شئت فشئت ألا يقربها انعقد الإيلاء، وإن لم تشأ لم ينعقد، وهل يشترط أن تكون مشيئتها على الفور، فيه وجهان:

الوجه الأول: يجب أن تكون المشيئة على الفور، فعلى هذا يحتاج أن تكون مشيئتها جواباً في الحال كالقبول في العقود وإن تمادى زماناً وإن قل أو تخللها كلام بطلت مشيئتها فلم يتعلق بها حكم.

الوجه الثاني: يراعى فيها المجلس، فإن شئت قبل الافتراق صحت مشيئتها وثبت حكمها، وإن شئت بعد الافتراق فلا حكم لمشيئتها.

(١) أسنى المطالب ج ٣ ص ٣٤٨.

(٢) المرجع السابق ج ٣ ص ٣٥٢، روضة الطالبين ج ٨ ص ٢٤٤.

وإذا علق الزوج الإيلاء من زوجته على مشيئة الأجنبية بأن قال لها والله لا أقربك إن شاء زيد، انعقد الإيلاء إذا قال زيد، قد شئت وإن قال لست أشأ لم ينعقد، ولا يعتبر الفور في التعليق على مشيئة الأجنبية بخلاف التعليق على مشيئة الزوجة لأنه إذا علق الإيلاء على مشيئتها كان فيه تملك فروعي فيه الفور، وإذا علق الإيلاء على مشيئة غيرها لم يكن تملك فلم يراعى فيه الفور، وإن مات ولم تعلم مشيئته لم ينعقد الإيلاء لأن الأصل أن لا مشيئة.

-تعليق الإيلاء على شرط يستحيل وجوده:

وإذا علق الإيلاء على شرط يستحيل وجوده بأن يقول والله لا وطنتك حتى تصعدي إلى السماء أو تصافحي الثريا فهو مول لأن معناه لا وطنتك أبداً.

الركن الثالث: المدة^(١):

ومدة الإيلاء تقدر بأربعة أشهر، ولا ينعقد الإيلاء في أقل منها، وينعقد إذا كانت المدة أكثر من الأربعة أشهر، فإذا حلف الرجل ألا يوطأ امرأته مدة تزيد على أربعة أشهر كان مولياً، وإن حلف على أربعة أشهر لم يكن مولياً لأنها لا تستحق مطالبتة بالفئة أو الطلاق إلا بعد مضي أربعة أشهر، فإذا مضت قبل أن يفيء استحققت المطالبة.

ويستوي في هذه المدة الحر والعبد، حرة كانت الزوجة أو أمة لأن المدة شرعت لأمر جبلي وهو قلة الصبر عن الزوج وما يتعلق بالجبلة والطبع لا يختلف بالحرية والرق.

ويدل على أن المدة مقدرة بأربعة أشهر، ما يلي:

١- قوله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلَوْنَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ)^(٢).

إن الأربعة أشهر هي المدة التي ضربها الله تعالى، فتعينت بنص القرآن دون غيرها.

(١) روضة الطالبين ج ٨ ص ٢٤٦، الحاوي ج ١٠ ص ٣٣٩.

(٢) سورة: البقرة- الآية: ٢٢٦.

٢- أكثر مدة تصبر فيها النساء عن الرجال هي الأربعة أشهر، فقد روى أن عمر بن الخطاب انه كان يطوف ليلة بالمدينة فسمع امرأة تتشد ألا طال هذا الليل واسود جانبه وأرقني أن لا حبيب ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لزعرع من هذا السرير جوانبه مخافة ربي والحياء يكفني وإكرام بعلي أن تتال مراكبه فلما كان من الغد أستدعى عمر بتلك المرأة وقال لها أين زوجك فقالت بعثت به إلى العراق فاستدعى نساء فسألهن عن المرأة كم مقدار ما تصبر عن زوجها فقلن شهرين ويقل صبرها في ثلاثة أشهر وينفذ صبرها في أربعة أشهر فجعل عمر مدة غزو الرجل أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر استرد الغازين ووجه بقوم آخرين وهذا^(١).

وخالف الحسن البصري في تحديد هذه المدة فقال إذا حلف الرجل على الامتناع من وطء زوجته في أي زمان كان قل الزمن أو كثر كان مولياً.

وقال بن عباس لا يكون الرجل مولياً من زوجته حتى يحلف ألا يمسه أبداً فإن قدر ذلك بزمان وإن طال لم يكن مولياً لأنه إذا قدره بزمان قدر على الخلاص بمضي الزمان من غير ضرر فلم يصير مولياً كما لو حلف على الامتناع من وطئها في مكان دون مكان.

- وإذا حلف الرجل على زوجته ألا يجامعها أربعة أشهر ثم أعاد اليمين بعد مضي تلك المدة وهكذا مرات لا يكون مولياً لأن اليمين في كل منها اقتصرت على الأربعة أشهر دون زيادة والإيلاء ما كان فوق الأربعة أشهر، ولو وصل اليمين فقال والله لا أجامعك أربعة أشهر فإذا مضت الأربعة أشهر فوالله لا أجامعك أربعة أشهر أخرى وهكذا مراراً فليس بمؤل على الأصح.

- وإذا قال: والله لا أجامعك عاماً ثم كرر اليمين فقال: والله لا أجامعك عاماً فهو إيلاء واحد حلف عليه يمينين، إلا أن ينوى باليمين الثاني عاماً آخر سواه، وإن قال: والله لا أجامعك عام ثم قال: والله لا أجامعك نصف عام دخلت المدة القصيرة في الطويلة لأنها بعضها، ولم يجعل إحداها بعد الأخرى، فأشبهه ما لو أقر بدينار ثم أقر بنصف دينار فيكون

(١) تفسير القرطبي ج ٣ ص ١٠٨.

إيلاءًا واحدًا لهما وقت واحد وكفارة واحدة، هذا إذا لم ينو باليمين الثانية مدة أخرى، فإن في الصورتين باليمين الثانية مرة أخرى فيهما إيلاءان في زمانين لا يدخل حكم أحدهما في الآخر.

- وإذا قال لزوجته، والله لا أجامعك حتى أموت أو تموتي انعقد الإيلاء لأن الظاهر بقاؤهما، وأن قال والله لا أجامعك، حتى يموت فلان انعقد الإيلاء لأن الظاهر بقاؤه.

- وإذا قال والله لا أجامعك في هذا البيت لم يكن موليًا لأنه يمكنه أن يطأها في مكان آخر من غير حنث، و لأنه لا ضرر عليها في ترك الوطء في بيت بعينه.

الركن الرابع: المحلوف عليه:

المحلوف عليه في الإيلاء هو ترك الجماع لا غير، فإذا حلف الزوج بالامتناع عن سائر الاستمتاع غير الجماع فليس بمولى.

ولفظ الجماع الدال عليه قسمان^(١): صريح و كناية فمن صريحه الإيلاج والوطء و الجماع والإصابة وافتضاض البكر وهي إزالة بكارتها كقوله (والله لا أولى ذكري أو حشفتي في فرجك أو لا أطؤك أو لا أجامعك أو لا أصبتك أو لا أفتضك)، ومن الكنايات - ما يفترق إلى النية لانعقاد الإيلاء - كقوله والله لأسوأئك والله لا قربتك أو والله لا أجمع رأسي برأسك أو لا ضمناً بيت أو لا ضاجعتك أو لتطولن غيبتني عنك فلا ينعقد الإيلاء بهذه الألفاظ إلا مع النية لأن لها معاني غير الوطء ولم تشتهر في الوطء اشتها الألفاظ السابقة فيه، فإن نوى بها الإيلاء انعقد وإن لم ينو لم ينعقد.

وإذا قال والله لا أجامع فرجك أو لا أجامع نصفك الأسفل كان موليًا بخلاف باقي الأعضاء كقوله لا أجامع يدك أو رجلك أو نصفك الأعلى أو بعضك أو نصفك لم يكن موليًا.

الدرس الثالث

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٤٥ - ٣٤٦.

آثار الإيلاء

للإيلاء آثار تترتب عليه، وفيما يلي أهم هذه الآثار:

أولاً: عدم جواز المطالبة قبل انتهاء الأربعة أشهر^(١):

إذا انعقد الإيلاء فلا يجوز للزوجة مطالبة الزوج بالفيئة وهي الجماع أو الطلاق قبل مضي الأربعة أشهر، ويدل على ذلك ما يلي:

١- قوله تعالى: (لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ*وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)^(٢).

فإن الله تعالى شرع التربص هذه المدة فلا يجوز مطالبة الزوج قبلها، واختياره للفيئة بالجماع قبلها إبطال لحقه من جهة نفسه، فلا يبطل بإبطال غيره، كما أن الله تعالى قد ذكر الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب بقوله (فَإِنْ فَاءُوا) فوجب أن تستحق المطالبة بعد المدة.

٢- روى عن سليمان بن يسار أنه قال: أدركت بضعة عشر رجلاً من الصحابة كلهم يوقف المولي يعني بعد أربعة أشهر.

٣- وروى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أنه قال: سألت اثني عشر رجلاً من أصحاب رسول الله ﷺ عن المولي فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر.

وقال الحنفية^(٣): للزوجة مطالبة زوجها بالفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر، وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها بالجماع طلقت طلقت تطليقة بئنة.

وتحسب مدة التربص وهي الأربعة أشهر من وقت الإيلاء، لا من وقت المحاكمة لأن الإيلاء يقين فكان أول مدته من وقت وجوده.

(١) الحاوي ج ١٠ ص ٣٤٠.

(٢) سورة: البقرة - الآيات: ٢٢٦، ٢٢٧.

(٣) المبسوط للسرخسي ج ٧ ص ٢٠.

ثانيًا: المطالبة بالفيئة أو الطلاق:

فإذا انقضت مدة التبرص بمضي أربعة أشهر استحققت الزوجة مطالبة الزوج بالفيئة أو الطلاق، ولا يعترض عليها في المطالبة لأنه حق لها من حقوقها المحضة فوقف على خيارها.

فإذا انقضت مدة التبرص كان للزوجة الخيار بين مطالبته بالفيئة أو الطلاق وبين ترك المطالبة فإن طالبت كان الزوج مخيرًا بين الفينة أو الطلاق كما قال تعالى: (الَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ *وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)، فأيهما فعل لم يكن للزوجة مطالبته بالآخر فإن طلق فلم يكن لها مطالبته بالفيئة، وإن فاء لم يكن لها مطالبته بالطلاق.

وإذا خير الزوج بين الفينة أو الطلاق بعد مضي مدة التبرص وهي الأربعة أشهر فامتنع أن يفيء أو يطلق لم يجبر على الفينة لأن الفينة بالجماع وهو مما لا يعلمه سواه

كيفية الفية:

الفيهة من الإيلاء هي الجماع لأن معنى الفية في اللغة الرجوع إلى ما فارق، والزوج بالإيلاء ممتنع من الجماع فكانت فيئته بالرجوع إليه، فإن كان قادرًا على الجماع لم تتحقق فيئته إلا بجماع زوجته.

وإن كان الزوج عاجزًا عن الجماع لعذر كمرض أو غيره لزمه أن يفيء بلسانه لعذره وهو أن يقول لست أقدر على الوطء ولو قدرت عليه لفعلته، فإذا قال ذلك سقط حقها في المطالبة، فإذا زال العذر سقط حكم الفية باللسان ولزمه أن يفيء بالجماع لأن الوطء حق ثبت لها مع القدرة فلم يسقط بالعجز حكم القدرة كسائر الحقوق.

وإذا سأل الزوج الإنظار بالفيهة لعجزه عنها بالمرض فإنه يؤمر أن يفيء بلسانه فيء معذور كما سبق ويجاب إلى الإنظار، فإذا سأل الإنظار بالفيهة بغير مرض أجيب إلى الإنظار يوم أو ليلة وقيل يُنظر إلى ثلاثة أيام لقوله تعالى: (وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ

قَرِيبٌ *فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعَدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ^(١) فقد بينت الآية أن الإمهال إلى ثلاثة أيام، ولأن الثلاثة حد بين القلة والكثرة فهي حد لأكثر القليل وأقل الكثير، فلما نظر بالقليل جاز أن ينتهي إلى غاية حده.

ثالثاً: وجوب الكفارة بالفيئة:

وإذا حلف ألا يجامع زوجته مدة أقل من أربعة أشهر فليس بمول وإذا جامع في هذه المدة فقد وجبت عليه كفارة يمين.

وإذا حلف بالله أو بصفة من صفاته على ألا يجامع زوجته مدة أكثر من أربعة أشهر انعقد للإيلاء، فإن فاء بالوطء قبل انقضاء الأربعة أشهر ففي وجوب كفارة اليمين على الزوج قولان:

القول الأول: وهو المذهب القديم: لا كفارة عليه بالوطء في المدة لأن الله تعالى جعل للإيلاء حكماً: الفية أو الطلاق، فلم يجز أن يضم إليهما ثالث هو الكفارة لما في إيجابها من زيادة حكم على النص.

القول الثاني: وهو المذهب الجديد: تجب على الزوج كفارة يمين بالوطء في المدة، وهو الصحيح لما يلي:

١- قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ)^(٢)، فكانت الآية عامة في كل يمين، في الإيلاء وغيره.

(١) سورة: هود - الآيات ٦٤ - ٦٥.

(٢) سورة: المائدة - الآية: ٨٩.

٢- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه^(١).

وفئة المولى في الأربعة أشهر خير منها بعدها وذلك لا يمنع من وجوب التكفير.

ويجري القولان السابقان في حكم وجوب الكفارة في الفئة بالوطء بعد المدة أيضاً.

رابعاً: الامتناع عن الفئة والتطليق:

إذا انقضت مدة التبرص ولم يرض الزوج بالفئة استحققت الزوجة الطلاق، فإذا امتنع الزوج من التطليق، فهل يجوز للحاكم أو للقاضي أن يوقع عليه الطلاق بناء على أن الطلاق يصح فيه النيابة، ويقوم غيره مقامه فيه أم لا يجوز للحاكم ذلك؟ فيه قولان:

القول الأول: وهو قول الشافعي في القديم: ليس للحاكم أن يطلق على المولى زوجته بغير رضاه وإنما يحبسه حتى يفيء أو يطلق، ويدل على أنه ليس للحاكم أن يطلق عليه زوجته ما يلي:

١- قوله تعالى: (وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ)^(٢) فقد أضاف الله تعالى العزم على الطلاق إلى الزوج فافتضى أن لا يصح من غيره.

٢- عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ، قال: الطلاق لمن أخذ بالساق فجعل الطلاق إلى الأزواج دون غيرهم.

القول الثاني: وهو قول الشافعي في الجديد: يجوز للحاكم أن يطلق على الزوج زوجته إذا انقضت المدة ورفض الفئة ثم طوّل بالطلاق فرفضه، لأن ما دخلته النيابة كالطلاق إذا تعين مستحقه وهي الزوجة، وامتنع من عليه الحق وهو الزوج من الإيفاء كان للحاكم الاستيفاء كالديون.

وحتى يجوز للحاكم أن يطلق على المولى زوجته يشترط ثلاثة شروط:

(١) صحيح مسلم - كتاب الإيمان - باب ندب من حلف يميناً فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه.

(٢) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٧.

١- أن يمتنع الزوج من الفیئة والتطليق، فإن فاء إلى زوجته بالجماع أو كان غير ممتنع من التطليق لم يجز للحاكم أن يطلق عليه زوجته.

٢- أن يقتصر الحاكم في طلاقه على العدد المستحق وهو طلقة واحدة، فإن طلق أكثر منها وقعت الواحدة ولم يقع الزيادة عليها.

٣- أن يوقع الطلاق بعد انقضاء المدة، فإن طلق قبل انقضاء الأربعة أشهر لم يقع طلاقه.

خامساً: الواجب طلقة واحدة رجعية:

وإذا كان الزوج هو المطلق لزوجته كان مخيراً في عدد الطلاق وأقله واحدة يملك فيها الرجعة فإن طلق اثنتين كان له الرجعة بعدها، وإن طلق ثلاثاً بانتهى وطلاقه واقع في أي زمان أوقعه قبل المدة وبعدها.

وإذا طُلق على المولى زوجته طلقها الحاكم طلقة واحدة لا يتجاوزها، لأن الله تعالى أطلق عزيمة الطلاق فاقترض ما ينطلق عليه اسم الطلاق، وهو ينطلق على الواحدة، فلم يلزم الزيادة عليها.

وتكون هذه الطلقة رجعية، فإذا طلق الزوج طلقة واحدة أو طلق عليه الحاكم واحدة كان له الحق في مراجعة هذه المرأة في عدتها، لقوله تعالى: (وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا)^(١)، فهذه الآية عامة في مشروعية الرجعة ما لم يستوف المطلق عدد الطلقات.

فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فقد بانتهى منه، فإن عقد عليها بعد انتهاء العدة لا يعود الإيلاء وإن كانت اليمين باقية لأنه لا يكون مولياً قبل النكاح.

(١) سورة: البقرة - الآية: ٢٢٨.

الدرس الرابع

الاختلاف في الإيلاء

الاختلاف في أصل الإيلاء:

إذا اختلف الزوج والزوجة في أصل الإيلاء بأن ادعت الزوجة أنه قد حلف عليها وأنكر الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه لأن الأصل عدم الإيلاء.

الاختلاف في وقت صدور اليمين:

وإذا اختلف الزوج والزوجة في الوقت الذي صدر فيه اليمين من الزوج، فقال الزوج: حلفت في غرة رمضان، وقالت الزوجة: بل حلفت في غرة شعبان فالقول قول الزوج أيضاً مع يمينه لأن اليمين قد صدر من جهته، وهو أعلم به فكان القول قوله فيه، كما أو اختلفا في أصل الإيلاء.

الاختلاف في انقضاء المدة:

إذا اختلف الزوج والزوجة في انقضاء المدة المضروبة وهي الأربعة أشهر فادعت المرأة انقضاءها وأنكر الزوج فالقول قول الزوج في بقاء المدة ولا مطالبة عليه لأن الأصل أنها لم تنقض، كما أن الأصل، ثبوت النكاح، والزوجة تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة.

الاختلاف في الإصابة:

ولو رفعت الزوجة أمرها للحاكم بعد مضي الأربعة أشهر، وادعى الزوج إصابتها ليسقط مطالبتها وأنكرت الزوجة أن يكون أصابها وادعت أنها على حقها من المطالبة، فإن كانت ثيباً كان القول قول الزوج مع يمينه، لأن الأصل بقاء النكاح والمرأة تدعي عدم الإصابة الملزمة لرفع النكاح والزوج يدعي ما يوافق الأصل ويبقيه فكان القول قوله، ولأن الوطء يستتر به ولا يمكن إقامة البينة عليه فقبل فيه قول مدعيه كالحيض والظهر.

وإن كانت المرأة بكرًا واختلفا في الإصابة فالقول قول الزوجة مع يمينها أنه لم يصبها لأن البكارة من شواهد صدقها في عدم الإصابة فصار قولها أقوى من قول الزوج.

ولو اختلفا في البكارة فادعت الزوجة أنها ما زالت بكرًا وبالتالي يكون القول قولها في عدم الإصابة، وأنكر الزوج بكارتها ليكون قوله مقبولاً في وجود الإصابة لم يرجع إلى قول أحدهما، وإنما يجب على الزوجة أن تمكن نفسها لعدد من النساء الثقات ينظرن إليها فإن شهدن بثيوبتها فالحق قول الزوج لأن الظاهر معه، وإن شهدن بكارتها فالحق قول الزوجة لأنه لو وطئها زالت بكارتها.

وإذا اعترفت الزوجة بالوطء بعد انتهاء الأربعة أشهر وأنكره الزوج سقط حقها من الطلب عملاً باعترافها ولم يقبل رجوعها عنه لاعترافها بوصول حقها إليها.

أسئلة على الوحدة:-

- س ١: ما المراد بالإيلاء، وما حكمه، مع بيان الدليل على ما تقول ؟
- س ٢: بين أركان الإيلاء مع ذكر الألفاظ المستعملة فيه، وهل يقبل التعليق أو لا ؟
- س ٣: ما هي الآثار المترتبة على الإيلاء في الفقه الإسلامي ؟

الوحدة الخامسة

أحكام الظهار في الفقه الشافعي

أهداف الوحدة تتمثل فيما يلي:-

- ١- إلقاء الضوء على معنى الظهار، وحكمه، والأصل في شرعيته.
- ٢- بيان أركان الظهار كي يكون منتجاً لآثاره المترتبة عليه.
- ٣- إلقاء الضوء على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالظهار، ومدى تمشيها مع تطورات العصر الحديث.

الدرس الأول

تعريف الظهار لغة واصطلاحاً

١-تعريف الظهار في لغة العرب:

الظهار والتظهار والتظاهر: عبارة عن قول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، مشتق من الظهر، وخصوا الظهر دون غيره، لأنه موضع الركوب، والمرأة مركوبه إذا غشيت فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي، أراد: ركوبك للنكاح حرام علي، كركوب أمي للنكاح، فأقام الظهر مقام الركوب، لأنه مركوب، وأقام الركوب مقام النكاح، لأن الناكح راكب وهذا من استعارات العرب في كلامها^(١).

٢-تعريف الظهار في اصطلاح فقهاء الشافعية:

أ-عرف الإمام الشيرازي الظهار بأنه: تشبيه الزوجة غير البائن بأنثى لم تكن حلاً^(٢).

ب-وعرفه بمثل هذا التعريف صاحب المحلي على المنهاج^(٣)، وغالب شراح المنهاج^(٤).

وإذا كان الأمر كذلك فإننا نأخذ من هذا التعريف -وهو تعريف الشيرازي - ونضيف عليه حتى نصل من وجهة نظرنا إلى التعريف الجامع المانع، وبعد النظر والتأمل في القيود والضوابط الخاصة بأحكام الظهار، ننتهي إلى أن حقيقة الظهار الشرعية تتمثل في الآتي:

تشبيه الزوج المكلف زوجته في الحرمة بمحرمة عليه على التأييد:

شرح التعريف:

(١) الصحاح - الجوهري ج ٢ ص ٧٣٠، المصباح المنير ج ٢ ص ٥٩٠، تاج العروس ج ٣ ص ٣٧٣، مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٤٨، حاشية البيجرمي على الخطيب ج ٤ ص ١١.

(٢) المهذب - الشيرازي ج ٢ ص ١٤٣.

(٣) شرح الجلال المحلي على المنهاج ج ٤ ص ١٤.

(٤) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٤٨، حاشية البيجرمي على الخطيب ج ٤ ص ١٢، حاشية البيجوري على ابن قاسم ج ٢ ص ٥٨.

فقوله في التعريف «تشبيهه» جنس في التعريف يشمل أى تشبيه، سواء من الزوج للزوجة أو من الزوج لغير زوجته، أو من غير الزوج لزوجة الغير، وهكذا.

وقوله في التعريف: «تشبيه الزوج» قيد في التعريف يخرج تشبيه غير الزوج فلا يعد الأجنبي مظاهراً من زوجة الغير؛ لأنه لا رابطة بينهما.

وقوله في التعريف: «المكلف» قيد يخرج به ظاهر الصبي والمجنون لأن عبارة الصبي والمجنون لغو فلا تعتبر ولا ترتب عليها آثار شرعية.

وقوله في التعريف: «زوجته» أي التي تكون في امرته بعقد النكاح حتى ولو كانت مطلقة طلاقاً رجعيّاً، لأنها في عصمته، أما البائن فلا تدخل معنا، لأنها ليست زوجة فلا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، وهو قيد في التعريف يخرج به تشبيه الرجل أجنبيّه بمحرمة عليه، فهذا لا يرتب أثراً شرعياً، ولا يدخل معنا.

وقوله في التعريف: «في الحرمة» أي أن التشبيه يختص بامرأة يحرم وطئها بحرمة الشارع، وهو قيد في التعريف يخرج تشبيه الزوج زوجته بمحرمة عليه في الجمال أو في الطول أو في الثراء إلى غير ذلك فلا يدخل معنا في الظهار.

وقوله في التعريف، «محرمه على التأبيد» أي التي لم تكن حلاله قبل ولادته وحتى موته، أو بمعنى آخر أنها محرمة لم يطرأ تحريمها عليه، وهو قيد في التعريف يخرج به تشبيه الزوج زوجته بأجنبية ومطلقه وأخت زوجة والأب أو الابن إلى غير ذلك لأن أولئك غير محرمات على التأبيد فلا يدخلن معنا.

الدرس الثاني

حكم التلفظ بالظهار ودليله^(١):

اعتبر الشارع الحكيم قول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمي منكراً من القول وزوراً أما كونه منكراً، وأمراً قبيحاً، فلأنه تضيق وحرمان مما يتمتع به الأزواج، وإساءة إلى من أمر بالإحسان إليها، ويكون قد حرم نفسه مما أحله الله له، وكل هذا مما يأباه الشرع الشريف ويرفضه العقل السليم، وأما كونه زوراً، فإن الزوجة ليست أمّاً حقيقة، ولا يوجد وجه شبه بينهما، ولكن الشارع الحكيم يهمل كلامه بالمدة، لأنه صادر عن إرادة وعقل -كما أنه سبحانه رحمه، ولم يرهقه من أمره عسراً فأوجب عليه الكفارة فقط رحمة به، ولم يجعل ما صدر منه في حكم الطلاق مؤاخذه له لأنه ألزم نفسه ما لم يلزمه أحد، وحملها إصراراً من بقايا الجاهلية الأولى بغير موجب وجعلها على النحو الذي ورد به القرآن الكريم، قال تعالى: (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُم مِّن نِّسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌ غَفُورٌ)^(٢)

وكان الظهار معروفاً في الجاهلية، وكانوا يعتبرون قول الرجل لمن تحل له، «أنت علي كأمي» محرماً لها على الأبد، لا تحل له أصلاً بعد ذلك، فلما جاء الإسلام، وظاهر أوس ابن الصامت من امرأته خوله بنت ثعلبة، ودعاها إليه بعد ظهاره، فقالت له، والذي نفس خوله بيده لا تصل إلي، وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله، وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله إن أوساً تزوجني وأنا شابه مرغوب في، فلما خلا سني ونثرت بطني جعلني عليه كأمه، وتركني إلى غير أحد، فإن كنت تجد لي رخصة تتعشني بها وإياه، فحدثني بها، فقال لها | : (ما أراك إلا قد حرمت عليه) فجادلت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له ما ذكر طلاقاً وقعدت بعد ذلك مراراً، ثم قالت: اللهم إني أشكو إليك

(١) انظر الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣١٧. التهذيب ج ٦ ص ١٥٠، مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٤٨، المحلي على المنهاج وحاشية

قليوبي عليه ج ٤ ص ١٤.

(٢) سورة: المجادلة - الآية: ٢.

فاقتي وشدة حالي فأنزل على لسان نبيك^(١)، فأنزل الله سبحانه وتعالى: (قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ)^(٢) إِلَى أَنْ قَالَ: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تُوعِظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً)^(٣).

فكانت هذه الآيات حداً فاصلاً بين ما كان عليه أهل الجاهلية من جعل الظهار طلاقاً مؤبداً وما عليه الإسلام من اعتبار الحرمة فيه مؤقتة تزول بفعل الكفارة^(٤).

وإذا كان حكم التلطف بالظهار والحرمة، فإن بعض العلماء قد صنفوا

هذه الحرمة بأنها حرمة عظيمة تدخل ضمن الكبائر، ومن ثم فأحرى بالمسلمين أن يجتنبوا كبائر ما نهوا عنها حتى يكفر عنهم سيئاتهم الأخرى، فيغنمون خير الله في الدنيا ويدخلهم في الآخرة مدخلاً كريماً.

(١) المروية ذكرها البيهقي في سننه ج ٧ ص ٣٩٢، والطبري في تفسيره ج ٢٨ ص ٧٠٢.

(٢) سورة: المجادلة - الآية: ١.

(٣) سورة: المجادلة - الآيات ٣ - ٤.

(٤) التهذيب - البغوي - ج ٦ ص ١٥٠.

الدرس الثالث

أركان الظهار وشروط كل ركن^(١):

يرى فقهاء الشافعية أن أركان الظهار أربعة: مظاهر، ومظاهر منها، وصيغة ومشبه به.

أولاً: شروط المظاهر والأحكام المترتبة عليها:

يشترط في المظاهر عدة شروط نوردتها على النحو التالي:

أ- أن يكون المظاهر زوجاً، فلا تصح بظاهرة السيد من أمته ولو كانت أم ولدها لأن الله تعالى أناط حكمه بالنساء، فقد قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)^(٢) فكلمة النساء جاءت مطلقة، الأمر الذي يصرفها إلى الزوجات.

ب- أن يكون المتناحر مكلفاً، بأن يكون بالغاً عاقلاً وإن كان عبداً أو كافراً ومن ثم فلا يصح من صبي ومجنون ومغمی عليه لارتفاع القلم عنهما، أما شرط الإسلام فلا يشترط الشافعي في المظاهر كونه مسلماً حتى تجب الكفارة عليه، وذلك لأنه تعالى قال: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)^(٣)، واسم الموصول من صيغ العموم يتناول المسلم والكافر ولأنه قول يختص به النكاح، فيصح من كل زوج مكان كالطلاق، كما أن الكفارة زاجرة في حق الكافر فتجب^(٤)، كما أن ظهار السكران يصح قياساً على طلاقه.

ج- أن يكون المظاهر مختاراً، أي أن يكون المظاهر غير مكره على التلفظ بهذا ومن ثم فلا يصح ظهار المكره.

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٤٨.

(٢) سورة: المجادلة - الآية ٣.

(٣) سورة: المجادلة - الآية ٣.

(٤) الحاوي الكبير ج ١٣١٣ ص ٣١٩.

د- لا يشترط في المظاهر سلامته من العيوب التي تثبت الخيار للزوجة في الطلاق، فيصح من الخصى والمحبوب والممسوح والعنيين قياساً على صحة طلاقهم^(١).

ثانياً: شروط المظاهر منها والأحكام المترتبة عليها: يشترط في المظاهر منها أن تكون زوجة يصح طلاقها، فيدخل في ذلك المريضة والرتقاء^(٢) والقرناء^(٣) والكافرة والرجعية، وتخرج الأجنبية ولو مختلعة والأمة^(٤).

واستدل الشافعية على هذا بقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ)^(٥)، فالآية تدل على أن الله تعالى أضاف النساء إلى المظاهرين، وهي ظاهرة في الأزواج، فاختص الظهار بهم دون غيرهم، يقوي ذلك أن الظهار في الإسلام جاء ناسخاً لما كانت عليه الجاهلية من اعتباره طلاقاً مؤبداً، وهم إنما كانوا يعرفون الظهار في الزوجات دون الأرقاء، فوجب بقاء المحل كما كان في الجاهلية، والنسخ يرجع إلى الحكم لا إلى المحل.

شرط الصيغة والأحكام المتعلقة به: يشترط في الصيغة أن تكون بلفظ يشعر بالظهار، وذلك إما صريح كأن يقول الزوج لزوجته أنت علي أو مني أو معي أو عندي أو لدي أو نحو ذلك كظهر أُمِّي في ركوب ظهرها لأن هذه الحروف يقوم بعضها مقام بعض، فلم يخرج في الظهار عن حكم الصريح، وكذا قوله أنت كظهر أُمِّي فهو لفظ صريح في الدلالة على تحقق الظهار وهذا على الصحيح، والثاني: أن هذا اللفظ كناية، لاحتمال أنه يريد: أنت على غيري كظهر أمه، ويترتب على هذا الخلاف أنه لو قال: أردت به غيري لم يقبل على

(١) التهذيب ج ٦ ص ١٥١.

(٢) الرتق وهو انسداد محل الجماع بلحم.

(٣) القرن وهو انسداد محل الجماع بعظم.

(٤) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٤٩، الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٢٠، التهذيب ج ٦ ص ١٥١.

(٥) سورة: المجادلة - الآية ٣.

الأول، ويقبل على الثاني^(١)، وإما كناية كقوله كأنت كأمي، هل في الكرامة أو في التحريم فيحتاج إلى نية، وكذا الأمر لو قال لها أنت كبدن أمني أو كرأس أمني أو كبدها، فإنه يكون بكل ذلك مظاهراً، وذلك في الأظهر لأن تشبيهه بعضه يحرم التلذذ به فكان كالظهر، ومقابل الأظهر: أنه ليس بظهار، لأنه ليس على صورة الظهر المعهودة في الجاهلية^(٢).

وأيضاً التشبيه بالجدة من الجهتين وإن بعدت، كقوله: أنت علي كظهر جدتي، ظاهر، لأنها تسمى أمًا، ولها ولادة، وتشارك الأم في العتق وسقوط العقود ووجوب النفقة.

حكم قول الرجل لزوجته أنت علي كظهر بنتي أو أختي أو على كل محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة:

يري فقهاء الشافعية: أن المذهب أنه ظاهر لأنها لم تزل محرمة عليه فضلاً عن مساوتها للأم في التحريم المؤبد. والطريق الثاني كالمذهب، والثالث: المنع لورود النص في الأم.

ويرى بعض الفقهاء التفرقة بين المحرمات بسبب النسب، وبين المحرمات بسبب المصاهرة والرضاع، فقال الأولى طرد القولين في محرم السب، أي الأظهر أنه ظاهر، والثاني لا.

وطرد خلاف الطرق على المحرمات بسبب الرضاع و المصاهرة^(٣).

ما الحكم لو أن المرأة هي التي ظاهرت زوجها: يري فقهاء الشافعية أن المرأة لو قالت لزوجها أنت علي كظهر أمني، لم يصح الظهر منها، ولم تلزمها كفارة، وذلك لأن الله تعالى قال: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ)^(٤) فخص الرجال، ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٤٩.

(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٥٢.

(٣) المحلي على المنهاج، وحاشية عميرة عليه ج ٤ ص ١٥، الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٣٩، ٣٤٠.

(٤) سورة: المجادلة - الآية ٣.

معتبراً بالطلاق في الإسلام، فلما لم يكن للطلاق من النساء حكم، فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم^(١).

حكم تعليق الظهار: يري فقهاء الشافعية صحة تعليق الظهار، لأنه يتعلق به التحريم كالطلاق والكفارة وكل منهما يجوز تعليقه.

وتعليق الظهار، كقول الرجل إذا جاء محمد أو إذا طلعت الشمس فأنت علي كظهر أمي، فإذا وجد الشرط صار مظاهراً لوجود المعلق عليه.

ما الحكم لو قال: إذا نكحتك -يقصد امرأة بعينها- فأنت علي كظهر أمي فنكحها.

يري فقهاء الشافعية في هذه الصورة أن هذا الرجل لم يكن متظاهراً ممن نكحها، لأنه لما لم ينعقد طلاق قبل نكاح، لم ينعقد ظهار ولا إيلاء قبل نكاح، فإذا نكحها لم يكن مظاهراً^(٢).

حكم لو قال لزوجته أنت طالق كظهر أمي مني ويريد الظهار أو العكس:

يري الشافعي أنه لو قال ما قيل يقع الطلاق دون الظهار، لأنه صرح بالطلاق، فلا معنى لقوله كظهر أمي إلا أنك حرام علي بالظهار كظهر أمي أو محال، فلا معنى له. أو يحمل قوله: كظهر أمي على تأكيد تحريم الطلاق^(٣)، أما لو قال أنت علي كظهر أمي يريد الطلاق فهو ظهار^(٤).

شرط الركن الرابع وهو المشبه به:

يشترط في المشبه به كونه كل أنثى محرم أو جزء أنثى محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلاً للزوج كبنته وأخته من نسب ومرضعة أبيه أو أمه وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته أو معها.

(١) الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٤٢.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٥١.

(٣) التهذيب ج ٦ ص ١٥٢.

(٤) الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٤٥، ٣٤٦.

ويترتب على هذا أن من شبه زوجته بخلاف غير الأنثى من ذكر وخنثى لا يعد متظاهراً لأن الذكر ليس محل التمتع، وأيضاً لا يعد الرجل متظاهراً إذا شبه زوجته بمن كانت حاله كزوجه ابنه، وكذلك الأمر إذا شبه بزوجات النبي ﷺ لأن تحريمهن ليس للمحرمية، بل لشرفه ﷺ^(١).

الدرس الرابع

الأثر المترتب على وقوع الظهار من الرجل

إذا نطق الزوج بلفظ الظهار الصريح، أو بشيء من ألفاظ الظهار، وأراد بذلك معنى الظهار ثم أراد العود فإنه يجب عليه الكفارة بعد العود^(٢)، لأن الظهار علة لوجوب الكفارة، والعود شرطها. قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا)^(٣).

جهة الدلالة: تدل الآية على أن الله تعالى أوجب الكفارة بالظهار والعود، لأنه جعله شرطاً عقبه بالجزاء، والجزاء إذا علق بشرط اقتضى وجوبه عند وجود الشرط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أوس بن الصامت بالكفارة قبل وطنه، وأمره على الوجوب، فدل على ثبوت الكفارة في الذمة قبل الوطء، وأن ليس الوطء شرطاً في الوجوب، ولأن الكفارة المتعلقة بسبب تقتضي الوجوب عند وجود ذلك السبب اعتباراً بسائر الكفارات، ولأنه تكفير بعق فجاز أن يثبت في الذمة قياساً على كفارة القتل^(٤).

هل يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، وما الحكم لو وطئها؟

(١) حاشية البيجري الخطيب ج ٤ ص ١٤.

(٢) العود هو أن يمسكها بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه، فلا يطلق -الحاوي الكبير- ج ١٣ ص ٣٥٣.

(٣) سورة: المجادلة - الآية ٣.

(٤) الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٦٠.

يرى فقهاء الشافعية أن الوطء حرام قبل التكفير، لأن الله سبحانه وتعالى قيد العتق والصوم ما قبل المسيس. وأطلق الإطعام، فيحمل المطلق على المقيد، فقد قال تعالى: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكَ تَوَعَّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا)^(١)، وإذا كان الوطء قبل التكفير حرام، فإنه لو وطئها يكون قد عصى الله لمخالفته حدود الله وتبقى الكفارة في ذمته عليه قضاؤها بعد المسيس، ولا يجوز أن يعود حتى يكفر^(٢).

هل يحرم سائر المباشرات سوى الوطء أيضا أم لا ؟

يرى فقهاء الشافعية أن القبله واللمس بالشهوة والمباشرة فيما دون الفرج قبل التكفير فيه قولان:

أصحهما: لا يحرم و ذلك بقوله تعالى: (مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا)، والمس في عرف الشرع عبارة عن الوطء كما قال تعالى: (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ)^(٣)، ولأن تحريم الوطء في المحيض والصوم لا يوجب تحريم التلذذ بما سواه، كذلك في الظهار لبقاء النفعية واستباحة الواعي من الطيب وغيره.

والثاني: يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج، كما يحرم عليه الوطء في الفرج^(٤).

حكم من وطء المظاهر منها بعد الشروع في الصوم:

يرى الشافعية أن المظاهر إذا كفر بالصيام لزمه صوم شهرين متتابعين قبل الوطء كالعتق وهو نص، قال تعالى: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ

(١) سورة: المجادلة - الآيات ٣-٤.

(٢) التهذيب-البغوي ج٦ ص١٥٨.

(٣) سورة: البقرة-الآية: ٢٣٧.

(٤) الحاوي الكبير ج١٣ ص٣٦٤، التهذيب ج٦ ص١٥٨.

فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا^(١)، فإن وطئ في نهار الصوم عامدًا بطل صومه وتتابعه، واستأنف صوم شهرين متتابعين بعد وطئه وإن وطئ في نهار الصوم ناسيًا، لم يبطل صومه ولا تتابعه، وإن وطئ في ليل الصوم ناسيًا أو عامدًا لم يبطل الصوم ولا التتابع.

وروي عن بعض الشافعية أن المظاهر لو وطئ خلال صوم الشهرين، فإنه يكون قد عصى الله بتقديم الوطء على إتمام الكفارة، ولكن لا يجب عليه استئناف الشهرين^(٢).

حكم من وجب عليه الإطعام، ثم جامع قبل إتمام الكفارة:

لا خلاف بين الفقهاء في أن المظاهر لو كان يكفر بالإطعام، فأطعم بعض المساكين ثم جامع. لا يبطل ما مضى^(٣).

(١) سورة: المجادلة - الآيات ٣-٤.

(٢) التهذيب ج ٦ ص ١٥٨.

(٣) التهذيب ج ٦ ص ١٥٨.

الدرس الخامس

أنواع الظهر

الظهر نوعان: مطلق ومقيد.

فالمطلق أن يقول الرجل: أنت علي كظهر أمي، ولا يقدر ذلك مدة والعود فيه بما ذكرنا من إمساكها بعد الظهر مدة يقدر فيها على الطلاق.

فأما المقيد فهو أن يقول: أنت علي كظهر أمي يومًا أو شهرًا أو سنة، ولا يطلقه على التأبيد، ولفقهاء الشافعية في اعتباره ظهارة تترتب عليه أحكامه أم لا قولان: الأظهر أنه يكون مظاهراً بالمؤقت، كما يكون مظاهراً بالمطلق المؤبد، لأن الظهر كالطلاق ولأنه منكر من القول وزور فصح كالطلاق المعلق، ويترتب على ذلك أن عوده لا يحصل إلا بوطء في المدة لأن الحل منتظر بعد المدة، فالإمساك يحتمل أن يكون لانتظار الحل أو للوطء في المدة والأصل براءته من الكفارة، فإذا وطئ فقد تحقق الإمساك لأجل الوطء ومقابل الأظهر، لا يكون مظاهراً بل هو لفظ لغو لأن تحريم الظهر يقتضي التأبيد كالألم، فإذا قدره بمدة يخرج بالتقدير من حكم الظهر، وصار كمن شبه امرأته من حرمت عليه في مدة، ولا يكون مظاهراً جمعاً بين توقيت المدة المشبه بها، وعلى هذا لا يراعى فيه العود لسقوط الظهر أو بمعنى آخر لأنه لم يؤيد التحريم فأشبهه ما إذا شبهها بامرأة لا تحرم على التأبيد^(١).

حكم من ظاهر عن أربع نسوة^(٢):

لو قال الزوج لزوجاته الأربع أنتن علي كظهر أمي، فلا خلاف بين الشافعية في أنه مظاهر منهن لوجود لفظة الصريح، ثم بعد ذلك ننظر إن ظاهر عنهن بأربع كلمات، تلزمه أربع كفارات سواء فرق أو تابع.

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٥٤، الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٦٩.

(٢) المحلي على المنهاج ج ٤ ص ١٩، ٢٠.

وإن ظاهر عنهن بكلمة واحدة، فقال: انتن علي كظهر أمي صار مظاهراً عنهن، ولكن هل تجب أربع كفارات مثل الحالة الأولى أم لا ؟

الجديد وهو المذهب: عليه أربع كفارات إذا أمسكهن عقيب اللفظ اعتباراً بالمحل وبعود واحد يجب الكفارات كلها.

وإن طلقهن في الحال: فلا كفارة عليه.

وفي القديم: لا يجب عليه إلا كفارة واحدة، كما لو حلف لا يكلمهن وكلمهن: لا يجب إلا كفارة واحدة^(١).

حكم من كرر لفظ الظهار في امرأة واحدة تكريراً متصلاً وقصد به تأكيداً:

فالحكم في هذه الحالة يكون ظهار واحد، لأن التأكيد شائع في اللغة فقبل قوله كالطلاق فيلزمه كفارة إن أمسكها عقب المرات، وإن فارقها عقبها فلا شيء عليه.

أما لو قصد بتكرير الظهار في امرأة استئنافاً فالأظهر التعدد للظهار بعد المستأنف كالطلاق، ومقابل الأظهر لا يتعدد كتكرير اليمين على شيء مرات^(٢).

(١) التهذيب ج ٦ ص ١٦١.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٥٦.

الدرس السادس

كفارة الظهار

تعريف الكفارة: لغة مأخوذة من الكفر وهو الستر، فيقال للحراث كافر، لأنه يستر البذر بالأرض، ومنه الكافر، لأنه يستر الحق بالباطل^(١).

تعريف الكفارة في اصطلاح الفقهاء: عرفها العلامة البيجوري بأنها: مال أو بدله يخرج به الشخص بسبب ظهار أو قتل أو جماع في نهار رمضان أو حنث في يمين^(٢).

وسميت الكفارة بهذا الاسم لأنها تكفر أي تستر الذنب وتمحوه من صفح الملائكة، وقيل تستره عن أعين الملائكة مع بقاءه في الصحيفة.

أنواع الكفارات^(٣):

تنقسم الكفارات إلى قسمين: مرتبة ومخيرة.

فالمرتبة: كفارة الظهار، وكفارة الجماع في نهار رمضان، يجب فيها إعتاق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، وكذلك كفاره القتل مرتبة، إلا أن الإطعام هل يدخل فيها أم لا. على قولين:

أحدهما: لا، لأن الله تبارك وتعالى قال: (فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ)^(٤) ولم يذكر الإطعام.

والثاني: الإطعام يدخل فيها، قياساً على كفارة الظهار والجماع.

(١) حاشية قليوبي على المنهاج ج ٤ ص ٢٠.

(٢) حاشية البيجوري على ابن قاسم ج ٢ ص ١٦٠.

(٣) التهذيب - البغوي: ج ٦ ص ١٦٣، ١٦٤.

(٤) سورة: النساء - الآية: ٩٢.

وأما الكفارة المخيرة: فكفارة اليمين إذا حنث فيها: يتخير فيها بين أن يطعم عشرة من المساكين، أن يكسوهم، أو يعتق رقبة، فإن لم يقدر على شيء منها -فعليه صوم ثلاثة أيام. شروط الكفارة إجمالاً^(١):

يشترط في الكفارة عدة شروط نذكرها على النحو التالي:

١- النية، وذلك بأن ينوي العتق أو الصوم أو الإطعام عن الكفارة، لأنها حق مالي يجب تطهيره كالزكاة، والأعمال بالنيات، فلا يكفي الإعتاق أو الصوم أو الكسوة أو الإطعام الواجب عليه، لأنه قد يجب بالنذر.

٢- لا يشترط تعيينها، بأن تقيد بظهار أو غيره، فلا يشترط، كما لا يشترط في زكاة المال تعيين المال المزكي، بجامع أن كلا منها عبادة مالية، بل تكفي نية أصلها، ويترتب على هذا الشرط أنه لو اعتق رقتين بنية الكفارة، وكان عليه كفارة قتل و ظهار أجزأه عنهما، وإن أعتق واحدة وقعت عن إحداها، ويرجع السبب في عدم اشتراط تعيينها لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات، فاكتفى فيها بأصل النية.

ما الحكم لو عين النية وأخطأ:

لو عين المؤدي للكفارة ما يؤديه ثم أخطأ في النية، كأن نوى كفارة قتل؛ وليس عليه إلا كفارة ظهار لم يجزئه ما أتى به بتلك النية عما عليه قياساً على ما لو أخطأ في تعيين الإمام في الصلاة^(٢).

خصال الكفارة في الظهار^(٣):

وخصال كفارة الظهار ثلاث. إحداها: عتق رقبة مؤمنة، ويشترط في

(١) شرح المحلي على المنهاج ج ٤ ص ٢٠، ٢١، مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٥٧.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٥٨.

(٣) شرح المحلي على المنهاج ج ٤ ص ٢١، ٢٢، حاشية البيجوري علي ابن قاسم ج ٢ ص ١٦٠، ١٦١، التهذيب -البغوي ج ٦ ص ١٦٤، وما بعدها، الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٣٥٣ وما بعدها.

الرقبة المجزئة في الكفارة أربعة شروط:

١- أن تكون مؤمنة، ولو بإسلام أحد الأبوين، ومن ثم فلا يجزئ كافر، قال تعالى في كفارة القتل: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ)^(١)، وألحق بها غيرها قياساً عليها، أو حملاً لمطلق آية الظهار على المقيد في آية القتل، كحمل المطلق في قوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِّن رِّجَالِكُمْ)^(٢) على المقيد في قوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِّنكُمْ)^(٣).

ولأن الزكاة لا يحوز صرفها لكافر، فكذا الكفارة به.

٢- أن تكون سالمة بلا عيب فيها يخل بالعمل والكسب إضراراً بيئاً، لأن المقصود تكميل حالة ليتفرغ لوظائف الأحرار، ويحصل ذلك إذا استقل بكفاية نفسه، وإلا فيصير كلا على نفسه وعلى غيره.

ولا يتنافى هذا الشرط مع قول الشافعية بإجزاء الأقرع والأعرج والأصم والأخرس والأخشم -فاقد الشم - وفاقد الأنف وفاقد الأذن و فاقد أصابع الرجلين، لأن فقد ذلك لا يخل بالعمل والكسب، وكذلك فاقد الأسنان والمجبوب والعينين.

أما من اتصف بأوصاف تخل بالعمل والكسب والخدمة فلا يجزئ كالزمن أو فاقد رجل أو جزء مهم من يد ونحو ذلك من هرم عاجز، ومريض لا يرجى برد علته.

٣- إكمال الرق في الإعتاق عن الكفارة، فكل ما يستحق العتق بسبب غير الشراء لا يجزئ في الكفارة، فلا يجزئ عتق أم الوليد لاستحقاقها العتق بجهة الاستيلاء، ولا عتق ذي كتابة صحيحة، لأنه عتقه بسبب الكتابة.

أما المدير وهو المعلق عتقه بموت سيده، كأن قال له سيده إن مت فأنت

حر، والمعلق بصفه غير التدبير، فإن يجزئ، لأنه ملكه عليهما تام.

(١) سورة: النساء - الآية: ٩٢.

(٢) سورة: البقرة - الآية: ٢٨٢.

(٣) سورة: الطلاق - الآية: ٢.

٤- خلو الرقبة عن شوب العوض، فلو اعتق عبده عن كفارته بعرض يأخذه لم يجز ذلك الإعتاق عن كفاره لعدم تجرده لها.

ضابط المعتق في الكفارة^(١):

قرر فقهاء الشافعية أن ضابط المعتق في الكفارة هو أن كل من ملك عبداً لا يحتاج إليه أو ملك ثمنه من نقد أو عوض فاضلاً عن كفاية نفسه وعياله الذين تلزمه مؤنتهم شرعاً نفقة وكسوة وسكنى وأثاثاً لا بد منه لزمه العتق.

وذلك لأن الله تعالى قال: (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَا)^(٢).

أما من ملك عبداً وهو محتاج إليه لا يلزمه، وأيضاً لا يجب على المكفر بيع ضيعه ولا رأس مال للتجارة ولا بيع مسكن وعبد نفيسين ألفهما وذلك في الأصح وذلك لعسر مفارقة المألوف ونفاستهما بأن يجد بثمن المسكن مسكناً يكفيه، ومقابل الأصح يجب بيعهما لتحصيل عبد يعتقه.

فإن عجز عن الرقبة، بأن لم يجد الرقبة وقت إرادة التكفير أصلاً أو شرعاً بأن لم يجد ثمنها فاضلاً عن كفاية العمر الغالب، أو احتاجها لنحو مرض أو زمانه، فيجب عليه شهرين متتابعين.

معيار التتابع^(٣):

ذهب الشافعية إلى أن التتابع لا ينقطع مادام سبب الانقطاع عذر مقبولاً شرعاً، أما إذا كان الانقطاع بدون عذر أو كان بعذر ولكنه لا يعتبر في الشرع فإنه يفوت التتابع، ولو كان الانقطاع في اليوم قبل الأخير.

حساب الشهرين^(١):

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٦٣.

(٢) سورة: المجادلة - الآية ٣.

(٣) المحلي على المنهاج ج ٤ ص ٢٥، ٢٦.

ويحسب الشهران بالهلال، بمعنى أنه إن أمكن أن يصوم من أولهما، فهذا أولى، وإن صام في أثناء الشهر اعتبر الشهر الثاني بالهلال وإن نقص وتم الأول من الثالث يومًا، إذ المطلوب صيام شهرين متتابعين ولو نقص كل منهما عن ثلاثين يومًا.

ويكون صومها بنية الكفارة من الليل، كما لا يشترط نية تتابع في الأصح، اكتفاء بالتتابع الفعلي.

أما إذا لم يستطع المظاهر صوم الشهرين أو لم يستطع تتابعهما فعليه إطعام ستين مسكينًا أو فقيرًا يجوز دفع الزكاة له، فلا يكون هاشمي ولا مطلبى ولا مكفى بنفقة قريب أو زوج ولا لعبد، ويعطى لمن يستحق مد من جنس الحب المخرج في زكاة الفطر، أي يخرج من غالب قوت البلد الذي يسكن فيه.

حكم من عجز عن الخصال الثلاث^(١):

يري فقهاء الشافعية أن المكفر إذا عجز عن الخصال الثلاث استقرت الكفارة في ذمته إلى أن يقدر على خصله من الخصال الثلاث، فيفعلها.

حكم من قدر على بعض خصله^(٢):

لو قدر المكفر على إخراج بعض خصله كمد طعام أو بعض أخرجه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، ويبقى الباقي في ذمته، لأن العجز عن الكفارة لا يسقطها.

وهذا الأمر مقبول في الخصلة الثالثة وهي الإطعام، أما الأمر بالنسبة للعنق أو الصيام فلا يجزئ، لأنه إذا وجد بعض الرقبة لم يعتقه، لأنه بهذا عادم للرقبة، وكذا الأمر بالنسبة للصوم، فلو قدر على بعض الصوم كيوم لم يجب عليه، لأنه يجب التتابع في صوم الشهرين، فإذا صام البعض لم يحصل تتابع.

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٤٦٤، الحاوي الكبير ج ١٣ ص ٤٤٤.

(٢) حاشية البيجرمي علي الخطيب ج ٤ ص ٢٦.

(٣) التهذيب ج ٦ ص ١٨٦.

هل يجوز تبويض الكفارة^(١):

يرى الشافعية عدم جواز تبويض الكفارة من خصلتين، كأن يعتق نصف رقيق، ويصوم شهرًا، أو يطعم ثلاثين مسكينًا ويصوم ثلاثين يومًا.

أسئلة على الوحدة:-

س١: ما المراد بالظهار، وما حكم التلفظ به ودليله ؟

س٢: ما هي أركان الظهار وشروط كل ركن ؟

س٣: هل يجوز للمظاهر الوطء قبل التكفير، وما الحكم لو وطئها ؟

(١) حاشية البيجرمي علي ابن القاسم ج ٢ ص ١٦٢.

الوحدة السادسة

أحكام اللعان عند الشافعية

أهداف الوحدة تتمثل فيما يلي:-

- ١- إلقاء الضوء على معنى اللعان، وحكمه، والأصل في ورود الشرع به.
- ٢- بيان أركان اللعان، وكيفيته، كي يكون منتجاً لآثاره.
- ٣- إلقاء الضوء على بعض الأحكام الفقهية المتعلقة باللعان، وهل هو يرتب الانفصال بين الرجل والمرأة، وهل يكون الانفصال دائماً أو مؤقتاً بحيث لا يحق له مراجعتها بعده، أو لا؟

تمهيد:-

إذا علم الزوج أن امرأته قد زنت بأن رآها بعينه وهي تزني أو أقرت الزوجة عنده بالزنا أو أخبره ثقة أن زوجته تزني أو استفاض الخبر بين الناس أن رجلاً يزني بها، فرماها زوجها بالزنا، ولم تقر الزوجة بذلك ونفت زناها، ولم يرجع الزوج عن رميها بالزنا فقد شرع الله لهما اللعان، فما المقصود باللعان ؟ وما هي الأحكام التي تتعلق به ؟ وفيما يلي بيان أهم المسائل التي تتعلق باللعان، وذلك على الوجه التالي:

الدرس الأول

تعريف اللعان

أولاً: تعريف اللعان:

اللعان لغة^(١): مأخوذ من اللعن: وهو الإبعاد والطرده من الخير وبابه قطع، يقال: لعن الله فلاناً، أي أبعد الله وطرده، وهو مصدر لاعن يلاعن ملاعنة ولعاناً، والجمع لعان و لعنات والرجل لعين وملعون والمرأة لعين أيضاً.

واللعين الذي يلعنه كل أحد، وقال الأزهري: اللعين المشتوم واللعين المطرود. واللعين المنفي والرجل العين لا يزال منتبهاً عن الناس، وكل من لعنه الله فقد أبعدته عن رحمته وأستحق العذاب فصار هالكا، واللعين الشيطان صفة غالبية لأنه طرد من السماء وقيل لأنه أبعد من رحمة الله واللعبة الدعاء عليه.

اللعان والملاعنة اللعن بين اثنين فصاعداً واللعنة الكثير اللعن للناس واللعنة الذي لا يزال يلعن لشرارته، وتلاعن القوم لعن بعضهم بعضاً، ولاعن امرأته في الحكم ملاعنة ولعاناً ولاعن الحاكم بينهما لعاناً حكم، والملاعنة بين الزوجين إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها فالإمام يلاعن بينهما.

وسمي اللعان بهذا الاسم لبعد الزوجين من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر فلا يجتمعان أبداً إذ يحرم النكاح بينهما أبداً، أو لاشتغالها على كلمة اللعن.

تعريف اللعان في الشرع: كلمات معلومة جعلت حجة للمضطر إلى قذف من لطح فراشه و ألحق العار به أو إلى نفي ولد^(٢).

شرح التعريف:

(١) مختار الصحاح ص ٢٥٠، لسان العرب ج ١٣ ص ٣٨٨.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٧.

- كلمات معلومة: أي مخصوصة وهي أربعة أيمان على الصحيح وليس هناك يمين تتعدد وتكون في جانب المدعي إلا هذه والقسامة فهذه الكلمات الأربعة أيمان أربعة.
- جعلت حجة للمضطر: وهو الزوج بمعنى أن هذه الأيمان سبب دافع للحد عن المضطر.
- من لطح فراشه: الفراش هو الزوجة، والضمير في فراشه عائذ على المضطر.

الدرس الثاني

حكم اللعان^(١):

اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج، فإذا رأى الزوج زوجته بعينه وهي تزني أو أقرت الزوجة عند زوجها بالزنا، أو أخبره ثقة بزنا زوجته أو استفاض في الناس خبر زنا زوجته وانضمت إلى الاستفاضة قرينة^(٢) بأن رآها ولو مرة مع من أشيع زناه بها فجاز له قذفها والتعانها، والأصل في مشروعية اللعان: الكتاب، والسنة:

١- الكتاب:

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ*وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ)^(٣).

بين الله تعالى بهاتين الآيتين لعان الزوج لزوجته، ثم بين الله تعالى بعد ذلك لعان الزوجة بقوله: (وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ*وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)^(٤).

قال الشافعي: فكان بينا في كتاب الله عز وجل أنه أخرج الزوج من قذف المرأة يعني باللعان كما أخرج قاذف المحصنة غير الزوجة بأربعة شهود يشهدون عليها بما قذفها به من الزنا وكانت في ذلك دلالة أن ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المرأة المقذوفة حدها^(٥).

٢- السنة:

(١) التكملة الثانية للمجموع ج ١٧ ص ٣٨٧.

(٢) ولا يكتفي بمجرد الاستفاضة بين الناس بل لابد من انضمام القرينة لأن الاستفاضة وحدها قد يشيعها عدولها أو من طمع فيها فلم يظفر بشيء.

(٣) سورة: النور - الآيات ٦: ٧.

(٤) سورة: النور - الآيات ٨: ٩.

(٥) أحكام القرآن للشافعي ج ١ ص ٢٣٨، ٢٣٩.

روى أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال: كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقّلته فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله ﷺ عن ذلك. فأتي عاصم النبي ﷺ فقال: يا رسول الله فكره رسول الله ﷺ المسائل، فسأله عويمر فقال إن رسول الله ﷺ كره المسائل وعابها. قال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله عن ذلك، فجاء عويمر فقال يا رسول الله: رجل وجد مع امرأته رجلاً أيقّلته فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله ﷺ: قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبك فأمرهما رسول الله ﷺ بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها، ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين، ثم قال رسول الله ﷺ انظروا فإن جاءت به أسحم -أي أسود - أدعج العينين^(١) عظيم الآليتين خدلج الساقين -أي عظيم الساقين - فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها، وإن جاءت به أحيمر -أي مثل البنعة وهي خرزة حمراء - كأنه وحره^(٢) فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله ﷺ من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه^(٣).

ووردت قصة أخرى في اللعان، فقد روي عن ابن عباس أن هلال ابن أمية قذف امرأته عند النبي ﷺ بشريك بن سحماء فقال النبي ﷺ البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله: إذا رأى أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلتمس البينة، فجعل النبي ﷺ يقول البينة وإلا حد في ظهرك، فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق فليزّلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ) فقرأ حتى بلغ (إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ) فانصرف النبي ﷺ فأرسل إليها فجاء هلال فشهد، والنبي يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفصح قومي سائر اليوم

(١) الدعج شدة سواد العين في شدة البياض.

(٢) الوحر: الحقد والغيط والغش. وامرأة وحره سوداء دميعة أو حمراء قصيرة.

(٣) صحيح البخاري -كتاب التفسير -باب قوله عز وجل (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ).

فمضت، فقال النبي: أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين -أي اسود العينين - سابق الآليتين خدلج الساقين -أي عظيم الساقين -فهو لشريك بن سحماء فجاءت به كذلك، فقال النبي ﷺ: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن^(١).

-ويحرم على الرجل أن يقذف زوجته بالزنا إذا لم يظهر زناها ببينة أو استقاضة بين الناس لقوله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ *لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ)^(٢).

دل ذلك على أن الناس إذا سمعوا من يقذف آخر سواء كانت زوجة أو غيرها أن يحكموا بكذبه ورد شهادته إلى أن يأتي بالبينة.

يقول القرطبي: قال العلماء إن الآية^(٣) أصل في أن درجة الإيمان التي حازها الإنسان ومنزلة الصلاح التي حلها المؤمن ولبسه العفاف التي يستتر بها المسلم لا يزيلها عنه خبر محتمل وإن شاع إذا كان أصله فاسداً أو مجهولاً^(٤).

-ثبوت اللعان بعد القذف: ولا بد أن يسبق اللعان قذف^(٥) لأن الله ذكر اللعان بعد القذف ولأنه حجة ضرورية لدفع الحد أو نفي الولد ولا ضرورة قبل ذلك^(٦).

(١) المرجع السابق.

(٢) سورة: النور - الآيات ١١: ١٢.

(٣) المراد بالآية قوله تعالى: (لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ) [سورة: النور - الآية: ١٢].

(٤) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ٢٠٣.

(٥) روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٢٨، ٣٣٢.

(٦) القذف: لغة الرمي، وشرعاً الرمي بالزنا على جهة التعبير.

ويتعلق بالقذف سواء كان القاذف زوجاً أو غيره ثلاثة أحكام وهي وجوب الحد على القاذف و هو ثمانون جلدة إن كان حراً، ورد شهادته، وثبوت فسقه، فإذا قذف الرجل رجلاً محصناً أو امرأة أجنبية منه محصنة وجب عليه حد القذف وحكم بفسقه وردت شهادته.

ويمكن إسقاط هذه العقوبة عن القاذف بأحد الطريقتين إما بإقرار المقدوف بالزنا أو شهادة أربعة شهود على زنا المقدوف، فإذا أقر المقدوف بالزنا أو شهدت البينة بزنا فلا حد على القاذف ويزول عنه الفسق والأصل في ذلك قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ) [سورة: النور - الآية: ٤].

أما إذا كان القاذف هو الزوج فيمكن له إسقاط عقوبة القذف عن نفسه بالطريقتين السابقتين - إقرار المقدوف أو شهادة الشهود - ويختص الزوج بطريق ثالث يمكنه به إسقاط عقوبة القذف عن نفسه وهو اللعان، فلا يثبت حق الزوج في اللعان إلا بعد قذف زوجته، فإذا قذفها كان للزوج إسقاط حد القذف عن نفسه بإقرار المقدوف بالزنا أو بالبينة شأنه شأن غيره، ويختص الزوج باللعان دون غيره لثبوته في حق الأزواج دون غيرهم بالكتاب والسنة، وهو ما سبق بيانه.

وإن قدر الزوج على إسقاط الحد عن نفسه بالبينة واللعان فله أن يسقط الحد عن نفسه بأيهما شاء لأنهما بينتان في إثبات حق فجاز له إقامة كل واحدة منهما مع القدرة على الأخرى.

الدرس الثالث

أركان اللعان وكيفيته

أولاً: أركان اللعان:

الركن الأول: الزوجان^(١):

اللعان يمين تصح من كل زوج صح طلاقه وظهاره مع كل زوجة صح منها فعل الزنا، سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلماً والآخر كافراً، وسواء كانا حرين أو مملوكين، أو أحدهما حرّاً والآخر مملوكاً، وسواء كانا عفيفين أو محدودين في قذف أو أحدهما عفيفاً والآخر محدوداً.

والدليل على أن اللعان يصبح من الزوجين الكافرين والمملوكين عموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ)^(٢).

لم يفرق سبحانه وتعالى في تشريعه لللعان بين الزوج المسلم والكافر، ولا بين الزوج الحر والعبد، فدل على ذلك على جواز جريانه بين الزوجين الكافرين والزوجين المملوكين. ولأن كل زوج صح طلاقه صح لعانه سواء كان مسلماً أو كافراً وسواء كان حرّاً أو عبداً. وقال الحنفية لا يقع اللعان إلا بين الزوجين المسلمين الحريين، فلا يقع بين الكافرين ولا بين الزوجين المملوكين^(٣).

ويشترط في الزوج البلوغ والعقل لما روى عن عائشة عن النبي ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق، ولأن غير المكلف بالصغر والجنون لا يصح طلاقه، فكذلك لا يصح لعانه.

(١) المهذب ج ٢ ص ١٢٤، الحاوي ج ١١ ص ١٢، التكملة الثانية للمجموع ج ١٧ ص ٤٣٣.

(٢) سورة: النور - الآية ٦.

(٣) بدائع الصنائع ج ٣ ص ٢٤١.

وكذلك يشترط في الزوجة حتى يصح لعانها البلوغ والعقل للخبر السابق، فإن كانت الزوجة صغيرة أو مجنونة لا يصح منها اللعان، وإن كان يجوز للزوج أن يلاعن منها في هذه الحالة لرفع الزوجية وفي النسب.

الركن الثاني: صيغة اللعان:

وكل لفظ أوجب حد القذف كان قذفًا يجوز به اللعان من الزوجة، سواء كان بلفظ الشهادة كقوله: رأيتها تزني، أو كان بغير لفظ الشهادة كقوله: قد زنت، أو يا زانية، وتنقسم ألفاظ القذف إلى ثلاثة أقسام^(١):

القسم الأول: اللفظ الصريح: وصريح القذف هو ما لا يحتمل غير القذف كقوله لرجل أو امرأة زينت أو زينتٍ أو يا زاني أو يا زانية لتكرر ذلك وشهرته كسائر الصرائح، ولا يضر اللحن بالتذكير للمؤنث وعكسه كقوله للرجل يا زانية وللمرأة يا زاني.

القسم الثاني: اللفظ الكناية: واللفظ الكناية في القذف هو ما يحتمل القذف وغيره ويتوقف على نية القاذف كقوله للرجل يا فاجر ويا فاسق ويا خبيث، وللمرأة يا فاجرة يا فاسقة يا خبيثة وأنت تحبين الخلوة في الظلمة أو لا تردين يد لامس، أو يقول لزوجته لم أجذك عذراء أو بكرًا أو وجدت معك رجلاً كل ذلك كناية في القذف ويتوقف الحكم بكونه قذفًا أو غير على نية القاذف، فإن قال نويت القذف كان قذفًا، وإن قال لم أنو القذف صدّق في قوله.

القسم الثالث: التعريض بالقذف: إذا قال شخص لغيره يا ابن الحلال وأما أنا فلست بزان، أو قال لغيره ليست أُمي بزانية ولست ابن خباز أو إسكافي، فمثل هذه الصيغ تعريض بغيره وليست من قبيل القذف وإن نوى بها القذف في الأصح لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي وههنا ليس في اللفظ إشعار بالقذف لا بصريح ولا بكناية.

-اللعان من الأخرس^(٢):

إن كان للأخرس إشارة مفهومة أو كتابة مقروءة عوقب بقذفه لغيره وصح لعانه من زوجته إذا قذفها بإشارة مفهومة أو بكتابة مقروءة لأنه كالناطق في نكاحه وطلاقه فكان كالناطق في لعانه،

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٦٧، ٣٦٨.

(٢) المهذب ج ٢ ص ١٢٤.

ولأنه لما صح منه النكاح مع تأكيده بالولي والشاهدين، فأولى أن يصح منه ما هو أخف من القذف واللعان.

فإن لم يكن للأخرس إشارة مفهومة ولا كتابة مقروءة لم يصح لعانه لأنه في معنى المجنون. وقال الحنفية: لا يصح من الأخرس قذف ولا لعان، واستدل على بطلان قذفه بأن الإشارة كناية والقذف لا يثبت بالكنايات، واستدل علي أن لعانه لا يصح بأن اللعان عنده شهادة، والشهادة لا تصح من الأخرس.

-اللعان بغير العربية^(١):

إذا كان الزوجان المتلاعنان يعرفان اللغة العربية ففي صحة اللعان باللفظ العجمي وجهان:

الوجه الأول: يصح اللعان بالعجمية مع القدرة على العربية كسائر الأيمان.

الوجه الثاني: لا يصح اللعان بالعجمية مع القدرة على العربية لأن الشرع ورد فيه بالعربية فلم يصح بغيرها مع القدرة كأذكار الصلاة.

وإن كان الزوجان لا يحسنان اللغة العربية جاز لهما الالتعان بلسانهما لموضع الحاجة، فإن كان الحاكم يحسن لسانهما أجزأ ذلك، وإن لم يكن يعرف لسانهما أحضر الحاكم من يترجم له، ويكتفي بمتترجمين وقيل لابد من أربعة.

ثانيًا: كيفية اللعان:

لا يصح اللعان إلا بحكم الحاكم^(٢) لأن النبي ﷺ لا عن بين عويمر العجلاني وامرأته، وبين هلال بن أمية وزوجته ولم يكن في أيامه لعان غير هذين فتولاه بينهما، ولأنه يمين في دعوى فلم يصح إلا بأمر الحاكم كاليمين في سائر الدعاوي.

-أما عن كلمات اللعان فهي خمس كلمات^(١)، ويجب أن يبدأ الزوج بأن يقول أربع مرات: أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت فلان من الزنا، ويقول في الخامسة إن علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا.

(١) المرجع السابق.

(٢) الحاوي ج ١١ ص ٤٤.

ويجب على الزوج أن يسمي الزوجة باسمها ويرفع في نسبها بحيث تتميز غيرها إن كانت غائبة عن المجلس، أو تتميز عن سائر زوجاته إن كان متزوجاً بغيرها.

فإن كانت المرأة حاضرة مجلس الحكم أشار إليها ولا يحتاج مع الإشارة إليها إلى تسميتها على الأصح كسائر العقود والفسوخ، وقيل يجب التسمية مع الإشارة لأن اللعان مبني على الاحتياط والتغليظ.

وإن كان الزوج يريد باللعان نفي الولد وجب عليه أن يقول في الكلمات الخمس: وإن الولد الذي ولدته إن كان غائباً أو هذا الولد إن كان حاضراً من الزنا وليس هو مني لأن كل مرة بمنزلة شاهد فلو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه.

وصفة لعان المرأة أن تقول أربع مرات أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وتقول في الخامسة علي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به.

ويجب على الزوجة أيضاً تسمية الزوج باسمه لتمييز عن غيره، فإن كان الزوج حاضراً مجلس الحكم أشارت إليه عند حلفها، وينتقي بإشارتها على الأصح وقيل يجب عليها تسمية الزوج مع إشارتها إليه.

وتكرار اليمين في حلف الزوج والزوجة مستحق وشرط في صحة اللعان، وهو حكم ثابت بنص القرآن، حيث يقول تعالى: (وَالَّذِينَ يَزُمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَذَرُهَا عَنْهَا الْعَذَابُ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) (١).

والعدد معتبر بنص هذه الآيات، والحكمة في تكرار اليمين لتأكيد الأمر لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام عليها الحد ولذلك سميت شهادات وهي في الحقيقة أيمان وأما الكلمة الخامسة فمؤكدة لمفاد الأربع.

(١) روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٥٠.

(٢) سورة: النور – الآيات ٦، ٧، ٨، ٩.

ما يشترط في الكلمات الخمس^(١):

- ١- يشترط في اللعان الموالاة بين الكلمات الخمس في جانب الزوج والزوجة فيضّر الفصل الطويل.
 - ٢- ويشترط في اللعان أيضا تمام الكلمات الخمس، فإن ترك بعض الكلمات وإن قل لم يصح اللعان ولم يتم، ولا يتعلق به حكم.
 - ٣- يشترط تأخير لفظتي اللعن والغضب عن الكلمات الأربع على الأصح.
 - ٤- يجب الابتداء بلعان الزوج قبل الزوجة، وهو شرط في صحة اللعان، فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به، لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) {النور: ٦}، حيث يجب البداءة في اللعان بما بدأ الله به وهو الزوج^(٢)، وقد جعل لعانها بعد لعان الزوج لأن لعانها لإسقاط الحد عنها.
- تغليظ اللعان^(٣):

ويستحب تغليظ اللعان بالجماعة والمكان والزمان ويؤمر به المتلاعنان، والتغليظ بما ذكر سنة وليس بواجب^(٤):

- ١- التغليظ بالجماعة: ويستحب أن يكون اللعان بمحضر جماعة من أعيان البلد وصلحائه فإن ذلك أعظم وأقلهم أربعة، لأن اللعان رواه أحداث الصحابة، كابن عباس وابن عمر وسهل بن سعد الساعدي ولا يحضر من الأحداث في مجلس الحكم والقضاء إلا مع أضعافهم من ذوي الأسنان، ولأن اللعان مبني على التغليظ والمبالغة في الردع به والزجر، فإن فعله في الجماعة أبلغ في ذلك، وليكونوا حجة إن تناكر المتلاعنان.

- ٢- التغليظ بالمكان: ويستحب تغليظ اللعان بالمكان واختصاصه بأشرف البقاع التي يتوقى فيها الإقدام على الفجور، وذلك بأن يلاعن في أشرف مواضع البلد فإن كان بمكة فبين الركن الأسود

(١) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٧٦.

(٢) تفسير القرطبي ج ١٢ ص ١٩١.

(٣) التكملة الثانية للمجموع ج ١٧ ص ٤٣٨ - ٤٤٤، مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٧٦.

(٤) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٧٨.

والمقام، وإن كان في المدينة لاعن عند منبر رسول الله ﷺ، وإن كان في بيت المقدس لاعن في المسجد الأقصى عند الصخرة، وتم الملاعنة في باقي البلاد في المساجد لأنها أشرف بقاع العبادات ويكون ذلك عند المنبر.

ويدل على مشروعية تغليظ اللعان بالمكان ما روي عن ابن عمر أن النبي ﷺ لاعن بين الزوجين على المنبر فدل اختصاصه بالمنبر على تغليظه به لشرفه، ولعظم العقوبة في الإقدام على المعاصي فيه، فقد روى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: من حلف يمينًا فاجرة على منبري هذا، ولو على سواك من أراك فليتبوأ مقعده من النار.

وإن كانت المرأة حائضًا التعن الزوج في المسجد والمرأة على باب المسجد.

ويلاعن الحاكم المسلم بين أهل الذمة في الموضع الذي يعظمونه وهو الكنيسة لليهود والبيعة للنصارى، ولا يلاعن بينهم في مساجدنا وإن كانت أعظم حرمة لأنهم لا يرون تعظيم مساجدنا ما يرونه من تعظيم بيعهم وكنائسهم.

وان كان الزوج مسلمًا والزوجة ذمية التعن الزوج في المسجد والزوجة في الكنيسة.

وإذا كانا مشركين لا دين لهما وتحاكما إلينا لاعن الحاكم المسلم بينهما في مجلس الحكم، وسقط تغليظ لعانتهما بالمكان لاستواء الأماكن كلها عندهم.

٣-التغليظ بالزمان: ويستحب أن يكون اللعان بعد العصر لتعرض من يحلف كاذبًا منهما لغضب الله، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: أنه قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم؛ رجل بايع إمامًا ثم خانته، ورجل حلف بعد العصر يمينًا فاجرة ليقطع بها مال امرئ مسلم، ورجل فضل عنه ماء بالفلاة فلم يدفعه إلى أخيه.

ويكون اللعان بعد صلاة العصر، وإقامة جماعتها، ولا يلتعن بعد دخول الوقت وقبل إقامتها لقول الله تعالى: (تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ)^(١)، ولأن ما بعد الصلاة وقت للدعاء ولا ارتفاع الأعمال.

(١) سورة: المائدة - الآية: ١٠٦.

الدرس الرابع

الآثار التي تترتب على اللعان

إذا وقع اللعان بين الزوجين كان له عدة آثار تترتب عليه، وأهم هذه الآثار ما يلي^(١):

أولاً: سقوط حد القذف عن الزوج باللعان^(٢):

وإذا قذف الرجل زوجته بالزنا وجب عليه حد القذف، فإذا لاعنها سقط عنه حد القذف، ويدل على ذلك ما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته فقال رسول الله البينة أي حد في ظهرط فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق ولينزلن الله في أمري ما يبيري ظهري من الحد فنزلت (وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ) {النور: ٦}، فسرى عن رسول الله فقال أبشر يا هلال فقد جعل الله لك فرجاً ومخرجاً فقال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي عز وجل.

ثانياً: ثبوت الحد على الزوجة إن لم تلعان^(٣):

إذا لاعن الزوج من زوجته بعد قذفها بالزنا وامتنعت من لعانه كان عليها حد الزنا لأنه بينة حقق بها الزنا عليها فلزمها الحد كالشهادة، فإن كانت الزوجة بكرًا فجلد مائة وتغريب عام، وإن كانت محصنة رجمت.

وإن كانت الزوجة الصغيرة فلا حد عليها لارتفاع القلم عنها لما روى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي ﷺ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يكبر وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.

ثالثاً: سقوط الحد عن الزوجة بلعانها^(٤):

(١) روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٥٦، مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٠، الحاوي ج ١١ ص ٧٤ وما بعدها.

(٢) المهذب ج ٢ ص ١٢٧.

(٣) الحاوي ج ١١ ص ٢٩.

(٤) التكملة الثانية للمجموع ج ١٧ ص ٤٥١.

قلنا بأنه يجب الحد على الزوجة بعد ملاعنة الزوج وامتناع الزوجة من اللعان، فإذا لاعنت بعد لعان الزوج فقد أسقطت حد الزنا عن نفسها، ويدل على سقوط الحد عنها بلعانها قوله عز وجل: (وَيَذَرُوهَا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ) {النور: ٨}.

رابعاً: وقوع الفرقة بين الزوجين:

وإذا لاعن الرجل من زوجته وقعت الفرقة بينهما، وهي فرقة فسخ لحصولها بغير لفظ، وتكون هذه الفرقة على التأبيد بحيث لا يجوز لهما أن يجتمعا بنكاح مدى الحياة. ويدل على أن هذه الفرقة على التأبيد ما يلي:

١- عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبداً^(١).

فدل هذا الخبر على تأييد التحريم بين الزوجين باللعان.

٢- روى عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أنه قال في حديث المتلاعنين: مضت السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبداً^(٢).

ولا تتوقف هذه الفرقة على لعان الزوجة بل يكفي بلعان الزوج، فإذا لاعن الزوج وقعت الفرقة سواء لاعنت الزوجة أم لا.

وإذا كان متزوجاً بأمة فلاعن زوجته الأمة ثم اشتراها بعد اللعان حرم عليه الاستمتاع بها بملك اليمين لتأبيد تحريمها عليه باللعان.

خامساً: وجوب العدة للزوجة:

ويترتب على وقوع الفرقة بلعان الزوج، أن على الزوجة العدة سواء لاعنت أو حدثت إذا كانت مدخولاً بها، ولها السكنى زمان عدتها.

سادساً: يجوز للزوج نكاح أربع سواها ومن يحرم جمعه معها كأختها وعمتها وغير ذلك من الأحكام المرتبة على البينونة وإن لم تنقض عدتها.

(١) السنن الكبرى للبيهقي - كتاب اللعان - باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي الولد وحده المرأة إن لم تلتعن.

(٢) المرجع السابق.

سابعاً: نفي نسب الولد^(١):

وإذا أتت الزوجة بولد وتيقن الزوج أنه ليس منه وجب عليه نفيه باللعان وهذا هو الصحيح، وقيل لا يجب النفي باللعان وإنما ينتفي نسبه بدون لعان لتأكد أنه ليس من صلبه.

ويحصل اليقين للزوج بأن الولد ليس من صلبه إذا لم يطأها أصلاً أو وطنها وأتت بولد لأكثر من أربع سنين من وقت الوطء أو لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء.

وإذا كان الزوج يطأ الزوجة ويعزل عنها فلا يجوز له نفي الولد بذلك على الصحيح، وقيل يجوز له نفي الولد باللعان.

وإذا أتت الزوجة بولد لا يشبه الزوج بأن خالفه في نقص وكمال وقبح ونحوها أو ولدت ولداً أسوداً وهما أبيضان أو عكسه حرم النفي لأنه لا يؤثر الاختلاف في الألوان المتقاربة كالأدمة والسمرة والشقرة والبياض وغيرها.

-وإنما يحتاج الزوج الملاحن إلى نفي نسب ولد يمكن أن يكون من صلبه، فحينئذ يجوز له أن يلاعن لنفي النسب^(٢).

ويدل على مشروعية نفي نسب الولد باللعان ما روي عن بن عمر أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته فانتهى من ولدها ففرق بينهما والحق الولد بالمرأة^(٣).

يدل الحديث على مشروعية اللعان لنفي الولد^(٤).

فإن تعذر كون الولد منه بأن ولدته الزوجة الملاحنة لستة أشهر فأقل من العقد انتفى نسب الولد بلا لعان لانتفاء زمن الوطء والوضع.

(١) روضة الطالبين ج ٨ ص ٣٢٨ - ٣٣٠.

(٢) مغني المحتاج ج ٣ ص ٣٨٠.

(٣) صحيح البخاري - كتاب النكاح - باب ما يلحق الولد بالملاحنة.

(٤) فتح الباري ج ٩ ص ٤٦٠.

أسئلة على الوحدة:-

س١: ما المراد باللعان، وحكمه، والأصل في ورد الشرع به ؟

س٢: ما هي أركان اللعان، وكيفيته، وما هي الشروط التي تشترط فيه ؟

س٣: ما هي الآثار المترتبة على ورود اللعان ؟

الوحدة السابعة

الدية وما يتعلق بها من أحكام

أهداف الوحدة تتمثل فيما يلي:-

- ١-إلقاء الضوء على مفهوم الدية والتطور التاريخي لها.
- ٢-بيان أن إزهاق الروح جريمة بشعة تأبها كل التشريعات السماوية، ومن ثم لو استشرت في قوم لأودت بهم إلي الفناء .
- ٣-بيان أن الشرع كفيل بردع كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة، وكان من بين ما رصده لردع هذه الجريمة الدية، والتي سنتناولها في هذه الوحدة من خلال الدروس الآتية.

الدرس الأول

مفهوم الدية

أولاً: الدية في اللغة: حق القتل. أو المال المؤدى للمجني عليه أو وليه قال تعالى: (.... وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا....) (١).

وهي مصدر ودي القاتل المقتول: إذا أعطى وليه المال الذي هو بدل النفس، وأصلها ودي ودية، فحذفت الواو وعوض عنها بالتاء في آخرها، كالعدة من الوعد، والزينة من الوزن (٢).

ثانياً: في اصطلاح الفقهاء: هي الواجب بجناية علي الحر في نفس أو فيما دونها (٣).

الدرس الثاني

مشروعية الدية

اتفق فقهاء الشافعية وغيرهم علي مشروعية الدية على سبيل الوجوب (٤)، واستدلوا علي ذلك بالكتاب والسنة:

أما الكتاب:

فبقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا...﴾ (٥).

(١) سورة: النساء - الآية: ٩٢.

(٢) لسان العرب لابن منظور مادة "ودي" ٣٨٣/١٥، ٣٨٤، القاموس المحيط للفيروز آبادي ٤/٤٠١، ٤٠٢، حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين ١٠/١٨٢ ط ١ دار إحياء التراث العربي بيروت - سنة ١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م.

(٣) معني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج للخطيب الشربيني ٤/٦٦ ط دار الفكر - بيروت - ١٤١٥ هـ - ١٩٩٥ م.

(٤) انظر: بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ٢/٤٨٨ بتحقيق رضوان جامع رضوان ط ١. مكتبة الإيمان. المنصورة سنة ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م، الحاوي الكبير للماوردي ١٢/٢١٠ بتحقيق الشيخين: علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد الموجود ط دار الكتب العلمية. بيروت. سنة ١٤١٩ هـ. ١٩٩٩ م.

(٥) من الآية ٩٢ من سورة النساء.

وجه الدلالة: إن هذه الآية وإن كانت نصا في دية القتل الخطأ، إلا أن العلماء قد أجمعوا على وجوبها في القتل العمد أيضا في حالة سقوط القصاص أو تعذر استيفائه.

وأما السنة:

فما رواه الأئمة: مالك والنسائي والبيهقي والدارمي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب إلي أهل اليمن كتاباً، وكان في كتابه: " أن من اعتبط مؤمناً^(١) قتلاً عن بينة، فإنه قود، إلا أن يرضي أولياء المقتول، وإن في النفس الدية: مائة من الإبل، وإن في الأنف إذا أوعب جدعه^(٢) الدية، وفي اللسان الدية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذكر الدية، وفي الصلب الدية، وفي العينين الدية، وفي الرجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل، وفي كل إصبع من أصابع الرجل عشر من الإبل، وفي السن خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلي أهل الذهب ألف دينار^(٣) .

قال ابن عبد البر: " لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث بهذا الإسناد. وقد روي مسنداً من وجه صالح، وهو كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة تستغني بشهرتها^(٤) .

(١) أي قتله بغير سبب موجب. من اعتبط الناقة إذا ذبحها من غير مرض ولا داء. (نيل الأوطار للشوكاني ٥٨/٧ ط دار الحديث. القاهرة.).

(٢) أوعب جدعه. بضم الهمزة. علي البناء للمجهول، أي قطع جميعه. (نيل الأوطار ٥٨/٧).

(٣) الموطأ للإمام مالك كتاب العقول باب ذكر العقول ٨٤٩/٢ (١) .. سنن النسائي كتاب القسامة باب عقل الأصابع ٥٨/٨. سنن البيهقي كتاب الديات ٨١/٨، سنن الدارمي كتاب الديات ٢٥٣/٢، ٢٥٦، (٣٦٦)، منتقى الأخبار لابن تيمية مع نيل الأوطار للشوكاني ٥٨، ٥٧/٧. وقد جاء في نيل الأوطار: " وأخرجه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان وابن الجارود والحاكم والبيهقي موصولاً. وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل. وقد صححه جماعة من أئمة الحديث منهم أحمد والحاكم وابن حبان والبيهقي ".

(٤) التمهيد لابن عبد البر ٣٣٨/١٧ تحقيق: مصطفى بن أحمد العلوي، محمد عبد الكبير البكري، نشر: وزارة

عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب سنة ١٣٨٧ هـ. المغني مع الشرح الكبير ٤٨١/٩، ٤٨٢.

الدرس الثالث

كيفية تقدير الدية

اتفق فقهاء الشافعية على أن الإبل أصل في كيفية تقدير الدية. واستدلوا على ذلك بالأحاديث الشريفة الواردة، ومنها:

١. حديث عمرو بن حزم المذكور.

٢. وما رواه الشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: " الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها "(١).

٣. وما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: " في دية الخطأ عشرون حقة(٢)، وعشرون جذعة(٣)، وعشرون بنت مخاض(٤)، وعشرون بنت لبون(٥)، وعشرون بني مخاض ذكر "(٦).

وهل الإبل وحدها هي الأصل في تقدير الدية فتجب فيها ولا تقضي إلا منها ؟ أم أن هناك صنوفاً أخرى من الأموال أصل معها تجب فيها وتقضي من أي منها ؟

اختلف فقهاء الشافعية في ذلك على قولين:

(١) سنن النسائي ٤٢/٨ (٤٧٩٩) تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة ط ٢ مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب . سنة ١٤٠٦ - ١٩٨٦ م. السنن الكبرى للبيهقي ٤٤/٨ (١٥٧٧٠).

(٢) الحقة هي ما أكملت ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. سميت بذلك : لأنها استحققت أن تتركب ويحمل عليها. ولأنها استحققت أن يطرقها الفحل واستحق الفحل أن يطرق. (مغني المحتاج للخطيب الشربيني ٥٠٢/١ ط دار الفكر سنة ١٤١٥ هـ ١٩٩٥ م).

(٣) الجذعة هي ما أكملت أربع سنوات ودخلت في الخامسة. وسميت بذلك : لأنها أجذعت مقدم أسنانها أي سقطته. وقيل: لتكامل أسنانها. وقيل: لأن أسنانها لا تسقط بعد ذلك. (المرجع والموضع السابقان).

(٤) بنت المخاض هي التي أكملت سنة ودخلت في الثانية. سميت بذلك : لأن أمها بعد سنة من ولادتها أن لها أن تحمل مرة أخرى فتصير من المخاض أي الحوامل. (مغني المحتاج ٥٠٢/١).

(٥) بنت اللبون هي ما أكملت سنتين ودخلت في الثالثة. وسميت بذلك : لأن أمها أن لها أن تلد فتصير لبونا. (المرجع السابق ٥٠٢/١).

(٦) سنن أبي داود ٥٩٢/٢ (٤٥٤٥) تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط دار الفكر، سنن النسائي ٤٣/٨ (٤٨٠٢) سنن ابن ماجه ٨٧٩/٢ . ٢٦٣١) تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار الفكر. بيروت .

سنن الدارقطني ١٧٢/٣ . ٢٦٢٠) تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني المدني، ط دارالمعرفة. بيروت . سنة ١٣٨٦ هـ ١٩٦٦ م.

القول الأول: يري أصحابه أن الإبل وحدها هي الأصل في الدية، لا تجب إلا فيها ولا تقضي إلا منها، اللهم إلا إذا أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها، فيعدل عنها إلي قيمتها من الدنانير والدرهم بالغة ما بلغت بحسب اختلافها في البلدان والأزمان، وهذا ما ذهب إليه ذهب الشافعي في الجديد^(١).

القول الثاني: يري أصحابه أن أصول الدية ثلاثة تقضي من أي منها بحسب ما يختار القاتل أو أوليائه، ولا خيار لأولياء المقتول في ذلك، وهذه الثلاثة هي: الإبل والذهب والفضة، وهذا ما ذهب إليه الشافعي في القديم^(٢).

الأدلة

استدل أصحاب القول الأول القائل بأن الأصل في تقدير الدية يكون بالإبل وحدها بالسنة، وذلك كما يلي:

١- حديث ابن عمر السابق الذي رواه الشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: "الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ألا إن قتيل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفه في بطونها أولادها"^(٣).

وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي ﷺ فرق فيه بين دية العمد والخطأ، فغلظ بعضها وخفف بعضها، ولا يتحقق هذا في غير الإبل^(٤).

٢- وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: " أكرموا الإبل، فإن فيها رقوء الدم ".

وجه الدلالة من هذا الحديث: واضح ؛ حيث إن النبي ﷺ خص الإبل بهذه الصفة؛ لأنها تبذل في الدية، فيعفى بها عن القود، فدل على اختصاصها بالحكم^(١).

(١) انظر: الحاوي ٢٢٦/١٢ وما بعدها.

(٢) انظر: المرجع السابق.

(٣) سبق تخريجه.

(٤) الحاوي ٢٢٨/١٢، المغني ٤٨٣/٩.

٣- وما رواه الأئمة أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ﷺ يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمئة دينار أو عدها من الورق ويقومها على أمان الإبل، فإذا غلت رفع في قيمتها وإذا هاجت رخصاً نقص من قيمتها وبلغت على عهد رسول الله ﷺ ما بين أربعمئة دينار إلى ثمانمئة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم... " (٢).

ووجه الدلالة من هذا الحديث: واضح أيضاً؛ حيث إنه بين أن النبي ﷺ كان يقوم الدنانير والدرهم بالإبل حين تجب الدية على أهل القرى الذين لا توجد عندهم إبل، أي أنه لا جعل للإبل هي الأصل في تقويم الدنانير والدرهم، وهذا يدل على أنها أصل وحدها.

استدل أصحاب القول الثاني القائل بأن الأصل في تقدير الدية يكون الإبل والذهب والفضة بالسنة وذلك كما يلي:

١- ما رواه أبو داود والبيهقي وعبد الرزاق والدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما " أن رجلاً من بني عدي قتل، فجعل النبي ﷺ ديته اثني عشر ألف درهم " (٣).

٢- ما رواه الأئمة: مالك والنسائي والبيهقي والدارمي عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده: أن رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن كتاباً، وكان في كتابه: ".... وإن الرجل يقتل بالمرأة، وعلي أهل الذهب ألف دينار " (٤).

وجه الدلالة من هذين الحديثين: واضح؛ حيث إن النبي ﷺ قضى فيهما بالدية من هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والذهب والفضة، فدل على التخيير فيها، وعلي أنها كلها أصول في الدية (١).

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢٢٨/١٢.

(٢) المسند للإمام أحمد ٢١٧/٢ (٧٠٣٣)، سنن أبي داود ١٥٩/٢ (٢٩٧٢)، وفي سننه محمد بن راشد الدمشقي، قال الزيلعي: ومحمد بن راشد الدمشقي فيه مقال "نصب الراية الأحاديث الهداية للزيلعي ٣٩١/٤ تحقيق: محمد يوسف البنوري ط دار الحديث - مصر، سنة ١٣٥٧هـ.

(٣) سنن أبي داود ٥٩٢/٢ (٤٥٤٦) السنن الكبرى للبيهقي ٧٨/٨ (١٥٩٥٦). المصنف لعبد الرزاق ٢٩٦/٩ سنن الدارمي ٢٥٢/٢ تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي ط دار الكتاب العربي - بيروت - سنة ٢٥٠٧هـ.

(٤) سبق النص الكامل للحديث وتخرجه.

وقد نوقش هذا الاستدلال: بأنه غير صحيح؛ لاحتمال أن يكون النبي ﷺ قضى بالدية من الذهب والفضة عند فقد الإبل حقيقة أو حكماً^(٢).

القول المختار:

بعد هذا العرض لقولي الشافعية في هذه المسألة وأدلتهم وما دار حولها من مناقشات، أري أن المختار هو ما قال به أصحاب القول الأول من أن الإبل وحدها هي الأصل في الدية، وأن غيرها لا يكون إلا عند فقدانها حقيقة بانعدامها، أو حكماً بغلائها عن ثمن مثلها، وفي هذه الحالة يعدل عنها إلي قيمتها من الدنانير والدراهم بالغة ما بلغت بحسب اختلافها في البلدان والأزمان ؛ وذلك لقوة أدلته وصحته وسلامته من المعارضة والمناقشة. والله أعلم.

(١) البدائع ٣٧٥/٧.

(٢) الحاوي الكبير ٢٢٩/١٢، المغني ٤٨٣/٩.

الدرس الرابع

أقسام الدية عند الشافعية

تمهيد:-

لما كان القتل ينقسم إلى عمد محض، وخطأ محض، وعمد الخطأ أو خطأ العمد؛ فإن الدية تنقسم . تبعاً لذلك . إلى ثلاثة أقسام: دية العمد المحض، ودية الخطأ المحض، ودية عمد الخطأ أو خطأ العمد.

الفقرة الأولى: دية العمد المحض عند الشافعية

إن القتل العمد المحض هو ما كان القاتل فيه عامداً في فعله بما يقتل مثله، قاصداً لقتله، وذلك بأن يضربه بسيف أو ما يقتل مثله من المثلل عامداً في الفعل قاصداً للنفس^(١).

ومن ثم فإن هذا النوع من القتل يستوجب القصاص من القاتل، كما أن هناك أسباباً يسقط بها القصاص بعد وجوبه من أهمها: العفو عنه من صاحب الحق فيه بأن يقول: عفوت أو أسقطت أو أبرأت أو رهبت وما يجري هذا المجرى.

وهذا العفو قد يكون مطلقاً . لا إلى بدل . ، وقد يكون إلى بدل، وهو ما يسمى بالصلح على مال^(٢).

فإذا عفا أولياء المقتول عن القصاص إلى الدية كان لهم ذلك، ولزم القاتل دفع ما تم الصلح عليه من المال، قلّ عن الدية أم كثر باتفاق الفقهاء^(٣).

وذلك لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ...﴾^(٤).

يعني: فمن عفي عن دمه من أخيه بعد استحقاقه نظير دفعه الدية، فعلى الطالب اتباع بالمعروف، وعلى القاتل أن يؤديها إليه بإحسان يعني من غير ضرر ولا مظل^(٥).

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢١٠/١٢.

(٢) الحاوي الكبير ٢١٠/١٢، منار السبيل ٢١٧/٢ وما بعدها.

(٣) الحاوي الكبير ٢١٠/١٢، المغني ٤٧٨/٩.

(٤) من الآية ١٧٨ من سورة البقرة.

ولما رواه الترمذي وابن ماجة والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة. وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل "(٢). وإذا ثبت هذا فإن دية القتل العمد المحض تختص بثلاثة أحكام هي: أنها مغلظة، وحالة، وفي مال القاتل لا العاقلة. وفي الأغصان التالية بيان ذلك:

الفقرة الثانية: تغليظ دية العمد المحض

يكاد يتفق الفقهاء علي أن دية العمد المحض مغلظة (٣)، لكن الشافعية ذهبوا إلى أن التغليظ للدية يكون بدفعها مثلثة: أي ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة في بطونها أولادها (٤)، واستدلوا على ذلك بالسنة والآثار والمعقول:

أما السنة فمنها:

١- ما رواه الشافعي وأحمد والنسائي والبيهقي وغيرهم أن رسول الله ﷺ قام يوم فتح مكة على درجة الكعبة فحمد الله وأثنى عليه وقال: " الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب

(١) تفسير القرآن العظيم لابن كثير تحقيق: سامي بن محمد سلامة ١/٤٩٠، ٤٩١ ط ٢ دار طيبة للنشر والتوزيع سنة ١٤٢٠هـ - ١٩٩٩ م

(٢) صحيح الترمذي ١١/٤ (١٣٨٧) بتحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين ط دار إحياء التراث العربي - بيروت .. سنن ابن ماجة ٢/٨٧٦ (٢٦٢٦)، السنن الكبرى للبيهقي ٨/٦٠ (١٥٨٥٥). قال الترمذي: " حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن غريب ".

(٣) وقد شذ عن ذلك أبو ثور فيما روي عنه فقال بأن الديات كلها أخماس . مخففة . كدية الخطأ ؛ لأنها بدل متلف، فلا تختلف بالعمد والخطأ كسائر المتلفات. (المغني مع الشرح الكبير ٩/٦٩٧). لكن هذا رأي مردود بصراحة ووجه الأدلة النقلية والعقلية علي تغليظ دية العمد المحض كما سبني إن شاء الله تعالى.

(٤) البدائع ٣٧٦/٧، تكملة شرح فتح القدير . نتائج الأفكار . لقاضي زادة، ومعه العناية علي الهداية للبابرتي ١٠/٢٧٢، ٢٧٣ ط دار الفكر . بيروت .. الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/٢٦٧، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد ٢/٤٨٩ شرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان . مكتبة الإيمان . المنصورة سنة ١٤١٧هـ - ١٩٩٧ م. الحاوي الكبير للماوردي ١٢/٢١٣، المغني والشرح الكبير ٩/٤٩٠، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ١٠/٥٨ تحقيق أبي عبد الله محمد حسن الشافعي ط ١ دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١٤١٨هـ - ١٩٩٧ م

وحده، ألا إن قتل العمد الخطأ بالسوط والعصا شبه العمد فيه مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفه في بطونها أولادها " (١).

٢. ما رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: " من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا أخذوا الدية. وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفه. وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك لتشديد العقل " (٢).

وجه الدلالة من هذين الحديثين واضح ؛ حيث إن النبي ﷺ نص في الحديث الأول منهما علي وجوب أن يكون من بين الإبل المدفوعة في دية العمد الخطأ وشبه العمد أربعون خلفة في بطونها أولادها. ونص في الحديث الثاني علي أن الستين الآخرين يدفعون ثلاثين حقة وثلاثين جذعة، كما نص فيه علي أن ذلك إنما كان لتشديد العقل، فدل علي ما نقول (٣).

وأما الآثار فمنها: ما رواه مالك في الموطأ عن عمرو بن شعيب: أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزى في جرحه فمات، فقدم سراقه بن جعشم علي عمر بن الخطاب فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد علي ماء قديد عشرين ومائة بغير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفه. ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا. قال: خذها فإن رسول الله ﷺ قال: " ليس لقاتل شيء " (٤).

فهذا الأثر واضح الدلالة علي أن تغليظ الدية يكون بتثليثها علي الوجه المبين. وقد قال بنحوه عثمان وعلي وكثير من الصحابة والتابعين (٥).

وأما المعقول: فهو أنه لما كان تغليظ الدية ضد تخفيفها اقتضي أن يكون أدني ما في المغلظة من الأسنان هو أعلي أسنان المخفة؛ لأجل علتين، فوجب أن يكون المستحق فيها الجذاع والحقاق، دون بنات لبون وبنات مخاض (١).

(١) سبق تخريجه.

(٢) سبق تخريجه.

(٣) الحاوي الكبير ١٢/٢١٣، ١١٤، المغني ٩/٤٩١، تكملة الفتح والعناية ١٠/٢٧٣.

(٤) الموطأ للإمام مالك كتاب العقول باب (١٧) ٨٦٧/٢ (١٥٥٧).

(٥) الحاوي الكبير ١٢/٢١٣، ١١٤، المغني ٩/٤٩١، تكملة الفتح والعناية ١٠/٢٧٣، البدائع ٧/٣٧٦، المصنف لعبد

الرزاق ٩/٢٨٣، ٢٨٤ (١٧٢١٤، ١٧٢١٥، ١٧٢١٦، ١٧٢١٧، ١٧٢١٨، ١٧٢١٩، ١٧٢٢٠،

(١٧٢٢١، ١٧٢٢٢).

الفرقة الثالثة: حلول دية القتل العمد.

حلول الدية معناه: وجوبها في الحال وعدم تأجيلها.

اتفق الفقهاء على أن دية القتل العمد المحض تجب حالة غير مؤجلة^(٢).

كما أن فقهاء الشافعية ذهبوا إلى أن القتل العمد الذي دخلته شبهة كما لو قتل الأب ولده عمداً، تجب الدية فيه حالة غير مؤجلة^(٣).

وعلة ذلك: أن سبب الوجوب وجد حالاً فتجب الدية حالة؛ إذ الأصل أن الحكم يثبت على وفق السبب، إلا أن التأجيل في الخطأ ثبت معدولاً به عن الأصل؛ لإجماع الصحابة ~، أو ثبت معلولاً بالتخفيف على القاتل حتى تحمل عنه العاقلة. والعامد يستحق التغليظ ولهذا وجب في ماله لا على العاقلة^(٤).

وبناء على هذا: " فإن العاقلة لا تحمل دية العمد، وأنها تحمل دية الخطأ " ^(٥) ودليل ذلك ما يلي:

١- فما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رسول الله ﷺ: " لا تعقل العاقلة عمداً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعتراقاً ولا ما دون أرش الموضحة " ^(٦).

(١) الحاوي الكبير ١٢/٢١٤.

(٢) انظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤/٢٦٧، الحاوي الكبير للماوردي ١٢/٢١٤، المغني ٩/٤٩٠، الروض المربع ١/٦٤٦.

(٣) انظر: المراجع السابقة.

(٤) المغني والشرح الكبير ٩/٤٩٠.

(٥) الإجماع لابن المنذر ص ١٤٢ تحقيق عبد الله عمر البارودي ط دار الجنات.

(٦) أخرج ابن أبي شيبة في " مصنفه " عن النخعي قال: " لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا يعقل العمد ولا الصلح ولا الاعتراف ". انتهى. وأخرج عبد الرزاق في " مصنفه " عن الشعبي قال: أربعة ليس فيهن عقل على العاقلة وإنما هي في ماله خاصة: العمد والاعتراف والصلح والمملوك انتهى. وأخرج عن الزهري قال: العمد وشبه العمد والاعتراف والصلح لا تحمله عنه العاقلة هو عليه في ماله ". (نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي وبحاشيته بغية الأملعي في تخريج الزيلعي ٤/٤٣٧ تحقيق: محمد يوسف البنوري ط دار الحديث - مصر، ١٣٥٧ هـ). وانظر أيضاً: السنن الكبرى للبيهقي ٨/١٠٤، المصنف لعبد الرزاق ٩/٤١٠ (١٧٨١١، ١٧٨١٢، ١٧٨١٥، ١٧٨١٧) تلخيص الحبير لابن حجر ٤/٣٣. وقيل في معنى قوله ×: " ولا عبداً " أن المراد منه العبد المقتول وهو الذي قتله مولاه، وهو مأذون مديون أو المكاتب، لا العبد القاتل؛ لأنه لو كان

٢- وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "...ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود عن والده..."^(١). أي أن جناية كل منهما قاصرة عليه لا تتعداه إلى غيره.

٣- وما رواه الأئمة: الشافعي وأحمد والحاكم وصححه، وابن حبان والدارمي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله ﷺ فسلم عليه أبي وجلسنا ساعة فتحدثنا. فقال رسول الله ﷺ لأبي: ابنك هذا قال: إي ورب الكعبة. قال: حقا؟ قال: أشهد به فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكاً من ثبت شبهي بأبي و من حلف أبي على ذلك. قال: ثم قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك و لا تجني عليه " قال: و قرأ رسول الله ﷺ: ﴿ أَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِرِ الْأُولَى ﴾^(٢).

ولأن الدية بدل متلف، وبديل المتلف يجب على المتلف.

ولأن موجب الجناية أثر فعل الجاني، فيجب أن يختص بضررها كما يختص بنفعها، فإنه لو كسب كان كسبه له دون غيره. وقد ثبت حكم ذلك في سائر الجنايات والأكساب^(٣).

كذلك لكان من حق الكلام أن يقول: لا تعقل العاقلة عن عبد: لأن العرب تقول: عقلت عن فلان، إذا كان فلان قاتلاً، وعقلت فلاناً، إذا كان فلان مقتولاً، كذا فرق الأصمعي. (البدائع ٣٧٧/٧).

(١) جزء من حديث رواه الأئمة: أحمد في مسنده ٤٩٨/٣ (١٦١٠٨). والترمذي في صحيحه ٤٦١/٤ (٢١٥٩) واللفظ له، وابن ماجه في سننه ٨٩٠/٢ (٢٦٦٩). عن سليمان ابن عمرو بن الأحوص عن أبيه ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع للناس: "أي يوم هذا؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود عن والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبداً، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به". قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح".

(٢) الأم للإمام الشافعي كتاب الحكم في قتال المشركين ومسألة مال الحربي باب الفداء بالأساري ٣٦١/٤، المسند للإمام أحمد ٢٢٦/٢ (٧١٠٦، ٧١٠٧، ٧١٠٨، ٧١٠٩). المستدرک للحاكم ٤٦١/٢ (٣٥٩٠) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا ط ١ دارالكتب العلمية - بيروت .. ١٤١١ هـ - ١٩٩٠ م، صحيح ابن حبان ٣٣٧/١٣ (٥٩٩٥)، تحقيق: شعيب الأرنؤوطي ط ٢ مؤسسة الرسالة - بيروت ١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م، سنن الدارمي ٢٦٠/٢ (٢٣٨٨) تحقيق: فواز أحمد زمرلي، خالد السبع العلمي ط ١ دارالكتاب العربي - بيروت. سنة ١٤٠٧ هـ. والآيات من ٥٦: ٣٨ من سورة النجم.

(٣) المغني ٤٨٩/٩.

ولأن تحمل العاقلة الدية في الخطأ وشبه العمد إنما كان علي طريق التخفيف عن الخاطئ والرفق به؛ لكثرة الواجب عليه وعجزه في الغالب عن تحمله، مع وجوب الكفارة عليه، والعامد لا عذر له فلا يستحق التخفيف، ولا يوجد فيه المعنى المقتضي للمواساة في الخطأ^(١).

الفقرة الرابعة: دية الخطأ المحض وما يتعلق بها من أحكام

إن الخطأ المحض هو ما كان القاتل فيه غير عامد للفعل ولا قاصد للنفس، وذلك بأن يرمي هدفاً أو صيداً، أو يلقي حجراً فيعترضه إنسان فتصيبه الرمية فيموت منها، فيكون مخطئاً في الفعل والقصد^(٢).

وبعكس دية العمد المحض، فإن دية الخطأ المحض مختصة بثلاثة أحكام هي: أنها مخففة، ومؤجلة، وعلي العاقلة، وضابط التخفيف أن دية الخطأ المحض عشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، ودليل ذلك ما يلي:-

١- ما روي أن النبي ﷺ ودي سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بمائة من إبل الصدقة^(٣). وإبل الصدقة ليس فيها بنو مخاض^(٤).

(١) البدائع ٣٧٧/٧، المغني ٤٩٠/٩.

(٢) الحاوي الكبير للماوردي ٢١٠/١٢.

(٣) رواه الإمام مالك والشيخان عن سهل بن أبي حثمة أنه أخبره رجال من كبراء قومه: أن عبد الله بن سهل ومحبيصة خرجا إلى خيبر من جهد أصابهم، فأتى محبيصة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قتل وطرح في قفبر بئر أو عين. فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه. فقالوا: والله ما قتلناه. فأقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك، ثم أقبل هو وأخوه حويصة وهو أكبر منه، وعبد الرحمن، فذهب محبيصة ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال له رسول الله ﷺ: "كَبْرَكَ" يريد السن. فتكلم حويصة ثم تكلم محبيصة. فقال رسول الله ﷺ: "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب" فكتب إليهم رسول الله ﷺ في ذلك فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله ﷺ: "لحويصة ومحبيصة وعبد الرحمن: "أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟" فقالوا: لا. قال: "أتحلف لكم يهود؟" قالوا: ليسوا بمسلمين. فوداه رسول الله ﷺ من عنده فبعث إليهم بمائة ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. قال سهل: لقد ركضتني منها ناقة حمراء. قال مالك الفقير هو البئر. (الموطأ للإمام مالك كتاب القسامة بال تبذنة أهل الدم بالقسامة ٢٧٧/٢، ٢٧٨ (١)، صحيح البخاري كتاب الديات باب القسامة، كتاب الأحكام باب كتاب الحاكم غلي عماله ٢٣٩/١٢، ٢٩٦/١٣ (٧١٩٢، ٦٨٩٨) مع فتح الباري لابن حجر العسقلاني ط دار الريان للتراث. القاهرة.، صحيح مسلم بشرح النووي كتاب القسامة ١٤٣/١١ وما بعدها (١٦٦٩/١).

(٤) المغني ٤٩٦/٩، نصب الراية للزليعي ٤١٨/٤.

٢. ما رواه الدارقطني والبخاري وابن أبي شيبة عن قتادة عن لاحق بن حميد عن أبي عبيدة عن ابن مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماساً: عشرون جذعة وعشرون حقة وعشرون بنات لبون وعشرون بنو لبون ذكور وعشرون بنات مخاض " (١).

٣. ما رواه إسماعيل بن عياش عن الحجاج عن زيد بن حية عن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قضى رسول الله ﷺ في دية الخطأ أخماساً: خمساً جذاع، وخمساً حقا، وخمساً بنات لبون، وخمساً بنات مخاض، وخمساً بني لبون ذكور " (٢).

قال الماوردي بعد أن روي هذا الحديث: " وهذه الرواية أثبت من رواية عبد الرحمن بن سليمان، وأشبه بما رواه عن ابن مسعود ابنه أبو عبيدة وعلقمة، وهو لا يفتي بخلاف ما يروي " (٣).

ما حكاه الماوردي عن إجماع الأمة، حيث قال: "... ثم يدل عليه ما حكاه الشافعي عن سليمان بن يسار من إجماع الصحابة، أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وسليمان تابعي، وإشارته إلي من تقدمه محمولة على الصحابة، فصار ذلك إجماعاً نقله عنهم " أ. هـ (٤).

الفقرة الخامسة: تأجيل دية الخطأ المحض

وقد اتفق الفقهاء على أن دية الخطأ المحض تقسط على ثلاث سنين (٥).

واستدلوا على ذلك بالسنة والآثار وإجماع الصحابة ~ والمعقول:

أما السنة:

(١) سنن الدارقطني ١٢/٣، مسند البخاري ٣٠٥/٥ (١٩٢٣)، المصنف لابن أبي شيبة ٣٤٦/٥ (٢٦٧٤٨). قال البخاري:

وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن عبد الله مرفوعاً إلا بهذا الإسناد.

(٢) رواه الدارقطني في سننه ١٧٥/٣ (٢٦٧).

(٣) الحاوي ٢٢٤/١٢.

(٤) الحاوي الكبير ٢٢٤/١٢.

(٥) البدائع ٤٧٥/٧، بداية المجتهد ٤٩٤/٢ وفيه: "وأما متى تجب؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في ثلاث

سنين". الحاوي ٢١٢/١٢، المغني ٤٩٨/٩، نيل الأوطار للشوكاني ١٤٣/٧ إدارة الطباعة المنبرية.

فما رواه الشافعي في المختصر قال: " لم أعلم مخالفا أن النبي ﷺ قضى بالدية على العاقلة، ولا اختلاف بين أحد علمته في أن النبي ﷺ قضى بها في ثلاث سنين" (١).

وما رواه البيهقي في سننه من طريق ابن لهيعة عن يحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: من السنة أن تتجم الدية في ثلاث سنين (٢).

وأما الآثار فمنها:

١- ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الدية الكاملة في ثلاث سنين، وجعل نصف الدية في سنتين، وما دون النصف في سنة. قال بن جريج: وجعل عمر الثلاثين في سنتين (٣).

٢- وما رواه البيهقي عن يزيد بن أبي حبيب: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قضى بالعقل في قتل الخطأ في ثلاث سنين (٤).

٣- وما رواه عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: تؤخذ الدية في ثلاث سنين (٥).

وأما إجماع الصحابة رضي الله عنهم: فقد حكاه غير واحد من أهل العلم منهم:

(١) مختصر المزملي ص ٢٦٢، قال الرافعي: " تكلم أصحابنا في ورود الخبر بذلك: فمنهم من قال: ورد ونسبه إلى رواية علي عليه السلام. ومنهم من قال ورد أنه ﷺ قضى بالدية على العاقلة، وأما التأجيل فلم يرد به الخبر وأخذ ذلك من إجماع الصحابة.

وقال ابن المنذر: ما ذكره الشافعي لا نعرفه أصلا من كتاب ولا سنة. وقد سئل عن ذلك أحمد بن حنبل فقال لا نعرف فيه شيئا فقل: إن أبا عبد الله يعني الشافعي رواه عن النبي ﷺ فقال لعله سمعه من ذلك المدني: فإنه كان حسن الظن به. يعني إبراهيم بن أبي يحيى. وتعقبه ابن الرفعة بأن من عرف حجة علي من لم يعرف. (نيل الأوطار للشوكاني ١٤٣/٧).

(٢) السنن الكبرى للبيهقي ١١٠/٨ (١٦١٦٩).

(٣) السنن الكبرى للبيهقي ١٠٩/٨ (١٦١٦٨)، المصنف لعبد الرزاق ٤٢٠/٩ (١٧٨٥٧، ١٧٨٥٨)، المصنف لابن أبي شيبة ٤٠٦/٥ (٢٧٤٣٨).

(٤) السنن الكبرى للبيهقي ١١٠/٨ (١٦١٦٩).

(٥) المصنف لعبد الرزاق ٤٢١/٩ (١٧٨٦١).

الإمام الكاساني؛ حيث قال: "...فإن كل الدية تؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين؛ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، فإن سيدنا عمر رضي الله عنه قضى بالدية على العاقلة في ثلاث سنين ولم ينكر عليه أحد من الصحابة فيكون إجماعاً" ^(١).

والإمام ابن قدامة؛ حيث قال: "ولا خلاف بينهم في أنها مؤجلة في ثلاث سنين؛ فإن عمر وعلياً رضي الله عنهما جعلاً دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين ولا نعرف لهما في الصحابة مخالفاً فاتبعهم على ذلك أهل العلم" ^(٢).

وأما المعقول: فهو أن دية القتل الخطأ مال يجب على سبيل المواساة فلم يجب حالاً تخفيفاً على متحمله. وهم العاقلة. كالزكاة ^(٣).

الفقرة السادسة: وجوبها على العاقلة

ذهب الشافعية وغيرهم إلى أن دية الخطأ المحض تجب على عاقلة الجاني ^(٤).

واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والأثر والإجماع والمعقول:

أما الكتاب: فقوله تعالى: "...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى..." ^(٥)، وتحميل العاقلة من جملة البر والتقوى، فدخل في عموم الآية.

وأما السنة: فما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنيها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم.

(١) البدائع ٤٧٥/٧.

(٢) المغني ٤٩٨/٩.

(٣) المرجع السابق.

(٤) لبدائع ٣٧٧/٧، المدونة الكبرى للإمام مالك ٦٤٠/٤، الأم للإمام الشافعي ٥٠/٥، مغني المحتاج ٥٠٤/٤، كفاية الأخيار للحصني ٥٩٠/١، حدائق الأزهار والسيول الجرار ٤١٦٠٤١٥/٤.

(٥) البدائع ٣٧٧/٧، المدونة الكبرى للإمام مالك ٦٤٠/٤، الأم للإمام الشافعي ٥٠/٥، مغني المحتاج ٥٠٤/٤، كفاية الأخيار للحصني ٥٩٠/١، حدائق الأزهار والسيول الجرار ٤١٦٠٤١٥/٤.

فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل ؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ: " إنما هذا من إخوان الكهان " من أجل سجعه الذي سجع (١).

وأما الأثر: فما رواه البيهقي في سننه عن الحسن رضي الله عنه قال: إن عمر رضي الله عنه بلغه أن امرأة بغية يدخل عليها الرجال، فبعث إليها رسولاً، فأتاها الرسول فقال: أجيبني أمير المؤمنين. ففزعت فزعة وقعت الفزعة في رحمها فتحرك ولدها، فخرجت فأخذها المخاض، فألقت غلاماً جنيناً، فأتى عمر بذلك فأرسل إلى المهاجرين فقص عليهم أمرها. فقال: ما ترون ؟ فقالوا: ما نرى عليك شيئاً يا أمير المؤمنين؛ إنما أنت معلم ومؤدب. وفي القوم علي، وعلي ساكت. قال: فما تقول أنت يا أبا الحسن ؟ قال: أقول إن كانوا قاربوك في الهوى فقد أثموا، وإن كان هذا جهد رأيهم فقد أخطأوا. وأرى عليك الدية يا أمير المؤمنين. قال: صدقت اذهب فأقسمها على قومك. وفي رواية: عزمت عليك أن لا تجلس حتى تضربها على قومك (٢).

وأما الإجماع: فقد حكاها الإمام الماوردي . - بعد أن روي هذه القصة فقال: " ولم يخالفه منهم ولا من جميع الأمة أحد مع انتشار القضية وظهورها في الكافة، فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه " (٣).

وأما المعقول فمن وجوه:

أحدها: أن اختصاص العاقلة بالاسم موجب لاختصاصهم بالحكم، وفقد الحكم يوجب زوال الاسم.

والثاني: أن العقل في كلامهم المنع، وقد كانت العرب في الجاهلية يمنعون عن القاتل بأسياقهم، فلما منعهم الإسلام من السيف، عوض منه منعهم منه بأموالهم ح ولذلك انطلق اسم العاقلة عليهم (١).

(١) صحيح البخاري كتاب الطب باب (٤٥) الكهانة ٢١٧٢/٥ (٥٤٢٦). تحقيق د. مصطفى ديب البغا ط ٣ دار ابن كثير.

اليمامة. بيروت. سنة ١٤٠٧ هـ. ١٩٨٧ م، صحيح مسلم كتاب القسامة والمحربين والقصاص والدية باب (١١)

دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وسبه العمد ١٣٠٧/٢ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ط دار

إحياء التراث العربي. بيروت.

(٢) السنن الكبرى للبيهقي ١٢٣/٦ (١١٤٥٢، ١١٤٥٣).

(٣) المرجع السابق ٣٤٢/١٢.

والثالث: أن النفوس مغلظة علي الأموال، وقتل الخطأ أكثر بين الناس، وفي إيجاب الدية علي القاتل في ماله أحد أمرين: إما استئصال ماله إن كان واحداً، وقل أن يتسع لتحمل الدية مال الواحد، وإما إهدار الدم إن كان معدماً، وفي تحمل العاقلة عنه مواساة تقضي إلي حفظ الدماء واستبقاء الأموال، وهذا أدعي إلي المصلحة وأبعث علي التعاطف.

والرابع: أنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في الأموال، وهو زكاة الفطر، جاز أن يتحمل بعض حقوق الأدميين في الأموال، وهو ديات الخطأ^(٢).

(١) المرجع السابق.

(٢) انظر: الحاوي الكبير ١٢/٣٤٢.

الفقرة السابعة: أحكام دية عمد الخطأ

إن عمد الخطأ هو ما كان القاتل فيه عامداً في الفعل غير قاصد للقتل، وذلك بأن يعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب، وإن جاز أن يقتل، كالسوط والعصا، وما توسط من المثل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل، فيأخذ شبهها من العمد لعمده للفعل، ويأخذ شبهها من الخطأ؛ لعدم قصده للقتل، فسمي عمد الخطأ؛ لوجود صفة العمد في الفعل، وصفة الخطأ في عدم القصد^(١).

ودية عمد الخطأ مختصة بثلاثة أحكام:

أولها: مأخوذ من أحكام العمد المحض، وهو تغليظها.

والثاني والثالث: مأخوذان من أحكام الخطأ المحض، وهو تأجيلها ووجوبها علي العاقلة.

أما الحكم الأول والثاني فلا فرق في الكلام فيهما بين العمد وشبه العمد أو عمد الخطأ؛ وعليه فلا داعي لإعادة ما قلناه هنا.

وأما الحكم الثالث وهو وجوبها علي العاقلة، ففيه بعض اختلاف؛ حيث قد اختلف الفقهاء في من يتحمل دية القتل شبه العمد أو خطأ العمد إلي مذهبين:

المذهب الأول: يري أصحابه أنها علي العاقلة روي هذا عن الشعبي والنخعي والحكم والثوري وإسحاق وابن المنذر، وإليه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة في ظاهر المذهب^(٢).

المذهب الثاني: يري أصحابه أنها علي القاتل لا علي عاقلته. وروي هذا عن ابن سيرين والزهري والحارث العكلي وابن شبرمة وقتادة وأبي ثور، واختاره أبو بكر عبد العزيز، وإليه ذهب المالكية في مقتضي مذهبهم؛ لأنهم يرون أن شبه العمد من باب العمد^(٣).

الأدلة والمناقشات

أدلة المذهب الأول:

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٢١٠/١٢.

(٢) بدائع الصنائع للكاساني ٣٧٢/٧، اللباب في شرح الكتاب للغنيمي ٤٢/٣، روضة الطالبين للنووي ٣٦٧/٣.

تكملة المجموع للمطيعي ١٥٠/١٩، الحاوي الكبير للماوردي ٢١٢/١٢، المغني مع الشرح الكبير ٤٩٢.

(٣) المغني ٤٩٢/٩، بداية المجتهد لابن رشد ٤٧٢/٢.

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعقول:

أما السنة: فما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنينها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع^(١).

فهذا الحديث واضح الدلالة علي أن دية عمد الخطأ تكون علي العاقلة؛ حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى في هذه القضية بدية القتيلة علي عاقلة القاتلة، التي كانت قد قتلتها قتلا شبه عمد؛ لأنها رمتها بحجر فقتلتها، ومعلوم أن الحجر لا يقتل غالباً.

وأما المعقول فمن وجهين:

أحدهما: أن العاقلة إنما تعقل الخطأ تخفيفاً على القاتل نظراً له؛ لكونه لم يقصد الوقوع فيه، وفي القتل شبه العمد شبهة عدم القصد؛ لحصوله بآلة لا يقصد بها القتل عادة، كان مستحقاً لهذا النوع من التخفيف^(٢).

والثاني: أنه نوع قتل لا يوجب قصاصاً، فوجب دية علي العاقلة كالخطأ^(٣).

دليل المذهب الثاني:

واستدل أصحاب المذهب الثاني بالمعقول من وجهين:

أحدهما: أن الدية موجب فعل قصد القاتل؛ فلم تحمله العاقلة كالعمد المحض.

والثاني: أنها دية مغلظة فأشبهت دية العمد، ولما كانت دية العمد واجبة علي القاتل، فكذلك يجب أن تكون دية خطأ العمد^(٤).

(١) سبق بيان موضعه في الصحيحين.

(٢) البدائع ٣٧٢/٧، تكملة المجموع للمطيعي ١٥٠/١٩.

(٣) المغني ٤٩٣/٩، تكملة المجموع للمطيعي ١٥٠/١٩.

(٤) المغني ٤٩٢.

لكن هذا استدلال ضعيف ؛ فالقياس على العمد المحض قياس مع الفارق ؛ لأن العمد المحض يغلظ من كل وجه؛ لقصد القاتل الفعل وإرادته القتل. بينما عمد الخطأ يغلظ من وجه، وهو قصد القاتل الفعل، ويخفف من وجه، وهو كونه لم يرد القتل يكون بدفعها فغلظت بتثليثها، أي بوجوب دفعها ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة في بطونها أولادها، وخففت بتحمل العاقلة لها^(١).

وعليه فالراجح من هذين المذهبين هو الأول. والله تعالى أعلم.

(١) المرجع السابق ٤٩٣/٩.

الدرس الخامس

العاقلة التي تتحمل الدية وما يتعلق بها من أحكام

العاقلة هم ضمناء الدية ومتحملوها عن القاتل.

وسموا عاقلة؛ لأنهم يتحملون العقل عن الجاني. والعقل هو الدية، وسميت الدية عقلا ؛ لأنها تعقل لسان ولي المقتول.

وقيل: إنما سميت العاقلة؛ لأنهم يعقلون القاتل أي يمنعون عنه، والعقل: المنع؛ ولذا سمي العقل في الناس عقلا ؛ لأنه يمنع من القبائح.

وقيل: إنهم سموا عاقلة ؛ لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها علي باب المقتول^(١).

حكم وجوب الدية علي العاقلة:

للعاقلة جهات عدة هي: العصابة، والموالي، وأهل الديوان، ومولي المولاة، والحلف، والعديد، وبيت مال المسلمين^(٢).

وقد اتفق الفقهاء علي وجوب تحمل بعض هذه الجهات للدية، واختلفوا في بعضها الآخر علي النحو التالي:

-العصابة-

يقصد بالعصابة: أقارب الشخص الذكور من جهة الأب، كالأخوة الأشقاء أو لأب وأبنائهم، والأعمام الأشقاء أو لأب وأبنائهم.

وقد اتفق الفقهاء علي أن هؤلاء يتحملون العقل عن القاتل^(٣).

واختلفوا في الأصول والفروع . الآباء وإن علوا والبنين وإن سفلوا . هل يتحملون في الدية مع العصابة أم لا ؟ ولهم في ذلك مذهبان:

(١) الحاوي الكبير للماوردي ٣٤٠/١٢، المغني والشرح الكبير ٥١٥/٩، الإنصاف للمرداوي ١١٤/١٠، ١١٥.

(٢) وسيأتي معاني هذه المصطلحات في موضعها إن شاء الله تعالى.

(٣) البدائع ٣٧٨/٧، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٢/٤، مختصر المزني ٢٦٢، المغني ٥١٥/٩.

المذهب الأول: يري أصحابه أنهم لا يتحملون شيئاً من الدية مع العصبية. إلي هذا ذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية (١).

المذهب الثاني: يري أصحابه أنهم يتحملون في الدية، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب (٢).

الأدلة:

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعقول:

أما السنة فمنها:

١. ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنيها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله، كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله ﷺ: "إنما هذا من إخوان الكهان" من أجل سجعه الذي سجع (٣).

وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه في هذه القصة قال: ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيتها وأن العقل على عصبتها (٤).

وفي رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منهما زوج وولد. قال: فجعل رسول الله ﷺ دية المقتولة على عاقلة القاتلة، وبرأ زوجها

(١) مختصر المزني ٢٦٢، الحاوي الكبير للماوردي ٣٤٤/١٢، المغني مع الشرح الكبير ٥١٥/٩، الإنصاف للمرداوي ١١٥.

(٢) الهداية للمريغني ١٧١٣/٤، تكملة فتح القدير، نتائج الأفكار، لفاضي زادة ٣٩٩/١٠، البناية للعيبي ٤٦٢/١٢، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٢/٤، المغني ٥١٦/٩، الإنصاف للمرداوي ١١٥/١٠.

(٣) سبق بيان موضعه في الصحيحين.

(٤) سنن أبي داود ٦٠٢/٢، سنن النسائي ٤٧/٨ (٤٨١٧).

وولدها. قال: فقال عاقلة المقتولة: ميراثها لنا ؟ قال: فقال رسول الله ﷺ " لا، ميراثها لزوجها وولدها" (١).

٢- وما روي عن النبي ﷺ أنه قال: "...ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود عن والده..." (٢).

٣. وما رواه الأئمة: أحمد والحاكم وصححه، وابن حبان والدارمي عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو رسول الله ﷺ فسلم عليه أبي وجلسنا ساعة فتحدثنا. فقال رسول الله ﷺ لأبي: ابنك هذا قال: أي ورب الكعبة. قال: حقا ؟ قال: أشهد به فتبسم رسول الله ﷺ ضاحكا من ثبت شبهني بأبي و من حلف أبي على ذلك. قال: ثم قال: أما إن ابنك هذا لا يجني عليك و لا تجني عليه " قال: و قرأ رسول الله ﷺ: " أَلَا تَرَى وَازِرَةً وَرَزَّ أُخْرَى " إلى قوله تعالى: " هَذَا نَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُولَى " (٣).

٤. ما رواه النسائي عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، ولا يؤخذ الرجل بجريرة أبيه ولا بجريرة أخيه " (٤).

وجه الدلالة من هذه الأحاديث واضح ؛ حيث إن النبي ﷺ نص فيها علي أن الولد لا يعقل عن والده ولا الوالد عن ولده، فوجب إعمالها.

وأما الأثر: فما روي عن إبراهيم أن الزبير وعليًا اختصما في موالي صفية إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال علي: مولى عمتي وأنا أعقل عنه. وقال الزبير: مولى أُمِّي وأنا أرثه فقضى بالميراث للزبير والعقل على علي.

(١) سنن أبي داود ٦٠١/٢ (٤٥٧٥).

(٢) جزء من حديث رواه الأئمة: أحمد في مسنده ٤٩٨/٣ (١٦١٠٨). والترمذي في صحيحه ٤٦١/٤ (٢١٥٩) واللفظ له، وابن ماجه في سننه ٨٩٠/٢ (٢٦٦٩). عن سليمان ابن عمرو بن الأحوص عن أبيه ﷺ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول في حجة الوداع للناس: " أي يوم هذا ؟ قالوا: يوم الحج الأكبر. قال: " فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا. ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده، ولا مولود عن والده، ألا وإن الشيطان قد أيس من أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فيسري به ". قال الترمذي: " هذا حديث حسن صحيح ".

(٣) سبق تخريجه.

(٤) سنن النسائي كتاب تحريم الدم باب تحريم القتل ١٢٧/٧ (٤١٢٨).

وفي رواية عن الحكم بن عتبة قال: اختصم علي والزبير إلى عمر في موالي صفية فقال علي: عمتي وأنا أعقل عنها وأرثها. وقال الزبير: أُمِّي وأنا أرثها. فقال عمر لعلي: أما علمت أن رسول الله ﷺ جعل الولاء تبعاً للميراث؟ فقضى به للزبير^(١).

قال الماوردي بعد أن روي هذا الأثر: " وهو إجماع " ^(٢).

وأما المعقول فمن وجوه:

أحدها: أن كل من لا يحمل العقل مع وجود أهل الديوان، لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه^(٣).

والثاني: أن كل من لزمه تحمل النفقة عنه في ماله، لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج^(٤).

والثالث: أن مال ولده ووالده كماله؛ ولهذا لم تقبل شهادتهما له ولا شهادته لهما، ووجب على كل واحد منهما الإنفاق على الآخر إذا كان محتاجاً والآخر موسراً، وعق عليه إذا ملكه؛ فلا تجب في ماله دية كما لم يجب في مال القاتل^(٥).

أدلة المذهب الثاني:

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والمعقول:

أما السنة: فما رواه أبو داود وابن ماجه والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: " قضى رسول الله ﷺ أن يعقل المرأة عصبته من كانوا. ولا يرثوا منها شيئاً، إلا ما فضل عن ورثتها. وإن قتلت فعقلها بين ورثتها. فهم يقتلون قاتلها " ^(٦).

(١) رواه سعيد بن منصور في سننه ٩٤/١ (٢٧٣)، والبيهقي في سننه ١٠٧/٨ (١٦١٥٤)، وابن أبي شيبة في مصنفه ٤١٩/٥ (٢٧٥٨٠).

(٢) الحاوي الكبير ٣٤٤/١٢.

(٣) المرجع السابق ٣٤٤/١٢.

(٤) المرجع نفسه ٣٤٤/١٢.

(٥) المغني ٥١٦/٩، ٥١٧.

(٦) سنن أبي داود ٥٩٨/٢ (٤٥٦٤)، سنن ابن ماجه ٨٨٤/٢ (٢٦٤٧)، السنن الكبرى للبيهقي ٥٨/٨ (١٥٨٤٤)، حديثهما عن رتبة الحسن.

فهذا الحديث واضح الدلالة علي أن الوالدين من الآباء والمولودين من الأبناء، من العصابات الذين يعقلون عن القاتل.

ويناقش هذا الاستدلال: بأن هذا الحديث حسن، والأحاديث الأول والثاني والثالث من أحاديث المذهب الأول صحيحة، والحسن لا يقوي علي معارضة الصحيح . كما هو معروف . وعليه فإن أحاديث المذهب الأول تقدم عليه ويجب العمل بها.

وأما المعقول فمن وجهين:

أحدها: أنهم عصابة فأشبهوا الإخوة، بل هم أولي؛ لأن تعصبيهم أقوى، ولأن النصرة لهم ألزم، فكانوا أحق بالتغريم^(١).

والثاني: أن العصابة في تحمل العقل كهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، وآباء الإنسان وأبناؤه أحق العصابات بميراثه فكانوا أحقهم بتحمل عقله^(٢).

ونوقش هذا القياس: بأنه منتقض بالصبيان والنساء والمجانين؛ فإنهم لا يتحملون من الدية ولو كانوا وارثين للقاتل باتفاق الفقهاء . كما سيأتي . والنصرة لا يصح أن تجعل علة لتحمل الوالدين والمولودين من الدية عن القاتل؛ إذ هي موجودة بين الزوجين وبعضهما وبين الحيران وبعضهم، ومع ذلك ليس الزوج ولا الجار ممن يتحملون منها^(٣).

الترجيح:

بعد هذا العرض لمذهبي الفقهاء في هذه المسألة وأدلتهم وما ورد عليها من مناقشات، أري ترجيح المذهب الأول القائل بأن الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا ليسوا من العاقلة، ولا يتحملون من الدية شيئاً؛ وذلك لقوة أدلتهم وصحتها وسلامتها من المعارضة الراجحة، والمناقشة المفنفة، وضعف أدلة المخالفين؛ فإن أحاديث المذهب الأول صحيحة وعامة في القتل العمد وشبه العمد والخطأ ولا مخصص لها، كما أن أدلتهم العقلية أيضاً أدلة وجيهة ومنطقية. بينما حديث المذهب الثاني لم يرق عن درجة الحسن، فلا يمكن تقديمه علي الأحاديث الصحيحة الواردة فيما ورد فيه،

(١) الحاوي ٣٤٤/١٢، المغني ٥١٦/٩.

(٢) المرجعان والموضعان السابقان.

(٣) الحاوي الكبير للماوردي ٣٤٤/١٢.

وأيضاً فإن حجتهم العقلية ضعيفة ومردود عليها. ولهذا كان الواجب العمل بالمذهب الأول. والله تعالى أعلم.

-أهل القتال من الرجال الأحرار البالغين

أهل الديوان هم المقاتلة من الرجال الأحرار البالغين العاقلين^(١).

ويلحق بهم في عصرنا الحالي: أصحاب الحرف والوظائف والنقابات المتطابقة. وقد اختلف الفقهاء في تحمل هؤلاء الدية عن القتل إذا كان القاتل واحداً منهم، وفي تقديمهم على العصابة والعكس إلي مذهبين:

المذهب الأول: يرى أصحابه أن الذي يعقل عن القاتل هم عصبته لا أهل ديوانه. فإن لم يكن له عصابة نسبية ولا سببية، أو كانت عصبته فقيرة، أو لم تطق تحمل الدية كلها ففضل عنها شئ من الواجب، وجب الباقي في بيت المال، إن كان الجاني مسلماً، فإن كان مستأثماً أو ذمياً، فلا يتحمل عنه بيت المال، وإنما تجب الدية في ماله على المذهب. إلي هذا ذهب الشافعية والحنابلة^(٢).

المذهب الثاني: يرى أصحابه أن الذي يعقل عن القاتل إن كان من أهل القتال من الرجال هم أصحابه وأهل حرفته، فتؤخذ من أعطياتهم. ولا تؤخذ من العصابة إلا إذا لم يكن ديوان أو كان ولم يكن القاتل من أهله. وروي هذا عن عمر بن عبد العزيز والحسن والزهرى والنخعي، وإليه ذهب الحنفية والمالكية^(٣).

الأدلة

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والأثر والمعقول:

(١) البدائع ٣٧٨/٧.

(٢) المختصر ص ٢٦٢. الحاوي الكبير للماوردي ٣٤٦/١٢، الوسيط في المذهب للغزالي ٣٦٩/٦، المغني ٥١٨/٩.

(٣) المصنف لابن أبي شيبه ٣٩٨/٢، ٣٩٦/٥ (١٣٦٨)، ٢٧٣٢٣، ٢٧٣٢٤، المصنف لعبد الرزاق ٤١١/٩ (١٧٨٢٥)،

بدائع الصنائع للكاساني ٣٧٨/٧، الهداية للمرغيناني ١٧١/٤، نتائج الأفكار لقاضي زادة ٣٩٥/١٠، البناية

للعيني ٤٥٤/١٢.

أما السنة: فيما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاخصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنيها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم^(١).

وجه الدلالة من هذا الحديث واضح الدلالة؛ حيث إن النبي ﷺ قضى فيه بدية القتيلة علي عاقلة القاتلة، ولم يكن علي عهده ديوان^(٢).

وأما الآثار: فما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قضى بالدية علي العاقلة، ولم يكن في عهده ديوان.

وكذلك قضى عمر رضي الله عنه بالدية علي العاقلة في صدر من أيامه إلي أن أحدث الديوان في آخر أيامه لتمييز القبائل وترتيب الناس في العطاء^(٣).

قالوا: فلم يجز العدول به عما كان في أيام رسول الله ﷺ إلي غيره من أمر حدث بعده؛ لأنه يكون نسخا، والنسخ مرتفع بعد موت الرسول ﷺ^(٤).

وأما المعقول فمن وجوه:

أحدها: أن كل حكم تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان، تعلق به مع وجود الديوان، كالميراث وولاية النكاح.

ثانيها: أنها جناية يتحمل عقلها، فوجب أن يختص بها العصابات، كالذي لا ديوان له^(٥).

ثالثها: أن كل سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل، كالجوار^(٦).

(١) سبق تخريجه.

(٢) مختصر المزني ص ٢٦٢، الحاوي الكبير ١٢/٣٤٦، ٣٤٧، المغني ٩/٥١٨.

(٣) مختصر المزني ص ٢٦٢، الحاوي الكبير ١٢/٣٤٦، ٣٤٧.

(٤) الحاوي ١٢/٣٤٧.

(٥) المرجع السابق ١٢/٣٤٧.

(٦) الحاوي ١٢/٣٤٧، المغني ٩/٥١٨.

رابعها: أن عدم العقل في مقابلة غنم الميراث؛ ليكون غانما وغارما، ولا يجتمع هذا إلا في العصبات؛ ولذلك انتقل عنهم العقل إذا عدموا إلي بيت المال؛ لانتقال ميراثه إليه. ولا يعقل بيت المال عن الكافر؛ لأن ماله يصير إليه فيئاً لا ميراثاً^(١).

أدلة المذهب الثاني:

واستدل أصحاب المذهب الثاني بإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك؛ فإنه روي عن إبراهيم النخعي . ' - أنه قال: كانت الديات على القبائل فلما وضع سيدنا عمر رضي الله عنه الدواوين جعلها على أهل الدواوين.

وفي رواية: " أول من فرض العطاء عمر بن الخطاب، وفرض فيه الدية كاملة " ^(٢).

ونوقش هذا: بأن قضاء النبي ﷺ بالدية علي العاقلة أولى من قضاء عمر رضي الله عنه. على أنه إن صح ما ذكر عن عمر رضي الله عنه فإنه يحتمل أن أهل الديوان كانوا هم عشيرة القاتل ^(٣).

وأجيب عن هذه المناقشة: بأنه لو كان سيدنا عمر رضي الله عنه فعل ذلك وحده، لكان يجب حمل فعله على وجه لا يخالف فعل رسول الله ﷺ. لكنه فعله بمحضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولا يظن من عموم الصحابة رضي الله عنهم مخالفة فعله عليه الصلاة والسلام، فدل علي أنهم فهموا أنه كان معلولاً بالنصرة، وإذا صارت النصرة في زمانهم الديوان نقلوا العقل إلى الديوان، فلا تتحقق المخالفة؛ وهذا لأن التحمل من العاقلة للتناصر، وقبل وضع الديوان كان التناصر بالقبيلة، وبعد الوضع صار التناصر بالديوان، فصار عاقلة الرجل أهل ديوانه ^(٤).

والواقع أن كلا المذهبين يمكن العمل به، تبعا لنقلب الظروف وتطور الأحداث، ففي البيئات التي تعيش علي النظام القبلي ويكون التناصر فيها بين أبناء القبيلة موجودا، يعمل بالرأي الأول، حتى ولو كان القاتل من أهل الديوان، أو من الموظفين أو المهنيين الذين تجمعهم نقابة معينة، وفي

(١) الحاوي ٣٤٧/١٢.

(٢) الموطأ للإمام مالك ٣/٣١ (٦٧٨) تحقيق: د. تقي الدين الندوي ط ١ دار القلم - دمشق. سنة ١٤١٣ هـ - ١٩٩١ م.

نصب الراية للزليعي ٣٩٢/٤، البدائع للكاساني ٣٧٨/٧.

(٣) المغني ٥١٨/٩.

(٤) البدائع ٣٧٨/٧.

هذه الحالة لا مانع من أن يتحمل أهل الديوان أو النقابة جزءا من الدية علي سبيل التعاون مع العصبة علي البر والتقوى.

أما في البيئات التي ينعدم أو يقل التناصر فيها بين أبناء القبيلة الواحدة فأهل الديوان أو النقابة التي ينتمي إليها القاتل هي الأولى بالعقل عنه خاصة إذا كان النظام الوظيفي قائما علي ضرورة استقطاع جزء من راتب العامل، أو كانت النقابة تلزم المنتمين إليها بدفع أقساط شهرية أو سنوية للإنفاق منها في مثل هذا الغرض. والله تعالى أعلم.

-حكم تحمل بيت مال المسلمين

بيت مال المسلمين هو المكان المخصص لأن تودع فيه الموارد المالية للدولة الإسلامية، حتى تتفق في مصارفها الشرعية. وهو المسمي في هذه الأيام بـ " الخزانة العامة للدولة "

وقد اختلف الفقهاء في تحمله الدية عن القاتل إلي مذهبين:

المذهب الأول: يري أصحابه أنه يتحملها عنه إذا لم يكن له عاقلة، أو كان ولكن عجزوا عن تحملها وحدهم. روي هذا عن الزهري وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة في ظاهر الرواية والمالكية والشافعية والحنابلة في المذهب (١).

المذهب الثاني: يري أصحابه أنه لا يجب علي بيت المال أن يعقل عنه. وإلي هذا ذهب الإمامان: أبو حنيفة في رواية وأحمد في رواية (٢).

(١) وفي هذه الحالة هل تؤدي من بيت المال دفعة واحدة أو في ثلاث سنين ؟ رأيان لأصحاب هذا المذهب، أصحابهما: أنها تؤدي دفعة واحدة : لأن النبي ﷺ أدى دية الأنصاري دفعة واحدة. وكذلك فعل عمر رضي الله عنه. ولأن الدية بدل متلف لا تؤديه العاقلة في هذه الحالة، فيجب كله في الحال، كسائر بدل المتلفات، وإنما أجل على العاقلة تخفيفا عنهم ولا حاجة إلى ذلك في بيت المال ولهذا يؤدي الجميع. (البدائع ٣٧٩/٧، مختصر خليل ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٣٤٨/٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٢/٤، ٢٨٣، الأم للإمام الشافعي ١٥١/٦، مختصر المزني ص ٢٦٣، الحاوي ٣٦٧/١٢، المغني ٥٢٥/٩، المقنع والإتصاف ١١٩/١٠، المحرر لابن تيمية ١٤٨ / ٢).

(٢) وقد اختلف أصحاب هذا المذهب فيمن تجب عليه الدية في هذه الحالة:

فذهب الشافعي في قول والحنابلة في المذهب إلي أنها في هذه الحالة لا تجب على أحد لا القاتل ولا غيره : لأن الدية لزمت العاقلة ابتداء؛ بدليل أنه لا يطالب بها غيرهم، ولا يعتبر تحملهم ولا رضاهم بها، ولا تجب على غير من وجبت عليه، كما لو عدم القاتل فإن الدية لا تجب على أحد كذا ههنا. فعلى هذا إن وجد بعض العاقلة حملوا بقسطهم وسقط الباقي فلا يجب على أحد

الأدلة

استدل أصحاب المذهب الأول بالسنة والأثر والمعقول:

أما السنة: فما روي أن النبي ﷺ ودي سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه بمائة من إبل الصدقة (١).

فهذا الحديث دليل علي أن بيت المال يعقل عن القاتل إذ إن النبي ﷺ قد ودي هذا الصحابي الجليل منه.

وقد نوقش الاستدلال بهذا الحديث: بأنه غير صحيح ؛ لأن الذين قتلوا الصحابي الجليل سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه هم اليهود، وبيت المال لا يعقل عن الكفار بحال وإنما النبي ﷺ تقضل عليهم (٢).

ثم إن هذا الحديث قد ورد في رواية أخرى بلفظ: " فوداه من عنده ". قال الإمام النووي: " وقوله (فوداه من عنده) يحتمل أن يكون من خالص ماله... ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين " (٣).

وأما الأثر: فما روي أن رجلا قتل في زحام في زمن عمر فلم يعرف قاتله. فقال علي لعمر: " يا أمير المؤمنين لا يطل دم امرئ مسلم ". فأدى ديته من بيت المال.

وذهب الشافعي في القول الثاني وأحمد في رواية إلي أنها في هذه الحالة تجب على القاتل ؛ لعموم قوله: ﴿ ودية مسلمة إلى أهله ﴾، ولأنها في الأصل واجبة علي الجاني : جبرا للمحل الذي قوته، وإنما سقطت عن القاتل لقيام العاقلة مقامه في جبر المحل. فإذا لم يؤخذ ذلك بقي واجبا عليه بمقتضى الدليل. ولأنه لو لم يتحمل القاتل الدية في هذه الحالة لأهدردم المقتول، وإهداردم المقتول مخالفة جسيمة للكتاب والسنة وقياس أصول الشريعة. ثم إن هناك نظائر لتحمل القاتل دية قتله خطأ ومن ذلك: المرتد ؛ فإنه لما لم يكن له عاقلة وجبت الدية في ماله. والذمي الذي لا عاقلة له، تلزمه كذلك الدية في ماله. ومن رمى سهما ثم أسلم، أو كان مسلما فارتد، أو كان عليه الولاء لموالي أمه فانجر إلى موالي أبيه، ثم أصاب بسهم إنسانا فقتله، تلزمه الدية في ماله أيضا ؛ لتعذر حمل عاقلته عقله. وإذا ثبت ذلك فكذلك ههنا. (البدائع ٣٧٩/٧، المغني ٥١٨/٩، ٥٢٦، ٥٢٧، الإنصاف للمرداوي ١٠/١٢٠، ١٢١، منار السبيل لابن ضويان ٢٤٣/٢).

(١) وقد سبق نص الحديث وتخريجه.

(٢) المغني لابن قدامة ٥١٨/٩.

(٣) شرح صحيح مسلم للنووي ١٤٨/١١ ط ٢ دار إحياء التراث العربي - بيروت. سنة ١٣٩٢ هـ.

وفي هذا أيضا دليل واضح علي أن بيت المال يعقل عن القاتل؛ حتى لا يهدر دم في الإسلام.

وأما المعقول فمن وجهين:

أحدهما: أن المسلمين يرثون من لا وارث له فيعقلون عنه عند عدم عاقلته؛ لما يجمعهم من ولاية الدين، كما يعقل عنه مواليه لما يجمعهم من ولاية الولاء^(١).

ونوقش هذا: بأنه غير صحيح؛ لأن صرف مال من لا وارث له إلي بيت المال ليس علي أنه ميراث، بل علي أنه فيء؛ ولهذا يؤخذ مال من لا وارث له من أهل الذمة إلي بيت المال، ولا يرثه المسلمون. هذا من ناحية.

ومن ناحية أخرى: فإنه لا تلازم بين الميراث وتحمل العقل؛ فإن العقل لا يجب على الوارث إذا لم يكن عسبة، ويجب على العسبة وإن لم يكن وارثاً^(٢).

والثاني: أن الوجوب على العاقلة لمكان التناصر، فإذا لم يكن له عاقلة، كان استتصاره بعامة المسلمين، وبيت المال ما لهم فكان ذلك عاقلته^(٣).

استدل أصحاب المذهب الثاني بالمعقول من وجوه:

أحدها: أن الأصل هو الوجوب في مال القاتل لأن الجناية وجدت منه وإنما الأخذ من العاقلة بطريق التحمل فإذا لم يكن له عاقلة يرد الأمر فيه إلى حكم الأصل^(٤).

والثاني: أن بيت المال فيه حق للنساء والصبيان والمجانين والفقراء، ولا عقل عليهم، فلا يجوز صرفه فيما لا يجب عليهم.

والثالث: أن العقل على العصابات وليس بيت المال عسبة، ولا هو كعسبة، فلا يتحمل عن القاتل.

(١) مختصر المزني ص، الحاوي الكبير ٣٦٧/١٢، المغني مع الشرح الكبير ٥٢٥/٩.

(٢) المغني ٥١٨/٩.

(٣) البدائع ٣٧٩/٧.

(٤) المرجع السابق.

المذهب المختار: بعد هذا العرض لكلا المذهبين وأدلتهما وما ورد عليها من مناقشات، أرى أن كلا المذهبين يمكن العمل به ؛ فالمذهب الأول يعمل به إذا كان القاتل مُقتلاً ولا يملك من المال ما يؤدي منه الدية الواجبة، والمذهب الثاني يعمل به إذا كان مُكثراً ولا تحجب الدية بماله ؛ وذلك لأن لكل مذهب منهما أدلة قوية ومنطقية، وهي وإن كان قد ورد علي بعضها ملاحظات، فقد سلم بعضها الآخر، والمعروف أن " إعمال الكلام أولي من إهماله ". والله تعالى أعلم.

الدرس السادس

شروط العاقلة وكيفية تحملها الدية

يشترط في العاقلة التي تتحمل الدية عدة شروط هي: الحرية، والذكورة، والتكليف، والموافقة في الدين، واليسار.

فلا تضرب علي العبيد ولا النساء ولا الخنثى^(١)، ولا الصبيان ولا المجانين ولا المخالفين في الدين، ولا الفقراء.

وأدلة ذلك ما يأتي:

أولاً: أنها مختصة بأهل النصرة من العصابات، وهؤلاء ليسوا من أهل النصرة^(٢).

ثانياً: أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف . كما سبق وعرفنا . وذلك مختص بالرجال الأحرار العقلاء الموافقين في الدين دون غيرهم من النساء والصبيان والمخالفين في الدين^(٣).

ثالثاً: أن هذا الضمان صلة وتبرع بالإعانة، والصبيان والمجانين والمماليك والمخالفين في الدين ليسوا من أهل التبرع^(٤).

وأما عدم ضربها علي الفقير فعلي رأي عامة الفقهاء^(٥) ؛ لأن تحمل العقل مواساة، فلا يلزم الفقير؛ كنفقات الأقارب والزكاة^(٦).

(١) الخنثى المشكل هو الملتبس أمره ؛ أي من له فرج المرأة وذكر الرجل. ويلحق به من عُري عن الألتين جميعاً. (تبيين

الحقائق للزليعي ٢١٤/٦ ، الشرح الكبير للدردير ٤٨٩/٤).

(٢) البدائع ٣٧٨/٧ ، الحاوي ٣٤٧/١٢ ، المغني ٥٢٤/٩.

(٣) الحاوي ٣٤٧/١٢ ، المغني ٥٢٤/٩.

(٤) البدائع ٣٧٨/٧.

(٥) بل لقد حكى ابن المنذر الإجماع علي ذلك فقال: "وأجمعوا علي أن الفقير لا يلزمه من ذلك شيء". (الإجماع لابن

المنذر ص ١٤١). وانظر: الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٤/٤ ، مختصر المزني ص ٢٦٢ ، الحاوي الكبير

٣٥١/١٢ ، مختصر خليل ومواهب الجليل والتاج والإكليل ٣٤٩/٨ ، المغني ٥٢٤/٩ ، المقنع والإنصاف

١١٦/١٠.

(٦) الحاوي الكبير ٣٥١/١٢ ، المغني ٥٢٤/٩.

ولأنها وجبت على العاقلة؛ تخفيفاً عن القاتل، فلا يجوز التثقيل بها على من لا جناية منه، وفي إيجابها على الفقير تثقيل عليه وتكليف له بما لا يقدر عليه^(١).

وبعبارة أخرى: أن المقصود بها إزالة الضرر عن القاتل، فلم يجز أن يدخل بها الضرر على غير القاتل؛ إذ المعروف أن "الضرر لا يزال بالضرر" ^(٢).

وما الحكم لو توافرت شروط التحمل عند الحلول بعد أن كانت مفتقدة؟ هل يدخلون في العاقلة؟

لو توافرت شروط التحمل عند الحلول بعد أن كانت مفتقدة، كما لو أيسر الفقير أو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو أسلم الكافر أو اتضحت ذكورة الخنثى المشكل عند الحلول، ففي دخول من توافرت فيه في العاقلة رأيان:

أحدهما: نعم يدخلون في العاقلة؛ لأن الشروط قد توافرت فيه وقت الوجوب وهو من أهله. وهذا الرأي قال به الشافعية والحنابلة^(٣).

والثاني: لا يدخلون فيها؛ لأنهم لم يكونوا من أهل الوجوب حالة السبب، فلم يثبت الحكم عليهم حالة الشرط، كالكافر إذا ملك مائلاً ثم أسلم عند الحول، لم تلزمه الزكاة فيه. وهذا الرأي قال به المالكية وابن قدامة في احتمال له^(٤).

-حكم اشتراك الحاضر والغائب من العاقلة في تحمل الدية

إذا ثبت هذا، فإنه يشترك في تحمل الدية الحاضر والغائب من العاقلة. وبهذا قال الحنفية والشافعية في قول والحنابلة؛ لأن النبي ﷺ قضى بدية القتيلة على عاقلة القاتلة، ولم يفرق بين حاضر وغائب^(٥).

ولأنهم استوتوا في التعصيب والإرث؛ فاستوتوا في تحمل العقل كالحاضرين.

(١) المغني ٥٢٤/٩.

(٢) الحاوي الكبير ٣٥١/١٢.

(٣) الحاوي ٣٥١/١٢، المغني ٤٢٣/٩.

(٤) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٥/٤، مواهب الجليل والتاج والإكليل ٣٤٩/٨، المغني ٤٢٣/٦.

(٥) الهداية ١٧١٦/٤، الحاوي ٣٤٤/١٢، المغني ٥١٩/٩.

ولأنه معنى يتعلق بالتعصيب فاستوى فيه الحاضر والغائب كالميراث والولاية في النكاح ^(١).

هذا بينما ذهب المالكية والشافعي في قوله الثاني إلى أن الغائب من العاقلة لا يتحمل شيئاً من الدية وإنما يتحملها الحاضر فقط ؛ لأن التحمل بالنصرة وإنما هي بين الحاضرين ^(٢).

لكن هذا رأي ضعيف مردود بعموم الحديث الشريف الذي لم يفرق في تحميله الدية علي العاقلة بين حاضر وغائب. وبأن النصرة ليست مرتبطة بحضور القريب أو بغيابه، خاصة في هذه الأيام التي تيسرت فيها سبل المواصلات والاتصالات بالشكل الذي جعل العالم كله وكأنه يعيش في قرية واحدة.

وعليه فالراجح هو الرأي الأول. والله تعالى أعلم.

-حكم اشتراك القاتل مع العاقلة في تحمل الدية

ذهب الشافعية إلى أن القاتل لا يلزمه شيء من الدية ^(٣). واستدلوا علي ذلك بالسنة والمعقول:

أما السنة: فما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اقتتل امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله ﷺ فقضى رسول الله ﷺ أن دية جنيها غرة: عبد أو وليدة. وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وورثها ولدها ومن معهم ^(٤).

وجه الدلالة من هذا الحديث واضح ؛ لأن الظاهر منه أن النبي ﷺ قضى بجميع الدية عليهم، ولم يحمل القاتلة شيئاً منها ^(٥).

كما استدلو بالمعقول أيضاً من وجوه:

(١) المغني ٥١٩/٩.

(٢) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨٤/٤، المغني ٥١٩/٩.

(٣) مواهب الجليل للحطاب ٤٣٦/٨، الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٢٨١/٤، ٢٨٢، الحاوي الكبير للماوردي

٣٤٥/١٢، المغني والشرح الكبير ٤٩٨/٩، المقنع والإنصاف ١٢٠/١٠.

(٤) سبق تخريج هذا الحديث برواياته المتعددة.

(٥) الحاوي ٣٤٥/١٢، المغني والشرح الكبير ٤٩٨/٩.

أحدها: أنه قاتل لم تلزمه الدية فلم يلزمه بعضها، كما لو أمره الإمام بقتل رجل فقتله يعتقد أنه بحق فبان مظلوماً^(١).

والثاني: أنه تلزمه الكفارة في ماله وهي تعدل قسطه من الدية وأكثر. فلا حاجة إلى إيجاب شيء من الدية عليه^(٢).

والثالث: أن العاقلة إنما تحملوا الدية عن القاتل مواساة له، وتحمل المواساة يوجب استيعاب ما وقعت به المواساة، كالنفقة وزكاة الفطر^(٣).

والرابع: أن القاتل يتحمل وحده دية العمد، فلما تقرر بدية العمد، وجب أن تنفرد العاقلة بدية الخطأ؛ لأن الدية مستحقة في جهة واحدة^(٤).

-حكم تقسيم الدية على العاقلة وكيفيته-

ذهب الشافعية ومن وافقهم إلى أنه يبدأ في قسمة الدية بالأقرب فالأقرب فتقسم على الإخوة وبنينهم، والأعمام وبنينهم، ثم أعمام الأب، ثم بنينهم، ثم أعمام الجد، ثم بنينهم كذلك أبداً، حتى إذا انقرض المناسبون فعلى المولى المعتق، ثم على عصابته، ثم على مولى المولى، ثم على عصابته، الأقرب فالأقرب كالميراث سواء. هذا إذا طبقنا المذهب الراجح في استبعاد الأصول والفروع من التحمل في العقل.

أما إذا قلنا بأنهم لا يستبعدون، فإنه يبدأ بهم؛ لأنهم أقرب.

-حكم ما يتحملة كل واحد من العاقلة من الدية-

لقد أجمع أهل العلم على أن العاقلة لا تكلف من المال ما يجحف بها ويشق عليها؛ لأنها إنما تحملت الدية على سبيل المواساة للقاتل والتخفيف عنه، فلا يخفف عن الجاني بما يثقل على غيره ويجحف به كالزكاة.

(١) المغني ٩/٤٨٩.

(٢) المرجع السابق ٩/٤٩٨.

(٣) الحاوي الكبير ١٢/٣٤٥.

(٤) المرجع السابق ١٢/٣٤٥.

ولأنه لو كان الإجحاف مشروعاً لكان الجاني أحق به؛ لأنه موجب جنايته وجزاء فعله. فإذا لم يشرع في حقه ففي حق غيره أولى.

الفهرس

م	الموضوع	م الصفحة
١		١
٢	الأولى: مبادئ النكاح ومقدماته	٢
٣	الزواج في الإسلام	٣
٤	الأول: تعريف النكاح	٥
٥	الثاني: حكم النكاح	١٠
٦	الثالث: حكمة مشروعية النكاح	١٨
٧	الرابع: ما يستحب في النكاح	٢٠
٨	الخامس: نظر مرید النكاح الى المرأة	٣١
٩	السادس: الخطبة، تعريفها ودليل مشروعيتها وحكمها بالنظر إلى حال المرء	٣٨
١٠	السابع: حكم الخطبة على الخطبة	٤٥
١١	الثامن: أمور متعلقة بالخطبة والنكاح	٥١
١٢	التاسع: أركان عقد النكاح وبيان كل ركن وشروطه	٥٩
١٣	الثانية: موانع النكاح والخيار فيه وحقوق الزوجين	٩١
١٤	الأول: المحرمات من النساء	٩٢
١٥	الثاني: الخيار في فسخ النكاح والرد بالعيب	١٠١
١٦	الثالث: حقوق الزوجين	١٠٨
١٧	الثالثة: موقف التشريع الإسلامي من بعض الزيجات المعاصرة	١٣٣
١٨	الأول: الزواج المؤقت	١٣٤

١٣٨	الثاني: زواج التحليل	١٩
١٤٤	الثالث: زواج المتعة	٢٠
١٥٢	الرابع: الزواج العرفي	٢١
١٥٧	الخامس: الزواج السري	٢٢
١٦١	السادس: زواج الميسار	٢٣
١٦٥	الرابعة: أحكام الإيلاء عند الشافعية	٢٤
١٦٧	الأول: تعريف الإيلاء وحكمه	٢٥
١٧٠	الثاني: أركان الإيلاء	٢٦
١٨١	الثالث: آثار الإيلاء	٢٧
١٨٦	الرابع: الاختلاف في الإيلاء	٢٨
١٨٩	الخامسة: أحكام الظهار في الفقه الشافعي	٢٩
١٩٠	الأول: تعريف الظهار لغة واصطلاحاً	٣٠
١٩٢	الثاني: حكم التلفظ بالظهار ودليله	٣١
١٩٤	الثالث: أركان الظهار وشروط كل ركن	٣٢
١٩٩	الرابع: الأثر المترتب على وقوع الظهار من الرجل	٣٣
٢٠٢	الخامس: أنواع الظهار	٣٤
٢٠٤	السادس: كفارة الظهار	٣٥
٢١١	السادسة: أحكام اللعان عند الشافعية	٣٦
٢١٣	الأول: تعريف اللعان	٣٧
٢١٥	الثاني: حكم اللعان	٣٨

٢١٩	الثالث: أركان اللعان وكيفيته	٣٩
٢٢٦	الرابع: الآثار التي تترتب على اللعان	٤٠
٢٣١	السابعة: الدية وما يتعلق بها من أحكام	٤١
٢٣٢	الأول: مفهوم الدية	٤٢
٢٣٣	الثاني: مشروعية الدية	٤٣
٢٣٥	الثالث: كيفية تقدير الدية	٤٤
٢٣٩	الرابع: أقسام الدية عند الشافعية	٤٥
٢٥٧	الخامس: العاقلة التي تتحمل الدية وما يتعلق بها من أحكام	٤٦
٢٦٩	السادس: شروط العاقلة وكيفية تحملها الدية	٤٧
٢٧٨	الموضوعات	٤٨